

جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون

مبادئ القانون التجاري

الأعمال التجارية والتاجر
المحل التجاري والشركات التجارية
تأليف

أد/ حمدي مصطفى

أد/ ذكري خليفة

أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد
ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب
بكلية الشريعة والقانون بتفهما الأشراف دقهلية

أستاذ القانون التجاري والبحري
ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

٢٠٢٥/١٤٤٦هـ/م

مبادئ القانون التجاري المصري

إعداد

د. حمدي محمد مصطفى حسن

وكيل كلية الشريعة والقانون

لشئون التعليم والطلاب

تفهما الأشراف دقهلية

جامعة الأزهر

تصدير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على معلم البشرية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد...

شاءت إرادة الله تعالى أن يجعل التنوع والاختلاف سمة من السمات في البشر والبيئات ،
والانشطة والحاجات ، حتى يحتاج الناس بعضهم بعضاً. وأمرهم بالسعي في جوانب الأرض
لتحصيل أرزاقهم ، وسخر لهم الأسباب المعينة على ذلك ، قال تعالى(هو الذي جعل لكم
الأرض ذُلُولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النُّشُور) (١).

فكان من نتيجة هذا السعي أن عرّف الإنسان التجارة منذ أقدم العصور ، فتبادل الناس
البضائع والمنتجات ، وهو ما دفعهم إلى البحث عن القواعد التي تحكم تصرفاتهم وعقودهم ،
فدرجوا على اتباع أساليب وقواعد أوجدها سلوكهم العملي ، فصارت أعرافاً ملزمة لهم ،
وتنوعت تلك القواعد بما يتناسب مع البيئة التي نشأت فيها ، والتجارة التي تحكمها.

ومع تطور المجتمعات ، ووجود الدولة بسلطانها الثلاث بدأت الحاجة إلى التقنين والتشريع لتوحيد
القواعد التي تحكم التجارة داخل حدود الدولة. فنشأت تلك القواعد في أحضان القانون المدني
الذي يعتبر الشريعة العامة في القانون الخاص ، إلا أن التطور السريع والمتلاحق للحياة التجارية ،
وما يتميز به العمل التجاري من سرعة واثمان ، دفعت إلى استقلالية القواعد التي تحكم التجارة ،
لتصبح قانوناً مستقلاً له صفاته التي تميزه عن غيره من فروع القانون الخاص.

ولا يفهم من هذه الاستقلالية انقطاع الصلة بين القانون التجاري وقواعد القانون المدني ، فلا زالت
قواعد الأخير مصدراً من المصادر التي يلجأ إليها القاضي في المنازعات التجارية ، متى توافرت الأسباب
والشروط. وعلى الرغم أن القانون التجاري كان في بداية نشأته قانوناً طائفيّاً يحكم طائفة معينة فقط
من الناس ، وهم طائفة التجار ، إلا أن تطورات الحياة الاقتصادية والتجارية قد أسهمت في تغيير تلك
النظرة للقانون التجاري ، بحيث أصبح يحكم فئة معينة من الأعمال ، هي الأعمال التجارية ، بصرف
النظر عن شخص القائم بها ، هذا بالإضافة إلى طائفة التجار الذين تخضع تصرفاتهم المتعلقة بأعمالهم
، وما يجب عليهم من التزامات لأحكام هذا القانون.

منهج الكتابة والخطة

لما كانت دراسة القانون التجاري من الأهمية بمكان بالنسبة لدارس القانون عموماً ، ولطلاب كليات الشريعة والقانون خصوصاً ، فإنه ليشرفني أن أضع بين يدي طلابي هذا المؤلف في مبادئ القانون التجاري ، مراعيًا فيه المساحة الزمنية المخصصة لتدريس هذه المادة ، مع شموليته لكل الموضوعات المحددة في التوصيف المعد من قبل الكلية لهذه المادة.

وبعد أن استعنت بالله تعالى في وضع هذا الموجز في مبادئ القانون التجاري ، فقد راعيت فيه الاختصار غير المخل ، ليسهل على الطالب الدراسة والتحصيل ، دون الدخول في دقائق تفصيلات الخلاف الفقهي؛ حيث لا حاجة لطالب هذه المرحلة بهذه التفصيلات الشديدة. كما حرصت على أن تكون معالجة موضوعات الدراسة قاصرة على قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، دون مقارنته بأي نظام قانوني آخر ، لكن قد يوجب المقام -أحياناً- التنبيه على بعض الاختلافات بين قانون التجارة المصري وقانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣ لما بين القانونين من ارتباط باعتبار أن القانون التجاري المصري القديم هو المصدر التاريخي لقانون المعاملات التجارية الاتحادي.

وقد راعيت -قدر الاستطاعة- أن يكون الأسلوب سهلاً ، والعبارة بسيطة والعرض موجزاً ، وواضحاً ، دون الإخلال بالمادة العلمية والقدر الواجب على الطالب تحصيله. فإن وفقت فالفضل الله وحده ، وإن كان من نقص ، فأستغفر الله منه ، وهو ليس مني عن قصد ، والنقصان هي سمة العمل البشري ، وسبحان من له الكمال.

الخطة الدراسية

جاءت الخطة الدراسية لهذا المؤلف مشتملة على ثلاثة أبواب ، كل باب منها مقسم إلى عدد من الفصول ، ويسبق الأبواب الثلاثة تمهيد في التعريف بالقانون التجاري ، فجاءت الخطة على التفصيل التالي:-

تمهيد في: التعريف بالقانون التجاري ، وقد عاجلت فيه النقاط الآتية:-

أولاً المقصود بقانون المعاملات التجارية

ثانياً أسباب استقلال قانون المعاملات التجارية.

ثالثاً مراحل تطور قانون المعاملات التجارية.

رابعاً مصادر قانون المعاملات التجارية.

خامساً نطاق قانون المعاملات التجارية وموقف المشرع المصري.

الباب الأول نظرية الأعمال التجارية في قانون المعاملات التجارية

الفصل الأول: ضوابط التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني والنتائج المترتبة على ذلك.

الفصل الثاني: الأعمال التجارية بطبيعتها.

الفصل الثالث: الأعمال التجارية بالتبعية.

الفصل الرابع: الأعمال التجارية المختلطة.

الباب الثاني: أحكام التاجر الفرد

الفصل الأول: شروط اكتساب وصف التاجر.

الفصل الثاني: الالتزامات المهنية لطائفة التجار.

الباب الثالث: المحل التجاري

الفصل الأول: ذاتية المحل التجاري.

الفصل الثاني: حماية المحل التجاري من أعمال المنافسة غير المشروعة.

الفصل الثالث: أهم التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري.

تمهيد

التعريف بالقانون التجاري

أولاً المقصود بقانون المعاملات التجارية

عرف الفقه القانوني () ، القانون التجاري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يحكم فئة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية ، بصرف النظر عن شخص القائم بها ، كما أنه يطبق على طائفة معينة من المجتمع هم التجار .

ويعكس هذا التعريف مراحل تطور هذا القانون ، حيث إنه عند نشأته كان قانوناً طائفيّاً لا يطبق إلا على فئة التجار فقط دون غيرهم ، غير أن هذه النظرة الشخصية للقانون التجاري سرعان ما زالت بعد تطور حركة التشريع التي أعقبت الثورة الفرنسية () ، ليصبح القانون التجاري قانوناً يطبق على كل عمل تجاري ، بصرف النظر عن شخص القائم به ، سواء كان تاجراً أو

غير تاجر ، هذا بالإضافة إلى تطبيقه على أشخاص التجار في كل ما يصدر عنهم من أعمال تتعلق بتجارهم.

ويتفق هذا التعريف مع نظرة المشرع التجاري ، حيث حدد نطاق تطبيق القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المادة الأولى منه بالنص على أن(تسري أحكام هذا القانون على التجار ، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر).

ثانياً أسباب استقلال القانون التجاري

لما كان القانون التجاري هو أحد فروع القانون الخاص ، فهو وثيق الصلة بالقانون المدني ، باعتبار أن الأخير هو القاعدة العامة في القانون الخاص بمختلف فروعه ، غير أن هذه الصلة الوثيقة لا تعني توحيد القواعد القانونية التي تطبق على المعاملات التجارية والمعاملات المدنية ، فقواعد القانون التجاري تتمتع بخصائص وصفات تميزها عن قواعد القانون المدني ، الأمر الذي يستوجب معه استقلالية القواعد التي تحكم المعاملات التجارية عن القواعد التي تحكم المعاملات المدنية. ونجمل الأسباب التي أدت إلى استقلالية القانون التجاري في الآتي:-

١- السرعة

تختلف طبيعة الحياة المدنية بتعاملاتها عن الحياة التجارية ، فالتعاملات المدنية بطيئة لا تتسم بالسرعة ، نتيجة أن الشخص في تعاملاته المدنية يحتاج إلى وقت كبير للتفكير والتروي بسبب الافتقار إلى الخبرة ، وهذا أمر منطقي. فالشخص في الحياة المدنية لا يبرم العقود إلا على فترات متباعدة ، فهو لن يشتري مثلاً سيارة ، أو منزلاً ، أو أرضاً زراعية في كل يوم.

وعلى العكس من ذلك التعاملات التجارية التي توجب على التاجر أن يبرم في نهاره وليله العديد من العقود ، بالإضافة إلى قيامه بالعديد من الأعمال التجارية المتلاحقة والمختلفة ، وقد يترتب على تأخيرها في تنفيذ بعض صفقاته التجارية -نتيجة التمسك ببعض الشكليات القانونية- فوات ربح كبير عليه ، أو تحمله ببعض الالتزامات المالية ، لذا استوجبت قواعد القانون التجاري السرعة في إبرام العقود والتصرفات ، وهو ما يبرر مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية^(١)، ووجوب تنفيذ الأحكام التجارية تنفيذاً عاجلاً ، وحظر منح المدين مهلة للوفاء بالديون التجارية^(٢).

٢- الائتمان

لا يكفي توافر عامل السرعة بمفرده لإبرام التصرفات التجارية ولإيجاد جو تجاري آمن وسليم ، فالبيئة التجارية تحتاج -بجانب السرعة في إبرام التصرفات- إلى توفير قدر كبير من الثقة والائتمان^(١) بين التجار في محيط تعاملهم ، فمن المعلوم أن التجار يتعاملون فيما بينهم بالأجل فتاجر الجملة يأخذ من المنتج ثم يعطي لتاجر التجزئة ، دون أن يأخذ أحدهم أي نقد ، ودون التزام باتباع شكلية معينة لإثبات هذه المبالغ أيّاً كان مقدارها.

وهكذا يرتبط التجار بروابط متتابعة ، قوامها الائتمان أو الثقة المتبادلة بينهم ، بحيث إذا أخل أحدهم بهذه الثقة ، نتج عن هذا الإخلال سلسلة طويلة من الاضطراب في المعاملات^(٢). الأمر الذي يوجب على القانون أن يواجه أي إخلال بهذا الائتمان بقواعد صارمة تكفل الحفاظ على الثقة في الحياة التجارية ، ومن الأمثلة التي تتميز بها قواعد القانون التجاري في هذا الخصوص ، جواز شهر إفلاس التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية الحالة^(٣) ، وقاعدة افتراض تضامن المدينين بدين تجاري^(٤).

٣- عوامل أخرى لاستقلالية القواعد التجارية

بالإضافة إلى السرعة والائتمان كأسباب لاستقلال قواعد القانون التجاري عن القانون المدني ، يضيف أستاذنا الدكتور/علي قاسم أسباباً أخرى تدفع باتجاه استقلال قواعد القانون التجاري عن القانون المدني ، ومنها تشابك العلاقات بين المشروعات ، واستعار المنافسة بينها على إحكام السيطرة على عمليات الإنتاج والتوزيع بما يضر بالطرف الضعيف ، كان من اللازم سن قواعد تحمي حرية المنافسة وتحظر التفاهات الضارة بالاقتصاد القومي.

ومن أسباب الاستقلالية أيضاً ، غلبة الاتجاه نحو حسم المنازعات التجارية بعيداً عن ساحات القضاء بطريق التحكيم أو بطريق الوساطة ، بالإضافة إلى ما فرضه التقدم العلمي من وجود حقوق للملكية الصناعية تحتل أهمية كبيرة بين عناصر الذمة المالية للمشروع ، مما يستوجب معه إيجاد قواعد تحتاج إلى تنظيم قانوني مغاير ومتميز عن حق الملكية الذي يعرفه القانون المدني^(٥).

ثالثاً مراحل تطور قانون المعاملات التجارية

القانون التجاري كغيره من العلوم مرّ بالعديد من المراحل التاريخية حتى وصل إلينا بهذه الصورة

التي عليها الان. ونستطيع أن نقسم هذه المراحل إلى مراحل ثلاث وهي كالتالي:-

المرحلة الأولى: مرحلة المجتمعات القديمة

نظراً لما كانت عليه تلك المجتمعات من بدائية في كل أمورها في هذه المرحلة التاريخية من حياة الانسانية ، فقد وجد النشاط التجاري بين بعض هذه المجتمعات ، كما كان عليه الحال لدى الفينيقيين ، والإغريق ، والبابليين. فالفينيقيون هم أول من أسسوا الخسائر البحرية المشتركة ، حيث كانت تلقى في البحر البضائع التي تزيد عن حمولة السفينة خوفاً عليها من الغرق ، ويشترك جميع التجار في تحمل خسائر البضائع الملقاة في البحر ، وليس التاجر صاحب البضاعة بمفرده^(١).

كما عرف الإغريق عقد القرض البحري الذي يعد أصل التأمين البحري ، كما عرف البابليون التجارة بشكل واسع ، وقد نظمت مدونة حمورابي سنة ١٧٠٠ ق.م. عقد الوديعة ، وعقد القرض بفائدة ، والوكالة بالعمولة ، وشركة التوصية البسيطة^(٢).

غير أن القواعد التي كانت تحكم النشاط التجاري في هذه الحقبة الزمنية ، ظهرت في شكل أعراف تجارية تعارف عليها التجار ، بالإضافة إلى بعض القواعد المدونة ، والتي لم تأخذ شكل قانون مستقل ، وإنما وجدت كقواعد متناثرة في القوانين الأخرى.

المرحلة الثانية: مرحلة العصور الوسطى

في هذه المرحلة وبعد انهيار الدولة الرومانية واستقلال المدن الإيطالية بإدارة شئونها ، وخضوع هذه المدن لسيطرة التجار الذين اعتمدوا على ثرائهم ، فدانت لهم السلطة السياسية ، وحكم هؤلاء التجار مدن جنوه ، والبندقية ، ونابولي ، وفينيسيا ، وفلورنسا وغيرها ، حيث تجمعوا في هذه المدن في شكل طوائف ، لكل منها رئيس يسمى (قنصل التجار) ، وقد كان يقوم بمهام الفصل بين التجار في منازعاتهم التجارية ، مطبقاً في ذلك ما جرى عليه العمل فيما بين التجار من العادات وما استقر منها ، باعتبار أن ذلك عرف واجب الاتباع^(٣).

وقد ترتب على هذا النشاط التجاري المتزايد ، ظهور العديد من الأعراف التي تعارف عليها التجار ، ثم قامت كل طائفة بتدوين هذه القواعد في شكل قانون مكتوب ، وبذلك يكون القانون التجاري قد نشأ مرتبطاً بأشخاص التجار وطيد الصلة بمهنتهم ، مما نتج عنه ظهور

القضاء التجاري المستقل ، وقواعد شركات التوصية ، وأحكام الإفلاس ، كما عرف السجل التجاري كوسيلة لحصر التجار. وقد حظيت التجارة البحرية ، وما نتج عن ذلك من ثراء قواعد التجارة البحرية ، بنصيب الأسد في تلك الفترة الزمنية بسبب عدم ظهور الطيران بعد ، باعتبار أن البحر كان الوسيلة الأكثر استعمالاً لتبادل السلع بين التجار في البلدان المختلفة.

وفي هذه الفترة ربما يغفل بعض المؤرخين الإسهامات التي قدمتها دولة الخلافة الإسلامية لتنشيط حركة التجارة ، وانعكاس ذلك على قواعد القانون التجاري. فقد اهتم الخلفاء المسلمون بتعبيد الطرق وتأمينها ، بجانب خضوع جميع دويلات الخلافة لسلطة واحدة ، والتي تتمثل في شخص الخليفة. هذا بالإضافة إلى اهتمام الفقهاء المسلمين باستنباط أحكام الشريعة الإسلامية ، ووضع القواعد الفقهية في مجال المعاملات من خلال فهمهم للقرآن الكريم والسنة النبوية المباركة.

غير أن الفقهاء المسلمين -عند وضعهم لهذه القواعد لم يفرقوا بين المعاملات التجارية والمعاملات المدنية ، وإنما بحثوا أحكام المعاملات بشكل عام ، أي أن الشريعة الإسلامية لم تعرف قانوناً خاصاً بالمعاملات التجارية ، وإنما كانت القواعد المنظمة للنشاط التجاري جزءاً من الشريعة العامة التي تحكم جميع المعاملات ، بصرف النظر عن طبيعتها أو صفة القائم بها.

ومن يطالع كتب الفقه الإسلامي ، وما دونه الفقهاء المسلمون من قواعد فقهية في مجال المعاملات ، سيجد أن الشريعة الإسلامية قد أكدت على الطابع الرضائي للعقود ، والبعد عن الشكلية ، وهما الأساس الذي يقوم عليه العمل التجاري ، كما أقرت مبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية^(١).

غير أن الفقهاء المسلمين لم يكتفوا بشرح مبادئ الشريعة الإسلامية واستنباط قواعد المعاملات فيها ، وإنما اقتبسوا بعض النظم التجارية التي لا تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية كنظام الخسائر المشتركة الفينيقي الأصل ، كما أقروا بعض الأنظمة التي جرى عليها العمل ، كمسك الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات^(٢).

كما خصص الفقهاء المسلمون في كتبهم باباً للمعاملات التجارية^(٣) ، فعرفوا الكمبيالة ، وفصلوا أحكامها وسموها بالسفتجة ، كما عرفوا عقد الصرف وبنوا أحكامه ، كذلك فرقوا بين شركة إلاباحة^(٤) ، وشركة الملك^(٥) ، وشركة العقد^(٦) ، وقسموا شركة العقد إلى شركة أموال^(٧) ، وشركة أعمال^(٨) ، وشركة وجوه^(٩) وهي التي تتأسس على الائتمان القائم على الثقة بين الشركاء. كما وضع الفقهاء أحكام المضاربة ، وعرفوا الإفلاس ، وعالجوا الإجراءات التي تتبع في حالة إحاطة الدين بمال المدين.

المرحلة الثالثة: العصر الحديث

في هذا العصر تم اكتشاف الأمريكتين ، وتحول النشاط التجاري من حوض البحر الإبيض المتوسط إلى الدول المطلة على المحيط الإطلنطي وبحر الشمال كإنجلترا ، وفرنسا ، والبرتغال ، نتيجة لاكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ، كما فقدت إيطاليا سيطرتها بعد أن اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في ظل الخلافة العثمانية.

وتطورت وسائل المواصلات ، وأخذت تتدفق على أوروبا كميات كبيرة من الذهب والمعادن الثمينة ، فظهرت البنوك الكبرى وأقبل الناس على الإيداع ، كما ظهرت الشركات الاستعمارية الكبرى كشركتي الهند الشرقية وشركة خليج هدسون^(١). وقد بلغت هذه الشركات حداً من النفوذ اضطر معه المشرع للتدخل للحد من طغيان هذه القوى الاقتصادية.^(٢)

كل هذه التغيرات بالإضافة إلى أن الدول الأوروبية بعد أن حققت وحدتها السياسية ، أرادت أن تحقق وحدتها التشريعية فصدرت مجموعة من التقنينات التجارية ، ففي عهد لويس الرابع عشر صدر في فرنسا سنة ١٦٧٣ قانون للتجارة البرية ، والمعروف باسم قانون سافاري والذي استلهم أحكامه من قانون التجار الإيطالي ، ثم صدر بعد ذلك سنة ١٦٨١ قانون خاص بالتجارة البحرية^(٣).

وفي سنة ١٨٠٧ صدر بفرنسا قانون التجارة الفرنسي والذي كان له أثره على الدول التي اعتنقت النظام اللاتيني ، وعنه أخذ المشرع المصري نصوص قانون التجارة القديم الصادر في نوفمبر ١٨٨٣ ، والذي يعد مصدراً تاريخياً للكثير كمن قوانين التجارة في عالمنا العربي ، ومنها على سبيل المثال قانون المعاملات التجارية الاتحادي الإماراتي الصادر في ٧ سبتمبر ١٩٩٣. وقد أعاد المشرع الفرنسي تجميع التشريعات التجارية المتفرقة في مجموعة واحدة بمقتضى الأمر رقم ٩١٢ والصادر في ١٨ سبتمبر سنة ٢٠٠٠.

رابعاً مصادر قانون المعاملات التجارية (ترتيبها وضوابط تطبيقها)

أ- المصادر الإلزامية للقانون التجاري

يقصد بمصادر القانون التجاري: القاعدة القانونية التي يتبعن على القاضي اللجوء إليها للفصل في نزاع تجاري معروض عليه. وقد حددت المادة الثانية من القانون التجاري تلك المصادر ، وضوابط تطبيقها ، فنصت على أنه(١- يسري على التجار وعلى الأعمال التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين. فإذا لم

يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية. ثم قواعد العرف التجاري والعادات الجارية ، فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنية. ٣- ولا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين أو قواعد العرف التجاري أو العادات إذا تعارضت مع النظام العام في مصر).

وطبقاً لهذا النص ، فإن المصادر الإلزامية للقاضي -عندما تعرض عليه منازعة تجارية- تتمثل في المصادر الآتية مرتبة حسب موقعها في النص:-

١- اتفاق طرفي التعاقد

لم يغفل المشرع التجاري إرادة طرفي التعاقد في تحديد الالتزامات والحقوق المتبادلة فيما بينهم ، فجعل هذه الإرادة هي الحكم الأول في الحكم على التصرفات المبرمة بين الطرفين ، وهو تطبيق واضح لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.

وهذا مسلك محمود من المشرع التجاري يتفق بدرجة كبيرة مع واقع التجارة الدولية؛ إذ الغالب في المصالح التجارية أنها مصالح خاصة بأطرافها ينظمونها فيما بينهم بما لا يتعارض مع النصوص الآمرة للقانون أو مع النظام العام أو الآداب السائدة في المجتمع ، مما قد يسهم بدرجة كبيرة في توحيد القواعد التي تحكم معاملات التجارة الدولية^٥. هذا وقد اشترطت الفقرة الثانية من النص السابق -لتطبيق اتفاق الطرفين- عدم مخالفة هذا الاتفاق للنظام العام أو الآداب ، فإذا وقع الطرفان اتفاقاً معارضاً للنظام العام أو الآداب السائدة في المجتمع وجب -طبقاً لمفهوم المخالفة- عدم الاعتداد بهذا الاتفاق^٥.

٢- التشريع التجاري

يقصد بالتشريع التجاري في هذا الخصوص:-

أ- نصوص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والقوانين التجارية الأخرى.

تعتبر نصوص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ هي القاعدة العامة الواجبة التطبيق في المسائل التجارية ، إلا إذا وجد تشريع خاص ينظم بعض هذه المسائل وجب تطبيق هذا الأخير؛ تطبيقاً لقاعدة الخاص يقيد العام. ومن الأمثلة على التشريعات التجارية الخاصة القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٠ بشأن المحال التجارية ، والقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ بشأن تنظيم أعمال الزكالة التجارية ، والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في شأن شركات المساهمة وغيرها من شركات الأموال.

ب- الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمعاملات التجارية

تعتبر الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعت عليها الدولة في منزلة التشريع ، ويتعين على القاضي الحكم بها مقدماً إياها على العرف ، ومن الأمثلة على هذه الاتفاقيات الدولية اتفاقية فيينا ١٩٨٠ المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع. وتبدو أهمية هذه الاتفاقيات في الاتجاه نحو تدويل أحكام قانون المعاملات التجارية الدولية^(١).

٣- العرف التجاري والعادات التجارية

يقصد بالعرف التجاري: تلك القواعد التي درج التجار عليها في تنظيم معاملاتهم التجارية ، وتواترهم على تطبيقها بحيث أصبحت ملزمة فيما بينهم^(٢). وقد يكون العرف التجاري عاماً أي يكون ملزماً ومقرراً في جميع مدن الدولة ، وقد يكون العرف التجاري خاصاً ، أي قاصراً على مدينة أو بلدة فقط دون سائر مدن البلد ، كما قد يكون العرف خاصاً بسلعة معينة دون غيرها من السلع الأخرى.

وفي التطبيق يقدم العرف الخاص على العرف العام^(٣). ويعتبر العرف التجاري مصدراً للعديد من الأحكام الخاصة بالعمليات المصرفية ، ومن أهمها قاعدة عدم تجزئة الحساب الجاري وقاعدة احتساب فوائد على متجمد الفوائد في الحساب الجاري^(٤). ولا يجوز لأحد المتعاقدين الاستناد إلى العرف للتحلل من التزامات يفرضها عليه التعاقد الذي تم بينه وبين الطرف الآخر في العقد؛ إذ لا يوجد ما يمنع من اتفاق الطرفين على ما يخالف العرف التجاري ، ويكون اتفاقهما ملزماً^(٥). وقد قضت محكمة النقض بأنه (لا محل للرجوع إلى العرف التجاري إذا وجدت دفاتر للشركة يبين منها أن الشريكين جريا في تعاملهما على خلاف ذلك....).

ويترك لقاضي الموضوع التحقق من قيام العرف من عدمه^(٦) ، ويخضع القاضي في شأن وجود العرف وتطبيقه لرقابة محكمة النقض لأنه ليس واقعة مادية ، بل لأنه مسألة قانونية يجب على المحكمة العليا -وهي الرقبة على صحة تطبيق القانون- التثبت من وجودها وصحة تطبيقه لها^(٧). ولا يعفى القاضي من بيان دليله على قيام العرف والمصدر الذي استقى منه ذلك ، إذا نازع أحد الخصوم في وجود العرف^(٨).

أما العادة التجارية: فيقصد بها ما اعتاده التجار ودرجوا على اتباعه ، بحكم ما استقر من سنن

وأوضاع في التعامل ، فيكفي في العادة التجارية أن تكون معبرة عن سنة مستقرة ، ولا يشترط أن تكون هذه السنة مخالفة لأحكام القانون^(١). ومن الأمثلة على العادة التجارية ، إنقاص الثمن بدلاً من فسخ البيع إذا كانت البضاعة المسلمة للمشتري من صنف أقل جودة من الصنف المتفق عليه^(٢). وتعتبر العادات التجارية من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بأمر التثبت من قيامها وتفسيرها ، دون رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك ، إلا حيث يحيد القاضي عن أعمال حكم العادة التجارية بالرغم من ثبوتها لديه^(٣).

وتختلف العادة التجارية عن العرف التجاري في أن الأولى إذا ثبت عدم رضا أحد أطراف العقد بها ، أو إن لم يكن يعلم بها فلا يكون ملزماً بها ، بخلاف العرف فهو يلزم الأطراف حتى لو ثبت عدم علمهم به ؛ إذ إنه كالقانون يفترض علم الكافة به.

ويأتي العرف التجاري والعادات التجارية في مرتبة تالية للتشريع التجاري ، أي أن القاضي يطبق القاعدة العرفية متى لم يوجد اتفاق بين الطرفين ، ولم يوجد نص صريح في التشريع ، فالقاعدة العرفية تأخذ نفس قوة القاعدة التشريعية عند غياب الأخيرة^(٤).

٤- القانون المدني

إذا خلت الواقعة التجارية المراد الحكم فيها من اتفاق بين أطرافها ، ولم ينظم القانون التجاري حكم هذه الواقعة ، وليس فيها عرف تجاري ، فإن القاضي يطبق على هذه الواقعة ما ورد في نصوص القانون المدني وتعديلاته ، باعتباره الشريعة العامة لجميع معاملات القانون الخاص ، ومنها المعاملات التجارية.

ولا يعد تقديم العرف التجاري في التطبيق على نصوص القانون المدني ، إعلاءً للعرف على التشريع ، بالمخالفة لترتيب مصادر القاعدة القانونية التي يعلو فيها التشريع على العرف. فالأمر هنا متعلق بتطبيق القاعدة التجارية أولاً ، سواءً كان مصدرها التشريع أو العرف التجاريين ، ثم تطبيق القواعد العامة في المعاملات والمتمثلة في قواعد القانون المدني^(٥).

ب- المصادر التفسيرية للقانون التجاري

بالإضافة إلى المصادر الإلزامية السابقة للقانون التجاري ، فإن الفقه والقضاء يعتبران مصدرين تفسيريين يستعين بهما القاضي في استخلاص القواعد القانونية من المصادر الرسمية وعلى فهم حكم تلك القواعد فيما يغض عليه^(٦).

والمقصود بالقضاء كمصدر تفسيري لأحكام القانون التجاري: تلك الأحكام والحلول القضائية المستقر عليها في حل المنازعات المعروضة على المحاكم. ويتمثل دور القاضي هنا ، في استنباط واستلزام القواعد القانونية من الأعراف والعادات السائدة في البيئة التجارية التي يعيش فيها ، والنظر في مدى ملائمة تطبيق تلك القواعد على المنازعات التجارية ، حتى يلتفت المشرع لها ويضعها في قالب تشريعي ، لتتحول من استنباطات قضائية ، إلى قواعد تشريعية منصوص عليها. ومن الأمثلة ، القواعد الخاصة بعمليات البنوك ، ونظرية الشركة الفعلية ، والتنظيم القانوني للحسابات الجارية. فكل هذه القواعد -هي في الأصل- من خلق القضاء. ويعتبر القضاء مصدراً ملزماً في بلاد قانون الانجلو أمريكي التي تأخذ بنظام السوابق القضائية ، وهي عبارة عن المبادئ القانونية التي استقرت المحاكم على تطبيقها في موضوع معين^(١).

أما الفقه كمصدر تفسيري ، فيتمثل في مجموع الآراء ، والشروح ، والتفسيرات التي يضعها أساتذة القانون ، ورجال القضاء ، والمحامون في شروحهم وتعليقاتهم القانونية. ويسهم الفقه في تفسير القواعد التشريعية ، وبيان العيوب أو النقص الذي قد يشوب هذه القواعد ، وتقديم المقترحات لتلافي هذه العيوب. كما أن الفقه قد يتناول بعض الموضوعات الحديثة في مجال التجارة -والتي لم يصدر فيها تشريع بعد- بوضع مقترحات وحلول قانونية لمشاكلها ، فيستعين بها المشرع عند وضع قانون لتلك الموضوعات.

خامساً نطاق تطبيق القانون التجاري

اختلف الفقه في تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري ، ويرجع هذا الاختلاف إلى اعتناق كل فريق منهم نظرية تختلف عن الأخرى ، ونستطيع حصر تلك النظريات في نظريتين اثنتين ، ١- النظرية الشخصية. ٢- النظرية الموضوعية. وأخيراً نبين ٣- موقف المشرع التجاري المصري.

١- النظرية الشخصية

يعتمد أصحاب هذه النظرية -في تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري- على معيار شخصي ، أي شخص القائم بالعمل التجاري ، وهو التاجر؛ حيث إن القانون التجاري في مفهوم أصحاب هذه النظرية يعني ، مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على طائفة التجار في ممارستهم لنشاطهم المهني^(٢).

ولعل هذه النزعة الشخصية في تطبيق القانون التجاري -لدى أصحاب هذه النظرية- يرجع إلى الأعراف التي ابتدعها وطبقها أصحاب الحرف التجارية ، الأمر الذي أصبح به القانون التجاري

قانوناً مهنيًا ، وعلى الرغم من إلغاء نظام الطوائف وانتشار مبدأ الحرية الاقتصادية الذي يعطي الحق لكل شخص في مزاوله ما يشاء من نشاط. إلا أن القواعد التجارية ظلت مستقرة كما كانت عليه في مجتمع التجارة الطائفي ، كما أبقت التشريعات الحديثة على المحاكم التجارية نزاول اختصاصها بالفصل في المنازعات التجارية دون غيرها^(١).
ويترتب على الأخذ بالنظرية الشخصية في تطبيق قواعد القانون التجاري ، عدم تطبيق أحكام هذا القانون على غير التجار عند ممارستهم لبعض المعاملات التجارية.

٢- النظرية الموضوعية

يتحدد نطاق تطبيق القانون التجاري لدى أصحاب هذه النظرية بالعمل التجاري ذاته ، بصرف النظر عن شخص القائم به ، سواء كان تاجراً أو غير تاجر. وطبقاً لهذه النظرية ، فإنه لا يشترط لتطبيق القانون التجاري أن يتكرر وقوع العمل الذي يعد تجارياً ، وإنما يكفي لتطبيق هذا القانون أن يقوم الشخص بالعمل التجاري الذي حدده المشرع ولو مرة واحدة^(٢). وهو ما يعني تبعية القانون التجاري في التطبيق للعمل التجاري ، سواء اشترط المشرع في هذا العمل- لإكساب الصفة التجارية- أن يكون على سبيل الاحتراف ، أم يكفي مجرد القيام به ولو مرة واحدة.

الرأي في النظريتين

لكل نظرية من النظريتين أنصارها الذين يدافعون عنها ، إلا أنه لا يمكن الأخذ- في تحديد نطاق القانون التجاري- بنظرية واحدة منهما دون الأخرى؛ لأن الأخذ بالنظرية الشخصية على إطلاقها يمكن أن يؤدي إلى استغراق الحرفة لحياة التاجر ، بمعنى أن كل ما يصدر من التاجر سيعتبر- طبقاً للنظرية- عملاً تجارياً يخضع لقواعد القانون التجاري^(٣).

وهذه النتيجة غير صحيحة من الناحية الواقعية ، فالتاجر كغيره من الأشخاص له حياته الخاصة التي يتعامل فيها باعتباره غير تاجر ، كزواجه وشرائه منزلاً لسكنائه أو سيارة لا استعماله الشخصي ، وليس من المقبول أن ينطبق القانون التجاري على تصرفاته المدنية ، ويترتب على ذلك ضرورة أن تدخل النظرية الشخصية في الفصل بين نوعين من الأعمال : تجارية ومدنية ، وهو ما يعني الأخذ بالنظرية المادية أو الموضوعية.

أما النظرية الموضوعية أو المادية فيؤخذ عليها ، أنها تعتمد على تحديد المشرع للأعمال التجارية

لتحديد تطبيق القانون التجاري ، وهو معيار تحكيمي لأن المشرع لا يمكنه حصر الأعمال التجارية ، وتوقع ما يستجد منها في المستقبل. كما أنه يترتب على الأخذ بهذه النظرية التضيق من نطاق أحكام القانون التجاري حيث إن هناك بعض الأعمال التي تكتسب الصفة التجارية بشرط ممارستها على سبيل الاحتراف كالسمسرة ، والوكالة التجارية ، والوكالة بالعمولة ، والصناعة ، والنقل البري ، والتوريد^(١).

ونظراً لقصور كل نظرية بمفردها من النظريتين السابقتين في تحديد نطاق القانون التجاري ، لم يكتف المشرع التجاري المصري بالأخذ بنظرية واحدة فقط ، وإنما كان له اتجاه آخر.

٣- موقف المشرع التجاري المصري

لم يأخذ المشرع التجاري بنظرية دون الأخرى وإنما نهج نهجاً يجمع بين النظريتين ، فقد نصت المادة الأولى من القانون التجاري على أن (تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر) ، كما نص في المادة الرابعة منه على الأعمال التي تعد تجارية بطبيعتها ، ولو لم يزاوها الشخص على سبيل الاحتراف وهو ما يعد أخذاً بالنظرية المادية.

وعلى الجانب الآخر نصت المادة الخامسة من ذات القانون على الأعمال التي تعد تجارية إذا كانت مزاولتها على سبيل الاحتراف. كما نصت المادة العاشرة منه على الشروط الخاصة باكتساب الشخص صفة التاجر ، فضلاً عن النصوص التي تنظم التزامات التجار ، كضرورة القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية ، مما يعد دليلاً واضحاً على أخذ المشرع التجاري بالنظرية الشخصية بجانب النظرية المادية. فقد تجنب المشرع الميل لإحدى النظريتين دون الأخرى ، خشية أن يفقده الميل حرية الحركة ، فجمع بين النظريتين الشخصية والموضوعية أو المادية ، واستخلص مزيجاً يقوم على اعتبار بعض الأعمال تجارية بذاتها ولو وقعت على سبيل الانفراد (المذهب الموضوعي) وبعضها الآخر لا يكتسب هذه الصفة إلا إذا وقع على سبيل الاحتراف (المذهب الشخصي).

الباب الأول

نظرية الأعمال التجارية

في قانون المعاملات التجارية

تمهيد وتقسيم

لم يضع المشرع التجاري تعريفاً للأعمال التجارية ، ولكنه عدد هذه الأعمال في المواد من المادة الرابعة إلى المادة السابعة من قانون التجارة. وقد أظهر هذا التعداد للأعمال التجارية أنها ليست على درجة واحدة في التمتع بالصفة التجارية ، وذلك على النحو التالي:-

المجموعة الأولى: الأعمال التجارية بالطبيعة

وهذه الأعمال هي التي نص عليها المشرع في المادتين الرابعة والخامسة تجاري ، وهي تنقسم بحسب نظرة المشرع لها إلى نوعين من الأعمال:-

النوع الأول

أعمال اعتبرها المشرع عملاً تجارياً ، وإن وقعت من الشخص مرة واحدة ، وبصرف النظر عن شخص القائم بها ، سواء كان تاجراً أو غير تاجر ، وهذه الأعمال هي المنصوص عليها في المادة الرابعة.

النوع الثاني

وهذا النوع من الأعمال اعتبرها المشرع تجارية ، غير أنه اشترط -لاكتسابها هذا الوصف- وقوعها من الشخص على سبيل الاحتراف والتكرار ، أي أن شخص القائم بها يلزم أن يكون تاجراً ، وهذه هي الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة.

المجموعة الثانية: الأعمال التجارية بالتبعية

وهذه هي مجموعة الأعمال التي هي في الأصل أعمال مدنية ، لكن نظراً لوقوعها من تاجر بمناسبة عمله التجاري ، أو كانت مرتبطة أو مسهلة لعمل تجاري ، وبصرف النظر عن شخص القائم بالعمل التجاري ، فقد اعتبرها المشرع عملاً تجارياً تبعاً للعمل الأصلي ، وهذه هي

الأعمال التجارية بالتبعية الشخصية والموضوعية ، والمنصوص عليها في المادة ١/٨ تجاري.

المجموعة الثالثة: الأعمال التجارية المختلطة

وهذه هي الأعمال التي تقع من طرفين ، أحدهما يكون تاجراً ، وتقع منه بمناسبة عمله التجاري ، والطرف الآخر ليس بتاجر ، فاعتبرها المشرع تجارية بالنسبة للطرف الأول ، وليست كذلك بالنسبة للطرف الثاني ، وهذه هي فئة الأعمال المختلطة ، وهي المنصوص عليها بالمادة ٣ تجاري.

ملحوظات على تعداد المشرع للأعمال التجارية

وأخيراً فإنه يلاحظ على التعداد السابق الذي أورده المشرع التجاري للأعمال التجارية ما يلي:-
أولاً: التعداد الذي أورده المشرع في المادتين الرابعة والخامسة والسادسة تجاري ليس على سبيل الحصر ، وإنما ذكره المشرع على سبيل المثال ، بدليل ما نص عليه في المادة السابعة من ذات القانون بأن (يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه في الصفات والغايات). فالمشرع بهذا النص ترك الباب مفتوحاً -بطريق القياس- لاستيعاب كل عمل جديد تفرزه تطورات الحياة الاقتصادية لم يكن موجوداً وقت صدور القانون ، لينضم إلى قائمة الأعمال التجارية. وهذا مسلك حسن من المشرع لأن القانون لن يتمكن من حصر كل الأعمال التجارية حصراً كلياً ، كما أنه لا يمكنه التنبؤ بما في المستقبل ، وهو ما يحقق -بقدر معين- استقراراً تشريعياً.

ثانياً: لا يجوز للأشخاص تغيير الصفة التجارية التي منحها المشرع لتلك الأعمال؛ نظراً لتعلق الصفة التجارية بالنظام العام ، ومن هذا المنطلق تخضع محكمة الموضوع لرقابة المحكمة العليا فيما يتعلق بتحديد طبيعة العمل والنتائج المترتبة عليه ، باعتبار أنه من المسائل القانونية^(١).

أضف إلى ما سبق أن المشرع عدد الأعمال التجارية بحكم الماهية في المادة الرابعة ، تجاري ، ثم عدد الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف في المادة الخامسة ، حتى وصلت ستة عشر عملاً ، وأخيراً نص في المادة ٦ تجاري على أعمال الملاحة البحرية على أنها من الأعمال التجارية ، وخص منها بعض الأعمال.

ونعتقد أن المشرع لو كان يسير وفق خطة موضوعية منظمة ، ما كان قد وقع في هذا التكرار ، ولا في هذا التعداد لكل هذه الأعمال ، على الأخص أنه في المادة السابعة فتح باب القياس على الأعمال

التجارية لكل عمل يتشابه معها في الغايات والصفات.

ثالثاً: لم يكن محموداً من المشرع تحديده لبعض الأعمال على أنها أعمال مدنية ، كما فعل في المادة التاسعة^(٥)؛ حيث إننا نعتقد أن النص في المواد ٤ ، ٥ ، ٦ تجاري على الأعمال التجارية وجواز القياس عليها بالمادة السابعة تجاري يكفي لتحديد ما هو مدني وما هو تجاري من الأعمال.

رابعاً: على الرغم من تعداد المشرع للأعمال التجارية في المواد السابق ذكرها ، إلا أن هذا التعداد لم يمنع الفقه من الاختلاف حول المعيار الذي يمكن الاعتماد عليه لتحديد ما هو من الأعمال يكون تجارياً؟ وما هو منها يكون مدنياً؟ حيث إن هذا التعداد- كما بينا سابقاً- لم يكن على سبيل الحصر بل كان على سبيل المثال.

وعموماً فإنه يجدر بنا قبل تفصيل الكلام في الأعمال التجارية بأنواعها المختلفة ، أن نبين المعايير أو الضوابط التي أوجدها الفقه القانوني للتمييز بين العمل التجاري والعمل المدني ، وما يترتب على هذا التمييز من نتائج وفوائد.

لذلك وتأسيساً على ما تقدم ، فإننا نقسم معالجتنا لنظرية الأعمال التجارية في هذا الباب إلى أربعة فصول:-

الفصل الأول: ضوابط التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني والنتائج المترتبة على ذلك.

الفصل الثاني: الأعمال التجارية بطبيعتها.

الفصل الثالث: الأعمال التجارية بالتبعية.

الفصل الرابع: الأعمال التجارية المختلطة.

ضوابط التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني

والنتائج المترتبة على ذلك

تمهيد وتقسيم

بالرغم من نص المشرع على تجارية العديد من الأعمال ، سواء وقعت على سبيل الاحتراف ، أو باسرها الشخص مرة واحدة فقط ، إلا أن تطور الحياة التجارية يثبت عدم قدرة المشرع على ملاحظة هذا التطور ، الأمر الذي يستدعي ضرورة البحث عن معيار ، أو ضابط للتمييز بين العمل التجاري والعمل المدني. ومما لا شك فيه أن التمييز بين العاملين له قدر كبير من الأهمية؛ حيث إنه ينتج عنه تحديد نطاق تطبيق أحكام القانون التجاري على الأعمال التي ينطبق عليها هذا المعيار ، وعدم خضوع الأعمال التي لا ينطبق عليها هذا المعيار لأحكام القانون التجاري.

وتأسيساً على ما سبق ، فإننا نقسم الكلام عن هذه الضوابط والنتائج المترتبة على هذا التمييز إلى مبحثين اثنين:-

المبحث الأول: ضوابط التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني.

المبحث الثاني: نتائج التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني.

المبحث الأول

ضوابط التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني

أورد المشرع التجاري تعداداً للأعمال التجارية في المواد من ٤ إلى ٦ من قانون المعاملات التجارية الاتحادي ، غير أن هذا التعداد لم يكن على سبيل الحصر ، وإنما على سبيل المثال ، وقد دفع هذا التعداد غير الحصري للأعمال التجارية الفقه القانوني لمحاولة البحث عن ضوابط تحديد العمل التجاري ، وتمخضت تلك المحاولات الفقهية عن مجموعة من النظريات ، تأثر بعضها بالطابع الموضوعي للقانون التجاري ، كنظرية التداول والمضاربة ، بينما تأثر البعض الآخر بالطابع الطائفي أو التقليدي ، كنظرية الحرفة التجارية والمشروع. وتتناول بالعرض والبيان كل نظرية من هذه النظريات.

١-نظرية التداول

يرى أنصار هذه النظرية أن العمل التجاري يتميز بكونه يهدف إلى تسهيل تداول السلع والنقود بين المنتج والمستهلك ، فكل عمل من هذا القبيل يعد عملاً تجارياً ، وكل عمل لا يقوم على هذا الغرض لا يعتبر تجارياً^(١). فتحويل السلعة بالتصنيع ونقلها وبيعها للتاجر الذي يتولى بدوره بيعها إلى المستهلك ، كل هذه الأعمال الداخلة في حركة تداول السلعة هي أعمال تجارية. أما الأعمال المدنية فهي التي ترد على الثروات قبل تداولها أو بعد وصولها للمستهلك^(٢).

فالتداول لدى أصحاب هذه النظرية إنما يعني تحريك السلعة من يد المنتج إلى يد المستهلك ، والعمل التجاري هو كل عمل ينصب على هذا التحريك. ونرى أن هذه النظرية وإن صلت كميّاراً لكثير من الأعمال التجارية كالشراء لأجل البيع ، والنقل ، وعمليات البنوك ، لكنها لا تصلح معياراً لأعمال أخرى تجارية ، كالفعل الضار الذي يقع من التاجر بمناسبة مباشرة التجارة. فعلى الرغم من أنه عمل تجاري إلا أنه لا يتضمن أي تداول للسلع والنقود ، بالإضافة

إلى أن بعض الأعمال فيها معنى التداول ولا تعتبر تجارية كعملية نقل واحدة منفردة يقوم بها شخص بصفة عارضة ، فإنها وإن كانت عملية تداول إلا أن القانون لا يعتبرها تجارية. كما أنه من المؤكد أن حركة التداول وحدها لم تعد قاصرة على التجار بل أصبحت تشمل كافة النشاط الانساني^(١).

٢- نظرية المضاربة

يعتمد أصحاب^(٢) هذه النظرية على فكرة المضاربة كمعيار لتحديد العمل التجاري ، أي أن العمل التجاري لدى أنصار هذا الفكر: هو كل عمل يكون الهدف منه تحقيق الربح. أما العمل الذي يتم دون مقابل ، ودون أن يهدف إلى تحقيق الربح ، فلا يعتبر عملاً تجارياً ولا يخضع لقواعد القانون التجاري ، وإنما يعتبر عملاً مدنياً تطبق عليه أحكام القانون المدني^(٣).

وهذه النظرية وإن كانت على جانب كبير من الصواب نظراً لأن الغالب الأعم من الأعمال التجارية تهدف إلى تحقيق الربح ، وهو ما يميزها عن الأعمال المدنية ، إلا أنها قاصرة عن وضع معيار جامع مانع للأعمال التجارية؛ حيث إن كثيراً من الأعمال المدنية تهدف -أيضاً- لتحقيق الربح ، كعمل المحامي ، والطبيب ، والزارع ، والمهندس. فهذه الأعمال لا تعتبر أعمالاً تجارية بالرغم من توافر قصد الربح فيها.

كما أن هناك من الأعمال التي اعتبرها المشرع أعمال تجارية على الرغم أنها لا تهدف إلى تحقيق الربح كسحب الشيك ، فهو عمل تجاري بنص القانون بالرغم من أن الساحب قد يقصد التبرع بقيمة الشيك ، والتبرع عمل بعيد تماماً عن فكرة المضاربة ، ومن ناحية أخرى فقد ينتفي هدف تحقيق الربح من العمل دون أن يؤثر ذلك على تجارته ، كما هو الحال بالنسبة لعملية بيع البضاعة بأقل من ثمن شرائها للقضاء على المنافس^(٤).

وهكذا نجد أن معيار المضاربة لا يستطيع بمفرده أن يضع حداً فاصلاً بين العمل المدني والعمل التجاري ، بالرغم من الاستعانة به لا ستبعاد بعض الأعمال المدنية من نطاق القانون التجاري ، كنشاط الجمعيات التعاونية الذي يستهدف خدمة أعضائها دون تحقيق ربح معين ، وكذلك النشاط الذي يجري بهدف الدعاية^(٥).

٣- نظرية الاحتراف

يعد الفقيه الفرنسي ريبير^(٦) من أشد أنصار هذه النظرية والتي تعتمد في تحديد العمل التجاري

على ضوابط شخصية مستمدة من شخص القائم بالعمل وليس من العمل ذاته ، فالعمل لا يكون تجارياً إلا إذا قام به الشخص من خلال حرفته التجارية. ويعد الشخص محترفاً للتجارة متى باشر الأعمال التجارية بصفة منتظمة ومستمرة حتى تصبح التجارة المورد الرئيس لرزقه ، مع استعأنته على مباشرتها بمجموعة من الوسائل المادية لتحقيق الغرض المقصود ، ومن ثم فكل الأعمال التي تقع من التاجر أثناء مزاولته لمهنة التجارة ، بل حتى الأعمال التي تتصل بهذه المهنة تعتبر تجارية ، أما التصرفات التي يقوم بها التاجر ولا علاقة لها بمزاولته مهنة التجارة ، كشرائه منزلاً لسكناه وتبرعاته ، فلا تعتبر أعمالاً تجارية^(١).

وهذه النظرية وإن جاءت متفقة مع المشرع في اشتراطه الاحتراف لإضفاء التجارية على بعض الأعمال ، كما هو الحال في الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة تجاري ، ومن أمثلتها الصناعة ، والوكالة التجارية ، والسمسرة ، وأعمال الدور والمكاتب ، وتشديد العقارات ، وأعمال الفنادق والمطاعم ، إلا أنها تصطدم مع المشرع في بعض الأعمال التي اعتبرها تجارية حتى ولو لم تقع على سبيل الاحتراف ، كما هو الحال في الأعمال المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون التجارة ، ك شراء المنقولات بقصد بيعها بغية التربح ، وتأسيس الشركات التجارية ، واستئجار المنقولات بقصد تأجيرها ، فكل هذه الأعمال اعتبرها القانون تجارية ، ولو لم تقع إلا مرة واحدة. أضف إلى ماتقدم أن ربط العمل بالحرفة يستلزم-حتماً وبالضرورة-تعريف المقصود بهذه الحرفة ، ولن تتمكن من تعريف الحرفة إلا إذا كنا على دراية بالأعمال المكونة لها ، وهذه الأعمال إذا ما تعلق الأمر بحرفة تجارية لا يمكن أن تكون إلا الأعمال التجارية.

وهكذا تؤدي بنا نظرية الاحتراف إلى الوقوع في حلقة مفرغة ، فالحرفة التجارية لا يمكننا تعريفها إلا بمعرفة طبيعة الأعمال المكونة لها ، وهذه الطبيعة لا يمكننا معرفتها إلا على ضوء الحرفة التي تنظمها.

٤- نظرية المشروع

يقصد بالمشروع تكرار القيام بالعمل وممارسته بصورة منتظمة ، وتصاحبه-غالباً- بعض المظاهر المادية الخارجية التي تنبئ عنه^(٢) ، كاتخاذ محل تجاري مقرأ للمشروع ، أو إعداد آلات وأدوات تستخدم في المشروع ، ك شراء آلات صناعية في مشروع صناعي بالإضافة إلى استجلاب فنيين وعمال للعمل فيه^(٣). ويرى أنصار هذه النظرية أن الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص على سبيل المشروع ، بصرف النظر عن طبيعة هذه الأعمال أو الغرض منها ، وسواءً

حققت هذه الأعمال ربحاً أم لم تحقق.

ومن جانبنا فإن نظرية المشروع تتشابه إلى حد كبير مع نظرية الاحتراف ، ولذا فهي أيضاً تعد غير قادرة على استيعاب جميع الأعمال التجارية ، كما هو الحال في الوكالة بالعمولة والتي اعتبرها المشرع عملاً تجارياً بالرغم من أن الوكيل قد يمارس عمله معتمداً على جهده الفردي فقط ودون أن يتم ذلك في شكل مشروع ، وكذلك الحال في السمسرة والباعة الجائلين. وعلى العكس من هذه النظرية فإن بعض الأعمال تتم في شكل مشروع ومع هذا لا تكتسب الصفة التجارية ، كما هو الحال في مكاتب المحامين والأطباء.

وبعد هذا العرض للنظريات التي قيلت للتمييز بين العمل التجاري والعمل المدني ، فإنه يتضح لنا أن كل نظرية بمفردها غير قادرة على وضع حد فاصل بين العمل التجاري والعمل المدني. لذا فإن النظريات الأربع تصلح جميعها للتمييز بين العمل التجاري والعمل المدني.

المبحث الثاني

النتائج المترتبة على التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني

تخضع المعاملات التجارية لأحكام خاصة تختلف عن تلك التي تخضع لها المعاملات المدنية؛ حيث إن أحكام التشريعات التجارية تسعى لتحقيق هدفين أساسيين أولاهما: السرعة في إتمام المعاملات التجارية. ثانيهما: تحقيق الائتمان والثقة فيمن يباشر هذا النوع من المعاملات. وقد حرص المشرع التجاري على تحقيق هذين الهدفين ، فأفرد للأعمال التجارية نظاماً قانونياً خاصاً ظهرت فيه بجلاء الانعكاسات القانونية لكل من هذين الهدفين. وتتناول في هذا المبحث النتائج المترتبة على التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني.

١- الإثبات

الإثبات بمعناه القانوني يقصد به إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة ترتب آثارها^(١). ولما كانت المعاملات التجارية تعتمد على السرعة وحرية تداول الثروات ، بخلاف المعاملات المدنية فطابعها الثبات والاستقرار ، لذلك كانت حرية الإثبات هي الأصل في المعاملات التجارية ، حيث يجوز فيها الإثبات بكافة طرق الإثبات^(٢) دون تحديد مقدار معين للحق المراد إثباته بغير الكتابة^(٣). أما إذا كانت المعاملة مدنية فلا يقبل فيها الإثبات

بغير الكتابة إلا إذا كانت قيمة المعاملة لا تزيد لى ألف جنيه ، فإذا كانت القيمة في المعاملة المدنية تزيد عن هذا المبلغ فلا يجوز إثبات الحق إلا بالكتابة^(١). ولا يجوز في المعاملة المدنية لإثبات ما يخالف دليلاً كتابياً إلا بالكتابة حتى لو كانت قيمة المعاملة لا تزيد على ألف جنيه^(٢). أما إذا كانت المعاملة تجارية ، فيجوز فيها الإثبات بغير الكتابة فيما يخالف دليلاً كتابياً ، أيّاً كانت القيمة^(٣).

ومن التطبيقات القضائية في موضوع حرية الإثبات في المسائل التجارية ، ما قضت به محكمة النقض المصرية بأن (إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها في علاقة المدين بالدائن الأصلي طليق من القيود التي وضعها المشرع لما عداها من الديون في المواد ٤٠١-٤٠٣ مدني تقابل المواد ٦٠-٦٣ من قانون الإثبات ، فيجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات في المواد التجارية -إلا ما استثنى بنص خاص- بكافة الطرق القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما عو ثابت بالكتابة)^(٤).

الاستثناءات على قاعدة حرية الإثبات في المعاملات التجارية

رأينا أن القاعدة في المعاملات التجارية هي حرية الإثبات ، غير أن المشرع قد يورد بعض الاستثناءات على هذه القاعدة مراعاة منه لاعتبارات معينة ، ومن هذه الاستثناءات

أ- اشتراط الكتابة في بعض العقود

أوجب القانون التجاري الكتابة في بعض العقود وجعلها ركناً فيها ، كما هو الحال بالنسبة لعقد الشركة فلا يجوز إثباته إلا بالكتابة^(١) ، كما لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في عقد الشركة إلا بالكتابة^(٢) ، ومن هذه العقود -كذلك- عقد بيع المحل التجاري فلا يجوز إثباته إلا بالكتابة^(٣). ولعل السبب في اشتراط المشرع التجاري الإثبات بالكتابة في مثل هذا النوع من العقود ، هو أن هذه العقود والتصرفات قد يستغرق إبرامها أو تنفيذها وقتاً طويلاً ، فتكون الكتابة فيها حاسمة لكل نزاع قد ينشأ في المستقبل^(٤) ، على الأخص أن الشهود -مع افتراض صدقهم- قد تتسبب كثرة التفصيلات في هذه العقود -مع طول الزمن- في نسيانهم لكثير من بنود هذه العقود ، الأمر الذي لا يجوز معه ترك إثباتها تحت رحمة الشهود^(٥).

ب- الاستبعاد الاتفاقي لقاعدة حرية الإثبات

لما كانت قاعدة حرية الإثبات في المواد التجارية لا تتعلق بالنظام العام ، فيجوز لأطراف المعاملة

التجارية الاتفاق على طريقة للإثبات بينهما^١ ، فيجوز لهم اشتراط الإثبات بالكتابة فيما يجوز إثباته بغير الكتابة فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن (قاعدة الإثبات في المواد التجارية لا تتعلق بالنظام العام ، ومن ثم فعدم تمسك الخصم بذلك قبل البدء في سماع الشهود يؤدي لاعتباره متنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق القانوني)^٢.

٢- الاختصاص القضائي

أ- الاختصاص النوعي

ذهبت بعض الدول^٣ إلى الفصل بين القضاء المدني والقضاء التجاري ، فجعلت لكل واحد منهما قضاءً مستقلاً ينفرد بالنظر في المنازعات التجارية ، فيجوز- في ظل هذا النظام- الدفع بعدم الاختصاص إذا رفعت الدعوى التجارية أمام القضاء المدني والعكس. غير أن غالبية الدول ، ومنها دولة مصر ، لم تأخذ بنظام ازدواج القضاء المدني والتجاري ، وإنما أخذت بوحدة الاختصاص القضائي في مسائل القانون الخاص.

ففي ظل هذا النظام الأخير يوجد في كل محكمة مجموعة من الدوائر ، بعضها يختص بنظر الدعاوى المدنية ، وبعضها بنظر الدعاوى التجارية ، والبعض الآخر بنظر دعاوى الأحوال الشخصية. ولا يمكن في ظل هذا النظام الدفع بعدم الاختصاص إذا رفعت الدعوى التجارية أمام الدائرة المدنية والعكس؛ لأنه -فقط- مجرد ترتيب إداري داخل المحكمة الواحدة قصد به مجرد التيسير على المتقاضين وإيجاد نوع من التخصص بين القضاة^٤.

ب- الاختصاص المحلي أو المكاني

يقصد بالاختصاص المحلي نصيب كل محكمة من محاكم الطبقة الواحدة من ولاية القضاء^٥ طبقاً لاعتبارات-غالباً- محلية كموطن المدعى عليه ، أو محل الأموال موضوع النزاع. والقاعدة العامة في الاختصاص المحلي هي دائماً محكمة موطن المدعى عليه ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهذا تطبيق للقاعدة التقليدية التي تقضي بأن المدعي هو من يجب عليه أن يسعى للمدعى عليه للمطالبة بحقه^٦.

وقد خرج المشرع عن هذه القاعدة في الدعاوى التجارية^٧ بهدف التسهيل على المتقاضين تماشياً مع خاصية السرعة التي تهيمن على الأعمال التجارية ، فجعل المشرع الاختصاص في منازعات

العقود التجارية لمحكمة موطن المدعى عليه ، أو للمحكمة التي تم الاتفاق فيها ، أو المحكمة التي فيها نفذ في دائرتها بعض الاتفاق أو كله ، أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها^(١). كما جعل المشرع الاختصاص في دعاوى الإفلاس للمحكمة التي يقع في دائرتها المحل التجاري الذي اتخذ مركزاً رئيساً لأعماله التجارية ، فإذا اعتزل التجارة انعقد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه ، أما الدعاوى الناشئة عن التفليس فتعقد للمحكمة التي قضت بشهر الإفلاس^(٢).

٣- المهلة القضائية

طبقاً لما تقضي به المادة ٢/٣٤٦ مدني من قانون المعاملات المدنية ، فإنه يجوز في الدين المدني أن يمنح القاضي ، في حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون ، أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه ، إذا استدعت حالته ذلك ، ما لم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.

أما في المسائل التجارية فإن المشرع التجاري يتشدد في منح القاضي هذه السلطة ، فلا يملك القاضي منح المدين في دين تجاري مهلة للوفاء إلا بموافقة الدائن نفسه ، أو إذا كانت هناك ظروف استثنائية أوجبت ذلك. فقد نصت المادة ٥٩ تجاري على أنه (لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضرورة وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن). وترجع الحكمة في تشدد المشرع التجاري في منح المدين التجاري مهلة قضائية ، إلى ما تحتمه طبيعة المعاملات التجارية وما تقوم عليه من سرعة وثقة تقتضي من التاجر ضرورة الوفاء بدينه في الميعاد ، وإلا كان ذلك سبباً في إشهار إفلاسه^(٣).

كما أن المشرع التجاري أحياناً قد لا تأخذه رافة ولا رحمة بالمدين المقصر ، فيحرمه من الحصول على مهلة للوفاء بالتزامه مفضلاً بذلك حماية الائتمان التجاري على مصلحة المدين ، فقد نصت المادة ٥٤٧ تجاري على أنه (لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال وفي الحدود التي ينص عليها القانون).

٤- التضامن بين المدينين

يقصد بالتضامن هنا وجود أكثر من مدين ملتزمين جميعاً بدفع دين واحد ، وللدائن أن يطالب أي مدين منهم بالوفاء بهذا الدين ، وليس لمن يُطالب من المدينين بالوفاء أن يدفع في مواجهة الدائن بالرجوع على غيره من المدينين^(٤). ويعد الوفاء بالدين من أحد هؤلاء المدينين مبرئاً لزمة

باقي المدينين في ذات الدين⁰ ، وللمدين الموفي أن يرجع على باقي المدينين بنصيبهم في هذا الدين.

وطبقاً لما تقضي به المادة ٢٧٩ مدني فإن التضامن بين المدينين لا يفترض في المسائل المدنية ، بل يلزم أن يكون هذا التضامن بناءً على اتفاق أو نص في القانون. وعلى العكس من ذلك في الدين التجاري ، نجد أن التضامن بين المدينين يكون مفترضاً دعماً للائتمان التجاري حتى يضمن الدائنون الحصول على حقوقهم ، فقد نصت المادة ١/٤٧ تجاري على أنه (١- يكون الملتزمون معاً بدين تجاري متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك...).

كما قضت محكمة النقض المصرية بأن (الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن ، وللدائن مطالبته وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصاصه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين)⁰.

٥- التقادم

الدعوى القضائية هي وسيلة لحماية الحق ، غير أن المشرع مراعاة منه لاستقرار المعاملات منع سماع الدعوى إذا مرت مدة زمنية محددة ولم يقيم المدعي -دون عذر شرعي- برفع دعواه ، وهو ما يعرف بالتقادم. وقد نصت المادة ٣٧٤ مدني على أنه (يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية...).

غير أن هذه المدة الزمنية -لسقوط الحق في سماع الدعوى- لا تتناسب مع طبيعة المعاملات التجارية ، وما تتسم به من سرعة في اقتضاء الديون وتحصيل الحقوق. لذلك جعل المشرع التجاري مدة التقادم بمرور سبع سنوات من تاريخ حلول الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، فقد نصت المادة ٦٨ تجاري على أنه (تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى).

٦- اكتساب وصف التاجر

لا يكتسب وصف التاجر إلا من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وكانت حرفة له ،

مع حيازته للأهلية الواجبة^٥ ، فلا يكتسب وصف التاجر من احتراف الأعمال المدنية حتى لو كان حائزاً للأهلية المطلوبة. ويترتب على اكتساب الشخص صفة التاجر خضوعه لمجموعة من الالتزامات^٥ ، بالإضافة إلى اختصاصه ببعض الأنظمة ، ومن أهمها شهر الإفلاس الذي نظمه المشرع التجاري في الباب الخامس من قانون التجارة في المواد من ٥٥٠ إلى المادة ٧٧٢ ، حيث إنه-طبقاً للمادة ٥٥٠ تجاري-يعتبر التاجر في حالة إفلاس متى توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها بسبب اضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه.

ويتم شهر إفلاس التاجر بحكم يصدر من المحكمة الابتدائية المختصة^٥ ، بناء على طلب من أحد الدائنين أو بطلب منه هو شخصياً^٥ أو بناء على طلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة^٥ ، وإذا أشهر إفلاس التاجر فإن يده تغل عن إدارة أمواله أو التصرف فيها ، وتعين المحكمة المختصة أميناً للتفليسة^٥ يتولى بنفسه إدارة أموال التاجر المفلس -نيابة عنه وعن الدائنين- حتى يتم تصفيتها وسداد الديون كاملة أو قسمة غرماء.

ويتسم نظام الإفلاس بالشدّة والقسوة في معاملة التجار ، حيث يضع نهاية لنشاط التاجر ويستأصله من البيئة التجارية وينذر غيره من التجار بضرورة الوفاء بديونهم في مواعيدها^٥ ، ولا ريب أن هذه القسوة في المعاملة تهدف إلى دعم الائتمان التجاري^٥.

٧- النفاذ المعجل

النفاذ المعجل: هو تنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن فيه بطرق الطعن العادية ، أو رغم حصول الطعن فيه بإحدى هذه الطرق^٥. والقاعدة أن الأحكام لا يجوز تنفيذها جبراً ، ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً ، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به^٥. أما الأحكام التجارية فانتظار التاجر فيها حتى يتم الطعن على الحكم ، أو نهاية المدة المحددة للطعن ، قد يفوت عليه فرصة إبرام صفقات تجارية ، لذلك نص المشرع على وجوب تنفيذ الحكم التجاري نفاذاً معجلاً وبشرط تقديم كفالة. وهناك حالات يكون النفاذ المعجل فيها واجباً وبغير كفالة.

٨- الإعذار

الإعذار هو وضع المدين موضع التأخر في تنفيذ التزامه بإثبات تأخره في الوفاء به^٥. والقاعدة العامة في المواد المدنية أن الإعذار يكون بإصدار المدين أي بمطالبته بالوفاء بمقتضى ورقة رسمية

تعلن إليه بواسطة قلم المحضرين بالمحكمة المختصة. والإعذار بهذه الوسيلة يناسب طبيعة المعاملات المدنية ، أما المعاملات التجارية وما تتسم به من سرعة واثمان ، فلا يجوز شل حركتها وتعطيلها بانتهاج ما قضى به القانون المدني في إثبات تقصير المدين بالوفاء بتعهداته^(١). لذلك أجاز المشرع التجاري إعذار المدين بأي وسيلة كتابية دون اشتراط أن يكون بورقة رسمية^(٢) ، فقد نصت المادة ٥٨ تجاري على أنه (يكون إعذار المدين أو إخطاره في المواد التجارية بإنذار ، رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، ويجوز في أحوال الاستعجال أن يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية أو توكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة). وبهذا النص يكون المشرع التجاري قد سائر الاتجاهات الحديثة للتقنية المتطورة ، وأجاز استخدامها في إعذار المدين في المواد التجارية دون اشتراط الرسمية في الإخطارات ، كما أن النص المشار إليه يسمح بقبول أي وسيلة من وسائل الاتصال تظهر حديثاً لتكون وسيلة من وسائل الإعذار في الالتزامات التجارية بجانب وسائل الاتصال الحديثة والمعروفة لدينا.

٩- الفوائد

أ- الفوائد التأخيرية

يقصد بالفوائد القانونية: تلك التي تستحق دون اتفاق عليها لتعويض الدائن عما أصابه من ضرر ، قد يلحق به جراء تأخر المدين في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود. وطبقاً للمادة ٢٢٦ مدني فإنه (إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره).

وكما هو ملاحظ من النص فإن مقدار الفائدة المقررة على التأخير في الوفاء بالدين الذي محله مبلغ من النقود في المعاملات المدنية يختلف عنه في المعاملات التجارية ، ففي المسائل المدنية يتحدد مقدار الفائدة القانونية بأربعة في المائة. أما في المسائل التجارية فيتحدد مقدار الفائدة بخمسة في المائة. ولعل السر في زيادة الفائدة في المسائل التجارية عنها في المدنية يرجع إلى أن الاستغلال التجاري ربحه أكثر من الاستغلال المدني ، كما أن المخاطر في الديون التجارية أكثر

منها في الديون المدنية؛ لأن الديون التجارية عرضة لعدم الاستيفاء نظراً لما يصاحب استثمارها من مضاربات ، بالإضافة إلى احتمالية إفلاس التاجر المدين ، كما أن رفع سعر الفائدة في الدين التجاري يحث على سرعة الوفاء به.

ب- الفوائد الاتفاقية

هذا النوع من الفوائد ترك المشرع أمر تقديرها لإرادة الأطراف حسب ما يقرره الاتفاق بينهم ، غير أن المشرع وضع حداً أقصى لهذا النوع من الفوائد فلا يجوز للأطراف أن يتجاوزوه. فطبقاً للمادة ٢٢٧ مدني يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أو في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد ، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة. فإذا اتفق الأطراف على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها -بقوة القانون- إلى سبعة في المائة وتعين ردّ ما دفع زائداً على هذا القدر. فالالتزام بهذه القاعدة من النظام العام فلا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها. وطبقاً للمادة ٢٣٢ مدني لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.

أما في المسائل التجارية فليس هناك ما يمنع -طبقاً للمادة ٦٤ تجاري من زيادة مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن على المبلغ الذي احتسب العائد عليه ، ما دامت الأعراف التجارية قد جرت بذلك أو نص عليه القانون.

وتسري الفوائد القانونية في المسائل المدنية من تاريخ المطالبة القضائية ، أما في المسائل التجارية فتسري الفوائد من تاريخ استحقاق الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

الفصل الثاني

الأعمال التجارية بالطبيعة

الأعمال التجارية بالطبيعة هي تلك الأعمال التي تصطبغ بالصبغة التجارية بصرف النظر عن صفة القادّم بها سواء كان تاجراً أم غير تاجر حتى لو باشرها الشخص مرة واحدة وبصفة عارضة^(١) كالشراء لأجل البيع أو اشترط المشرع ممارستها على وجه الاحتراف كالصرافة

(١) د/ فايز رضوان المصدر السابق ص ٩٦.

والسمسرة وعمليات البنوك.

وقد ورد ذكر الأعمال التجارية بالطبيعة في المواد الرابعة والخامسة والسادسة من قانون التجارة الجديد ، وقد جاء ورودها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر فقط نصت المادة ٧ تجاري على أنه (يعتبر عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة في المواد السابقة - أي المواد ٤ ، ٥ ، ٦ - لتشابه في الصفقات).

ونتناول دراسة الأعمال التجارية بالطبيعة كما ورد تنظيمها في قانون التجارة الجديد وذلك في مباحث ثلاثة

المبحث الأول: الأعمال التجارية المنفردة.

المبحث الثاني: الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف.

المبحث الثالث: أعمال التجارة البحرية والجوية.

المبحث الأول

الأعمال التجارية المنفردة

تنص المادة الرابعة من قانون التجارة على أنه (يعد عملاً تجارياً:-

أ- شراء المنقولات أيّاً كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى ، وكذلك بيع أو تأخير هذه المنقولات.

ب- استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات.

ج- تأسيس الشركات التجارية.

وطبقاً لهذا النص فإن هذه الأعمال تخضع لأحكام القانون التجاري بصرف النظر عما إذا كانت هذه الأعمال موضوع احتراف أم لا ، وسواء تمت في إطار مشروع اقتصادي أم لا. ونلاحظ هذا أن الشراء لأجل البيع والاستئجار لأجل التأجير عملاً مظهران للمضاربة على المنقولات ، لذلك تجمع بينهما في إطار تحليلنا للشراء لأجل البيع والذي يعقبه تحديد المقصود بتأسيس الشركات التجارية وذلك في مطلبين اثنين:

المطلب الأول: الشراء لأجل البيع.

المطلب الثاني: تأسيس الشركات التجارية.

المطلب الأول الشراء لأجل البيع

أورد المشرع الشراء لأجل البيع على رأس قائمة الأعمال التجارية ، نظراً لأن هذا العمل التجاري بشكل النسبة الغالبة من الأعمال التجارية ، كما أنه عمل تتبلور فيه فكرة المضاربة التي تمتاز مع فكرة تداول الثروات التجارية.

ويشترط لاعتبار العمل تجارياً توافر ثلاثة شروط: ١- أن تتم عملية الشراء. ٢- أن ينصب الشراء على مال منقول. ٣- أ ، يتم الشراء بقصد البيع أو التأجير.

الشرط الأول: أن تتم عملية الشراء

يقصد بالشراء- هنا- الحصول على مال مملوك للغير بمقابل سواء كان هذا المقابل مبلغاً من المال أو عيناً منقولة فيصدق الشراء على المقايضة^(١). أما إذا كان اكتساب الشخص الملكية المنقول بوسيلة غير الشراء كالهبة أو الإرث مثلاً فلا يعتبر اكتسابه تجارياً على هذا النحو: وبالمثل لا يعتبر تجارياً التصرف بهذه الطريقة فيه بعد الحصول عليه^(٢).

وكذلك لا تعد عمليات بيع المحاصيل الزراعية والعمليات الاستخراجية من قبل الأعمال التجارية لعدم سبق الشراء ، فقد نصت المادة التاسعة تجارى على أنه (لا يعد عملاً تجارياً بيع الزراع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكا لها أو مجرد منتفع بها).

وكما يعتبر الشراء لأجل البيع عملاً تجارياً فكذلك الشراء بقصد التأجير عملاً تجارياً ، وقد أكد قانون التجارة الجديد ما استقر عليه القضاء - قبل صدور هذا القانون- من اعتبار الشراء بقصد التأجير عملاً تجارياً^(٣).

ومن الأمثلة على الشراء بقصد التأجير من يشتري سيارة بقصد إعدادها للتأجير ، وكذلك من يشتري ملابس بصد تأجيرها ، ويقع التأجير على منفعة المال وليس على ملكيته ، فيلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين خلال مدة محددة بمقابل معلوم ، لا يلزم أن يكون هذا المقابل نفوذاً فيجوز أنه يكون المقابل منفعة معينة تعود على المؤجر.

(١) على حسن يونس السابق ص ١٧.

(٢) د. على جمال الدين السابق ص ٣٣.

(٣) د. مصطفى كمال طه مبادئ القانون التجاري رقم ٣٦/د/محمد حسني عباس المصدر السابق ج ١ رقم ٩٧.

الشرط الثاني: أن ينصب الشراء على مال منقول

يشترط كي يعتبر الشراء عملاً تجارياً - طبقاً لنص المادة الرابعة تجاري- أن ينصب هذا الشراء على منقول سواء كان ذلك المنقول مادياً كالبضائع علي اختلاف أنواعها ، أو كان المنقول معنوياً كمن يشتري الصكوك التي تصدرها الشركات بقصد بيعها وتحقيق فروق الاسعار وكشراء المحال التجارية ، وكذلك يعتبر عملاً تجارياً شراء المنقول بحسب المال كما هو الحال في شراء المنزل بقصد هدمه وبيعه أنقاضاً.

وقد كان قانون التجارة القديم يعتبر المضاربة على العقارات ضمن الأعمال المدنية حتى جاء قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المادة الخامسة منه فأخذ بما أخذت به التشريعات الحديثة من اعتبار شراء العقارات وتشيدها واستئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة يعد عملاً تجارياً إذا كانت مزاولته على وجه الاحتراف. ويعتبر شراء المنقول عملاً تجارياً سواء تم بيع المنقول بعينة دون أي تهية له كمن يشتري أقمشة وبيعهها كما هي ، أو بعد تهيته وتحويله إلى شيء آخر ، كمن يشتري قمحاً ليطحنه وبيعه دقيقاً. وإذا نصب الشراء على شيء يعتبر في ذاته عنصراً ثانوياً في البيع فإن الشراء لا يعتبر عملاً تجارياً كقيام مثال بشراء قطعة من الحجر أو الرخام لينحتها تمثالاً

الشرط الثالث: أن يتم الشراء بقصد البيع أو التأخير

يجب لاعتبار العمل تجارياً أن يكون شراء المنقول بقصد بيعه أو تأجيله بهدف الحصول على الربح ، بصرف النظر عن كون من اشترى المنقول تاجراً أو غير تاجر ، مادام قد توافرت لدية نية البيع أو التأجيل وتحقيق الربح وقت الشراء سواء حصل على ربح فعلاً أم لا ، فمثلاً لو قام شخص بشراء سيارة بقصد بيعها ثم رأي أن يحتفظ بها لنفسه فإن الشراء يعتبر عملاً تجارياً ، وبالعكس لو اشتراها بقصد استعمالها ثم أثر بيعها بعد ذلك ليحصل على ربح فلا يعتبر عمله تجارياً.

وإثبات توافر نية البيع وقت الشراء التأجيل وقت الشراء أو الاستئجار من المسائل الموضوعية التي يستقل به قاضي الموضوع ، ويقع إثبات هذه النية على من يدعي تجارية العمل. ويمكن إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات تطبيقاً لمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية

المطلب الثاني

تأسيس الشركات التجارية

تنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون التجارة على أنه (يكون تاجراً كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيّاً كان الغرض الذي أنشأت الشركة من أجله) ولا يعد عقد الشركة التجارية صحيحاً إلا إذا انصب على شركة من الشركات الست المعروفة قانوناً.

وطبقاً لنص المادة الرابعة من قانون التجارة فإن تأسيس الشركات التجارية يعد عملاً تجارياً. ويقصد بتأسيس الشركة التجارية جميع العمليات والتصرفات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركة منذ لحظة تقديم طلب التأسيس للجهات المعنية وانتهاء باتخاذ إجراءات الشهر والعلانية وقيد الشركة بالسجل التجاري ؛ حيث لا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية ولا تبدأ أعمالها إلا بعد القيد بالسجل التجاري.

والقصد من اعتبار تأسيس الشركات التجارية عملاً تجارياً خضوع المؤسسين للالتزامات التجارية وهي التزامات أشد وأقصى من الالتزامات المدنية.

المبحث الثاني الأعمال التجارية بالاحتراف

بجانب الأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون التجارة الجديد والتي تمثل الاتجاه المادي لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري , نجد أن المشرع قد أخذ بالاتجاه الشخصي في تحديد تجارية بعض الأعمال والتي اشترط المشرع وقوعها على سبيل الاحتراف.

وقد ورد تعداد هذه الأعمال في المادة الخامسة من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ . وحتى يتسنى لنا عرضها ببساطة ووضوح فإننا نقسم هذه الأعمال التي تكتسب صفتها التجارية من كثرة وقوعها إلى ثلاثة أقسام رئيسة وذلك في ثلاثة مطالب

المطلب الأول: الحرف الإنتاجية

المطلب الثاني: حرف التداول

المطلب الثالث: حرف الخدمات

المطلب الأول الحرف الإنتاجية

يقصد بالحرف الإنتاجية : تلك الحرف التي يترتب علي مزاولتها خلق لقيم جديدة ، وتحدد هذه الأعمال في الصناعة والعمليات الاستخراجية ومشروعات تربية الحيوان والمقاولات العقارية والأشغال العامة وذلك علي التفصيل الآتي :

أولاً : الصناعة

يقصد بالصناعة : تحويل المواد الأولية إلى مواد نصف مصنعة ، أو إلى مواد كاملة الصنع ، كصناعة المنسوجات من القطن أو السكر من القصب ، كما يعد من الصناعة إضفاء هيئة جديدة على السلعة المصنعة أصلاً ، كتجفيف المواد الغذائية وتعليبها^(١) وقد توسع القضاء في تفسير مدلول الصناعة بحيث يشمل الأعمال التي يترتب عليها تعديل للأشياء يرفع من قيمتها أو يزيد من استخدامها . ومن أمثلة هذا التوسع اعتبار ورش إصلاح السيارات من قبيل مقاولات الصناعة التي تعتبر من الأعمال التجارية.

وقد نصت الفقرة . ب . من المادة الخامسة من قانون التجارة علي اعتبار الصناعة من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها علي وجه الاحتراف . وتعتبر الصناعة من الأعمال التجارية سواء قام الصانع بشراء المواد الأولية اللازمة للصناعة وقام بتحويلها ، أو قدمت إليه هذه المواد من الغير ليقوم هو بتصنيعها . ويرى بعض الفقه أنه في حالة شراء الصانع للمواد الأولية وقيامه بتصنيعها ، فإنها لا تكتسب تجاريتها علي أساس أنها من أعمال الصناعة ، وإنما علي أساس أنها شراء لأجل البيع ، ويقتصر هذا الفقه الأعمال الصناعية فقط علي مجرد قيام الصانع بتصنيع مواد أولية قدمت إليه .

وتعتبر الصناعة عملاً مدنياً إذا كانت تابعة لعمل مدني وكانت غير مقصودة لذاتها كما هو الحال في الزارع الذي يصنع منتجات أرضه الزراعية بالوسائل البسيطة المعتادة . أما إذا أصبحت الصناعة هي العمل الرئيس وارتبط بها نشاط زراعي تابع لها ، فإن الصفة التجارية تنسحب علي هذا العمل باعتباره فرعاً يتبع الأصل ، كمن يزرع قطناً لاستخدامه في مصنع لغزل ونسج القطن .

ولا تنسحب الصفة التجارية علي الأعمال الصناعية التي تقتصر علي مباشرة الشخص للعمل بمفرده أو بمساعدة أحد أفراد أسرته أو عدد من الصبية ، حيث إن عملهم هذا يكون أقرب إلي بيع الإنتاج والمهارة الشخصية منه إلي المضاربة كعمل الخياط والسباك والنجار وغيرهم من أصحاب الحرف .

ثانياً : المقاولات العقارية

بيننا سابقاً أن المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد ساير الاتجاهات الحديثة باعتباره المضاربات العقارية من الأعمال التجارية ، ولا يقتصر المضاربات العقارية علي أعمال تشييد العقارات فقط ، وإنما تمتد لتشمل مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها(مادة ٥/ل تجاري).

ولا يشترط لسحب الصفة التجارية علي هذه الأعمال أن يلتزم المقاول بتقديم الأدوات والمواد والعمالة اللازمة للعمل العقاري ، بل يكفي أن يقتصر دوره علي تقديم الأيدي العاملة فقط ، بينما يقدم رب العمل المواد والأدوات اللازمة لتلك الأعمال .

ثالثاً : العمليات الاستخراجية

يقصد بالعمليات الاستخراجية نشاط استخراج الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنايع النفط وغيرها من صور استغلال الثروات الباطنة في الأرض ، وتعتبر مواد الثروات الجوفية من معادن وأحجار ونفط وغاز طبيعي من المواد الأولية التي يقوم علي استغلالها عدد كبير من الصناعات . وقد كان العرف . قبل صدور قانون التجارة الجديد . مستقراً علي اعتبار الثروات الطبيعية من باطن الأرض هي أعمال مدنية وليست أعمالاً تجارية ، فلما صدر قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ نصت المادة ٥/ي تجاري علي اعتبار تلك الأعمال أعمالاً تجارية إذا باشرها الشخص علي سبيل الاحتراف .

رابعاً : مشروعات تربية الحيوان

اعتبرت الفقرة . المادة ٥/ك تجاري مشروعات تربية الحيوان من دواجن ومواشي وغيرها بقصد بيعها من الأعمال التجارية إذا وقعت علي وجه الاحتراف . ونري أن المشرع لم يوفق حين ضمن هذه الأعمال ضمن الأعمال التجارية التي تتم علي وجه الاحتراف ، حيث إن بيع تلك الحيوانات غالباً ما يسبقه شراء فيكون العمل تجارياً ولو تم علي سبيل الانفراد وليس الاحتراف طبقاً للمادة الرابعة تجاري .

خامساً : الأشغال العامة

عقد الأشغال العامة هو عقد مقاوله بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وبين مقاول

-فرد أو شركة- بمقتضاه يتعهد المقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء أو التعديل أو الصيانة لحساب " الشخص العام " تحقيقاً لمصلحة عامة مقابل مبلغ محدد في العقد .
وقد ورد النص علي تجارية هذه الأعمال بالمادة ٥/ل تجاري حيث جمع النص بينها وبين المضاربات العقارية .

المطلب الثاني حرف التداول

تضم مجموعة حرف التداول عدداً من الأنشطة تتميز بأنه يتم من خلالها تداول الأموال سواء كانت أموالاً منقولة أم عقارية ، وتتمثل تلك الأنشطة في توريد السلع والخدمات ، وعمليات البنوك والصرافة ، والبيع بالمزاد ، والوكالة التجارية ، والسمسرة. ونبين كل واحدة منها بالتفصيل المناسب .

أولاً : توريد السلع والخدمات

اعتبرت الفقرة (أ) من المادة الخامسة تجاري أعمال توريد السلع والخدمات من الأعمال التجارية التي تتم علي وجه الاحتراف.
ويقصد بعقود التوريد هي تلك العقود التي يلتزم فيها المقاول بتسليم الطرف الآخر كميات من الشئ الذي حصل التعاقد بشأنه بصفة دورية ومنتظمة خلال فترة زمنية معينة كمن يتعهد بتوريد اللحوم والخضروات إلي الجيش أو إلي إحدى المستشفيات ، وقد يكون توريد السلع والخدمات مجرد استعمالها ثم ردها للمورد مرة أخرى كتوريد الملابس والمناظر والمقاعد لفرق مسرحية .
وعقد التوريد من العقود الزمنية أي عقد من عقود المدة التي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه ، ويتم تنفيذه دورياً علي فترات منتظمة ، ونذهب مع الرأي الراجح إلي اعتبار توريد السلع والخدمات هو من طبيعة تجارية ، حتي ولو لم يسبقه شراء للأشياء محل العقد ، وذلك لقيام المورد بتوريد ما ينتجه أو ما يحصل عليه من أرضه الزراعية .

ثانياً : عمليات البنوك والصرافة

طبقاً للفقرة (و) من المادة الخامسة من قانون التجارة فإن عمليات البنوك والصرافة تعد من قبيل الأعمال التجارية التي تتم علي وجه الاحتراف .

ويقصد بعمليات البنوك والصرافة هي تلك العمليات التي تقوم بها عادة المصارف خدمة لعملائها ، كفتح الحسابات الجارية واستلام الودائع النقدية وغير ذلك من العمليات التي تقوم بها البنوك. كما يقصد بعمليات الصرافة مبادلة نقود وطنية بنقد آخر أجنبي أو نقود ذهبية بنقود ورقية ، وتتم هذه المبادلة إما بالتسليم المباشر ويسمي الصرف المحلي Local وإما أن يكون تسليم النقود في مكان واستلام النقود الأخرى في مكان آخر ويسمي الصرف المسحوب .

وتعتبر جميع عمليات البنوك تجارية بصرف النظر عن نوع النشاط الذي يقوم به البنك أو طبيعة العملية ذاتها ، أما بالنسبة للعميل فلا يكون العمل تجارياً إلا إذا توافرت شروط العمل التجاري بالتبعية . كما تعتبر عملية مبادلة النقود تجارية بالنسبة للصراف أما العميل فلا يعد العمل تجارياً بالنسبة له إلا إذا كان عملاً تابعاً لعمل تجاري أو متعلقاً بتجارته .

ثالثاً : البيع بالمزاد

البيع بالمزاد هو كل بيع يستطيع أي شخص حضوره حتي لو اقتصر المزد علي طائفة معينة من الأشخاص ، ويتم لمن يقدم أعلي ثمن .

ولما كان قانون التجارة القديم لا يعتبر المضاربة علي العقارات من الأعمال التجارية فقد اتجه الفقه إلي قصر تجارية البيع بالمزاد العلني علي المنقولات دون العقارات ، ولكن بعد صدور القانون التجاري الجديد واعتباره المضاربات العقارية من الأعمال التجارية ، فإن بيع المزد الواردة علي العقار تعتبر من الأعمال التجارية إذا وقعت علي سبيل الاحتراف .

رابعاً : السمسرة

تعرف السمسرة بأنها الوساطة في إبرام عمل معين بين متعاقدين بهدف حصول السمسار . القائم بالعمل . علي عمولة معينة من قيمة الصفقة مقابل جهده في التقريب بين وجهة نظر المتعاقدين .

وفي المادة ٥ / د تجاري فإن السمسرة من الأعمال التجارية التي تقع علي وجه الاحتراف حيث نصت علي أنه (يعد عملاً تجارياً الوكالة التجارية والسمسرة أياً كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار) .

وإذا تم تكليف السمسار من جانب واحد فقط سميت السمسرة بالسمسرة البسيطة ، أما إذا تم تكليف السمسار من طرفي العقد سميت بالسمسرة المزدوجة ، ولا يعتبر السمسار وكيلًا عن أي واحد من أطراف العقد ، ولا يستحق السمسار أجرة إلا إذا نجح في التقريب بين الطرفين وتم إبرام العقد ويبقي الأجر مستحقاً إن لم يتم تنفيذ هذا العقد ، ويبقي عمل السمسار تجارياً سواء انصبت السمسرة علي صفقة تجارية أو صفقة مدنية .

خامساً : الوكالة التجارية

نظم قانون التجارة الجديد عقد الوكالة التجارية في المواد من ١٤٨ إلي ١٦٥ تجاري وقد نصت المادة ١٤٨ علي أن (أحكام الوكالة التجارية تطبق إذا كان الوكيل محترفاً إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير) .

وهو ما يعني أن الشرط الجوهري لاعتبار الوكالة تجارية بجانب شرط الاحتراف أن يكون محلها إجراء معاملات تجارية أي أن الوساطة في إبرام العقود المدنية لحساب الغير لا تعتبر من قبيل

الوكالة التجارية ولا تخضع لأحكام القانون التجاري .

وينظم أعمال الوكالة التجارية القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ وهو تنظيم لمزاولة مهنة الوكالة التجارية ويحدد شرط مزاومتها سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات. وقد عرفت المادة الأولى من هذا القانون الوكيل التجاري بأنه (كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بصفة معتادة دون أن يكون مرتبطاً بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء. ويمارس الوكيل التجاري أعمال التمثيل التجاري أو الصناعي علي وجه الاستقلال ، ويتعاقد باسم ولحساب الموكل في مقابل عمولة .

وقد يتعاقد الوكيل مع الطرف الآخر باسمه الشخصي وليس باسم موكله فيظهر الوكيل أمام من يتعاقد معه بوصفه الأصيل في التعاقد مما يترتب عليه تحمله شخصياً مسؤولية عدم تنفيذ العقد .

المطلب الثالث

حرف الخدمات

يقصد بالحرف الخدمية تلك الأعمال المرتبطة بالإنتاج السلعي من جهة وتهدف لإشباع حاجات الجمهور بقضاء مصالحهم من جهة أخرى .

وطبقاً لما تقضي به المادة الخامسة من قانون التجارة فإنه يمكننا أن نحصر هذه الأعمال والتي تعتبر تجارية . إذا وقعت علي سبيل الاحتراف . في الأنشطة التالية :

أولاً : الملاهي العامة

يقصد بالملاهي العامة تلك الأعمال التي يكون الغرض منها تسلية الجمهور في مقابل أجر ، فتشمل المسارح ودور السينما والسيرك وحدائق الملاهي وسباق الخيل .

وقد نصت الفقرة . المادة ٥ / س تجاري علي تجارية هذه الأعمال إذا وقعت علي سبيل الاحتراف ، فإذا كان القيام بهذه الأعمال علي سبيل العرض وليس الاحتراف فلا تعد أعمالاً تجارية ولا تخضع لأحكام القانون التجاري ، وإذا مارست الدولة هذه الأنشطة وقامت بفتح مسرح أو ملهي لتسلية الجمهور مقابل أجر كان النشاط الخاص بهذا الملهي تجارياً ، وانسحب هذا الوصف لالتزاماتها المتعلقة بتشغيله. لكن لا يكتسب شخص القانون العام القائم بهذا النشاط التجاري وصف التاجر .

ثانياً : وكالات الأعمال

تعد الأنشطة التي تقوم بها وكالات الأعمال تجارية طبقاً للمادة ٥/ ح تجاري والتي ذكرت صوراً لهذه الأنشطة ومنها أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في النشر والطباعة والتصوير والكتابة علي الآلات الكاتبة وغيرها والترجمة والإذاعة والتليفزيون والصحافة ونقل الأخبار والبريد والاتصالات والإعلان ، وهذا التعداد من الفقرة (ح) لصور تلك الوكالات مذكور علي سبيل المثال وليس الحصر

ولا تنسحب الصفة التجارية هنا علي الإنتاج الذهني أو الإبداع الفكري نفسه ، كتأليف كتاب أو رواية أو قصة أو رسم إذ تبقي هذه الأعمال مدنية ، ولكن إذا تم استغلال هذا الإبداع الذهني أو الفكري في صورة مشروع بهدف تحقيق ربح فيعتبر هذا العمل تجارياً كدور لنشر الكتب .

ثالثاً : النقل

النقل هو التحريك المادي للأشخاص أو الأشياء من مكان القيام إلي مكان الوصول مقابل أجر معين . وقد نصت الفقرة . ج . من المادة الخامسة علي تجارية أعمال النقل البري والنقل في المياه الداخلية . مياه الأنهار . إذا وقعت علي سبيل الاحتراف . ونلاحظ هنا ان المشرع لم يضمن نفس الفقرة النقل البحري . وكذلك النقل الجوي وذلك لأن هذين النوعين من النقل تنسحب عليهما الصفة التجارية بنص الفقرة . د . من المادة السادسة تجاري . ويعتبر النقل تجارياً بالنسبة للنقل ، أما المسافر أو صاحب السلعة المنقولة فيبقي عمله مدنياً إلا إذا كان تاجراً وكان النقل متعلقاً بشئون تجارته فينسحب علي عمله الصفة التجارية بالتبعية .

وبالنص علي تجارية حرفة النقل يكون المشرع قد حسم خلافاً ساد في الفقه التجاري في ظل القانون القديم حول تجارية عمل مالك السيارة الأجرة الذي يقودها بنفسه ، فلا ريب أنه بعد صدور القانون الجديد فإن هذا العمل يعتبر تجارياً إذا وقع علي سبيل الاحتراف .

وتعتبر عمليات النقل التي تتولاها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة كالسكك الحديدية كالمواصلات العامة في المحافظات ، فإن هذه الأعمال تعتبر تجارية وتخضع لأحكام القانون التجاري ، فقد قضت محكمة النقض بأن (مصلحة البريد تعتبر أمينة للنقل ووكيلة بالعمولة في الوقت نفسه ويعتبر عملها تجارياً تحكمه مواد القانون التجاري والتي توجب عليها نقل الرسائل

والطرد وسلامة وصولها وتسليمها للمرسل إليه وتحمل مسؤولية الهلاك والتلف والتأخير) .

رابعاً : الإيداع

نظم القانون التجاري الإيداع في المستودعات العامة في الفصل الرابع من الباب الثاني بالمواد من المادة ١٣٠ إلى المادة ١٤٧ ، وقد تعرضت المادة ١٣٠ لتعريف عقد الإيداع في المستودعات العامة فعرفته بأنه (عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسليم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضي الصكوك التي تمثلها) . ومن صور هذه المستودعات مخازن إيداع البضائع بالموانئ ، ومخازن الأثاث ، ومخازن المحاصيل الزراعية الموجودة بالريف . وطبقاً للفقرة ٥ من المادة ٥ تجاري فإن أعمال استيداع البضائع ووسائل النقل والمحاصيل تعد أعمالاً تجارية إذا وقعت علي سبيل الاحتراف .

خامساً : مقالة التأمين

يقصد بالتأمين ذلك العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص يسمي المؤمن بأن يؤدي لشخص آخر يسمي المستأمن مبلغاً من المال أو إيراد مرتب أو عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن منه مقابل أقساط يدفعها المستأمن للمؤمن .

وقد نص المشرع بالمادة ٥/هـ تجاري علي تجارية التأمين بجميع أنواعه إذا وقع علي سبيل الاحتراف . ونري أن الصفة التجارية لا تنسحب علي التأمين الذي لا يهدف لتحقيق ربح كالتأمين التعاوني أو التبادلي وهو التأمين الذي يلتزم فيه مجموعة من الأشخاص بدفع اشتراكات معينة تدفع منها التعويضات المناسبة عند تعرض أحد المشتركين لخطر -ما- فإذا تبقي شئ منها ردت إلي المشتركين ، وكذلك التأمين الاجتماعي الذي ترعاه صناديق التكافل الاجتماعي في بعض المصالح الحكومية فلا يعد هذا النوع من التأمين تجارياً لعدم استهدافه الربح .

سادساً : استغلال برامج الحاسب الآلي والبت الفضائي عبر الأقمار الصناعية :

طبقاً لما تقضي به المادة الخامسة من قانون التجارة فقرة ٥ ط . فإن الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبت الفضائي عبر الأقمار الصناعية تعد من الأعمال التجارية إذا وقعت علي سبيل الاحتراف . وطبقاً لما تقضي به المادة الأولى من القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن حماية المؤلف والمعدل بالقانونين رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ وبالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٤ فإن

برامج الحاسب الآلي تعد من المصنفات الدبية والفنية ، وبالتالي فهي أعمال مدنية وليست أعمالاً تجارية ولكن استغلالها بهدف تحقيق ربح من ورائها كنسخها من أجل بيعها وتسويقها هو الذي يعد عملاً تجارياً. كما اعتبر المشرع مشروعات البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية عملاً تجارياً إذا وقع علي سبيل الاحتراف ، وتحتوي هذه الأقمار علي قدر كبير من القنوات التلفزيونية يؤجر بعضها لشبكات الإذاعة والتلفزيون مقابل مبالغ نقدية كبيرة ، ونظراً لأن هذه الأنشطة تحتاج في ممارستها لتنظيم فني خاص وتقع كلها بهدف تحقيق ربح وبالتالي فهي من قبيل أعمال مضاربة ، لذلك كان المشرع موفقاً حيث اعتبرها ضمن الأعمال التجارية التي تتم علي وجه الاحتراف .

سابعاً : توزيع مصادر الطاقة

نصت الفقرة . ع . من المادة الخامسة تجاري علي تجارية الأعمال التي تتعلق بالمياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة ، وقد كانت هذه الأعمال من الأعمال التي تحتكرها الدولة لتعلقها بالحاجات الضرورية للأفراد في المجتمع ، ولكن بعد اتجاه الدولة إلي إسناد تلك الخدمات لبعض أشخاص القانون الخاص أصبح لزاماً تحديد النظام القانوني الذي تخضع له هذه الخدمات ، فجاء قانون التجارة الجديد مواكباً للاتجاه الحديث للدولة .

ولما كانت هذه الأعمال تقع علي سبيل المضاربة ويهدف تحقيق الربح ، إذ إنها تقوم بالحصول علي تلك المصادر من المنابع الطبيعية لها أو تقوم باستيرادها مقابل مبالغ مالية ، ثم تقوم بإعادة توزيعها مرة أخرى علي العملاء ، ومن ثم أدخلها المشرع في نطاق الأعمال التجارية التي تتم مزاولتها علي وجه الاحتراف .

المبحث الثالث

أعمال التجارة البحرية

تنص المادة السادسة من القانون التجاري علي أنه (يعد عملاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية) . ويقصد بالملاحة التجارية البحرية والجوية استغلال السفن والطائرات في تقديم خدمات للغير مقابل أجر. أما الاستخدامات الخاصة للسفن أو الطائرات كالانتقال الفردي أو للزهة فلا تعد من قبيل الملاحة التجارية ولا تخضع للقانون التجاري .

وقد ضمن المشرع في المادة السابقة صوراً من أعمال التجارة البحرية والجوية وهي:

بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها .

شراء وبيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات .

شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات .

النقل البحري والنقل الجوي .

عمليات الشحن أو التفريغ .

استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات.

وقد جاء ذكر هذه الأعمال علي سبيل المثال وليس الحصر ، ومن الواضح أن هذه الأعمال تعتمد في تجارتها علي استغلال مجهز السفينة أو الطائرة لهذا النشاط علي سبيل المضاربة ، كما أنه يسهم في تداول الثروات التجارية . ويدخل ضمن أعمال التجارة البحرية استغلال السفن في تقديم خدمات القطر أو الارشاد ، إذ إن هذه الأعمال تمثل بعض صور استغلال السفن بهدف الربح .

الفصل الثالث

الأعمال التجارية بالتبعية

التاجر كغيره من الناس يباشر العديد من الأعمال منها ما يتعلق بعمله التجاري ، ومنها ما يتعلق بحياته الشخصية كالزواج والنفقة علي الأولاد والسكني والطلاق وغير ذلك ، أما عن الأعمال التي تتعلق بحياته الشخصية فهي تبقي بالنسبة له أعمالاً مدنية ولا تنسحب عليها الصفة التجارية ، أما الأعمال التي تتعلق بعمله التجاري أو بشخصه كتاجر حتي ولو كانت في الأصل مدنية إلا أنها تكتسب الصفة التجارية لتبعية العمل التجاري أو لشخص التاجر ، ما لم يثبت عكس ذلك. فقد نصت المادة الثامنة من القانون التجاري علي أنه يعد عملاً تجارياً (١). الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته . ٢. كل عمل يقوم التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت عكس ذلك) .

فالعمل التجاري بالتبعية هو عمل مدني وإنما يكتسب الصفة التجارية بتبعيته لعمل تجاري ك شراء صاحب مطعم دراجة بخارية لتوصيل الطلبات للعملاء في منازلهم ، فالشراء هنا لم يكن بقصد

البيع ، ونبين في هذا الفصل التأصيل التي قامت عليه نظرية الأعمال التجارية بالتبعية وشروط تطبيقها في مبحث أول ، وكذلك تطبيقات نظرية الأعمال التجارية بالتبعية وذلك في مبحث ثان .

المبحث الأول

تأصيل نظرية الأعمال التجارية بالتبعية

وشروط تطبيقها

المطلب الأول

تأصيل نظرية الأعمال التجارية بالتبعية

يقصد بتأصيل نظرية الأعمال التجارية بالتبعية بيان الأساس الذي تستند عليه تلك النظرية سواء من الوجهة المنطقية أو من الناحية القانونية .

أولاً : الأساس المنطقي لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية

لما كانت أعمال التاجر كثيرة ومتشعبة ، ولما كان نشاطه الأساسي هو العمل التجاري فإن المنطق يقضي بإخضاع جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر للقانون الذي يحكمه وهو القانون التجاري عدا ما كان منها مرتبطاً بحياته الشخصية ، تطبيقاً لقاعدة الفرع يتبع الأصل . كما أن توحيد النظام القانوني لأعمال التاجر يوفر علي القاضي مشقة البحث في طبيعة العمل الذي يقوم به التاجر هل هو عمل مدني أم عمل تجاري؟ كما أن توحيد النظام القانوني للتاجر يوفر حماية للغير الذي يتعامل مع التاجر لإقدامه علي التعامل مع التاجر وهو يعلم أن القانون الذي يحكم نشاط التاجر هو القانون التجاري .

ثانياً : الأساس القانوني لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية

تستند نظرية الأعمال التجارية بالتبعية في العمل بها إلي نصوص القانون التجاري ، فالمادة التاسعة من القانون التجاري السابق كانت تنص علي تجارية جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والسماسرة والصيارفة ما لم تكن العقود والتعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها أو

بناءً على نص في العقد .

وقد توسع الفقه والقضاء في هذا النص معتبرين أن جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر ما دامت مرتبطة بتجارته فهي أعمال تجارية ، وما لم يكن منها مرتبطاً بتجارته فتبقي كما هي أعمال مدنية ، ولما صدر القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أكد هذه النظرية ففطن نظرية الأعمال التجارية بالتبعية وأصلها بالمادة الثامنة منه والتي تنص على أن (١). الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية . ٢. كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت عكس ذلك).

المطلب الثاني

شروط تطبيق الأعمال التجارية بالتبعية

طبقاً لنص المادة ٨ تجاري فإنه يلزم لتطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية توافر الشروط الآتية :

١- أن يكون القائم بالعمل تاجراً

يشترط لتطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية أن يكون القائم بالعمل تاجراً ، وذلك تطبيق للمادة العاشرة من القانون التجاري والتي نصت على أنه يكون تاجراً (كل من يزاو على وجه الاحتراف باسمه وحسابه عملاً تجارياً) . يستوي أن يكون التاجر فرداً أو شركة كما أن المعول عليه في كون الشخص تاجراً أو غير تاجر ليس بما يصف به التاجر نفسه ، ولا بما يصفه به غيره ، ولا بقيد اسمه في السجل التجاري ، ولكن باعتياده القيام بالأعمال التجارية واتخاذها حرفة له .

٢- أن يكون العمل متعلقاً بأعمال تجارية

لا يكفي لتطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية أن يكون القائم بالعمل تاجراً فقط ، بل يشترط بجانب ذلك أن يكون العمل تابعاً لعمل تجاري حتي تنسحب عليه الصفة التجارية ك شراء التاجر سيارة لخدمة المحل التجاري ، فمثل هذا العمل وإن كان في الأصل مدنياً إلا أنه يكتسب الطبيعة التجارية لمباشرته من قبل تاجر وبسبب أعماله التجارية .

أما إذا كان العمل الذي قام به التاجر غير متعلق بتجارته ك شرائه سيارة للاستعمال الشخصي فإن هذا العمل يظل على أصله مدنياً ولا يكتسب الصفة التجارية لعدم تعلقه بعمل تجاري.

وقد اعتبر نص المادة ٨ تجاري جميع أعمال التاجر أعمالاً تجارية إلا إذا أثبت التاجر عكس ذلك ، أي أن قرينة تجارية العمل التجاري ليست قاطعة بل هي قرينة تقبل إثبات العكس .

المبحث الثاني

تطبيقات الأعمال التجارية بالتبعية

التصرفات التي يقوم بها التاجر قد تكون عقدية وقد تكون غير عقدية ، ولم تفرق المادة ٨ تجاري في تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية بين التصرفات العقدية وغير العقدية ، ومنتناول تلك التطبيقات في مطلبين اثنين احدهما للتصرفات العقدية والآخر للتصرفات غير العقدية .

المطلب الأول

تطبيقات نظرية الأعمال التجارية بالتبعية

علي التصرفات العقدية

يتطلب العمل التجاري من التاجر أن يبرم العديد من العقود من أجل تيسير وإتمام عمله التجاري ، وتتولد عن هذه العقود مجموعة من الالتزامات يجب علي التاجر الوفاء بها ، كالعقد الذي يبرمه التاجر مع متعهد الأثاث لشراء أثاث أو آلات أو وسائل نقل لازمة لمتجره ، حتي ولو لم يكن هذا الشراء بقصد البيع فإن جميع هذه الالتزامات المتولدة عن هذه العقود تعتبر أعمالاً تجارية لتبعيةها لعمل تجاري . وليست كل هذه العقود علي درجة واحدة من ناحية الاعتراف بتجاريته ، فهناك عقود كانت مثار تساؤلات حول اعتبارها من الأعمال التجارية كعقد الكفالة ، والعقود المتعلقة بشراء وبيع المحل التجاري ، والعقود المتعلقة بالعقارات .

أولاً : عقد الكفالة

هو عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه . ويكفل الكفيل المدين دون أن يحصل علي أجر ، إذ الأصل فيها أنها عقد من

عقود التبرع ، وتتم الكفالة بقبول الدائن لها ، ولذلك يعتبر عقد الكفالة عقداً مدنياً حتي ولو كان الدين المكفول تجارياً وكان الكفيل أو المكفول تاجراً . ومع اعتبار الكفالة مدنياً فالرأي مستقر علي تجارية عقد الكفالة في بعض الفروض:

١- إذا كانت الكفالة متصلة بعمل تجاري أصلي ، كأن تكون الكفالة لضمان أحد الموقعين علي ورقة تجارية متي كان سحب الورقة أو تحريرها يعتبر عملاً تجارياً ، لأنه من قبيل العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية .

٢- إذا كان الكفيل والمكفول تاجرين وكانت بينهما علاقات مصلحة متبادلة

٣- الكفالة الصادرة من البنك ، إذ إن جميع الأعمال الصادرة من البنك تعد أعمالاً تجارية .
وقد جاء نص المادة ٤٨ تجاري في فقرتها الأولى حاسماً في مسألة تجارية الكفالة إذ نص علي أنه (لا تعتبر كفالة الدين عملاً تجارياً إذا نص القانون علي ذلك أو كان الكفيل بنكاً أو كان تاجراً وله مصلحة في الدين المكفول).

ثانياً : العقود المتعلقة بشراء وبيع المحل التجاري

طبقاً لما تقضي به المادة ٤/أ تجاري فإنه إذا قام التاجر بشراء المحل التجاري بقصد بيعه فإنه يعتبر عملاً تجارياً علي سبيل الانفراد ، كما يعد شراء المحل التجاري عملاً تجارياً حتي ولو لم يكن بقصد البيع ، كما لو قام تاجر بشراء متجر بقصد استغلاله في ممارسة مهنته فإنه يعتبر عملاً تجارياً بالتبعية .

ويثور الخلاف حول شراء شخص -لم يكتسب بعد وصف التاجر- محلاً تجارياً لبدأ فيه نشاطه التجاري ، فهل يعد هذا الشراء عملاً مدنياً أم تجارياً ؟ ذهب بعض الفقه - وبحق - إلي تجارية عقد شراء المتجر من جانب شخص لم يكتسب بعد وصف التاجر ؛ تطبيقاً لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية ، حيث إن اتجاه إرادته للاحتراف التجارة يظهر من شرائه للمتجر وهو من أهم أدوات التاجر في ممارسة التجارة ، وهذه النية للاحتراف تضيف صفة التجارية علي الأعمال التي تعتبر مقدمة لازمة للاحتراف .

وقد ذهب البعض الآخر من الفقه إلي التفرقة بين حالتين

الحالة الأولى : إذا كان شراء التاجر للمتجر بهدف ممارسة تجارته فيه فإن عقد الشراء يعد عملاً تجارياً بالتبعية .

الحالة الثانية : إذا كان هدفه من الشراء هو مجرد تأجير المحل التجاري إلي تاجر ليستخدمه في

تجارته ، فإن عقد الشراء يعد عملاً مدنياً من جانب المشتري لعدم تحقق المضاربة في هذا العمل

ونري أن العقد . هنا . يعد عملاً تجارياً في حق المشتري ولكن ليس بالتبعية ، وإنما علي سبيل
الانفراد تطبيقاً للمادة ٤/أ تجاري والتي تعتبر شراء المنقولات بقصد تأجيرها يعد عملاً تجارياً علي
سبيل الانفراد ، ولما كان المتجر منقولاً معنوياً فيدخل شراؤه بقصد تأجيريه تحت حكم هذه المادة

ثالثاً : العقود المتعلقة بالعقارات

أثرت النظرة التقليدية للعقار وإخراجه من المعاملات التجارية علي العقود الواردة علي العقار من
ناحية تجاريتها حتي ولو كانت هذه العقود تعتمد علي شراء العقار بقصد بيعه بهدف تحقيق
الربح ، فهذه العقود تأثرت بالنظرة التقليدية واعتبرها الفقه . أعمالاً مدنية لورودها علي العقار ،
ولهذا لم يكن الفقه التقليدي يميل إلي تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية علي العقود المتعلقة
بالعقارات حتي ولو كانت صادرة من تاجر وبمناسبة عمله التجاري.

ويستبعد الاتجاه الفقهي والقضائي الحديث تلك النظرة التقليدية للعقار فيضيفان الصفة التجارية
علي العقود الواردة علي العقار ، غير إن هذا الاتجاه يفرق بين العقود المتعلقة بالعقار وتعلق
بترتيب حق عيني ، وتلك التي تولد التزامات شخصية ، فأضيفي الصفة التجارية علي الطائفة
الثانية. وأبقي الطائفة الأولى علي صفتها المدنية ولم يسحب عليها الصفة التجارية.

وفي رأينا وعلي الأخص بعد إقرار القانون التجاري الجديد لتجارية المضاربات الواردة علي العقار
بالمادة الخامسة في فقرتها (ل) و (م) فإن جميع العقود الواردة علي العقار ، وتعلق بممارسة
التاجر لتجارته حتي لو كانت ترتب حقوقاً عينية أو كانت منصبة علي حق ملكية العقار يطبق
عليها نظرية الأعمال التجارية بالتبعية إلا ما كان منها متعلقاً بحاجات التاجر الشخصية ،
كشرائه عقاراً للزواج فيه أو لاستخدامه في مشروع خيري كمكتبة عامة لطلاب العلم .

المطلب الثاني

تطبيقات نظرية الأعمال التجارية بالتبعية

علي التصرفات غير العقدية

قد تؤثر التصرفات غير العقدية سلباً في ذم التاجر فتحمله بالتزامات يجب عليه الوفاء بها ، ومن
أمثلتها العمل غير المشروع الذي يصدر منه أثناء ممارسته لمهنة التجارة ، ويستوي في ذلك أن

يكون العمل صادراً منه شخصياً أو من أحد تابعيه الذي يعملون لديه ، وقد تؤثر تلك التصرفات غير العقدية بالإيجاب في ذمة التاجر ومن أمثلتها الإثراء بلا سبب كالالتزام برد ما قبضه من الغير دون حق .

وقد استقر الرأي علي تطبيق نظرية الأعمال بالتبعية علي الالتزامات التي يتحملها التاجر بسبب عمله غير المشروع المتعلق بأعمال تجارته كالالتزام التاجر بالتعويض عن أعمال المنافسة غير المشروعة التي قد تقع منه إضراراً بتاجر آخر . كأن يسئ لسمعته التجارية أو أن يستخدم علامته التجارية أو عنوانه التجاري ، وكذلك مسؤولية التاجر في مواجهة الغير عن غش بضائعه . كما يطبق ذات المبدأ في شأن مسؤولية التاجر عن الأضرار التي قد تقع بفعل مستخدميه أو خطأهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها ، كما يطبق ذات المبدأ بسبب الأفعال الضارة الناشئة عن الأشياء التي يستخدمها في تجارته ، فيعتبر تجارياً التزام التاجر بالتعويض عن الأضرار التي أحدثتها سيارته أثناء نقلها البضائع المعدة للتسليم للعملاء .

وكما تعتبر الالتزامات الناشئة في ذمة التاجر نتيجة فعله غير المشروع تجارية إذا كانت بسبب مباشرته لتجارته ، فكذلك الالتزامات التي يتحملها التاجر نتيجة فعل نافع وقع لصالحه فإنه يعتبر أيضاً تجارياً ، تطبيقاً لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية كقيام فضولي بعمل حقق من ورائه نفعاً لهذا التاجر ، فإن دعوي استرداد ما أنفقه هذا الفضولي تكون دعوي تجارية يخضع فيها التاجر لأحكام القانون التجاري .

الفصل الرابع

الأعمال التجارية المختلطة

لم ينص القانون التجاري علي الأعمال التجارية المختلطة كما فعل بالنسبة لغيرها من الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية ، والسر في ذلك يرجع إلي أن الأعمال التجارية المختلطة ليست طائفة من الأعمال قائمة بذاتها كالأعمال التجارية الأصلية أو التبعية ولكنها أعمال مختلطة لا تخرج عن نطاق الأعمال التجارية عموماً .

وقد بحث فقهاء القانون تلك الأعمال المختلطة تحت ضغط من الحاجة العملية والتي تظهر في ضرورة تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق علي الأعمال التي يكون أحد أطرافها تاجراً

والطرف الآخر غير تاجر ، وتدفعنا دراسة تلك الأعمال إلى تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين اثنين ، نتناول في المبحث الأول منهما المقصود بالأعمال المختلطة ، وفي الثاني نتناول الآثار المترتبة علي تلك الأعمال .

المبحث الأول المقصود بالأعمال التجارية المختلطة

يقصد بالعمل التجاري المختلط هو ذلك العمل الذي يعتبر تجارياً بالنسبة لأحد أطرافه ومدنياً بالنسبة للطرف الآخر ، ك شراء المستهلك بعض السلع من أحد التجار أو قيام التاجر بشراء بعض المحاصيل الزراعية من أحد المزارعين وكشراء الطلب كتاباً من أحدي المكتبات المختصة ببيع وتوزيع الكتاب الجامعي ، وهكذا تتعدد صور هذه الأعمال وتكثر بحجم وقوعها وتكرارها في حياتنا اليومية . ولا يعني أن العمل المختلط يكون تجارياً بالنسبة لأحد الأطراف ومدنياً بالنسبة للطرف الآخر أن يكون العمل ذا طبيعتين مختلفتين ، إذ ان العمل له صفتان بالنظر إلى تعلقه بنشاط كل طرف من أطرافه فهو تجاري بالنسبة للتاجر ومدني بالنسبة لغير التاجر .

وتمتد تلك الأعمال المختلطة لتشمل الأعمال التجارية الأصلية والأعمال التجارية التبعية ، فشراء التاجر محلاً تجارياً أو أثاثاً لمحله التجاري من غير تاجر يعد عملاً تجارياً تبعياً بالنسبة للتاجر المشتري ومدنياً بالنسبة للبائع ، كما تطبق الأعمال التجارية المختلطة علي مسؤولية التاجر الناجمة عن الفعل الضار أو الفعل النافع.

فالزام التاجر بتعويض أحد العملاء نتيجة تناوله طعاماص فاسداً ألحق به ضرراً يعد تجارياً في حق التاجر بينما يعد مدنياً في حق العميل . ويذهب جانب من الفقه إلى حد اعتبار الأعمال المختلطة طائفة ثالثة من الأعمال التجارية بجانب العمال التجارية الأصلية والأعمال التجارية التبعية . ومن جانبنا نري أن هذه الأعمال لا تمثل طائفة ثالثة في تقسيمات الأعمال التجارية . إذ أنه لا تكون تجارية إلا من جانب واحد فقط وهو جانب التاجر دون الطرف الآخر الذي يعد العمل في حقه مدنياً .

المبحث الثاني الآثار المترتبة علي الأعمال التجارية المختلطة

هناك بعض الآثار التي تترتب علي اختلاف صفة العمل التجاري المختلط بالنظر إلى كل طرف من أطرافه ، وأهم هذه الآثار يتمثل في اختلاف تطبيق القواعد القانونية التي تطبق علي كل

طرف من أطراف المعاملة ؛ حيث تطبق قواعد القانون التجاري علي التاجر الذي يعتبر العمل بالنسبة له تجارياً ، بينما تطبق قواعد القانون المدني علي الطرف الآخر والذي يعتبر العمل بالنسبة له مدنياً وذلك علي النحو التالي :

أ . الاختصاص

تقضي القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بأن الاختصاص بنظر الدعوي يثبت لمحكمة موطن المدعي عليه ، غير إن تطبيق هذه القاعدة قد يضر بالمدعي إذا كان العمل تجارياً بالنسبة للمدعي عليه ، لأن تطبيق تلك القاعدة يقتضي رفع الدعوي أمام القضاء التجاري وربما يجهل المدعي إجراءات التقاضي أمام القضاء التجاري ، ومن هنا نجد أن الرأي قد أستقر في الفقه والقضاء علي أن المدعي في هذه الحالة يكون مخيراً في رفع دعواه بين القضاء التجاري أو القضاء المدني ، أما إذا كان العمل مدنيا بالنسبة للمدعي عليه وتجارياً بالنسبة للمدعي فلا يكون أمام المدعي من خيار سوي رفع دعواه أمام القضاء المدني .

ب . الإثبات

لما كانت قواعد الإثبات في القانون التجاري تختلف عن قواعد الإثبات في القانون المدني ، فإنه يترتب علي ذلك الاختلاف في تطبيق قواعد الإثبات علي الأعمال المختلطة بالنظر لكل طرف علي حده ، فتطبق قواعد الإثبات التجارية في مواجهة الشخص الذي يعد العمل تجارياً في حقه ، بينما تطبق قواعد الإثبات المدنية في حق الشخص الذي يعتبر العمل بالنسبة له مدنياً . ومن المعلوم أن وسائل الإثبات تكون مقيدة في المسائل المدنية بينما تكون حرة في المسائل التجارية ؛ حيث يجوز في هذه الأخيرة اللجوء إلي كافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن مهما كانت قيمة النزاع ، ولا تلازم بين المحكمة المرفوع أمامها الدعوي والقانون الواجب التطبيق ، فقد ترفع الدعوي أمام المحكمة التجارية وتطبق قواعد الإثبات الخاصة بالقانون المدني .

وقد خرج القضاء علي قواعد الإثبات في العمل المختلط باستثنائين هما:

١- يمكن للتاجر اتباع قواعد الإثبات التجارية ويثبت معاملاته بكافة طرق الإثبات تجاه الطرف الآخر الذي يعتبر العمل في حقه مدنياً إذا كان يقتصر عمله علي نفي ادعاء الطرف الآخر أي أثناء دفاعه لإثبات أنه وفي بالتزامه التجاري .

٢- يمكن للتاجر في حالة الاستحالة المعنوية والتي تحول بين التاجر وبين استلزام الدليل الكتابي

في كل عملياته أن يثبت تلك العمليات بكافة طرق الإثبات في مواجهة الطرف الآخر الذي يكون العمل في حقه مدينياً .

ج . الرهن والفائدة

من الصعوبة بمكان الفصل بين الجانب المدني والجانب التجاري فيما يتعلق بالرهن وسعر الفائدة في إطار العمل المختلط ، بحيث تطبق قواعد القانون المدني علي الطرف الذي يعد العمل في حقه تجارياً ، فنظام الرهن التجاري يختلف عن نظام الرهن المدني في إثباته وتنفيذه ، كما أن سعر الفائدة في الرهن التجاري يختلف عن سعر الفائدة في الرهن المدني ، وقد يكون الرهن مدينياً في حق طرف بينما هو تجاري في حق الطرف الآخر فأني قواعد الإثبات نطبق ؟ وأي سعر للفائدة نأخذ به ؟ هل نأخذ بسعر الفائدة المدني أم نأخذ بسعر الفائدة التجاري ؟ وليس من المنطق أن نقرر للدائن سعر الفائدة المدنية . مثلاً . لأن العمل في جانبه مدني ، وأن تقرر في نفس الرهن سعر الفائدة التجاري علي المدين لأن الرهن تجاري في حقه ، فلا يستقيم ذلك لأنه سيؤدي إلى الازدواجية في سعر الفائدة عن الرهن الواحد.

ومن هنا فقد استقر الفقه والقضاء علي النظر إلي المدين وما يتصف به العمل المختلط في حقه ، فإذا كان الرهن في حقه مدينياً طبق علي هذا الرهن قواعد الإثبات والتنفيذ وسعر الفائدة المدنية ، وبالعكس إذا كان الرهن في حقه تجارياً طبقت القواعد الخاصة بالرهن وسعر الفائدة في القانون التجاري .

وقد خرجت محكمة النقض المصرية^(١) ، عن هذا المبدأ في بعض أحكامها فقررت أن (القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض أيا كان الغرض الذي خصص له القرض). وطبقاً لهذا الحكم تخضع القروض التجارية البنكية من ناحية الإثبات وسعر الفائدة لأحكام القانون التجاري وليس المدني.

الباب الثاني

التاجر

رأينا أن المشرع المصري في تحديده لنطاق تطبيق القانون التجاري لم يقتصر على النزعة المادية

فقط ، بل أخذ بالنزعة الشخصية بجانب النزعة المادية فوضع قواعد خاصة بالتجار لا تطبق على غيرهم من الأشخاص المدنيين.

وقد عرف القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في مادته العاشرة التاجر بأنه (كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً ، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله). وتتجلى فائدة تعريف القانون للتاجر وتمييزه عن غيره في النواحي الآتية:

١- يتمتع التجار وحدهم دون غيرهم من الأشخاص المدنيين بعض الحقوق والمزايا كحق الانتخاب في الغرف التجارية وكذلك الترشيح لعضوية هذه الغرف ، كما أنهم يتمتعون بمزية اختيارهم كأعضاء في المحاكم التجارية في الدول التي تأخذ بنظام القضاء التجاري كما هو الحال في فرنسا والكويت.

٢- تختلف الأهلية القانونية في التاجر لمباشرة الأعمال التجارية عن الأهلية المطلوبة في غير التاجر لمباشرة الأعمال المدنية.

٣- بجانب هذه الحقوق التي يتمتع بها التجار فإن القانون قد فرض عليهم مجموعة من الالتزامات والتي لا يلتزم بها غيرهم ممن لم يكتسب وصف التاجر ، ومنها الالتزام بمسك الدفاتر التجارية والقيّد في السجل التجاري وشهر النظام المالي للزواج وخضوعهم لنظام الإفلاس وهو أشد وأقسى من نظام الإعسار المدني.

٤- تخضع طائفة التجار لأنواع خاصة من الضرائب لا يخضع لها غير التجار كخضوعهم للضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل.

٥- تخضع الشركات التجارية في إنشائها لأوضاع وإجراءات خاصة لا تخضع لها الشركات المدنية.

وسوف نخصص هذا الباب لدراسة الحكم التي تتعلق بالتاجر كشخص طبيعي تاركين دراسة التاجر كشركة تجارية لموضعها ، ونقسم هذا الباب إلى فصلين اثنين:-

الفصل الأول: شروط اكتساب وصف التاجر.

الفصل الثاني: الالتزامات المهنية لطائفة التجار.

الفصل الأول

شروط اكتساب وصف التاجر

يتضح من نص المادة العاشرة تجاري أن شرط اكتساب الشخص لوصف التاجر هو أن يزاول على وجه الاحتراف باسمه وحسابه عملاً تجارياً ، كما أن المادة الحادية عشرة تجاري تحدثت عن الأهلية اللازم توافرها في الشخص لممارسة التجارة ، ومن خلال هذين النصين فإننا نحدد شروط اكتساب وصف التاجر بشرطين اثنين نخصص لهما المبحثين التاليين:

المبحث الأول: احتراف الأعمال التجارية.

المبحث الثاني: توافر الأهلية التجارية.

المبحث الأول

احتراف الأعمال التجارية

يعد الاحتراف شرطاً جوهرياً لاكتساب الشخص وصف التاجر ، ونظراً لأهمية هذا الشرط في تحديد مركز الشخص من النظام القانوني للتجارة فإننا نفصل الكلام فيه في المطالب الآتية:-

المطلب الأول: ماهية الاحتراف.

المطلب الثاني: محل الاحتراف.

المطلب الثالث: إثبات الاحتراف.

المطلب الرابع: بدء الاحتراف وانتهائه.

المطلب الأول

ماهية الاحتراف

يقصد بالاحتراف أن يقوم الشخص بالعمل بصفة متكررة ومستمرة ومنتظمة بحيث يعتمد عليه كمصدر لرزقه^(١). فإذا قام الشخص بالعمل بصفة عارضة فلا يعد محترفاً ولا يكتسب وصف التاجر حتى لو خضعت الأعمال أو العمل الذي يقوم به لحكم القانون التجاري.

وقد حاول بعض الفقه أن يخرج بفكرة الاحتراف من الدائرة القانونية إلى الدائرة الاجتماعية فعرفه بأنه (توجيه النشاط بشكل رئيسي ومعتاد للقيام بعمل معين بقصد الربح أو بأنه مباشرة نشاط يتخذ وسيلة لتعيش صاحبه وإشباع حاجاته)^(٢).

وقد عرف البعض الاحتراف بأنه (توجيه النشاط على نحو رئيسي ومعتاد للقيام بالأعمال التجارية سواء كانت أعمالاً تجارية مطلقة أو كانت من الأعمال التجارية التي يمارسها الشخص على وجه الاحتراف)^(١).

ويلزم حتى يتحقق الاحتراف أن يعتاد الشخص القيام بالأعمال التجارية بصفة منتظمة ومستمرة ، وعلى ذلك فالقيام بعمل تجاري ، أو أعمال تجارية متفرقة على نحو عارض ، لا يكفي لتكوين الاعتياد واكتساب صفة التاجر^(٢). اللهم إلا إذا تقرر ذلك على سبيل الاستثناء ، فقد يكفي مباشرة العمل لمرة واحدة للقول بتوافر الاعتياد ، كما هو الحال فيمن يعلن للجُمهور عن تأسيس محل تجاري؛ مع أنه لم يباشر بعد الأعمال التجارية^(٣).

ولا يكفي مجرد اعتياد الشخص على القيام بالأعمال التجارية لاكتساب صفة التاجر ، بل يلزم أن يقصد الشخص من اعتياده لتلك الأعمال أن تكون حرفة له يتعيش ويرتزق منها^(٤). وبالتالي لا يعتبر تاجراً مؤجر العقار الذي يعتاد سحب الكمبيالات على المستأجرين لاستيفاء دين الأجرة؛ لأن سحب الكمبيالة وإن كان يعد عملاً تجارياً ، إلا أن مؤجر العقار لا يتعيش من مجرد سحب الكمبيالات ، بل من استغلاله للعقار^(٥).

وعلى العكس من ذلك ، فإنه يعتبر تاجراً من يقوم بشراء الأقطان كل عام في موسم حصاد القطن بقصد إعادة بيعه لتحقيق ربح من وراء هذا العمل ، فإنه يعد تاجراً على الرغم من أن الشراء لم يقع إلا مرة واحدة في العام ، إلا أنه أصبح حرفة له يتعيش من ورائها ، ولو لم تقع في العام إلا مرة واحدة.

فإذا كان احتراف الشخص للعمل التجاري هو عمله الذي يتعيش منه ، فلا يهم بعد ذلك أن يكون للشخص محل تجاري أو أن يمارس التجارة كبائع متجول ، ولا عبرة — في توافر صفة التاجر — بمقدار المال الذي يتكسبه الشخص التجارة^(٦) ، أو الحصول على ترخيص من عدمه.

ولا يلزم أن يستغرق احتراف التجارة كل حياة الشخص ، فيجوز أن تكون للشخص حرف متعددة ، بعضها تجاري وبعضها غير تجاري^(٧) ، كأن يجمع بين التجارة والزراعة ، أو بينها وبين وظيفة له في هيئة خاصة ، بل إن القضاء في فرنسا قد توسع في ذلك ، وقضى بأن يكتسب الشخص صفة التاجر متى احترف الأعمال التجارية ، حتى ولو كانت حرفته المدنية أو وظيفته هي التي تساعد على مزاوله الأعمال التجارية^(٨).

احتراف العمل التجاري من الفئات المحظور عليها العمل التجاري

ولا يؤثر على احتراف الشخص للتجارة واكتسابه صفة التاجر أن تمنع القوانين واللوائح بعض الأشخاص من القيام بأعمال تجارية كالقضاة^١ والمحامين ، والموظفين العموميين^٢. فقد نصت المادة ١٧ تجاري على أنه (إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة اعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام القانون التجاري).

فإذا باشر واحد من الفئات السابقة المذكورة التجارة ، اعتبر تاجراً وجاز شهر إفلاسه^٣ ، ولا يمنع اكتسابه صفة التاجر من تطبيق الجزاء الإداري المقرر طبقاً لقوانين المهنة التي ينتمي إليها. ففي حكم محكمة النقض المصرية بشأن ممارسة محام لأعمال تجارية حيث قضت بأن(القانون الذي ينظم مهنة المحاماة إذ ينص على عدم جواز أن يجمع المحامي بين مهنة المحاماة وبين الاشتغال بالتجارة. وأن كل ما يترتب على مخالفة هذا الحظر هو توقيع الجزاءات التأديبية التي نصت عليها المادة ٣٥ من قانون المحاماة رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧. مما مفاده أن المشرع لم يحرم على المحامي الاشتغال بالتجارة لعدم مشروعية محل الالتزام. بل نص على هذا الحظر لاعتبارات قدرها تتعلق بمهنة المحاماة)^٤. وحسناً فعل المشرع بإكسابه وصف التاجر لهذه الفئات المحظورة من التجارة عند ممارستها لها ، حتى لا تتخذ من الحظر المقرر سبيلاً للهروب من شدة وقسوة الأحكام التجارية.

وتعد مسألة الاحتراف من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض.

المطلب الثاني

محل الاحتراف

يقصد بمحل الاحتراف تلك الأعمال التي يباشرها الشخص على وجه الاحتراف - حتى يوصف بأنه تاجر ، ويشترط- طبقاً للمادة ١/١٠ تجاري- أن تكون الأعمال محل الاحتراف أعمالاً تجارية.

ويجب أن يكون احتراف الأعمال التجارية مقصوداً لذاته وليس وسيلة لتحقيق غرض أو إنجاز عمل بمعنى أن يكون الاحتراف بمزاولة نشاط رئيس لصاحبه ، أما إذا اقتصر العمل على خدمة أغراض النشاط الرئيسي فلا يعد ذلك احترافاً يكسب الشخص صفة التاجر كحالة المزارع الذي

اعتاد أن يدفع ديونه الزراعية بسحب كمبيالات على مدينه؛ إذ إن سحب الكمبيالات لا يصلح هنا أن يكون موضوعاً للاعتراف؛ لأنه ليس مقصوداً لذاته بل لتسوية عمليات أخرى مدنية فيكون موضوع الاعتراف هو العمليات الأخرى وليس سحب الكمبيالات.^(١) ولا يكفي لاكتساب الشخص وصف التاجر أن تكون الأعمال محل الاعتراف أعمالاً تجارية ، بل يشترط فوق ذلك أن تكون هذه الأعمال أعمالاً مشروعة^(٢) ، فلا يكتسب وصف التاجر من يباشر أنشطة محظورة قانوناً كمن يتاجر في المخدرات أو من يدير صالة للقمار أو للدعارة؛ حيث إن التاجر هو مركز قانوني ينظمه القانون ، ولا يتمتع بهذا المركز القانوني سوى من يباشر نشاطاً مشروعاً.

فصاحب التجارة غير المشروعة لن يلتزم بما يلتزم به التاجر من مسك الدفاتر والقيود في السجل التجاري ، كما أن أحكام القانون الجنائي والتي تهدف إلى تحقيق الردع العام تحول دون إضفاء صفة التاجر على هؤلاء الذين يمارسون أنشطة غير مشروعة حماية لمصلحة الغير حسن النية الذين تعاملوا معه دون علم بعدم مشروعة نشاطه^(٣).

أضف إلى ما تقدم أن قواعد النظام العام والآداب تكفل حماية المجتمع ممن يحاول أن ينال من أمنه ومنهم هؤلاء الذين يمارسون تلك الأنشطة المشبوهة ، فالمشرع التجاري حريص على انتقاء من ينتمي إلى مجتمع التجارة الذي يسوده مبدأ الثقة والائتمان بفرض قواعده الآمرة وجزاءاته الصارمة^(٤).

اكتساب الأشخاص الاعتبارية صفة التاجر

١- الشركات^(١)

نصت المادة ٢/١٠ تجاري على أنه (يعتبر تاجراً: - كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله.) . وطبقاً لهذا النص فإن اكتساب الشركات لصفة التاجر يتوقف على أحد معيارين:-

المعيار الأول: النشاط الذي تباشره الشركة

من المعلوم أن الشركة إنما تُؤسس لتحقيق غرض اقتصادي معين ، ولذلك فالشركة لا يكون لها حرفة ، بل غرض معين. وتتحدد أهلية الشركة بهذا الغرض الذي يتم النص عليه في عقد

تأسيسها. فإذا كان الغرض من إنشاء الشركة هو مباشرة نشاط تجاري ، فإن الشركة تكتسب صفة التاجر بصرف النظر عن الشكل الذي تتخذه الشركة. وبالتالي فإن الشركات التي تبشر نشاطاً مدنياً لا تكتسب صفة التاجر^(١).

المعيار الثاني: الشكل الذي تتخذه الشركة

طبقاً لهذا المعيار فإن الشركة التي تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها للشركات التجارية وهي: - أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ت- شركة المساهمة. ث- شركة المساهمة الخاصة. ج- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ح- شركة المحاصة.

وأخيراً فإنه إذا كانت الشركة تكتسب صفة التاجر ، إذا توافر أحد المعيارين السابقين ، فإن هذا الوصف لا يمتد إلى الشركاء فيها؛ لأن الشركة كشخص معنوي هي التي تبشر التجارة وليس الشركاء ، ومع ذلك فإن بعض الشركاء في الشركة يتمتعون بصفة التاجر لمجرد كونهم شركاء في شركة ، وهؤلاء هم الشركاء المتضامنون في شركات التضامن والتوصية البسيطة ، فالشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر حتى ولو لم يمارس عملاً تجارياً^(٢).

أما الشركاء غير المتضامين ، وهم الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة ، والشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، والمساهم في شركات المساهمة العامة والخاصة ، فكل هؤلاء لا تمنحهم شراكتهم في الشركة صفة التاجر بسبب مسئوليتهم المحدودة^(٣).

٢- الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات ذات النفع العام

قد تمارس الدولة أو أحد أشخاص القانون العام النشاط التجاري على وجه الاحتراف ، كقيام محافظة من المحافظات أو حي من الأحياء بإحدى المدن باستغلال مرفق النقل الداخلي ، فهل يكتسب شخص القانون العام صفة التاجر عند ممارسته للنشاط التجاري على وجه الاحتراف؟ نصت المادة ٢٠ تجاري على أنه (لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام . ومع ذلك تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التي تزاولها إلا ما يستثنى بنص خاص). وطبقاً لهذا النص فإن شخص القانون العام -إذا مارس النشاط التجاري- فإنه لا يكتسب صفة التاجر ؛ على اعتبار أن هذه الصفة تتعارض مع الوظيفة الأساسية للدولة ، وهي تقديم الخدمات للجمهور دون استهداف الربح.

وإذا كانت الدولة لا تكتسب وصف التاجر عند ممارستها للنشاط التجاري ، فإن ذلك لا يعني أن تفقد الأعمال التجارية التي تقوم بها الدولة طبيعتها التجارية ، بل تظل لها هذه الطبيعة وتخضع فيها الدولة لأحكام القانون التجاري ، كما هو نص المادة ٢٠ تجاري سالف الذكر؛ لأن الدولة إذا باشرت مجال الأعمال التي يمارسها الأفراد ، خضعت لنفس القوانين التي يخضعون لها^(١).

المطلب الثالث إثبات الاحتراف

يترتب على اكتساب الشخص صفة التاجر وثبوتها له أن يخضع في التزاماته لما تفرضه عليه أحكام القانون التجاري ، وإلحاق صفة التاجر بالشخص ليس مفترضاً ، وإنما يقع على من يدعيها عبء إثباتها ويتم ذلك بكافة وسائل الإثبات ، وقد تقوم قرائن على الاحتراف لا تكفي وحدها لإثبات الاحتراف وإنما تسترشد بها المحكمة لإثباته؛ إذ أنها مجرد قرائن بسيطة تقبل إثبات العكس كالقيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية^(٢). والقرائن على احتراف العمل التجاري كثيرة ، منها -مثلاً- فتح محل تجاري أو استثمار مبالغ ضخمة في التجارة. ولا يلزم لإثبات صفة التاجر أن يكون للشخص محل تجاري؛ إذ أن المحل التجاري ليس من مستلزمات احتراف التجارة فقد يباشر التاجر تلك الحرفة متجولاً^(٣) ، دون أن يملك محلاً تجارياً.

وإثبات احتراف الأعمال التجارية مسألة موضوعية يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع على ضوء وقائع الدعوى ودون رقابة عليه من محكمة النقض^(٤) غير إنه إذا لم يكن لمحكمة النقض مراقبة صحة الوقائع التي استخلصها قاضي الموضوع -لتوافر شرط الاحتراف- إلا إنها تراقب تكيف هذه الوقائع ، أي تراقب الوصف القانوني الذي أعطاه القاضي للشخص على ضوء ما تم استخلاصه من أدلة وقرائن

ولا يكفي إقرار الشخص على نفسه باحتراف التجارة لإثبات تلك الصفة سواء كان هذا الإقرار صريحاً كما هو الحال في الفواتير الصادرة عنه^(٥) ، أو ضمناً كما لو ادعى عليه شخص آخر أمام المحكمة بأنه تاجر ولم ينف المدعى عليه هذا الادعاء مما جعل المحكمة تأخذ به وتصدر حكمها بناء عليه معتبرة إياه تاجراً ودون تحقق فإن ذلك يعد خطأ وقصوراً في الحكم^(٦) ، ذلك أن صفة التاجر مسألة قانونية تتصل بالنظام العام ، فلا يتوقف وجودها على إرادة الأفراد وإنما لا بد من توافر شرائطها القانونية^(٧).

المطلب الرابع

بدء الاحتراف وانتهائه

١- بداية الاحتراف

لتحديد بداية الاحتراف ونهايته أهمية كبيرة تتمثل في أن الشخص الذي يكتسب صفة التاجر لن تطبق عليه أحكام القانون التجاري إلا خلال فترة احترافه للتجارة ، فلن تطبق تلك الأحكام قبل أو بعد نهاية فترة الاحتراف.

ويبدأ الاحتراف منذ أول عمل يقوم به الشخص متعلقاً بالمهنة وينتهي بانتهاء آخر عمل يأتيه الشخص بنية اعتزال تلك المهنة^١ ، هذا هو الأصل غير أنه قد يقوم الشخص ببعض الأعمال التحضيرية التي تسبق احتراف التجارة ، كشرائه أخشاباً لتصنيع أثاث المحل التجاري ، ومد الأسلاك الكهربائية للمصنع ، والتعاقد مع دور للدعاية والإعلان للإعلان عن افتتاح محل جديد فهل تعد تلك الأعمال التحضيرية أعمالاً مدنية أم أعمالاً تجارية؟

ذهب رأي^٢ إلى اعتبار هذه الأعمال التحضيرية أعمالاً تجارية بالتبعية؛ حيث إنها أعمال تمهيدية لاحتراف التجارة وتظل لها هذه الطبيعة سواء حقق المشروع نجاحاً أم لم يحقق.

بينما يذهب رأي آخر^٣ إلى اعتبار تلك الأعمال أعمالاً مدنية حسب أصلها ، ولا تنسحب عليها الصفة التجارية؛ لأن هذه الأعمال ليست أعمالاً تجارية أصلية ، ولكنها أعمال تجارية بالتبعية أي تبعاً لشخص القائم بالعمل ، أو تبعاً للعمل ذاته ، فإذا كان الشخص نفسه لم يكتسب صفة التاجر ، أو أن العمل لم يتم ، فكيف نعطي للفرع وصفاً لم يكتسبه الأصل ، وبالتالي تبقى هذه الأعمال مدنية ، إلا إذا اكتسب الشخص صفة التاجر فتعتبر أعمالاً تجارية بالتبعية.

ومن جانبنا فإننا نعتبر الأعمال التحضيرية أعمالاً تجارية بالتبعية ، حتى ولو لم يكتسب صاحب المشروع صفة التاجر بعد ؛ حيث إن هذه الأعمال التحضيرية أعمال لا يمكن للعمل التجاري المزمع القيام به أن يتم بدون هذه الأعمال ، فهي أعمال تجارية بالتبعية طبقاً للمادة ٨ تجاري والتي تنص على أن (١ - الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية . ٢ - كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك).

٢- نهاية الاحتراف

ينتهي احتراف الشخص للتجارة منذ توقفه عن ممارسة الأعمال التجارية بقصد اعتزال التجارة مما يترتب عليه أن يفقد الشخص صفة التاجر ، ولا يكفي مجرد التوقف المؤقت ليفقد الشخص صفة التاجر^(١) ، بل يجب أن تكون نية الشخص واضحة نحو إنهاء احتراف الأعمال التجارية. وقد ينتهي الاحتراف بشهر إفلاس التاجر ، أو بالحجر عليه ، كما ينتهي أيضا بوفاة شخص التاجر مع انتقال الالتزامات المترتبة في ذمته إلى ذمة ورثته ، دون أن تنتقل إليهم صفة التاجر إلا إذا احترفوا الأعمال التجارية بعد مورثهم ، فإنهم يكتسبون صفة التاجر على أساس احترافهم للتجارة وليس بصفتهم ورثة للتاجر المتوفى^(٢).

ولا يترتب على التوقف عن احتراف الأعمال التجارية فقدان الشخص لوصف التاجر بأثر رجعي ، فتبقى التزاماته السابقة على التوقف كما هي التزامات تجارية ، فيجوز شهر إفلاسه إذا اعتزل التجارة وكان متوقفاً عن دفع ديونه التجارية ، أو توفي وهو في حالة توقف عن الدفع^(٣) ، بشرط أن يتم طلب شهر الإفلاس خلال سنة من تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة ، فقد نصت المادة ١/٥٥١ تجاري على أنه (١- يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة ، إذا توفي أو اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع . ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة . ولا يسرى هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب إسم التاجر من السجل التجاري).

الاستقلالية في مباشرة الأعمال التجارية

لا يكفي احتراف الشخص للعمل التجاري حتى يكتسب صفة التاجر ، وإنما يلزم بجانب ذلك أن تكون ممارسته للعمل التجاري على وجه الاستقلال ، بمعنى أن يحترف الشخص الأعمال التجارية باسمه وحسابه.

وهنا يثور التساؤل عن وضع الشخص الذي يحترف العمل التجاري لحساب غيره ، هل يكتسب صفة التاجر أم لا؟

لا ريب أن الإجابة على هذا التساؤل تستوجب منا بيان حالة الشخص الذي يحترف العمل التجاري مستتراً وراء شخص آخر ، بالإضافة إلى بيان مدى اكتساب صفة التاجر لكل من مدير الشركة ، والعمال التابعين للتاجر ، ومستأجر المحل التجاري ، والممثل التجاري ، والوكيل

العادي ، والولي ، والوصي ، والقيم إذا باشروا التجارة لمن هم تحت رعايتهم؟

١- مدى اكتساب الشخص الظاهر والمستتر لصفة التاجر؟

قد يمارس شخص العمل التجاري مستتراً وراء شخص آخر ، بحيث يبدو من يظهر بمظهر التاجر كما لو كان يمارس العمل التجاري باسمه ولحساب نفسه ، مع أنه في الحقيقة ليس إلا ستاراً يخفي وراءه الشخص الحقيقي الذي يحترف العمل التجاري. وقد يكون السبب في استتار هذا الأخير راجعاً إلى حظر القانون لممارسته العمل التجاري كالقضاة والمحامين والموظفين العموميين ، وقد يتمثل هذا السبب في رغبة الشخص المستتر في عدم الإفصاح عن اسمه. ولا يهم -هنا- معرفة سبب الاستتار لأنه لن يؤثر في إثبات أو نفي صفة التاجر بالنسبة له أو بالنسبة للشخص الظاهر.

وقد كان المشرع التجاري حاسماً في معالجته لهذه الحالة ، فأضفى وصف التاجر على الشخص الظاهر حماية للوضع الظاهر ، حيث إن هذا الشخص هو الذي تعامل معه الناس وهو الذي كان محلاً لثقتهم ، ولذلك يكتسب صفة التاجر تطبيقاً لنظرية الوضع الظاهر ودعمها وحماية للثقة التي يقوم عليها العمل التجاري. أما الشخص المستتر فهو صاحب التجارة الحقيقي ، وهو من تنصرف إليه -في الحقيقة- آثار التصرفات التي يبرمها الشخص الظاهر ، فعدم إضفاء صفة التاجر عليه يحميه من الخضوع لقواعد القانون التجاري ، والتي تتسم بالشدة والصرامة حماية للثقة التجارية ، مما يجعل الباب مفتوحاً على مصراعيه للتحايل على الحظر القانوني في ممارسة العمل التجاري ، لذلك أضفى المشرع صفة التاجر -أيضاً- على الشخص المستتر منعاً له من التهرب من أحكام قانون التجارة ، فقد نصت المادة ١٨ تجاري على أنه (تثبت صفة التاجر لكل من احتترف التجارة باسم مستعار أو كان مستتراً وراء شخص آخر ، فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر).

٢- مديرو الشركات والمحلات التجارية

يمارس المدير في الشركة أو المحل التجاري العمل التجاري لحساب الشركة أو المحل الذي يديره ، وبالتالي فهو لا يحترف العمل التجاري على وجه الاستقلال ، وإنما يحترفه لحساب المحل أو الشركة التي تكتسب هي صفة التاجر. وبالتالي فالمدير لا يكتسب صفة التاجر ، ولا يخضع لقواعد القانون التجاري ، ولا يكون ملزماً بالقيد في السجل التجاري ، أو بمسك دفاتر تجارية.

ويستوي في هذا أن يكون المدير شريكاً^٥ أو غير شريك ، فهو لا يكتسب صفة التاجر بوصفه مديراً ، وسواءً كان مقابل إدارته راتباً شهرياً أو نسبة من أرباح الشركة؛ حيث إنه يكون تابعاً في ممارسته للعمل التجاري للشركة أو المحل الذي يديره.

٣- العمال والمستخدمون التابعون للتاجر

يستعين التاجر- في ممارسته للعمل التجاري- بعدد من العمال والمستخدمين ليعاونوه في إنجاز أعماله التجارية ، هؤلاء العمال والمستخدمون على الرغم أنهم يحترفون العمل التجاري ، إلا أنهم لا يكتسبون صفة التاجر ، ولا يخضعون لأحكام القانون التجاري؛ لأنهم لا يحترفون العمل التجاري لحساب أنفسهم ، بل لحساب التاجر الذي تربطهم به علاقة تبعية ناشئة عن عقد العمل. فهؤلاء العمال لا يكتسبون صفة التاجر حتى لو حصلوا على نسبة من الأرباح؛ لأنهم تابعون للتاجر وليسوا مستقلين عنه ، وهو ما لا يتحقق به شرط الاحتراف الذي يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر. هذا بالإضافة إلى أن آثار المروع تعود على رب العمل ، حتى لو اتفق على إشراكهم في الإدارة أو الأرباح فهم ليسوا تجاراً ؛ لأنهم تربطهم برب العمل علاقة تبعية.

٤- مستأجر المحل التجاري

قد يملك شخص محلاً تجارياً فيقوم بتأجيره لشخص آخر ، فهل يكتسب صفة التاجر كل من المؤجر-مالك المحل التجاري- والمستأجر؟ أم أن أحدهما فقط دون الآخر؟
لا ريب أن مستأجر المحل التجاري يحترف العمل التجاري باسمه ولحسابه ، ولا تربطه بمالك المحل التجاري أي علاقة ، اللهم إلا العلاقة الإيجارية التي يحكمها عقد الإيجار المبرم بينهما ، وبالتالي فإن مستأجر المحل التجاري يكتسب صفة التاجر؛ لاحترافه العمل التجاري باسمه ولحساب نفسه. أما مالك المحل التجاري فإنه لا يكتسب صفة التاجر ما دام لا يمارس العمل التجاري^٥.

٥- الممثل التجاري^٥

الممثل التجاري : شخص مفوض بأن يبرم الصفقات التجارية باسم موكله ولحسابه ، فهل يكتسب الممثل التجاري صفة التاجر؟
يتوقف إكساب الممثل التجاري صفة التاجر على نوع العلاقة التي تربطه بالتاجر أو بالمشروع الذي يمثله ، فإن كانت علاقة تبعية ناشئة عن عقد عمل فلا يكتسب الممثل التجاري صفة

التاجر؛ حيث إنه لا يستقل في مزاولته للعمل التجاري الذي يقوم به. أما إذا قام الممثل التجاري بممارسة بعض الأعمال التجارية لحسابه الخاص ، ودون أن يكون تابعاً فيها للتاجر أو للمشروع الذي يمثله ، كأن يتاجر في قطع غيار السيارات باسمه وحسابه ، بجانب قيامه-مثلاً- بتوزيع سيارات الشركة التي يمثّلها ، في مثل هذه الحالة يكتسب الممثل التجاري صفة التاجر؛ حيث إنه يحترف تجارة قطع غيار السيارات باسمه وحسابه دون أن تربطه في هذه التجارة علاقة تبعية بالشركة التي يمثّلها.

٦- الوكيل العادي

يختلف الوكيل العادي عن الوكيل بالعمولة ، فالأخير طبقاً للمادة ١٦٦ تجاري هو من يبرم باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل ، وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل. أما الوكيل العادي فهو من يتعاقد باسم الموكل وحسابه ووفقاً لأوامره وتعليماته ، كما تنصرف آثار التصرفات التي يبرمها الوكيل إلى ذمة الموكل وليس الوكيل^(١).

وينتج عن التفرقة السابقة بين الوكيل بالعمولة والوكيل العادي أن الأول يكتسب صفة التاجر ، بينما الوكيل العادي لا يكتسب صفة التاجر؛ والسبب في ذلك يرجع إلى أن الوكيل العادي لا يتمتع بأي استقلالية في العمل الذي يقوم به ، وإنما يخضع لتعليمات الموكل ناهيك عن انصراف آثار التصرفات التي يقوم بها إلى ذمة الموكل وليس إلى ذمة الوكيل. أما الوكيل بالعمولة فهو يكتسب صفة التاجر؛ نظراً لأنه يتمتع بالاستقلالية في ممارسة عمله التجاري ، وعلى الرغم أن التصرفات التي يبرمها تنصرف آثارها إلى ذمة الموكل ، إلا أن هذا في العلاقة بينه وبين الموكل ، أما بالنسبة في العلاقة مع من يتعاقد معه الوكيل بالعمولة فهو يظهر بمظهر الأصيل^(٢) ، لذلك فالوكيل بالعمولة يعتبر تاجراً ويلتزم بما يلتزم به التاجر.

٧- الولي والوصي والقيّم

الجامع المشترك بين كل من الولي ، والوصي ، والقيّم هو أن كل واحد من الثلاثة يتولى إبرام التصرفات عن شخص لا يقدر بمفرده على إبرامها ، إما للسن كولاية الأب لابنه الذي لم يبلغ سن الرشد ، أو رعاية الوصي لمن فقد أباه ولم يبلغ سن الرشد ، أو رعاية القيّم لمن بلغ سن الرشد ولكن تم الحجر عليه لسبب من الأسباب التي حددها القانون.

فإذا تولى الولي أو الوصي أو القيّم إدارة الأعمال التجارية لصالح من هم تحت رعايتهم ، فإنهم لا

يكتسبون صفة التاجر؛ لأنهم وإن كانوا يتمتعون باستقلالية في القيام بالعمل التجاري هنا ، إلا أنهم لا يقومون به لصالحهم وإنما لصالح الصبي أو المحجور عليه.

المبحث الثاني توافر الأهلية التجارية

طبقاً لما تقضي به المادة ١١ تجاري فإنه لا يكفي الاحتراف لاكتساب الشخص صفة التاجر ، بل بجانب الاحتراف أن تتوافر في الشخص الأهلية اللازمة لاكتسابه تلك الصفة. وتنوع الأحكام المتعلقة بالأهلية التجارية^(١) كما أن نظام الزواج قد يؤثر على تلك الأهلية بالنسبة للمرأة ، فبعض الشرائع الأجنبية ترحم على المرأة مباشرة التجارة بعد الزواج إلا بأذن الزوج لاعتبارات تتعلق بالنظام الذي تخضع له العلاقة المالية بين الزوجين الأسرة. وقد نظم قانون التجارة الجديد أحكام الأهلية التجارية في المواد ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ من قانون التجارة ، ثم تحدثت المادة ١٥ عن النظام المالي بين الزوجين ، وبالتالي فإننا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين اثنين نتناول في المطلب الأول منهما الأهلية التجارية للمصريين ، ونتناول في المطلب الثاني الأهلية التجارية للأجانب في مصر.

المطلب الأول

الأهلية التجارية للمصريين

على خلاف الشخص الطبيعي لا تتحدد أهلية الشخص الاعتباري ببلوغ سن معين ، وإنما تتحدد أهليته- طبقاً لما تقضي به المادة ٣٥ / ٢ مدني- بالأعمال اللازمة لمباشرة الغرض من تكوينه والموضحة بعقد إنشائه ، فالعمل غير المنصوص عليه في عقد تكوين الشخص الاعتباري لا تتوافر له صلاحية القيام به لخروجه عن حدود أهليته.

أما عن الشخص الطبيعي فإن أهليته تختلف باختلاف مرحلته السنية ، فهناك أشخاص يتمتعون بالأهلية التجارية الكاملة وهناك أشخاص ليسوا بكامل أهلية.

أولاً: أهلية الراشدين

تنص المادة ١١ - ١ تجاري على أنه (يكون أهلاً لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصراً في هذا السن) ، كما تقضي المادة ٤٤ مدني بأنه يكون راشداً من بلغ إحدى وعشرين سنة كاملة ولم يقم به عارض من عوارض الأهلية.^(١)

ومن خلال هاتين المادتين يتضح لنا أن الشخص لا يعتبر كامل الأهلية سواء أكانت أهلية مدنية أم أهلية تجارية إلا إذا بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية ، ولم يقم به عارض من عوارض الأهلية ، فإذا بلغ الشخص هذا السن كان له أن يبرم التصرفات القانونية وأن يحترف التجارة وأن يكتسب صفة التاجر سواء كان ذكراً أو أنثى أيأ كانت ديانته أو حالته الاجتماعية.^(٢)

ثانياً: القصر

ميز القانون في ممارسة التجارة بين القاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة وبين القاصر الذي لم يبلغ هذه السن وذلك على النحو التالي:-

أ- القاصر المأذون له في التجارة

أدرك المشرع أن بعض الأشخاص قد تكون لديهم القدرة على ممارسة التجارة غير أنهم لم يبلغوا سن الأهلية الكاملة فيؤدي عدم اشتغالهم بالتجارة إلى تعطيل تلك الطاقات وربما أدى ذلك إلى تفويت الفرصة على من يؤهل نفسه للاشتغال بالتجارة في التدريب على مزاولة الأعمال التجارية

، لذلك فقد أجاز القانون- بالمادة ١١ فقرة ب تجاري- لمثل هذا الشخص الذي بلغ سن الثامنة عشرة أن يمارس مهنة التجارة بشرط الحصول على إذن بذلك من المحكمة المصرية المختصة ، كما أجازت المادة ٥٧ من قانون الولاية على المال رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ لمن بلغ سن الثامنة عشرة أن يمارس التجارة بشرط الحصول على إذن من المحكمة المختصة^(١).

وإذا أصدرت المحكمة إذنها للقاصر بالالتجار فلها سلطة تقديرية في منح الإذن مطلقاً يبيح للقاصر القيام بأي عمل تجاري أو أن تمنحه إذناً مقيداً فيقتصر على بعض الأعمال التجارية دون البعض الآخر أو على نوع معين من التجارة ، كما أن للمحكمة أن ترفض منح القاصر إذناً بالالتجار^(٢).

وطبقاً للمادة ٦٤ من قانون الولاية على المال فإن القاصر يعتبر كامل الأهلية فيما أذنت فيه المحكمة من التجار ، فإن تجاوز القاصر حدود هذا الإذن بأن باشر أعمالاً لم تأذن له فيها المحكمة كان تصرفه في هذا العمل باطلاً بطلاناً نسبياً أي قابلاً للإبطال لمصلحته.

ولما كان القاصر المأذون له في التجارة يعتبر كامل الأهلية في حدود ما أذنت له المحكمة فإنه يكتسب وصف التاجر^(٣) ، فيفترض أن الأعمال التي يقوم بها تجارية إلى أن يثبت العكس^(٤)، كما أنه يلتزم بما يلتزم به التجار من مسك الدفاتر التجارية ويجوز شهر إفلاسه.

ويلتزم القاصر المأذون له في التجارة بتقديم حساب سنوي عن الأعمال التي قام بها ، فإن أهمل في تقديم هذا الحساب أو أساء التصرف أو خيف عليه من الضرر جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من النيابة العامة أو صاحب المصلحة الحد من الإذن للقاصر أو سلبه بعد سماع أقواله^(٥) ، وإذا رأت المحكمة سلب الإذن من القاصر أو تقييده فلا يكون لهذا السلب أو التقييد أثر على الأعمال التي تمت قبل سلب الإذن أو تقييده ، ويجب تسجيل طلب سلب الإذن أو تقييده في سجل يعد لذلك بقلم كتاب المحكمة المختصة بالإذن^(٦).

ولا يكون قرار المحكمة بسلب الإذن أو تقييده حجة على الغير حسن النية إلا من تاريخ تسجيل الطلب المقدم عنه ، فإذا لم يسجل الطلب فلا يكون قرار المحكمة حجة على الغير حسنة النية^(٧).

وإذا بلغ الشخص ثماني عشرة سنة ولم يحصل على إذن من المحكمة المختصة بالتجارة فليس له أن يمارس الأعمال التجارية ، فإن باشرها كانت أعماله قابلة للإبطال لمصلحته ولا يكتسب بهذه الأعمال وصف التاجر ، فإن قررت المحكمة بطلان تصرفات القاصر غير المأذون له فقد

وجب عليها أن تلزمه برد ما عاد عليه من نفع بسبب القيام بهذه الأعمال.^(١)

ب - القاصر دون الثامنة عشرة عاماً

إعمالاً للفقرة الثانية من المادة ١١ تجاري ، فإنه لا يجوز لمن تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاوّل التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشداً فى هذه السن أو يميز له الاتجار .

وبالتالى فإذا زاول القاصر الذى لم يبلغ الثامنة عشرة عاماً التجارة فإنه لا يكتسب صفة التاجر ، ولا يلتزم بالتزامات التجار كالقيد فى السجل التجارى أو مسك الدفاتر التجارية ، كما أن هذه التصرفات تكون قابلة للإبطال لمصلحة هذا القاصر إذا كان مميزاً أى تجاوز سن السابعة .
أما إذا كان القاصر غير مميز فإن أعمال هذا القاصر تقع باطلة بطلاناً مطلقاً . وليس لولي القاصر الذى لم يبلغ سن الثامنة عشر أو الوصي عليه أن يمارس تجارة مبتدأة باسم القاصر^(٢) .

أيلولة تجارة بطريق الميراث

يثور السؤال بشأن القاصر غير المأذون له أو الذى لم يبلغ سن الثامنة عشرة ، إذا آلت إليه تجارة عن طريق الميراث ، فهل يجوز لوليه الحصول على إذن من المحكمة بالاستمرار لمصلحة القاصر فى هذه التجارة؟

طبقاً للمادة ٢/١٢ تجاري فإنه إذا كان للقاصر الذى لم يبلغ الثامنة عشرة تجارة ورثها عن أحد والديه^(٣) ، فللمحكمة أن تأذن لولي هذا القاصر أو وصيه بالاستمرار فى هذه التجارة التى آلت إلى القاصر وفى حدود هذا الإذن ، دون أن يكون للمحكمة الحق فى أن تأذن له بإنشاء تجارة جديدة . ويصدر الإذن من المحكمة لولي القاصر أو وصيه بالاستمرار فى التجارة الموروثة بناء على مصلحة القاصر فى الاستمرار ، وعلى الأخص إذا كانت هذه التجارة ناجحة . وللمحكمة أن تمنح لولي القاصر أو وصيه إذناً مطلقاً أو مقيداً للقيام بالتصرفات التى تقتضيها التجارة . وللمحكمة طبقاً لما تقتضيه مصلحة القاصر أن تسحب الإذن أو تقيده من ولي القاصر أو وصيه ، إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب أو المأذون له فى التجارة ، ودون إخلال بالحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية .

وإذا منح الإذن للولي أو الوصي للاستمرار فى تجارة آلت إلى القاصر ، فلا يكتسب الولي أو الوصي صفة التاجر؛ لأنه لا يقوم بالعمل لحسابه وإنما لحساب القاصر^(٤) ، كما أن القاصر هو

الآخر لا يمكنه اكتساب صفة التاجر بسبب نقص أهليته^(١).

وإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه ، فلا يلتزم إلا في حدود أمواله المستثمرة في هذه التجارة ، ويجوز شهر إفلاسه على أن لا يشمل الإفلاس الأموال غير المستثمرة في التجارة ، وفي هذه الحالة لا يترتب على الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه.

ويجب تسجيل كل أمر يصدر من المحكمة بشأن الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه وإذا أصدرت المحكمة حكماً بسحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة فإنه يجب قيده في السجل التجاري ونشره في صحيفة.

أيلولة حصة شريك إلى مورثه القاصر

يثور السؤال عن حالة القاصر إذا كان مورثه شريكاً متضامناً في شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة ، فهل إذا وافق الشركاء على استمرار القاصر الوارث محل مورثه في الشركة ، فهل يدخل بصفته شريكاً موصياً؟ أم بصفته شريكاً متضامناً كما كان مورثه؟

بداية نقرر أن لا مشكلة لدينا إذا كان المورث شريكاً موصياً في شركة التوصية البسيطة ، أو شريكاً في شركة ذات مسئولية محدودة ، أو مساهماً في شركة مساهمة عامة أو خاصة؛ حيث إن القاصر سيحل بنفس الصفة محل مورثه في الشركة؛ لأن المورث بهذا النوع من الشراكة في هذه الشركات ، لا يكتسب صفة التاجر ، وبالتالي دخول القاصر كشريك محل مورثه لن يكسبه صفة التاجر.

أما إذا كان المورث شريكاً متضامناً في شركة تضامن أو في شركة توصية بسيطة ، فهنا إذا قلنا بدخول القاصر محل مورثه ، فهذا يعني أنه سيكتسب صفة التاجر ، وهذا أمر غير ممكن بسبب نقص أهلية القاصر ، وإذا قلنا بإخراجه من الشركة معناه عدم احترام اتفاق الشركاء باستمرارية الشركة مع الورثة ، فما هو الحل في هذه الحالة؟

طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة ٥٢٨ من القانون المدني^(٢) ، فإن الشركة تستمر ويحل القاصر محل مورثه بنفس حصته في الشركة ، وذلك دون توقف على إذن من المحكمة أو إذن من الولي أو الوصي. غير أن القاصر- في هذه الحالة- لن يدخل بصفته شريكاً متضامناً نظراً لنقص أهليته ، وإنما يدخل بصفته شريكاً موصياً. فإذا كانت الشركة شركة تضامن وجب تحويلها إلى شركة توصية بسيطة؛ نظراً لأن شركة التضامن يجب أن يكون جميع الشركاء فيها متضامنين ،

بخلاف شركة التوصية البسيطة ، فهي تضم شريكاً متضامناً على الأقل وشريكاً موصياً .
وفي كل الأحكام السابقة سواء بالنسبة للقاصر المأذون له في التجارة أو القاصر غير المأذون له
فإن أهلية المرأة لا تختلف عن أهلية الرجل .

القيود الواردة على الأهلية

رأينا أن صفة التاجر تثبت لكل من احترف العمل التجاري ، وكان قد أتم إحدى وعشرين سنة
ميلادية ، وكذلك لمن بلغ الثامنة عشرة وأذنت له المحكمة . ولا يكتسب هذه الصفة من بلغ
الثامنة عشرة ولم تأذن له المحكمة ، أو كان دون هذه السن .
ومع هذا فهناك أشخاص قد بلغوا سن الرشد ببلوغهم إحدى وعشرين سنة ميلادية ، غير إنهم
لا يستطيعون ممارسة العمل التجاري وبالتالي فهم لا يكتسبون صفة التاجر . هؤلاء الأشخاص
تختلف الأسباب التي منعتهم من مزاوله العمل التجاري ، فبعضهم قد يكون سبب منعه راجعاً
إلى ١- طبيعة مهنته ووظيفته ، وبعضهم قد يكون السبب في منعه راجعاً إلى ٢- حمايته من نفسه
نتيجة عارض أصابه فآثر على أهليته .

١- الأشخاص الممنوعون من التجارة لوظائفهم

هناك أشخاص ممنوعون بحكم وظائفهم من احتراف العمل التجاري ، كالقضاة ، والمحامين ،
ورجال الجيش ، وأساتذة الجامعات . وقد ورد النص على منع هؤلاء من العمل التجاري بموجب
قوانين خاصة .

فإذا خالف واحد ممن يشملهم هذا الحظر ، واحترف العمل التجاري ، فإنه يكتسب صفة
التاجر ، ويخضع لما يخضع له التجار من أحكام بالإضافة إلى جواز شهر إفلاسه^(١) ، وهذا ردع
له حتى لا يتهرب من الشدة التي تتسم بها قواعد القانون التجاري ، بالإضافة إلى معاقبته تأديبياً
من الجهات التي يتبعها بحكم وظيفته .

٢- المصابون بعارض من عوارض الأهلية

حددت المادة ١١٢ من القانون المدني عوارض الأهلية بأنها الجنون والعتة والسفه والغفلة ، هذه
العوارض تصيب العقل الذي هو مناط الأهلية فتعدم الأهلية أو تنقصها على حسب هذا
العارض .

أ-العوارض التي تعدم الأهلية

الجنون: وهو مرض يصيب العقل فيعدم عند صاحبه الإدراك والتمييز. أما العته فهي آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله^(١). وتقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين مما يستقل به قاضي الموضوع ، لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى^(٢).

وطبقاً للمادة ١١٣ مدني فإنه يقع باطلاً تصرف الجنون والمعتوه ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. ٢- أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منها^(٣).

وإذا كان كل من الجنون والمعتوه لا يتمتع بأي من نوع من الأهلية ، فإنه يتمتع عليه ممارسة العمل التجاري ، وإذا مارسها فإن تصرفاته تكون باطلة ولا يكتسب صفة التاجر. وتتولى المحكمة تعيين من يتولى إدارة أموالهما وهو القيم ، ولا يكتسب هذا الأخير صفة التاجر بمناسبة إدارته لتجارة الجنون أو المعتوه.

ب-العوارض التي تنقص الأهلية

السفه وهو خفة تحمل صاحبها على التصرف في ماله على غير مقتضى العقل والشرع^(٤). أما الغفلة فهي سذاجة أو بساطة متناهية تحمل صاحبها على أن يغيب في معاملاته^(٥).

وطبقاً للمادة ١١٥ مدني ، فإن التصرفات الصادرة من السفه وذي الغفلة بعد قيد طلب الحجر أو حكم الحجر يكون كتصرفات ناقص الأهلية^(٦). أما التصرفات الصادرة منهما قبل القيد فلا تكون باطلة ولا قابلة للبطلان إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ من الطرف الآخر.

والسؤال الآن هل يستطيع السفه أو ذو الغفلة اعتراف التجارة ويكتسب صفة التاجر؟

السبب في هذا السؤال يرجع إلى نص المادة ١١٦ مدني أجازت للمحكمة أن تأذن للمحجور عليه للسفه أو للغفلة في استلام أمواله كلها أو بعضها لإدارتها) ، فهل في مقدور السفه وذي الغفلة أن يحترف العمل التجاري إذا أذنت المحكمة لهما في تسلم أموالهما كلها أو بعضها؟

اختلف الفقه القانوني^(٧) ما بين مجيز ومانع للسفه ولذي الغفلة في اعتراف العمل التجاري واكتساب صفة التاجر ، ونرى عدم جواز ممارسة السفه وذي الغفلة العمل التجاري ، وذلك حفاظاً على أموالهما وحماية لهما من الخضوع لقواعد القانون التجاري وما تنسم به من شدة وصرامة.

المطلب الثاني أهلية الأجانب

فيما يتعلق بالأجانب أي غير المصريين سواء كانوا عرباً أم غير عرب وأياً كانت الديانة التي ينتمون إليها ، نجد أن قانون التجارة المصري سوى بينهم وبين المصريين فيما يتعلق بأهلية التجارة ، غير أن بعض التشريعات تتطلب إجراءات خاصة لممارسة المرأة المتزوجة الأعمال التجارية وبالتالي فإننا نفرق في أهلية الأجانب بين الرجل والمرأة.

أولاً: أهلية الرجل

اعتبر قانون التجارة المصري بالمادة ١١ / ١ أن الأهلية الكاملة لممارسة التجارة هي أهلية البالغ من العمر إحدى وعشرين عاماً ميلادية حتى لو كان أجنبياً بصرف النظر عن تنظيم قانون بلده للأهلية الكاملة للتجارة. فإذا كان القانون الأجنبي يقرر الأهلية الكاملة لمن هو دون الواحدة والعشرين فإنه في نظر القانون المصري يعتبر قاصراً ويجب عليه أن يحصل على إذن من المحكمة المختصة لممارسة التجارة في مصر.

أما إذا كان الأجنبي قد بلغ ثمانية عشر عاماً كاملة وكان قانون أحواله الشخصية يقضي بأنه قاصر ، فلا يجوز له أن يتجر إلا طبقاً للشروط المقررة فيه^(١). كأن يشترط حصوله على إذن من المحكمة أو من الوصي أو من مجلس العائلة^(٢). فإذا كان الأجنبي أقل من ثماني عشرة عاماً فإنه طبقاً للمادة ١١ / ٢ تجاري ليس له أن يزاول التجارة في مصر حتى ولو كان قانون دولته يعتبره راشداً أو يجيز له الاتجار ، وذلك حتى لا يتمتع بمركز قانوني أفضل من المواطن المصري ، مثال ذلك قانون المعاملات السعودي الذي يسمح للشخص الذي بلغ من العمر أربع عشرة عاماً بمزاولة التجارة واكتساب صفة التاجر^(٣) ، فإنه في داخل مصر يعد قاصراً دون الثامنة عشرة عاماً وليس له أن يمارس التجارة ولا يكتسب صفة التاجر.

ثانياً: أهلية المرأة

يطبق على النساء الأجنبية غير المتزوجات نفس أحكام الأهلية التجارية التي يخضع لها الرجال الأجانب على الرجال سواء كانوا متزوجين أم كانوا غير متزوجين ، أما المرأة الأجنبية المتزوجة فقد أخضع قانون التجارة المصري أهليتها التجارية لقانون الدولة التي تنتمي لها جنسيتها^(٤) ، فإن كان قانونها يشترط شرطاً معيناً لممارستها التجارة وجب مراعاة هذا الشرط إذا أرادت أن تمارس

التجارة داخل مصر ، كما هو الحال في القانون التجاري اللبناني والذي يشترط حصول المرأة المتزوجة على إذن من زوجها لممارسة التجارة فقد نصت المادة ١١ من هذا القانون على أن (المرأة المتزوجة مهما تكن أحكام القانون الشخصي الذي تخضع له لا تملك الأهلية التجارية إلا إذا حصلت على رضا زوجها الصريح أو الضمني).

وقد افترض القانون المصري في المرأة الأجنبية التي تزاول التجارة في مصر أنها تمارسها بإذن زوجها حتى يثبت عكس ذلك ، فإن كان للزوج أن يعترض على ممارستها التجارة أو يسحب إذنه أو يقيده وجب قيد ذلك في السجل التجاري المصري ونشره في صحيفة السجل ، ولا يكون لسحب الإذن أو تقييده أثر رجعي على المعاملات التي تمت قبل ذلك ، فقد نصت المادة ٢/١٤ تجاري مصري على أنه (يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها ، فإذا كان القانون الواجب التطبيق يميز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل ، ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام هذا النشر).

شهر النظام المالي لزواج الأجانب

لا ترتب الشريعة الإسلامية أي أثر على الناحية المالية بين الزوجين بسبب الزواج إذ أن إموال كل واحد منهما تبقى منفصلة عن مال الآخر كما كان قبل الزواج ، وهو ما أخذ به القانون المصري في النظام المالي بين الزوجين.

وفي المقابل نجد بعض التشريعات الأجنبية كالتشريع الفرنسي يرتب على الزواج اشتراك الزوجين في مالهما وهو ما يعرف بنظام اختلاط الأموال ، وطبقاً لهذا النظام فإن مسؤولية الزوجين تكون تضامنية في الديون المترتبة على الأموال المشتركة بينهما. أما في ظل نظام انفصال الأموال بينهما فإن كل واحد منهما يكون مسئولاً مسؤولية شخصية عن الوفاء بديونه دون أن يكون الآخر مسئولاً عنها ، وبالتالي فمن المهم معرفة طبيعة النظام المالي للتاجر الأجنبي المتزوج والذي يعمل بالتجارة في مصر حتى يتمكن من تحديد المسؤولية في ديونه أتكون مشتركة بين الزوجين أم تكون غير ذلك.

وقد افترض قانون التجارة المصري بالمادة ١/١٥ في الزوجة الأجنبية أن نظام زواجها يقوم على انفصال الأموال بين الزوجين إلا إذا كانت المشاركة المالية بينهما تقوم على خلاف ذلك ، وقد بينت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه لا يحتج على الغير بالمشاركة المالية بين الزوجين إلا إذا تم

شهرها وذلك بقيدها في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفة السجل ، وليس هناك ما يمنع إذا لم تشهر المشاركة المالية بين الزوجين أن يثبت الغير - صاحب المصلحة - أن الزواج قد تم وفقاً لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال.

وتقضي الفقرة الرابعة من المادة ١٥ تجاري بأنه (إذا صدر حكم قضائي خارج مصر يقضي بانفصال الأموال بين الزوجين فلا يكون هذا الحكم حجة إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفة السجل).

الفصل الثاني

الالتزامات المهنية لطائفة التجار

اهتم القانون بتنظيم مهنة التجارة لما يترتب عليها من أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية ، ومن تنظيم القانون لهذه المهنة ما أوجبه القانون على التجار ببعض الالتزامات المهنية والتي يعود نفعها على التجار أحياناً وعلى الغير أحياناً أخرى ، كالالتزام بالتاجر بمسك الدفاتر التجارية وكذلك الالتزام بالقيد في السجل التجاري ، وبالتالي فإننا نقسم الكلام في تلك الالتزامات إلى مبحثين التاليين:

المبحث الأول: التزام التاجر بمسك الدفاتر التجارية.

المبحث الثاني: التزام التاجر بالقيد في السجل التجاري.

المبحث الأول

الالتزام بالتاجر بمسك الدفاتر التجارية

يعتبر الالتزام بمسك الدفاتر التجارية^(١) من الالتزامات التي تعود بالنفع الكبير على التاجر إذا كانت منتظمة؛ إذ أنها قد تكون أداة إثبات يستطيع التاجر أن يستخدمها لمصلحته ، كما يمكن استخدامها كأساس لمصلحة الضرائب تحسب على أساسها الضرائب المفروضة على التاجر ، كما يمكن للتاجر من خلالها أن يتعرف على حقيقة مركزه المالي ومدى نجاحه أو ضعفه في تجارته ، فالدفاتر التجارية المنتظمة بمثابة المرآة التي تعكس صورة التاجر الحقيقية.

وقد نظم المشرع المصري الدفاتر التجارية في المواد ٢١ إلى المادة ٢٩ تجاري ، كما نظم المشرع حجية الدفاتر التجارية في المادتين ١٧ ، ١٨ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بشأن الإثبات

في المواد المدنية والتجارية.

ونتناول في هذا المبحث الأحكام التفصيلية للدفاتر التجارية وذلك في مطالب ثلاثة:

المطلب الأول: الملزمون بمسك الدفاتر التجارية وأنواعها

المطلب الثاني: القواعد المنظمة للدفاتر التجارية والجزاء على مخالفتها.

المطلب الثالث: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات.

المطلب الأول

الملزمون بمسك الدفاتر التجارية وأنواعها

أولاً الملزمون بمسك الدفاتر التجارية

نصت المادة ٢١ تجاري على أنه (على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها ، وعلى وجه الخصوص دفترى اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة)

وطبقاً لهذا النص فإن كل تاجر يكون ملزماً بمسك دفاتر تجارية سواء كان مواطناً أو أجنبياً ، وسواء كان فرداً طبيعياً أو كان شركة تجارية ، بصرف النظر عن معرفة التاجر للقراءة أو جهله لها؛ إذ إنه يمكنه تنظيم الدفاتر التجارية عن طريق المستخدمين لديه وما يقيد بها يفترض أنه على علم به إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك^(١).

ويقضي مفهوم المخالفة لهذا النص أن غير التاجر ، أو من يقوم بأعمال تجارية بصورة عرضية لا يكون ملزماً بمسك دفاتر تجارية. أما بخصوص الجمعيات والشركات المدنية فإنها لا تكتسب صفة التاجر ، لذلك فهي غير ملزمة-طبقاً لمفهوم المخالفة لنص المادة ٢١ تجاري- بعدم مسك دفاتر تجارية ، لكن عدم تقيدها بهذا الواجب القانوني لا يحول بينها وبين مسكها للدفاتر المحاسبية المنتظمة التي تستوجبها عملياتها المحاسبية والمراجعة والرقابة المالية اللازمة لحسن إدارتها^(٢).

ويثور التساؤل بخصوص الشريك المتضامن ، فمن المعلوم أنه يكتسب صفة التاجر لمجرد كونه شريكاً متضامناً ، فهل تكفي الدفاتر التجارية التي تمسك بها الشركة؟ أم يجب أن يمسك بدفاتر تجارية لنفسه خلاف دفاتر الشركة؟

ذهب بعض الفقه^(٣) إلى أن الدفاتر التجارية التي يمسك بها الشركة تغني عن التزام الشريك

المتضامن منفرداً بمسك دفاتر تجارية ، وحجتهم في ذلك أننا لو ألزمناهم بمسك دفاتر تجارية بجانب دفاتر الشركة ، لكانت دفاترهم ليست إلا تكراراً لدفاتر الشركة. بينما ذهب فريق آخر من الفقه^(١) -وهو ما نؤيده- إلى أن التزام الشريك المتضامن بمسك دفاتر تجارية ، بخلاف الدفاتر التي تمسك بها الشركة ، على الأخص إذا كانت له تجارة مستقلة^(٢) ، وذلك للأسباب الآتية:-

- ١- نص المادة ٢١ تجاري أوجب على كل من توافرت فيه صفة التاجر أن يمسك بالدفاتر التجارية ، ولا شك أن الشركة لها ذمة مالية منفصلة عن الذمة المالية للشريك المتضامن ، فلا يغني مسكها للدفاتر التجارية عن التزام الشريك المتضامن بمسكه دفاتر له.
- ٢- ليس صحيحاً أن مسك الشريك المتضامن لدفاتر تجارية يعد تكراراً لدفاتر الشركة ، حيث إن الدفاتر التجارية الخاصة بالشريك المتضامن سيقيد فيها مسحوباته الشخصية ، والأرباح السنوية التي حصل عليها ، ومقدار ما أسهم به في ديونها. هذا فضلاً عن أن إفلاس الشركة يستتبع إفلاسه ، فيكون من مصلحته الإمساك بدفاتر منفصلة عن الشركة لبيان مركزه المالي.

استثناء صغار التجار من الالتزام بمسك الدفاتر التجارية

أعفى المشرع التجاري -بالمادة ٢١ تجاري- الأشخاص الذين لا يزيد رأس مال تجارتهم عن عشرين ألف جنيه من الالتزام بمسك الدفاتر التجارية ، فهم يسعون من وراء تجارتهم لمجرد تحصيل قوت يومهم ، فحجم تجارتهم ليس بالقدر الذي يسهم في حركة اقتصاد الدولة ، فهؤلاء الأشخاص بالرغم من اكتسابهم لصفة التاجر ، إلا أنهم معفيون من الالتزامات التي يلتزم بها التجار كمسك الدفاتر التجارية ، والقيد في السجل التجاري ، فضلاً عن عدم خضوعهم لنظام الإفلاس.

ثانياً أنواع الدفاتر التجارية

يتوقف نوع الدفاتر التي يلتزم التاجر بمسكها على طبيعة تجارته وحجم أعماله ، ويرجع في تحديد هذه الدفاتر إلى العرف المحاسبي السائد. وتحديد كون هذه الدفاتر ملائمة لطبيعة عمل التاجر من عدمه مسألة تقديرية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع إذا ما نشب نزاع بشأنه أمام المحكمة المختصة^(٣).

١- الدفاتر التجارية الإلزامية

نص المشرع التجاري- بالمادة ٢١ تجاري- على حد أدنى من الدفاتر التجارية يجب على التاجر أن يمسك بها ، أيًا كانت طبيعة تجارته وهما نوعان:-

النوع الأول: دفتر اليومية

يعتبر دفتر اليومية طبقاً للمادة ١/٢٢ تجاري من الدفاتر التجارية الهامة للتاجر ، وأكثرها بياناً لحقيقة المركز المالي للمشروع بسبب طبيعته التي فرضها المشرع؛ حيث تسجل فيه كافة العمليات اليومية التجارية التي يقوم بها التاجر بالإضافة إلى قيد مصروفاته الشخصية. وربما يهدف المشرع من وراء إلزام التاجر بقيد لمصروفاته الشخصية الوقوف على مدى حرص التاجر أو بذخه في حالة الإفلاس؛ لأنه متى أسرف في الانفاق على حياته الخاصة ، على الرغم من اختلال أشغاله وتوقفه عن الدفع فإنه يضر بدائنيه ويعتبر مفلساً.^(١)

وطبقاً للفقرة الثانية من المادة ٢/٢٢ تجاري فإنه ليس هناك ما يمنع أن يمسك التاجر بدفاتر يومية مساعدة يثبت فيها تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات التي يقوم بها ، كأن يكون هناك دفتر للمشتريات وآخر للمبيعات ، فإذا أمسك التاجر بدفاتر يومية مساعدة فلا يكون في حاجة إلى تدوين تفاصيل العمليات مرة أخرى في دفاتر اليومية الأصلية ، وإنما يكفيه تدوين إجمالي هذه العمليات في فترات منتظمة.^(٢)

وإذا لم يقوم التاجر بنقل البيانات التي في الدفاتر المساعدة إلى دفتر اليومية الأصلي ، فإن كل دفتر من الدفاتر المساعدة يعتبر دفتر يومية أصلي ويخضع لأحكام تنظيم الدفاتر التجارية^(٣).

النوع الثاني: دفتر الجرد^(٤)

يعد دفتر الجرد من أهم الدفاتر بالنسبة للتاجر؛ إذ إنه الدفتر الرئيس الذي تصب فيه القيود الواردة بالدفاتر الأخرى ، كما أنه الدفتر الذي تظهر فيه النتائج النهائية لتحركات عناصر المشروع التجاري كما تبينها الدفاتر^(٥). وطبقاً لما تقضي به المادة ٢٣ تجاري فإنه يقيد في دفتر الأستاذ العام ما يأتي:

(١) جميع العمليات الحسابية المرحلة من دفتر اليومية من واقع المستندات المؤيدة لها وعلى وجه

الخصوص الحسابات المتعلقة بالصندوق والمصرف والشركاء والدائنين والمدنيين والإيرادات والمسحوبات والمصروفات.

٢) تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متما لدفتر الجرد.

٣) صورة عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.

فالتاجر يقوم بعمل جرد في نهاية السنة المالية لتجارته ، ولا قيد على التاجر في تحديد بداية سنته المالية ونهايتها. وتعتبر الميزانية السنوية عن المركز المالي للتاجر ، وتتألف هذه الميزانية من جانبين أحدهما الأصول وتمثل تلك الأصول مجموع ما للتاجر من أموال ثابتة ومنقولة وحقوق لدى الغير ، والجانب الآخر الخصوم وتمثل مجموع الديون التي على التاجر ، كما يدخل فيها رأس ماله باعتباره ديناً على مشروعه التجاري من وجهة النظر المحاسبية.

٢- الدفاتر التجارية غير الإلزامية

لا يقتصر التاجر في مسكه للدفاتر التجارية على دفترتي اليومية والأستاذ ، فالأمر يتوقف على طبيعة نشاطه التجاري وما يستلزمه من نوعية الدفاتر التي يمسكها. وقد درج التجار على مسك دفاتر معينة منها:-

أ- دفتر المخزن: وهو دفتر تقييد فيه حركة البضائع التي تدخل أو تخرج من المخزن.

ب- دفتر الأوراق التجارية: وهو دفتر تقييد فيه حركة الأوراق التجارية المسحوبة من التاجر وتواريخ استحقاقها.

ت- دفتر الخزنة: وتقييد فيه الأموال التي تدخل أو تخرج من الخزنة.

وهناك دفاتر أخرى خاصة ببعض طوائف التجار كسماسرة سوق الأوراق المالية ، وأصحاب محلات البيع بالمزاد العلني والخبراء المثلمين ، فهؤلاء يمسكون بدفاتر تتضمن مفردات المنقولات المعدة للبيع والتقدير الابتدائي لقيمتها ، وأسماء الأشخاص الذين يجري البيع لصالحهم.

٣- صور المستندات والمراسلات:

أوجبت المادة ٢٤ تجاري على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من المراسلات والبرقيات والفواتير التي يرسلها أو يصدرها لأعمال تجارته ، وعليه أيضاً الاحتفاظ بجميع ما يرد إليه من

مراسلات وبرقيات ، وفواتير ، وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته ، ويكون الاحتفاظ بهذه الأوراق بطريقة منظمة تسهل معها المراجعة ، ولمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تصديرها أو ورودها.

ولا تمثل صور المراسلات والبرقيات نوعاً ثالثاً من الدفاتر التجارية ، وإنما هي مجرد إثبات لمعاملات التاجر عن طريق الاحتفاظ بهذه المكاتبات ، وقد أوجب القانون حفظها بطريقة يسهل معها الرجوع إلى هذه الصور. ومن التطبيقات القضائية في هذا الشأن ما قضت به محكمة النقض بأبو ظبي بأنه (كما أن من المقرر أن رسالة الفاكس التي يطبعها الجهاز المتلقي بطريق التصوير نقلاً عن جهاز الفاكس مصدر الرسالة والموقعة من المرسل ، تقوم مقام الأصل المودع لدى الجهة المرسلة ، وتعد بالتالي نسخة ثانية منها ، ولها قيمة المحرر العرفي في الإثبات ، وليست صورة ضوئية ، ما لم تنكر الجهة المرسلة صدورها منها أو تنكر ما نسب إليها من توقيع عليها ، ومن المقرر أيضاً أن تقدير ما إذا كانت رسالة الفاكس صورة ضوئية أو أصلاً منقولاً عن جهاز الفاكس المرسل - هو من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب ، متى أقامت قضاؤها على أسباب سائغة).^(١)

وقد حددت المادة ٢٦ تجاري في فقرتها الأولى والثانية مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية وكذلك بصور المراسلات والبرقيات بخمس سنوات تبدأ مدتها في الدفاتر التجارية من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو نقلها ، وفي المكاتبات من تاريخ إرسالها أو تسلمها.

وقد جعل القانون لصور تلك المراسلات حجية في الإثبات كحجية الأصل بشرط أن يراعي في حفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل ، وبالقياس على مفهوم نص المادة ٢١ تجاري فإنه كما يعني صغار التجار الذين لا يزيد رأس مال تجارتهم عن عشرين ألف جنيه من مسك الدفاتر التجارية ، فإنهم كذلك يعفون من الاحتفاظ بصور المكاتبات والمراسلات الصادرة منهم أو الواردة إليهم.

المطلب الثاني

القواعد المنظمة للدفاتر التجارية

والجزء على مخالفتها

أولاً: القواعد المنظمة للدفاتر التجارية

اهتم المشرع التجاري بتنظيم الدفاتر التجارية فوضع لها من القواعد ما يكفل تحقيق هذا الانتظام

ويدفع كل ربية حول صحة البيانات المقيدة بالدفتر ، ويرجع حرص المشرع على انتظام الدفاتر التجارية إلى أنها تعتبر من أهم وسائل الإثبات أمام القضاء سواء بالنسبة للتاجر أو بالنسبة لمن يتعامل معه التاجر ، كما أن جهات الضرائب تعتمد عليها في ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.^(١)

ومن مظاهر التنظيم القانوني للدفاتر التجارية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٢٥ تجاري من ضرورة أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور ، والهدف من وراء ذلك هو ضمان سلامة البيانات الواردة بالدفاتر التجارية وذلك بعدم تغيير البيانات الأصلية للدفتر بطريق التحشير بين السطور ومنع إضافة أي شيء في أي فراغ يترك بين السطور^(٢).

وبالإضافة للفقرة السابقة فقد أوجبت الفقرة الثانية من المادة ٢٥ تجاري ترقيم صفحات دفترتي اليومية والجرد قبل استعمالها ، وأن يقوم التاجر بالتوقيع على كل صفحة من صفحات هذين الدفترتين في مكتب السجل التجاري التابع له التاجر مع وضع خاتم المكتب على كل صفحة من صفحات هذين الدفترتين في مكتب السجل التجاري التابع له التاجر مع وضع خاتم المكتب على كل صفحة من صفحات الدفترتين وبيان عددهما. كما يجب على التاجر تطبيقاً للفقرة الثالثة من المادة السابقة- أن يقدم دفترتي اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجاري للتصديق على عدد صفحات الدفتر المستعملة خلال السنة المالية ، فإذا انتهت صفحات الدفتر وجب على التاجر تقديم هذا الدفتر إلى مكتب السجل التجاري للتأشير عليه بما يفيد انتهاءه.

وفي حالة وفاة التاجر أو توقفه عن النشاط التجاري وجب على الورثة في الحالة الأولى أو على التاجر في الحالة الثانية تقديم دفترتي الجرد واليومية إلى مكتب السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.^(٣)

وفي خصوص تنظيم الدفاتر التجارية التي تستعملها البنوك أو الشركات التي يعينها قرار من الوزير المختص فإنه يجوز بقرار من الوزير المختص وضع الأحكام التي تنظم هذه الدفاتر^(٤). وكما بينا سابقاً فإن التاجر أو ورثته يحتفظون بهذه الدفاتر أو الوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله.

ثانياً: الجزاء على عدم مسك الدفاتر التجارية أو انتظامها

يتعرض التاجر الذي لا يمسك بدفاتر تجارية أو من يمسك بدفاتر تجارية غير منتظمة لجزاء قانوني ، ويتنوع هذا الجزاء ما بين جزاء جنائي وآخر مدني .

١- الجزاء المدني

فصل المشرع التجاري بالمادة ٢٥ الأحكام الخاصة بتنظيم الدفاتر التجارية ، فإذا خالف التاجر هذه الأحكام كانت دفاتره لا قيمة لها من الناحية القانونية ويتمثل ذلك في النواحي الآتية:-
لا تعتبر الدفاتر غير المنتظمة حجة في الإثبات أمام المحاكم؛ تطبيقاً للمادة ٧٠ من القانون التجاري.

لما كانت مصلحة الضرائب تعتمد على الدفاتر المنتظمة في تحديد الضرائب الواجب على التاجر أن يدفعها ، فإذا كانت هذه الدفاتر غير منتظمة فإن مصلحة الضرائب تطبيقاً للمادتين ٢٦ ، ١٤٤ من القانون الضريبي رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ تلجأ إلى التقدير الجزائي في تحديد حجم أرباح الوعاء الضريبي للتاجر الذي يتم على أساسه ربط الضريبة ، وربما يفوق التقدير الجزائي الأرباح التي يحققها التاجر فعلاً.

يتعرض التاجر الذي لا يمسك بدفاتر تجارية أو من مسك بدفاتر غير منتظمة للحرمان من الصلح الواقعي من الإفلاس ، حيث أن الدفاتر المنتظمة هي التي تظهر أن حالة التاجر التي يمر بها التاجر ليست إلا حالة مؤقتة وأنه حسن النية فيستفيد من الصلح الواقعي ، أما إذا كانت تلك الدفاتر غير منتظمة فيصعب تحديد المركز المالي لهذا التاجر وتصبح مهمة وكيل التفليسة في تحديد أصول وخصوم المفلس صعبة وشاقة.^(١)

٢- الجزاء الجنائي

كما يتعرض التاجر الذي لا يمسك بدفاتر تجارية أو التاجر المهمل في تنظيم تلك الدفاتر لجزاء مدني ، فإنه يتعرض كذلك لجزاء جنائي ويتمثل هذا الجزاء فيما يلي:-
أ- يتعرض مثل هذا التاجر للغرامة المالية التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه؛ وذلك تطبيقاً للمادة ٢٩ تجاري والتي نصت على أنه (يعاقب على مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل أو في القرارات الصادرة تنفيذاً لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه).

ب- إذا أفلس التاجر الذي لا يمسك بالدفاتر التجارية أو من يهمل في تنظيمها فإنه يتعرض للحكم عليه بعقوبة جنائية الإفلاس بالتدليس إذا ثبت أنه أخفى دفاتره التجارية أو أعدمها ، وتمثل هذه العقوبة في السجن من ثلاث إلى خمس سنوات ، تطبيقاً للمادة ٣٢٨ والمادة ٣٢٩ من قانون العقوبات ، وقد يتعرض نفس التاجر لعقوبة جنحة الإفلاس بالتقصير إذا كانت الدفاتر التي أمسك بها غير منتظمة أو لم يمسك بها أصلاً وتمثل عقوبة جنحة الإفلاس بالتقصير في الحبس مدة لا تتجاوز سنتين؛ تطبيقاً للمادتين ٣٣١ ، ٣٣٤ من قانون العقوبات.

المطلب الثالث

حجية الدفاتر التجارية في الإثبات

أجاز المشرع التجاري في المادة ٦٩ / ١ الإثبات في الالتزامات التجارية أيّاً كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ولما كانت الدفاتر التجارية التي يمسك بها التاجر تحوى بيانات غاية في الأهمية بسبب طبيعة المعاملات التجارية التي كثيراً ما تتم بالهاتف أو شفاهة دون أن يكون هناك مستنداً مكتوباً لإثباتها فقد أجازت المادة ٧٠ تجاري قبول الدفاتر التجارية للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو عليهم متى كانت تتعلق بأعمالهم التجارية.

وبالرغم من إجازة القانون للإثبات أمام المحكمة بالدفاتر التجارية المنتظمة ، فلا يعني هذا الاعتراف بالحجية المطلقة لهذه الدفاتر أو أن تكون المحكمة مجبرة على الأخذ بما جاء فيها ، فللمحكمة أن تأخذ بهذه الدفاتر ولها أن تطرحها جانباً وتلزم الخصوم بتقديم أدلة أخرى غير هذه الدفاتر دون سلطان من محكمة النقض على محكمة الموضوع في هذا الخصوص^(١) ، كما أنه يمكن للخصوم إثبات عكس ما ورد في تلك الدفاتر بكافة طرق الإثبات كالشهادة والقرائن.^(٢) ويرجع السبب في عدم الاعتراف بالحجية المطلقة للدفاتر التجارية في الإثبات إلى أنها تعتبر دليلاً للإثبات لمصلحة التاجر مما يجعلها استثناء على القواعد العامة القاضية بأنه لا يجوز للشخص أن يصنع دليلاً لنفسه ، فإذا استخدمت كدليل ضد التاجر كانت استثناء على القاعدة القاضية بأنه لا يجبر الشخص على تقديم دليل ضد نفسه.

طريقة الرجوع للدفاتر التجارية

يتم الرجوع إلى دفاتر التاجر - بشأن الخصومة المعروضة - بإحدى طريقتين ، الأولى طريقة التقديم والثانية طريقة الاطلاع.

١- طريقة التقديم

المراد من طريقة التقديم: هو وضع الدفتر تحت تصرف المحكمة لاستخراج منه ما يتعلق بالخصومة سواء كان ذلك بنفسها أو عن طريق خبير تعيينه المحكمة لهذا الغرض. نصت المادة ٢٨ / ١ تجاري على أنه (يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها ، وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بواسطة خبير تعيينه لذلك). يفهم من هذا النص أن التقديم هو وضع الدفتر تحت تصرف المحكمة لاستخراج منه ما يتعلق بالخصومة سواء كان ذلك بنفسها أو عن طريق خبير تعيينه المحكمة لهذا الغرض.

ويتم التقديم في حضور التاجر - صاحب الدفتر المقدم - وتحت رقابته ودون أن يتخلى عنه ، ولا يجوز في هذه الطريقة تسليم الدفاتر التجارية للخصم ليبحث فيها ويطلع على أسرار التاجر ، بل إن البحث في الدفاتر يكون بحضور التاجر صاحب الدفتر وتحت رقابته ، بل يتم التقديم في حضور التاجر - صاحب الدفتر المقدم - وتحت رقابته ودون أن يتخلى عنه.

ويعتبر التقديم هو القاعدة العامة في الإطلاع على الدفاتر التجارية فهو جائز في جميع المنازعات سواء مدنية أم تجارية^(١). وطبقاً لما تقضي به المادة ٢٨ / ٤ تجاري فإنه إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتر للإطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر.

ثانياً: طريقة الإطلاع^(٢)

يقصد بالإطلاع الكلي إجبار التاجر على تسليم دفاتره والتخلي عنها للقضاء ليسلمها بدوره إلى الخصم ليطلع عليها ليستخرج منها الأدلة التي تؤيد طلباته. ولم يبين القانون كيفية حصول الإطلاع وبالتالي فإن تحديد هذه الكيفية متروك لحرية المحكمة فقد تأمر بإيداع الدفاتر في قلم كتاب المحكمة ليطلع عليها الخصم لدى قلم الكتاب ، وقد تأمر المحكمة بتسليم الدفاتر لشخص - ما - ليتم الإطلاع لديه ، وقد تأمر المحكمة بخصوص الإطلاع في محل التاجر نفسه.

(١)

التحديد الحصري للحالات التي يتم فيها الاطلاع

لما كانت طريقة الاطلاع تمكّن الخصم من معرفة حجم معاملات التاجر عن طريق الرجوع إلى

الدفاتر التجارية ، وفي ذلك خطورة كبيرة بالنسبة للتاجر الذي قدم دفاتره للاطلاع ، لذا حرص القانون على حصر هذه الطريقة في حالات معينة ، وبحيث يكون لطالب الاطلاع على الدفاتر التجارية مصلحة مباشرة ومشاركة لا تقل أهمية عن مصلحة المحافظة على أسرار التاجر المدونة بدفاتره.

وقد حدد المشرع حالات الاطلاع على الدفاتر التجارية للتاجر بالمادة ٢/٢٨ تجاري بصيغة حصرية^(١)، فنصت على أنه (٢- لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر باطلاع خصمه على دفاتره إلا في المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات. ٣- تسلم الدفاتر في حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه للمحكمة المختصة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح).

١- النزاع المتعلق بتركة

يقصد بالتركة: الأموال التي تؤول إلى أكثر من شخص بطريق الميراث أو الوصية. فإذا تعلق النزاع التجاري بتركة ، واحتاج فيها الوارث أو الموصى له أن يتأكد من بعض البيانات المدونة بدفاتر تجارية والتي في حوزة وارث آخر ، جاز له أن يطلب الاطلاع على الدفاتر التجارية ليمكن من إثبات حقه في التركة.

٢- النزاع المرتبط بشركة

فإذا تعلق النزاع بشركة ، وكانت الشركة في مرحلة التصفية بسبب انقضاءها ، فإنه يجوز لكل شريك في هذه الشركة أن يطلب الاطلاع على الدفاتر التجارية لهذه الشركة ، حتى يتأكد من نصيبه وما حققتة الشركة من أرباح أو ما تحملته من خسائر. والحق في الاطلاع على دفاتر الشركة إنما هو قاصر على الشركاء فقط باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرة في الاطلاع على دفاتر الشركة ، وبالتالي لا يكون من حق الدائنين الشخصيين للشركاء الاطلاع على دفاتر الشركة؛ لانفصال الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية للشركاء ، كما لا يكون من حق دائني الشركة نفسها الاطلاع على دفاترها ما دامت أن الشركة لم تقع في هاوية الإفلاس^(٢).

٣- قسمة الأموال الشائعة

تتحقق حالة الشبوع -هنا- عندما توجد أموال مشتركة بين عدد من التجار ولم تأخذ شكل شركة ، أو نتيجة تطبيق نظام اختلاط الأموال بين الزوجين في الأنظمة التي تقر اتحاد الأموال بين

الزوجين. فإذا تعلق النزاع بمال على الشبوع ، واحتاج أحد الملاك في هذا المال الاطلاع على الدفاتر التجارية ، جاز له أن يطلب ذلك من المحكمة ليتمكن من معرفة نصيبه من هذا المال ، كما أنه يجوز -في نظام اختلاط الأموال- لأحد الزوجين الاطلاع على دفاتر الآخر لمعرفة نصيبه.

٤- الإفلاس أو الصلح الواقعي منه

إذا تم شهر إفلاس التاجر ، فإنه يجوز لدائنيه الاطلاع على دفاتره التجارية ، كما يجوز للسنديك كذلك الاطلاع على تلك الدفاتر للتأكد من حقيقة الموقف المالي للمفلس من ناحية ماله من حقوق وما عليه من ديون. كذلك يجوز للمحكمة أن تأمر لدائني التاجر بالاطلاع على دفاتره التجارية في حالة الصلح الواقعي من الإفلاس ليتسنى لهؤلاء الدائنين التأكد من قدرة التاجر - صاحب الدفاتر محل الاطلاع- على تنفيذ الصلح.

حجية الدفاتر التجارية في الإثبات

تتمتع الدفاتر التجارية بقوة في الإثبات تختلف على حسب ما إذا كان الإثبات لمصلحة التاجر صاحب الدفاتر التجارية في مواجهة غيره من التجار أو ض غير التجار ، كما تختلف تلك الحجية على حسب ما إذا كان الإثبات لمصلحة الغير في مواجهة التاجر صاحب الدفاتر التجارية ، ومن هنا فإننا نتناول حجية الدفاتر التجارية في الإثبات من خلال الفروض الثلاثة الآتية:-

الفرض الأول الإثبات لمصلحة التاجر ضد غيره من التجار

تتمثل صورة هذا الفرض في قيام نزاع بين التاجر صاحب الدفاتر التجارية وتاجر آخر مثله ويرغب التاجر الأول في الاعتماد على دفاتره التجارية لإثبات دعواه ، ففي هذا الفرض يجوز للمحكمة أن تعتبر الدفاتر التجارية دليلاً كاملاً في الإثبات^(١) ، فقد نصت المادة ٧٠ تجاري على أنه (يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية ، وتكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو قام الدليل بأي طريق آخر على عدم صحتها).

فطبقاً لهذا النص تكون الدفاتر التجارية التي يمسك بها التاجر حجة على غيره من التجار ، ولعل السبب في تقرير المشرع هذه الحجية للدفاتر التجارية في حالة قيام النزاع بين التاجر وبسبب أعماله التجارية في مواجهة غيره من التجار هو أن كل تاجر منهم يملك دفاتر تجارية منتظمة ، وأنه من المفترض أن يقيد بتلك الدفاتر كل ما يتعلق بالعمل التجاري فيمكن للمحكمة أن تضاهي تلك الدفاتر ببعضها للوصول إلى الحقيقة^(١) ، غير أن النص المقدم قد اشترط ثلاثة شروط للاعتراف بحجية الدفاتر التجارية في هذا الفرض وهذه الشروط هي:-

الشرط الأول أن يكون النزاع قائماً بين تاجرين

يشترط لحجية الدفاتر التجارية في الإثبات في هذا الفرض أن يكون الطرف الذي يتمسك التاجر في مواجهته بالدفاتر التجارية تاجراً مثله؛ حيث أن النزاع سيكون بين تاجرين يلتزم كل منهما بملك دفاتر تجارية ، ومن ثم يملك كل منهما نفس الوسيلة التي يواجه بها خصمه وهو ما يميز الخروج على القاعدة القاضية بأنه لا يجوز للشخص أن يستند إلى دليل صنعه بنفسه^(٢) ، ومن هنا فإنه يمكن للقاضي أن يأخذ بما ورد في الدفاتر التجارية ويعتبرها دليلاً كاملاً في الإثبات إذا توافقت دفاتر الخصمين بأن يكون موضوع النزاع مقيداً في دفتر أحدهما في جانب الدائن ، ويكون نفس البيان مقيداً في دفتر الطرف الآخر في جانب المدين.

وللمحكمة طبقاً للفقرة ج من المادة ٧٠ تجاري إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون وأسفرت هذه المطابقة بين تلك الدفاتر عن تناقض بياناتها ، فإنه يجب على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر.

وللدفاتر التجارية حجيتها بين التاجرين أصحاب النزاع حتى لو اعتزل كل منهما أو أحدهما التجارة وقت النزاع؛ لأن العبرة بوقت إمساك الدفاتر التجارية وليس بوقت نشوء النزاع وتقديم الدفاتر إلى القضاء.^(٣)

الشرط الثاني أن يكون النزاع متعلقاً بالأعمال التجارية

وهذا الشرط يتناسب مع طبيعة العمليات وفقاً لمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية ، فإذا كان العمل محل النزاع مدنياً بالنسبة لخصم التاجر فلا يجوز لهذا الأخير التمسك بدفاتره التجارية بشأن هذه المسألة لعدم التزام الخصم بقيد تفصيلات الأعمال المدنية في دفاتره التجارية.^(٤)

ومن المعلوم أن القانون أوجب بالمادة ٢١ تجاري الالتزام بمسك الدفاتر التجارية على التجار الذين يزيد رأس مال تجارتهم عن عشرين ألف جنيه ، وبالتالي فلا يمكن الاحتجاج بدفاتره في هذه الحالة على التاجر الذي لا يصل رأس مال تجارته إلى عشرين ألف جنيه لأنه لن يكون ملزماً بمسك الدفاتر التجارية.

الشرط الثالث أن تكون الدفاتر منتظمة

عبرت الفقرة - ب- من المادة ٧٠ تجاري عن هذا الشرط بقولها (تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون). أي أن الدفاتر إذا اتبع التاجر في شأنها القواعد المقررة في قانون التجارة والمتعلقة بكيفية مسك الدفاتر التجارية فإنها تكون منتظمة. وقد بينت الفقرة - ١- المادة ٢٥ تجاري كيفية انتظام هذه الدفاتر ومطابقتها لأحكام القانون وذلك بخلوها من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور إلى غير ذلك من هذه الأحكام.

والحكمة من ضرورة توافر هذا الشرط ترجع إلى التسهيل على القاضي في مضاهاة القيود الواردة في الدفاتر التجارية للخصوم ، فإذا لم يجد القاضي هذا التطابق بين الدفاتر التجارية فله مطلق الحرية في الأخذ بما يراه دون تقيد بانتظام أو عدم انتظام الدفاتر التجارية.

وقد بينت الفقرة - د- من المادة ٧٠ تجاري أنه في حالة عدم تطابق البيانات المقيدة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما منتظمة ومطابقة لأحكام القانون وكانت دفاتر الطرف الآخر غير مطابقة فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة ، إلا إذا أقام الخصم دليلاً على عكس ما ورد بالدفاتر المنتظمة ، ويسرى نفس الحكم حتى لو قدم أحد الطرفين دفاتر منتظمة ولم يقدم الطرف الآخر دفاتر أصلاً.

ولا يلزم لحجية هذه الدفاتر أن يكتبها التاجر بنفسه ، بل يمكن أن تكون مكتوبة من أحد معاونيه ما دامت تحت إشرافه. ^(١)

والدفاتر التجارية غير المنتظمة وإن كانت معدومة الحجية في الإثبات إلا أنها قد تصلح لأن تكون قرينة يمكن -مع غيرها من الأدلة- أن تساعد على تكوين اقتناع القاضي. فمسألة عدم استيفاء الإجراءات الشكلية والشروط القانونية في الدفاتر لا يحول أن يستخلص القاضي من الدفاتر غير المنتظمة قرينة لمصلحة من يتمسك بها. ^(٢)

الفرض الثاني الإثبات لمصلحة التاجر ضد غير تاجر

الأصل أنه لا يجوز للتاجر أن يحتج بدفاتره التجارية في مواجهة غير تاجر؛ إذ أنه لا يجوز للشخص أن يصنع دليلاً لنفسه يحتج به على الغير ، غير أن هذا التاجر ربما لا يكون لديه دليل ضد العميل الذي اشترى منه بعض الأشياء ولم يدفع ثمنها سوى ما قيده هذا التاجر في دفاتره التجارية ، ومن هنا وتمشياً مع ضرورات الحياة التجارية فقد أجازت المادة ١٧ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ للتاجر أن يحتج بهذه الدفاتر أمام القاضي لتكون أساساً يوجه بها القاضي اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك في حدود ما يجوز إثباته بالبينة أي لا تزيد قيمة الأشياء التي وردها التاجر للعميل وقام بقيدها في دفاتره عن خمسمائة جنيه؛ طبقاً للمادة ٦٠ من قانون الإثبات والمعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٢٢ وبالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ المعدل لقانون الإثبات وقانون المرافعات.

وللقاضي سلطة تقديرية في الأخذ بهذه الدفاتر ويوجه على أساسها اليمين المتممة أو يرفضها ويطلب التاجر بدليل آخر غير هذه الدفاتر^(١). وإذا قبل القاضي هذه الدفاتر فلا يكون ملزماً بتوجيه اليمين المتممة إلى خصم التاجر وإنما من الممكن أن يوجهها للتاجر نفسه.^(٢)

الفرض الثالث حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ضد التاجر نفسه

تنص الفقرة - أ - من المادة ٧٠ تجاري على أنه (تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية حجة على صاحبها ، ومع ذلك يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلاً لنفسه أن يجري ما ورد بها من بيانات). فطبقاً لهذا النص فإنه يمكن للغير أن يحتج على التاجر بما ورد في دفاتره التجارية من بيانات ، وقد جاء هذا الحكم على خلاف الأصل الذي يقضي بأنه لا يجبر الشخص على تقديم دليل ضد نفسه. ويحتج على التاجر بالبيانات الواردة في دفاتره التجارية سواء كانت تلك الدفاتر منتظمة أو غير منتظمة حتى لا يفيد التاجر من عدم انتظام دفاتره^(١) ، غير أنه إذا كانت دفاتر هذا التاجر منتظمة فلا يجوز لمن يحتج بها أن يجزئ ما ورد فيها باستبعاد ما كان منها مناقضاً لدعواه ليستخلص دليلاً لنفسه^(٢) ، أما إذا كانت تلك الدفاتر غير منتظمة ففي هذه الحالة يمكن لمن يحتج بها أن يجزئ منها ليستخلص دليلاً لنفسه^(٣). وكأن القانون يعاقب التاجر المهمل على إهماله في دفاتره التجارية.

وللتاجر الحق في أن يثبت بكافة طرق الإثبات ما يخالف البيانات الواردة في هذه الدفاتر؛ إذ أنها

ليست سوى قرينة ضد التاجر يمكن دائماً أن ينقضها بإقامة الدليل على ما يخالفها^(١). ولا يكون القاضي مجبراً على الأخذ بما ورد بهذه الدفاتر من بيانات فله أن يعتد بها كما له أن لا يعتد بها وفقاً لظروف الدعوى^(٢).

المبحث الثاني السجل التجاري

الثقة هي عماد العمل التجاري ، وتقتضي هذه الثقة أن يحاط من يتعامل مع التاجر بجميع البيانات التي تتعلق بالتاجر ، كمعرفة النظام المالي لزوجيه ، ومعرفة ما إذا كان مشهراً إفلاسه أم لا؟ من هنا كانت الوسيلة التي تحقق هذه المعرفة وتدعم الثقة ، وتبعث بالطمأنينة في نفس من يتعامل مع التاجر في نظام السجل التجاري ؛ حيث يلتزم التاجر بشهر كل البيانات التي تتعلق بعمله التجاري.

ويعرف السجل التجاري بأنه^(٣) عبارة عن دفتر تفرد فيه لكل تاجر ، سواء كان فرداً ، أو شركة ، صفحة تقيد فيها البيانات الخاصة بالتاجر والنشاط التجاري الذي يمارسه. ويهدف نظام السجل التجاري إلى تحقيق غايتين اثنتين:-

الأولى: حصر عدد المتاجر والشركات التجارية في البلاد من أجل الوقوف على سير أمورها الاقتصادية.

الثانية: إعطاء الغير الذي يتعامل مع التاجر صورة كاملة عن حالة النشاط التجاري حتى يكون على بينة من أمره.

وتعد ألمانيا من أوائل الدول التي شرعت لنظام السجل التجاري في تقنينها الصادر في سنة ١٨٩٧ ، ومن بعدها فرنسا بالتقنين الصادر في سنة ١٩١٩ ، وقد أخذ المشرع المصري بهذا النظام بالقانون رقم ٤٦ الصادر سنة ١٩٣٤ ، ثم ألغى بالقانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٥٣ والذي ألغى بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ ، ثم صدر قرار وزير التجارة رقم ٩٤٦ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ثم تناول التشريع التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ السجل التجاري في الفصل الرابع من الباب الأول بالمواد من ٣٠ إلى المادة ٣٣.

ونتناول في هذا المبحث وظائف القيد في السجل التجاري في مطلب أول. ثم في مطلب ثان الملزمون بالقيد في السجل التجاري ، وأخيراً نبين في المطلب الثالث أحكام القيد في السجل التجاري

المطلب الأول

وظائف القيد في السجل التجاري

يحقق القيد في السجل التجاري مجموعة من الوظائف ، تتمثل هذه الوظائف في الدور الإعلامي الذي يقوم به السجل التجاري ، حيث يزود من يتعامل مع التاجر بحقيقة موقفه المالي والتجاري. كما يمكن القيد في السجل التجاري من إحصاء عدد المشتغلين بالتجارة وحجم تجارتهم ، مما يمكن أجهزة الدولة المعنية بوضع الخطط الاقتصادية المناسبة لحجم تعاملاتها التجارية ، كل هذا بالإضافة إلى الوظيفة القانونية التي يحققها السجل التجاري. وبالتالي فإننا سنتحدث بشئ من التفصيل عن الوظائف الأربع التي يحققها القيد في السجل التجاري.

١- الوظيفة الإعلامية

أجازت المادة ١/٣٢ من قانون السجل التجاري لكل من له مصلحة ، في الاستعلام عن الوضع المالي والتجاري لمن يتعامل معه من التجار ، أن يحصل من السلطة المختصة على مستخرج رسمي من صفحة القيد الخاصة بذلك التاجر ، وفي حالة كون التاجر-المستعلم عنه- غير مقيد بالسجل ، فقد أجازت المادة لصاحب المصلحة إعطاءه شهادة تفيد عدم قيد هذا التاجر في السجل التجاري. غير إن ذات المادة حرصاً منها على سمعة التاجر إذا كان قد وقع في برائن الإفلاس ، ثم قضي برد اعتباره ، أو كان قد حجر عليه ، ثم قضي برفع هذا الحجر ، لم تجز هذه المادة أن يتضمن المستخرج أي بيان عن هذا الإفلاس أو الحجر.

وتأكيداً على الوظيفة الإعلامية للسجل التجاري ، أوجب قانون السجل التجاري على كل تاجر ، وكل مسئول عن إدارة شركة ، أن يبين في جميع المكاتبات ، والمطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية رقم القيد في السجل التجاري ، وأن يثبت على واجهة المحل الذي يزاول فيه العمل التجاري وباللغة العربية اسمه التجاري ، مشفوعاً برقم القيد. ومما هو جدير بالذكر- في خصوص هذه الوظيفة- أن المشرع التجاري بإقراره للوظيفة الإعلامية بنصوص صريحة ، يكون قد واکب التشريعات المقارنة ، والتي تعتبر هذه الوظيفة من أهم الوظائف التي يقوم بها السجل التجاري^١.

٢- الوظيفة الإحصائية

يحقق القيد في السجل التجاري وظيفة إحصائية ، تتمثل في قدرة الدولة في حصر عدد من يحترفون العمل التجاري فيها ، بالإضافة إلى الوقوف على حقيقة أوضاعهم المالية ، ونوع وطبيعة

الأعمال التي يقومون بها ، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين .
 وحتى يقوم السجل التجاري بهذه الوظيفة على الوجه الأكمل ، فقد شدد المشرع على صحة البيانات المقيدة في السجل ، وأعطى لموظف السجل سلطة التحقق من هذه البيانات ، كما أنه قرر عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه تقديم بيانات غير حقيقية ، أو يتقاعس عن تعديل ما يلزم تعديله من بيانات . كما أوجب القانون على قلم كتاب المحكمة التابع لها التاجر ، أن يخطر مكتب السجل التجاري بكافة الأحكام المتعلقة بالتاجر أو التجارة لقيدها ، كأن يتم شهر إفلاس التاجر ، أو أن يصدر حكم بالحجر عليه ، أو يصدر حكم بحل الشركة أو تعيين مصف لها ، وكذلك في حالة رد اعتبار التاجر أو رفع الحجر عنه ، بالإضافة إلى ما أوجبه قانون السجل التجاري على التاجر من إلغاء القيد في حالة اعتزال التجارة أو وفاته .
 ويذهب بعض الفقه-وهو ما نؤيده- إلى أن قانون السجل التجاري الاتحادي هو أحد التشريعات التي تلجأ إلى الأخذ بمبدأ القيد الوحيد-طبقاً للمادة الثانية منه- والتي تستوجب أن القيد يتم بالاسم الشخصي للتاجر حتى لا يقيد التاجر-في حالة تعدد المتاجر التي يملكها- برقم مختلف في كل قيد^٥.

٣- الوظيفة الاقتصادية

يترتب على قيد التجار في السجل التجاري ، إحاطة الدولة علماً بعدد ونوعية التجار والأنشطة التجارية في الدولة ، وأماكن تركيز تلك الأنشطة ، الأمر الذي يمكّن الدولة من رسم خططها الاقتصادية بصورة حقيقية؛ فتحدد الدولة الأنشطة التي ستتوسع فيها لحاجتها إليها ، والأنشطة التي عندها من التصنيع والتوزيع ما يكفيها. أضف إلى ذلك أن وقوف الدولة على حقيقة ونوعية الأنشطة التجارية ، يمكنها من معرفة الأنشطة التي تجذب الاستثمارات الأجنبية ، فتهتم بها الدولة وتضع لها الحوافز المناسبة بهدف جذب أكبر قدر من رؤوس الأموال الأجنبية.

٤- الوظيفة القانونية

من الوظائف الهامة التي يحققها القيد في السجل التجاري ، هي حجية البيانات المقيدة فيه ، بحيث لا يجوز إثبات عكسها ، بالإضافة إلى اكتساب الشخص صفة التاجر بمجرد القيد في السجل التجاري. والسؤال الآن هل يحقق القيد في السجل التجاري المصري هذه الوظيفة بهذه الحجية؟

في الواقع إن نظام السجل التجاري نظام إداري وليس قضائياً؛ حيث يعهد به إلى جهة الإدارة ، بخلاف ما عليه الحال في السجل التجاري الألماني ، فهو نظام قضائي يعهد به إلى القضاء وليس لجهة الإدارة ، لذلك فالقيد في السجل التجاري يحقق وظيفته القانونية على الوجه الأكمل^(١).
أما القيد في السجل التجاري المصري فليس دليلاً على اكتساب الشخص صفة التاجر ، لكنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس^(٢) ، كما أن عدم قيد الشخص في السجل التجاري ، لا يعني عدم تمتعه بصفة التاجر لو توافرت فيه شروط اكتسابها^(٣). كما أن البيانات المقيدة في السجل التجاري لا تفيد الحجية القاطعة لها ، لكنها تعتبر قرينة وإن كانت قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس.

ولا يعني قيد التصرف في السجل التجاري صحة هذا التصرف ، فالقيد في السجل التجاري لا يطهر التصرف من أسباب البطلان لو كان التصرف مشوباً بأحد أسباب البطلان^(٤). كما أن قيد التصرف في السجل التجاري لا يغني عن القيد في السجلات الأخرى المتعلقة بتلك الواقعة كالقيد في السجل التجاري بالإضافة إلى القيد في سجل الوكلاء التجاريين ، كما أن قيد التصرف الوارد على المحل التجاري المشتمل على عناصر خاصة في تسجيلها ، كبراءة الاختراع مثلاً ، لا يغني قيده في السجل التجاري عن القيد في السجلات الخاصة به.
ومما يجب التنبيه إليه أن قيد الاسم التجاري في السجل التجاري يحقق نفس الحماية التي يحققها القيد في النظام الألماني ، فيمنع من ازدواجية استعماله ، وتكون الأسبقية في الاستعمال لمن كان أسبق في قيد هذا الاسم بالسجل التجاري.

كذلك لا تكتسب الشركات التجارية ، باستثناء شركة المحاصة ، الشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري^(٥) ، كما أن أي تعديل يطرأ على عقد الشركة أو حتى تصفيتها لا يكون حجة على الغير إلا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري^(٦).

المطلب الثاني

الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري وشروطه أولاً الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري

تنص المادة ١/٣٠ تجاري على أنه (يعد في الجهة الإدارية المختصة سجل يقيّد فيه أسماء التجار أفراداً كانوا أم شركات). وقد حددت المادة الثانية من قانون السجل التجاري رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ الأشخاص الملزمين بالقيد في السجل التجاري وهم:

١- الأفراد الراغبون في مزاولة التجارة في محل تجاري

فيشترط فمن يقيد اسمه في السجل التجاري أن يكون مكتسباً لوصف التاجر طبقاً لما تقضي به المادة ١٠ من القانون التجاري ، كما يجب أن يكون هذا الشخص بجانب اكتسابه وصف التاجر أن يكون لديه محل تجاري في داخل جمهورية مصر العربية يباشر فيه تجارته ، وبالتالي فلا يكون ملتزماً بالقيد في السجل التجاري الباعة المتجولون ، كما لا يسري هذا الالتزام على الأفراد الذين يقومون عرضاً بأعمال تجارية ، ولا الشريك المتضامن بالرغم من اكتسابه وصف التاجر بمجرد انضمامه للشركة ، ولكن يكفي بذكر اسمه ضمن البيانات الخاصة بالشركة ، وذلك ما لم تكن له تجارة مستقلة عن تجارة الشركة.^(١)

٢- شركات الأشخاص والمساهمة والتوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة

فالشركات جميعها سواء كانت شركات تجارية أو مدنية فإنها طبقاً لنص المادة ٣٠ تجاري تكون ملتزمة بالقيد في السجل التجاري ، وفي ذلك تجاوز للفرقة التقليدية بين الشركات المدنية والشركات التجارية المبنية على طبيعة النشاط محل الشركة.^(٢) ولا يعني خضوع الشركات المدنية التي تتخذ الشكل التجاري للقيد في السجل التجاري أنها تكتسب وصف التاجر؛ إذ تبقى كما هي شركات ذات طبيعة مدنية لا تكتسب وصف التاجر^(٣) بالرغم من قيدها بالسجل التجاري ، ولا يسري هذا الالتزام على الشركات التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية كشركات المحاصة؛ حيث أنها شركات مستترة وبالتالي فلا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للقيد في السجل التجاري.^(٤)

٣- الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطاً تجارياً

يقصد بالأشخاص الاعتبارية العامة شركات القطاع العام والمؤسسات العامة التي تمارس النشاط التجاري ، والحكمة من وراء إلزام الشخص الاعتباري بالقيد في السجل التجاري إنما ترجع إلى تحقيق العلانية في المواد التجارية. ويرى بعض الفقه^(٥) أن قيد الأشخاص الاعتبارية العامة لم يعد له محل للتطبيق في ظل أحكام القانون التجاري الجديد؛ حيث تنص المادة ٢٠ تجاري على عدم ثبوت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام ، ويخلص من ذلك إلى أن حكم المادة ٢٠ تجاري يلغي الحكم الوارد بقانون السجل التجاري بقيد الأشخاص الاعتبارية العامة

بالسجل التجاري.

ولا نرى وجها لما ذهب له هذا الرأي؛ حيث إن نص المادة ٢٠ تجاري لا يتعارض مع الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون السجل التجاري بقيد الأشخاص الاعتبارية العامة بالسجل التجاري ، حيث إنه لا يترتب على القيد بالسجل التجاري اكتساب الصفة التجارية^٥ ، وما دام قيد الأشخاص الاعتبارية العامة بالسجل التجاري لا يترتب عليه اكتساب الصفة التجارية فالنتيجة أنه لا تعارض بين نص المادة ٢٠ تجاري ونص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون السجل التجاري.

ومن الملاحظ أن المشرع قد اشترط بالنسبة للشخص الاعتباري العام الملتزم بالقيد في السجل التجاري أن يزاول الأعمال التجارية بنفسه ، أما إذا اقتصر دوره على الإشراف الإداري والمالي على نشاط أشخاص أخرى فلا يكون ملزما بالقيد في السجل التجاري^٥ كما هو الشأن بخصوص هيئات القطاع العام الخاضعة للقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣.

٤ - الجمعيات التعاونية التي تبشر نشاطا تجاريا

تقوم الجمعيات التعاونية على تقديم الخدمات للجمهور دون أن تهدف من وراء ذلك لتحقيق ربح مادي ، ومع هذا فإن هذه الجمعيات التعاونية ما دامت تمارس نشاطاً تجارياً حتى لو لم تكتسب صفة التاجر فإنها طبقاً للمادة الثانية من قانون السجل التجاري رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ تلتزم بالقيد في السجل التجاري تحقيقاً للعلانية في المواد التجارية.

٥ - الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة من المنشآت الأجنبية

ومن أمثلة هؤلاء وكلاء تسويق السيارات الأجنبية في مصر ، فيلتزم هؤلاء الأشخاص بالقيد في السجل التجاري ، فضلا عن قيدهم في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك بوزارة الاقتصاد والتجارة إعمالاً لنص المادة الثانية من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.

ثانياً شروط القيد بالسجل التجاري

طبقاً لما تقضي به المادة الثالثة من قانون السجل العيني رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ فإنه يشترط فيمن

يقيد في السجل التجاري- بالإضافة لكونه من الأشخاص السابق بيانهم- ما يلي:-
أن يكون مصرياً.

وأن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة.
ويكفي توافر هذين الشرطين فيمن كان يتمتع بالجنسية المصرية ، أما الأجانب غير المصريين فقد أراد المشرع أن يستوثق من النشاط التجاري للأجانب في مصر حتى يضمن سلامة البنيان الاقتصادي للبلاد ، فنص في المادة الرابعة من قانون السجل التجاري على شروط يجب توافرها في شأن الأجانب الذين يمارسون التجارة بمصر حتى يتمكنوا من تسجيل أسمائهم بالسجل التجاري وهي:-

موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في حالة المشروعات التي تنشأ وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، وقد صدرت لائحته التنفيذية بقرار من رئيس الوزراء رقم ٢١٠٨ لسنة ١٩٩٧ .
إذا كان الأجنبي شريكاً في شركة من شركات الأشخاص فإنه يشترط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصرياً ، وأن يكون للشريك المصري المتضامن حق التوقيع والإدارة ، وأن تكون حصة الشركاء المصريين ٥١٪ على الأقل من رأس مال الشركة.
كل شركة أياً كان شكلها القانوني يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها في الخارج إذا زاولت في مصر أعمالاً تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاوله بشرط موافقة هيئة الاستثمار .
الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفي حدود هذا النشاط سواء كانوا أفراداً أو شركاء في شركات أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم في رأس المال.^٥

المطلب الثاني

أحكام القيد بالسجل التجاري

يجب على كل تاجر توافرت فيه الشروط القانونية للقيد بالسجل التجاري أن يقدم طلباً لمكتب السجل التجاري الواقع في دائرة محله التجاري خلال شهر من تاريخ الترخيص له بمزاولة التجارة في المحل التجاري. ويتم تحرير طلب القيد من نسختين على النماذج المعدة لهذا الغرض وترفق بها المستندات المؤيدة لها وفقاً للمادة ٨ من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري ، ويجب أن يكون الطلب مكتوباً باللغة العربية وبخط واضح دون اختصار أو تغيير أو تحشير أو محو أو كشط ، وأن يوقع الطالب على كل إضافة أو تصحيح بمامشها ، وأن تحصر عدد الكلمات

المضافة أو الملغاة ويؤشر عليها مكتب السجل التجاري بما يفيد المراجعة^١ - وطبقاً للملحق رقم ١- بشأن طلبات السجل التجاري والمرفق باللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٤٦ لسنة ١٩٧٦ ، فإنه يجب أن يشتمل طلب القيد على بيانات تختلف هذه البيانات على حسب ما إذا كان طالب القيد تاجراً- فرداً أو شركة أو فرع أو جمعية تعاونية تباشر نشاطاً تجارياً أو منشأة تجارية بها عنصر أجنبي ، فإذا كان طالب القيد فرداً فإن طلبه يجب أن يشتمل على البيانات الآتية

اسم التاجر ولقبه وجنسيته وتاريخ وحل ميلاده وأهليته التجارية.

الاسم التجاري ، واسم محله التجاري والسمة التجارية إن وجدت ونوع تجارته.

رأس المال المستثمر في التجارة.

تاريخ بدء مزاوله طالب القيد للتجارة في مصر والترخيص له بمزاولة المهنة.

عنوان المحل التجاري الرئيس وعنوان الفروع التابعة له سواء في مصر أو في الخارج.

أسماء وألقاب الوكلاء المفوضين وجنسياتهم وتاريخ ومحل ميلادهم.

المحال التجارية التي كانت للتاجر سابقاً في دائرة مكتب السجل التجاري ذاته أو في دائرة أخرى مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ الترخيص له بمزاولة التجارة ورقم قيده في السجل التجاري وتاريخ غلقه.

رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر.

أما إذا كان طالب القيد بالسجل التجاري شركة تجارية ، فإنه يجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:-

نوع الشركة وعنوانها واسمها أو السمة التجارية إن كانت موجودة.

الغرض من تأسيس الشركة ، وعنوان مركزها الرئيسي وفروعها داخل مصر وخارجها.

رأس المال الإجمالي وما تم دفعه منه وما يجب على كل شريك أن يؤديه من مبالغ وتاريخ ذلك ، مع بيان حصة الشركاء الأجانب وحصة الشركاء المصريين ، وقيمة الحصة العينية.

تاريخ بدء الشركة وإنهائها ، وتاريخ الترخيص لها بمزاولة مهنة التجارة.

تاريخ موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.

أسماء وألقاب الشركاء المتضامنين وجنسياتهم وتاريخ ميلاد كل منهم.

أسماء وألقاب الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها ، وجنسياتهم ، وتاريخ ميلاد كل منهم مع بيان سلطتهم في الإدارة والتوقيع .
أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة ، ووكلاء المدين وصفة كل منهم ، ومدى سلطتهم في الإدارة والتوقيع ، وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته .

رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية إذا وجدت . **ثانياً**
سلطة مكتب السجل التجاري في التحقق من صحة البيانات

طبقاً لما تقضي به المادة ٨ من قانون السجل التجاري فإنه من حق مكتب السجل التجاري أن يكلف طالب القيد بتقديم ما يراه لازماً من مستندات تؤيد صحة بيانات طالب القيد في السجل أو التأشير فيه بتغيير أي تعديل يطرأ على بيانات سبق قيدها(.) كما أن من حق مكتب السجل أن يرفض الطلب المقدم إذا لم تتوافر فيه الشروط القانونية المطلوبة ، ولكن بشرط أن يكون الرفض مسبباً ، وأن يبلغ إلى طالب القيد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب ، ولمقدم الطلب أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري في المواعيد المقررة للطعن في القرارات الإدارية . فإذا كان الطلب مستوفياً لجميع البيانات والشروط المطلوبة فإن الطلب يتم قيده بحسب إيداعه لدى مكتب السجل التجاري ، ويكون القيد بأرقام متتابعة في السجل . وقد ألزم القانون في المادة الخامسة منه كل من قيد اسمه بالسجل التجاري سواء كان فرداً أو شركة أن يكتب على واجهة محله وفي مطبوعاته اسمه التجاري ، بالإضافة لبيان مكتب السجل التجاري التابع له ورقم قيده فيه .

ثالثاً: التأشير بتعديل أو تغيير البيانات المقيدة بالسجل :

طبقاً لما تقضي به المادة ٦ / ١ من قانون السجل التجاري فإنه يجب على كل من تم قيده بالسجل أن يطلب طبقاً للأوضاع المقررة التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تتطلب ذلك ، كما أوجبت الفقرة الثانية من نفس المادة على مكتب السجل التجاري أن يؤشر من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر أو بالشركة يتم قيده في السجل المنصوص عليه في القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها .

وطبقاً لما تقضي به المادة ٧ من قانون السجل التجاري فإنه يجب على قلم كتاب المحكمة التي تصدر أحكاماً ضد أحد التجار أو الشركات أن يرسل صورة من هذا الحكم خلال شهر من

تاريخ صدوره إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمقتضاه في السجل. وهذه الأحكام كما وردت بالمادة السابعة من قانون السجل التجاري هي: أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه ، والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديله.

أحكام قفل التفليسة وأحكام إعادة فتحها.

أحكام إعادة رد الاعتبار.

الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو بإبطاله أو إقفال إجراءاته والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو فسخه أو بإبطاله. الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر على التاجر أو بتعيين القائمة^٥ والوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجر.

القرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر بالتجار في محل تجاري أو بإلغائه أو بالحد منه.

الأحكام الصادرة بالبطان أو التفرقة الجسمانية أو المالية إذا اقتضى الحال ذلك.^٥

أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين.

أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها ، وتعيين المصفيين وعزلهم.

رابعاً: تجديد القيد

طبقاً لما تقضي به المادة ٩ من قانون السجل التجاري فإن التاجر المقيد بمكتب السجل التجاري التابع له يلتزم كل خمس سنوات بتجديد قيده بالسجل من تاريخ القي أو من تاريخ آخر تجديد ، ويتم تقديم طلب التجديد خلال شهر قبل انتهاء مدة الخمس سنوات من القيد أو التجديد ، وبمنح التاجر فرصة أخرى للتجديد إذا فاتته الموعد السابق ، وذلك بتقديم طلب التجديد خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء مدة الخمس سنوات بشرط أن يلتزم طالب التجديد بأداء رسم مضاعف للقيد.

ويتم محو القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد انتهاء مدة التسعين يوماً من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول^٥. ويعد ذلك قرينة على اعتزاله التجارة ، ووجوب رفع اسمه من السجل التجاري حتى يؤدي السجل وظيفته الإحصائية بدقة ، وحتى يظل معبراً عن الواقع بصفة مستمرة.^٥

خامساً: محو القيد

يتم محو قيد التاجر أو من يؤول إليه المحل التجاري أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري من السجل التجاري طبقاً للمادة ١٠ من قانون السجل التجاري وذلك في الأحوال الآتية:-
اعتزال التاجر للتجارة ومغادرته البلاد نهائياً أو وفاته.
انتهاء تصفية الشخص الاعتباري أو توقف نشاطه.

وطبقاً للمادة ١١ من قانون السجل التجاري فإنه يتم تقديم طلب المحو خلال شهر من تاريخ الواقعة التي استوجبت المحو ، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من الواقعة التي أدت إلى ذلك ، وعلى المكتب في هذه الحالة أن يبلغ صاحب الشأن خلال العشرة أيام التالية بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وأن يخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه.

المطلب الثالث

الآثار المترتبة على القيد بالسجل التجاري

رتب القانون مجموعة من الآثار على القيد بمكتب السجل التجاري ، تنبع هذه الآثار من الوظيفة التي يقوم بها السجل التجاري كأداة إحصاء لمعرفة عدد المشروعات التجارية ، كما رتب القانون جزاء جنائياً ضد كل من يحاول أن ينال من صدق وأمانة البيانات المدونة بالسجل التجاري ، ونعرض أولاً للآثار التي تترتب على القيد بالسجل التجاري ثم نعرض ثانياً للجزاء الجنائي المطبق على من يدلي ببيانات غير حقيقية للقيد بالسجل التجاري.

أولاً: الآثار التي تترتب على القيد بالسجل التجاري

يترتب على قيد الشخص بالسجل التجاري اكتسابه صفة التاجر ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة أخرى. فالقيد بالسجل التجاري- طبقاً للمادة ١٧ تجاري- يعد قرينة على اكتساب الشخص صفة التاجر ، غير أن هذه القرينة ليست قاطعة ولكنها تقبل إثبات عكسها^(١). ولم يصل قانون السجل التجاري رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ بالبيانات المدونة فيه إلى اعتبارها حجة على الغير كما هو الحال في قانون السجل التجاري الفرنسي الصادر في ١٩٥٣/٨/٩^(٢).

يترتب على القيد في السجل التجاري حماية كبيرة للاسم التجاري المقيد بدفاتر مكتب السجل التجاري ، فقد نصت المادة ٣ من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ بشأن الأسماء التجارية أنه (إذا

قيد الاسم التجاري في السجل التجاري وشهر وفقاً لأحكام اللائحة التي تصدر لهذا الغرض فلا يجوز لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة مكتب السجل التجاري الذي حصل فيه القيد ، وإذا كان اسم التاجر الآخر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد في السجل وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بياناً يميزه عن الاسم السابق قيده ، ويسري هذا الحكم على الفروع الحديثة للمحل التجاري.

يرتب القيد بالسجل التجاري الحق لصاحب القيد الانتخاب والعضوية بالغرف التجارية ، كما يتمتع صاحب القيد بالسجل التجاري بمزايا الصلح الواقعي من الإفلاس^(١). وقد علق المشرع على القيد بالسجل أهمية كبيرة بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ، إذ أن هذه الشركات لا تكتسب الشخصية الاعتبارية ولا يجوز لها أن تبدأ عملها إلا بعد القيد بالسجل التجاري ونشر محررها في النشرة التي تصدرها وزارة التجارة لهذا الغرض^(٢).

ثانياً: الجزاء الجنائي

رتب قانون السجل التجاري بالمادتين ١٨-١٩ منه بعض الجزاءات الجنائية على مخالفة أحكام القوانين الخاصة بالسجل التجاري ، فقد نصت المادة ١٨ من قانون السجل رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ على أنه (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن علي سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين:-

كل من يقدم يغير قصد بيانات غير صحيحة بطلبات القيد أو التأشير في السجل التجاري أو التحديد أو المحو ، وتأمّر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقاً للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها ، ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح. كل من ذكر على واجهة محله التجاري أو على إحدى مراسلاته أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بتجارته اسماً تجارياً أو رقماً ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله.

ج- كل من يقوم بتنفيذ هذا القانون إذا أفشى سراً (اتصل به بحكم عمله). كما نصت المادة ١٩ من نفس القانون على أن (كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهاً ولا تجاوز مائة جنية ، وتضاعف الغرامة لا تقل عن

عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية ، وتضاعف الغرامة في حالة العود ، كما قضت نفس المادة بإغلاق المحل التجاري في حالة مزاولة التجارة في محل تجاري بدون القيد في السجل التجاري. وتعتبر هذه العقوبة تبعية بجانب الغرامة المنصوص علي ها بنفس المادة.

الباب الثالث

المتجر

تحتل المحال التجارية مركزاً خطيراً في الحياة التجارية ، كما أنها قد أصبحت مركزاً لرؤوس الأموال الضخمة ، وقد زاد من أهمية تلك المحال التجارية وجعل منها موضوعاً للصفقات التجارية زيادة النشاط التجاري واتساع الأسواق التجارية ، ولما كان المحل التجاري يمثل أداة التاجر لمباشرة النشاط التجاري فقد تكفل المشرع بحمايته من الأعمال غير المشروعة التي تضر بالاستغلال التجاري ، كما أن المحل التجاري باعتباره مالاً منقولاً فهو يعد محلاً للمضاربات إذ أنه يمكن للتاجر أن يبيعه أو أن يرهنه أو أن يؤجره ، ولذلك فإننا نقسم هذا الباب إلى الفصول الآتية:-

الفصل الأول: ذاتية المحل التجاري.

الفصل الثاني: حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة.

الفصل الثالث: التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري.

الفصل الأول

ذاتية المحل التجاري

نتناول في المبحث الأول من هذا الفصل تعريف المحل التجاري وطبيعته القانونية ، ثم نتناول في المبحث الثاني خصائص المحل التجاري وأهميته الاقتصادية ، وأخيراً نتناول في المبحث الثالث من هذا الفصل العناصر التي يتكون منها المحل التجاري.

المبحث الأول

تعريف المحل التجاري وطبيعته القانونية

تنقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين اثنين نبين في الأول منهما اتجاهات فقهاء القانون في تعريف المحل التجاري ، أما المطلب الثاني فإننا نخصه ببيان الطبيعة القانونية للمحل التجاري.

المطلب الأول

تعريف المحل التجاري

لم يتعرض المشرع في قانون المحل التجاري - سواء في فرنسا ١٩٠٩ أو في مصر ١٩٤٠ - لتعريف المحل التجاري وإنما اكتفى فقط بذكر العناصر الداخلة في تكوين المحل التجاري ، وخيراً فعل المشرع إذ إن وضع التعريف ليس من مهمة المشرع وإنما هي من مهام الفقه ، ومن هنا كان على الفقه أن يعالج هذا النقص بوضع تعريف للمحل التجاري.

ولما كان الفقه لم يتفق على طبيعة المحل التجاري فلم يبلغ في تعريفه حد الإجماع^(١) ، وذلك على الرغم من اتفاق الفقهاء على أن عنصر الاتصال بالعملاء هو قلب فكرة المحل التجاري ، وأنه أساس لوجوده ، ويمكننا أن نقسم اتجاهات الفقهاء القانونيين في تعريف المحل التجاري إلى ما يلي:

الاتجاه الأول^(٢)

يعتمد أنصار هذا الاتجاه في تعريفهم للمحل التجاري على إبراز طبيعة المحل التجاري كمال منقول معنوي فعرفوه بأنه (مال منقول معنوي يتضمن مجموعة عناصر مادية ومعنوية ومخصص لاستغلال تجارة أو صناعة معينة).

الاتجاه الثاني^(٣)

يبرز أصحاب هذا الاتجاه - في تعريفهم للمحل التجاري - دور العناصر التي يشتمل عليها المحل التجاري سواء المادية أو المعنوية فعرفوه بأنه (مجموع من الأموال المنقولة - المادية والمعنوية - يستثمرها التاجر في نشاطه التجاري والتي تسمح بتحصيل عنصر الاتصال بالعملاء). أو بأنه (مجموعة من الأموال المنقولة - المادية والمعنوية - التي يستخدمها التاجر في مباشرة حرفته ، ويشمل ذلك البضائع وأثاث المحل وسيارته وآلاته وشهرة اسمه وما يكون لديه من براءة اختراع وما إلى ذلك مما يستعين به التاجر في مباشرة التجارة).

الاتجاه الثالث

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن المحل التجاري ما هو إلا عنصر الاتصال بالعملاء ولذلك عرفوا المحل التجاري بأنه (ملكية معنوية تتكون من حق الاتصال بالعملاء والذي يرتبط أساساً بالعناصر المستخدمة في الاستغلال التجاري)^(٤).

ولم تقتصر المحاولات في تعريف المحل التجاري على الفقه وحده ، فقد شاركه القضاء في محاولة

إيجاد تعريف للمحل التجاري فعرّفه بأنه (كتلة من الأموال المنقولة تخصص لممارسة مهنة تجارية يتضمن عناصر معنوية وقد يشتمل أيضاً على عناصر أخرى مادية ، والعناصر التي تتركب منها هذه الكتلة لا تذوب فيها ولا تتلاشي في محيطها ولا تتفاعل فيما بينها تفاعلاً يترتب عليه فقدان معالمها أو خصائصها إنما يظل كل عنصر منها محتفظاً بذاتيته وطبيعته خاضعاً للقواعد القانونية الخاصة به^(١). كما نجد محكمة النقض المصرية في أكثر من حكم لها تؤكد على العناصر المعنوية للمتجر واعتبارها الاتصال بالعملاء هو العنصر الرئيسي للمتجر وأنه لا يتصور وجود المتجر بدون عنصر الاتصال بالعملاء.^(٢)

وقد وضع المشرع المصري في قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ تعريفاً للمحل التجاري ركز فيه على إبراز عنصر الاتصال بالعملاء والأموال المنقولة التي يتكون منها المتجر فعرّفه بأنه (مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية).

المطلب الثاني

الطبيعة القانونية للمحل التجاري

نظراً لأن المحل التجاري يتكون من مجموعة من العناصر المنقولة والتي تختلف في طبيعتها- فبعضها مادي والآخر معنوي- فقد ساد جدل فقهي ساد جدل فقهي كبير مضمونه هل يمكن اعتبار المحل التجاري مجموعاً قائماً بذاته ومتميزاً عن عناصره؟ أم أن هذه العناصر تبقى متفرقة فلا ينتج من اجتماعها وحدة مستقلة ومتميزة عن أفرادها^(١)؟ لكن سرعان ما انتهى هذا الجدل باتفاق فقهي^(٢)- قد يصل إلي حد الإجماع - معتبراً المحل التجاري مجموعاً مستقلاً بذاته عن العناصر الداخلة في تركيبته وتكوينه. وعلى الرغم من اتفاق فقهاء القانون على اعتبار المحل التجاري مجموعاً إلا أن آراء الفقهاء قد تضاربت حول طبيعة هذا المجموع هل هو مجموع قانوني أم أنه مجموع واقعي^(٣)؟ ونعرض لهذه الآراء في فروع ثلاثة.

الفرع الأول

نظرية المجموع القانوني^(٤)

يأخذ الفقه الألماني بنظرية المجموع القانوني والتي تفترض أن المحل التجاري مجموع قانوني أو ذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر ، وأنه ثروة تجارية متكونة من مجموع القيم المخصصة للاستغلال التجاري ومنفصلة تماماً عن الأموال الأخرى للتاجر ، وأنها تضمن- في حدود هذه القيم- ما عليها من ديون أو التزامات ، وبالتالي فإنه في حالة إفلاس المحل التجاري لا يكون لدائنيه إلا التنفيذ على ما تضمنه المحل من أموال دون أن يكون لهم الحق في التنفيذ على أموال صاحب المحل التجاري الأخرى^(٥) ، كما أن لدائني المتجر أن ينفردوا بالتنفيذ عليه دون مزاحمة الدائنين الآخرين للتاجر؛ لأنه- طبقاً لهذه النظرية- يعد المحل التجاري وحدة قانونية مستقلة عن شخص التاجر.

تقييم نظرية المجموع القانوني

تنسجم نظرية المجموع القانوني- والتي نادي بها الفقه الألماني- مع الأصول العامة للتشريع الألماني والتي تجيز تعدد الذمم وتخصيص كل منها لعمليات معينة. أما في ظل التشريع المصري والفرنسي فإن الأخذ بهذه النظرية يتعارض مع مبدأ وحدة الذمة المالية السائد في التشريعين المصري والفرنسي والذي يقضي بأن جميع أموال المدين تكون ضامنة لجميع ديونه^(٦) كما أن هذه النظرية

تعارض مع ما هو مسلم به في قانوننا من أن التنازل عن المحل التجاري لا يترتب عليه - بقوة القانون - انتقال الحقوق الشخصية والالتزامات التي نشأت عن استغلال المحل التجاري^(١) وبالتالي فإن الأخذ بهذه النظرية يتعارض مع المبادئ القانونية السائدة في هذين التشريعين.

الفرع الثاني نظرية المجموع الواقعي

أما نظرية المجموع الواقعي^(١) فتتنظر إلى المحل التجاري على أنه مجموع واقعي من الأموال يتألف من مجموعة من العناصر المختلفة في طبيعتها بهدف الاستغلال التجاري ، مع خضوع هذا المجموع لنظام قانوني واحد وما يترتب على ذلك من آثار نتيجة هذا الاستغلال ، غير إن كل عنصر من هذا المجموع يظل محتفظاً بطبيعته القانونية الخاصة ونظامه القانوني الخاص عند التعامل عليه منفرداً عن المحل التجاري.

وبالتالي فهذه النظرية لا تعتبر المحل التجاري ذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر ، وإنما عنصر من عناصر المالية للتاجر ، وهو ما يؤدي إلى أنه في حالة تنازل المالك عن المحل التجاري للغير فلا يستتبع ذلك التنازل عن الحقوق الشخصية أو الالتزامات التجارية إلى المتنازل إليه إلا إذا وجد اتفاق خاص يقضي بذلك.

تقييم نظرية المجموع الواقعي

لم تلق نظرية المجموع الواقعي تأييداً كبيراً من جانب الفقه ، إذ أنها لم توضح الطبيعة القانونية للمحل التجاري فيما عبرت به عن المحل التجاري وإنما قررت واقعاً؛ فالمطلوب هو معرفة الطبيعة القانونية للمحل التجاري ، وليس تقرير اجتماع عناصر المحل التجاري بقصد الاستغلال التجاري. فالمجموع الواقعي من الأموال ليس له معني قانوني ، فالمجموع من الأموال إذا وجد فلا يكون إلا قانونياً ويعترف القانون له بشخصية اعتبارية لها ذمة وأهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقرها القانون ، والمحل التجاري بوجه عام ليس من هذا القبيل^(٢). إذ أنه لا ينفصل عن الذمة المالية للتاجر.

الفرع الثالث

نظرية الملكية المعنوية

على الرغم من المحل التجاري يتكون من خليط من المنقولات المادية والمعنوية إلا أن أنصار نظرية الملكية المعنوية يعتبرون المحل التجاري ملكية معنوية على أساس أن العناصر المعنوية الداخلية في تكوين المحل التجاري تفوق في أهميتها العناصر المادية؛ ودليل ذلك أن رهنه لا يخضع لقاعدة الحيازة التي تخضع لها المنقولات المادية حتى أن البعض - كما بينا - قد اعتبر المحل التجاري هو الاتصال بالعملاء. وقد اعتنق هذه النظرية غالب الفقه^(١) وكذلك القضاء^(٢).

المبحث الثاني

خصائص المحل التجاري وأهميته الاقتصادية

المطلب الأول

خصائص المحل التجاري

أبرز الفقهاء مجموعة من الخصائص التي يتميز بها المحل التجاري ، ومن أهم هذه الخصائص أنه منقول معنوي ، ويتمتع بالصفة التجارية ، وأن القواعد المطبقة علي المتجر علي كمجموع تختلف عن القواعد المطبقة علي عناصره منفردة وذلك علي التفصيل الآتي:

أولاً: المحل التجاري مال منقول معنوي

لما كان المحل التجاري يتألف من مجموعة من العناصر المادية والمعنوية وكلها عناصر منقولة يجمعها التاج لمزاولة مهنة التجارة ، ولما كانت فكرة المحل التجاري ليس لها جود مادي ملموس فلا يتصور بالنسبة لها الاستقرار والثبات للذات هما من صفات العقار ، فإنه وتطبيقاً للرأي السائد في الفقه المصري- فإن المحل التجاري يعتبر هو الآخر مالا منقولاً معنوياً.

وتجدر الإشارة إلي أن المحل التجاري وإن كان يضم بين عناصره بعض العناصر المادية كالبضائع والمهمات- إلا أنه لا يعتبر منقولاً مادياً ، وإنما هو منقول معنوي ، فقد تجاوز الفكر القانوني هذه العناصر الظاهرة إلي العناصر المعنوية غير الملموسة نظراً لأهميتها ودورها الخطير في مجال المحال التجاري من الناحية الاقتصادية^(١) ، ويترتب علي كون المحل التجاري مالا منقولاً معنوياً ما

يلي:

أنه يخضع بحسب الأصل للنظام الخاص بالمنقول ، وإذا كان المشرع يخضعه في بعض الأموال للأحكام الخاصة بالعقار - كما هو الحال بالنسبة للقواعد العامة بامتياز البائع ورهن المحل التجاري ، إلا أنه ذلك لا يؤثر علي طبيعة المتجر باعتباره مالاً منقولاً ، فلا يجوز - مثلاً - تقرير حقوق الارتفاق علي المتجر ، لأن هذه الحقوق لا تتقرر إلا علي العقار^٥. لا تسرى على المتجر القواعد الخاصة بالمنقولات المادية كقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية حيث يشترط لسريانها التسليم المادي وهو ما لا يمكن تصوره في المتجر. كما يترتب على اعتبار المحل التجاري منقولاً أنه إذا أوصى تاجر لآخر بجميع أمواله المنقولة فإن محله التجاري يدخل فيها^٥.

ثانياً: الصفة التجارية للمحل التجاري

يتميز المحل الخاضع للتنظيم القانوني للمحلات التجارية بأنه تجاري^٥ ، وهو في هذا يختلف عن المحلات المدنية أو الصناعية والتي لا تخضع لأحكام هذا التنظيم لعدم تمتعها بالصفة التجارية. ويجب لاعتبار المحل تجارياً أن يكون مستغلاً في نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية. فإذا كانت صفة التجارية تطلق عادة على العمل أو الحرفة أو النشاط بوجه عام ولا تطلق على الأموال سواء كانت عقارات أو منقولات ، فإن هذا المنقول المعنوي - المحل التجاري - يقترن بصفة التجارية وتلك هي إحدى خصائصه^٥. فإذا كان المحل غير تجاري بأن انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية ، بأن كان المحل مستغلاً في نشاط مهني أو حرفي قوامه الاعتماد وبصفة رئيسية على المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية فلا يعتبر محلاً تجارياً حتى لو توافر لهذا المحل غير التجاري عنصر الاتصال بالعملاء ، وهو ما قضت به محكمة النقض في العديد من أحكامها^٥.

ثالثاً: اختلاف القواعد المطبقة على المتجر عن القواعد المطبقة على عناصره منفردة

يتميز المحل التجاري بأنه يتكون من مجموعة من العناصر المادية والمعنوية ، وأن هذه العناصر تكون في مجموعها ذلك المجموع المعروف بالمحل التجاري ، وأن هذا المجموع تطبق عليه مجموعة من القواعد القانونية تختلف عن تلك التي تطبق على كل عنصر من هذه العناصر على انفراد ، من ذلك مثلاً أن رهن المحل التجاري لا يقتضي انتقال حيازته إلي الدائن المرتهن ، بينما يلزم

انتقال حيازة أحد عناصره المكونة له لو تم رهن هذا العنصر على انفراد^(١) باستثناء العلامة التجارية التي لا يجوز رهنها أو التصرف فيها على انفراد وإنما ضمن عناصر المتجر المرهون^(٢).

المطلب الثاني

الأهمية الاقتصادية للمحل التجاري

يمثل المحل التجاري- على الرغم من بعض نقائصه- بنيانا ماليا حيويا يتماشى مع حقيقة اقتصادية هامة وهي أن المحل التجاري هو المشروع التجاري الصغير لبنيان ذاتي أو أسرى.

وقد أوضحت دراسات على مدى عشرين عاما بمركز البحث بالغرفة التجارية والصناعية بباريس بأن التعديلات الواردة على قانون المشروع لم تغير من الحقيقة الثابتة وهي أن المحل التجاري هو عصب الحياة القانونية للمشروع^(٣)؛ بحيث إن المحل التجاري- يبقى في الغالب- البنيان القانوني الوحيد للاستثمار الفردي ، ثم بعد ذلك حتى لو كان المشروع التجاري منظما في شكل شركة فإن هذا النظام يندرج تحت شركة الشخص الواحد أو الشركة متعددة الأفراد فالمحل التجاري لا يخفي لفي كلاهما فهو يأخذ غالبا مكانا في حضان الذمة المالية للشركة^(٤).

وما زالت فكرة المتجر تتطور ويرتبط تطورها الحديث بفكرة المشروع وإذا كان المشروع يتميز بالشخص الذي يقوم بالاستغلال فإن المتجر يتميز بأنه يضم الأموال التي تكون موضوعاً للاستغلال التجاري ، حيث يشتمل المتجر على طائفة من العناصر المادية والمعنوية التي تحقق- مجتمعة- الهدف من ذلك الاستغلال ويتولد من اجتماعها مال مستقل بنظامه الخاص عن كل عنصر أو مال داخل في التركيب. وما من شك أن التطبيق المحدود للمتجر في ميدان التجارة يعجز عن شمول كافة صور النشاط الاقتصادي ، ثم إن تطور ذلك النشاط أدّى إلى ظهور وحدات اقتصادية معقدة بدرجة كبيرة وهي المشروعات بأشكالها المختلفة حتى أن مفهوم المتجر يقصر عن إيضاح مدى تباينها والتعبير عن ثرائها^(٥).

وفي ميدان الصناعة فإن المتجر يكتسب أهمية كبيرة في هذا الميدان؛ إذ أن الصانع يقوم بتحويل المادة الأولية وهيئتها بهيئة ، أخرى لتتحول بعد ذلك إلى سلعة شبه مصنعة أو إلى سلعة كاملة الصنع ، ثم يحدد ثمن البيع بمراعاة مصروفات الاستغلال ، وقد يعتبر المصنع متجرا متى توافرت له مقوماته المادي والمعنوية وبعبارة أخرى إذا لم يقتصر على تشكيل المواد الأولية والسلع شبه

المصنعة وإنما يعرض السلع- بعد صنعها- للبيع عن طريق الاتصال بالعملاء على وجه مباشر وهكذا يمكن القول بأن المتجر أداة للمشروع الصناعي أيضاً^(١).

كما أن المحل التجاري يمكن أن يكون وسيلة لتوفير حصيلة من النقد الأجنبي فيرخص للمنشآت السياحية التي يحددها وزير السياحة بقبول النقد الأجنبي مقابل ما تقدمه من خدمات على أن تقوم بتقديم حصيلة كل يوم من النقد الأجنبي إلى أحد المصارف المعتمدة وذلك في يوم العمل التالي مباشرة وتتولى وزارة السياحة الإشراف على هذه العمليات^(٢). وفي اعتقادنا أن دور المتجر- في يوم العمل التالي مباشرة وتتولى وزارة السياحة الإشراف على هذه العمليات^(٣). وفي اعتقادنا إن دور المتجر- في هذا الصدد- ينطوي على أهمية خاصة بشرط الاستفادة من النقد الأجنبي بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المبحث الثالث

عناصر المحل التجاري

يتكون المحل التجاري من مجموعة من العناصر المادية والمعنوية وقد ورد النص عليها في المادة ٣٤ من قانون التجارة الجديد في الفقرتين الثانية والثالثة وتتناول في مطلبين اثنين بيان هذه العناصر نخصص الأول منها لبيان العناصر المعنوية ، والثاني لبيان العناصر المادية للمحل التجاري.

المطلب الأول

العناصر المعنوية للمحل التجاري

ذكر المشرع التجاري في الفقرة الثانية من المادة ٣٤ تجاري العناصر المعنوية التي يجوز أن يتضمنها المحل التجاري فنص على أنه (يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخرى كالاسم التجاري والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق في الإيجار وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة).

أولا الاسم التجاري

الاسم التجاري^(٤): هو ذلك الاسم الذي يطلقه التاجر على محله التجاري لتمييزه عن غيره من المحلات الأخرى وهو الذي يعرف به التاجر . غالبا . في نشاطه التجاري ، وقد يكون مشتقا من

لقب التاجر أو من اسم آخر مستعار^(١) مع مراعاة أن لا يسبب هذا الاسم المستعار ضررا للآخرين ، وقد يكون . الاسم التجاري . تسمية متخيلة . من اسم مركب . بشرط أن لا يوحي بوجود شركة .

ويجب عدم الخلط بين الاسم التجاري *le nom commercial* للمحل التجاري وبين الاسم المدني *le nom civil* للتاجر مالك المحل ، فالأول لا يعتبر لصيقا بشخص التاجر ت كالأسم المدني . وإنما يخول له حقا ماليا باعتباره عنصرا من عناصر المحل المهرهون .

ولما كان الهدف من الاسم التجاري هو تمييز المحل عن غيره من المحلات الأخرى فإن التاجر يقوم بكتابة اسمه على المحل أو فروعه إن كان له فرع بطريقة واضحة ظاهرة . ويجب أن يكون الاسم التجاري مطابقا للحقيقة فلا يؤدي الى التضليل أو ما يمس بالصالح العام^(٢) . وللأسم التجاري قيمة اقتصادية معتبرة ، ربما فاقت قيمة العناصر المعنوية الأخرى للمحل التجاري .

ويجب قيد الاسم التجاري بمكتب السجل التجاري كما يجب شهره بجريدة الأسماء التجارية ، ولمكتب السجل التجاري أن يرفض قيد الاسم التجاري إذا لم يكن مستوفيا الشروط التي تطلبها القانون^(٣) .

ولما كان الاسم التجاري داخلا في تكوين المحل يزيد من قيمته المالية فإن الاعتداء عليه يمثل ضررا للتاجر مالك المحل التجاري ولذا فقد تكفل القانون بحمايته بطريق دعوى المنافسة غير المشروعة والتي ليست إلا تطبيقا للنظرية العامة للمسؤولية المدنية عن الخطأ . ضد من يعتدي عليه^(٤) .

وبالإضافة لحماية الاسم التجاري بدعوى المنافسة غير المشروعة فقد قررت المادة ٩ من قانون الأسماء التجارية حماية الجنائية وذلك بمعاقة كل من يستعمل عمدا اسما تجاريا بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ثانيا: الاتصال بالعملاء والسمة التجارية

ورد ذكر هذا العنصر في المادة ٣٤ فقرة ١- من قانون التجارة المصري الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والتي نصت على أن المتجر (مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمة التجارية) .

وقد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون الجديد^(٥) أن المقصود بالاتصال بالعملاء هو مجموع العملاء الدائمين الذين يعتادون التعامل مع التاجر ويلتصقون به بسبب صفات شخصية كاللياقة ،

والأمانة والإخلاص في إرضاء رغباتهم. أما السمة التجارية فالمقصود منها قدرة المنشأة على اجتذاب العابرين بسبب ميزة خاصة فيها كحسن الموقع ، أو فخامة المظهر ، أو جمال العرض ، أو لإتقان التنظيم.

وأيا ما كان الوضع فإن عنصر الاتصال بالعملاء وعنصر السمة التجارية يعد من أهم العناصر التي يقوم عليها المتجر^(١) ، حتى إن بعض الفقه^(٢) ذهب الى أن المتجر ما هو إلا الاتصال بالعملاء ولا أهمية للعناصر الأخرى. كما بينت الفقرة الأولى من المادة ٣٤ السابقة الذكر أن المتجر لا ينطبق عليه الوصف القانوني للمتجر بدون عنصر السمعة التجارية والاتصال بالعملاء. كما تضافرت أحكام القضاء سواء في مصر أو فرنسا على تأكيد أهمية هذا العنصر^(٣). وبالرغم من تأكيد القضاء على جوهرية هذا العنصر في المحل التجاري ، إلا إنه لا يكون كافيا بمفرده لتكوين المحل التجاري حيث يجب أن ينضم إلى هذا العنصر بعض العناصر الأخرى المكونة للمحل التجاري^(٤).

ويشترط أن تتوافر في هذا العنصر مجموعة من الصفات من أهمها:

١- أن يكون عنصر الاتصال بالعملاء والسمة التجارية تجاريا؛ أي أن يكون ناتجا من عقود تجارية وليست مدنية^(٥).

٢- أن يكون هذا العنصر شخصا؛ أي متعلقا بمالك المحل التجاري الموهون بمعنى أن لا يكون ناتجا من عمل الغير وهذا الشرط يثير تساؤلا عن موقف المحل التجاري في مركز تجاري يضم مجموعة من المحلات هل يكون للمحل عميل خاص أم أن العميل هنا يكون تابعا للمركز أو الساحة الموجودة فيها المحل؟

عرضت محكمة النقض الفرنسية لهذه المسألة في خصوص حانة موجودة في ميدان للسباق وقضت هذه المحكمة بأن تلك الحانة ليس لها عمل خاص؛ فعملاؤها هم عملاء ميدان السباق الذين يترددون عليه^(٦) وهذا على عكس صاحب الامتياز التجاري كمحطات خدمة البنزين فإن له عميله الخاص به وصاحب محل تجاري مستقل ، حتى لو كان مستفيدا من علامات تجارية مملوكة للغير^(٧).

ولا يعني حق الاتصال بالعملاء أن للتاجر حقا على عملائه؛ إذ أن لهم الحرية في التعامل مع هذا التاجر أو غيره ، وإنما مناط هذا الحق أن القانون يقرر حماية للتاجر إذا ما تعرض هذا الحق لاعتداء عليه عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة كمحاولة تشويه سمعة التاجر أو الحط من

جودة منتجاته ففي هذه الحالة من حق التاجر مالك المحل التجاري رفع دعوى المنافسة غير المشروعة للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي أصابه.

ثالثا: العلامات الصناعية والتجارية

عرفت المادة الأولى من القانون المصري رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ الخاص بالبيانات والعلامات التجارية ، العلامة التجارية والصناعية بأنه: كل إشارة أو رمز عادي يستخدم في تمييز منتجات محل صناعي أو استغلال زراعي أو يقصد بها الدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمائها أو طريقة تحضيرها^(١). وتعد العلامات التجارية والصناعية وسيلة هامة في الحفاظ على العملاء ، ولذلك فهي تتمتع بقيمة اقتصادية معتبرة ، لهذا فاختيار العلامة يكون شيئا جوهريا وأساسيا^(٢).

وتعتبر العلامة التجارية وسيلة من وسائل المنافسة المشروعة بين المنتجين وتكتسب ملكية العلامات التجارية من تسجيلها لدى مصلحة التشريع التجاري. ويلزم لمنح الحماية القانونية للعلامة التجارية أن تكون هذه العلامة جديدة بمعنى أن لا تكون مستخدمة قبل ذلك من قبل مشروع آخر للدلالة على منتجه^(٣) ، كما يلزم أن لا تؤدي إلى خداع الجمهور وتضليلهم ، بأن تتخذ مظهرا مغايرا للحقيقة ما يؤدي إلى خداع الجمهور^(٤). فقد قضى بعدم مشروعية علامة تجارية لمدرسة لتعليم القيادة في فرنسا اتخذت علامة لها مثلثا متضمنا للون الأزرق والأبيض والأحمر وهي نفس ألوان العلم الفرنسي ، مما أوحى إلى الجمهور أنها مدرسة ذات صفة رسمية مع أنها في الحقيقة مدرسة خاصة^(٥).

ووفقا للمادة ٣٣ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ الخاص بالبيانات والعلامات التجارية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون وكل من استعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة ، وكل من وضع على منتجاته بسوء قصد علامة مملوكة للغير ، وكل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

رابعا: الرسوم والنماذج الصناعية

ذكرت المادة ٣٧ من القانون رقم ١٣٢ الصادر في مصر سنة ١٩٤٩ أن الرسوم والنماذج

الصناعية هي (كل ترتيب للخطوط أو شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الانتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيميائية).

وتعد الرسوم والنماذج الصناعية من أهم مقومات المشروعات الصناعية ، ويشترط في الرسوم والنماذج أن تكون جديدة تتمتع بطابع خاص يميزها عن غيرها من الرسوم والنماذج المشابهة لها وأن تستخدم في المجال الصناعي^٥.

ويتمتع المستفيد من الرسوم والنماذج بنوعين من الحماية فمن جانب يتمتع المستفيد بالحماية المقررة للملكية الأدبية والفكرية كحقوق التأليف ، ومن جانب آخر يتمتع بالحماية المقررة لهذه الرسوم بصفقتها من الملكية صناعية^٥.

وتتم حماية الرسوم والنماذج الصناعية عن طريق دعوى التقليد والتي يمكن أن تمارس أمام القضاء الجنائي كما هو ممكن أمام القضاء الجنائي كما هو ممكن أمام القضاء المدني ضد كل مقلد للرسوم والنماذج والذي يفترض فيه سوء النية مادة ٥٢١-٢ من قانون الملكية الصناعية.

خامسا: براءات الاختراع

وهي شهادة تمنحها الدولة لصاحب الاختراع وتعطيه الحق في احتكار استغلاله بشروط معينة ولمدة محددة.

ويشترط في الاختراع . محل البراءة . أن يكون قابلا للتطبيق الصناعي ، كما يجب أن يكون الاختراع جديدا بمعنى ألا يكون متضمنا في تطبيق في يوم إيداع الطلب ، كذلك يجب أن يكون ناتجا من نشاط اختراعي ، وأن يكون الاختراع غير مخالف للنظام العام والآداب^٥.

ويترتب على صدور البراءة من الجهة المختصة . إدارة البراءات بمصلحة التشريع التجاري بوزارة الاقتصاد . أن يصبح لمالكها الحق في احتكار استغلالها مدة معينة كما يصبح له الحق في التصرف فيها بكافة أنواع التصرف . فمن حق المستفيد من براءة اختراع أن ينتفع بها مدة عشرين عاما بداية من تاريخ إيداع الطلب وهذه المدة غير قابلة للتجديد ، وبراءة الاختراع مثلها مثل غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو الملكية المعنوية تكون محمية بدعوى التقليد والتزييف ، وسواء كانت هذه الدعوى مدنية أم جنائية فإنه يجب ممارستها خلال ثلاثة أعوام بداية من آخر واقعة تقليد أو تزييف^٥.

سادسا: الحق في الإجارة

عرفت المادة ٥٥٨ مديني مصري الإجارة بوجه عام بأنها (عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم).

أما الحق في الإجارة كعنصر من عناصر المحل التجاري فيقصد به: حق التاجر مستأجر العقار في الاستمرار في عقد الإجارة والانتفاع بالعقار المؤجر ، وعلى الأخص إذا كان العقار يقع في مكان ممتاز يؤدي إلى جذب العملاء كفندق يقع على مقربة من منطقة أثرية^(١).

وعلى الرغم من أهمية هذا العنصر بالنسبة للمحل التجاري ، على الأخص في تجارة التجزئة ، إلا أنه ليس من العناصر الضرورية لوجود المتجر ، فقد يوجد المتجر دون وجود عنصر الحق في الإجارة ، كما هو الحال بالنسبة للتاجر الذي يمارس تجارته في عقار مملوك له^(٢).

والحق في الإجارة . كعنصر من عناصر المتجر . حق مالي وليس من الحقوق الشخصية للتاجر ، ومن ثم فإنه يجوز للتاجر ١ ، يتصرف فيه ، كما أن لدائنيه أن يحجزوا على هذا الحق ، وأن يستعملوه نيابة عنه. ولذلك قضت المادة ١٨ من القانون ١١ لسنة ١٩٤٠ ببطالان أي شرط في عقد الإيجار يترتب عليه الإخلال بحق المستأجر في الرهن فقد نصت على أنه (يعتبر باطلا كل شرط في عقد الإيجار يترتب عليه الإخلال بحق المستأجر في الرهن طبقا لهذا القانون).

ولم يعالج قانون المحل التجاري رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ مسألة التنازل عن اجارة المحل التجاري ، ولذلك يتحتم علينا الرجوع الى القاعدة العامة في القانون المدني والتي أجازت للمستأجر الإجارة من الباطن أو أن يتنازل عن الإيجار ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك مادة ٥٩٣ مديني ، إلا أن المادة ٥٩٤ فقرة ١ من نفس القانون نصت على أن (منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس) ، ولكن نظرا لأهمية هذا العنصر في المحلات التجارية ، فقد استثنت الفقرة الثانية من نفس المادة المحلات التجارية من هذا المنع بقولها (ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة . بالرغم من وجود الشرط المانع . أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق التاجر من ذلك ضرر محقق).

وقد أكدت محكمة النقض هذا الاستثناء بقولها (إن القانون قد أباح للمستأجر . وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة . أن يتنازل مع الإيجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع ، وبالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط)^(٣).

سابعا: حقوق الملكية الأدبية والفنية

وهي الحقوق التي تكون للمؤلفين على مؤلفاتهم ومصنفاتهم الفنية أو الأدبية أو العلمية ، وهذه الحقوق ذات شقين: الأول أدبي أو معنوي ويكون قاصرا على صاحبه ومرتبطا بشخصه ، والثاني شقي مالي يدخل في ذمة صاحبه المالية ويجوز التعامل عليه بيعا ورهنا ، وللمؤلف الحق في استغلال نشر أعماله بنفسه أو التنازل cession عنها للغير^٥.

ولا يلزم أن يتوافر هذا العنصر في كل متجر وإنما يتوقف ذلك على طبيعة النشاط الذي يقوم به المتجر ويعد وجوده في غاية الأهمية بالنسبة لبعض المحلات كدور النشر والتوزيع^٥.

وإذا كان لصاحب هذه الحقوق الحق في استغلالها والانتفاع بها ، فقد قرر المشرع حماية هذه الحقوق حماية جنائية ضد كل من يستغل هذه الحقوق بطريقة غير مشروعة. ولم يكن المشرع المصري قبل صدور قانون ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ يقرر حماية جنائية لحق المؤلف حتى صدر هذا القانون مقررًا حماية جنائية لحقوق المؤلف^٥ ، وقد تم تعديل هذا القانون بالقانون رقم ٣٨ . ١٩٩٢.

ثامنا الرخص والإجازات

يقصد بالرخص والإجازات: تلك التصاريح والرخص التي تمنحها الجهات الإدارية للممارسة نشاط تجاري أو صناعي معين^٥.

وليست كل الرخص الإدارية عنصرا داخلا في تكوين المحل التجاري ، وإنما يتوقف ذلك على المعيار الذي من أجله منحت هذه الرخص فإن كانت قد منحت لصفة شخصية موجودة في مالك المحل التجاري ، فهي مرتبطة بشخص مالك المحل التجاري ، ومن أمثلتها الرخص التي تمنح لوكالة للسفر والرحلات أو للسياسة فمثل هذه الرخص لا تتبع مصير المحل التجاري ، ولا يمكن للمحال إليه المحل التجاري أن يبدأ نشاطه التجاري إلا بعد الحصول على إذن جديد^٥.

أما إذا كانت هذه الرخص قد منحت بناء على معيار عيني reel أي أنها ممنوحة للمتجر وغير مرتبطة بشخص مالك المحل التجاري ، فهذه الرخص تقدم طابعا ذا صفة موضوعية ، ومن أمثلتها الترخيص الخاص ببيع الخمور فمثل هذه الرخص تصنع جزءا من المحل التجاري ويمكن أن تكون محالة مع المحل أو معطاة في إجارة معه^٥.

تاسعا: حق التعريف بالتشغيل

لم يرد ذكر هذا العنصر ضمن المتجر في قانون المحل التجاري رقم ١١ الصادر في مصر سنة ١٩٤٠ ، ولا في قانون ١٧ مارس الصادر في فرنسا ١٩٠٩ . وقد نصت عليه حديثا المادة ٣٤ فقرة ٢ من قانون التجارة المصري الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ حين عدت عناصر المتجر بقولها (يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخرى. وذكرت من بينها حق المعرفة). ولم يرد بالمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد أي تعليق على هذا العنصر الذي أضافته المادة ٣٤ فقرة ٢ من القانون الجديد.

ويعرفه الفقه الأمريكي بأنه (عبارة عن معلومة فنية ويجسد معلومة تقنية تحتوي على حقيقتين الأولى: أن تكون المعلومة سرية ، والثانية: أن تهيئ هذه المعلومة لصاحبها ميزة على منافسيه الذين لا يعرفونها)^١. وبالنظر في هذا التعريف السابق يتضح لنا أن هذا الحق يتميز بالميزات الآتية:.

١-السرية

وهي نسبية إذ أنه لا يتصور أن يحتفظ بها شخص واحد داخل المشروع؛ إذ الفرض أنها تمثل عدة معارف معقدة يشترك في التوصل إليها العديد من عقول الخبراء والفنيين ، وقد تعرض القضاء الفرنسي لمسألة إفشاء أسرار الصناعة فقضى بأنه (تتميز فكرة سر الصناعة عن براءة الاختراع في أن الأولى ليست سوى تطور لا ابتكار سابق ، ويتميز سر الصناعة بأنه يمنح المشروع فرصة أكبر لمزيد من المنافسة التي تحقق انخفاضا في سعر المنتج مع تحسن في جودة المنتج ..).

٢-القابلية للانتقال

وقابلية هذا الحق للانتقال يشمل جميع الوثائق الفنية والتصميمات ، والتقارير ، والصور الفوتوغرافية ، والمكينات وقطع الغيار اللازمة ، وهذه المعلومات يحتفظ صاحبها بسريتها ويمنعها لمن يريد الانتفاع بها مقابل نقدية قد تكون باهظة^٢.

٣-حق المعرفة ليس محلا لبراءة اختراع:

يفضل أصحاب هذه المعرفة عدم اللجوء إلى نظام براءات الاختراع للاحتفاظ بسرية ابتكارهم وذلك بقصد عدم إفشاء أسرار وخصائص ابتكاراتهم^٣.

يتمثل حق المعرفة وما يحويه من معلومات وخبرات وأسرار فنية في التكنولوجيا التي ورد النص عليها في القانون التجاري الجديد عند حديثه عن عقود نقل التكنولوجيا ، فقد نصت المادة ٧٣

من قانون ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن عقد نقل التكنولوجيا (اتفاق بمقتضاه يتعهد مورد التكنولوجيا بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إلى مستورد التكنولوجيا لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو تركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ، ولا يعتبر نقلا لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع ، ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل التكنولوجيا أو كان مرتبطا به).

المطلب الثاني العناصر المادية للمحل التجاري

تنص الفقرة الثالثة من المادة ٣٤ تجاري على أنه (ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجاري). ونبين بشيء من التفصيل هذه العناصر المادية التي يتكون منها المحل التجاري.

أولاً: البضائع

يقصد بها المنقولات الموجودة بالمحل والمعدة للبيع سواء كانت في شكل سلع جاهزة أو مواد أولية^(١) وقد نصت على اعتبار البضائع من ضمن العناصر المادية للمتجر المادة رقم ٣/٣٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بقولها (ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجاري).

ونظرا للطابع المتغير للبضائع ، كما أنها تكون دائما معدة للبيع فقد استبعدتها القانون من عناصر المتجر في حالة رهنه. وعلى عكس رهن المحل التجاري فإنه في حالة بيع المحل التجاري تعد البضائع من العناصر الداخلة في امتياز البائع ما لم يتفق الطرفان على استبعادها^(٢) ولا تعد البضائع عنصرا جوهريا من عناصر المتجر إذ من المتصور وجود متاجر خالية كلية من البضائع كالمصارف ، ومكاتب السمسرة فلا تعد البضائع ذات صفة جوهريّة في هذه المتاجر.

وقد تدق التفرقة أحيانا بين البضائع والمهمات كما في حالة مواد الإنتاج الأساسية كالزيت ، والبتروول فهي تعد من قبيل المهمات إذا تم استخدامها في تشغيل المصنع وآلاته وتعد من البضائع لو كانت تدخل في صناعة السلع المعدة للبيع أو التعامل عليها^(٣) ، كذلك يعد الحاسب الآلي . الكمبيوتر من البضائع إذا كان في متجر لبيع الحاسوب ، بينما يعد من الآلات إذا كان

في متجر لبيع شيء آخر ويستخدم الحاسب لتنظيم أعماله. فالاختلاف بين البضاعة والمهمات ليس من قبيل الاختلاف في الطبيعة ، وإنما هو اختلاف يستند إلى الغرض الذي خصص له كل منهما ، ومن ثم فإن التمييز بين المهمات والبضائع من مسائل الواقع التي تخضع لمطلق تقدير قاضي الموضوع^(١). ولا ريب أنه يترتب على التفرقة بين المهمات والبضائع أهمية كبيرة تظهر في نواح عديدة وعلى الأخص في حالة رهن المحل التجاري؛ حيث إنه وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها فإنه لا يجوز أن يقع الرهن على البضائع وإنما من الجائز أن يقع على المهمات.

ثانيا: المهمات

يقصد بالمهمات: جميع الأدوات والآلات والمنقولات المادية اللازمة لاستغلال المحال التجارية حسب نوع النشاط الذي يمارسه دون أن تكون معدة للبيع^(٢). ومن ذلك المعدات التي تستخدم في الإنتاج الصناعي كآلات المصنع وأجهزته ، والآلات الحاسبة ، وماكينات التصوير ، والأثاث المعد لاستقبال العملاء ، كما تشمل المهمات أثاث المحل التجاري كالمقاعد ، والمكاتب ، والخزائن ، وأدوات الكيل والوزن أو القياس ، والصناديق اللازمة للمحافظة على البضائع. ويشترط لتكون هذه الأدوات - عنصرا من عناصر المحل التجاري - أن تكون مخصصة لخدمة المحل التجاري ، أما إذا كانت هذه الأدوات من قبيل الاستعمال الشخصي للتاجر مالك المحل التجاري فلا تمثل هذه الأدوات الشخصية عنصرا من عناصر المحل التجاري حتى لو كانت موضوعة في المحل.

وفي مصر نجد أن المشرع المصري قد أحسن صنعا حين نص - في هذه المسألة - على اعتبار العقار بالتخصيص من ضمن عناصر المتجر والتي يشملها رهن المحل التجاري ، فقد نصت المادة التاسعة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ على أن (رهن المتجر يشمل المهمات والآلات التي تستعمل في استغلال المحل ولو صارت عقارا بالتخصيص).

ولم يغيب عن فكر المشرع المصري ما قد ينشأ من خلاف في الرأي حالة اجتماع رهن المتجر ورهن العقار في وقت واحد: إذ أن الدائن المرتهن للعقار يتمسك بحقه في التنفيذ على المهمات بحجة أنها عقارات بالتخصيص بينما يتمسك الدائن المرتهن للمتجر بالتنفيذ عليها بحجة أنها عناصر المتجر ، فوضع المشرع المصري حلا لهذه المسألة إذ قضى بأن الأفضلية بين الدائن المرتهن العقاري والدائن المرتهن للمتجر تكون حسب أسبقية تاريخ القيد ، أما إذا تم القيدان في يوم

واحد فإنه يقدم المرتهن رهنا عقاريا على المرتهن للمحل التجاري. فقد نصب ١٦ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بأنه (تكون الأولوية في المرتبة بين الدائن المرتهن الحيازي وبين الدائن المرتهن رهنا عقاريا بحسب تاريخ القيد ومع ذلك تكون مرتبة الراهن العقاري مقدمة على الرهن الحيازي إذا قيد في يوم واحد).

الفصل الثاني

حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة

يهدف التجار من وراء ممارستهم لمهنة التجارة إلى تحقيق أكبر ممكن قدر الربح ، ويعتمدون في ذلك على التنافس فيما بينهم لاجتذاب أكبر عدد من العملاء. وهذه المنافسة تعد عملا مشروعاً إذا لم تؤد إلى الإضرار بالآخرين ، أما إذا ترتب على هذه المنافسة ضرر بالغير أو كانت الوسائل المستخدمة غير مشروعة وتتنافى مع الثقة والنزاهة فقد استقر العرف التجاري على اعتبارها عملاً غير مشروع يستوجب التعويض عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة^(١). ولم يكن التشريع التجاري القديم يقرر نظاماً حائياً خاصاً بالمتجر كوحدة مالية حتى جاء التشريع التجاري الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وتناول في المادة ٦٦ منه تحديد المقصود بأعمال المنافسة غير المشروعة ، وتحديد الجزاءات المترتبة على ارتكاب هذه الأفعال. وتتناول في المبحث الأول من هذا الفصل شروط دعوى المنافسة غير المشروعة ، وفي المبحث الثاني نتناول التطبيقات القضائية للمنافسة غير المشروعة ، وفي المبحث الثالث نتناول الجزاء المترتب على المنافسة غير المشروعة.

المبحث الأول

شروط دعوى المنافسة غير المشروعة

يقصد بالمنافسة غير المشروعة كما ورد في المادة ١/٦٦ تجاري أنها (كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية). وتتناول شروط دعوى المنافسة غير المشروعة في مطالب ثلاثة نخص لكل شرط منها مطلباً مستقلاً.

المطلب الأول

ركن الخطأ في دعوى المنافسة

يتمثل ركن الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة في قيام حالة منافسة غير مشروعة بين تاجرين يعمل كل واحد منهما في تجارة مماثلة للأخرى أو مشابهة لها كتجارة قطع غيار السيارات مثلا ، بحيث يترتب على الاعتداء على إحدهما انصراف العملاء عن التجارة الأخرى المماثلة أو المشابهة مما يصيبها بالضرر ، فإذا كان التاجران يعملان في تجارتين مختلفتين ، كأن تكون الأولى في تجارة الأخشاب مثلا والثانية في تجارة الحديد المسلح ، فلا نكون . في هذه الحالة . أمام منافسة غير مشروعة؛ لانتفاء الضرر هنا بسبب اختلاف كل تجارة منهما عن الأخرى ، فإذا ترتب على هذا الانصراف . في التجارتين المختلفتين . إلحاق الضرر بسمعة التاجر فلا يمنع ذلك من قيام دعوى المسؤولية التقصيرية ضد التاجر المتسبب في هذا الضرر^(١).

ولا يلزم أن يكون التماثل كاملا بين التجارتين ولكن يكفي أن يتقارب النشاطان بحيث يكون لإحدهما تأثير على عملاء الأخرى ، كما لو كان أحد المحلين مصنعا لإنتاج وبيع سلعة معينة وكان المحل الآخر متجرا لبيع هذه السلعة ، ويخضع الفصل في توافر شرط التماثل بين التجارتين من عدمه للقضاء فقد قضى بعد وجود تنافس بين التجارة في البن الطبيعي والتجارة في البن المجرد من مادة الكافيين ، كما تنتفي المنافسة بين بيت من بيوت الأرياء وبين متجر للأزياء ، ولكن يمكن أن تتوافر المنافسة بين بنك ووكالة للاستعلامات التجارية^(٢).

وقد كان القضاء يتطلب ضرورة توافر الخطأ العمدى لقيام حالة المنافسة غير المشروعة^(٣) ، ولكن ما لبث القضاء أن عدل عن موقفه في مراحله التالية فأصبح يكتفى لوقوع المنافسة غير المشروعة بتوافر الخطأ غير العمدى أي أن يكون الفعل ناجما عن إهمال أو عدم احتياط ، فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه (لما كانت المنافسة التجارية تعد فعلا تقصيريا يستوجب مسؤولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملا المادة ١٦٣ مدني ، وكان ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات مما يعد تجاوزا لحدود المنافسة المشروعة)^(٤) . وقد جاءت المادة ١/٦٦ تجاري مؤكدة لهذا المفهوم حين عرفت المنافسة غير المشروعة بأنها (كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية).

المطلب الثاني

الضرر

يعتبر الضرر هو الشرط الثاني من شروط دعوى المنافسة غير المشروعة ، وعلى خلاف القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية فلا يلزم أن يكون الضرر قد وقع بالفعل ، بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع في المستقبل ، كما لا يشترط أن يكون الضرر ماديا فقط فمن الممكن أن يكون الضرر أدبيا ، ويستوى في ذلك أن يكون الضرر كبيرا أو صغيرا ، فلا اعتبار لجسامة الضرر في دعوى المنافسة غير المشروعة ، فقد قضت محكمة النقض بتوافر المنافسة غير المشروعة حتى ولو كان الضرر مجرد احتمال وليس واقعا ، فقد جاء في قضائها (وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع قصور التسبيب وفساد الاستدلال إذ لم يتحرر تحقق الضرر الذي قضى بتعويض ، فبني الحكم على مجرد احتمالي وكان يتعين عليه بحث نشاط منشأة المطعون عليه قبل خروج العمال منها وبعد خروجهم وذلك لتحقيق حصول الضرر ومقداره. وحيث إن النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه فإنه من بين من أغروا من العمال على ترك الخدمة لدى المطعون عليه من توافرت فيه الكفاية الفنية وخبرة سنوات طويلة قضاها في خدمته ، وأدت إلى رواج حركة محله وذيوع شهرته في المحيط التجاري ، ومما يحد من حركته التجارية ويقلل من شهرته أمدا طويلا إلى أن يتسنى له استعادة مركزه الأول. ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استخلص من الاعتبار التي أشار إليها لتحقيق حصول الضرر الفعلي وهو استخلاص سائغ ، وعلى ذلك يكون غير صحيح ما نعي به الطاعنون من الحكم أقام قضاءه على مجرد الضرر الاحتمالي^٥).

المطلب الثالث

تحقق علاقة السببية بين الخطأ والضرر

يشترط لتوافر دعوى المنافسة غير المشروعة تحقق علاقة السببية بين الخطأ وهو فعل المنافسة غير المشروعة وبين الضرر وهو التأثير السلبي على تجارة التاجر الذي تعرض للمنافسة غير المشروعة. ولما كان إثبات وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر يعتمد على وقوع الضرر فعلا ، وكنا قد بينا أنه يكفي في المنافسة غير المشروعة مجرد احتمال وقوع الضرر دون وقوعه فعلا ، لذلك فقد استقر القضاء على أن القاضي لا يحكم بالتعويض إلا عن الضرر المحقق فعلا حينما تحقق رابط

السببية بين أعمال المنافسة غير المشروعة وبين الضرر المحقق فعلاً. أما إذا كان الضرر محتملاً فإن القاضي لا يحكم بالتعويض بل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع هذا الضرر وذلك لعدم قيام رابطة السببية بين الضرر المحتمل وأعمال المنافسة غير المشروعة^(٥). ويجوز لكل تاجر رفع الدعوى بسبب ما لحق به من ضرر من جراء أعمال المنافسة غير المشروعة ، وفي الحالة التي يتعدد فيها المضررون يجوز لكل منهم أن يرفع الدعوى منفرداً كما في حالة المنافسة التي تقوم على إثارة اضطراب في السوق^(٦).

المبحث الثاني

تطبيقات المنافسة غير المشروعة

ذكرت الفقرة الأولى من المادة ٦٦ تجاري أمثلة عديدة لأعمال المنافسة غير المشروعة من ذلك (الاعتداء على علامات الغير ، أو على اسمه التجاري ، أو على براءات الاختراع ، أو على أسرارته الصناعية التي يملك حق استثمارها ، وتحريض العاملين في متجر على إذاعة أسرارته ، أو ترك العمل ، وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس في المتجر أو في منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكه أو في القائمين على إدارته أو في منتجاته). ولم يتضمن التشريع التجاري حصراً لحالات المنافسة غير المشروعة ، وإنما صنف المشرع حالات المنافسة غير المشروعة إلى ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: أعمال من شأنها إحداث اللبس والخلط

ومن أمثلة هذه الأعمال استعمال تاجر لاسم تجاري مملوك لتاجر آخر أو تقليد علامة تجارية ، أو وضع بيانات غير صحيحة على المنتجات مما يؤدي إلى إيقاع العملاء في لبس وخلط فتؤدي إلى الانصراف عن التاجر صاحب العلامة ، أو الاسم التجاري الحقيقي إلى التاجر الذي قام بتزوير العلامة أو استخدام الاسم التجاري نتيجة هذا اللبس والخلط.

الصنف الثاني: الأعمال التي تؤدي إلى التحقير والنيل من قدر التاجر

يعتمد من يحاول النيل من التاجر في هذه الأعمال على النيل من سمعة التاجر ، وذلك بالترويج للإشاعات المغرضة كالادعاء بعدم أمانة التاجر أو بقرب شهر إفلاسه أو بعدم صلاحية

المنتجات للاستهلاك أو غشها.

وتتم هذه الأعمال بطريق العلانية عنها حتى يتم التشهير ، وتؤدي إلى الغرض المطلوب منها لإعلام العملاء بها حتى يمكن صرفهم عن منافسه ، وذلك عن طريق توزيع منشورات أو الإعلان عنها في الصحف أو تقديم شكاوى كيدية للجهات الإدارية المختلفة كالضرائب والصحة والسجل التجاري^(١). وتؤدي هذه الأعمال إلى النيل من سمعة التاجر المنافس مما قد يؤدي إلى صرف العملاء عن التعامل معه^(٢).

الصف الثالث: الأعمال الموجبة للاضطراب في المشرع المنافس

تتعدد صور الأعمال التي تهدف إلى إحداث اضطراب في المشروع المنافس والتأثير سلبي على انتظامه وسير العمل فيه ، كاستخدام عامل أو أكثر كانوا يعملون لدى منافس يقصد اجتذاب عملاء المشروع الأول أو الوقوف على أسرار عمله^(٣). وقد تتمثل هذه الأعمال في تخفيض أسعار البضاعة عن السعر الجاري في السوق حتى يصرف العملاء عن منافسيه ويجتذبهم إليه ، فمثل هذا العمل هل يعد من قبيل المنافسة غير المشروعة؟ ذهب رأي إلى اعتباره من قبيل المنافسة غير المشروعة ؛ على أساس الباعث إذ إنه يهدف من وراء ذلك إلى جذب عملاء التاجر الآخر^(٤). بينما ذهب رأي آخر إلى عدم اعتبار هذا العمل من قبيل المنافسة غير المشروعة^(٥).

المبحث الثالث

الجزاء المترتب على المنافسة غير المشروعة

تنص المادة ٢/٦٦ تجاري على أن (كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها ، وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن التعويض بإزالة الضرر وينشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية). ويستفاد من هذا النص أن الجزاء المترتب على المنافسة غير المشروعة هو تعويض التاجر المنافس عن الضرر الذي أصابه ، وتقضي المحكمة بالتعويض متى ثبت لها توافر عناصره الثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما. وتستعين المحكمة لتقدير التعويض المحكوم به بأهل الخبرة في شئون التجارة ، ولا تحكم المحكمة بالتعويض إلا عن الأضرار التي لحقت المضرور بالفعل^(٦). وتأمّر المحكمة . فضلاً عن التعويض

بإزالة الضرر الواقع على التاجر المنافس كالأمر بمحو الاسم التجاري المزيف من على واجهة المتجر. وحتى يتسنى للمحكمة إلزام المسئول عن المخالفة بإزالتها فإنها تطبقا للقواعد العامة تأمر بتوقيع الغرامة التهديدية عن كل يوم يمتنع فيه عن الإزالة^٥.

وقد اختتم نص المادة ٦٦ تجاري هذا الجزاء بنشر ملخص الحكم الصادر ضد التاجر المسئول عن الضرر بإحدى الصحف اليومية ، وفي ذلك ما يردع هذا التاجر لما في ذلك من إظهار أفعاله الضارة وهو ما على سمعته التجارية.

الفصل الثالث

التصرفات القانونية الواردة على المتجر

لما كان المحل التجاري مالا منقولاً فهو محل للتعامل عليه بيعاً وشراءً ، كما . يمكن للتاجر أن يستخدمه كوسيلة ائتمان وذلك برهنه مقابل الحصول على القروض التي يحتاجها. وقد نظم المشرع بيع ورهن المحل التجاري بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ ، وأبقى على نصوصه بعد صدور قانون التجارة الجديد ولم يتناول القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ ولا قانون التجارة الجديد تنظيم تأجير المحال التجارية مما يترتب عليه خضوع تأجير المحال التجارية للقواعد العامة في الإيجار. وتتناول في هذا الفصل تنظيم المشرع للبيع والرهن الواردين على المحل التجاري مخصصين مبحثاً مستقلاً لكل تصرف منهما.

المبحث الأول

رهن المحل التجاري

يعد المحل التجاري وسيلة ائتمان للتاجر يمكنه ان يقترض بضمان متجره ، ولما كان المتجر منقولاً معنوياً ، ولما كان يمثل . ربما . جل مال التاجر فقد نظم المشرع بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ رهن المحل التجاري بحيث لا يخرج المتجر من يد الراهن وذلك على خلاف الأصل في رهن المنقول والذي تخرج فيه الحياة من يد المدين الراهن ، كما أوجد المشرع الوسائل التي يحفظ بها حقوق الدائن المرتهن على المحل التجاري المرهون ، فجاء تنظيمه قريباً من التنظيم التشريعي لرهن العقار. وتتناول رهن المحل التجاري في المطالب الآتية

المطلب الأول

شروط رهن المحل التجاري

يفتقر رهن المتجر في صحته إلى مجموعة من الشروط بعضها موضوعي والآخر شكلي ، ونتناول هذين النوعين من الشروط في الفرعين التاليين

الفرع الأول

الشروط الموضوعية لرهن المحل التجاري

بالإضافة إلى الشروط العامة للعقود وهي الرضا الصحيح والمحل والسبب والأهلية ، فإنه يلزم أن يتوافر في رهن المحل التجاري بعض الشروط الموضوعية الخاصة ، بعضها يتعلق بالمدين الراهن والبعض الآخر يتعلق بالدائن المرتهن.

أولاً: المدين الراهن

تقضي القاعدة العامة^(١). في الرهن أن يكون الراهن مالكا للشيء المرهون وأن تتوافر فيه الأهلية اللازمة لصحة الرهن.

١- أن يكون الراهن مالكا للمحل التجاري المرهون

إذا رهن شخص محلا غير مملوك له ودون إذن من المالك الحقيقي فالنتيجة المنطقية لهذا الرهن هي البطلان؛ لورود الرهن على متجر غير مملوك للمدين الراهن ، ولكن ما طبيعة هذا البطلان^(٢)؟ هل هو بطلان مطلق أم أنه بطلان نسبي^(٣)؟

والفائدة من معرفة طبيعة هذا البطلان هي أن البطلان النسبي يمكن تصحيحه بشروط ، وبالتالي فهو يترتب آثاره . في حالة تصحيحه . من وقت انعقاد الرهن. أما البطلان المطلق فهو غير قابل للتصحيح أي أن الرهن يكون كأن لم يكن حتى لو أصبح الراهن مالكا للمحل التجاري فيما بعد.

وفي هذا الشأن فإننا نجد نص المادة ١٠٢٣ مدني والتي تنص على أنه (إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحا إذا أقره المالك بورقة رسمية ، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار

مملوكا للراهن).

ونستخلص من هذا النص أن المشرع المصري لا يعتبر رهن مالك الغير باطلا بطلانا مطلقا؛ لأنه رتب عليه آثارا لا تتفق مع البطلان المطلق ، ومن ذلك إجازته لعقد الرهن المبرم من غير المالك إذا ما أقره المالك الحقيقي للشيء المرهون ، كما أنه نفى عنه البطلان إذا ما انتقلت ملكية هذا الشيء المرهون إلى الراهن بعد إبرام العقد ، وهذان الأثران لا يتفقان مع البطلان المطلق. ويترتب على كون رهن المحل التجاري المقدم من غير المالك باطلا بطلانا نسبيا ما يلي:

أ- أن الدائن هو الوحيد الذي من حقه أن يتمسك ببطلان هذا العقد وليس للقاضي أن ينطق به من تلقاء نفسه.

ب- أن الرهن ينقلب صحيحا في الأحوال الآتية:

-إذا أقره المالك الحقيقي للمحل التجاري ، وأرى أن إقرار المالك هنا لا بد وأن يكون كتابيا سواء كانت الكتابة في شكل عرفي أو في شكل رسمي؛ وذلك لتنبيه المالك لخطورة ما هو مقدم عليه.

-إذا أصبح المدين الراهن مالكا للمحل التجاري.

فإذا تحققت واحدة من هاتين الحالتين أصبح الرهن صحيحا بأثر رجعي ولا يكون للدائن الحق من أن يطلب إبطال الرهن. أما إذا ظل العقد باطلا فإن المالك الحقيقي للمحل التجاري يظل أجنبيا عن العقد ، وله أن يتصرف في محله بكافة أنواع التصرف وليس للدائن المرتهن حتى لو كان حسن النية يحتج على المالك الحقيقي للمحل بالمادة ٢/١١١٨ مدني مصري ، والتي تجيز للدائن المرتهن أن يتمسك بحقه في الرهن متى كان حسن النية ، حيث إن هذه القاعدة إن هذه القاعدة متعلقة بالمنقول المادي والمحل التجاري منقول معنوي لا يخضع لقاعدة الحيابة في المنقول سند الملكية^(١).

وليس هناك ما يمنع أن يكون المتجر المرهون مقدما من شخص غير المدين ضمانا لدين المدين ، ويسمي هذا الشخص بالكفيل العيني.

فالكفيل العيني: هو من يرهن أمواله ضماناً للوفاء بديون غيره^(٢). ويقتصر التزام الكفيل العيني في حدود المحل التجاري المرهون فلا يسأل عن دين الرهن المضمون بالمحل التجاري في سائر أمواله

(١) د. كمال أبو سريع المحل التجاري ص ٢٩٧ ، د/ علي يونس المحل التجاري ص ٢٩١.

(٢) د. محمود محمد زهران التأمينات العينية والشخصية من ٢٦٦ دار المعارف الإسكندرية ٢٠٠١م..

وهو ما يميزه عن الكفالة الشخصية.

والتزام الكفيل العيني التزام تباع لأنه ليس مديناً أصلياً تابعاً ، وبالتالي فإنه يحق لهذا الكفيل بمقتضى هذه الصفة أن يدفع دعوى الدائن بالدفع المتعلقة بأصل الدين حتي لو نزل عنها المدين^(٣) وليس من حق الكفيل العيني - ما لم يوجد اتفاق خاص - أن يطالب الدائن بأن ينفذ أولاً على أموال المدين وهو ما يعرف بحق الدفع بالتجريد.

ولا يشترط في ملكية الرهن للمحل التجاري المرهون أن تكون ملكية منجزة ، فقد يكون الرهن مالكا للمحل المرهون تحت شرط ، سواء كان هذا الشرط واقفاً أو فاسخاً. وقياساً على نص المادة ١٠٣٤ مديني مصري ، وكذلك المادة ٢١٢٥ مديني فرنسي فإن رهن المحل التجاري المملوك تحت شرط واقف أو فاسخ يكون صحيحاً إلا أن الرهن يخضع لنفس المصير الذي تخضع له ملكية الرهن المعلقة على الشرط ، فإذا تحقق الشرط الواقف تأيد الرهن نهائياً ويمتد أثره من وقت نشوء العقد^(٤) ؛ وذلك تطبيقاً لنص المادة ١/٢٧٠ مديني مصري. أما إذا لم يتحقق الشرط الواقف أو كان الشرط فاسخاً فتحقق فإن الرهن يصبح باطلاً ، لصدوره من غير المالك ويكون ذلك بتأثير رجعي.

ويُفرق في هذا الصدد بين الدائن المرتهن حسن النية والدائن المرتهن سئ النسبة ، فإذا كان الدائن المرتهن الدائن المرتهن في المرهون المعلقة ملكيته على شرط حسن النية وقت إنشاء الرهن ، أي لم يكن يعلم أن ملكية المرهون معلقة على شرط فإن له أن يتمسك بالرهن تطبيقاً للمادة ١٠٣٤ مديني مصري ، أما إذا كان الدائن المرتهن سئ النية أي كان يعلم بأن الرهن إنما يملك المحل التجاري المرهون ملكية معلقة على شرط فاسخ فلا يجوز له التمسك بالرهن^(١).

٢- أن يكون الرهن أهلاً للتصرف

نظراً لأن رهن المحل التجاري - بالنسبة للمدين الرهن - تصرف يدور بين النفع والضرر ؛ لأنه قد يؤدي إلي البيع الجبري للمحل التجاري المرهون إذا لم يوف المدين الرهن بالدين المضمون

(٣) د/ رمضان أبو السعود التأمينات العينية والشخصية ص ٣٦٤ ، د/ حسام الأهواني المصدر السابق ص ٧١.

(٤) د. سليمان مرقس الوافي في التأمينات ص ٧٨ ، د. عبد الناصر العطار التأمينات العينية ص ٣١.

(١) د/ محمد سعد خليفة الوجيز في التأمينات العينية ص ٤٢ طبعة ١٩٩٧ بدون ذكر الناشر.

بالرهن^(٢) ، فقد أوجب القانون أن تتوافر في المدين الراهن أهلية التصرف ، أي أهلية الرشيد البالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية ، متمتعاً بقواه العقلية ، غير محجور عليه ، فقد نصت المادة ٤٤ مدني على أن (كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد هي إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة). فإذا رهن المحل التجاري من شخص عديم الأهلية - كالمنحون أو الصبي غير المميز- فإن رهنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً أي غير قابل للتصحيح تطبيقاً لنص المادة ١١٠ مدني.

أما إذا صدر رهن المحل التجاري من قاصر- وهو الشخص الذي لم يبلغ ٢١ سنة ميلادية- فإننا نفرق بين ما إذا كان القاصر مأذوناً له في التجارة أو غير مأذون له.

القاصر غير المأذون له

إذا أبرم القاصر غير المأذون له في التجارة عقد رهن على محله التجاري فإن هذا الرهن يكون باطلاً مثل العقود الأخرى التي يبرمها^(٣) ، غير إن هذا البطلان يكون بطلاناً نسبياً قابلاً لتصحيح بناء على طلب القاصر عند بلوغه أو بناء على طلب وليه ، وليس للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها مادة ١١١/٢ مدني.

وإذا كان القانون قد أجاز للقاصر أن يبطل العقد لمصلحته ، إلا أن القانون قد ألزمه بالتعويض في حالة ما إذا كان هذا القاصر قد أتى من الطرق الاحتيالية ما يخفي بها نقص أهليته. مادة ١١٩ مدني ، ويسقط حق القاصر في طلب إبطال العقد بمرور ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يزول فيه نقص أهليته مادة ١٤٠/١ مدني.

القاصر المأذون له

يمكن للقاصر الذي لم يبلغ ٢١ سنة ميلادية - بعد إذن من المحكمة المختصة - أن يزاول التجارة ، غير إنه لا يعتبر تاجراً إلا بعد بلوغه سن الواحد والعشرين ، فإذا رهن القاصر المأذون له في التجارة محله التجاري فإن رهنه يقع صحيحاً تطبيقاً للمادة ٣/١١ تجاري (تكون للقاصر

(٢) د/ قاسم الوتيدى ص ٧٤٩ مسئولية الدائن المرتحن رسالة القاهرة ١٩٨١ م.

(٣)

المأذون له في التجارة الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارتها). وبالتالي فليس للقاصر المأذون له في التجارة أن يطلب إبطال عقد رهن المحل التجاري بناء على نقص أهليته ، لكن يمكن له أن يحتج بعدم توافر صفة التاجر فيه^(١).

وطبقاً للمادة ١٢فقرة ٢ من قانون رهن المحل التجاري فإنه في حالة الإفلاس تطبق على رهن المحل التجاري الأحكام المقررة في المواد ٢٢٧ ، ٢٢٨ ، ٢٣١ تجاري ، وكذلك المواد المشار إليها في المادة ٩٢ من قانون رهن المحل التجاري ، والتي يقابلها الآن المواد ٥٩٨ ، ٦٠١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ .

وطبقاً لنص المادة ٥٩٨ من قانون التجارة الجديد فإنه يكون لاغيا ولا ينفذ في مواجهة جماعة الدائنين رهن المحل التجاري إذا وقع من المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس^(٢) ، فقد نصت المادة ٥٩٨ على أنه (لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس: د- كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على أموال المدين ضمانا لوفاء دين سابق على التأمين.) .

فإذا كان المدين قد رهن المحل التجاري وقت نشوء الدين وكان الدائن يعلم باختلال أشغال المدين فإن هذا الرهن يكون قابلا للبطلان طبقاً لنص المادة ٥٩٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ فقد نصت على أنه (كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة ٥٩٨ من هذا القانون وخلال الفترة المشار إليها فيها فيجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارا بها وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس من الدفع).

ويلاحظ أن الحكم بعدم نفاذ التصرف الوارد في المادة السابقة إنما هو جوازي للمحكمة فهي غير مجبرة على الحكم به ولو توافرت شروطه^(٣).

ثانيا الدائن المرتهن

نظراً لأن المرتهن في رهن المحل التجاري - وفي الرهن عموماً- لا يلتزم بشي فيعتبر الرهن بالنسبة

(١) إيفيز رينهار Reinhard yoes القانون التجاري Droit cominrcial ص ٢٢٢ .

(٢) كمال أبو سريع المحل التجاري ص ٢٦٦ طبعة ١٩٩٤ ، ديريبية رهن المحل التجاري ص ٧ دللوز 2000D .

(٣) محمد إبراهيم خليل قانون التجارة الجديد والتعليق علي نصوصه من ١٠٠٥ طبعة ١٩٩٩/٢٠٠٠ .

له عملاً نافعاً محضاً ، فتكفيه أهلية الإدارة أي أن الدائن المرتهن يجوز له قبول الرهن بنفسه بمجرد بلوغه سن التمييز أو حتي لو كان محجوراً عليه لسفه أو غفلة ، ويعتبر الرهن صحيحاً غير قابل للإبطال^(٢). وللوصي أو الولي أن يرتهن للمشمول بالوصاية أو الولاية دون حاجة إلى استئذان المحكمة ، كما يمكن للوكيل أن يرتهن لموكله بالتوكيل العام دون حاجة إلى توكيل خاص^(٣).

وفي ظل قانون رهن المحل التجاري المصري رقم ١ لسنة ١٩٤٠ فإن الدائن المرتهن يجب أن يكون من الأشخاص التي حددها القانون ، ولا يجوز لغير هذه الأشخاص ارتهان المحل التجاري فقد اشترط القانون أن يكون الدائن من البنوك أو بيوت التسليف التي يرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص تطبيقاً لنص المادة ١٠ من قانون ١٩٤٠ (يجوز أن يرتهن لدى البنوك أو بيوت التسليف التي يرخص لها بذلك وزير التجارة والصناعة بالشروط التي يحددها بقراره بصدده) وقد استنبط المشرع المصري هذا النص من القانون البلجيكي الصادر في ٢٥-١٠-١٩١٩ ، والحكمة من وراء حصر الدائن المرتهن للمحل التجاري في طائفة من البنوك المرخص لها بذلك من الوزير المختص هي حماية صغار التجار وأصحاب المصانع من جشع المرابين الذين ينتهزون حاجة المدين الملحة في الاقتراض ولتسهيل اجراءات الرهن ، وهو نص أمر لا تجوز مخالفته لتعلقه بالنظام العام. وبالتالي يقع باطلا رهن المحل التجاري متى كان الدائن لا ينتمي إلى طائفة من الطوائف المحددة بقرار من الوزير المختص.

ويرى الاستاذ الدكتور قاسم الوتيدي أن النص على تحديد الدائن المرتهن في هذه الحالة إنما هي صورة من صور تدخل القانون العام لحماية التاجر الذي في حاجة لرهن محله التجاري والتي قد تضطره هذه الحاجة إلى التهاون في شروط هذا الرهن وتلك هي فرصة المرابين^(١).

الفرع الثاني

الشروط الشكلية

لا تكفي الشروط الموضوعية - سالفه الذكر - ليصبح رهن المحل التجاري حجة في مواجهة الغير

(٢) الوسيط للسنة ١٠ ج ١٠٠-١٣١ ، د/ همام محمد محمود زهران التأمينات للعينية والشخصية ص ٢٢٦ دار للمعارف الإسكندرية ٢٠٠١م..

(٣) د/ سليمان مرقس الوائلي ص ٤٦* ٢٥ ، د/ محمد سعد خليفة الوجيز في التأمينات العينية ص ٣٣ طبعة ١٩٩٧ م بدون ذكر الناشر.

(١) د. قاسم الوتيدي مسؤولية الدائن المرتهن ص ٣٣٦ رسالة القاهرة ١٩٨١م.

، بل لابد من اتباع شكلية معينة حتي يصبح الرهن حجة ومنتجاً لآثاره في مواجهة الغير ، لذلك استوجب المشرع المصري الكتابة والشهر ، نظراً لكونهما طريقتين لإعلام الغير برهن المحل التجاري.

أولا الكتابة

الأصل في عقد الرهن التجاري أن كتابة العقد لا تكون واجبة لإثباته ، وأنه يثبت بكل الوسائل ، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير^(١). وقد خرج المشرع في قانون رهن المحل التجاري عن هذا الأصل واشترط الكتابة لإثبات رهن المحل التجاري مما أدى إلى وجود خلاف بين الفقهاء حول طبيعة الكتابة في رهن المحل التجاري. ومما ساعد على وجود هذا الخلاف ما ورد بالمذكرة التفسيرية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ والتي علقت امتياز الدائن المرتهن على تحرير عقد رسمي أو عرفي مقرون بالتصديق على توقيعات أو اختتام المتعاقدين ، فذهب غالب الفقه^(٢) إلى أن الكتابة واجبة في عقد رهن المحل التجاري بحيث يترتب على تخلفها بطلان العقد ، فهي شرط لانعقاد رهن المحل التجاري.

وطبقاً لهذا الرأي فإن عقد رهن المحل التجاري يعتبر عقداً شكلياً. بينما ذهب البعض الآخر من الفقه^(٣) إلى أن الكتابة في عقد رهن المحل لا تتعدى أن تكون شرطاً لإثبات العقد وليست شرطاً لانعقاد ، ومن ثم فلا يترتب على تخلف الكتابة بطلان عقد رهن المحل التجاري.

وحسباً لهذا الخلاف الفقهي - حول طبيعة الكتابة في رهن المحل التجاري- جاء التشريع التجاري المصري الجديد ليقضي على هذا الخلاف معتبراً الكتابة ركناً لانعقاد رهن المحل التجاري ، أي أنه يترتب على تخلفها بطلان عقد رهن المتجر فقد نصت المادة ١/٣٧ تجاري على أن (كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عيني عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً).

فالنص قد اعتبر الكتابة في رهن المحل التجاري شرط صحة لانعقاد الرهن. ولم يوجب قانون رهن

(١) مادة ٢٠١م ١٣٣ من قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٠.

(٢) د. علي يونس القانون التجاري ص ٢٩٩ دار النهضة ١٩٩٩ ، د/ علي البارودي العقود وعمليات البنوك من ١٤١ منشأة الإسكندرية ٢٠٠١ م ، د/ العربي ، د/ جلال وفاء القانون التجاري ص ٤٥٣ دار المطبوعات ١٩٩٨.

(٣) د. اكثم الخولي الوسيط في القانون التجاري : ص ٤٣٢ فحضة مصر ١٩٦٤ ، د. علي جمال الدين الوجيز ص ١٩٤ دار النهضة ١٩٧٥.

المحل التجاري أي شيء فيما يتعلق بمضمون الكتابة ، إلا أن الناحية العملية توجب أن يتضمن عقد رهن المحل التجاري البيانات الضرورية لتعيين الدائن المرتهن ، والمدين الراهن ، والدين المضمون ، وكذلك المحل التجاري المرهون ، وتوقيع أطراف العقد. وبالجملية يجب أن يشتمل عقد رهن المحل التجاري على البيانات الوارد ذكرها بقائمة القيد والمنصوص عليها بالمادة ١٩ من قانون ١٩٤٠ ، وإذا ورد في عقد رهن المحل التجاري عدة توقيعات بتواريخ مختلفة فالعبرة بتاريخ آخر توقيع إلا في حالة الغش^(١).

ثانياً شهر رهن المحل التجاري

لما كانت حيابة المحل المرهون تبقي في يد المدين الراهن ولا تنتقل إلى الدائن المرتهن ، فقد أوجد المشرع وسيلة لإعلام الغير بالرهن الواقع على المحل التجاري ، وذلك عن طريق قيده لدى الجهة التي حددها المشرع ليتمكن كل من يتعامل على هذا المحل من معرفة الحقوق التي تنتقل هذا المحل.

١ - مكان القيد

حددت المادة ٣/١١ من القانون رقم ١١ الصادر سنة ١٩٤٠ مكان شهر عقد رهن المحل التجاري بمكتب السجل التجاري بالمحافظة - أو المديرية - الواقع في دائرتها المحل التجاري المرهون ، وهذا السجل يكون مستقلاً عن السجل التجاري الذي يقيد فيه التجار أسماءهم عند مزاوله مهنة التجارة وإذا كان آخر يوم في القيد يوم عطلة أسبوعية أو رسمية ، فإن المدة تمتد - بقوة القانون - حتى أول يوم عمل.

٣ - طريقة القيد

طلب قيد رهن المحل التجاري حق لكل ذي مصلحة ، وصاحب المصلحة الأولي في هذا الشأن هو الدائن المرتهن فهو المستفيد الأول من قيد رهنه أو من ينوب عنه كوكيله وتكفي الوكالة العامة للقيد ؛ لأنه لا يعد من أعمال التصرف وإنما من أعمال الإدارة^(١). ويمكن لوكيل التقليسة أن

(١) استئناف باري CA paris ١٩٧٦/٧/٤ جاري دي بال Gaz Pal ١٩٧١ ج ٢ ص ٧٩ ، استئناف روان CA.Rouen

١٩٥٨/٧/٤ الاسبوع القانوني ICP ١٩٥٩ ج ٢ رقم ١٠٩٤٢.

(١) د/ عبد النعم البدوي - التأمينات العينية - ص ٨٠ ، د/ عبد الناصر العطار - التأمينات العينية - ص ٦٥ فقرة ٣٤.

يطلب إجراء القيد ، كما يمكن لورثة الدائن المرتهن المتوفى أن يطلبوا قيد رهن مورثهم كما يمكن لدائني المرتهن أن يطلبوا قيد رهن مدينهم إذا تقاعس عنه. مادة ٢٣٥ مدني مصري.

وليس هناك ما يمنع المدين الراهن من طلب قيد الرهن الوارد على محله التجاري ولا تشتط - في الدائن - الأهلية الكاملة لطلب القيد ، إذ إنه إجراء نافع له نفعاً محضاً فيجوز لناقص الأهلية أن يطلبه^(٢).

يقدم الدائن المرتهن طلب التقيد إلى الجهة المختصة ويرفق مع الطلب صورة مصدقا عليها من عقد الرهن الرسمي أو أصل العقد العرفي ، ويرفق بالعقد نسختين من حافظة المستندات تتضمن البيانات المتعلقة بالدائن المرتهن والمدين الراهن والمحل المرهون.

وقد ورد ذكر هذه البيانات في المادة ١٩ من القانون رقم ١١ الصادر في مصر ١٩٤٠ وهي:

١- اسم الدائن ولقبه ، جنسيته وصناعة وموطنة ولم يرد في المادة ٢٤ من قانون ١٩٠٩ ذكر لجنسيته الدائن وصناعته ، ولكنها وردت فقط في القانون المصري على الرغم من أن هذا القانون - على ما بينا سابقاً- لم يرخص في هذا الرهن إلا للبنوك الوطنية ، وبالتالي فالدائن في ظل هذا القانون معروف الصنعة والجنسية.

٢- اسم المدين ولقبه و جنسيته وصناعته وموطنه ، وينطوي تحديد المدين على جانب كبير من الأهمية حيث إنه يمكن الغير من معرفة الضمانات التي قبلها المدين على محلة التجاري.

٣- بيان المحل التجاري والفروع التابعة له إذا وجدت ، مع تحديد الأجزاء التي يتكون منها المحل التجاري والتي يرد عليها عقد الرهن وكذلك نوع عملياته ومقره. ويجب أن يكون تحديد المحل المرهون وفروعه مؤكداً وبعيدا عن أي خطأ محتمل وقوعه^(١).

٥- بيان نوع عقد الرهن - رسم أو عرفي - وتاريخه.

٦- وجود أو عدم وجود امتياز البائع أو رهن سابق أو أي حق عيني على الشيء المرهون بوصفه عقاراً بالتخصيص.

٧- اسم الشركة المؤمن لديها ضد خطر الحريق.

٨- اسم المؤجر وقيمة الإيجار السنوية ومواعيد الاستحقاق.

(٢) السنهوري - الوسيط في شرح القانون المدني - ١٠ ص ٤٣٧ فقرة ١٩٣ ، د/ رمضان أبو السعود - التأمينات الشخصية والعينية - ص ٣٨٦.

^١ محكمة لوهافر التجارية le havre ١٩٣٤/١/٣١ مجلة المحل التجاري ١٩٣٥ ص ٩٨.

ويتم القيد بتقديم حوافظ القيد المنصوص عليها في القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ إلى مكتب السجل التجاري بالحفاظة الواقع في دائرتها المحل المرهون ، ويتعين على مكتب السجل التجاري أن يتحقق من شخصية مقدم الطلب.

وإذا كان طالب القيد وكيلا فإن التوكيل يجب أن يكون رسميا أو عرفيا مقرونا بالتصدق على توقيعات أو أختام المتعاقدين ، وسبق أن بينا أنه يكفي أن يكون التوكيل عاما فلا يلزم توكيل خاص للعمل القيد.

يتم تدوين البيانات التي بالحفاظة دون اختصار أو تغيير أو كشط ويوقع الطالب على كل إضافة بهامش الحفاظة ، ولا تقبل الحوافظ غير المستوفية للبيانات والشروط المقررة. يتم تدوين هذه الحوافظ في دفتر خاص بأرقام متتابعة ويعطي للطالب إيصال يفصل من قسيمة الدفتر ويشمل البيانات الآتية:

١- رقم الحفاظة بحسب ترتيب الإيداع ويبدأ الترقيم من أول يناير من كل عام ٢- التاريخ وساعة إيداع الحفاظة. ٣- اسم المودع ولقبه ومحل إقامته. ٤- عدد المستندات المرفقة بالحفاظة ونوعها.

ويتم قيد الحوافظ في نفس يوم إيداعها. ويكون اليد بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة من تاريخ سريان القانون.

يتم شهر عقود الرهن التي تم قيدها في جريدة بيع المحال التجارية ورهنها في بحر شهرين من قيدها.

وإذا حدث أي تغيير أو تعديل في أي بيان من البيانات السابقة والمنصوص عليها في المادة ١٩ ، فإنه يجب على الدائن المرتهن أن يطلب إثباته حتي يكون حجة في مواجهة الغير مادة ٢٠ من قانون ١٩٤٠.

ولا تتم إضافة التعديلات التي تقع على أحد شروط العقد إلا بمقتضي حكم حاز قوة الشيء المقضي أو عقد رسمي أو عرفي مقرون بالتصديق على توقيعات المتعاقدين ، وترفق بالحفاظة الصورة التنفيذية للحكم أو صورة مصدق عليها من العقد إذا كان رسمياً أو أصل العقد إذا كان عرفيا مقرونا بالتصديق على توقيعات وأختام المتعاقدين ، وترفق الحفاظة في هذه الحالة بالصورة التنفيذية للحكم أو بصورة مصدق عليها من العقد إذا كان عرفيا مقرونا بالتصديق على توقيعات وأختام المتعاقدين.

ويتم إضافة التعديلات بنسخ البيانات المطلوب تدوينها في هامش القيد مع الإشارة إلى رقم وتاريخ الإيداع ، ويرد المكتب إحدي نسختي الحافظة بعد التأشير عليها بما يفيد إجراء التدوين مع ذكر تاريخه.

يتم شهر البيانات المضافة أو المعدلة في جريد بيع المحال التجارية ورهنها في بحر شهرين من التعديل أو الإضافة ويشمل الشهر البيانات والتعديلات التي تم إدخالها مادة ١٥ ، ١٦ ، ١٨ ، من القرار الوزاري رقم ١١٠ لسنة ١٩٤٣.

٤- الجزاء على إغفال بيان في القيد

يتوقف الجزاء على إغفال بيان من بيانات القيد على حسب طبيعة هذا البيان ، حيث إن البيانات الواردة في المادة ١٩ ليست على درجة واحدة من الأهمية ، إذ إن بعضها ثانوي والآخر جوهري. والفصل في طبيعة جوهريية البيان من عدمه متروك لقاضي الموضوع^(١).

هذا وقد رتب المشرع البطلان على إغفال بيان من هذه البيانات ، إلا أن الحكم بالبطلان متوقف على وجود ضرر يصيب الغير نتيجة إغفال هذا البيان^(١) ، فقد نصت المادة ٢٢ مصري على أنه (لا يترتب على إغفال واحد أو أكثر من الإجراءات أو البيانات السابقة بطلان إلا إذا أضر ذلك بالغير). ولا تملك المحكمة أن تنطق بالبطلان من تلقاء نفسها وإنما بناء على طلب ممن أصابه الضرر. وعلي من يدعي الضرر إثبات ذلك ، وللقاضي سلطة تقديرية في وجود الضرر من عدمه دون رقابة عليه من محكمة النقض^(٢).

ويترتب على قيد رهن المحل التجاري قبل نهاية الخمسة عشر يوما المحددة لقيدته أن يحفظ مرتبة امتياز الدائن المرتهن مدة خمس سنوات تجدد مع تجديد القيد ، كما أنه يضمن له الحصول على فوائد الدين لمدة سنتين بامتياز من ذات مرتبة الدين الأصلي ، ولا يلزم أن تكون الفوائد للسنتين التاليتين لقيد الرهن ، بل يمكن للدائن أن يمارس الأولوية بالنسبة للفوائد غير المدفوعة عن أي سنتين إذا لم تكن قد سقطت بالتقادم.

(١) د. علي يونس - القائمون التجاري - ص ٣٠ ، د/ كمال أبو سريع - المحل التجاري - ص ٣٧٨ .

(١) السنهوري - الوسيط في القانون المدني - ج ١٠ ص ٤٤٩ فقرة ٢٠٣ ، د/ عبد المنعم البدر - التأمينات العينية ص ٩٠ .

- ٩١ ، حسام الأهواني التأمينات العينية ص ٣٥٩ طبعة ٢٠٠٠ بدون ذكر الناشر .

(٢) د/ علي يونس - القانون التجاري - ص ٣٠٤ ، د/ محسن شقيق - القانون التجاري ، ج ١ ص ٦٤٦ .

المطلب الثاني

محل الرهن

حدد المشرع العناصر التي يجوز أن يشتمل عليها رهن المحل التجاري وذلك بالمادة ١/٩ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ واليت نصت على أن (وهن المحل التجاري يجوز أن يشتمل على العنوان والاسم التجاري والحق في الإجازة والاتصال بالعملاء والسمة التجارية والأثاث التجاري والمهمات والآلات التي تستعمل في استغلال المحل ، ولو صارت عقاراً بالتخصيص والعلامات التجارية والرخص والاجازات ، وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية والمرتبطة به).

وواضح من صياغة عبارة هذا النص أن اشتمال رهن المحل التجاري علي تلك العناصر أمر جوازي وليس وجوبياً ، فقد يتفق الأطراف على أن يشمل الرهن كل هذه العناصر أو بعضها. أما إذا لم يوضح الطرفان في العقد العناصر التي فقد ورد في الفقرة الثانية من نفس المادة السابقة أنه (إذا لم يعين الطرفان الراهن والدائن المرتهن ما يشمل الرهن ، فإنه لا يرد إلا على العنوان والاسم التجاري والحق في الإجازة والاتصال بالعملاء والسمة التجارية).

وعلى الرغم من جواز اشتمال الرهن على المهمات والتي قد تكون عقارات بالتخصيص ، إلا أنه لا يجوز أن يشتمل رهن المتجر على العقار الكائن فيه المتجر إذا كان مملوكاً للتاجر؛ وذلك لنص المشروع صراحة على إخراج العقار من ضمن عناصر المتجر فقد نصت المادة ٣٦ من قانون التجار الجديد على أنه (إذا كان التاجر مالكا للعقار الذي يزاوّل فيه التجارة ، فلا يكون هذا العقار عنصراً في متجره).

كما أن البضائع لا تعد من العناصر التي يجوز أن يشتمل عليها رهن المتجر؛ وذلك نظراً لسرعة انفصالها عن المتجر ، وإمكانية الاحتجاج بشأنها بقاعدة الحيّزة في المنقول سند الملكية^(١). كما أن المشرع قد أخرج البضائع من عناصر رهن المتجر حتى تبقى ضماناً فعالاً للدائنين العاديين الذين يعولون عليها في منح الائتمان للتاجر^(٢).

المطلب الثالث

آثار رهن المحل التجاري

يترتب على رهن المحل التجاري مجموعة من الآثار التي تتولد مع ميلاد الرهن وتنقضي بانقضائه ،

وتختلف هذه الآثار حسب الأشخاص الذين تتولد في حقهم ، فالدائن المرتهن يتمتع بمزية التقدم التي تخول له الحصول على حقه - على غيره من الدائنين ، كما أنه يتمتع بمزية التتبع التي تخول له تتبع المحل التجاري في يد الحائز للمتجر ، لو تصرف فيه الراهن تصرفاً قد يؤثر على ضمان الدائن المرتهن.

أما الراهن فإن المحل التجاري يضع على عاتقه مجموعة من الالتزامات التي تكفل الحفاظ على المحل التجاري باعتباره الضمان المقدم للوفاء بالدين ، وفي مقابل هذه الالتزامات فإنه يتمتع بالحق في إدارة المحل المرهون واستثماره.

أما الدائنون العاديون فقد منحهم المشرع في رهن المح التجاري - خلاف القواعد العامة - الحق في أن يطالبوا بسقوط آجال ديونهم إذا توافرت شروط معينة.

الفرع الأول

آثار رهن المحل التجاري بالنسبة للدائنين المرتهنين

أولا الحق في التقدم

يعرف حق التقدم بأنه: أثر جوهري لرهن المحل التجاري يعني بتقسيم ثمن بيع المحل المرهون أو أحد عناصره المرهونة أو التعويضات الناجمة عن هلاكه أو لرفض المؤجر تجديد الإجارة ، ويخول للدائن المرتهن الحق في التقدم في حدود هذه المبالغ على الدائنين العاديين لمالك المحل التجاري أو الدائنين المرتهنين التاليين له في المرتبة^(١).

فطبقاً لهذا التعريف فإنه من حق الدائن المرتهن أن يستوفي حقه - بالأسبقية على غيره من الدائنين العاديين أو التاليين له في المرتبة - من ثمن المحل التجاري المرهون أو أحد عناصره المرهونة ، وكذلك على مبالغ التعويضات الناجمة عن هلاك المحل المرهون أو لرفض المؤجر تجديد الإجارة أو غير ذلك ، وذلك دون حاجة إلى اتفاق سابق بين الدائن المرتهن والمدين الراهن. ولكن تمتع الدائن المرتهن بحق التقدم في ثمن المحل التجاري مشروط بأن يكون الرهن قد نشأ صحيحاً بين أطرافه ، وأن يكون الدائن المرتهن قد قام بقيد رهنه على المتجر المرهون قبل مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ إنشاء الرهن.

والأصل أن يمارس الدائن المرتهن حقه في التقدم على المبلغ النقدي الناجم عن بيع المحل التجاري المرهون ، لكن إذا ما حدث هلاك كلي أو جزئي للمحل التجاري المرهون ، فمن حق الدائن المرتهن أن يمارس حقه في التقدم على التعويضات الناجمة عن هلاك المحل التجاري ، كما هو الحال في التقدم بمبلغ التأمين المقدم من شركة التأمين حالة وقوع الخطر المؤمن ضده على المحل التجاري المرهون فقد نصت المادة من قانون ١٩٤٠ علي أنه (يكون للدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة عن التأمين إذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها). وكذلك حق الدائن المرتهن أن يتقدم بالتعويض عن المسؤولية ، ويقصد به المبلغ المستحق في ذمة الغير المسئول عن هلاك المحل التجاري المرهون أيا كان الخطأ الذي أسست عليه المسؤولية مادة ١٠٤٩ مدني.

ولم ينظم قانون رهن المحل التجاري - بنصومه - حلاً للتزاحم بين الدائن المرتهن وغيره من أصحاب الامتيازات الأخرى ، فلم يتحدث قانون ١٩٤٠ سوي عن حل للتنازع الذي قد يثور بين الدائن المرتهن للمتجر والدائن المرتهن العقاري ، كما تحدث في المادة الثالثة منه عن الأولوية المطلقة لقيد بائع المتجر على غيره من القيود إذا تم قيد هذا البيع في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنشاء العقد.

وطبقاً لما تقضي به القواعد العامة فإنه حيث يوجد دائن بحق مقيد وآخر بحق غير مقيد- إما لأنه غير واجب القيد أو كان واجباً ولم يقيده الدائن- ، فالأولوية تكون للدائن المقيد ، وبالتالي فلا تزاحم بين الدائن المرتهن والدائنين المرتهن العقاري إلا إذا كان المدين يمارس تجارته على عقار مملوك له ثم قام المدين للراهن يأخذ رهن على العقار الكائن فيه المحل فيثور التنازع بين الدائن المرتهن للمحل وبين الدائن المرتهن على العقار في خصوص العقارات بالتخصيص.

وقد نظمت المادة ١٦ من قانون رهن المحل التجاري الصادر في مصر سنة ١٩٤٠ التزاحم بين الدائن المرتهن للمحل والدائن المرتهن رهناً عقارياً والتي نصت على أنه (تكون الأولوية بين المرتهن الحيازي^(١) وبين الدائن المرتهن رهناً عقارياً بحسب تاريخ القيد ، ومع ذلك تكون مرتبة الرهن العقاري مقدمة على الرهن الحيازي إذا قيدا في يوم واحد).

ونلاحظ أن الحل الذي جاءت به المادة ١٦ يتفق في جانب منه مع القواعد العامة ، ويخالفها

^١- يقصد المرتهن رهناً حيازياً هنا هو الدائن المرتهن للمحل التجاري وهذه التسمية لا تتفق مع الصياغة الفنية والقانونية ولا تعتبر عن الفكرة الحديثة في رهن المحل التجاري رهناً حراً لا يتجرّد فيه الراهن من الحياة.

في جانب آخر ، فهو يتفق معها في أن الأولوية تكون للدائن الأسبق قيда ، ويخالفها في تفضيله للمرتهن العقاري على المرتهن للمتجر إذا تم قيد الرهنيين في يوم واحد.

أما عن حل التزاحم بين مرتهن المتجر وامتياز البائع فقد نظم قانون رهن المحل التجاري التزاحم بين امتياز البائع والدائن المرتهن بقاعدة خرج بها عن حكم القاعدة العامة في التزاحم بين أصحاب القيود - والتي تقضي بأنه عند تزاحم حقين مقيدتين منهما الأسبق تاريخها - تتقرر أولوية مطلقة لامتياز البائع المقيد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع ، وأنه يسبق كل القيود المأخوذة في نفس المدة ، حتى لو كان قد قيد امتياز البائع لاحقا على هذه القيود. فقد نصت المادة ٣ من قانون ١٩٤٠ على أنه (يجب إجراء القيد- أي عقد بيع المتجر- في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ للبيع وإلا كان القيد باطلا). ويكون للقيد الأولوية على القيود التي تجري على ذات المشترين في نفس الميعاد).

ولعل الحكمة من وراء تفضيل امتياز البائع تكمن في أن المحل التجاري دخل في ذمة المشتري مثقلا بامتياز البائع ، حيث يجب على الدائن المرتهن الذي تعامل مع المشتري أن يدخل ذلك في اعتباره متى كان البيع لم يمحض عليه خمسة عشر يوماً ، وأنه كان يمكنه أن ينتظر هذه المدة قبل قبوله الرهن.

ولمؤجر العقار الكائن فيه المحل التجاري المرهون الأولوية على ثمن الاثاث والآلات المستعملة في استغلال المحل المرهون في حدود أجرة عامين فقط ، وذلك على الرغم من أنه حق شخصي وليس حقا واجب الشهر.

ويقتصر حق المؤجر في الأولوية - طبقا للمادة ١٧- من قانون ١٩٤٠ على أنه (ليس لمؤجر المكان الذي يوجد فيه الأثاث أو الآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المحل التجاري أن يباشر امتيازاه لأكثر من قيمة إيجار سنتين).

ثانيا الحق في التبع

يقصد بحق الدائن المرتهن في تتبع المتجر المرهون: قدرة الدائن المرتهن في أن يتتبع الشيء المرهون - المحل التجاري - في يد الغير - والذي يسمى اصطلاحا بالحائز - وأن ينفذ عليه ليستفيد من

قيمتة بالحصول على حقه من الثمن بالأولوية على غيره من الدائنين^(١). فإذا تصرف المدين الرهن في المحل التجاري المرهون تصرفاً ناقلاً للملكية جاز للدائن المرتهن تتبع ذلك المحل المرهون والتنفيذ عليه تحت يد المتصرف إليه ليتقدم الدائن المرتهن بثمنه على غيره من الدائنين التاليين له في المرتبة.

ويتضح لنا من خلال هذا التعريف أن الحق في التتبع ليس هدفاً في ذاته but - كالحق في التقدم - وإنما هو وسيلة تمهد الطريق للوصول إلى الحق في التقدم ، في حالة ما إذا تصرف المدين الرهن في المحل التجاري المرهون.

والحق في التتبع مزية يتمتع بها كل دائن مرتهن - قام بقيد رهنة على المحل التجاري- بصرف النظر عن مرتبته أي حتي لو كان مرتبته متأخرة ، قد لا تسمح له باستيفاء حقه من ثمن الحل التجاري بعد بيعه ، وهو ما يميز الدائن المرتهن عن غيره من الدائنين العاديين الذين ليس لهم إلا اقتضاء حقوقهم من الضمان العام لمدينهم. ومن ثم فلا يخرج من الضمان العام للمدين فليس للدائن العادي التنفيذ عليه^(١).

ويشترط لتتبع الدائن المرتهن المحل المرهون في يد الغير الحائز توافر مجموعة من الشروط ليتمكن الدائن المرتهن من ممارسة حقه في تتبع المحل المرهون في يد الحائز وذلك على النحو التالي:

١- أن يكون الرهن حجة في مواجهة الحائز^(٢). وذلك بأن يكون الرهن مشهراً بقيد لدى الجهة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من إنشاء عقد الرهن. فإذا كان سند ملكية الحائز سابقاً على تاريخ قيد الرهن أو أن الدائن المرتهن ترك قيده دون تجديده في الموعد المحدد فإن رهنه لا يكون حجة في مواجهة الحائز وبالتالي لن يكون في مقدور ذلك الدائن أن يمارس حق التتبع في مواجهة الحائز.

٢- حلول أجل الدين ، فطبقاً لما تقضي به المادة ١٠٦٠ مديني فليس من حق الدائن أن يمارس حقه في التتبع على المحل المرهون إلا إذا كان دينه قد أصبح واجب الأداء ، وهو تطبيق للمبدأ القاضي بعدم جواز التنفيذ بمقتضي حق مؤجل وبناء عليه فإذا كان الدين معلقاً على شرط أو

(١) د/ كمال أبو سريع المحل التجاري ص ٢١٠ ، د/ أحمد سلامة مقالة الرهن الطليق للمتجر ص ١٢٢ ، د/ علي يونس

القانوني التجاري ص ٣١٣ ، فرانسوا ليكا القانوني التجاري D.Com. ص ١٢٦ طبعة ١٩٩٨ .

(١) د/ محمد المرسي زهرة ضمانات الائتمان العينية ص ٥٥٤ مطبوعات جامعة الإمارات ١٩٩٧ .

(٢) د/ عبد الناصر العطار التأمينات العينية ص ١٢٢ ، ستيفان بيدلوفر التأمينات ص ٥٣٦ .

مضافاً إلى أجل فلا يجوز التتبع بمقتضاه إلا إذا تحقق الشرط أو حل الأجل^(٣).

٣- عدم توافر صفة المديونية في الحائز ، إذ أنه يلزم - لممارسة سلطة التتبع في مواجهة الحائز - أن يكون هذا الحائز غير مسئول مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن^(١). وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١٠٦٠ مديني مصري. والحكمة من هذا الشرط هي أنه إذا كان الحائز مسئولاً عن الدين مسئولية شخصية فإن من حق الدائن أن ينفذ على جميع أموال هذا الشخصي لما له من حق الضمان العام ، ولهذا لا يجوز لهذا الشخصي أن يتمسك في مواجهة الدائن المرتقن بالحقوق التي يمنحها القانون للحائز كحق التطهير مثلاً؛ إذ إنه لا يستقيم الاعتراف بهذه الحقوق لمن كان مسئولاً عن الدين في جميع أمواله^(٢).

وتطبيقاً لهذا الشرط لا يعد حائزاً كل من كان مسئولاً مع المدين عن سداد الدين المضمون بالرهن كال كفيل الشخصي لو انتقلت إليه ملكية المحل بطريقة الشراء مثلاً وكذلك الكفيل العيني لأن كلا منهما مسئول المدين العيني محدودة في حدود محل الرهن^(٣).

٤- أن ينصب التتبع على مجموع المحل التجاري المرهون ، فالمحل التجاري - كما قدمنا من قليل - يتكون من مجموع من العناصر المادية والمعنوية وأن هذا المجموع ينفصل عن تلك العناصر الداخلة في تركيبه ، وأنه لو انصب الرهن على أحد هذه العناصر منفرداً لم نكن أمام رهن محل تجاري ، ولكن أمام رهن لعنصر مادي أو معنوي يخضع في أحكامه للقانون الذي ينظمه وبالتالي فإنه يشترط الممارسة الدائن المرتقن لحقه في التتبع في مواجهة الحائز أن يتم التصرف في المحل التجاري كمجموع^(٤) ولن يكون للحائز - هنا - مهما كان حسن النية أن يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز لأن هذه القاعدة تسري في شأن المنقولات المادية ولا أثر

(٣) د. المرسى زهرة ضمانات الائتمان العينية من ٥٥٦ فقرة ٢٩٥ مطبوعات جامعة الإمارات ١٩٩٧ ، د/جلال محمد إبراهيم

التأمينات العينية والشخصية ص ٢١٨ طبعة ٢٠٠١.

(١) د/ المرسى زهرة ضمانات الائتمان العينية ص ٥٥٦ فقرة ٢٩٥ مطبوعات جامعة الإمارات ١٩٩٧ ، د/ جلال محمد إبراهيم

التأمينات العينية والشخصية ص ٢١٨ طبعة ٢٠٠١.

(٢) الوسيط السهري ج ١٠ ص ٥٢٤ ، فراسنوا شابا ومازو دروس في القانون المدني ص ٤٥٤ فقرة ٤٩٤ استئناف رن

CA.Remes ١٣-٥-١٩٣٦ جازيت دي بال ١٩٣٧ ج ١ ص ١٦٧.

(٣) د/أحمد سلامة التأمينات ص ٣٢٣/عبد المنعم البداوي المصدر السابق ص ١٧٠، سنيفان المصدر السابق ص ٣٢٦.

(٤) العربي وجلال محمددين القانون التجاري ص ٤٦٥/علي البارودي العقود وعمليات البنوك ص ١٢٥، ١٢٤ أوليفية باريه

العقود الواردة على المحل التجاري ص ١٨٣ فقرة ٣٠٩ طبعة ٢٠٠١.

لها في شأن المنقولات المعنوية^(١).

أما إذا تم التصرف في عنصر منفرد من عناصر المحل التجاري المرهون فهل يمكن للدائن المرتهن أن يتتبع هذا العنصر في يد الحائز؟

نفرد في هذا الشأن بين ما إذا كان التصرف في عنصر من العناصر المعنوية للمحل التجاري كحقوق الملكية الصناعية والأدبية وبين التصرف في عنصر من العناصر المادية للمحل التجاري كالمهمات والأدوات:

أ- التتبع في العناصر المعنوية للمحل التجاري

وفي خصوص إمكانية تتبع الدائن المرتهن للعنصر المعنوي للمحل التجاري المتصرف فيه على انفراد ، فإننا نفرق بين العناصر المعنوية الخاضعة ل قيد خاص ، خلاف القيد المأخوذ للمحل التجاري كمجموع كما هو الحال في العلامات التجارية المشتمل عليها المحل المرهون والتي يجب قيدها - فضلاً عن القيد بمكتب السجل التجاري لرهن المحل - بسجل إدارة العلامات التجارية تطبيقاً للمادة ١٩ مكرر من قانون ١٩٤٠ . وهذه الطائفة من العناصر المعنوية يكون من حق الدائن المرتهن أن يتتبعها في مواجهة الحائز لو تم التصرف فيها على انفراد^(٢).

أما إذا انصب التصرف على عنصر معنوي ليس له قيد سوى القيد المأخوذ للرهن كالحق في الإجازة فإنه لن يمكن للدائن المرتهن أن يمارس حق التتبع في مواجهة المحال إليه ، وربما لا يتمكن الدائن المرتهن كذلك من ممارسة حقه في التقدم على الثمن ، لو كان لم يدفع بعد. ولن يكون أمام الدائن المرتهن في هذه الحالة إلا أن يحتج بالمادة ٢٧٣ مديني مصري والتي تقضي بسقوط الأجل في حالة هلاك الضمان الخاص بفعل المدين.

ب- التتبع في العناصر المادية للمحل المرهون

إذا انصب التصرف المنفرد للراهن في المحل التجاري على أحد العناصر المادية للمحل المرهون كالمهمات والآلات أو الأثاث التجاري فإن الدائن المرتهن لن يستطيع أن يمارس الحق في التتبع في مواجهة الحائز ، تأسيساً على قاعدة لا تتبع في المنقول بناء على رهن. ولن يبق أمام الدائن

(١) د/علي يونس القانون التجاري ص ٣١٣ ، د/هاني دويدار التنظيم القانوني للتجارة ص ٣٢٤ .

(٢) موسوعة كلاسيور في المحل التجاري ص ٨٠٨ ، ديريبيبة المحل التجاري ص ٨٧ دلوذ ١٩٩٤ ، د/كمال أبو سريع المحل

التجار ي ص ٢٩٧ ، د/ علي يونس القانون التجاري ص ٣١٤ .

المرتهن من ضمان جدي سوي أن يلوح بحكم المادة ١٨ مكرر والتي تقضي بمعاينة كل من يبدد أو يتلف عن إضرار بالغير مهمات أو آلات أو أثاث المحل التجاري المرهون بالعقوبة المقررة في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات المصري.

الفرع الثاني

آثار الرهن بالنسبة للدائنين العاديين

الأصل طبقاً للقواعد العامة^(١) أن أجل الديون لا يسقط إلا إذا تقدم الدائنون أصحاب التأمين الخاص- رهن أو امتياز - بشكوى من جراء نقصان ضمانهم الخاص ، غير إن قانون رهن المحل التجاري خرج عن هذه القاعدة فأجاز للدائنين أصحاب الديون العادية ، طبقاً للشروط خاصة طلب سقوط أجل الدين إذا ما أجري المدين قيداً بالرهن على المحل التجاري ، وذلك بالمادة ٣٥ من قانون سنة ١٩٤٠ واليت تنص على أنه (للدائنين السابقين على قيد الرهن متى كان الغرض من ديونهم استغلال المحل التجاري أن يطلبوا سداد ديونهم قبل مواعيد استحقاقها إذا أصابهم ضرر بسبب ذلك القيد). ويتضح من هذا النص أنه يحق للدائنين العاديين طلب سقوط أجل الدين قبل ميعاد الاستحقاق ، ولكن يلزم لتحقيق ذلك أن يتوافر شروط ثلاثة:

١- أن يكون الدين المطالب صاحبه بسقوط أجله سابقاً على قيد الرهن ، وهذا بخلاف الدائن الذي نشأ دينه بعد قيد الرهن ، فقد تعامل مع المدين وهو على علم بوجود القيد وإذا لم يعلم به فليتحمل نتيجة تقصيره في البحث.

٢- أن يكون الدين-المطالب صاحبه بسقوط أجله- بسبب استغلال المحل التجاري كالقروض التي يعقدها التاجر لشراء سلع للمحل كإدخال تحسينات في المصنع. ولعل الحكمة من تقييد التي بكونه متعلقاً باستغلال المحل التجاري ترجع إلي أن الدائنين الذين نشأت ديونهم بسبب استغلال المحل التجاري يعتمدون في استيفاء ديونهم على المحل التجاري وتقرير الرهن على المتجر يضعف من انتمائهم^(١) ، أو ربما تكمن الحكمة في أن المشرع أراد أن بلغت نظر المدين إلي خطورة أخذ قيد علي المحل التجاري قد يؤدي به غلي ارتباك حالته المالية نتيجة مطالبة أصحاب الديون العادية بسقوط آجال ديونهم^(٢).

(١) د/ أكنم الخولي القانون التجاري ص ٤٣٧ ، د/ ثروت عبد الرحيم القائمون التجاري ص ٢٧٠ درا النهضة ٢٠٠٠.

(٢) د/ علي يونس القانون التجاري ص ٣١٧ ، د/ كمال أبو سريع المحل التجاري ص ٣٠٣.

وللمدين - إذا تعلق دينه باستغلال المحل التجاري - أن يطلب سقوط أجل الدين أيا كان مصدر هذا الدين سواء كان عقداً أو شبه عقد أو كان فعلاً ضاراً وسواء كان الدين بالنسبة للدائن يعتبر عملاً مدنياً أو عملاً تجارياً^(٣). أما إذا كان الدين غير متعلق باستغلال المحل التجاري ، كزواج صاحب المحل التجاري ، فلا يحق لمثل هذا الدائن طلب سقوط أجل الدين ، بل كل ما يملكه الدائن هو طلب عدم نفاذ التصرف في حقه لو كان التصرف منطوياً على غش يقصد الإضرار بالدائنين.

٣- أن يصاب الدائن العادي الذي يطلب بسقوط أجل الدين - بضرر من جراء هذا القيد المأخوذ على المحل التجاري كما إذا لم يكن للمدين أموال أخرى تفي بدينة ، ومسألة الضرر مسألة موضوعية يترك تقديرها للمحكمة. أما إذا تبين أن للمدين أموالاً أخرى كعقارات أو أسهم أو سندات تكفي لضمان حقوق الدائنين العاديين فليس هناك محلاً لطلب سقوط الأجل^(٤). وسقوط أجل الديون العادية إذا توافرت شروطه لا يكون بقوة القانون ، فلا تملك المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، وإنما بناء على طلب الدائنين العاديين. وللمحكمة لسلطة تقديرية في الحكم بسقوط أجل الديون أو رفضه^(١). ويجب على المحكمة قبل النطق بسقوط أجل الدين أن تتأكد من توافر الشروط الواردة بالمادة ٢٥ من قانون سنة ١٩٤٠.

الفرع الثالث

آثار رهن المتجر بالنسبة للمدين الراهن

نظراً لأن رهن المحل التجاري يقوم - في أساسه - على فكرة احتفاظ الراهن بالمحل التجاري المرهون ، مع اتخاذ الدائن المرتهن من الوسائل ما يحتفظ له حقه على المتجر المرهون ، فإن للراهن الحق في الانتفاع بالمحل التجاري والتصرف فيه على وجه لا يؤثر على ضمان الدائن المرتهن ، وفي مقابل هذا الانتفاع فإن المدين الراهن يكون ملتزماً بضمان المحل التجاري والمحافظة عليه.

(٣) د/ محسن شفيق القانون التجاري ص ٨٦٣

(٤) د/ كمال أبو سريع المحل التجاري ص ٣٠٢، د/ ثروت عبد الرحيم القانون التجاري ص ٢٧٠ دار النهضة ٢٠٠٠

(١) راتب الجنيدى الاتجاهات الحديثة في رهن المنقول ص ٤٠٢ رسالة القاهرة ١٩٨٠.

أولا حقوق المدين الراهن في رهن المتجر الحق في إدارة المحل والتصرف فيه

لما كان الراهن يحتفظ بحياة محله المرهون فإنه يظل متابعاً نشاطه التجاري دون أن يؤثر الرهن على حقه في استثمار محله أو التصرف فيه ، فيظل على رأس تجارته يستثمرها ويمارس نشاطه ، إذا أن رهن المتجر لا يخرج المحل عن ملكه ، وتأكيداً لذلك فقد أقصي المشرع البضائع من الرهن حتى تكون حرية المدين في الاستثمار كاملة^(١) إلا أن هذه الحرية مقيدة بحاجة الاستثمار بمعنى أنه لو ترتب على تصرف المدين في البضائع - باعتبارها تمثل جزءاً من قيمة المحل عند بيعه - ما يؤدي إلى إنقاص ضمان الدائنين المرتهين فقد يترتب على ذلك سقوط الأجل بل ، يمكن للدائن المرتهن أن يطالب بإبطال التصرف لو انطوي على غش بين المدين والمنصرف إليه ، ويقاس على ذلك كل عنصر من عناصر المحل التجاري غير المشمولة بالرهن^(٢).

ولا يقف حق المدين الراهن على محله المرهون عند حد الإدارة فقط ، وإنما يتعداه إلى الحق في التصرف في هذا المحل بكل أنواع التصرف^(٣). تطبيقاً للمادة ١٠٤٣ مدني مصري فله أن يبيعه أو أن يقدمه كحصة في شركة كما أن له أن يأخذ عليه رهناً جديداً.

ثانياً: التزامات المدين الراهن ١-المحافظة على المحل المرهون

طبقاً لما تقضي به المادة ١٣ من قانون ١٩٤٠ يلتزم المدين الراهن بالمحافظة على المحل التجاري المرهون ، فقد نصت على أن (المدين الذي يرهن طبقاً لأحكام هذا القانون مسئول عن حفظ الأشياء المرهونة بحالة جيدة دون أن يكون له الحق في الرجوع على الدائن المرتهن بشيء في مقابل ذلك).

وطبيعة الالتزام الذي يلتزم به المدين الراهن في المحافظة على المحل المرهون هو التزام ببذل عناية ، وليس التزاماً بتحقيق غاية ، وذلك تطبيقاً لما تقضي به المادة ٢١١ مدني مصري والتي نصت

(١) د/ محسن شفيق القانون التجاري ج ٥٠١ ، ٨٥٥ ، د/ سميحة القليوبي المحل التجاري ص ١١٠ ، كوهين المحل التجاري
فقرة ٩٣٨.

(٢) د على البارودي العقود وعمليات البنوك ص ١٢٢ دار المعارف الإسكندرية.

(٣) د/علي العريف القانوني التجاري ص ٤٥٩-٤٦٠ ، د/محسن شفيق المصدر السابق فقرة ٦٤٤.

على أنه (في الالتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين الرهن أن يحافظ على الشيء المرهون ، أو أن يقوم بإدارته ، أو أن يتوخى الحيلة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفي بالتزامه إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض ، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك) ، فيلتزم المدين الرهن بأن يأتي من الأعمال بما يتناسب مع طبيعة عناصر المحل التجاري المرهونة ، فمثلاً بالنسبة لعنصر الإجازة يلتزم المدين الرهن بالوفاء بأجرة المحل المرهون حتي يتفادى فسخ الإجازة^(١).

وبالنسبة للأدوات والمهمات الداخلة في الرهن عليه أن يقوم بأعمال الصيانة الدورية اللازمة لها حتي تبقي محافظة على قيمتها ، وقدرتها الإنتاجية ، على الأخص في المحلات ذات الإنتاج الصناعي.

وما ينفقه المدين الرهن للمحافظة على المحل المرهون لا يعود بشئ منه على الدائن المرتهن وللدائن المرتهن أن يتخذ من الوسائل التحفظية ما يلزم للمحافظة على المحل المرهون قله أن يطلب تعيين حارس ، بل له إن له أن يطلب تعيين المدين نفسه حارساً عليه^(١).

فإذا أخل المدين الرهن بالمحافظة على المحل المرهون ، وترتب على ذلك إنقاص كبير لضمان الدائن المرتهن ، فإنه بالتطبيق للمادة ٢٧٢/٢ مدي مصري يحرم المدين للرهن من الحق في الأجل ، وتحل آجال الديون المؤجلة فقد نصت المادة ٢٧٢ على أنه (يسقط حق المدين في الأجل إذا أضعف بفعله إلي حد كبير ما أعطي للدائن من تأمين خاص ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضي القانون).

٢- ضمان سلامة المحل التجاري المرهون

يقصد بضمن سلامة المحل التجاري المرهون أن يلتزم الرهن - كما يلتزم البائع - بضمن التعرض والاستحقاق فالمدين الرهن يلتزم طبقاً للقواعد العامة^(٢) بأن يتمتع بشخصه عن كل تعرض مادي أو قانوني من شأنه المساس بالحق العيني للدائن المرتهن ، أو الانتقاص من ضمانه

(١) د/ كمال أبو سريع المحل التجاري ص ٢٨٧ ، د/ علي يونس القانون التجاري ص ٣٠٦.

(١) د/ مصطفى كمال طه القانون التجاري: الأعمال التجاري ص ١٩٦ ، د/ عماد الشربيني القانون التجاري ج ١ ص ١٦٣.

(٢) فقد نصت المادة ١٠٤٧ مدي مصري علي أنه (يلتزم الرهن بسلامة الرهن، وللدائن المرتهن أن يعترض علي كل عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصاً كبيراً ، وله في حالة الاستعجال أن تخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية وأن يرجع علي الرهن بما ينفق في ذلك).

كما يلتزم ثانياً بأن يدفع التعرض القانوني الصادر من الغير. ونبين المقصود بكل من ضمان التعرض وضممان الاستحقاق.

ضمان التعرض

قد يكون التعرض مادياً أو قانياً ، كما قد يكون التعرض صادراً من المدين أو من الغير. فأما التعرض المادي الصادر من المدين الراهن فإنه يضمنه كما لو أتلّف بعض أدوات المحل ويضمن المدين الراهن أعماله المادية التي تؤثر إلى إنقاص الضمان إنقاصاً كبيراً^(٣).

أما الأعمال التي يقوم بها الراهن ولا يترتب عليها الانتقاص من المحل التجاري بدرجة كبيرة ، فإن للراهن الحرية في إجرائها دون أن يكون للدائن المرتهن الحق في الاعتراض عليها ، بل إنه لا يجوز له أن يعترض على ذلك الأعمال التي تخلق بالمتجر نقصاً تافهاً لا سيما إذا ظل ضمانه بعد إجرائها قوياً^(١).

أما التعرض المادي الصادر من الغير كما لو أحرق شخص المحل المرهون ، فإن المدين لا يضمنه وإنما يدفعه للدائن المرتهن بنفسه دون وساطة المدين^(٢).

التعرض القانوني

يضمن المدين التعرض القانون سواء كان صادراً من المدين أو من الغير ومثال التعرض القانوني الصادر من الغير كما لو أدعى شخص ملكية المحل المرهون^(٣).

أما التعرض القانوني الصادر من المدين كما لو قام المدين ببيع المحل المرهون أو رهنه ثانية فإنه يضمن هذا التصرف ، ونحن نعلم في هذا الخصوص أن الدائن المرتهن يكون محصناً تجاه تصرف المدين الراهن بامتياز الذي يخول له حقي التقدم والتتبع — كما سنري فيما بعد — ، لكن تبقي حالة ما إذا صدر الرهن من غير مالك ثم يقوم نفس المدين بارتهاً نفس المحل من مالكة الحقيقي ثم يتمسك هذا الراهن بعد ذلك عند توزيع ثمن بيع المحل بأن مالكة عند الرهن الأول لم

(٣) د/محمود السيد خيال الالتزام بالضمان في عقد الرهن الرسمي ص ٩٤ دار النهضة بدون ذكر التاريخ.

(١) د/محمود السيد خيال الالتزام بالضمان في عقد الرهن الرسمي ص ٩٤ دار النهضة بدون ذكر التاريخ.

(٢) د/حسام الاهواني التأمينات العينية والشخصية ص ٣٥٩ ط سنة ٢٠٠٠ ، د/رمضان أبو السعود التأمينات العينية ص ٣١٩.

(٣) د/كمال أبو سريع المحل التجاري ص ١٢٦ ، د/علي يونس المحل التجاري ص ٢١٦.

يرتب للمرتحن حق لصدوره من غير مالك ، لكن للمرتحن من غير المالك في هذه الحالة أن يدفع دعوى الرهن بأن من التزم بالضمان امتنع عليه التعرض والاستحقاق^(٤)

ضمان الاستحقاق

قد يهلك المحل المرهون بسبب يرجع إلي المدين الرهن ، أو بسبب أجنبي لا دخل للمدين فيه كهلاك العقار الكائن فيه المحل المرهون نتيجة كارثة سماوية. ففيه الحالة الأولي لو كان الهلاك راجعاً إلي خطأ المدين ، فإنه طبقاً للمادة ١٠٤٨/٢ يكون الدائن المرتحن مخيراً - في حالة هلاك الدخل التجاري المرهون بخطأ الرهن - بين سقوط الأجل أو التنفيذ العيني بأن يقدم تأميناً كافياً.

أما في الحالة الثانية ، فإن كان الهلاك راجعاً إلي سبب أجنبي ولم يقدم المدين الرهن تأميناً ، ورفض الدائن المرتحن بقاء الرهن بلا تأمين فالدائن المرتحن الحق في استيفاء دينه ولكن منقوصاً منه قيمة الفوائد عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ الحلول تطبيقاً للمادة ١٠٤٨ مديني مصري ، أما إذا قدم المدين تأميناً كافياً فلا يجوز للدائن المرتحن أن يرفض تقديم التأمين وإلا كان متصفاً برفضه فليزِم بقبول ما اختاره المدين^(١) الالتزام بإخطار الدائن المرتحن بنقل المحل التجاري المرهون.

نقل الرهن محله لمكان آخر

رأينا أن من أهم خواص رهن المحل التجاري أن المدين الرهن الحق في التصرف في المحل في المحل المرهون ، وربما يرغب المدين الرهن في نقل محله التجاري إلي مكان آخر لمصلحة يرى أنها ربما تعود عليه بالنفع ، وأن منعه من النقل يتعارض مع حقه في التصرف في المحل.

وقد يجد الدائن المرتحن في نقل المحل المرهون تعارض مع مصلحته ، إذ إن المكان الجديد ربما لا تتوافر فيه نفس العوامل الإيجابية الموجودة في المقر الكائن فيه المحل المرهون ، أو قد يستهدف المدين من وراء نقل المحل أن يكون بعيداً عن رقابة دائنية ، أو ربما تواطأ مع منافسيه وحصل منهم على تعويض مستتر للحصول على عملائه بعد رحيله^(٢). أضف إلي ذلك أن الدائن

(١) د/سليمان مرقس المرجع السابق ص١٧٣، د/منصور مصطفى ، د/جلال إبراهيم التأمينات العينية والشخصية ص١٤١ دار الاسراء سنة ٢٠٠١م.

(٢) ريزر وروبلو القانون التجاري ص ٤٧٩ فقرة ٦٦٠.

المرتهن- ليحافظ على حجية قيده - يلزمه أن يعيد قيد الرهن في المقر الجديد وهو أمر لا يخلو من المخاطر^(٣).

وقد وازن المشرع في قانون-رهن المحل التجاري- بين هاتين المصلحتين المتعارضتين ، فأجاز للمدين الراهن نقل محله إلي مكان آخر ، إلا أنه ألقى على عاتقه التزاما بإخطار الدائن المرتهن قبل النقل بشهر ، وإلا أصبح الدين واجب الأداء ، كما أوجب على الدائن المرتهن أن يعلن رأيه في النقل في خلال خمسة عشر يوما ، وذلك بالمادة ٢٤ من قانون ١٩٤٠ والتي نصت على أنه (يجب على المدين الذي يرغب في نقل المحل التجاري أو الأثاث أو الآلات التي تستعمل في استغلاله أن يخطر الدائن للمرتهن بخطاب موصي عليه في ميعاد شهر على الأقل قبل النقل فإذا أبدى الدائن عدم موافقته على النقل بخطاب موصى عليه في خلال خمسة عشر يوما التالية ، وتنشأ عن نقل المحل المرهون إنقاص لقيمته يصبح الدين واجب الأداء فورا ، وكذلك الحال إذا نقل المحل بدون إخطار سباق).

وقد ذهبت بعض أحكام القضاء إلي أن إخطار الدائن المرتهن بالنقل شكلية لا تغني عنها أي وسيلة أخرى^(١). وقد رتب المشرع جزاء على إهمال المدين الراهن عمل الإخطار للدائنين المرتهنين يتمثل هذا الجزاء في سقوط الأجل ووجوب أداء الدين.

ولا يعد نقل المخازن التابعة للمحل التجاري المرهون نقلا للمحل ، فلا تطبق عليه أحكام النقل ، لأنها لا تعتبر محلا مستقلا وكذلك نقل بعض الأدوات المستخدمة في المحل المرهون ، هذا بخلاف ، نقل فرع المحل إذا كان مشمولاً بالرهن فتطبق عليه أحكام النقل الواردة بالقانون لأن الفرع يعتبر محلا مستقلا^(٢).

وإذا أبدى الدائن المرتهن موافقته على النقل فلا يخلو الأمر من أحد فرضين:
الفرض الأول: أن يكون النقل داخل نفس دائرة مكتب السجل التجاري- أو المحكمة التجارية- الواقع في دائرته المحل التجاري ، وفي هذه الحالة يجب على الدائن أن يقوم بالتأشير على هامش القيد بنقل المحل التجاري.

الفرض الثاني: أن يكون النقل خارج دائرة مكتب السجل التجاري التابع لها المحل المرهون ، وفي

(٣) د/أحمد سلامة الرهن الطليق للمنقول ص ٢٣٤.

(١) ريبير رولو القانون الجاري ص ٤٧٩ فقرة ٦٦٠؟

(٢) موسوعة لامي في القانون التجاري سنة ١٩٩٧ فقرة ٧٣٧ ، موسوعة كلاسور في للمحل التجاري سنة ١٩٩٧ فقرة ١٢.

هذه الحالة يجب على الدائن المرتهن أن يقوم بعمل قيد لرهنه بالمقر الجديد الذي نقل فيه المحل التجاري وتاريخ القيد الأول ، ويكون للتأشير أو القيد الثاني نفس الأثر القانوني الذي للقيد الأول ، كما أن الرهن يرد على كل العناصر التي تدخل في ضمان الدائن المرتهن أن يقوم بعمل قيد لرهنه بالمقر الجديد الذي نقل فيه المحل التجاري وتاريخ القيد الأول. ويكون للتأشير أو القيد الثاني نفس الأثر القانوني الذي للقيد أول كما أن الرهن يرد على كل العناصر التي تدخل في ضمان الدائن المرتهن وعلى الأخص الإجارة الجديدة ولكل عنصر مشابه لما كان موجودا في المقر السابق لأنه معني بنفس العنصر وليس بالعنصر الجديد ويلتزم الدائن المرتهن بعمل القيد الجيد أو التأشير في هامش القيد في خلال الشهر الثاني لإخطاره أو الشهر التالي لعلمه بالنقل. (ويجب علي الدائن المرتهن في خلال الشهر التالي لإخطاره أو الشهر التالي بالنقل أن يطلب التأشير في هامش القيد القائم بالمقر الجديد للمحل. مادة ٢٤ من قانون ١٩٤٠.

المطلب الرابع

التنفيذ على المحل التجاري المرهون

بينت المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الإجراءات الواجب إتباعها في التنفيذ على المحل التجاري المرهون ، وذلك على النحو التالي:

أولاً: أن يتم طلب البيع بواسطة الدائن المرتهن

ليس لكل دائن يريد التنفيذ الجبري على المحل التجاري أن يلجأ إلي الإجراءات المنصوص عليها وإنما يقتصر هذا الحق فقط على الدائن المرتهن وكذلك بائع المحل التجاري وأما الدائن العادي فليس له أن يسلك طريق المادة ١٤ للتنفيذ على المحل التجاري وإنما يسلك الطريق العادية للتنفيذ والتي وردت في قانون المرافعات^(١).

ثانياً: لا تكون المهتمات التابعة للمحل التجاري مثقلة برهن عقاري

يشترط لتطبيق المادة ١٤ أن لا تكون المهتمات الموجودة بالمحل التجاري غير مثقلة برهن عقاري

(١) على قاسم المشروع الفردي ص ٣٤٦فقرة ٢٢٦ ، حسني عباس الملكية الصناعية فقرة ٥٨٣ ، نقص مدين ٥-٦-

، ويمكن تصور ذلك في حالة امتلاك التاجر - ملك المحل التجاري - للعقار الكائن فيه المحل التجاري وقام هذا التاجر يأخذ رهن على المهمات الموجودة بهذا المحل باعتبارها عقارا بالتخصيص ، فلا يجوز في هذه الحالة طبقا للمادة ١٤ بيع هذه المهمات إلا مع العقار الذي ورد عليه الرهن ، كما يجب إتباع إجراءات نزع الملكية وهو ما يعني عدم سريان الأحكام الخاصة بالتنفيذ على المحل التجاري.

ثالثا: أن ينصب البيع على العناصر المرهونة فقط

يشترط لإعمال المادة ١٤ أن يقتصر طلب البيع الجبري للمحل التجاري على العناصر المشمولة فقط بالرهن والتي ورد النص عليها في العقد ، فإذا لم يحدد الطرفان هذه العناصر فإنها تكون قاصرة على العناصر المشمولة بالرهن وجوبا والواردة بالمادة ٩ من قانون سنة ١٩٤٠. أما إذا انصب طلب البيع على عناصر غير المشمولة بالرهن فلا مجال لإعمال نص المادة ١٤ وإنما يتبع إجراءات التنفيذ العادية طبقا للقواعد العامة^٥.

رابعا: لا يلزم السند التنفيذي

يفهم من نص المادة ١٤ أنه لا يشترط كما هو الحال في القواعد العامة للتنفيذ على المحل التجاري المرهون أن يكون بيد الدائن المرتهن سند تنفيذي ، وإنما من حق هذا الدائن أن يباشر الإجراءات بمقتضى سند الدين حتى ولو كان هذا السند عرفيا^٦.

الإجراءات الواردة بالمادة ١٤

تحدد إجراءات البيع الجبري للمحل التجاري طبقا للمادة ١٤ من قانون ١٩٤٠ في الخطوات الآتية:

أولا: التنبيه الرسمي بالوفاء:

يقوم الدائن المرتهن بالتنبيه على مدينه والحائز للمحل التجاري بالوفاء تنبيهها رسميا. ويتم التنبيه الرسمي للحائز بجانب المدين على افتراض أن المدين تصرف في المحل التجاري المرهون لشخص آخر هو الحائز. أما إذا كان المدين لم يتصرف في المحل المرهون وما زال المحل في حوزته فإن التنبيه

الرسمي بالوفاء يكون قاصرا على المدين فقط ، وإذا خالف الدائن المرتهن ولم ينبه على مدينه بالوفاء ولم يقدم دليلا على قيامه بهذا الإجراء صحيحا فإنه يكون مسئولاً عن تعويض المدين عن الضرر نتيجة المخالفة^(١).

ثانيا: تقديم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة:

بعد مرور ثمانية أيام^(١) من تاريخ التنبيه على المدين والحائز بالوفاء ، يتقدم الدائن المرتهن بعريضة لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الواقع في دائرتها المحل التجاري المرهون يطلب فيها الإذن ببيع العناصر التي المشمولة بالرهن على أن يكون البيع بالمزاد العلني^(٢). وللقاضي سلطة تقديرية في تحديد العناصر التي يأذن ببيعها؛ إذ إنه ليس ملزما ببيع جميع العناصر الواردة بالطلب الذي تقدم به الدائن المرتهن ، فقد يرى القاضي أن بيع بعض العناصر المرهونة يكون كافيا للوفاء بالثمن المطلوب ، ومن ثم فلن تكون هناك حاجة للإذن ببيع جميع العناصر حتى ولو كانت محلا للامتياز. وفي كل الأحوال لا يستطيع القاضي أن يأذن إلا ببيع العناصر المشمولة بالرهن^(٣).

وطبقا للمادة ١٤ من قانون ١٩٤٠ فإنه يلزم أن يذاع عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل عن طريق النشر في الجرائد أو باللصق في لوحة الإعلانات المخصصة لإعلان الأحكام القضائية ، ويجب على القاضي أن يراعي ذلك عند تحديد اليوم الذي سيقع فيه البيع. ويجب على الدائن المرتهن أن يعلن صورة من هذه الإعلانات قبل البيع بخمسة أيام على الأقل لمالك العقار الكائن به المحل المرهون وللدائنين المرتهنين المقيدين ويتم البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يحددها القاضي المختص.

ثالثا: البيع بالمزاد العلني

اشتطت المادة ١٤ من قانون ١٩٤٠ لصحة البيع أن يتم البيع بالمزاد العلني^(١). وتنتقل الى الراسي عليه المزاد ملكية العناصر التي انصب عليها البيع ويصبح البيع نهائيا بمجرد رسو المزاد فلا يجوز الطعن فيه بزيادة العشر كما هو مقرر في حالة بيع العقار. وإذا بيع المحل المرهون بالمزاد العلني فإنه ينتقل إلى الراسي عليه المزاد خاليا من الحقوق العينية التي كانت تثقله ، وتنتقل حقوق الدائن المرتهن طالب البيع حقه من الثمن الذي رسا به المزاد ، فإن بقي شيء بعد ذلك انتقل

الى مالك المحل التجاري عند رسو المزاد^(١).

ولا يكون الدائن المرتهن مجبرا على اتباع طريق بيع المحل التجاري كما ورد بالمادة ١٤ بل له أن يلجأ إلى الطرق العادية للبيع والتي تشترط أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي حائز قوة الشيء المقضي أو سند رسمي ، فضلا عن إتباع الإجراءات الخاصة بتوقيع الحجز كما وردت في قانون المرافعات ، وفي نفس القوت لا يجوز الاتفاق على حرمان الدائن من سلوك طريق بيع المتجر كما ورد بالمادة ١٤ من قانون ١٩٤٠ فإذا وقع مثل هذا الاتفاق كان باطلا^(٢).

وفي كل الأحوال إذا لم يكف المبلغ الناتج من بيع المحل التجاري للوفاء بالديون المضمونة بالرهن فإن الدائن المرتهن يصبح مجرد عادي بالنسبة لما تبقى له من دين فيمكنه التنفيذ على أموال المدين الأخرى بما له من ضمان عام على هذه الأموال ، وفي هذه الحالة يجب إتباع الطرق العادية للتنفيذ. ويتم البيع برسو المزاد ، وينتقل المتجر لمن رسا عليه المزاد خاليا من الحقوق العينية التي كانت تثقله ، وتنتقل حقوق الدائنين المقيدة إلى الثمن.

المبحث الثاني

بيع المحل التجاري

نتناول أحكام بيع المحل التجاري في مطلبين اثنين نخصص الأول منهما لانعقاد بيع المحل التجاري وإثباته ، أما المطلب الثاني فنخصصه لآثار بيع المحل التجاري.

المطلب الأول

انعقاد بيع المحل التجاري وإثباته

انعقاد بيع المحل التجاري

عقد بيع المحل التجاري كغيره من العقود يفتقر لانعقاده إلى توافر الأركان العامة للعقد وهي الرضا والمحل والسبب والأهلية ، فإذا شاب عقد بيع المحل التجاري عيب من عيوب الرضا والمحل كالغلط أو الإكراه أو التدليس أو كان نشاط المحل التجاري غير مشروع كان العقد باطلا^(٣).

فقد قضت محكمة النقض ببطالان عقد بيع محل تجاري بسبب أن البائع قد أخفى على المشتري أن سبب إغلاق المحل التجاري المباع هو أنه كان يدار بدون ترخيص من الجهات الإدارية ، فقد اعتبرت محكمة النقض أن هذا الكتمان تدليس يؤدي الى بطلان العقد⁰.

محل البيع:.

لا تنطبق الأحكام الخاصة ببيع المحل التجاري إلا على العقد الذي يكون محله متجرا⁰ ، فإذا كان محل البيع شيئا آخر غير المتجر فلا تنطبق أحكام القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ ، ولم يفرض القانون على طرفي عقد بيع المتجر عناصر معينة يجب أن يشتمل عليها العقد ، وإنما ترك تحديد تلك العناصر لحرية طرفي العقد ، غير أن قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أكد على ضرورة اشتغال عقد بيع المتجر على عنصر الاتصال بالعملاء ، فقد نصت المادة ٣٥ تجاري على أنه (إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التي يتألف منها المتجر محل العقد ، فإنه يشتمل فضلا عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية على كل عنصر معنوي أو مادي يكون لازما لاستغلال المتجر على الوجه الذي قصده المتعاقدان).

وتتولى المحكمة تحديد عناصر بيع المتجر إذا أغفل المتعاقدان تحديدها مراعية في ذلك النية المشتركة للمتعاقدين وطبيعة المحل التجاري ونوع العملاء ، فقد قضت محكمة النقض بأن (بيع المتجر يشتمل على العناصر المادية والمعنوية ، وأن قصره على العناصر المادية فقط مؤداه عدم اعتباره بيعا لمحل تجاري)⁰.

وتقدير ما إذا كانت العناصر التي انصب عليها البيع ومدى اعتبارها مكونة للعناصر الجوهرية للمحل التجاري من عدمه مسألة قانونية تخضع لتقدير قاضي الموضوع الذي يخضع تقديره فيها لرقابة محكمة النقض⁰.

وقد يكون محل عقد بيع المتجر حصة شائعة من المحل التجاري ، ومع هذا يعتبر البيع صحيحا ما دامت هذه العناصر متضمنة العناصر الجوهرية للمحل التجاري⁰.

وطبقا للمادة الأولى من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ فإنه يجب أن يشتمل عقد بيع المتجر على ثمن المقومات غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حده. ويعتبر من محل البيع في عقد بيع المتجر الثمن الذي يقدمه المشتري كمقابل للمحل التجاري ، وقد يكون هذا الثمن حال الأداء وقد يكون مؤجلا أو أن يتم الوفاء به على أقساط دورية.

شهر بيع المتجر

أوجب المشرع قيد عقد بيع المحل التجاري بالسجل الخاص المعد لذلك بمكتب السجل التجاري الواقع في دائرة المحل التجاري المباع ، ويعد هذا القيد وسيلة لشهر عقد بيع المتجر حتى يكون حجة في مواجهة الغير ، وهو شرط شكلي استوجبه المادة ٣/٣٧ وحددت البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الشهر وهي:

١. أسماء طرفي العقد وعناوينهما وجنسياتهما.
٢. تاريخ عقد بيع المحل التجاري.
٣. نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التي اتفق على ان يشملها العقد والتمن وما دفع منه عند البيع وكيفية سداد باقي الثمن.
٤. الاتفاق بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.
٥. الاتفاق بشأن المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز. ت

إثبات بيع المحل التجاري:.

يعتبر عقد بيع المتجر عملاً تجارياً بالنسبة للبائع؛ لأنه قد يكون آخر عمل يقوم به التاجر ويعتزل بعده الحياة التجارية ، كما أنه قد يكون تجاراً بالنسبة للمشتري أيضاً؛ إذ أنه قد يكون أول عمل يقوم به لاحتراف النشاط التجاري ، ويرى البعض أن بيع المحل التجاري يعد عملاً تجارياً بصفة مطلقة استناداً إلى موضوع العقد نفسه^(١).

وعلى الرغم من تجارية عقد بيع المحل التجاري ، فإن إثبات هذا العقد لا يتم بكافة طرق الإثبات كما هو الشأن في جميع المسائل التجارية والتي تتسم بالحرية في الإثبات ، وإنما يتم إثبات عقد بيع المتجر عن طريق الكتابة فقد وليس بشيء آخر ، وذلك بحيازة العقد الذي يثبت واقعة البيع؛ تطبيقاً للمادة ١/٣٧ تجاري والتي حسمت خلافاً دام طويلاً قبل صدور القانون الجديد حول طبيعة تطلب الكتابة في عقد البيع ، فقد نصت المادة ١/٣٧ تجاري على أن (كل تصرف موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عيني عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً). وهو ما يؤدي إلى القول باعتبار العقود الواردة على المحل التجاري من تطبيقات الاستثناء على مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية^(٢).

المطلب الثاني

آثار بيع المتجر

يرتب بيع المحل التجاري مجموعة من الآثار بالنسبة لكل من البائع والمشتري ، ونبين آثار بيع المتجر بالنسبة للبائع ثم نبين - ثانيا - بيع المتجر بالنسبة للمشتري.

أولاً: آثار بيع المتجر بالنسبة للبائع

يلتزم البائع في بيع المتجر بنقل ملكية المتجر إلى المشتري ، وكذلك الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المتصلة بالمحل التجاري ، وكذلك التزام البائع بضمان العيوب الخفية ، وأخيراً يلتزم بائع المتجر بعدم المنافسة.

١- الالتزام بنقل ملكية المتجر وتسليمه

الأصل أن ملكية المتجر تنتقل بمجرد إبرام عقد البيع بين البائع والمشتري؛ تطبيقاً للقواعد العامة دون توقف على أي إجراء آخر ، غير أن قانون التجارة الجديد جاء بحكم جديد يعد استثناء على القاعدة العامة في هذا الشأن؛ إذ تطلب لانتقال ملكية المحل التجاري بين البائع والمشتري أو بالنسبة للغير ضرورة قيد التصرف الناقل للملكية في السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه في صحيفة السجل التجاري ، فقد نصت المادة ١/٣٨ تجاري على أنه (لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا من تاريخ قيد التصرف في السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه في صحيفة السجل التجاري).

وبخصوص العناصر المختلفة الداخلة في تكوين المحل التجاري والتي يشترط القانون الخاص بها اتباع إجراءات معينة لنقل ملكيتها كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية فإنه يلزم اتباع الإجراءات الخاصة المقررة لذلك^(١). وإذا كانت هذه العناصر خاضعة لنظام شهر خاص فلا يقوم شهر التصرف في المتجر في السجل التجاري مقام الشهر أو التسجيل الخاص بتلك العناصر إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ٣٨ تجاري على أنه (إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر أو التسجيل فلا يقوم شهر التصرف في المتجر في صحيفة السجل التجاري مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك).

وإذا اتفق الطرفان على أن يشمل البيع العقار الكائن به المحل التجاري فيجب إتباع إجراءات

التسجيل والإشهار الخاصة بالعقار ، ولا تسري في شأن بيع المحل التجاري قاعدة الحياة في المنقول سند الملكية حتى ولو كان حسن النية؛ إذ أن المحل التجاري منقول معنوي ولا تسري هذه القاعدة سوى على المنقول المادي^(١).

ويلتزم البائع كذلك بتسليم المحل التجاري إلى المشتري ويخضع تسليم المتجر للقواعد العامة ، وذلك بوضع المتجر تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه المشتري استيلاء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك^(٢).

ويتم تسليم المتجر للمشتري بأن يسلم البائع للمشتري كافة المستندات التي تمكنه من ملكية المتجر والانتفاع به ، وان يسلمه الحق في العملاء وذلك بإعطائه كافة المعلومات والمستندات اللازمة بالمتجر.

٢- الالتزام بنقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر:

لا يقصد بالحقوق والالتزامات في هذا الشأن تلك التي ترتبت في ذمة التاجر بصفة شخصية ، وإنما يقصد بها تلك الحقوق والالتزامات المترتبة بخصوص عقود وتصرفات مرتبطة بالمحل التجاري كما هو الحال بالنسبة لحق صاحب المتجر في الاتصال بالعملاء والسمة التجارية وحقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية والالتزامات المترتبة على الاتفاقات الخاصة التي يبرمها بائع المتجر والخاصة بتنظيم المنافسة المشروعة مع المحال التجارية المجاورة^(٣) ، وكذلك عقود العمل التي أبرمها بائع المتجر مع العمال والمستخدمين بالمحل التجاري ، فإن هذه العقود طبقا للمادتين ٧٦ ، ٨٥ من قانون العمل تستمر بما تتضمنه من حقوق والتزامات في مواجهة عمال المحل ومستخدميه.

٣- الالتزام بعدم منافسة المشتري:

يقصد بعدم منافسة البائع للمشتري أن يمتنع البائع عن منافسة المشتري بمباشرة تجارة مماثلة بتلك التي كان يستغل فيها المتجر المباع بحيث يؤدي إلى جذب العملاء عن المحل المباع^(٤).

ويهدف هذا الالتزام إلى حماية المشتري من الإضرار به وفقدانه لعملاء المحل التجاري المباع^(٥) ، وبالتالي فإن هذه الحماية تقتصر على الحالات التي يلحق فيها الضرر بالمشتري ، فإن لم يكن هناك أي إضرار بالمشتري فلا محل لهذا الالتزام كأن ينشئ البائع تجارة منطقة بعيدة عن منطقة المحل التجاري المباع. أو أن ينشئ البائع تجارة مغايرة للنوع الأول.

ويقتصر الحظر في المنافسة على عملاء المحل المباع دون أن يشمل هذا الحظر الأشخاص الذين يساهمون في نشاط المحل التجاري كالموردين والمتعهدين فهؤلاء تظل علاقتهم ببائع المحل التجاري مستمرة^(١).

وقد جاء قانون التجارة الجديد ليخفف من حدة شرط عدم المنافسة بتحديد مدته بعشر سنوات ما لم يتفق الأطراف على مدة أقل ، فقد نصت المادة ٤٢ تجاري على أنه (لا يجوز لمن تصرف في المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله أن يزاول نشاطا مماثلا لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الاستغلال إلا إذا اتفق على خلاف ذلك ، ويسر هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة أقل).

وينتقل شرط عدم المنافسة إلى ورثة البائع من بعده^(٢) ، ولا يسري هذا الشرط على الغير ولو كان من أقارب البائع كأبنائه إلا إذا استتر هذا البائع خلفهم في ممارسة نشاط تجاري بالمخالفة لأحكام شرط عدم المنافسة^(٣).

ويترتب عل الإخلال بشرط عدم المنافسة حق المشتري في رفض الوفاء بالثمن ، وحقه في طلب فسخ البيع أو التنفيذ العيني والتعويض عما أصابه من ضرر^(٤).

٤-ضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية:

يقصد بضمان الاستحقاق: أن يضمن البائع كل تعرض قانوني يصدر عن الغير فيما يتعلق بملكية المحل التجاري المبيع او فيما يتعلق بملكية عنصر من عناصره ، فإذا ادعى شخص أجنبي ملكية المحل التجاري أو ملكية عنصر من عناصره التزم البائع بالرد على كل دعوى ترفع من الغير باستحقاق المتجر سواء كان الادعاء منصبا على جميع عناصر المتجر أو على عنصر من عناصره ، وغالبا ما تكون حالات الاستحقاق منصبة على جزء من أجزاء المتجر الاختراع أو على العلامة التجارية التابعة للمتجر^(٥).

وكما يلتزم البائع بضمان الاستحقاق فإنه يلتزم أيضا بضمان العيوب الخفية التي لو علمها المشتري قبل البيع ما أقدم على إبرام العقد ، ويشترط أن يتوافر في العيب أربعة شروط حتى يوجب الضمان^(٦) :

١ . أن يكون العيب مؤثرا. ب . أن يكون قديما. ج . أن يكون خفيا. د . أن يكون غير معلوم للمشتري.

وطبقا للمادة ٤٤٩ مدني فإنه إذا وجد المشتري عيبا في المبيع ، وكان خفيا ومؤثرا وقديما وجب

عليه أن يخطر البائع حتى يرجع على البائع بالضمان. ويخضع تقدير ما إذا كان العيب خفيا ومؤثرا على استغلال المتجر لتقدير قاضي الموضوع^٥ ، ويجب رفع دعوى الضمان خلال سنة من وقت اكتشاف العيب ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء العيب^٥ ، فإن كان البائع قد تعمد إخفاء العيب جاز رفع دعوى الضمان خلال خمس عشرة سنة^٥.

ثانيا: التزامات المشتري

يعد الالتزام بدفع ثمن المحل التجاري المباع من أهم الالتزامات التي تترتب في ذمة المشتري بسبب بيع المحل التجاري ، ويلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه ومصاريف إبرام العقد والسمسرة. ولا يحق للمشتري حبس الثمن إلا إذا امتنع البائع عن تسليم المتجر أو تعرض للمشتري في استغلاله للمتجر أو تعرض له الغير في هذا الاستغلال أو اكتشف في المتجر عيوباً خفية^٥. وقد يتم الوفاء بثمان المحل التجاري دفعة واحدة ، غير أن الغالب . نظرا لارتفاع أثمان المحل التجارية أن يتم الدفع على أقساط وفي هذه الحالة يحرر المشتري سندات إذنيه لمصلحة البائع تسمى بسندات المتجر ، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد عقد البيع ثمن كل عنصر من عناصر المتجر^٥.

ويشترط أن يحدد بدقة في عقد بيع المحل التجاري الثمن الذي يخص البضائع والمهمات المادية والعناصر المعنوية كل على حده ، وقد أوجبت المادة ٣٨ من قانون سنة ١٩٤٠ أن يخصم ما يدفعه المشتري أولا من ثمن البضائع ثم من ثمن المهمات أولا من هذا الامتياز لأنها عناصر ظاهرة يعتمد عليها دائنو المشتري يسمح بمزاحمته ، كما أن البائع لا مصلحة له في إبقاء امتيازها؛ لأن حقه في تتبعها يتعطل إذا انتقلت إلى حائز حسن النية^٥.

ثالثا: ضمانات البائع

يتمتع بائع المحل التجاري بالحق في حبس المحل التجاري باعتباره منقولا إذا لم يوف المشتري بكامل الثمن أو بعضه إذا كان مؤجلا ، كما أن له الحق في فسخ عقد البيع واسترداد المتجر المباع وتناول هاتين الضمانتين بشيء من التفصيل.

أولاً: امتياز بائع المحل التجاري

الأصل في بيع المنقول أن من حق البائع أن يستوفي ثمن المبيع بالأولوية على غيره من دائني المشتري ، كما أن الأصل أن امتياز بائع المنقول يرد على المنقول كله دون تجزئة ، أما في خصوص بيع المحل التجاري فقد نظم المشرع قواعد في هذا الخصوص تختلف عن القواعد العامة ، فمثلاً نجد أن امتياز البائع يجرأ إلى ثلاثة أقسام ، جزء يرد على البضائع ، وجزء يرد على المهمات ، والجزء الثالث يرد على العناصر المعنوية. كما أن المادة الخامسة من قانون ١٩٤٠ قد قررت بقاء امتياز بائع المتجر على حاله في حالة إفلاس المشتري فلا يتحول من دائن ممتاز إلى دائن عادي وذلك بعكس ما تقضي القواعد العامة في هذا الشأن والتي تقضي بأن يتحول الدائن الممتاز إلى دائن عادي في حالة إفلاس المدين^(١). ويشترط لتمتع البائع بالامتياز على المتجر المباع ما يلي:.

١. أن يكون عقد البيع ثابتاً بعقد رسمي أو بعقد عربي مصدق على التوقيعات أو الأختام فيه^(٢).
٢. أن يتم شهر عقد بيع المتجر في السجل المعد لذلك بمكتب السجل التجاري الواقع في دائرته المحل التجاري وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد العقد.
٣. أن يتفق على تجزئة ثمن المحل التجاري إلى عناصر ثلاثة في عقد البيع وعند قيده في السجل التجاري وهي كما ذكرنا البضائع والمهمات والعناصر المعنوية ، ويكون كل جزء منها مضموناً بالامتياز الذي يتقرر على العنصر الذي يقابله من المحل التجاري^(٣) ، وقد عالج المشرع في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون ١٩٤٠ الحالة التي يرد فيها الثمن مجزئاً في العقد وفي القيد دون بيان العناصر التي تشملها التجزئة فقد نصت تلك الفقرة على أنه (إذا لم يعين الطرفان على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز فإنه لا يرد إلا على عنوان المحل التجاري واسمه والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمة التجارية ، أي أن المشرع قصر الامتياز في هذه الحالة على العناصر المعنوية سالفه الذكر دون البضائع والمهمات ، كما لا يرد على العناصر المعنوية الأخرى التي لم يذكرها المشرع كبراءة الاختراع وحقوق الملكية الأدبية^(٤)).

ولما كان المحل التجاري منقولاً معنوياً فمن حق بائع المحل التجاري أن يتبعه في أي يد إذا تصرف فيه المشتري تصرفاً ناقلاً للملكية دون أن يتمسك الحائز في مواجهته بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز؛ حيث إنها تسري في شأن المنقولات المادية دون المنقولات المعنوية.

ثانيا: دعوى الفسخ

الأصل طبقا للقواعد العامة أن يرفع البائع دعوى يطلب فيها فسخ عقد البيع إذا لم يقيم المشتري بالوفاء بكامل الثمن ، وقد نصت المادة ٥ من قانون ١٩٤٠ على هذا الحق لبائع المحل التجاري غير أنها قيدت هذا الحق بمجموعة من الشروط خرجت بدعوى الفسخ على بعض القواعد العامة ومن ذلك ما يلي:

١. إن بائع المحل التجاري لا يتمتع بالحق في فسخ البيع إلا إذا كان العقد منصوصا فيه صراحة على حق البائع في الفسخ عن عدم الوفاء بكامل الثمن^١ ، وبالإضافة إلى النص على هذا الحق في عقد البيع فقد اشترطت نفس المادة النص على هذا الحق في ملخص القيد الذي يودع بمكتب السجل التجاري.

٢- إن دعوى الفسخ لا ترفع إلا لرد الجزء التي كانت محلا لعقد البيع دون العناصر الأخرى التي لم تكن داخلة في البيع ، فإذا أضاف المشتري إلى المتجر عناصر أخرى فإنه لا يلتزم بردها لأنها لم تكن داخلة في البيع^٢.

والحكم الذي يصدر في دعوى الفسخ لا يحتج به على الغير ومن ثم يسترد البائع المتجر. محملا بما عليه من حقوق مقررة للغير^٣. ولم يبين المشرع الإجراءات الواردة بالقواعد العامة ، وقد حرص المشرع على تمكين الدائنين المقيدين من مراقبة هذه الدعوى فأوجب على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يخطرهم بما في محالهم المبينة في القيد فإن لم يفعل البائع كان الدائن الذي لم يعلن بالدعوى أن يعترض على الحكم الصادر فيها^٤.

تم بحمد الله

الشركات التجارية

(القواعد العامة للشركات التجارية - شركات الأشخاص

- شركات الأموال - الشركات ذات الطبيعة المختلطة - شركة الشخص الواحد)

الدكتور

ذكرى عبد الرازق محمد خليفة

أستاذ القانون التجاري ورئيس قسم القانون الخاص

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

جامعة الأزهر

١٤٤٥ هـ / ٢٠٢٥ م

قال تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ أَفَمَنْ أَتَسَسَ بُنْيَانُهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَتَسَسَ بُنْيَانُهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢﴾

صدق الله العظيم.

[الآية: ١٠٩ : سورة التوبة].



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد المهادي الأمين وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:

الشركات التجارية

مقدمة عامة في:

أولاً: أهمية الشركات التجارية:

يكتسب التنظيم القانوني للشركات التجارية أهمية ذاتية خاصة على مختلف المستويات القانونية والإقتصادية والمالية والإدارية، بالنظر إلى الروابط التي تنشأ في إطار المشروع التجاري الجماعي " الشركة " بين الأفراد ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات، عبر توحيد الجهود والتكامل في سبيل تحقيق الأهداف والنهوض بأعمال يعجز الأفراد، في الغالب، عن تحقيقها بشكل فردي، وذلك بتركيز نشاطهم في شخص معنوي ينبثق عن إرادتهم المشتركة بغية تحقيق طموحاتهم في الحصول على أعلى عائد.^(١)

وقد ظهرت منذ القدم الحاجة إلى تكتل القوى في الميدان الاقتصادي من أجل القيام بالمشروعات الكبيرة التي تتجاوز في متطلبات تحقيقها قدرات الأفراد، مهما بلغت إمكانياتهم المالية والاقتصادية والتنظيمية، والولوج في مشروعات لا يرغب الأفراد في أن يغامرون في تحقيقها منفردين، فما أن قامت الثورة الصناعية حتى ظهرت معها الحاجة إلى الأعمال والمشروعات ذات رؤوس الأموال الضخمة التي تتطلب تضافر طاقات وجهود الأفراد وتعبئة مدخراتهم، من أجل الاضطلاع بالمشروعات الانتاجية الصناعية والتجارية والزراعية الكبرى، وغيرها من المشروعات التي تتعدى بنشاطاتها حدود الدولة إلى دول أخرى.

ولا تقتصر أهمية الشركات على تجميع رؤوس الأموال وتعبئة المدخرات من أجل مواجهة المشروعات الكبيرة، بل استطاعت أيضاً أن تحقق لهذه المشروعات دواماً واستقراراً يتفوقان على ما تستطيع الطاقات الفردية تحقيقه، وذلك نظراً لطبيعة الشركة التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء، تمكنها من الاستمرار مدة أطول من حياة الأفراد التي يتهدها الموت فيجعل لها نهاية حتمية، بينما تستطيع الشركات أن تعيش عشرات بل مئات السنين بعد وفاة مؤسسيها، فيضمن بقاءها استقرار نشاط المشروعات والحفاظ على ثمرات جهود المؤسسين بعد وفاتهم.

وقد تعاظمت أهمية الشركات في العصر الحالي بوصفها الأداة المثلى للنهوض الإقتصادي، لدرجة أصبحت معها هذه الشركات، تتمتع في مختلف البلدان بسلطان يدايني سلطان الدولة، وتشكل قوة اقتصادية واجتماعية تخشى الدولة بأسها و سطوتها، وترى من واجبها أن تسهر على رقابتها حتى لا تنحرف عن الطريق السوي، وتصبح أداة للإستغلال الاجتماعي أو السيطرة السياسية.^(١)

وتعتبر الشركات، على اختلاف أنواعها وأشكالها من نظم الاقتصاد الحر، سيما شركة المساهمة، التي تعد من إفرازات الفلسفة الفردية والاقتصاد الرأسمالي، وما خلفاه من انعكاسات على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، انعكاسات تمثلت في مبدأي الحرية الاقتصادية وسلطان الإرادة، وقد تمكن النظام الرأسمالي الحر بفضل هذه الشركات من التوسع والانتشار داخل الدولة وخارجها، واستطاعت الشركة أن تؤدي وظيفتين هامتين يعجز عنهما غيرها من المؤسسات الخاصة ذات الأشكال القانونية الأخرى. الوظيفة الأولى: كون الشركات أداة فريدة لتجميع المدخرات في شكل أسهم أو سندات، يستوي في ذلك سائر المدخرين من كل الطبقات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، من أجل تمويل المشروعات الكبيرة. الوظيفة الثانية: هي انفرادها بنظام خاص في تسيير إدارتها يكفل لها المرونة والكفاءة في توجيه المشاريع، وبالتالي استثمارها على النحو الأفضل.^(٢)

غير أن هذه الأهمية التي اكتسبتها الشركات في العصر الحديث، في إرساء دعائم الانتاج الوطني وتعزيز ثروات المواطنين وإرفاد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات عن طريق جباية الضرائب على الأرباح، لم تخلو من بعض المساوئ سواء تجاه الأفراد أو تجاه الدولة، وذلك أن الحرية التي تمتعت بها الشركات، في ظل النظام الاقتصادي الحر، مكنتها من السيطرة على الانتاج، وخصوصاً بعد أن أنشأت التكتلات الاحتكارية وفرض الأسعار الفاحشة على المستهلكين، ليس هذا فحسب بل استطاعت الشركات أن تستمد منه مركزاً اقتصادياً وقوة امتدت إلى الحياة السياسية، ففرضت نفوذها في الأوساط السياسية واستطاعت أن تحقق أغراضها الخاصة على حساب المصلحة العامة.

وقد تنبّهت السلطات العامة لهذه المساوئ، وسعت إلى الحد منها عن طريق سن التشريعات التي تكفل حماية المساهمين والإدخار العام، وتقف بوجه الإحتكار فتحد من مساوئه، وتكفل في الوقت نفسه تنظيم إدارة الشركات وسير أعمالها، وتضع لذلك العقوبات

الكثيرة والمشددة، وهكذا بدأت تشريعات الشركات تضعف من دور الإرادة الحرة شيئاً فشيئاً، كما برز، إلى جانب الحرية التعاقدية، دور التنظيم القانوني للعلاقات الناشئة عن الشركة بغية تحقيق الأهداف السابقة.

هذا، وعلى الرغم من أن معظم التشريعات والاجتهادات الفقهية والقضائية تتعاطى مع موضوع الشركات كأحد الموضوعات الرئيسية التي تشكل محتوى القانون التجاري، انطلاقاً من أن ممارسة العمل التجاري ليست حكراً على التاجر الفرد أو الأشخاص الطبيعيين، وإنما يعترف بهذا الحق أيضاً للتجمعات القانونية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية كالشركات، إلا أنه ومع تعاضم أهمية الشركات في الواقع الاقتصادي، ومع التشعب والتعدد المتزايد لأنواعها وصورها وأهدافها على المستويات الدولية والوطنية، ومن ثم تشعب القواعد القانونية التي تنظمها، بدأ البعض في الحديث عن ضرورة إفراذ الشركات التجارية بتنظيم يراعي هذا الواقع، ويستجيب باستمرار للتعديلات المتلاحقة على قواعدها، بما يسهم تدريجياً في إسباغ بعض الذاتية والخصوصية على هذا التنظيم والمفاهيم التقليدية التي يتضمنها.

إن إفراذ موضوع الشركات بمساق خاص يستجبه التطور والتوسع في مجال الأعمال التي يتم ممارستها في إطار شركات، الأمر الذي يضغط باتجاه توسيع المادة القانونية التي تشملها، واستيعاب العناوين الفرعية والتعديلات المضطردة على العديد من المسائل والزيادة الملفتة في مفاهيمها المستقلة، ويستوجب ذلك تسليط الضوء ومحاولة بناء هذه المادة والتحديد الدقيق والمناسب لمضمونها ولأسلوب تقديمها، وهو أمر يلاحظ كذلك بشأن العديد من الأفرع القانونية، كالقانون المصرفي وقانون التجارة الدولية والقانون البحري والجوي.

ثانياً: تاريخ الشركات التجارية: ^(١)

يعود تنظيم الشركات إلى ما قبل القانون الروماني، فقد عرفه البابليون، ونظمه قانون حمورابي، أما البوادر الأولى للأصول الحديثة لأنظمة الشركات فقد ظهرت في القانون الروماني الذي اعتبر أن الشركة عقد رضائي لا ينتج إلا مجرد التزامات بين أطرافه، دون أن يرتب أثراً تجاه الغير، ومن ثم لا ينشأ عنه شخص معنوي مستقل عن أشخاص الشركة، ومع ذلك فقد ظهرت في روما شركات خاصة لجمع الضرائب ولتنفيذ الأشغال العامة وتوريد المؤن الحربية.

ونخفضت الحياة التجارية في الجمهوريات الإيطالية في القرن الثاني عشر، فتطور التشريع المتعلق بالشركات، وبرزت في تلك الأثناء شركات التضامن، وأصبح معها الشركاء مسئولين

بالتضامن عن ديون الشركة المتمتعة بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وكان اسم المديرين يودع في "قنصلية التجار" وهي الهيئة المركزية لتجار المدينة إعلاناً للغير عن وجود الشركة. كما ظهرت في الجمهوريات الإيطالية أيضاً شركة التوصية، التي يرجع أصلها إلى أحد أنظمة القانون البحري، وهو القرض البحري الجزائي أو ما يعرف بقرض المخاطر الجسمية Mauticum Focuses، وذلك للحصول على تمويل للرحلة البحرية بالتفادي لحظر الإفراض بالفائدة الذي فرضته الكنيسة، ولا يكون مقدم المال مسئولاً إلا بنسبة الأموال التي قدمها، ولا يستوفي حقه إلا إذا وصلت السفينة سالمة ونجحت الرحلة البحرية، وحينئذ يحصل، فضلاً عن مبلغ القرض على فائدة مرتفعة، أما إذا هلكت فإنه يفقد دينه، أي أن المقرض في هذه الصورة يكون شريكاً في مخاطر الرحلة البحرية.

أما شركات المساهمة فقد برزت إبان السياسة الاستعمارية في أوروبا منذ القرن الخامس عشر والسادس عشر، وما واكبها من الحاجة إلى تجميع الأموال الضخمة اللازمة لاستثمار المستعمرات الواسعة في الهند وإفريقيا وأمريكا، فنشأت شركات مساهمة كبيرة بمقتضى أوامر ملكية جعلتها تكتسب شخصيتها المعنوية بإرادة الدولة، ومنحت امتياز استثمار المستعمرات، وكان لها حق تكوين الجيوش وصك النقود وتحصيل الضرائب ومن ثم احتكار التجارة الدولية، فكانت بمثابة دول حقيقية داخل الدولة، وكان إنشاء هذه الشركات يتم بمقتضى إصدار أوراق مالية قابلة للتداول وهي الأسهم، ومن أمثلة هذه الشركات شركة الهند الشرقية التي أسسها الوزير كولبير سنة ١٦٦٤، وشركة الهند الجديدة التي نشأت سنة ١٧١٧، وشركة خليج هدسون.

وقد ازداد التسارع إلى تكوين شركات المساهمة مع تطور الحركة الصناعية في القرن الثامن عشر لإفساح المجال لتوظيف رؤوس الأموال بصورة تضمن تحقيق مزيد من الأرباح، وتخصر مسئولية المساهمين في حدود الحصة المقدمة منهم، ومع ظهور المخترعات الحديثة في منتصف القرن التاسع عشر وتطلب استثمارها جمع رؤوس أموال ضخمة وانتشار مبادئ الحرية الاقتصادية، عدلت الدول تشريعاتها وتخلت عن ضرورة الحصول على ترخيص حكومي مسبق لتأسيس شركة المساهمة، تشجيعاً لرواج هذه الشركات وانتشارها في ظل الاقتصاد الرأسمالي المتطور.

ومع بدايات القرن العشرين بدأت الفكرة التقليدية في الشركات المساهمة بالتراجع، ومالت التشريعات شيئاً فشيئاً إلى التضييق من دور الإرادة الحرة في تنظيم الشركات، وفرضت القيود والأحكام الآمرة التي تحميها جزاءات جنائية متعددة، حماية للمدخرين وللإقتصاديات الوطنية،

كما بدأ رأس المال العام يدخل في تكوين الشركات المساهمة عن طريق ما يعرف بـ "شركات الاقتصاد المختلط" في بعض القطاعات الاقتصادية التي تعرضت لأزمات، وكنوع من المواءمة ما بين الحرية الاقتصادية والمبادئ الاشتراكية.

كما أعقب الحرب العالمية الثانية موجة عارمة من التأميم شملت العديد من الدول التي تبنت النهج الاشتراكي، وقد أدت حركة التأميم إلى ظهور نوع جديد من الشركات العامة التي تمتلك الدولة أو أحد أشخاص القانون العام كل أسهمها.

وينظم الشركات التجارية في فرنسا القانون رقم ٦٦-٥٣٧ الصادر في ٢٤ يولييه لسنة ١٩٦٦، الذي جمع في ٥٠٩ مادة تنظيم جميع الشركات التجارية، وألغت المادة ٥٠٥ منه كافة القوانين السابقة التي تتعارض مع أحكامه، ومن أهم ما استحدثه هذا القانون أنه اعتبر شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة، تجارية بحسب شكلها، أيّاً كان موضوعها، ثم صدر قانون ١٦ ديسمبر لسنة ١٩٩٩، غير أن هذا القانون الأخير لم يتضمن القواعد العامة المشتركة للشركات ولا القواعد المنظمة لبورصة الأوراق المالية والتي نظمها لاحقاً القانون النقدي والمالي الصادر في ١٤ ديسمبر لسنة ٢٠٠٠^(١).

ثالثاً: تطور تشريع الشركات في مصر:

ظلت الشركات في مصر خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية شأنها شأن المعاملات المدنية حتى صدور المجموعات القانونية المختلطة ثم الأهلية، وقد تميز التنظيم القانوني للشركات التجارية في مصر لاحقاً بإيراد بعض أحكامه في القانون المدني وبعضها الآخر في القانون التجاري، فقد أفرد القانون المدني للشركة الفصل الرابع من الباب الأول من الكتاب الثاني، للأحكام العامة للشركات، وذلك في المواد من ٥٠٥ إلى ٥٣٧، والتي نظم فيها أركان عقد الشركة وكيفية إدارتها وطريقة توزيع أرباحها وخسائرها، وطرق انقضاءها وتصفيتها وقسمة أموالها، وهذا التنظيم الذي تضمنه التقنين المدني يعتبر من قبيل الأحكام العامة التي تنطبق على الشركات التجارية، بشرط عدم تعارضها مع الأحكام الواردة في القوانين التجارية التي تسري على الشركات.

بينما خصص قانون التجارة الملغي الصادر في سنة ١٨٨٣ للشركات التجارية المواد من ١٩ إلى ٦٥، وأحال فيما لم يرد بشأنه نص خاص إلى أحكام القانون المدني، ومما أخذ على هذا القانون أنه قصر تقصييراً واضحاً أمام نمو الشركات من الناحية الاقتصادية، وخاصة شركات المساهمة، واتساع نطاقها في مصر في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ووقف

المشرع المصري، في بادئ الأمر، مكتوف الأيدي، بسبب الامتيازات الأجنبية وما نشأ معها من نفوذ الشركات الأجنبية وقوتها استناداً إلى القوى الاستعمارية في ذلك الوقت.

وحاولت الحكومة تدارك بعض الأحكام عن طريق مجلس الوزراء الذي كان صاحب الحق في الترخيص للشركات المساهمة بمزاولة أعمالها وقتئذ، فأصدر بضع قرارات لتنظيم الشركات المساهمة في السنوات ١٨٩٩ و ١٩٠٦ و ١٩٢٣ و ١٩٢٧، غير أن هذه القرارات لم تستطع سد الثغرات المتعددة في قانون التجارة في موضوع الشركات المساهمة، كما أنها لم تكن لها قوة القانون، ولذلك رأى المشرع أن يتدخل عن طريق التشريع، فأصدر القانون رقم ١٣٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركة المساهمة، كما أصدر المشرع القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والذي نظم فيه ولأول مرة الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وقد كشف العمل عن قصور القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤، فأصدر المشرع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١. وأخيراً تم إلغاء قانون التجارة الصادر سنة ١٨٨٣ بمقتضى قانون التجارة الحالي رقم ١٧ والصادر سنة ١٩٩٩، غير أن هذا الإلغاء لم يكن كلياً، إذ أبقى القانون الجديد على الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الملغى والخاص بشركات الأشخاص، حيث تظل هذه الأخيرة منظمة بمقتضى أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى القواعد العامة التي تنظم عقد الشركة في القانون المدني.

وعلى هذا، فالقواعد المنظمة للشركات في القانون المصري هي تلك الواردة بهذا الشأن في قانون التجارة الجديد وقانون التجارة الملغى، وقانون شركات الأموال رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتشريعات المعدلة والمكملة له، والتي تسري أحكامه على الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في كل من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، وقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٨، وأخيراً قواعد القانون المدني.

رابعاً: الشركة التجارية والشركة المدنية:

تعتبر الشركة مدنية أو تجارية وفقاً لأحد معيارين، المعيار الموضوعي والمعيار الشكلي:

١- المعيار الموضوعي: الذي يقصر الصفة التجارية على تلك الشركات التي تمارس عملاً تجارياً فعلياً، فإذا كانت الشركة تحتترف القيام بالنشاط التجاري اعتبرت تجارية، كاحتراف شراء

منقولات بقصد بيعها وتحقيق ربح، أو القيام بأعمال الصناعة أو النقل أو التوريد، أو القيام بأعمال البنوك والتأمين، وغيرها من الأعمال التجارية الأصلية، أما إذا كان الغرض من تكوين الشركة يعد بحسب القانون عملاً مدنياً، فإنها تعتبر شركة مدنية، كالشركات التي تقوم على الاستغلال الزراعي أو شركات المهن الحرة.

وقد توجهت إلى المعيار الموضوعي العديد من أوجه النقد، والتي تتمحور حول أن هذا المعيار يستند في نهاية الأمر إلى فكرة العمل التجاري ويتبنى الأساس نفسه المعتمد للتفرقة بين التاجر وغير التاجر، بينما أن فكرة العمل التجاري نفسها وما ينبني عليها من تحديد صفة التاجر، هي بدورها فكرة غامضة عجز الفقه عن وضع ضابط واضح لها، كما أن هذا المعيار يثير صعوبات عملية كبيرة في تكييف طبيعة الشركة، وينطوي على جمود لا يتفق مع طبيعة العديد من الشركات الكبرى وما تقتضيه طبيعتها وروابطها بالغير من اكتسابها الصفة التجارية، فالمعيار الموضوعي يقيي الشركات الزراعية والتعليمية والاستخراجية الكبرى كشركات مدنية، رغم ما تقوم عليه من استثمار لرؤوس أموال ضخمة، وما تنطوي عليه من مضاربة وقصد تحقيق الربح، ومن ثم فلا يتمتع المتعاملون معها بضمانات القانون التجاري، في الوقت الذي يكتسب فيه صغار التجار صفة التاجر رغم ضآلة استثماراتهم وضعف مشاريعهم من الناحية الاقتصادية.

وقد كان المعيار الموضوعي هو المعيار المعتمد للتفرقة ما بين الشركات التجارية والشركات المدنية في ظل القانون التجاري الملغي الصادر في سنة ١٨٨٣، قبل أن يتم العدول عنه إلى المعيار الشكلي بمقتضى أحكام قانون التجارة الجديد لسنة ١٩٩٩.

٢- المعيار الشكلي: وهو الذي يكتفي بالشكل الذي تعتمده الشركة لإضفاء الصفة التجارية عليها، دونما اعتبار لنشاط الشركة سواء كان مدنياً أو تجارياً، وقد أخذ بهذا المعيار قانون الشركات الفرنسي الصادر في ٢٤ يولييه لسنة ١٩٦٦، فوفقاً للمادة الأولى من هذا القانون تعد الشركة تجارية إذا اتخذت أحد أشكال الشركات التي نظمها القانون، كما تبنى قانون التجارة المصري الحالي هذا المعيار صراحة عندما نص في الفقرة الثانية من المادة العاشرة على أنه: "يكون تاجراً كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيّاً كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله".

وعلى هذا تكتسب الشركة في القانون المصري الصفة التجارية بمجرد اتخاذها أحد الأشكال التي نظمها القوانين الخاصة بالشركات، وهذه الأشكال هي: شركة التضامن وشركة التوصية

البسيطة وشركة المحاصة وشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، وسواء كان نشاط الشركة أو الغرض من إنشائها كان هو القيام بأعمال مدنية أو بأعمال تجارية^(١)، وذلك باستثناء شركة المحاصة، باعتبارها شركة مستترة لا تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الشركاء فيها، ومن ثم فإن إضفاء الصفة التجارية عليها لا يرتبط بالمعيار الشكلي، والفرض أنها لا تستوفي هذا الشكل، وإنما إلى المعيار الموضوعي، حيث تعد تجارية إذا باشرت أحد الأنشطة التجارية، ومدنية إذا كان عملها من طبيعة مدنية.^(٢)

نتائج التفرقة بين الشركات التجارية والشركات المدنية:

للوقوف على طبيعة الشركة وما إذا كانت مدنية أو تجارية أهمية بالغة، وذلك بالنظر إلى إختلاف القواعد القانونية التي تسري على كل منهما، فبينما تخضع الشركات المدنية لأحكام القواعد العامة الواردة في القانون المدني، تخضع الشركات التجارية للأحكام الواردة في القانون التجاري والقوانين المكملة له في شأن الشركات، وتسري عليها قواعد القانون المدني فيما لم يرد بشأنه نص تجاري خاص، ومن ثم فعند التعارض ترجح الأحكام الواردة في القانون التجاري، بوصفها أحكاماً خاصة.

ويترتب على ذلك مجموعة من الأحكام التي تختلف فيها الشركة التجارية عن الشركة المدنية نشير إلى أهمها فيما يلي:

١- تكتسب الشركات التجارية صفة التاجر، وتخضع وحدها لالتزامات التاجر، من القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية، فضلاً عن أن القانون يتطلب إجراءات الشهر بالنسبة لتأسيس الشركات التجارية (وفقاً للمادة ٤٨ وما بعدها من قانون التجارة)، عدا شركة المحاصة، دون الشركات المدنية التي لا تخضع لإجراءات شهر خاصة، ولا يلتزم فيها المؤسسون إلا بأحكام القانون المدني.

٢- تخضع الشركات التجارية لأحكام شهر الإفلاس، ولها وحدها طلب الصلح الواقعي من الإفلاس أو إعادة الهيكلة، أما الشركات المدنية فيسري عليها نظام أقل صرامة هو نظام الإعسار المدني.

٣- تسري على الشركات التجارية، بوصفها تكتسب صفة التاجر، نظرية التبعية حيث تعتبر أعمالها المدنية تجارية إذا ارتبطت بممارسة نشاطها التجاري، كما تخضع الشركة التجارية لضريبة الأرباح التجارية، وفي كل ذلك تختلف الشركة المدنية عن الشركة التجارية.

٤- الأصل، وفقاً للمادة ٥٢٣ من القانون المدني الخاصة بعقد الشركة، أن الشركاء في الشركة المدنية مسئولون عن ديون الشركة مسئولية شخصية من غير تضامن ما لم يتفق على غير ذلك، إذ أن التضامن في المعاملات المدنية لا يفترض، أما بالنسبة للشركات التجارية فإن مسئولية الشركاء فيها عن ديون الشركة يختلف بحسب نوع الشركة وبحسب مركز الشريك فيها، فتكون المسئولية شخصية وتضامنية بين الشركاء المتضامنين في شركة التضامن وشركة التوصية، وتكون محدودة بالنسبة إلى الشركاء الموصين في شركات التوصية، وبالنسبة للشركاء المساهمين، وكذلك كافة الشركاء في الشركة المحدودة المسئولية.

٥- يسقط حق الدائنين في مطالبة الشركاء في الشركات التجارية بالتقادم الخمسي، بينما يخضع حق الدائنين للشركات المدنية للتقادم الطويل المقرر في القواعد العامة لانقضاء الالتزام بخمس عشرة سنة.

خامساً: صور وأشكال الشركات التجارية:

حدد القانون أشكال الشركات التي يمكن للمشروعات التجارية اتخاذها، تحديداً ورد على سبيل الحصر، فلا يمكن إنشاء شركة في شكل لم يرد بشأنه نص قانوني، على أنه يمكن للمشرع أن يضيف أشكالاً جديدة وفقاً لمقتضات الإقتصاد الوطني، ويكون لأصحاب العلاقة حرية اختيار الشكل القانوني الملائم للشركة التجارية التي يعتمون تأسيسها، على أن يتقيدوا بالأحكام القانونية للتأسيس من ناحية، وعدم اختيار أكثر من شكل واحد لشركتهم من ناحية أخرى، والعلة في تحديد أشكال الشركات التجارية تحديداً حصرياً، ترجع إلى أن كثرة الأشكال تؤدي إلى الخلط وصعوبة التمييز وتداخل الأحكام القانونية المنظمة لكل نوع منها، لاسيما وأن الأشكال التي حددها القانون تعد كافية للاستجابة لتحقيق مختلف الحاجات الإقتصادية.^(١)

وقد يتدخل المشرع في بعض الحالات ليحد من حرية الأفراد في اختيار شكل معين للشركة التي يعتمون تأسيسها، كأن يوجب، لأسباب هامة تتعلق بمصلحة البلاد الإقتصادية، أن تتخذ بعض المشاريع الاستثمارية شكلاً معيناً من أشكال الشركات، كإنشاء المؤسسات المصرفية أو البنوك في شكل شركة مساهمة، كما قد يحظر المشرع على الشركة التي تمارس نشاطاً استثمارياً

معيناً أن تتخذ صورة شركة معينة، كما هو الشأن في مشروعات التأمين أو أعمال البنوك أو الإدخار، التي حظر المشرع أن تتخذ صورة الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو التوصية بالأسهم، لضعف ائتمان هذا النوع من الشركات عن تلبية المتطلبات الائتمانية والاقتصادية لتلك الأنشطة، التي تتطلب عادة رؤوس أموال ضخمة تعجز عنها في الغالب شركات المسؤولية المحدودة والتوصية بالأسهم.^(١)

وعلى هذا يجب أن تتخذ الشركة إحدى الصور التي نص عليها القانون وإلا كانت باطلة، وهذه الصور في القانون المصري هي: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة، وشركة المساهمة، وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، حيث تخضع الشركات الثلاث الأولى " شركات الأشخاص " لأحكام القانون التجاري والقواعد العامة الواردة في القانون المدني المنظمة لعقد الشركة فيما لا يتعارض مع نص تجاري، أما بقية الشركات السبع فينظمها قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته اللاحقة والقوانين المكملة له.

شركات الأشخاص وشركات الأموال:

تنقسم الشركات التجارية إلى نوعين رئيسيين: النوع الأول: شركات الأشخاص، أو شركات الحصص (sociétés de personnes ou par intérêts) والنوع الثاني: شركات الأموال أو شركات المساهمة (sociétés de capitaux ou par actions) .

ففي شركات الأشخاص، يسود الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة التي يضعها كل شريك في الآخر، ويسود الاعتبار الشخصي ويؤثر على تكوين الشركة ويظل سارياً مدة بقائها، كما أن أثره ينعكس على انقضاء الشركة، حيث تتكون الشركة بين عدد محصور من الشركاء يعرف بعضهم بعضاً. ونظراً لأهمية الاعتبار الشخصي في هذه الشركات فإن هناك آثاراً جوهرية تترتب على ذلك: منها على سبيل المثال: أن الغلط في شخص الشريك يؤدي إلى بطلان عقد الشركة بطلاناً نسبياً، كما لا يسوغ لأي من الشركاء التنازل عن حصته أو أن يتصرف فيها إلى الغير دون موافقة الشركاء الآخرين لئلا يقحم على الشركاء أحداً لا تتوفر فيه ثقتهم التي أولوها للشريك الأول، كما أن وفاة أحد الشركاء أو إعلان إفلاسه، أو فقد أهليته، أو انسحابه من الشركة، يؤدي، مبدئياً، إلى انحلال الشركة، ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك.

والصورة المثلى لهذه الشركات هي شركة التضامن (société en nom collectif) التي تضم شركاء يكونون جميعاً مسؤولين عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية، ويكتسبون صفة التاجر.

ومن شركات الأشخاص أيضاً، شركة التوصية البسيطة (société en commandite simple)، التي تضم نوعين من الشركاء هما: الشركاء المتضامنون أو "commandités"، الذين لا يختلف وضعهم عن وضع الشركاء المتضامين في شركة التضامن، ويكتسبون صفة التاجر، والشركاء الموصون أو شركاء التوصية (commanditaires)، الذين تنحصر مسؤوليتهم بقيمة حصصهم في الشركة، ومع ذلك، لا تكون حصصهم قابلة، كأصل عام، للتنازل عنها إلى الغير، وتنحصر الإدارة في هذه الشركة بالشركاء المفوضين أو المتضامين، دون الشركاء الموصين. أما إذا تدخل هؤلاء في الإدارة، أصبحوا مسؤولين كالشركاء المفوضين في كامل أموالهم.

وهناك نوع ثالث من شركات الأشخاص هو شركة المحاصة (société en participation)، وهي شركة خفية مستترة لا تظهر إلى الغير ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، ويستتبع ذلك أنه لا يكون لها اسم ولا عنوان ولا محل لإقامة ولا ذمة مالية مستقلة، بل ينحصر أثرها بين الشركاء الذين يعينون مديراً لها يتولى باسمه الخاص وعلى مسؤوليته الشخصية مسألة التعامل مع الغير.

أما شركة المساهمة أو الشركة المغفلة (société anonyme) وهي الصورة المثلى لشركات الأموال، فهي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، قابلة للتداول بالطرق التجارية، ولا يكتسب الشريك "المساهم" فيها صفة التاجر، وتنحصر مسؤوليته عن ديونها في حدود الأسهم التي يملكها فيها، دون أن تمتد إلى عناصر ملكيته الأخرى، ولا تؤثر وفاة أحد المساهمين فيها أو فقده أهليته أو إعلان إفلاسه على وجود الشركة وسير أعمالها، ولا على الضمان العام لدائنيها، الذين يعتمدون على أموالها وموجوداتها، وليس على الذمم الشخصية للشركاء.

وبجانب شركات الأشخاص وشركات الأموال على النحو المتقدم، يوجد من الشركات ذات الطبيعة المختلطة ما بين النوعين السابقين، حيث تكتسب خصائص مشتركة وتقع في مركز وسط ما بين شركات الأشخاص وشركات الأموال. وتضم هذه الشركات:

- شركة التوصية بالأسهم: والتي تضم نوعين من الشركاء: شركاء متضامنون لهم نفس المركز القانوني الذي للشركاء في شركة التضامن، وشركاء مساهمون يكتسبون ذات المركز القانوني

للشركاء في شركة المساهمة، سواء من حيث مدى اعتبار شخصية الشريك فيها، أو طبيعة مسؤوليته عن ديونها، أو حرية تداول الأسهم والتنازل عنها، أو مدى اكتساب صفة التاجر.^(١)

- الشركة ذات المسؤولية المحدودة: استحدثت هذه الشركة في مصر لأول مرة بمقتضى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤، وهي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكاً، كما أن للاعتبار الشخصي دور هام في تأسيس الشركة، ويخضع تداول الحصص فيها لإجراءات وقيود معينة، وهذه الخصائص تقرّبها من شركات الأشخاص، غير أن ما يقرّبها من خصائص شركات الأموال هو أن مسؤولية الشركاء فيها عن ديون الشركة تتحدد بقدر حصصهم في رأس المال، فضلاً عن أنها تتبنى نظاماً للإدارة تقترب من طريقة إدارة شركات الأموال.

والواقع أن هذا التقسيم للشركات إلى شركات للأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي، وشركات للأموال تستند إلى الاعتبار المالي، وشركات ذات طبيعة مختلطة، لا يستند إلى أسس حاسمة، ذلك أن شركات الأشخاص، وإن كانت الغلبة فيها للاعتبار الشخصي، إلا أنها لا تخلو من الاعتبار المالي، فرأس مال الشركة ضروري لتحقيق أهدافها، كما الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه لا ينفصل تماماً عن الاعتبار المالي للشريك، كذلك لا تخلو شركات الأموال من الاعتبار الشخصي، فقد يكون لشخصية المؤسسين في شركة المساهمة دور في إقبال الجمهور على الاكتتاب في رأس مال الشركة من عدمه.

كما أن للإرادة التعاقدية دور في تفاعل تقسيمات الشركة سالفة الذكر، فقد يتضمن عقد شركة التضامن، وهي شركة تقوم على الاعتبار الشخصي، شرطاً يقضي باستمرار الشركة مع الورثة بالرغم من وفاة الشريك، كما قد يتفق على استمرار الشركة بالرغم من وفاة الشريك باشتراط موافقة أغلبية معينة، وبذلك تقترب شركة التضامن، وهي الصورة المثلى لشركات الأشخاص، من خصائص شركات الأموال، ومن ناحية أخرى فقد يتضمن النظام الأساسي لشركة المساهمة قيوداً تتعلق بتداول الأسهم، كحظر التنازل عنها للأجانب إذا كانت مؤسسة برأس مال وطني، بل إن هناك بعض القيود القانونية التي ترد على تداول الأسهم، كعدم جواز تداول الأسهم العينية والأسهم التي يكتب فيها المؤسسون قبل نشر الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين من تاريخ تأسيس الشركة، وفي تلك القيود الاتفاقية والقانونية على تداول الأسهم في شركات الأموال ما يقرّبها من خصائص شركات الأشخاص.^(١)

خطة الدراسة: بناء على العرض المتقدم للشركات التجارية التي تعهدوا المشرع بالتنظيم، نتناول دراسة أحكام هذه الشركات كل على حده، غير أن الشركات التجارية على اختلاف صورها تخضع لمجموعة من الأحكام العامة المشتركة التي تسري على الشركة أياً كان نوعها.

وعلى ما تقدم نعرض لدراسة الشركات التجارية في الفصول التالية:

الفصل الأول: الأحكام العامة للشركات التجارية:

الفصل الثاني: شركات الأشخاص:

الفصل الثالث: شركات المساهمة:

الفصل الرابع: الشركات ذات الطبيعة المختلطة:

الفصل الخامس: شركات الشخص الواحد:

الفصل الأول الأحكام العامة للشركات التجارية

لم يتضمن القانون التجاري أو القوانين المكملة له أحكاماً عامة للشركات التجارية، وقد وردت الأحكام العامة للشركات في القانون المدني في الفصل الخاص بعقد الشركة، وتسري هذه الأحكام على الشركات التجارية، وذلك بالتطبيق لنص المادة التاسعة عشرة من قانون التجارة القديم التي تقضي بأنه: "تتبع في هذه الشركات (الشركات التجارية) الأصول العمومية المبينة في القانون المدني" فقد نظمت المواد من ٥٠٥ إلى ٥٣٧ من هذا القانون، أركان عقد الشركة وكيفية إدارتها وطريقة توزيع أرباحها وخسائرها، وطرق انقضاءها وتصفياتها وقسمة أموالها، وعلى هذا تسري الأحكام العامة المنظمة لعقد الشركة في القانون المدني على الشركات، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون التجاري والقوانين المكملة له، كما سبق وأن أشرنا.

وتوضيحاً لذلك فإننا نعرض للأحكام العامة للشركات التجارية بتقسيم هذا الفصل إلى

المباحث الآتية:

المبحث الأول: تعريف الشركة وبيان طبيعتها القانونية:

المبحث الثاني: أركان عقد الشركة:

المبحث الثالث: الشخصية المعنوية للشركة:

المبحث الرابع: انقضاء الشركة وتصفياتها:

المبحث الأول

تعريف الشركة وبيان طبيعتها القانونية

تولى المشرع تعريف عقد الشركة في المادة ٥٠٥ من التقنين المدني بأنها: "عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة".^(١)

ومن هذا التعريف يتضح أن الشركة تنشأ بمقتضى تصرف قانوني إرادي في صورة عقد، ولذا يلزم لصحتها توافر الأركان الموضوعية العامة اللازمة لصحة سائر العقود، وهي الرضا والأهلية والمحل والسبب، كما يتضح من التعريف ضرورة توافر أركان خاصة تستوجبها الطبيعة القانونية الخاصة بعقد الشركة، وهي: تعدد الشركاء، واشتراك الأعضاء في تكوين رأس المال عن طريق تقديم حصة من مال أو عمل، واشتراكهم في اقتسام الأرباح والخسائر، وتوافر نية المشاركة، كما يجب فضلاً عن ذلك لصحة عقد الشركة توافر الركن الشكلي المتمثل في الكتابة والإشهار.

الطبيعة التعاقدية وفكرة النظام القانوني في الشركة:

الفكرة التعاقدية:

صيغ مفهوم الشركة وتحدد طبيعتها القانونية في ظل الفكرة التعاقدية conception contractuelle، وقد سادت النظرية التعاقدية خلال القرن التاسع عشر لانسجامها آنذاك والنظرية العامة لسلطان الإرادة théorie générale de l'autonomie de la volonté، التي أتاحت، باسم الحرية التعاقدية، عقد مختلف الاتفاقات، وحتى تعديل الأحكام التشريعية، خدمة لمبدأ الحرية الاقتصادية، وبالفعل تمكن أنصار مذهب الحرية الاقتصادية، بفضل هذا المبدأ وإكمالاً لحرية التعاقد، من التوصل إلى إقرار مبدأ حرية تأسيس شركات المساهمة، الذي تقرر في فرنسا بقانون ١٩٦٧ بعدما كان قانون التجارة يمنع ذلك.^(٢)

تقييم الفكرة التعاقدية:

على أن الفكرة التعاقدية، في نطاق الشركات، لم تكتسب تأييداً مطلقاً، وأخذت في التراجع شيئاً فشيئاً، حتى بدا مع الوقت أن هناك فروقاً كبيرة تقوم بين قواعد قانون الشركات من جهة، والقواعد التي تحكم العقود بوجه عام من جهة أخرى. ويظهر ذلك من نواح عدة:

فمن جهة، فإن فكرة العقد لا تستوعب كل الآثار القانونية التي تترتب على تكوين الشركة، ذلك أن عقد الشركة ليس عقداً كغيره من العقود يقتصر أثره على ترتيب التزامات على عاتق

الشركاء في الشركة، بل هو عقد يترتب عليه غالباً نشوء شخص قانوني جديد، شخص معنوي هو الشركة يقوم إلى جانب أشخاص الشركاء، حيث تشير كلمة شركة في نفس الوقت إلى العقد من جهة وإلى الشخص المعنوي الذي يتولد عنه من جهة أخرى، وهذا الشخص المعنوي هو الذي يسيطر ويهيمن على الإرادات الفردية التي اشتركت في تكوين العقد، ولا سيما في شركات المساهمة، حيث يتعامل هذا الشخص المعنوي مع الغير بمختلف صور التعامل، فيكتسب منهم الحقوق ويتحمل قبلهم بالالتزامات، وذلك عن طريق أشخاص يتولون إدارة الشركة لا يعتبرون مجرد وكلاء عن الشركة، بل أعضاء membres فيها، باعتبارها شخصاً معنوياً مستقلاً عن الشركاء.

كما يجوز في إطار هذا الشخص المعنوي لأغلبية الشركاء أن تفرض إرادتها على الأقلية وأن تعدل شروط وأحكام العقد، خلافاً للقاعدة العامة في العقود التي تستلزم، لتحديد مضمونها أو لتعديلها، إلتقاء إرادة المتعاقدين جميعاً.^(١)

كما يظهر نقص الفكرة التعاقدية في شركة المساهمة في أن الشخص قد يكتسب في أسهم الشركة دون أن يعنى بالتعرف على الغرض منها أو عن الأحكام التي وردت في عقدها، بل إنه قد يشتري السهم فقط بغرض المضاربة وبيعه بمجرد ارتفاع الثمن، دون اكتراث جدي بإدارتها وتسيير أعمالها، فزاد بذلك انفصال الشخص المعنوي عن إرادة الشركاء، فمثل هذا الشريك يصعب اعتباره شريكاً متعاقداً مع غيره من الشركاء.

وفضلاً عن العوامل الداخلية المستمدة من طبيعة الشركة، فقد ضعفت الفكرة التعاقدية في الشركات بتأثير عوامل خارجية مستمدة من الواقع الاقتصادي والضرورات الاجتماعية، اتجه المشرع على إثرها إلى إحاطة الشركات بسياج من الأحكام الآمرة لتنظيمها، حماية للمصالح الوطنية ومصالح المدخرين والغير الذين يتعاملون مع الشخص المعنوي، لا سيما ما يتعلق بتأسيس الشركة وإدارتها الرقابة على أعمالها.

فكرة النظام القانوني:

لكل ما سبق بدأت الفكرة التعاقدية للشركة تضعف لحساب تطبيق فكرة النظام القانوني conception institutionnelle، وهي نظرية مستوحاة من نظريات القانون العام، والمتمثلة بعنصري الاستمرار والتنظيم، بقصد تحقيق الغرض المشترك للشخصية المعنوية، عن طريق إخضاع الحقوق والمصالح الخاصة إلى مصالح المجموعة المشتركة، وتكريساً لهذا المفهوم فقد تدخل المشرع

في تنظيم الشركة، كشخص معنوي، بأحكام تشريعية أمرة، بصورة يمكن القول معها أن هذه المؤسسة أصبحت خاضعة لنظام قانوني، بصورة قد تتجاوز اعتبارها تعاقدًا حرًا بين الشركاء.^(١) تقييم فكرة النظام القانوني:

غير أن فكرة النظام القانوني، وإن عبرت عن الدور المتزايد للمشرع في تنظيم أحكام الشركات، لا سيما في إطار شركات المساهمة، إلا أنها تفتقر إلى التحديد، كما أن نطاق تطبيقها لا يستوعب جميع الشركات، خاصة شركات الأشخاص، فالثابت أن العقد لا يترتب عليه دائماً نشوء شخص معنوي، إذ أن هناك نوعاً من الشركات لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتحكمه إرادة الأطراف التعاقدية، وليس مجموع قواعد قانونية فرضها القانون، وهي شركة المحاصة، وهو ما يعني أن الفكرة التعاقدية لا يمكن الاستغناء عنها كلياً، بل إنها ما زالت تنعكس بآثارها على مجمل التنظيم القانوني للشركات، كما أن الثابت أن الشركة تنشأ بمقتضى عقد حقيقي يتم بتوافق إرادتين أو أكثر، ويخضع للقواعد العامة في العقود.

والواقع أن دور كل من الفكرتين، التعاقدية والتنظيمية، يختلف باختلاف أنواع الشركات، حيث يسود بعضها النظام التعاقدي والبعض الآخر يسوده النظام القانوني، فبينما تغلب الفكرة التعاقدية في شركات الأشخاص، وحيث لا يجوز تعديل أحكام العقد إلا بموافقة كافة الشركاء كأصل عام، تغلب الفكرة التنظيمية في شركات الأموال، وبالأخص شركات المساهمة، ولذا تخضع الإرادة العقدية في هذه الشركات للعديد من القواعد القانونية الملزمة، لاعتبارات تتعلق بحماية مصالح المدخرين والمتعاملين مع الشركة من جهة، و بمقتضيات الإقتصاد الوطني من جهة أخرى.^(٢)

المبحث الثاني أركان عقد الشركة

تعريف الشركة بأنها عقد، يخضعها للشروط والأركان المقررة قانوناً لصحة العقود بوجه عام، من جهة، كما تخضع، من جهة أخرى، لقواعد خاصة يفرضها القانون لصحة عقد الشركة، سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الشكلية، وتكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية المستقلة إن توافرت لها هذه الأركان مجتمعة، بينما يرتب القانون على تخلفها بطلان العقد.

وعلى هذا ندرس في هذا المبحث تكوين عقد الشركة من حيث وجوب توافر: الأركان الموضوعية العامة في مطلب أول، فالأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة في مطلب ثان، ثم

الركن الشكلي في مطلب ثالث، وأخيراً وفي مطلب رابع نعرض للأثر المترتب على اختلال أي من هذه الأركان "بطلان عقد الشركة".

المطلب الأول

الأركان الموضوعية العامة

يشترط لصحة تكوين الشركة، بوصفها عقداً من العقود، ضرورة توافر الشروط اللازمة لصحة العقود وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني، وهي الرضا والأهلية والمحل والسبب.

أولاً: الرضا:

يشترط لانعقاد الشركة رضا الشركاء جميعاً، ويجب من ناحية أن ينصب الرضا على كافة شروط العقد، كاسم الشركة وموضوع نشاطها ورأس مالها ومركزها وكيفية إدارتها، وكافة ما يتضمنه عقدها، ومن ناحية أخرى يتعين أن يكون الرضا صحيحاً، بأن يكون صادراً عن إرادة واعية ومدركة لحقيقة ما تلتزم به، ويتحقق ذلك بخلوها من العيوب التي يمكن أن تشوبها، فإذا شابها عيب من عيوب الإرادة، كان العقد قابلاً للإبطال لمصلحة من شاب العيب رضاه.

وعيوب الإرادة هي: الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال، فقد يتمثل العيب في غلط وقع فيه المتعاقد، سواء في طبيعة العقد أو في صفة جوهرية فيه، فإذا بلغ الغلط حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط^١، فإنه يؤدي إلى إبطال العقد لمصلحة من وقع في الغلط، كما إذا تعاقد الشخص ظاناً أن العقد خاصاً بشركة ذات مسؤولية محدودة، فإذا بها شركة تضامن، يسأل عن ديونها مسؤولية غير محدودة، أو وقع في غلط في شخصية أحد الشركاء في شركة أشخاص، مما دفعه إلى قبول الدخول في الشركة، فتبين له خلاف ذلك، نظراً لأن شخصية الشريك محل اعتبار في هذا النوع من الشركات.

ويكون عقد الشركة قابلاً للإبطال كذلك إذا وقع المتعاقد ضحية لتدليس، إذا كان التدليس هو العامل الدافع إلى التعاقد، وذلك كأن تستخدم طرق احتيالية للإيهام على خلاف الحقيقة بقوة المركز المالي للشركة، من أجل دفع الغير إلى الدخول فيها، ولا يجوز إبطال الشركة للتدليس إلا إذا كان قد وقع من أحد الشركاء على شريك آخر، أما إذا وقع التدليس من أحد من الغير على أحد الشركاء، فليس للمتعاقد أن يطلب إبطال العقد، إلا إذا ثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفترض به حتماً أن يعلم به عند إنشاء العقد، فإن عجز المتعاقد

عن إقامة الدليل على ذلك، ظل عقد الشركة صحيحاً، واقتصر حق المدلس عليه على مجرد مطالبة المدلس بالتعويض.^(١)

كذلك يصبح الرضا معيياً إذا أبرم عقد الشركة نتيجة لإكراه أو استغلال، دفع الشريك للتعاقد وهو غير واع أو مدرك حقيقة العقد أو مختار في إقدامه على التعاقد، وذلك إذا استطاع الشريك إثبات أن هذا العيب هو الباعث الدافع إلى التعاقد.

ثانياً: الأهلية:

كما يشترط لصحة عقد الشركة أن يصدر الرضا عن ذي أهلية، ولأن عقد الشركة من العقود الدائرة بين النفع والضرر، فإن الأهلية اللازمة لعقد الشركة، هي الأهلية الخاصة بأعمال التصرف، أي أهلية الرشيد البالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية متمتعاً بكامل قواه العقلية، ولم يحجر عليه لعارض يفقده قواه العقلية^(٢)، وعلى هذا فإن قيام القاصر بإبرام عقد الشركة، يجعل العقد قابلاً للإبطال لمصلحته، بحيث يكون له وحده التمسك بإبطال عقد الشركة، ما لم يكن قد بلغ الثامنة عشر وأذنت المحكمة بمباشرة التجارة وفقاً للمادة ٤ من قانون التجارة، مع مراعاة أن الإذن العام بالتجار لا يكفي لصحة دخول القاصر كشريك متضامن في شركة تضامن أو توصية، بل لابد في هذه الحالة من الحصول على إذن خاص، لأن هذه الصفة تجعل القاصر مسئولاً مطلقاً وتضامنية عن ديون الشركة، فضلاً عن اكتسابه صفة التاجر، وهي مخاطر أكثر جساماً من مجرد مباشرة التجارة التي لا تستلزم سوى الحصول على الإذن العام بالتجار.

هذا وصلاحيه الولي أو الوصي في استثمار أموال القاصر، لا تشمل الدخول بها كحصة في شركة أشخاص يكون فيها القاصر شريكاً متضامناً، لما سبق من أن ذلك يجعله يكتسب صفة التاجر وينطوي على مغامرة بكل أموال القاصر، ويحمّله مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة في أمواله الشخصية الأخرى، وبمفهوم المخالفة فإنه يجوز للولي والوصي إدخال أموال القاصر كحصة توصية في شركة توصية أو شركة مسؤولية محدودة أو لشراء أسهم في شركة مساهمة، لأن مثل هذه المشاركة لن ينتج عنها سوى مسؤولية محدودة عن ديون الشركة، ولن يترتب عليها اكتساب القاصر صفة التاجر.

ثالثاً: المحل:

محل الشركة هو النشاط الاستثماري الذي حدده لها الشركاء في العقد من أجل تحقيقه، بينما محل التزام كل شريك في الشركة هو الحصة التي يلتزم بتقديمها في رأس المال، ويجب أن يكون محل الشركة أو موضوع نشاطها موجوداً وممكناً أي قابلاً للتحقيق، وأن يكون معيناً أو قابلاً للتعين، وعادة ما يتم تحديد موضوع نشاط الشركة بطريقة مرنة تسمح بإضافة الأعمال التي تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بنشاط الشركة، وهذا ما يطلق عليه في العمل "شرط المظلة Clause Parapluie".^(١)

كما يجب أن يكون المحل مشروعاً غير مخالف للنظام العام أو الآداب أو للقانون، وإلا كان عقد الشركة باطلاً، ولو كان الغرض المدون في العقد مشروعاً، كشركة تتكون لممارسة أعمال الإيجار في المخدرات أو لبيع الأسلحة غير المرخصة أو لإدارة محل للدعارة، أو للإيجار في الرقيق، كما يجب أن يكون محل الشركة من الأموال المتقومة، أي التي تدخل في دائرة التعامل، فلا يجوز تأسيس شركة لتوريد رفات الموتى لكليات الطب أو طلابها.

رابعاً: السبب:

السبب إذا أخذ بوصفه الباعث الدافع إلى التعاقد، فإنه سيعتبر أمراً مشروعاً دائماً في كل العقود ومنها عقد الشركة، حيث سيتمثل في الرغبة في الحصول على الربح واقتسامه بين الشركاء، وسيختلط السبب بهذا المعنى بمحل العقد، ويعد كلاً منهما أمراً واحداً، وعلى هذا إذا انطوى عقد الشركة على استغلال غير مشروع، فإن العقد سيعتبر باطلاً لعدم مشروعية السبب والمحل كليهما.^(٢)

غير أن الواقع أن المحل والسبب لا يختلطان من الناحية القانونية، فالسبب هو رغبة الشركاء في الحصول على الربح، وهو دائماً أمر مشروع، بينما محل الشركة هو استثمار الأموال والقيام بالمشروع المالي المشترك، وبهذا المفهوم فإنه يجب أن يرد المحل على أموال مشروعة أو متقومة، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض بقولها: "إن محل عقد الشركة هو تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء بقصد استغلاله للحصول على ربح".^(٣)

المطلب الثاني

الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة

وفقاً للتعريف السابق لعقد الشركة والوارد في المادة ٥٠٥ مدني، يتعين لصحة عقد الشركة،

فضلاً عن الأركان العامة اللازمة لصحة جميع العقود، توافر مجموعة من الأركان والشروط التي تميز عقد الشركة عن سائر العقود، والتي تستند إلى طبيعة هذا العقد، والتي تقوم على تكوين مشروع مشترك يهدف إلى تحقيق الربح وقسمته بين كافة الشركاء، وتتمثل هذه الأركان في: تعدد الشركاء، وتقديم الحصص في رأس المال، واقتسام الأرباح والخسائر، ونية المشاركة.

الفرع الأول: تعدد الشركاء

تقتضي الفكرة التعاقدية للشركة أن يتعدد الشركاء في الشركة، وذلك بأن يوجد شريكان فأكثر تتلاقى إرادتهما وتتوافق على إبرام العقد، الذي يترتب عليه نشوء شخص قانوني جديد في صورة الشخصية المعنوية للشركة، فلا يجوز لشخص واحد- كأصل عام- أن ينشئ بمفرده شركة يخصص لها جزءاً من أمواله، بحيث تكون أمواله الأخرى في مأمن من رجوع دائي الشركة عليها، وركن تعدد الشركاء، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، لازم لقيام الشركة ولا استمرارها، فإن اجتمعت حصصها أو أسهمها في يد شريك واحد انقضت الشركة، ما لم تتخذ الإجراءات القانونية لتوفيق أوضاع الشركة وفقاً لأحكام القانون (على التفصيل الآتي بيانه).

وقد كان موقف المشرع المصري، بإقراره مبدأ تعدد الشركاء في تعريفه لعقد الشركة، متوافقاً مع المبدأ العام المقرر في القانون المصري، وهو مبدأ وحدة الذمة المالية، والذي قرره القانون المصري في المادة ٢٣٤ من القانون المدني، والتي تقضي بأن: "أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه"، وهو ما يترتب عليه أنه لا يجوز للشخص أن يقطع جزءاً من ذمته المالية، يكون بعيداً عن الضمان العام للدائنين، ويخصصه للقيام بمشروع معين، مع تحديد مسؤوليته عن هذا المشروع بما خصص له من أموال، لأن في ذلك تعارض مع مبدأ وحدة الذمة المالية.

غير أن هناك بعض التشريعات، كالتشريع الألماني الصادر في ١٩٨٠ والتشريع الفرنسي الصادر في ١٩٨٥، لا تأخذ بمبدأ وحدة الذمة المالية، وبالتالي فهي تجيز للشخص أن يقطع جزءاً من ذمته ويخصصها لاستغلال مشروع تجاري معين، يتخذ شكل ما يعرف بشركة الشخص الواحد One Man's Company، وهذا الاتجاه، وإن كان يمثل خروجاً على الفكرة التعاقدية للشركة، إلا أنه ينسجم تماماً مع فكرة النظام القانوني للشركة.

إقرار المشرع المصري لفكرة شركة الشخص الواحد:

في تطور تشريعي ملحوظ، أصدر المشرع التجاري المصري القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة

الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، والذي أقر بمقتضاه الأخذ بشركة الشخص الواحد، بمفهومها المعروف في القانونين الألماني والإنجليزي، واستبدل بمقتضى مادته الأولى مسمى "قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد" بمسمى "قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة" أينما ورد في القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر". كما نصت المادة الثانية من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ على أنه: "يستبدل بنص المادتين (١-فقرة أولى) ..، من مواد القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، النصان الآتيان: "مادة: (١-فقرة أولى): "تسري أحكام هذا القانون المرافق على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد".

هذا وتعتبر شركة الشخص الواحد، التي أقرها هذا القانون، استثناء على الأصل العام المتعلق بتعدد الشركاء، حيث تنص المادة (١٢٩ مكرر) من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أنه: "استثناء من حكم المادة (٥٠٥) من القانون المدني، يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري في حدود الأغراض الذي أنشئ من أجلها، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقاً لأحكام هذا الفصل، وتكون هذه الشركة محدودة المسؤولية...، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص، تطبق على شركة الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسؤولية المحدودة الواردة بهذا القانون".

ووفقاً للمادة (٤ مكرر) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، المضافة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨، فإن شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها، ولا يُسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها، وتتخذ الشركة اسماً خاصاً لها يستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها، ويجب أن يتبع اسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة، ويوضع على مركزها الرئيس وفروعها -إن وجدت- وفي جميع مكاتبها".^(١)

أما فيما عدا شركة الشخص الواحد، فلا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة، كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقي الشركاء الخاضعة

لأحكام هذا القانون، فإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون، مالم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب، أو يطلب من بقي من الشركاء خلال هذا الأجل تحويلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد، ويكون من بقي من الشركاء مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة".^(١)

هذا ومن جهة أخرى، فإنه ليس هناك حد أقصى لعدد الشركاء، وذلك باستثناء الشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث ينص قانون الشركات صراحة على ألا يزيد عدد الشركاء في هذا النوع من الشركات على خمسين شريكاً^(٢)، فإذا ما زاد العدد على هذا الحد لأي سبب، كبيع الحصة بالمرزاد الجبري أو الإرث أو الوصية، وجب على الشركاء أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكام القانون في هذا الشأن خلال سنة من تاريخ الزيادة، أو أن يتخذوا إجراءات تغيير شكل الشركة إلى شركة مساهمة، وفي حالة عدم قيام الشركاء بذلك يكون لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة بحكم من القضاء.^(٣)

الفرع الثاني: تقديم الحصص في رأس المال

تفترض فكرة الشركة أن يلتزم كل شريك بتقديم نصيب أو حصة لتكوين رأس مال الشركة، بوصف رأس المال هو الوسيلة لتحقيق غرض الشركة، فضلاً عن كونه يمثل الضمان العام لدائني الشركة، ولا يستلزم القانون أن تتساوي الحصص التي يقدمها كل شريك في رأس المال، غير أنه يجب تقدير قيمة هذا الحصص مقدماً، حتي يمكن معرفة نصيب مقدم الحصة في رأس المال، ومن ثم تحديد نصيبه في الأرباح والخسائر وفائض التصفية عند انقضاء الشركة وتصفيتها.

هذا، وتتنوع الحصص التي يمكن تقديمها في رأس مال الشركة وفقاً للمادة ٥٠٥ مدني إلى ثلاثة أنواع: الحصة النقدية، والحصة العينية، والحصة بالعمل.

أولاً: الحصة النقدية:

الوضع الغالب في تكوين رأس مال الشركات، هو أن يلتزم الشريك بتقديم مبلغ من النقود بحسب حصته في رأس المال، ويلتزم الشريك في هذه الحالة بدفع الحصة التي تعهد بها في المواعيد المتفق عليها، فإن لم يتفق على ميعاد معين التزم الشريك بدفع حصته فور إبرام العقد.

وتطبق على التزام الشريك بدفع حصته النقدية القواعد العامة لتنفيذ الالتزام الذي يكون محله دفع مبلغ نقدي، في حق الدائن، في اقتضاء دينه جبراً على المدين، فضلاً عن مطالبته بالفوائد التأخيرية والتعويض، إن كان له مقتض.

غير أن المشرع المصري قد أورد استثناءين على حكم القواعد العامة فيما يتعلق بدين الشريك بحصته في الشركة، أحدهما: ما تقضي به المادة ٥١٠ من القانون المدني من أن الفوائد تسري من وقت استحقاق الحصة دون الحاجة إلى المطالبة القضائية أو الإعذار، خلافاً لما تقضي به القواعد العامة في المادة ٢٢٦ مدني من عدم سريان الفوائد إلا من يوم المطالبة القضائية بها. والثاني: يتعلق بجواز مطالبة الشريك بالتعويض التكميلي ولو لم يكن سيئ النية، خلافاً للقاعدة العامة المقررة في المادة ٢٣١ مدني، التي تشترط على الدائن، حتى يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد، أن يثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.

والعلة في إقرار هذين الاستثناءين تعود إلى رغبة المشرع في حث الشركاء على المسارعة إلى الوفاء بحصصهم في رأس مال الشركة، نظراً لحاجة الشركة الماسة إلى رأس المال للاستمرار في نشاطها وتحقيق أغراضها، والتي قد يترتب على تراخي الشركاء في تقديمها اضطراب أعمال الشركة وعجزها عن مواصلة نشاطها.

ثانياً: الحصة العينية:

والحصة التي يقدمها الشريك في الشركة قد تكون عيناً، أي مالاً آخر غير النقود، عقاراً كان أو منقولاً، والعقار الذي يتعهد الشريك بتقديمه قد يكون أرضاً تقيم عليه الشركة مصنعها أو مخازنها، وقد يكون مبنى جاهزاً تتخذه مثلاً مقراً لإدارتها، والمنقول قد يكون مادياً كالآلات والبضائع، وقد يكون معنوياً كدين للشريك لدى الغير أو أوراق مالية أو تجارية أو براءة اختراع أو محل تجاري أو رسوم أو نماذج صناعية أو أيأ حقوق الملكية الأدبية والفنية.^(١)

وتقديم الحصة العينية إلى الشركة قد يكون على سبيل التملك، أي بقصد نقل ملكيتها للشركة، وقد يكون على سبيل الانتفاع مع بقاء ملك الرقبة للشريك مقدم الحصة.^(٢)

١- تقديم الحصة على سبيل نقل الملكية:

إذا قدمت الحصة على سبيل التملك، فإن العلاقة بين الشريك والشركة تخضع لقواعد عقد البيع، فيجب استيفاء إجراءات نقل الملكية والاحتجاج بها على الغير، فإذا كانت الحصة علامة تجارية أو براءة اختراع مثلاً، وجب مراعاة أحكام القانون فيما يتعلق بنقل ملكية العلامة التجارية أو براءة الاختراع، وإذا كانت حصة الشريك هي ملكية عقار أو أي حق عيني آخر، فإن هذا الشريك يكون ملزماً بمجرد عقد الشركة بنقل حق الملكية أو الحق العيني إلى الشركة، كما يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، ولا ينتقل هذا الحق إلا بالتسجيل، سواء فيما

بين الشريك والشركة أو بالنسبة إلى الغير، لأن عقد الشركة في هذه الحالة يكون ناقلاً للملكية، فيجب تسجيله حتى تنتقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة.^(١)

وأحكام البيع هي التي تسري في ضمان هلاك الحصة أو استحقاقها وما يظهر فيها من عيب أو نقص، فإذا هلكت الحصة بعد انتقال ملكيتها إلى الشركة وتسليمها لها، فإنها تهلك على الشركة ولا يلزم الشريك بتقديم حصة أخرى، ويبقى حق الشريك في قبض الأرباح قائماً كما لو كانت الحصة لم تهلك، أما إذا حدث الهلاك قبل تسليمها للشركة بسبب لا دخل للشركة فيه، كان الهلاك على الشريك، ووجب عليه تقديم حصة أخرى وإلا أفصى عن الشركة، وإذا استحققت الحصة للغير أو ظهر فيها عيب أو عجز، تطبق أحكام ضمان الاستحقاق أو العيوب الخفية أو العجز في المقدار، ويترتب على تقديم الحصة على سبيل التملك أنه إذا انقضت الشركة، فإن المال لا يعود إلى الشريك الذي قدمه، ولكن يوزع ثمنه على الشركاء جميعاً (المادة ١٥١١/١ مدني).

على أن تطبيق أحكام القواعد العامة، المتعلقة بالهلاك وضمان الاستحقاق والعيوب الخفية، في البيع، على حالة تقديم حصة للشركة على سبيل التملك، لا يعني أننا بصدد بيع حقيقي، ذلك لأن الشريك لا يقدم الحصة مقابل ثمن تدفعه الشركة، كما لا يتمتع مقدم الحصة، فيما يتعلق بالمبالغ التي تستحق له، بما يتمتع به البائع، كذلك لا يفيد من قواعد الغبن عندما تكون الحصة المقدمة عقاراً.

هذا وإذا كانت حصة الشريك العينية عبارة عن ديون له في ذمة الغير، فإن التزامه قبل الشركة لا ينقضي إلا إذا استوفيت هذه الديون، ويكون الشريك مسؤولاً قبل الشركة، فضلاً عن ذلك، بتعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول آجالها (المادة ٥١٣ مدني)، ومقتضى هذا الحكم أن الشريك يكون ضامناً ليسار مدينه في الحال والاستقبال، بحيث لا ينقضي التزامه للشركة إلا بعد استيفاء الدين، وذلك خلافاً للقواعد العامة في حوالة الحق التي تقصر ضمان المحيل على وجود الحق المحال به وقت الحوالة وفق (المادة ٣٠٨ مدني)، ويستهدف هذا الحكم من قبل المشرع ضمان حصول الشركة على رأس مالها ودرء ما قد يقع من غش إذا وفي الشريك حصته في صورة ديون له قبل الغير يستحيل استيفاؤها.

٢- تقديم الحصة على سبيل الانتفاع:

أما إذا كان تقديم الحصة لمجرد الانتفاع، فإن العلاقة بين الشريك والشركة تخضع لقواعد عقد الإيجار، ومن ثم لا تخرج الحصة من ملك صاحبها، ولا يكون للشركة سوى حق شخصي في الانتفاع بالعين المقدمة (المادة ٢/٥١١ مدني)، وعلى هذا تظل ملكية الحصة للشريك، ولا يجوز للشركة أن تتصرف فيها، وإذا هلك الحصة بسبب لا شأن للشركة فيه، تحمل الشريك تبعه الهلاك، اتباعاً للأصل الذي يقضي بأن الشيء يهلك على مالكه، حيث يجب على الشريك في هذه الحالة أن يقدم حصة أخرى، وإلا أخرج من الشركة.^(١)

كما يلتزم الشريك بالضمان، إذا ظهر بالحصة عيب أو نقص يحول دون انتفاع الشركة بها طوال مدة الشركة، فإن أخل بهذا الإلتزام جاز للشركة أن تقوم بذلك على نفقته، وإلا جاز لها أن تفسخ العقد قبله وتخرجه من الشركة، وبناء على بقاء العين المقدمة على ملك الشريك، فإنها لا تدخل في الضمان العام المقرر لدائني الشركة على أموالها، ومن ثم فلا يجوز للدائنين التنفيذ عليها، وتلتزم الشركة بردها بنهاية مدة الانتفاع المتفق عليها.^(٢)

وفي جميع الأحوال يعتبر تقديم الحصة في رأس مال الشركة أنه قد ورد على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك (م ٥٠٨ مدني).

ثالثاً: الحصة بالعمل:

يجوز أن تكون الحصة في الشركة، وفقاً للمادة ٥٠٥ مدني، عملاً يؤديه الشريك، على أن يكون هذا العمل على جانب من الأهمية والجدية بحيث تفيد منه الشركة بما يعود عليها بالنفع المادي، كالخبرة الفنية مثلاً، ومن هذا القبيل عمل المهندس أو المحاسب أو العمل في الإدارة أو المحاسبة، والعبرة في هذا الشأن ليس بطبيعة العمل فقط وإنما بأهميته لنشاط الشركة، فالعمل التافه الذي لا يعود على الشركة بالنفع أو الذي لا يساهم في نجاحها، لا يعد بمثابة حصة ولا يعد مقدمه شريكاً، بل أجيراً يحصل على أجره في صورة جزء من الأرباح.^(٣)

وإذا تمثلت الحصة في عمل يقدمه الشريك للشركة، تعين عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها، وأن يكرس مجهوده لخدمة الشركة، ويتمتع عليه أن يباشر نفس العمل الذي تعهد بتقديمه إلى الشركة لحسابه الخاص أو لحساب الغير، بالنظر إلى ما في ذلك من منافسة للشركة، وإذا قام بعمل من هذا النوع، كان كل كسب يحققه من واره حقاً خالصاً للشركة، ولذلك يفرض القانون على الشريك بالعمل في هذه الحالة أن يقدم حساباً للشركة عما يكون قد كسبه من ربح

من وراء العمل الذي قدمه حصة في الشركة، وذلك من وقت قيام الشركة، لكنه لا يكون ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع، إلا إذا وجد اتفاق بغير ذلك (المادة ٥١٢ مدني).^(١)

فإذا أخل الشريك بالعمل بتعهدده، بتقديم عمله حصة في الشركة، سواء تم ذلك بإرادته أو نتيجة لمرض ألم به أو عاهة أصابته فأقعدته عن أداء العمل بشكل مستمر، اعتبر متخلفاً عن أداء الحصة التي التزم بها، ومن ثم جاز للشركة أن تخرجه منها، ومن ثم فقد حقه في الحصول على نصيبه من الأرباح المتفق عليه.

وعند حل الشركة يسترد الشريك بالعمل حصته، أي يتحلل من التزامه بتكريس وقته وجهده لأعمال الشركة، ويسترد حقه العام في حرية العمل وفق إرادته.

ويجوز أن تتمثل حصة أحد الشركاء في الثقة المالية أو التجارية، وذلك لأن الثقة التجارية، كالإسم التجاري مثلاً، تكسب الشركة قيمة مالية، لأنها تمكنها من الحصول على الائتمان اللازم لنجاح نشاطها، فالتاجر المعروف بملاءته المالية وسمعته التجارية الحسنة إذا ورد اسمه في عنوان الشركة، يقدم لها خدمات جلييلة تكفي لاعتبارها حصة في شركة، ولكن صلاحية الثقة التجارية كحصة في الشركة، إن لم تقتزن بمجهود الشخص ونشاطه الذي يعود على الشركة بالنفع، تستوجب في رأي الفقه، أن يكون مقدم الحصة مسؤولاً عن ديون الشركة مسؤولية غير محدودة، ولذا فإن هذه الحصة يصح أن تقدم فقط من الشركاء المتضامنين في شركات التضامن أو التوصية، دون غيرها من الشركات.^(١)

غير أنه لا يجوز، كما تقضي المادة ٥٠٩ مدني، أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، فالنفوذ الذي يتمتع به رجل السياسة أو الموظف العمومي لا يمكن اعتباره حصة، لأن استغلال النفوذ يتعارض مع النظام العام والآداب، ويقع في بعض الأحوال تحت طائلة القانون الجنائي.

تقدير قيمة الحصص:

يتم في العادة تقويم الحصص بالاتفاق بين الشركاء عند إبرام عقد الشركة، ويتحدد نصيب الشريك في الأرباح على أساس هذا التقويم، وإذا جرى العرف على شيء في هذا الصدد وجب اتباعه، وقد أقام القانون قرينة مؤداها أن حصص الشركاء يفترض أنها متساوية القيمة، على أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس (م ٥٠٨ مدني). أما حصة العمل فنظراً لصعوبة تقويمها بالنقود، فإنه يجري تقويمها وفقاً للفائدة التي تعود على الشركة من وراءها وقت التعاقد، فإن لم

يتم تقويمها عند التعاقد، كان للشريك بالعمل أن يطلب فيما بعد تقويم عمله، ويكون هذا التقويم أساساً لتحديد حصته في أرباح الشركة وخسائرها.

رأس مال الشركة وأصولها "موجوداتها":

يتكون رأس مال الشركة لدى تأسيسها من مجموع الحصص النقدية والعينية، باعتبار أن هذه الحصص يمكن تقويمها بالنقد، وتكون وحدها محلاً للضمان العام لدائني الشركة، لقابليتها أن تكون محلاً للتنفيذ الجبري، ولهذا فإن الحصة بالعمل لا تدخل ضمن تكوين رأس مال الشركة، فالحصة بالعمل وفقاً لطبيعتها لا تقبل التقويم النقدي ولا تصلح أن تكون محلاً للتنفيذ الجبري أو لوفاء الديون بها، ولهذا فإن أصحابها لا يمنحون صكوكاً تمثل جزءاً من رأس المال، وإنما تقتصر حقوقهم على نصيب من الأرباح كما يلتزمون بنصيب من الخسائر، ولهذا فلا يجوز أن تكون حصص جميع الشركاء عبارة عن أعمالهم وخبراتهم، إذ يجب أن يشتمل رأس مال الشركة على مال مادي "نقدي أو عيني" يمكن التنفيذ عليه.

إلا أنه لا ينبغي تصور أن رأس مال الشركة هو ما يمثل وحده المركز المالي الحقيقي للشركة، لأنه إذا كان صحيحاً أنه عند إنشاء الشركة تكون الأصول مساوية للخصوم، وهو ما يعني مطابقة رأس المال لموجودات الشركة أو أصولها، فإن الشركة ما أن تبدأ في نشاطها واستثماراتها، وتكتسب الحقوق وتحمل بالالتزامات وتحقق الأرباح، وتمتلك الأموال الثابتة والمنقولة، حتى يتكون من مجموع هذه العناصر، شاملاً رأس المال، ما يسمى بموجودات "Actif Social" الشركة أو أصولها أو ذمتها، والذي يمثل المركز المالي الحقيقي للشركة، بوصفه الضمان العام الكلي للدائنين، لذلك يجب على الشركة أن تحتفظ بموجودات لا تقل قيمتها عن قيمة رأس المال الذي بدأت به حياتها، حيث يظل رأس المال يمثل الحد الأدنى من الضمان العام لدائني الشركة.

وبناء على ذلك، فإن رأس مال الشركة، بوصفه يمثل هذا الحد الأدنى للضمان العام للدائنين، يجب عدم المساس به طيلة حياة الشركة، وعليه فإنه يمتنع على الشركاء استرداد حصصهم أثناء قيام الشركة، كما أنه ما لم تحقق الشركة أرباحاً حقيقية تنعكس في صورة زيادة موجودات الشركة عن رأسمالها، فإنه لا يجوز توزيع أرباح على الشركاء، وإلا اعتبرت أرباحاً صورية مقتطعة من رأس مال الشركة، يكون للدائنين حق استردادها ولو كان الشركاء حسني النية، وهو ما يعبر عنه عادة بـ "مبدأ ثبات رأس مال الشركة"، حيث لا يسوغ القول بوجود أرباح يمكن توزيعها، ما لم يتضح زيادة موجودات الشركة عن مجموع رأسمالها.

غير أن مبدأ ثبات رأس المال لا يحول دون تعديل رأس مال الشركة بالزيادة أو بالتخفيض، متى اقتضت ظروفها المالية ذلك، ويلزم لصحة تعديل رأس المال اتباع الإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة، وإذا كان التعديل بالتخفيض، فإنه لا يحتج على الدائنين بتخفيض رأس المال إن كانت ديونهم نشأت قبل التخفيض.^(١)

ورأس مال الشركة، بهذا المعنى، يعتبر ديناً للشركاء على الشركة، لأنه يمثل قيمة حصصهم التي قدموها في رأس المال، ويتعين عند انقضاء الشركة وتصفياتها إعادة توزيعه عليهم كل بحسب حصته فيه، وذلك بعد سداد كافة ديون الشركة، ومن هنا نستطيع أن ندرك لماذا يدرج رأس مال الشركة دائماً في جانب الخصوم "Passif" من الميزانية.

ويمثل حساب الأرباح والخسائر في الميزانية الفرق بين الأصول والخصوم، فإذا أدرج حساب الأرباح والخسائر في جانب الخصوم، كان معنى ذلك ارتفاعاً في قيمة موجودات الشركة بالنسبة لقيمة موجوداتها الأصلية، أي أن الشركة قد حققت أرباحاً، أما إذا أدرج حساب الأرباح والخسائر في جانب الأصول من الميزانية، كان معنى ذلك انخفاضاً في قيمة موجودات الشركة أو إصابتها بخسائر.^(٢)

ويراعى في هذا الشأن ما تقضي به المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ بتعديل قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من أنه: "تستبدل عبارة (القوائم المالية) بعبارة (حساب الأرباح والخسائر) وبكلمة (الميزانية) أينما وردت في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليه".

الفرع الثالث: اقتسام الأرباح والخسائر

تقوم الشركة، على مشروع مالي يستهدف الربح، فالربح هو الهدف الذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه من وراء التزامهم بتقديم الحصص وتكوين الشركة، بما تفترضه من اتحاد الشركاء في المصالح ورغبتهم في قبول المخاطر المشتركة التي يمكن أن يسفر عنها الاستغلال التجاري للمشروع محل الشركة، ويعد اقتسام الأرباح والخسائر على هذا، من أهم الأركان التي يفترضها عقد الشركة، وهو ما نص عليه المشرع صراحة فيما جاء بالمادة ٥٠٥ من القانون المدني، التي تعرف الشركة بأنها: "عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي... لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة".

وبعد هدف تحقيق الربح، سعياً إلى اقتسامه بين الشركاء، هو العنصر الذي يميز الشركة عن غيرها من المؤسسات التي قد تتشابه مع الشركة من حيث الشكل الخارجي، بالنظر إلى تكوينها من عدة أشخاص يتجمعون بهدف تحقيق أغراض معينة، لا يعتبر تحقيق الربح هو الغرض الرئيس من وراءها، وذلك كالجمعيات، فالجمعية لا تهدف إلى تحقيق الربح، بل تسعى في العادة إلى تحقيق غايات وأهداف اجتماعية أو فكرية أو سياسية أو دينية، أو غيرها من الغايات الأخرى التي لا يكون الربح أو الكسب المادي من أولوياتها أو من أغراضها، وذلك كالجمعيات الخيرية أو العلمية أو التعاونية أو الأدبية...^(١)

هذا ويقصد بالربح، الذي يفرق بين الشركة والجمعية، كل كسب نقدي أو كسب مادي يضاف إلى ثروة الشركاء، فلا يكفي إذن للقول بوجود قصد تحقيق الربح لدى الشركة، مجرد السعي إلى تجنب الخسارة أو الاقتصاد في النفقات أو تحقيق بعض المزايا القابلة للتقويم بالنقد، وإنما يتعين أن يكون الكسب من طبيعة إيجابية تزيد في جانب أصول الشركة.^(٢)

وينبغي على هذا أنه يخرج من دائرة الشركات ويعد من قبيل الجمعيات، الجماعات التي تتألف من أجل الدفاع عن مصالح أعضائها أو تجنبهم الخسارة أو الحصول على السلع والحاجيات الضرورية بأقل من سعر السوق، أو مجرد الإرتقاء بالمستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرياضي لأعضائها، دون أن يكون من أغراضها السعي إلى تحقيق الأرباح وزيادة ثروة أعضائها.^(٣)

طريقة توزيع الأرباح والخسائر:

لا يكفي لتكوين الشركة أن يكون غرضها هو تحقيق الأرباح، بل لابد من اشتراك جميع الشركاء في توزيع الأرباح، وفي حال إذا منيت الشركة بخسائر فيلزم أيضاً أن يتحملها كافة الشركاء، وهذا ما أشارت إليه الفقرة الأخيرة من المادة ٥٠٥ من القانون المدني "... لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة".

والأصل أن يتم توزيع الأرباح والخسائر طبقاً لاتفاق الشركاء الوارد في عقد الشركة، ويتمتع الشركاء بالحرية في كيفية هذا التحديد، ولا يشترط في هذا الشأن أن تتساوى الأرباح التي يحصل عليها كل شريك أو الخسائر التي يتحملها، أو أن تتساوى نسبة الاشتراك في الأرباح مع نسبة الاشتراك في الخسارة، أو أن يكون نسبة كل شريك في الربح والخسارة بنسبة حصته في رأس المال، وإنما يتعين أن توزع الحقوق والالتزامات التي تتولد عن استثمار المشروع المشترك بحيث

يصيب كل من الشركاء جزءاً من نتائج الاستثمار، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى حرمان شريك من الربح أو تحصين شريك من الخسارة.

وتسمى هذه الشروط، التي تحرم شريكاً من الأرباح أو التي تعفيه من الخسارة، بشروط الأسد، كما تسمى الشركة التي تتضمن مثل هذه الشروط بشركة الأسد^(١)، وشروط الأسد باطلة لأنها تتنافى مع طبيعة عقد الشركة، ولأن مساهمة جميع الشركاء في الأرباح والخسائر ركن جوهري من أركان عقد الشركة، ولا يقتصر البطلان على الشروط وحدها، بل يمتد إلى عقد الشركة، حيث تعتبر الشركة ذاتها باطلة، لتعارضها مع ما اتجهت إليه إرادة الشركاء من الاشتراك في الأرباح والخسائر وفق قواعد معينة، فإذا أهدرت هذه القواعد فلا محل للإبقاء على الشركة، إذ لا شك في أن استمرارها وتوزيع الأرباح والخسائر بطريقة غير التي ارتضوها لما يتعارض مع إرادتهم، ولأن الشروط الأساسية في الشركة وحدة لا تتجزأ، وقد يكون الشريك لم يقبل التعاقد إلا بناء على الشرط الباطل^(٢).

وقد تقرر هذا البطلان صراحة بنص المادة ٥١٥ من مدني بأنه: "إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها كان عقد الشركة باطلاً"، ومع ذلك تجيز الفقرة الثانية من المادة ٥١٥ مدني - سالفه البيان - إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله، وواضح أن هذا الاستثناء غير حقيقي، لأن الشريك بالعمل الذي لا يتقاضى أجراً عند الخسارة، يكون قد تحمل منها ضياع وقته وجهده، فإن قدم، علاوة على عمله، حصة مالية، كان له نصيب من الأرباح والخسارة بمقدار ما قدمه^(٣).

هذا وفي حال لم يرد في عقد الشركة تحديد نصيب كل شريك فيها، فقد تضمنت المادة ٥١٤ مدني أحكاماً قانونية بشأن توزيع الأرباح والخسائر، ومؤدى هذه الأحكام أن يتحمل كل شريك من الربح والخسارة بنسبة حصته في رأس المال، فإذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشركاء في الربح، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً، وبالمثل إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب كل منهم في الخسارة^(٤).

الفرع الرابع: نية الاشتراك

بالإضافة إلى الأركان الثلاثة الخاصة بعقد الشركة وفقاً للعرض السابق، يجب توافر ركن رابع لم تتضمنه المادة ٥٠٥ مدني، التي حددت خصائص عقد الشركة، وهو نية المشاركة أو قصد الاشتراك Affictio Societatis، والذي لا يتصور وجود الشركة بدونه.

ويقصد بنية المشاركة، وفقاً للفقهاء التقليدي، اتجاه نية الشركاء إلى التعاون الإيجابي وعلى قدم المساواة لتحقيق غرض الشركة، ومن مظاهر هذا التعاون الإيجابي وفقاً لهذا الرأي، المشاركة في إدارة الشركة والإشراف على مسيرتها والرقابة على أعمالها وقبول المخاطر المشتركة^(١)، وهذا الركن واضح في شركات الأشخاص، حيث تسود الصيغة التعاقدية، ولكنه أقل وضوحاً في شركات الأموال، حيث يستأثر مجلس إدارتها بالنشاط الإيجابي من أجل تحقيق غرض الشركة وإدارة نشاطها التجاري، ويتقلص مفهوم المشاركة الإيجابية لدى الشركاء ليقصر على القيام بعملية مالية، وبصفة عامة فإن توفر هذه النية هي من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك إن أقام قضاءه على أسباب سائغة.^(٢)

ويأخذ الفقهاء الحديث على المفهوم السابق لقصد الاشتراك، أن التعاون الإيجابي يصعب تصوره بالنسبة للشركاء الذين لا يشاركون في الإدارة، وخاصة بالنسبة للشركاء المساهمين، كما أن فكرة المساواة بين الشركاء لا تتحقق في كثير من الفروض، فلا مساواة مثلاً بين الشركاء المتضامنين والشركاء الموصيين، لذا يذهب هذا الاتجاه الحديث في الفقه إلى حصر مفهوم قصد الاشتراك، في الرغبة في الاتحاد وتحمل المخاطر المشتركة، فالرغبة في الاتحاد تفترض التنظيم الجماعي وتوازي المصالح، لكنها لا تقتضي بالضرورة التعاون الإيجابي على قدم المساواة بين الشركاء، وإن ظل محتفظاً بمفهوم المساواة في المراكز القانونية بين الشركاء، فلا يكون بينهم تابع ومتبوع، ولا عامل ورب عمل، ولا يعمل أحدهم لحساب الآخر.^(٣)

وتظهر أهمية ركن قصد الاشتراك، بالمفهوم السابق، في أنه يفرق بين الشركة، وبين صور من الاشتراك ذي المفهوم الإرادي، كالشروع الاختياري، وعقد القرض أو عقد العمل مع الاشتراك في الأرباح، حيث تنتفي في هذه الصور من الاشتراك فكرة العمل الإيجابي على قدم المساواة أو الرغبة في الاتحاد من أجل تحقيق الغرض من المشروع، كما تحتفي فكرة تحمل المخاطر المشتركة.^(٤)

المطلب الثالث

الركن الشكلي لعقد الشركة

لا ينشأ عقد الشركة صحيحاً بمجرد توافر الأركان الموضوعية العامة، أو الأركان الخاصة بعقد الشركة فقط، حيث اشترط القانون توافر الركن الشكلي والمتمثل في الكتابة والاشهار.

أولاً: كتابة العقد:

تعتبر كتابة عقد الشركة ركناً لازماً لانعقاد العقد وليس مجرد أداة لإثباته، وهذا ما تنص عليه صراحة المادة ٥٠٧ مدني بقولها: "يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً"، ويسري البطلان كذلك على كل تعديل يرد على العقد دون أن يستوفي الشكل الكتابي الذي اشترطه القانون في العقد ابتداءً^(١).

وتعتبر الكتابة شرطاً لازماً لانعقاد الشركات التجارية والمدنية على حد سواء، وذلك باستثناء شركة المحاصة التجارية، ذلك أن هذه الشركة لما كانت شركة مستترة لا وجود لها بالنسبة إلى الغير، فقد أعفاها المشرع من شرط الكتابة، حيث تنص المادة ٦٤ من تقنين التجارة القديم على أنه: "لا يلزم في شركات المحاصة التجارية اتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى"، أما شركات المحاصة المدنية فتسري عليها، وفقاً للفقهاء الغالب، قاعدة وجوب كتابة العقد، وإلا كان العقد باطلاً وفقاً لصريح النص المذكور.

بينما يرى جانب في الفقه نفيده، أن الكتابة لا تلزم لصحة عقد شركة المحاصة، تجارية كانت هذه الشركة أم مدنية، "وذلك استناداً على أن نص المادة ٥٠٧ من التقنين المدني، الذي يشترط كتابة عقد الشركة، ينبغي قصره على عقد الشركة الذي ينتج عنه شخص معنوي، فمثل هذا العقد يجب أن يكون مكتوباً وأن يكون مشهراً لإمكان الاحتجاج على الغير بالشخص المعنوي الذي ينشأ عنه، ولا شئ من ذلك فيما يتعلق بشركة المحاصة، سواء كانت تجارية أو مدنية، بحكم كونها شركة لا تكتسب الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الشركاء، ومن ثم فلا وجود لها أمام الغير"^(٢).

هذا وتعود الاعتبارات التي حدت بالمشرع إلى اشتراط الكتابة لانعقاد عقد الشركة، إلى حمل الشركاء على التفكير قبل الإقدام على تكوين شركة تكون عادة لمدة طويلة، وتترتب عليها في الغالب التزامات عديدة ومتشعبة ومعقدة، مما يستلزم إبرازها بوضوح بالصيغة المكتوبة، ويؤدي وجود السند الكتابي المحدد الشروط في هذه الحالة إلى الحد من المنازعات التي يمكن أن يثيرها

تعقد معاملات الشركة، مما لا يمكن معه الاطمئنان إلى ذاكرة المتعاقدين أو الشهود، فضلاً عن أن هذا العقد من شأنه أن ينشأ شخصاً معنوياً له وجوده الخاص وحياته القانونية المستقلة عن الشركاء، ولذلك يجب أن يكون لهذا الشخص دستوره المكتوب ليتمكن الغير من الاطلاع عليه، كما يبدو شرط الكتابة ضرورياً من الناحية العملية، نظراً لكون عقد الشركة واجب الشهر وفقاً للقانون، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان العقد مكتوباً.^(١)

والكتابة اللازمة كركن في عقد الشركة، قد تكون رسمية، كما يمكن أن تكون عرفية إذا كان مصدقاً على التوقيعات فيها، وفي هذا تقضي المادة ١٥ من قانون الشركات رقم ١٨٩ لسنة ١٩٨١ بأنه: "يكون العقد الابتدائي للشركة ونظامها أو عقد تأسيسها رسمياً أو مصدقاً على التوقيعات فيه، ويجب أن يتضمن بالنسبة إلى كل نوع من أنواع الشركات البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تحدد هذه اللائحة الإقرارات والشهادات التي ترفق بعقد الشركة، وكذلك أوضاع التصديق على التوقيعات لدى الجهة الإدارية المختصة".^(٢)

وعلى هذا فلم يرد في القانون ذكر للبيانات التي يجب أن يتضمنها عقد الشركة، إلا أنه يمكن الاسترشاد في تحديد هذه البيانات بالنصوص التي تعدد البيانات الواجب شهرها، وهي البيانات الجوهرية في عقد الشركة، والتي تشمل: نوع الشركة وغرضها ومدتها ورأس مالها، وبيانات الشركاء ومقدار حصة كل منهم، وعنوان الشركة أو اسمها ومركزها الرئيسي، ونسبة توزيع الأرباح والخسائر، واسم المدير الذي له حق التوقيع نيابة عن الشركة.

إثبات عقد الشركة:

إذا كانت الكتابة شرطاً لازماً لانعقاد الشركة ووجودها كشخص قانوني، فإنها تعد أيضاً شرطاً لازماً لاثباتها، لأن الإثبات مرتبط بالشكل^(٣)، بيد أنه تجب التفرقة، فيما يتعلق بإثبات عقد الشركة، وذلك فيما يتعلق بمركز الشركاء من جهة والعلاقة بين الشركة والغير من جهة أخرى. فبالنسبة للشركاء فيما بينهم، فالأصل أن الكتابة شرط لإثبات العقد فيما بينهم، إلا أن تخلف الكتابة لما كان يؤدي إلى بطلان عقد الشركة، وكان المقرر في هذا الشأن أن الشركة إذا باشرت أعمالها في الفترة السابقة على طلب الإبطال، فإن البطلان لا يتم بأثر رجعي، فإنه يجوز للشركاء إثبات الوجود الفعلي للشركة بكافة طرق الإثبات، وذلك بقصد تصفية العلاقات الناشئة فيما بينهم في الفترة السابقة على الحكم بالبطلان، وذلك باعتبار أن الشركة تقوم بين الشركاء في هذه الفترة كشركة فعلية - كما سيلي - حتى ولو لم يكن عقد الشركة مكتوباً.^(٤)

أما فيما يتعلق بعلاقة الشركة بالغير، فلا يجوز للشركاء إثبات وجود الشركة تجاه الغير إلا بالكتابة، في الوقت الذي يجوز فيه للغير أن يثبت وجود الشركة بكافة طرق الإثبات، بما فيها البينة والقرائن، لأن الشركة تعد بالنسبة إليه واقعة مادية.

ثانياً: الشهر:

لا يعتبر الشهر شرطاً لصحة عقد الشركة المدنية، وإنما هو فقط بمثابة شرط لنفاذها في مواجهة الغير، وذلك وفقاً لما يفهم من نص المادة ٥٠٦ من التقنين المدني التي تنص على أنه: "تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً، ولكن لا يحتج بهذه الشركة على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون" ومع ذلك يجوز للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها".

أما بالنسبة للشركات التجارية، فقد تطلب المشرع التجاري شهر عقودها التأسيسية وأنظمتها الأساسية وأي تعديل يرد عليها، باستثناء شركة المحاصة نظراً لعدم تمتعها بالشخصية القانونية المستقلة عن شخصية الشركاء، ويقع النشر وفقاً للأوضاع والشروط التي حددها القانون، وهي تختلف باختلاف شكل الشركة المطلوب نشر عقدها، الأمر الذي سنتناوله تفصيلاً في دراستنا لكل نوع من أنواع الشركات.

المطلب الرابع

الجزء المترتب على تخلف أركان عقد الشركة

"بطلان عقد الشركة"

البطلان هو الجزء الذي رتبته القانون على تخلف أحد أركان عقد الشركة الموضوعية أو الشكلية، سالف الذكر، ويختلف نوع البطلان تبعاً لطبيعة الركن المتخلف، فقد يكون هذا البطلان مطلقاً، وقد يكون نسبياً، وقد يكون بطلاناً من نوع خاص.

ويتربط على كل نوع من هذه الأنواع من البطلان آثار قد يخرج بعضها عن آثار البطلان في القواعد العامة، خاصة فيما يتعلق بالآثار الرجعي المترتب على الحكم بالبطلان، ذلك أن تطبيق آثار البطلان على إطلاقها، وخاصة فيما تؤدي إليه من زوال عقد الشركة وما يترتب عليه، بأثر رجعي، يؤدي إلى نتائج يصعب تطبيقها، بالنظر إلى ما تحدثه من اضطراب في المراكز القانونية ومن الإضرار بالغير، الأمر الذي دعا إلى أن يتبنى الفقه والقضاء ما يعرف بنظرية الشركة الفعلية أو الواقعية Société de fait، وذلك للحد من الآثار الرجعي للبطلان.

وعلى هذا، نعرض لما يترتب على تخلف أحد أركان عقد الشركة من آثار في فرعين، نخصص الأول منهما لحالات البطلان، ونتناول في الثاني نظرية الشركة الفعلية.

الفرع الأول: حالات البطلان

أولاً: البطلان المطلق:

يترتب البطلان المطلق لعقد الشركة إذا انعدم رضا أحد الشركاء أو انعدمت أهليته وقت التعاقد، وكذلك إذا كان محل عقد الشركة غير مشروع لمخالفته النظام العام أو الآداب، كما إذا تمثل نشاط الشركة في الاتجار في الجواهر المخدرة أو لإدارة محل للدعارة، كذلك يترتب البطلان المطلق في حالة تخلف أي من الأركان الخاصة لعقد الشركة، والبطلان المطلق في هذه الصور ونحوها يترتب ثبوت حق كل ذي مصلحة (الشركاء والغير على حد سواء) في التمسك به، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول هذا البطلان بالإجازة، وهو بطلان تسقط دعواه بمضي خمسة عشر عاماً من وقت التعاقد.^(١)

فإذا ما قضى بالبطلان قبل أن تبدأ الشركة ممارسة نشاطها، فلا إشكالية في الأمر، إذ يعتبر العقد كأن لم يكن ويعاد المتعاقدون إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، غير أن الصعوبة تثور في حال ما إذا قضى ببطلان عقد الشركة بعد أن يكون المتعاقدون قد شرعوا في تسليم حصصهم التي تعهدوا بتقديمها، فما مصير هذه الحصص، وهل يجوز استردادها؟

والراجح في هذا الشأن أن البطلان المطلق يترتب عليه حل الشركة وتصفيتها، حيث يتعين رد الحصص إلى الشركاء، وذلك حتى في الحالة التي يتأسس فيها البطلان على عدم مشروعية محل الشركة، حتى لا يثري المتعاقد الذي تسلم الحصص على حساب المتعاقدين الآخرين دون ما سبب يبرره، غير أن الشركاء إذا كانوا قد حصلوا على أرباح فلا يلتزمون بردها، كذلك ليس لهم مطالبة مدير الشركة بما قد وقع عليهم من خسائر في الفترة السابقة على الحكم بالبطلان، وإذا ما كانت ثم أرباح أو خسائر لم يتم توزيعها، فإنها لا تخضع لقواعد التوزيع الواردة في عقد الشركة، لأنه عقد باطل، وإنما يجري التوزيع وفقاً لأحكام القانون بحسب الحصص في رأس المال.^(٢)

كما أن الصعوبة تثور أيضاً حول ما إذا كان يمكن التمسك بالبطلان قبل الغير، في حالة عدم مشروعية محل الشركة، كشركة تعمل على ترويج أو بيع المخدرات أو لإدارة محل للدعارة، إذا كان حسن النية؟

ففي حين يرى البعض أنه يجوز التمسك بالبطلان المطلق قبل الغير حتى إذا كان حسن النية، استناداً إلى حق كل ذي مصلحة في هذا النوع من البطلان في التمسك به، بغض النظر عما إذا كان هذا الغير حسن النية أو سيئها، باعتبار أن الحكم بالبطلان مجرد عقد الشركة من جميع آثاره بالنسبة إلى الكافة، يرى البعض الآخر في الفقه، وهو ما نؤيده، أنه لا يجوز للشركاء أن يتمسكوا بهذا البطلان في مواجهة الغير للتوصل من التزام يطالبهم هذا الأخير به، ما دام أنه شخص حسن النية لا يعلم أنه يتعامل مع شركة غير مشروعة النشاط، وكان العقد الذي أبرمه مع هذه الشركة يقوم على سبب صحيح، كما لو كان العقد عبارة عن توريد مهمات لتأسيس مقر الشركة أو تقديم قرض لها، إذا أن العقد يقوم في هذه الحالة على سبب صحيح حتى وإن كان نشاط الشركة غير مشروع، بخلاف ما لو كان الغير سيئ النية، بأن كان يعلم عدم مشروعية سبب الشركة، فإنه يمكن التمسك بالبطلان تجاهه تطبيقاً للقواعد العامة، وهو أمر تقرره محكمة الموضوع، ولا معقب على قرارها في هذه الحالة، ما دام يستند إلى أسباب سائغة تبرره.^(١)

أما في حال تخلف أحد الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة، فإن البطلان المترتب في هذه الحالة لا يثير ثم صعوبة قانونية، فإذا تخلف ركن تقديم الحصص في رأس مال الشركة، فإن بطلان عقد الشركة سيكون راجعاً إلى استحالة قيام ذمة مالية مستقلة للشركة، فهذه الذمة قوامها رأس مال الشركة المكون من حصص الشركاء، أما إذا تخلف أحد الشركاء عن تقديم حصته في رأس المال، فتبطل الشركة بالنسبة له وتظل قائمة بالنسبة لبقية الشركاء، كذلك فإن انعدام عنصر نية المشاركة يترتب عليه عدم إمكانية تكييف هذه الشخصية المعنوية بأنها شركة من الشركات، لأن هذه النية هي التي تميز الشركة عن غيرها من الأشخاص المعنوية الأخرى كالجمعيات مثلاً.

ولكن إذا خلا عقد الشركة من ركن اشتراك المتعاقدين في اقتسام الأرباح والخسائر، بأن تضمن شرطاً من شروط الأسد، فإن بالبطلان يلحق العقد بزمته، وفقاً لصريح نص المادة ٥١٥ من التقنين المدني بأنه: "إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها كان عقد الشركة باطلاً"، ومن ثم يكون لكل ذي مصلحة أن يتمسك به، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

كما أن بطلان عقد الشركة عند تخلف ركن تعدد الشركاء، يرجع إلى فقدان العقد في هذه الحالة للمقومات التي تجعله قادراً على خلق شخص معنوي، يتمتع بكيان مستقل عن أشخاص المتعاقدين، ولتعارض ذلك مع مبدأ وحدة الذمة المالية الذي يأخذ به القانون المصري، بحسب الأصل.

غير أنه في حالة انهيار ركن تعدد الشركاء، فيما يتعلق بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، فإنه وفقاً للمادة (٨) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ (المعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨): "فيما عدا شركة الشخص الواحد، فلا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة، كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقي الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون ما لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب، أو يطلب من بقي من الشركاء خلال هذا الأجل تحويلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد، ويكون من بقي من الشركاء مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة".^(١)

وعلى هذا، فإنه بإقرار المشرع شركة الشخص الواحد بمقتضى القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨، بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، لا يقضى ببطلان عقد الشركة عند انهيار ركن تعدد الشركات، وذلك إذا بادر من بقي من الشركاء خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب، أو اتبعت إجراءات التحول إلى شركة من شخص واحد.

وفي هذا الشأن تنص المادة (١٢٩ مكرراً "٧") من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ - المشار إليه - على أنه: "يجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة في الحالة التي يقل عدد المؤسسين أو الشركاء عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، إذا لم توفق أوضاعها خلال المدة المحددة في المادة (٨) من هذا القانون، أن تتحول إلى شركة من شركات الشخص الواحد، ما لم تكن تزاوّل أحد الأنشطة المحظور على شركات الشخص الواحد مزاولتها طبقاً للمادة (١٢٩ مكرراً "٢") من هذا القانون".^(٢)

ولا يسري هذا الحكم إذا كان من بقي من الشركاء هو شركة من شركات الشخص الواحد".^(٣)

ثانياً: البطلان النسبي:

البطلان النسبي هو ذلك البطلان الذي لا يجوز التمسك به إلا لمن شرع لمصلحته، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وتصححه الإجازة الصريحة أي بإجازة العقد من قبل الشريك بعد بلوغ سن الرشد أو من وقت انكشاف العيب، أو الضمنية في حال تقاعس الشريك عن التمسك به خلال ثلاث سنوات من وقت انكشاف العيب أو زوال نقص الأهلية، وفي كل الأحوال يسقط حق التمسك بالبطلان بانقضاء خمسة عشر عاماً من وقت تمام العقد. وتعتبر الشركة باطلة بطلاناً نسبياً متى كان أحد الشركاء فيها ناقص الأهلية وقت العقد، أو اعتور رضاه عيب من عيوب الإرادة كغلط أو تدليس أو إكراه، فإذا حكم ببطلان الشركة بناء على طلب ناقص الأهلية أو صاحب الإرادة المعيبة، اقتصر أثر البطلان على هذا الشريك وحده دون باقي الشركاء، فتعتبر الشركة باطلة بالنسبة له منذ نشأتها، فتزول عنه صفة الشريك، ويسترد حصته كاملة، ولا يتحمل شيئاً من الخسائر ولا يحصل على نصيب من الأرباح.

وإذا كان الأصل أن البطلان النسبي يقتصر أثره على من شرع لمصلحته، إلا أن هذا البطلان يمتد مع ذلك إلى بقية الشركاء إذا ما تعلق الأمر بشركة من شركات الأشخاص، حيث يترتب على بطلان الشركة بالنسبة لأحد الشركاء وخروجه منها انحياز الاعتبار الشخصي الذي يقوم عليه هذا النوع من الشركات، ومن ثم انحياز الشركة بالنسبة لجميع الشركاء، غير أن البطلان في هذه الحالة يقتصر على المستقبل ولا يترد إلى الماضي، ومن ثم فإن الشركة تعتبر قائمة فعلاً في الفترة الواقعة بين إنشائها والحكم بإبطالها.

أما إذا كانت الشركة من شركات الأموال، وهي تلك الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي، فإنه لا يترتب على بطلان الشركة بالنسبة لأحد الشركاء وخروجه منها انحياز الشركة ذاتها، حيث يقتصر أثر البطلان على من شاب العيب رضاه أو كان ناقص الأهلية، ويقتصر الأمر على طرح أسهم هذا الشريك للاكتتاب لو قضي بالبطلان قبل إتمام تكوين الشركة، أو طرح هذه الأسهم للبيع إذا كانت الشركة قد تكونت بالفعل واكتسبت الشخصية المعنوية المستقلة.^(١)

ثالثاً: البطلان الخاص/ البطلان بسبب تخلف الأركان الشكلية:

قدمنا أنه يلزم أن يكون عقد الشركة مكتوباً، وأن تتخذ الإجراءات التي فرضها القانون لإشهاره، وفقاً للمادة ٥٠٧ من التقنين المدني، ويترتب على عدم إفراغ عقد الشركة في قالب

الكتابي بطلان عقد الشركة، وكذلك يبطل كل تعديل يدخل على العقد لا يفرغ في الشكل الكتابي المطلوب.

غير أن البطلان في هذه الحالة هو بطلان من نوع خاص، حيث لا تسري على هذا النوع من البطلان كافة أحكام البطلان المطلق، نظراً لأن المحكمة لا تستطيع الحكم به من تلقاء نفسها بل لابد من طلبه قضاء، كم أنه لا يعد من قبيل البطلان النسبي، لأن التمسك به جائز لكل ذي مصلحة في النطق به، سواء كان الشركاء أو الغير، فيجوز للشركاء أن يحتجون به في مواجهة بعضهم بعضاً، كما لو تمسك الشريك قبل شريكه بعدم كتابة عقد الشركة إذا ما طالبه بتقديم حصته في رأس المال.^(١)

فإذا ما قضي بالبطلان في هذه الحالة بناء على طلب أحد الشركاء، فلا ينتج البطلان أثره فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من تاريخ رفع الدعوى، فلا يتناول البطلان إلا مستقبل العقد، ومن ثم يتعين حل الشركة وتصفيتها، أما في الفترة ما بين إبرام عقد الشركة والحكم ببطلانها، فإن الشركة تعتبر صحيحة منتجة لآثارها باعتبارها شركة فعلية، ومن ثم فيتبع فيما يتعلق بتوزيع الأرباح والخسائر واقتسام موجودات الشركة، أحكام وشروط العقد.

يبد أنه لا يجوز لهؤلاء الشركاء أن يحتجون بهذا البطلان في مواجهة الغير (م ٢/٥٠٧ مدني)، لأن واجب الكتابة والشهر يقع على عاتق الشركاء، فإن هم قد أهملوا فلا يسوغ أن يفيدوا من إهمالهم، فإذا رفع دائن للشركة دعوى على الشركاء مطالباً بحق له على الشركة، فلا يجوز لهم دفع مطالبتهم بدعوى أن عقد الشركة غير مكتوب، كذلك لو طالب دائن الشركة باعتبار الشركة قائمة حتى يتمكن من التنفيذ على أموالها دون التعرض لخطر مزاحمة دائني الشركاء.^(٢)

بينما يجوز للغير الاحتجاج بالبطلان لتخلف الكتابة أو الشهر في مواجهة الشركة أو الشركاء، كما لو تمسك دائن أحد الشركاء ببطلان عقد الشركة لعدم كتابته أو لعدم شهره، ليمكن من التنفيذ بحقه على حصة الشريك، عندما يقضى ببطلان عقد الشركة وتعود الحصة إلى ذمته المالية، وإذا قضي بالبطلان بناء على طلب أحد من الغير، انسحب أثر البطلان إلى الماضي، هذا وإذا تمسك بعض الأغيار بالبطلان وتمسك البعض الآخر ببقاء الشركة، فالراجح فقهاً وقضائاً الحكم بالبطلان، لأنه هو الأصل، كما سيلي فيما يتعلق بآثار نظرية الشركة الفعلية.

الفرع الثاني: آثار البطلان ونظرية الشركة الفعلية

مفهوم الشركة الفعلية وأساسها:

الأصل أن الشركة لا تنشأ كشخصية معنوية مستقلة إلا عن عقد توافر له كل ما يتطلبه القانون من أركان موضوعية وشكلية، فإذا ما أبطل العقد لتخلف أي من هذه الأركان، وأياً كان نوع البطلان، فالفرض أن هذا العقد لا يعتبر أنه قد نشأ من الأصل، لأن البطلان الذي يلحق العقد يؤدي إلى انهياره من أساسه ومحو الآثار المترتبة عليه بأثر رجعي، بحيث يجب أن يعاد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، وفقاً لما تقتضي به القواعد العامة.

غير أن تطبيق هذه القواعد على عقد الشركة، وما يقتضيه من رد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، وإن كان ممكناً قبل مباشرة الشركة أعمالها، أو حتى بعد مباشرة الشخص المعنوي لأعماله طالما أن سبب البطلان لم يترك علاماته الواضحة على هذا الشخص المعنوي بحيث يتسنى للغير إدراك فساد أصله دون مشقة، فإنه يؤدي في الحالات الأخرى إلى نتائج غير عادلة أو غير مرغوب فيها من الناحية الاقتصادية، إذ يكون في أعمال الأثر الرجعي للبطلان في مثل هذه الحالات من الناحية العملية ما يعد تجاهلاً وإنكاراً لحقائق وجدت بالفعل في الفترة السابقة على الحكم بالبطلان.^(١)

إذ يترتب على ذلك تجاهل حقيقة وجود شخص معنوي من الناحية الواقعية، انخرط في معاملات مع الغير، فأصبح معها دائناً ومديناً وحصل على أرباح ومني بخسائر، ويؤدي الأثر الرجعي للبطلان في هذه الحالات إلى زعزعة المراكز القانونية المستقرة، وإهدار لحقوق الغير الذي تعامل مع هذا الشخص المعنوي، وهو يجهل ما يعتور العقد الذي أنشأه من أسباب البطلان التي تنخر في أساسه القانوني، وبعبارة أخرى فإن أعمال الأثر الرجعي للبطلان ينطوي على عدم مراعاة للمنطق السليم ومجافاة لقواعد العدالة.

ولتفادي هذه النتائج فقد استقر القضاء على أن آثار الحكم ببطلان عقد الشركة يجب أن يقتصر على المستقبل وحده ولا يمتد إلى الماضي، ولذا فيجب الاعتداد بنشاط الشركة السابق ووجوب تصفيته بغرض تحديد نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، بحيث تعتبر الشركة قائمة وموجودة وجوداً فعلياً واقعياً وليس وجوداً قانونياً أو شرعياً، فالاعتراف بوجود الشركة في هذه الحالات يتركز على الواقع وليس على القانون، ولذلك تسمى هذه الشركة بـ " الشركة الفعلية أو الواقعية. " Société de fait".

وقد استند القضاء في إقامة نظرية الشركة الفعلية على اعتبارات عملية، تتمثل في حماية الأوضاع الظاهرة، تحقيقاً لاستقرار التعامل، لأن الغير قد اطمأن إلى وجود الشركة وتعامل معها بوصفها شخصاً معنوياً، فمن غير المقبول بعد ذلك مباغتته بمحو حياة هذا الشخص، ومفاجئة هذا الغير ببطلان الشركة، لأسباب قد لا يعلمها أو يصعب عليه العلم بها.^(١)

وحاول القضاء إقامة النظرية على أسس قانونية، فاعتبر عقد الشركة من قبيل العقود الزمنية المستمرة التي تنفذ يوماً فيوماً، فإذا حكم بالبطلان تناول البطلان مستقبل العقد وحده فيتعين حل الشركة وتصفيته، ولكنه لا يتناول ماضي العقد، فوجود الشركة قبل البطلان حقيقة ملموسة، لا يمكن أن تمحوها نظرية الأثر الرجعي التي تقوم على محض افتراض، ومن ثم يتعين اعتبار البطلان وارداً على حياة الشركة في المستقبل دون أن يمتد إلى الماضي بحال.^(٢)

نطاق نظرية الشركة الفعلية:

يشترط بداهة لتطبيق نظرية الشركة الفعلية أن تكون الشركة قد باشرت أعمالها بالفعل قبل الحكم ببطلانها، فإن لم تكن الشركة قد زاولت نشاطها بعد، فإنه لا يتوفر لها كيان في الواقع، فلا ضرر في هذه الحالة من تطبيق الأثر الرجعي للبطلان.

ومن جهة أخرى فإن القضاء لم يطبق هذه النظرية في جميع الأحوال التي يحكم فيها ببطلان الشركة، فقد رأينا، لدى تعرضنا لدراسة أنواع البطلان، أن هناك حالات لا يجوز معها الاعتراف بوجود الشركة لا في نطاق القانون ولا في إطار الواقع، ويتعين معها إعمال القواعد العامة في البطلان كاملة ودون تحوير، بينما ظهر أن هناك حالات أخرى يمكن معها الاعتراف بوجود الشركة فعلاً لا قانوناً، بحيث يقتصر أثر البطلان على مستقبل الشركة ولا يمتد إلى ماضيها.

بعبارة أخرى يمكن الاهتمام في تحديد مجال انطباق نظرية الشركة الفعلية بطبيعة البطلان الذي لحق عقد الشركة، فإن كان البطلان مطلقاً لتعلق سببه بالنظام العام انهارت الشركة في الماضي والمستقبل على السواء، ومن ثم لا يكون هناك مجال لتطبيق أحكام الشركة الفعلية، أما إذا كان البطلان نسبياً، فيقتصر اختيار الشركة على المستقبل دون الماضي.^(٣)

وعلى هذا تعتبر الشركة فعلية، في الفترة بين تكوينها والحكم ببطلانها، في الحالات الآتية:

١- إذا كان البطلان مؤسساً على نقص أهلية أحد الشركاء، أو على عيب شاب رضاه، وكان من شأن هذا البطلان انحياز عقد الشركة بأكمله، كما هو الشأن في شركات الأشخاص، وذلك بالنسبة لبقية الشركاء، حيث تعتبر الشركة بالنسبة لهؤلاء شركة فعلية في الفترة بين تكوينها

والحكم ببطلانها، أما بالنسبة للشريك ناقص الأهلية أو الشريك الذي شاب العيب رضاه، فتعتبر الشركة كأن لم تكن وتطبق أحكام الأثر الرجعي للبطلان.

٢- إذا كان البطلان مؤسساً على تخلف كتابة عقد الشركة أو شهره: ذلك أنه يعتبر من قبيل الأخذ بنظرية الشركة الفعلية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٥٠٧ من التقنين المدني، من أن البطلان لعدم كتابة عقد الشركة لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له أثر بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان^(١)، حيث يتبع فيما يتعلق بتصفية الشركة وقسمة أموالها وتوزيع الأرباح والخسائر في هذه الحالة الشروط المتفق عليها في عقد الشركة، لأن العيب الذي شاب العقد لاحق في الحقيقة لاتفاق الشركاء الصحيح.

وبالمقابل فإنه لا محل للاعتراف بالوجود الفعلي للشركة، وفقاً للرأي الراجح فقهاً وقضاً، في الحالات الآتية:

١- بطلان الشركة بسبب عدم مشروعية المحل، لأن الاعتراف بوجود الشركة في الفترة السابقة على الحكم بالبطلان ينطوي على الاعتراف بالغرض غير المشروع الذي قامت عليه الشركة.

٢- بطلان الشركة لانعدام أهلية أو رضاء أحد الشركاء.

٣- إذا كان البطلان قد تأسس على عدم توافر الأركان الخاصة بعقد الشركة، مثل تخلف ركن تعدد الشركاء (فيما عدا شركات الشخص الواحد) أو تخلف ركن نية المشاركة أو تقديم الحصص في رأس المال، أو لانتواء الشركة على شرط من شروط الأسد.

النتائج المترتبة على الاعتراف بالشركة الفعلية:

يترتب على الاعتراف بوجود الشركة من الناحية الواقعية أو الفعلية في الفترة ما بين تكوين الشركة والحكم ببطلانها، مجموعة من الآثار سواء بالنسبة إلى الشركة أو الشركاء أو الغير:

أ- يتناول البطلان مستقبل الشركة، ويتعين حل الشركة وتصفيتها وفقاً للشروط التي وردت في عقد الشركة واتفق عليها الشركاء، ولما كانت الشركة تحتفظ بشخصيتها المعنوية خلال فترة التصفية، فيجوز شهر إفلاسها متى توقفت عن دفع ديونها، سواء نشأت هذه الديون قبل الحكم ببطلان الشركة أو أثناء عملية التصفية، ويترتب على الحكم بإفلاسها شهر إفلاس الشريك المتضامن^(١).

ب- تكتسب الشركة في الفترة السابقة على الحكم بالبطلان شخصيتها الاعتبارية المستقلة، ومن ثم يعتبر صحيحاً من الناحية القانونية كافة ما أجرته من عقود وتعهدات بما ترتبه من حقوق

والتزامات، سواء بالنسبة إلى الشركاء أو الغير الذي لم يطلب البطلان، ويستتبع حل الشركة وفسخها تصفية أموالها وقسمتها وفقاً لشروط وأحكام التوزيع الواردة في عقد الشركة.^(١)

ج- وبالنسبة إلى الغير، فإنه يكون له حق الخيار بين التمسك ببقاء الشركة في الماضي أو طلب بطلانها بأثر رجعي حسبما تقتضيه مصلحته، فقد تنشأ للغير مصلحة في التمسك ببطلان الشركة في الماضي، أي بأثر رجعي، كما لو تمسك دائن أحد الشركاء ببطلان عقد الشركة ليمكن من التنفيذ بحقه على حصة الشريك، وعلى العكس فقد تتمثل مصلحة الغير في التمسك ببقاء الشركة في الماضي، كدائن الشركة الذي يتمسك باعتبار الشركة قائمة حتى يتمكن من التنفيذ على أموالها دون التعرض لخطر مزاحمة دائني الشركاء، أما إذا تمسك بعض الأغيار بالبطلان وتمسك البعض الآخر ببقاء الشركة، فالراجح فقهاً وقضائياً الحكم بالبطلان، لأنه هو الأصل في حالة عدم استيفاء الأوضاع القانونية.^(٢)

د- يجوز إثبات الشركة الفعلية بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن، بحيث يجوز لمحكمة الموضوع استخلاص قيامها من الظروف ما دامت قد باشرت بعض أعمالها فعلاً.^(٣)

المبحث الثالث

الشخصية المعنوية للشركات

تبلورت فكرة الشخصية المعنوية تحت تأثير الحاجة إلى كيان قانوني تتجمع من خلاله جهود فريق من الأشخاص، أو تخصص له مجموعة من الأموال لتحقيق أغراض مشتركة، والأصل أن الشخص في لغة الفلسفة والأخلاق هو الإنسان، أما الشخص في نظر القانون فهو كائن صالح لأن تكون له حقوق وعليه التزامات، ويسري هذا المفهوم على الشخص الطبيعي، كما يشمل جماعة من الأفراد أو مجموعة من الأموال تخصص لتحقيق أهداف مشتركة، فيسبغ عليها القانون الشخصية الاعتبارية أو المعنوية "Personne Moral" وعليه فإن الشخص الاعتباري أو المعنوي ليس سوى "جماعة من الأشخاص يضمهم تكوين يرمي إلى تحقيق غرض معين، أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غرض معين، خلع عليها القانون الشخصية، فتكون شخصاً مستقلاً ومتميزاً عن الأشخاص الذين يساهمون في نشاطها أو يفيدون منها، كالدولة والجمعية والشركة والمؤسسة".^(٤)

هذا وسوف لن نتطرق في إطار هذه الدراسة للنظريات التي ساقها الفقه لتحديد طبيعة الشخصية المعنوية، وهل هي حقيقة (Realite) أم خيال (Fiction)، إذ أن ذلك يتجاوز موضوع

دراستنا، التي تعنى بالأساس بالشخصية المعنوية للشركات، والذي يهمننا في هذه الدراسة هو فقط كيفية اكتساب الشركة الشخصية المعنوية والنتائج المترتبة على اكتساب الشركة لهذه الشخصية.^(١)

ويعترف المشرع المصري، كقاعدة عامة، بالشخصية المعنوية لجميع الشركات، مدنية كانت أو تجارية، وذلك في المادة ٤/٥٢ من القانون المدني، كما تقضي المادة ١/٥٠٦ مدني كذلك بأن الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصاً معنوياً مستقلاً وقائماً بذاته عن أشخاص الشركاء المكونين لها، ولا يستثنى من الأصل السابق سوى شركة المحاصة، فلا تكتسب الشخصية الاعتبارية، بالنظر إلى كونها شركة مستترة لا وجود لها بالنسبة إلى الغير، وإنما تقتصر آثارها على أطرافها فحسب.^(٢)

وسوف نبحث على التوالي في بداية اكتساب الشركة الشخصية المعنوية ونهايتها، ثم النتائج المترتبة على اكتساب الشركة لهذه الشخصية.

المطلب الأول

بداية اكتساب الشركة الشخصية المعنوية ونهايتها

الأصل أن الشركة تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها، باستيفاء الإجراءات التي نص عليها القانون لتأسيسها (المادة ٥٠٧ مدني)، ويسري ذلك على شركات الأشخاص التي تكتسب شخصيتها المعنوية المستقلة منذ تأسيسها والتوقيع على العقد، دون التوقف على استيفاء إجراءات الشهر، أما فيما يتعلق بشركات الأموال، فإن اكتسابها الشخصية المعنوية لا يتم بمجرد كتابة العقد أو النظام الأساسي للشركة، أو بمجرد استيفاء إجراءات التأسيس التي نص عليها القانون، حيث ربط القانون اكتسابها تلك الشخصية على واقعة الشهر، وفي ذلك تنص المادة ١٧ من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أنه: "تشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها في السجل التجاري".^(٣)

وقد ورد استثناء على مدة الخمسة عشر يوماً يقضي بأنه: "ما لم تقرر الجهة الإدارية المختصة اكتساب الشخصية الاعتبارية قبل انقضاء هذه المدة، واستثناءً مما تقدم لا تكتسب الشركات والمنشآت التي تزاوّل نشاطها في شبه جزيرة سيناء الشخصية الاعتبارية إلا بقرار من رئيس الهيئة

العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لا يتم إجراء أي تعديل في نظامها الأساسي أو تداول أسهم رأس مالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة المشار إليها^(١).

وإذا اعترضت الجهة الإدارية المختصة -الإدارة العامة للشركات- على قيام الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة، للأسباب المحددة في المادة ١٨ المعدلة، نزول الشخصية الاعتبارية للشركة من تاريخ صدور قرار شطبها في السجل التجاري^(٢). وفي كل الأحوال لا يجوز الاحتجاج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر، فإذا أهملت الشركاء القيام بإجراءات الشهر، جاز للغير الذي علم بوجودها بأي طريق التمسك بالآثار المترتبة على الشخصية الاعتبارية للشركة ولو لم تتم إجراءات الشهر (م ٥٠٦ مدني)، ما يدل على أن الشهر مقصود به حماية مصلحة الغير.

والأصل أن الشخصية المعنوية تظل سارية طوال فترة وجود الشركة، وتظل محتفظة بها إلى أن يتم حلها وانقضاؤها، كما تظل الشركة محتفظة بهذه الشخصية بعد انقضاء الشركة وأثناء فترة التصفية، بالقدر اللازم للتصفية، وذلك من تاريخ انقضاء الشركة لحين توزيع أموالها على الشركاء، وعلى ذلك تنص صراحة المادة ١٣٨ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بقولها: "تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية"، وعلى ذلك أيضاً نصت المادة ٥٣٣ من التقنين المدني بأن: "شخصية الشركة تبقى بالقدر اللازم للتصفية إلى أن تنتهي هذه التصفية".

ويعتبر تبرير القاعدة السابقة في منتهى الوضوح، ذلك أن إجراءات التصفية تسلم العديد من التصرفات باسم الشركة، ولا يتصور ذلك إلا إذا تمتعت هذه الأخيرة بالشخصية المعنوية، كما أن الإبقاء على شخصية الشركة أثناء فترة التصفية يحول دون أيلولة أموالها -بمجرد الانقضاء- لملكية الشركاء على الشيوع، وبالتالي لمزاحمة دائني الشركاء الشخصيين لدائني الشركة في التنفيذ على هذه الأموال، فبقاء الشركة وحده هو الذي يتفق واحترام الحقوق المكتسبة لدائني الشركة على رأس مال الشركة، بوصفه الضمان العام الذي اعتمدوا عليه عند التعامل معها^(٣).

وعلى هذا يكون للشركة خلال هذه الفترة أهلية في حدود الغرض الذي تكونت من أجله، فيكون لها أن تستوفي حقوقها وأن توفي ديونها لدى الغير، وأن تقوم بكافة الأعمال اللازمة لتصفية نشاطها وقسمة أموالها بين الشركاء بواسطة من يمثلها، غير أن هذه الشخصية المعنوية المعترف بها للشركة في فترة التصفية يجب أن تقدر بقدر الضرورة التي أقرت من أجلها، وتتحدد

بحدود حاجات التصفية، ذلك أن أهلية الشركة تتضاءل في هذه الفترة إلى القدر اللازم للتصفية، بوصفها شخصاً موصىراً إلى العدم، وعلى ذلك فلا يجوز البدء بأعمال جديدة لحساب الشركة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة قامت بها الشركة قبل حلها.^(١)

المطلب الثاني

النتائج المترتبة على اكتساب الشركة الشخصية المعنوية

يترتب على الاعتراف للشركة بالشخصية المعنوية تمتعها بكافة الحقوق وتحملها كافة الالتزامات، شأنها في ذلك شأن الشخص الطبيعي، ولا يحدها في ذلك إلا ما كان من الحقوق أو الالتزامات ملازماً لطبيعة الإنسان، وعلى ذلك جرى نص المادة ٥٣ مدني بقولها: "الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون"، ومن ثم فلا يتصور أن يقوم الشخص الاعتباري بالالتزامات والحقوق المرتبطة بطبيعة الإنسان، كحقوق الأسرة من الزواج والمعايشة الجنسية بين الأزواج والسلطة الأبوية وحق النسب، كذلك الالتزام بالنفقة أو بأداء الخدمة العسكرية، وغيرها من الواجبات المرتبطة بالكيان الجسدي للإنسان.

بينما يترتب على اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية تمتعها بذمة مالية مستقلة، وأهلية في حدود الغرض الذي أنشأت من أجله، واسم وموطن وممثل يعبر عن إرادتها، وجنسية تربطها بدولة معينة، وسوف نتحدث عن هذه النتائج بشئ من التفصيل فيما يلي:

أولاً: ذمة الشركة:

للشركة، كشخصية اعتبارية مستقلة، ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن الذمم المالية الشركاء، تتكون من مجموع ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات مالية، وبغير هذا الفصل بين ذمة الشركة وذمم الشركاء، لا يمكن للشركة أن تحقق أغراضها التي وجدت من أجلها، فلا تعتبر أموال الشركة ملكاً شائعاً بين الشركاء، بل تعتبر هذه الأموال ملكاً للشركة.^(٢)

ويترتب على اكتساب الشركة تلك الذمة المالية المستقلة النتائج الآتية:

١- انتقال ملكية الحصص المقدمة من الشركاء من ذممهم المالية إلى الذمة المالية للشركة: ولا يكون للشركاء بعد ذلك إلا مجرد نصيب في الأرباح الإحتمالية أو في الأموال التي تبقى بعد تصفية الشركة، وهذا النصيب لا يعدو أن يكون ديناً للشريك في ذمة الشركة، وحق الشريك هذا قبل الشركة يعتبر ككل دين من طبيعة منقولة، ولو كانت الحصة التي قدمها الشريك عقاراً،

وعليه فلو أوصى شخص بجميع منقولاته لشخص آخر دخلت حصص الموصي في الشركات ضمن الوصية.^(١)

٢- تعتبر ذمة الشركة ضماناً عاماً لدائني الشركة وحدهم دون الدائنين الشخصيين للشركاء: فلا يجوز لدائني الشريك الحجز على أموال الشركة لاقتضاء حقه ولا الحجز على ما يخص الشريك في رأس المال، ويقتصر حقه فقط على الحجز تحت يد الشركة على نصيب ذلك الشريك في الأرباح بطريق حجز ما للمدين لدى الغير، فإذا انحلت الشركة وتمت تصفية أموالها فتزول عندئذ شخصيتها المعنوية، ومن ثم يكون لدائني الشريك الحجز على نصيب ذلك الشريك في فائض التصفية، وإذا كانت حصة الشريك ممثلة في أسهم، فإنه يجوز لدائني الشريك، فضلاً عما سبق، أن يطالبوا ببيع هذه الأسهم ليتقاضوا حقوقهم من حصيلة البيع.

ويظل الفصل بين الذمة المالية للشريك والذمة المالية للشركة قائماً حتى في حالة الشركات التي تكون ديونها مضمونة بأموال الشركة والأموال الشخصية للشركاء، كما هو الشأن بالنسبة للشركاء المتضامنين (في شركات التضامن والتوصية)، ذلك أن المسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء في هذه الحالات عن ديون الشركة، ليس من شأنه اختلاط الذمة المالية لهؤلاء الشركاء بذمة الشركة، أو الانتقاص من شخصيتها الاعتبارية المستقلة عنهم، وإنما فقط تعزيز وتقوية مركز الشركة المدين بتقديم أموالهم الشخصية كضمان إضافي لأموال الشركة ضماناً لحقوق دائنيها.^(٢)

٣- امتناع المقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء: فلا يجوز لأحد دائني الشركة أن يمتنع عن الوفاء بدين عليه للشركة بحجة أنه أصبح دائناً لأحد الشركاء، استناداً إلى قيام حقه في التمسك بالمقاصة بين الدينين، كما لا يجوز لمدين أحد الشركاء أن يمتنع عن الوفاء له بحجة أنه أصبح دائناً للشركة، وذلك نتيجة لاستقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء.

٤- إفلاس الشركة لا يستتبع إفلاس الشركاء كقاعدة، كما لا يؤدي إفلاس الشريك إلى إفلاس الشركة، ومع ذلك فإن إفلاس الشركة يؤدي إلى إفلاس الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية، وذلك نظراً لمسؤوليتهم التضامنية والمطلقة عن ديون الشركة، وعندئذ تتعدد التفليسات، فتكون هناك تفليسة خاصة بالشركة وتفليسة خاصة بكل شريك.

ثانياً: أهلية الشركة:

يترتب على الشخصية المعنوية للشركة أن يكون لها أهلية قانونية كاملة بالنسبة إلى الحقوق المالية، وذلك في حدود الغرض الذي وجدت من أجله في سند إنشائها ووفقاً لما يقرره القانون،

فأهلية الشركة كشخص معنوي محدودة بالغرض الذي قامت من أجله وفقاً لما تضمنه عقد الشركة أو نظامها الأساسي، فإذا نص عقد الشركة أو نظامها على قيامها بنوع معين من النشاط، فلا يجوز لها مباشرة نوع آخر إلا بعد تعديل العقد أو النظام، ويكون للشركة في حدود هذا الغرض أن تقوم بكافة الأعمال القانونية التي يستوجبها تحقيقه.

ويلزم من الاعتراف للشركة بالأهلية، أن تكون مسئولة مدنياً عن تعويض الأضرار التي تقع من مديريها وموظفيها والأشياء التي تحت حراستها، كما تعتبر مسئولة بداهة عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية.

أما فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية فقد استقر الفقه والقضاء على عدم قيامها بالنسبة للشركة والأشخاص المعنوية بوجه عام، وذلك لأنه، فضلاً عن عدم تصور قيام الشركة بالفعل المكون للجريمة بنفسها أو توقيع العقوبة البدنية، كالسجن والحبس، على الشركة كشخص معنوي، فإن مبدأ شخصية العقوبة، يوجب أنها لا توقع إلا على الشخص الذي ارتكبها، ومع ذلك فإن الجرائم المعاقب عليها بغرامات مالية، كجرائم التهرب الجمركي أو التهرب من الضرائب مثلاً، يجوز مساءلة الشركة عنها، لأن الغرامة لا تحمل معنى العقوبة البحتة، بل بمثابة التعويض المدني المستحق للخزانة العامة للدولة.^(١)

ثالثاً: تمثيل الشركة:

يلزم أن يكون للشركة، كشخص معنوي لا يستطيع أن يتعامل بنفسه، أشخاص طبيعيون يعبرون عن إرادتها ويديرون ذمتها المالية ويمثلونها أمام الغير، ويمثل الشركة مديروها أو مجلس إدارتها.^(٢)

ومدير الشركة لا يعتبر، كما يرى الفقه الراجح، وكياً عن الشركة، نظراً لاختلاف مركزه عن مركز الوكيل كما تنظمه القواعد العامة في الوكالة، لأن الوكالة تفترض وجود إرادتين، إرادة الموكل وإرادة الوكيل، وإذا توفرت إرادة الوكيل في حالة مدير الشركة، فليس للشركة إرادة في ذاتها، كما أنها لا تستطيع العمل بنفسها كما هو شأن الأصيل في عقود الوكالة بين الأشخاص الطبيعية.

كما أن مدير الشركة لا يعتبر وكياً عن الشركاء، فالمدير يعين ويعزل بقرار أغلبية الشركاء وليس بإجماعهم، ولو كان وكياً لما كانت له صفة في تمثيل من لم يوافق عليه، فضلاً عن أن مدير الشركة يملك سلطات خاصة حددها القانون تتجاوز بكثير ما يملكه الشركاء أنفسهم، وهو أمر

لا يستقيم مع تكيف العلاقة بأنها وكالة، مع ما تقتضيه من ألا يكون للوكيل من السلطات ما يتعدى سلطات موكله.

ولذا فالمقرر فقهاً هو اعتبار مديري الشركة بمثابة ممثلين قانونيين عنها وأعضاء في جسم الشركة وعنصراً من عناصرها التي تتكون منها، حيث لا يتصور أن يكون للشخص المعنوي وجود بدون أجهزة معينة تحقق نشاطه في الحياة القانونية، وبحيث تعتبر جزءاً لا يتجزأ عنه، يستخدمه الشخص المعنوي في تحقيق أغراضه كما يستخدم الإنسان أعضائه.^(١)

رابعاً: اسم الشركة أو عنوانها:

يجب أن يكون للشركة اسم خاص بها يميزها عن غيرها من الشركات ويتم التوقيع به على سائر معاملاتها والتزاماتها، ويختلف اسم الشركة باختلاف شكل الشركة، ففي شركات التضامن وشركات التوصية بنوعيتها، يسمى الاسم "عنوان الشركة-Raison sociale"، وهو يتكون من أسماء الشركاء المتضامنين، بالنظر إلى مسئوليتهم غير المحدودة عن ديون الشركة، وغالباً ما يقتصر عنوان الشركة في مثل هذه الشركات على اسم واحد من الشركاء المتضامنين مع إضافة عبارة "وشركاه"، أما في شركات المساهمة فليس للشركة سوى اسم تجاري unedenominaton "commercial" مستمد كقاعدة عامة من الغرض الذي قامت الشركة على تحقيقه.

خامساً: موطن الشركة:

وللشركة موطن خاص بها، ترفع عليها فيه الدعاوى وتعلن فيه بالأوراق القضائية، وهو المكان الذي يتحدد على ضوءه جنسية الشركة، وموطن الشركة هو عادة المكان الذي يوجد فيه نشاط الشركة الإداري والقانوني أو مركز إدارتها الرئيسي، وهو بالنسبة إلى شركات الأشخاص المكان الذي يباشر فيه مدير الشركة عمله، وبالنسبة لشركات الأموال المكان الذي يجتمع فيه مجلس الإدارة والجمعية العمومية، حتى ولو كان مركز الاستغلال في مكان آخر، وللشركاء حرية تحديد مركز الشركة في عقدها التأسيسي، غير أن العبرة في تحديد موطن الشركة هو بمركزها الحقيقي لا بالمركز الصوري، إذ المقرر أن المحاكم ليست مجبرة على التحديد الوارد في عقد الشركة، إذا ما تبين أن الإدارة الفعلية توجد في مكان غير المكان المحدد في العقد.^(٢)

هذا والعبرة دائماً في تحديد موطن الشركة هو بمركزها الرئيسي دون اعتداد بالمراكز الفرعية، ومع ذلك فقد أجاز القانون، تيسيراً للتعامل، اعتبار المكان الذي يوجد فيه كل فرع موطناً خاصاً بالأعمال المتعلقة به، ومن ثم يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع

الشركة، وذلك في المسائل المتصلة به (م ٢/٥٢ مرافعات)، كذلك فإن موطن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر، يكون هو المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية، فيما يتعلق بتطبيق القانون الداخلي (م ٢/٥٣ مدني).^(١)

سادساً: جنسية الشركة:

يكون للشركة جنسية خاصة لا ترتبط بجنسية الأشخاص الطبيعيين المكونين لها، ويرتبط منح هذه الجنسية للشركة بذات الرابط الذي يمنح بمقتضاه الشخص الطبيعي هذه الجنسية، وهو وجود نوع من التبعية بين الشركة ودولة معينة، ولا توجد شركة "عديمة الجنسية" أي بدون جنسية، إذ لو فقدت الشركة جنسيتها دون أن تكتسب جنسية أخرى تختم حلها وتصفياتها، كما أنه لا توجد شركة "مزدوجة أو متعددة الجنسيات" أي تحمل أكثر من جنسية، وإذا كانت هناك شركات توصف بـ "الدولية أو متعددة الجنسيات" كشركات الطيران والملاحة البحرية والنقل والبنوك والتأمين، فإن هذا الوصف يصدق فقط على نشاط هذه الشركات، من حيث امتداده إلى أقاليم أكثر من دولة، وليس على جنسية هذه الشركات.

ولتحديد جنسية الشركة أهمية كبيرة تظهر من نواح عدة: منها معرفة النظام القانوني الذي تخضع له الشركة من حيث أحكام تكوينها وإدارتها وحلها وتصفياتها، ومنها معرفة الدولة التي تتمتع الشركة بحمايتها في المجال الدولي، كما أن الدولة قد تخصص شركاتها الوطنية بإعفاءات ضريبية وحقوق الحصول على بعض الإعانات المالية، كذلك قد تقصر الدولة حق ممارسة بعض الأنشطة التجارية على الشركات الوطنية.^(٢)

وتختلف تشريعات الدول في اعتماد ضابط معين لمنح الشركة جنسيتها، وذلك وفقاً لما تراه الدولة محققاً لمصالحها الوطنية، وذلك ما بين معيار مكان تأسيس الشركة، أو موطنها أو مكان الاستغلال الرئيسي للشركة، أو معيار جنسية الشركاء أو جنسية القائمين على إدارتها.

غير أن المعيار السائد في هذا الشأن هو الذي يعتمد مركز الإدارة، حيث تمنح الدولة جنسيتها لكل شركة تتخذ من هذه الدولة مركزاً لإدارتها، باعتبار هذا المركز هو العقل المحرك للشركة وفيه يتركز نشاطها وحياتها القانونية، وذلك بصرف النظر عن جنسية الشركاء أو جنسية القائمين على الإدارة والإشراف أو مصدر الأموال التي تقوم عليها، وقد أخذ المشرع المصري بهذا المعيار، حيث تمنح الجنسية المصرية لكل شركة تتخذ من مصر مركزاً لإدارتها، وقد تضمنت هذا الرابط الفقرة الثانية من المادة ١١ مدني في شأن الأشخاص المعنوية الأجنبية بقولها: "أما

النظام القانوني للأشخاص المعنوية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي".^(١) وعليه، فالعبرة في هذا الشأن بمركز الإدارة الفعلي، فتكتسب الشركة الجنسية المصرية إذا كان مركز إدارتها الرئيسي الفعلي في مصر ولو كان نشاطها في الخارج، كما لا يعتد بالمركز الذي تتخذه الشركة، والذي ينص عليه في نظامها، إذا كان صورياً لا يتفق مع حقيقة الواقع، فإذا توزعت الإدارة فيعتد بالمركز الرئيسي للإدارة دون مراكز الإدارة المحلية أو الفرعية.^(٢) إلا أن المشرع المصري قد أورد استثناء هاماً على الضابط السابق نص عليه في عجز الفقرة الثانية من المادة ١١ مدني سالفه الذكر التي تقضي بأنه: "...، ومع ذلك إذا باشرت الأشخاص الاعتبارية الأجنبية نشاطها الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يسري"، وقد أخذ المشرع بهذا النص بمعيار مركز الاستغلال، فإذا اتخذت إحدى الشركات من مصر مركزاً رئيسياً لاستغلال نشاطها التجاري، تحتم معه إخضاعها لأحكام القانون المصري.^(٣)

المبحث الرابع

انقضاء الشركة وتصفيتها

يعني انقضاء الشركة انحلال الرابطة القانونية التي تجمع الشركاء، وتتنوع أسباب انقضاء الشركة ما بين أسباب انقضاء عامة تنقضي بها الشركة أياً كان نوعها أو شكلها، أي سواء كانت شركة مدنية أو تجارية، وسواء كانت من شركات الأشخاص أو من شركات الأموال أو من الشركات ذات الطبيعة المختلطة، وأسباب انقضاء خاصة باختيار الاعتبار الشخصي أو الثقة المتبادلة التي تقوم عليها شركات الأشخاص.

ومتى قام أي من أحد أسباب انقضاء الشركة، فإن الشركة تدخل مرحلة التصفية ولا تنقضي شخصيتها الاعتبارية لمجرد قيام سبب الانقضاء، إذا المقرر أن الشركة تظل محتفظة في هذه المرحلة بشخصية اعتبارية بالقدر اللازم للقيام بأعمال التصفية وسداد ديونها قبل الغير وقسمة أموالها وموجوداتها بين الشركاء.

وعليه سوف نقوم في هذا المبحث بدراسة أسباب انقضاء الشركات في مطلب أول، ثم نعرض في مطلب ثان لأحكام التصفية والقسمة.

المطلب الأول

أسباب انقضاء الشركات

في الفرع من هذا المطلب تتناول أسباب الانقضاء العامة للشركات، وفي فرع ثانٍ نعرض لأسباب الانقضاء الخاصة المبنية على الاعتبار الشخصي فيما يتعلق بشركات الأشخاص، ثم لشهر الانقضاء في فرع ثالث.

الفرع الأول: الأسباب العامة لانقضاء الشركات

تضمن التقنين المدني أسباب انقضاء الشركات في المواد ٥٢٦ وما بعدها، وتشمل هذه الأسباب انقضاء المدة المحددة للشركة، وانتهاء أو تحقق الغرض الذي قامت الشركة من أجله، وهلاك مال الشركة أو جزء كبير منه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً، واتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها، وحلها بمقتضى حكم قضائي، واندماج الشركة في شركة أخرى.

أولاً: انقضاء المدة المحددة للشركة:

الأصل أنه متى كانت الشركة محددة المدة فإنها تنحل بقوة القانون بمجرد انقضاء هذه المدة، وهذا ما نص المشرع عليه صراحة في المادة ١/٥٢٦ مدني، بينما تستمر الشركة إذا اتفق الشركاء على استمرار الشركة قبل انقضاء المدة المحددة لها في عقد تأسيسها، ويقع هذا الاتفاق بحسب الأصل من جميع الشركاء، ما لم يبين العقد الأغلبية اللازمة لذلك، وذلك لأن هذا الاتفاق يعد بمثابة تعديل لعقد الشركة، والتعديل لا يتم إلا بإجماع المتعاقدين أو بموافقة الأغلبية المنصوص عليها في العقد، وبالمثل فإنه إذا ما استمرت الشركة بعد انقضاء مدتها في مباشرة النشاط الذي تألّفت من أجله، اعتبر ذلك بمثابة اتفاق ضمني من المتعاقدين على مد أجلها، فيستمر الشخص المعنوي لهذه الشركة، ويكون استمرارها في هذه الحالة سنة فسنة بالشروط ذاتها (م ٢/٥٢٦ مدني).^(١)

أما إذا وقع الاتفاق على استمرار الشركة وامتدائها بعد انقضاء مدتها، فإن هذا الاتفاق يعتبر بمثابة إنشاء لشركة جديدة تألّفت على أنقاض الشركة المنقضية بحلول الأجل المحدد لها، بما يفرض ضرورة اتباع إجراءات التأسيس التي ينص عليها القانون بالنسبة لهذه الشركة الجديدة.^(٢) وسواء كان الاتفاق على امتداد الشركة صريحاً أو ضمناً، فإنه يجوز لدائي أحد الشركاء الاعتراض على امتداد الشركة، وذلك لأن من مصلحته أن تنقضي الشركة حتى يقوم له الحق في التنفيذ على حصة الشريك، ويترتب على هذا الاعتراض وقف أثر الامتداد فتعتبر الشركة منقضية

في حقهم ومن ثم تصفى حصة مدينهم في الشركة، لأنه إذا كان دائنو الشريك لا يستطيعون التنفيذ بحقهم على حصة الشريك أثناء قيام الشركة ودخول الحصة في رأس مالها، فلا أقل من أن يسمح لهم بالمعارضة في امتداد الشركة حتي يستطيعون التنفيذ على هذه الحصة بعد رجوعها لذمة مدينهم.^(١)

ثانياً: تحقق الغرض الذي تألفت الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه:

إذا تأسست الشركة للقيام بعمل معين، كإنشاء مصنع أو شق طريق أو حفر قناة، وانتهى هذا العمل انقضت الشركة (م ١/٥٢٦ مدني)، غير أنه إذا استمرت الشركة بعد ذلك تقوم بعمل من نوع الأعمال التي تأسست من أجلها، امتدت - كما في الحالة السابقة - سنة فسنة بالشروط ذاتها (م ٢/٥٢٦ مدني)، كما يكون لدائنيها الاعتراض على هذا الامتداد وفقاً للتفصيل الذي سقناه في الحالة السابقة.

كذلك تنقضي الشركة متى ثبت استحالة تحقق الغرض الذي قامت من أجله، فإذا تألفت الشركة للقيام بعمل معين ثم صدر تشريع يحظر هذا العمل على مثل نوع الشركة، انقضت هذه الشركة بقوة القانون لاستحالة تحقيق الغرض الذي تأسست من أجله.

ثالثاً: هلاك مال الشركة:

تنقضي الشركة بهلاك جميع رأس مالها أو معظمه بحيث لا يتسنى بعده القيام باستثمار مفيد أو مجد (م ١/٥٢٧ مدني)، وتقدير ما إذا كان الجزء الباقي لا يجدي في القيام باستثمار مفيد، مسألة موضوعية تقدرها المحكمة في ضوء ظروف الدعوى دون رقابة عليها من محكمة النقض، وإن كان الغالب أن ينص العقد التأسيسي للشركة على وجوب حلها إذا بلغت نسبة الهلاك حداً معيناً، كالثلث أو النصف مثلاً (على ما سيلي).

وهلاك رأس المال قد يكون مادياً، مثل احتراق مصنع الشركة أو غرق بواخرها أو تحطم طائراتها أو نضوب المنجم الذي تستغله، ويعتبر في حكم الهلاك اعتبار نشاط الشركة غير مشروع، كما لو كانت تتجر في بضائع أو تصنعها، ثم صدر قانون يحظر صنعها أو تداولها أو حيازتها.

وعلى ما تقدم فإن الهلاك الذي يؤدي إلى انتهاء الشركة، هو الذي يستحيل معه قيام الشركة بنشاطها، فإذا هلكت موجودات الشركة وكان مؤمناً عليها، فلا يؤدي هذا الهلاك إلى الانقضاء، ما دام أن ما تستحقه الشركة من مبلغ التأمين يكفي لكي تعود الشركة لممارسة

نشاطها من جديد، وبالنظر إلى أن الشركات غالباً ما تقوم بالتأمين على موجوداتها من مخاطر الهلاك، فمن النادر عملاً أن يكون الهلاك المادي سبباً لانقضائها.^(١)

وتنص المادة ٦٩ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ (المعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد) على أنه: "إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً لآخر قوائم مالية للشركة، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها".^(٢)

كما تنص المادة ١٢٩ من قانون الشركات المذكور، على أنه: "في حالة خسارة نصف رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يتعين على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة أمر حل الشركة، ويشترط لصدور قرار الحل توافر الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة".

رابعاً: اجتماع الحصص في ذمة شخص واحد:

قدمنا أن اجتماع حصص أو أسهم الشركة في يد شخص واحد يترتب عليه انهيار ركن تعدد الشركاء، وهو ما يؤدي إلى حل الشركة.

غير أنه إذا قل عدد الشركاء عن النصاب المحدد للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، فإن اجتماع الحصص في يد شريك واحد لا يترتب عليه حل الشركة بقوة القانون، وفقاً للمادة (٨) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ (المعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨) إلا إذا لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب، أو يطلب من بقي من الشركاء خلال هذا الأجل تحويلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد، ويكون من بقي من الشركاء مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة".^(٣)

خامساً: اتفاق الشركاء على حل الشركة:

كما يجوز للشركاء الاتفاق على مد أجل الشركة، فإنه يجوز لهم أيضاً الاتفاق على حل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة لانقضائها، ويشترط لذلك إجماع الشركاء وفقاً للمادة (١/٢٥٩ مدني) إلا إذا اتفق في العقد التأسيسي للشركة على خلاف ذلك فيجب موافقة الأغلبية المتفق عليها، وهي دائماً الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة، فقرار حل شركة المساهمة مثلاً تملكه الجمعية العامة غير العادية ويتم اتخاذه وفقاً للأغلبية المنصوص عليها في المادة (٦٨/ج) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١^(٤)، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم

إعمالاً للمادة ١١٠ من ذات القانون، أما الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقرار حلها لا تملكه سوى الجمعية العامة للشركاء.^(١)

ويشترط الفقهاء حل الشركة بهذه الطريق أن تكون الشركة موسرة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، فلا يعتد بحل الشركة باتفاق الشركاء إذا كانت الشركة في حالة توقف عن الدفع، منعاً للتحايل على قواعد الإفلاس، ومتى وقع حل الشركة صحيحاً، فإنه لا يحتاج به على الغير إلا بعد شهره بالطرق القانونية، ويترتب عليه دخول الشركة دور التصفية.^(٢)

سادساً: حل الشركة بمقتضى حكم قضائي:

تقضي المادة ٥٣٠ مدني بأنه: "يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به، أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل، ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك"، ويتضح من هذا النص أن حق الشريك في طلب حل الشركة، وبالنظر إلى خطورته وأهميته، هو حق شخصي للشركاء، فلا يجوز لدائن الشركة أو دائن أحد الشركاء أن يباشر هذا الحق، كما أنه حق متعلق بالنظام العام، ومن ثم يقع باطلاً كل اتفاق يحرم الشريك منه.

ومن أمثلة الأسباب الخطيرة التي تبرر الحل: وقوع أزمة اقتصادية حادة تؤدي إلى اضطراب أعمال الشركة، أو امتناع أحد الشركاء عن أداء حصته في رأسمالها بما يترتب عليه استحالة نهوض الشركة بأداء التزاماتها، أو توالي خسائر الشركة نتيجة ظروف المنافسة التجارية، أو وقوع نزاع شديد بين الشركاء يعوق أعمال الشركة ويجعل التعاون بينهم مستحيلاً.

وفي مثل هذه الحالات يكون للمحكمة كامل الحرية في تقدير وجهة أسباب الحل التي يتمسك بها الشركاء، ومن ثم يجوز لها بدلاً من الحكم بالحل، أن تقتصر على الحكم بالتعويض على الشريك المخطئ، أو الحكم بفصله بناء على ما تقضي به المادة ٥٣١ مدني، وهو حق بديل لطلب حل الشركة، خاصة إذا كان في فصل الشريك ما يخلص الشركة من الأسباب التي تعوق عملها، على أن تبقى الشركة قائمة بين بقية الشركاء، إلا إذا كانت الشركة مؤلفة من شريكين فقط، ففصل أحدهما سيفضي حتماً إلى حل الشركة.^(٣)

والحكم بحل الشركة هو حكم بفسخ العقد، وليس لهذا الفسخ أثر رجعي، لأن عقد الشركة عقد زمني كعقد الإيجار.^(٤)

سابعاً: الاندماج:

الاندماج هو تلاحم شركتين قائمتين تلاحماً يقتضي بالضرورة فناء كل منهما أو أحدهما ليكوناً معاً شركة واحدة، والاندماج لا يتم إلا بين الشركات التي تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ومن قضاء محكمة النقض في هذا الشأن: "أنه لا يعتبر اندماجاً في معنى القانون مجرد ضم وحدة إنتاجية أو حصة لشركة إلى ذمة شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها، طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من حقوق والتزامات".^(١)

واندماج المشروعات يعتبر ظاهرة عالمية في الوقت الحاضر، وهو يهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية متعددة، منها: البحث عن الحجم الأمثل للمشروع، وتخفيض نفقات الإنتاج، وإنشاء المشروعات الكبيرة القادرة على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي ... إلخ.

وللاندماج صورتان: الأولى الاندماج بطريق المزج "Par Combinaison" والثانية الاندماج بطريق الضم أو الابتلاع "Par annexion ou absorption".

ويترتب على الاندماج بطريق المزج فناء شخصية الشركتين ونشوء شركة جديدة تحل محل الشركات المندمجة في حقوقها والتزاماتها، وبحيث تقول إلى هذا الشخص المعنوي الجديد حقوق والتزامات الشركات المنقضية، أما الاندماج بطريق الضم فلا يترتب عليه سوى فناء شخصية الشركة المندمجة في شخصية الشركة الداخلة، ويترتب على ذلك أن حقوق والتزامات الشركة المندمجة تنتقل إلى الشركة الداخلة التي تسأل عن جميع هذه الالتزامات وتكتسب كافة تلك الحقوق، فتحل محلها قانوناً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وعلى هذا فالأصل أن جميع حقوق والتزامات الشركة أو الشركات المندمجة تنتقل إلى الشركة الداخلة أو الشركة الجديدة التي تحل حلوها قانونياً محل الشركة المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وخلافتها لها خلافة عامة.^(٢)

وفي صورتين يجب إجراء تقويم لجميع أموال الشركات المندمجة، ويحدد عقد الاندماج في رأس مال الشركة الداخلة، أو حصص الشركات المندمجة في الشركة الجديدة الناشئة عن الاندماج، ولا يكون الاندماج صحيحاً إلا إذا صدر من كل شركة طرف فيه وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها، ويجب أن يتم شهر قرار الاندماج بطرق الشهر المقررة لما يطرأ على عقد الشركة المندمجة أو نظامها من تعديلات.

والغالب أن يؤدي الاندماج إلى تقوية مركز الشركة الداجمة ثم إلى تقوية ضمان الدائنين، إلا أنه قد يضر أحياناً بدائني الشركة المندمجة، وذلك في حالة ما إذا كانت خصوم الشركة الداجمة تزيد عن أصولها، وحماية لهؤلاء الدائنين فإن قرار الاندماج لا ينفذ في مواجهتهم إلا من تاريخ شهره، ويكون لدائني الشركة المندمجة أن يعارضوا في الاندماج وتصبح لهم على موجودات الشركة المندمجة أفضلية على دائني الشركة الداجمة، بشرط أن تكون لهم مصلحة في المعارضة، كأن تكون خصوم الشركة الداجمة تزيد عن أصولها كما أسلفنا، ويترتب على اعتراض الدائنين عدم سريان الاندماج في حقهم، ومن ثم يكون لهم أن ينفذوا على موجودات الشركة المندمجة وتكون لهم عليها الأفضلية، ولكن الاندماج ينفذ في حق الدائنين رغم اعتراضهم إذا تنازلوا عن هذا الاعتراض، أو قضت المحكمة بناء على طلب الشركة بعدم صحة الاعتراض أو قدمت الشركة ضماناً كافياً للوفاء بديونهم إذا كانت هذه الديون آجلة.

الفرع الثاني:

أسباب الانقضاء الخاصة بالشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي

زوال الاعتبار الشخصي:

تقوم شركات الأشخاص، كما أسلفنا، على الاعتبار الشخصي والثقة التي تجمع بين الشركاء، وعلى هذا فإنه، بالإضافة إلى أسباب الانقضاء العامة، تنقضي هذه الشركات إذا قامت أسباب تؤدي إلى انهيار هذا الاعتبار الشخصي لدى الشركاء، وقد يتم ذلك بإرادة الشركاء كانسحاب الشريك من الشركة، أو بغير إرادتهم، كوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه لعدة عقلية أو لإعلان إفلاسه أو إعساره.

أولاً: انسحاب أحد الشركاء:

الأصل أنه إذا كانت الشركة غير محددة المدة، قام حق أي من الشركاء في الانسحاب منها، وهو حق متعلق بالنظام العام لا يجوز حرمان الشريك منه أو التنازل عنه لتعلقه بالحرية الشخصية (م ٥٢٩ / ١ مدني)، وحينئذ تنقضي الشركة بانسحاب أحد الشركاء منها، نظراً لأن شركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي للشركاء سواء في تكوينها أو استمرارها.

ويشترط لوقوع الانسحاب صحيحاً في هذه الحالة، وفقاً للمادة (١ / ٥٢٩ مدني) أن يتم وفق مبدأ حسن النية في التعامل، وذلك بأن يعلن الشريك رغبته إلى سائر الشركاء في ترك الشركة، وألا يكون هذا الانسحاب عن غش أو في وقت غير لائق بغرض الإضرار بالشركة، كما

لو تم الانسحاب مثلاً بغرض الانفراد بصفقة رابحة أو جاء في وقت تمر فيه الشركة بضائقة مالية، أو جاء بغرض حرمان الشركة من صفقة وشيكة ستدر عليها أرباحاً كثيرة، وفي كل الأحوال فإن هذا الانسحاب لا يسري في حق الغير إلا إذا تم شهره بالطرق القانونية.

أما إذا كانت الشركة محددة المدة، فالأصل أنه لا يجوز للشريك أن ينسحب منها بإرادته المفردة، لأن في انسحابه من الشركة بإرادته المفردة مخالفة لالتزامه بالبقاء فيها طوال مدتها المحددة، ويرتب إنهاء العقد الإضرار بسائر الشركاء، ومع ذلك يجوز للشريك - في حالة عدم الاتفاق مع الشركاء - أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفي حالة اقتناع القضاء بوجاهة الأسباب التي يثيرها الشريك تنقضي الشركة، وذلك ما لم يتضمن عقد الشركة نصاً يقضي باستمرارها رغم الحكم بخروج أي من الشركاء، أو يتفق الشركاء بالإجماع على استمرار الشركة فيما بينهم، ففي مثل هذه الحالات تستمر الشركة بين من تبقى من الشركاء، على ما سيلي في الفقرة التالية.

ثانياً: وفاة الشريك أو إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه:

يترتب على وفاة أحد الشركاء انقضاء الشركة التي تقوم على الاعتبار الشخصي بقوة القانون (م ١/٥٢٨ مدني)، حتى لو كان الأجل المحدد للشركة في عقدها التأسيسي لم يحل بعد، فلا يحل الورثة محل مورثهم كشركاء في الشركة، لأن الثقة شخصية، ومن ثم فلا يجوز إجبار الشركاء على الاستمرار في الشركة مع أشخاص قد لا يولونهم ثقتهم وإن كانوا من الورثة.

كذلك تنقضي الشركة بإفلاس الشريك أو إعساره أو الحجر عليه لسفه أو عته أو جنون (م ١/٥٢٨ مدني)، لأنه يستحيل على الشريك في مثل هذه الحالات الوفاء بتعهداته قبل الشركة أو الغير، فضلاً عن فقدان الثقة في ملاءة الشريك، ولا يحل وكيل الدائنين أو القيم على هؤلاء محلهم في الشركة، لأن الثقة بشخص معين لا تنتقل إلى مثله القانوني.

غير أن أسباب الانقضاء الخاصة بفقدان الاعتبار الشخصي، كقاعدة عامة، لا تتعلق بالنظام العام، ومن ثم يجوز طبقاً للمادة (٢١/٥٢٨ مدني) أن يتفق الشركاء على استمرار الشركة في حالة وفاة الشريك مع ورثة الشريك المتوفى، أو فيما بين الباقي من الشركاء في حالة وفاة الشريك أو إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه أو انسحابه من الشركة، ويرجع ذلك إلى رغبة المشرع في المحافظة على بقاء الشركة وإتاحة استمرارها بين من تبقى من الشركاء إذا رغبوا في ذلك، خاصة أن هذه الأسباب متوقعة الحدوث، وفي القول بحتمية انقضاء الشركة لدى حصولها

ما يضر بائتمان الشركة، لا سيما إذا كانت مزدهرة أو تكونت للقيام بأعمال طويلة الأجل، فإن أغفل الشركاء اشتراط استمرار الشركة بالرغم من حدوث أسباب الانقضاء السابقة، انقضت الشركة، لا محالة، وتعين تصفيتها.

ولهذا فقد أجاز المشرع، تحقيقاً للأغراض السابقة وتغادياً لحل الشركات التي يقوم بصدها سبب من الأسباب الخاصة للانقضاء، مع المحافظة في نفس الوقت على الطابع الشخصي لهذه الشركات، أن يتضمن عقد الشركة شروطاً لمواجهة هذا الاحتمال بما يتيح استمرارها بين من تبقى من الشركاء، وحينئذ لا يكون للشريك الذي قام سبب الانقضاء في شخصه-أو لورثته-إلا نصيبه في أموال الشركة بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى لخروجه من الشركة، ولا يكون له بعد ذلك نصيب من الأرباح إلا ما كان منها ناتجاً عن أعمال سابقة على هذا الحادث.

هذا والاتفاق على استمرار الشركة فيما بين الشركاء وورثة الشريك المتوفى، لا يثير صعوبة طالما لا يوجد بينهم قاصر، غير أن الصعوبة تظهر عندما يكون بين الورثة قصر، ومرد هذه الصعوبة أن القاصر لا يصلح أن يكون عضواً في شركة أشخاص يسأل عن ديونها مسؤولية شخصية وتضامنية في أمواله الخاصة ويكتسب فيها صفة التاجر، ويحكم عليه بالإفلاس إن أفلس الشركة.

ويمكن تفادي هذه الصعوبة أيضاً إذا ما تضمن عقد الشركة نصاً يقضي بأن تنقلب الشركة في هذه الحالة من شركة تضامن إلى شركة توصية بسيطة، كما أن الراجح فقهاً، في حالة خلو العقد من مثل هذا النص، هو أنه يفترض تحول الشركة في هذه الحالة أيضاً إلى شركة توصية بسيطة، يكون فيها القاصر شريكاً موصياً، وبذلك تنحصر فيها مسؤوليته في حدود حصته في رأس المال، ولا يكتسب صفة التاجر ولا يجوز شهر إفلاسه، على اعتبار أن هذا الحل يحفظ لهذا النوع من الشركات الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه، ويراعي مصلحتها في ألا تنقضي، دون أن يتعارض مع أحكام الأهلية وتوفير الحماية للقاصر.^(١)

وقد أخذ تشريع الشركات في فرنسا الصادر سنة ١٩٦٦ بهذا الحل في المادة ٢/٢١ منه، بتحول شركة التضامن في هذه الحالة، خلال سنة على الأكثر، إلى شركة توصية بسيطة، يكون فيها القاصر شريكاً موصياً، وإلا اعتبرت منحلة.^(٢)

الفرع الثالث: شهر الانقضاء

يجب شهر انقضاء الشركة وفقاً للأوضاع التي حددها القانون حتى يعلم به الغير، ويقع الشهر بذات الوسيلة التي يشهر بها عقد الشركة، فإذا تخلف الشهر ترتب ذات الجزاء المقرر لإهمال شهر العقد التأسيسي للشركة، وهو البطلان، بمعنى أن الانقضاء لا يسري في حق الغير الذي له التعامل مع الشركة كما لو كانت قائمة، ويظل الشريك مسئولاً عن الأعمال التي تجرى باسم الشركة ولو بعد انقضائها.

ولا محل لشهر انقضاء الشركة في حالة انتهاء المدة المحددة للشركة في عقدها، وذلك لسبق علم الغير بالمدة المحددة لسريانها من خلال العقد التأسيسي والذي سبق شهره، كما يجب شهر اتفاق الشركاء على استمرارها فيما بينهم بالرغم من قيام أحد أسباب الانقضاء، كما في حالة الاتفاق على استمرار الشركة بعد انسحاب أحد الشركاء من الشركة أو وفاته أو إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه، لأن الأصل في هذه الحالات انقضاء الشركة بقيام سبب الانقضاء، والاستثناء هو بقاء الشركة باتفاق الشركاء، ومن ثم يجب أن يشهر هذا الاتفاق لإعلام الغير باستمرار الشركة، وذلك إذا لم يكن مشروطاً في عقدها التأسيسي أن تستمر بين الشركاء بالرغم من حدوث هذا السبب.

ومتى تم الشهر وفقاً للإجراءات التي حددها القانون، فإن انقضاء الشركة لا يسري على الغير إلا من تاريخ إتمام الشهر، وليس من اليوم الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة للانقضاء، وترتيباً على ذلك فإن التصرفات التي أجرتها الشركة في الفترة ما بين تحقق سبب الانقضاء وشهره، تعتبر صحيحة منتجة لآثارها في حق الشركة والغير، ما دامت قد أجريت باسم الشركة ولحسابها.^(١)

المطلب الثاني

أحكام تصفية الشركة وقسمة موجوداتها

سنقسم دراستنا لهذا المطلب إلى ثلاثة فروع: نتكلم في الأول منها عن التصفية، وفي الثاني نعرض لقسمة الموجودات، بينما نخصص الفرع الثالث لتقادم الدعاوى التي تنشأ عن أعمال الشركة المنقضية.

الفرع الأول: تصفية الشركة

المقصود بالتصفية: بعد حل الشركة وانقضائها تأتي مرحلة التصفية، والمقصود بالتصفية كافة العمليات اللازمة لتحديد صافي أموال الشركة الذي يوزع بين الشركاء بطريق القسمة، بعد حصر الموجودات واستيفاء الحقوق وسداد الديون وبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً، وقبل إجراء القسمة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته في رأسمال، لأن هذه التصفية هي التي ستحدد صافي أموال الشركة التي سيجرى قسمتها بين الشركاء في تاريخ إجراء التصفية.^(١)

ويتضمن عقد الشركة عادة الطريقة التي تتم بها تصفية أموالها وقسمتها بين الشركاء، فإذا لم يتضمن العقد طريقة التصفية، وجب اتباع الأحكام المنصوص عليها في القانون بهذا الشأن، وهي المواد من ٥٣٢ إلى ٥٣٧ من التقنين المدني، حيث لم يتضمن القانون التجاري قواعد خاصة في هذا الشأن، عدا بعض الأحكام التي نص عليها قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن احتفاظ الشركة في طور التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإنهاء أعمالها.

استمرار الشخصية المعنوية للشركة في مرحلة التصفية:

الأصل أن الشخصية المعنوية للشركة تنقضي بمجرد حلها وانقضائها، ومع ذلك فالمقرر أن انقضاء الشركة لا يترتب عليه زوال شخصيتها المعنوية نظراً لما يؤدي إليه ذلك من نتائج يستحيل معها التصفية، إذ سترتب عليه أن تصبح أموال الشركة ملكاً شائعاً بين الشركاء، وسيتمكن الدائنون للشركاء من مزاحمة دائني الشركة في التنفيذ على أموالها، فضلاً عن تعذر إنجاز الأعمال الجارية واستيفاء حقوق الشركة ووفاء ما عليها من ديون بمقتضى استخدام اسم الشركة ولحسابها كشخصية معنوية مستقلة.^(٢)

ولهذا تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية طيلة فترة التصفية من تاريخ انقضاء الشركة لحين توزيع أموالها على الشركاء (م ٥٣٣ مدني)، ويترتب على استمرار الشخصية المعنوية للشركة خلال فترة التصفية: أن تظل للشركة ذمتها المالية المستقلة عن ذمم الشركاء، والتي تكون

ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم دون دائني الشركاء، كما تظل كذلك محتفظة باسمها، ليتم التعامل به في سائر أعمال التصفية مقروناً بعبارة " قيد التصفية"، وكذلك تحتفظ بموطنها القانوني في مركزها الرئيسي، بحيث ترفع الدعاوى على الشركة في هذا الموطن وتعلن إليها الأوراق القضائية فيه.^(١)

ويعتبر المصفي ممثلاً قانونياً للشركة، ينوب عنها في التقاضي ويطالب بحقوقها ويتصرف في أموالها في حدود سلطته، دون حاجة للحصول على موافقة كل شريك على حدة، ويجوز إشهار إفلاس الشركة متى توقفت عن دفع ديونها التجارية في هذه الفترة.

على أن الاعتراف بالشخصية المعنوية للشركة إبان التصفية، ينبغي ألا يتعدى حدود الهدف المنشود منه وبقدر الضرورة التي دعت إليه، ومن ثم فإن هذه الشخصية المعنوية ينبغي ألا تتعدى القدر اللازم والضروري لإتمام أعمال التصفية، ويعني ذلك أنه لا يجوز البدء بأعمال جديدة لحساب الشركة ما لم تكن هذه الأعمال نتيجة لازمة لإنهاء أعمال قديمة (م ٥٣٥ مدني)، وتوقف الشخصية المعنوية للشركة في فترة التصفية عن ترتيب أي أثر بعد إقفال التصفية.^(٢)

تعيين المصفي وعزله:

يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية إنتهاء سلطة المديرين، وبذلك تقضي المادة ٥٣٣ مدني، فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة، ويحل بدلاً عنهم المصفي الذي يصبح هو الوحيد صاحب الصفة في تمثيل الشركة، والقيام بكافة الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة (٢/١٣٨) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من أنه: وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، وتقتصر سلطاتها على الأعمال التي لا تدخل في اختصاص المصفين.

وغالباً ما ينص عقد الشركة على الكيفية التي يتم بها تعيين المصفي وعزله، فإذا خلا العقد من طريقة تعيين المصفي ولم يتفق الشركاء بالأغلبية على تعيين مصف واحد أو أكثر للشركة (م ١/٥٣٤ مدني)، أو حالت أية أسباب دون قيام المصفي المعين بأداء عمله، تولت المحكمة تعيينه بناء على طلب أحدهم (م ٢/٥٣٤ مدني)، وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة، تعين المحكمة المصفي وتحدد طريقة التصفية، بناء على طلب كل ذي شأن، ولو كان منصوباً في عقد الشركة على طريقة تعيينه^(٣)، وإلى أن يتم تعيين المصفي، اتفاقاً أو قضاءً، يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين (م ٣/٥٣٤ مدني). وذلك حتى يجد الغير ممثلاً للشركة يمكن توجيه الدعاوى إليه.^(٤)

وتنص المادة ١٣٩ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أنه: "تعين الجمعية العامة مصف واحد أو أكثر وتحدد أتعابهم ويكون تعيين المصفين من بين المساهمين أو الشركاء أو غيرهم، وفي حالة صدور قرار بجل الشركة أو بطلانها تبين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفي وتحدد أتعابه، ولا ينتهي عمل المصفي بوفاة الشركاء أو شهر إفلاسهم أو إعسارهم أو الحجر عليهم ولو كان معيناً من قبلهم".

ويتم عزل المصفي بذات الطريقة التي جرى تعيينه بها، ويجب شهر القرار الصادر من الشركاء أو من المحكمة بتعيين المصفي وعزله، ويقع على المصفي اتخاذ إجراءات الشهر، ويقوم المصفي الجديد بهذا الإجراء، ويتم الشهر في السجل التجاري وفي صحيفة الشركات، ولا يحتج قبل الغير بقرار تعيين المصفي أو عزله إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري وفي صحيفة الشركات (م ١٤٠ و ١٤١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١).

سلطات المصفي ومسئوليته:

الغالب أن يحدد عقد الشركة أو قرار الشركاء أو الحكم الصادر بتعيين المصفي السلطات الممنوحة له، وعلى المصفي أن يعمل في حدود هذه السلطات حتى تلتزم بها الشركة، فإن تجاوز المصفي حدود سلطاته المحددة، فالأصل ألا تلتزم الشركة بها، فإن لم تحدد سلطات المصفي في سند تعيينه، كان له القيام بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية.

حيث يقوم المصفي، بالاتفاق مع مجلس الإدارة أو مديري الشركة، بمجرد أموال الشركة وتسلمها وتحرير قائمة مفصلة بها، ويلتزم بالمحافظة عليها وعلى ما يسلم له من وثائق الشركة ودفاترها (م ١٤٢ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١)، واستيفاء حقوق الشركة قبل الغير والشركاء، والوفاء بديونها الحالية واحتجاز المبالغ اللازمة لسداد الديون المؤجلة أو المتنازع عليها (م ١/٥٣٦ مدني)، وله في سبيل ذلك أن يبيع المنقولات والعقارات وتحويلها إلى نقد، سواء تم ذلك بالميزان أو بالممارسة، وفقاً للضوابط التي تضمنها مستند تعيينه (م ٢/٥٣٥ مدني)، على أنه لا يجوز للمصفي أن يبيع موجودات الشركة جملة إلا بإذن من الجمعية العامة أو جماعة الشركاء على حسب الأحوال.^١

وللمصفي أن يمثل الشركة أمام القضاء وله قبول الصلح والتحكيم.^١

كما أن للمصفي أن ينجز الأعمال الجارية التي بدأت فيها الشركة قبل الحل، ولكن لا يجوز له أن يبدأ أعمالاً جديدة باسم الشركة إلا إذا كانت هذه الأعمال الجديدة لازمة لإتمام أعمال

سابقة على الحل (م ١/٥٣٥ مدني)، وإذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تستلزمها التصفية كان مسؤولاً في جميع أمواله عن هذه الأعمال، ويسأل المصفون عن هذه الأعمال بالتضامن عند تعددهم^(١)، وإذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا إذا تمت بموافقتهم الإجماعية، ما لم يشترط خلاف ذلك في وثيقة تعيينهم، ولا يحتاج بهذا الشرط قبل الغير إلا من تاريخ شهره في السجل التجاري.^(٢)

وعلى المصفي أن يقدم للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية، وأن يضع تحت أيديهم الأوراق والدفاتر الخاصة بأعمال التصفية، شريطة ألا يضع الشركاء العراقيين في سبيل التسوية بمطالب غير مشروعة، كما يجب على المصفي أن يقدم إلى الجمعية العامة أو جماعة الشركاء حساباً ختامياً عن أعمال التصفية، وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي.^(٣)

ويكون للمصفي أجراً يتقاضاه عن عمله، يحدد في سند تعيينه، وإلا حددته المحكمة على أساس حجم أعمال التصفية، ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على هذا التحديد.^(٤) وتقضي المادة ١٤٧ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بأن: "تلتزم الشركة بكل تصرف يجريه المصفي باسمها إذا كان مما تقتضيه أعمال التصفية ولو جاوز القيود الواردة على سلطة المصفي أو استعمل المصفي توقيع الشركة لحسابه الخاص، إلا إذا كان من تعاقد مع المصفي سيئ النية"، كما تقضي المادة ١٥٤ من القانون المذكور بأنه: "يسأل المصفي قبل الشركة إذا أساء تدبير شئونها خلال فترة التصفية، كما يسأل المصفي عن تعويض الضرر الذي يلحق المساهمين أو الشركاء أو الغير بسبب أخطائه".

الفرع الثاني: انتهاء التصفية وقسمة الأموال

يجب على المصفي إنهاء التصفية في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه، ومتى تمت التصفية وتحدد الصافي من أموال الشركة وتحولت أموال الشركة إلى نقود، وتم استيفاء حقوقها قبل الغير والوفاء بديونها، انتهت مهمة المصفي وزال الوجود القانوني للشركة كشخص معنوي^(٥)، ويتحتم عندئذ إجراء القسمة، وهي المرحلة التي تلي التصفية وتستهدف أن ينال كل شريك حقه في موجودات الشركة.

وإن لم يحدد الشركاء شخصاً آخر للقيام بالقسمة، فغالباً ما يتولى المصفي إجراء قسمة الأموال بين الشركاء، وهنا يعتبر المصفي وكلياً عن الشركاء وليس ممثلاً للشركة، التي تكون قد

زالت بالتصفية كشخص معنوي، ويتبع في القسمة، بحسب الأصل، ما يكون الشركاء قد اتفقوا عليه في عقد الشركة، مع مراعاة ما قرره المادة ٥٣٦ مديني في هذا الشأن من أحكام.^(١)

فإذا كان صافي أموال الشركة يساوي رأس مالها أو يزيد، فإن كل شريك يختص بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مبينة في عقد التأسيس، وإذا لم تبين قيمة الحصة العينية في العقد فإنه يحصل على ما يعادل قيمتها وقت تسليمها، وإذا بقي شيء من أموال الشركة بعد إعادة ما يعادل قيمة الحصص التي قدمها الشركاء، فإنه يقسم بين جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الربح، وإذا قدم الشريك حصته على سبيل الانتفاع فإنه يستردها قبل القسمة، لأن ملكية الرقبة ما زالت له-على نحو ما بينا سلفاً- أما الشريك بالعمل فإنه -بإتمام التصفية- يسترد حصته، باسترداد حريته في العمل وتحتله من الالتزام بقصر عمله على الشركة (م ٢/٥٣٦ مديني).

أما إذا لم يكف صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء، فإن ذلك يعني أن الشركة قد منيت بخسائر، فيتم توزيع هذه الخسائر بينهم وفقاً للأسس المتفق عليها، وإلا فإنها توزع بنسبة حصة كل شريك في رأس المال (م ٣/٥٣٦ و م ١/٥٢٤ مديني).

ويقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية في السجل التجاري وفي صحيفة الشركات، ولا يحتاج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ شهره في السجل التجاري^(٢)، ويجب على المصفي طلب محو قيد الشركة بالسجل التجاري خلال شهر من تاريخ قفل التصفية، وإلا كان لمكتب السجل التجاري محو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له، عملاً بالمادتين ١٠ و ١١ من قانون السجل التجاري رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦.

الفرع الثالث: تقادم الدعاوى التي تنشأ عن أعمال الشركة

الأصل أن تصفية الشركة وزوال شخصيتها المعنوية لا يبرئ ذمة الشركاء وورثتهم قبل دائني الشركة عما يكون لهؤلاء من حقوق قبل الشخص المعنوي المنقضي، ذلك أن الشريك لا يبرأ عند انقضاء الشركة من المسؤولية، سواء بحكم كونه شريكاً متضامناً أو لأنه مسئول في الشركات الأخرى عن تقديم الحصص في رأس المال.

وإذا كان الالتزام يتقادم وفقاً للقواعد العامة بانقضاء خمس عشرة سنة (طبقاً للمادة ٣٧٤ مديني)، فإن المشرع قد رأى ضرورة الخروج على هذا الأصل في الميدان التجاري-بغية حث الدائنين على عدم التأخر في المطالبة بحقوقهم وحماية الشركاء من الطلبات المتأخرة-فحدد مدة

معينة تسقط بانقضاءها الدعاوى التي قد يرفعها الغير على الشركاء بسبب أعمال الشركة المنحلة، فوفقاً للمادة ٦٥ من قانون التجارة القديم: كل ما نشأ عن أعمال الشركة من الدعاوى على الشركاء الغير مأمورين بتصفية الشركة أو على القائمين مقامهم يسقط الحق في إقامته بمضي خمس سنين من تاريخ انتهاء مدة الشركة إذا أشهر عقدها، أو من تاريخ شهر انقضاء الشركة إذا أوجب القانون هذا الشهر.

نطاق الدعاوى التي تخضع للتقادم الخمسي:

التقادم الخمسي المشار إليه خاص بالشركات التجارية، فلا يسري على الشركات المدنية وذلك لورود النص عليه في المجموعة التجارية، ولا يشمل هذا التقادم سوى الدعاوى التي ترفع على الشركاء الغير مصفين أو ورثتهم، لمطالبتهم مثلاً بديون الشركة، بينما لا يخضع لهذا التقادم الدعاوى التي ترفع على الشركة ممثلة في شخص المصفي من قبل دائني الشركة، ودعاوى المصفي على الشركاء لمطالبتهم مثلاً بما تكبده في التصفية من مصروفات أو لمطالبتهم بالباقي من حصصهم، ودعاوى المصفي على الغير كدائني الشركة، وكذلك الدعاوى التي يرفعها الشركاء بعضهم على البعض الآخر لمسئوليتهم التضامنية عن ديون الشركة، كما لو وفي أحد الشركاء المتضامنين ديناً على الشركة بأكثر من نصيبه، فكل هذه الدعاوى تتقادم بمضي خمس عشرة سنة بالتطبيق للقواعد العامة.

هذا والمقرر -وفقاً للفقهاء الراجح- أن للشريك المصفي أن يفيد من التقادم الخمسي فيما يتعلق بالدعاوى التي ترفع عليه لمطالبته بديون الشركة، بوصفه شريكاً كسائر الشركاء وليس بوصفه مصفياً، وذلك لئلا يكون هذا الشريك المصفي، في حالة خضوعه للتقادم الطويل في مثل هذه الدعاوى، في مركز أسوأ من بقية الشركاء، ما يدفعهم إلى الإحجام عن قبول وظيفة المصفي، وأخيراً فإنه يترتب على أن التقادم الخمسي مقرر لمصلحة الشركاء وليس لمصلحة دائني الشركة، أنه لو تقادمت الديون طبقاً للقواعد العامة قبل مرور الخمس سنوات على انقضاء الشركة، فإنه يسقط حق الدائنين في مطالبة الشركاء بها.^(١)

شروط التقادم الخمسي:

يفترض لكي يمكن للشركاء التمسك بالتقادم الخمسي لسقوط الدعاوى التي ترفع عليهم، تحقق عدة شروط:

فطبقاً لما ورد بالمادة ٦٥ تجاري قديم - سابق الإشارة إليها - يشترط أن تكون الشركة قد انقضت وانحلت، فإن كانت الشركة مستمرة فلا محل لسريان التقادم، إذ تظل مسؤولية الشركاء قائمة مهما مر الزمن، كما يجب لسريان هذا التقادم أن يتم شهر انقضاء الشركة بالطرق القانونية المقررة، وتسري مدة التقادم من تاريخ انقضاء الشركة متى كان القانون لا يقتضي شهر الانقضاء، كما لو انقضت الشركة بسبب انتهاء مدتها المحددة في عقدها التأسيسي، أو من تاريخ إتمام شهر الانقضاء في جميع الحالات التي يكون فيها الشهر واجباً، أو من تاريخ الدين متى نشأ بعد شهر انقضاء الشركة.

فإذا خرج أحد الشركاء من الشركة فلا يبدأ التقادم إلا من تاريخ شهر الخروج، وإذا كانت الدعاوى ناشئة عن التصفية أو القسمة فلا يبدأ حساب مدة التقادم إلا من تاريخ انتهاء التصفية أو القسمة، وفي كل الأحوال يخضع التقادم الخمسي لأحكام الوقف والانقطاع المقررة في القواعد العامة.

الفصل الثاني شركات الأشخاص

تمهيد وتقسيم:

تشمل شركات الأشخاص sociétés de personnes: شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة، وهي شركات تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء، ومن ثم فهي تتكون في العادة من عدد قليل من الشركاء، يعرف بعضهم بعضاً ويثق كل منهم في الآخر ممن تجمعهم صلة القرابة أو الصداقة، وذلك للاضطلاع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العادة.^(١)

وبالرغم من كون هذه الشركات يجمعها خصائص مشتركة، من واقع الاعتبار الشخصي الذي يؤثر في العديد من أحكامها وخصائصها، إلا أننا، ولمزيد من التوضيح ودقة العرض، سنفرد لكل شركة منها مبحثاً خاصاً.

وبذلك سوف نقسم الدراسة في شركات الأشخاص إلى المباحث الثلاثة الآتية:

المبحث الأول: شركة التضامن:

المبحث الثاني: شركة التوصية البسيطة:

المبحث الثالث: شركة المحاصة:

المبحث الأول شركة التضامن

عرف الرومان منذ القدم نوعاً من الشركات يضع فيه الشركاء ثرواتهم الحاضرة والمستقبلية، وكانت هذه الشركات تتكون في العادة بين أفراد العائلة الواحدة، ثم تطورت مع الزمن لتشمل أفراداً من خارج العائلة، كما عرفوا أيضاً نوعاً آخر من الشركات يقر مبدأ التضامن بين الشركاء، ثم تطور التشريع المتعلق بالشركات في العصور الوسطى، ولا سيما في المدن الشمالية من إيطاليا، وترسخت قواعد تأسيس شركة التضامن، فاتخذت شركة التضامن صورتها المعروفة حالياً.

وتعتبر شركة التضامن، بما تقوم عليه من اعتبار شخصي، النموذج الأمثل لشركات الأشخاص، وقد اعتبرت أحكامها القانونية القاعدة العامة لهذا النوع من الشركات، بحيث تطبق قواعدها على سائر شركات الأشخاص كلما افتقر أي منها لنصوص قانونية خاصة، وهي شركة راسخة في القدم، كإطار قانوني للمشروعات الإقتصادية ذات الحجم الصغير في الغالب.

وقد نظم المشرع أحكام شركة التضامن في المواد ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من قانون التجارة القديم، وأحال في بقية الأحكام إلى القواعد العامة لعقد الشركة الواردة في التقنين المدني، فضلاً عن الشروط المتفق عليها بين الشركاء في عقد الشركة.

ونتناول في دراستنا لشركة التضامن، أحكام تكوينها وشهرها (مطلب أول)، حياة الشركة أو نشاطها (مطلب ثان).

المطلب الأول أحكام تكوين وشهر شركة التضامن

أولاً: تكوين شركة التضامن:

عرفت المادة ٢٠ من قانون التجارة القديم شركة التضامن بأنها: شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم، تحت عنوان مخصوص يكون لها، للقيام بالأعمال التجارية. ونصت المادة ٢٢ تجاري بأن يكون الشركاء فيها مسئولين على وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.

ويبدو واضحاً قصور هذا التعريف عن بيان حقيقة شركة التضامن وخصوصيتها عن بقية الشركات، ذلك أنه تضمن قصد الاتجار، في حين أن هذا القصد ليس من مستلزمات شركة التضامن ذاتها، كما أنه أغفل أهم خصائص الشركة، وهو المسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء عن ديون الشركة.

وبصفة عامة لا تنشأ شركة التضامن إلا بناء على عقد، وتبدو الطبيعة التعاقدية لتبرير هذه الشركة بصورة أوضح منها في الشركات التي يغلب عليها طابع النظام القانوني، كشركات الأموال، ومن ثم فهي تخضع، من حيث انعقادها، للأحكام العامة في العقود، فيجب أن يتوفر لها الأركان الموضوعية العامة، والأركان الخاصة لعقد الشركة-على النحو السابق- وإلا كان العقد باطلاً، إلا إذا أمكن الاعتراف بآثارها كشركة فعلية.

كما يجب أن يتوافر لعقد شركة التضامن الركن الشكلي، بأن يكون العقد مكتوباً، ويسري تطلب الكتابة على كل تعديل يرد على أي من شروط العقد، وتعتبر الكتابة ركن انعقاد وليس مجرد شرط للإثبات، بحيث يترتب على تخلفها بطلان العقد، وهو بطلان من نوع خاص، يجوز أن يتمسك به كل من الشركاء في مواجهة الآخر، دون أن يكون لهم التمسك به في مواجهة الغير، بينما يجوز للغير أن يتمسك به في مواجهة الشركة والشركاء، إذا كان له مصلحة في ذلك، ولا يرتب البطلان أثره إلا من تاريخ الحكم به.

ثانياً: شهر عقد شركة التضامن وجزاء إغفاله:

شهر العقد: أوجب القانون شهر شركة التضامن لإعلام الغير بتأسيس الشركة وقيام شخصيتها المعنوية^(١)، وتمثل إجراءات شهر شركة التضامن في الخطوات الآتية:

١- إيداع ملخص عقد الشركة قلم كتاب المحكمة التجارية التي يوجد في دائرتها مركز الشركة أو في المحكمة التابع لها فرع من فروعها، ليسجل في السجل المعد لذلك، وذلك ليتمكن كل من يهمه الأمر من الإطلاع على هذا الملخص أو يحصل على صورة منه (م ٤٨ تجاري).

٢- لصق ملخص عقد الشركة لمدة ثلاثة أشهر في اللوحة المعدة في المحكمة للاعلانات القضائية (م ٤٨ تجاري).

٣- إدراج ملخص العقد في إحدى الصحف التي تطبع في مركز الشركة وتكون معدة لنشر الاعلانات القضائية، أو في صحيفتين تطبعان في مدينة أخرى (م ٤٩).

وتوجب المادة (٥١) تجاري أن يتم الايداع والاصق والنشر في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ آخر توقيع للشركاء على عقد الشركة أو على أي تعديل يطرأ عليه، حيث توجب المادة (٥٨) شهر التعديلات التي تطرأ على ملخص العقد، سواء انصبت التعديلات على مدة الشركة أو على عنوانها أو على تسمية أحد المديرين أو إخراج أحد الشركاء منها أو ضم أحد من الغير إليها..

هذا ولا يقتصر واجب شهر ملخص العقد على عاتق مدير الشركة فقط، فقد أجازت المادة ٤٩ تجاري لكل من الشركاء القيام به في حالة إهمال الباقيين، وينبغي أن يذيل ملخص العقد بتوقيع الشريك الذي قام بإجراءات الشهر والنشر إذا كان العقد التأسيسي للشركة عرفياً، وبتوقيع الموظف الرسمي الذي حرر أمامه العقد إذا كان رسمياً (م ٥٦ تجاري).^(١)

بيانات ملخص العقد الواجب شهره:

استلزم المشرع في المادة (٥٠) تجاري أن يتضمن الملخص الخاضع للشهر البيانات الآتية: أسماء وألقاب وصفات الشركاء ومسكنهم، عنوان الشركة، أسماء الشركاء المأذونين بالإدارة والإمضاء باسم الشركة، وقت ابتداء الشركة ووقت انتهائها.

وتمثل هذه البيانات الحد الأدنى لما يجب أن يشمله ملخص عقد الشركة المشهر من بيانات، ومن ثم يجوز للشركاء أن يضيفوا إلى ملخص العقد المقدم للشهر بيانات أخرى، كالغرض من الشركة ومركز إدارتها الرئيسي ومقدار رأس المال وحدود السلطات المخولة للمديرين وأثر خروج أو وفاة أحد الشركاء على مصير الشركة...

الشهر في السجل التجاري: وبجانب إجراءات الشهر التي أوجبتها المجموعة التجارية، استلزم قانون السجل التجاري رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ طريفاً آخر لشهر شركة التضامن، وهو قيدها في السجل التجاري، بأن يقوم مديروها ب قيد بيانات خاصة بها خلال شهر من تاريخ تأسيسها، فضلاً عن ضرورة التأشير في السجل بكل التعديلات التي تطرأ على هذه البيانات.^(٢)

غير أن إغفال قيد الشركة في السجل التجاري لا يؤثر على صحة الشركة، ولا يترتب على هذا الإغفال سوى جزاء جنائي يتمثل في عقوبة الجنحة، كما أنه لا يغني في حالة القيام به عن إجراءات الشهر الواردة في قانون التجارة، والذي يترتب على تخلفه بطلان عقد الشركة، وهو بطلان من نوع خاص، نتناوله بالتوضيح في الموضوع التالي.

جزاء تخلف شهر العقد: البطلان هو الجزاء المقرر قانوناً على تخلف أي من إجراءات شهر عقد شركة التضامن (الإيداع والالصق والنشر في الصحف)، أو شهر التعديلات التي قد ترد على بيانات العقد الواجب شهرها وفقاً للمادة (٥٠ تجاري)^٥، حيث تقضي المادة ٥١ تجاري على أنه: "يجب استيفاء إجراءات الشهر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وضع الإمضاء على المشاركة وإلا كانت الشركة لاغية".

ومن خلال الأحكام التي تضمنها القانون للبطلان المترتب على إغفال إجراءات الشهر، يتضح أن هذا البطلان، هو بطلان من نوع خاص، فلا هو بالبطلان المطلق، بالرغم من جواز التمسك به من كل ذي مصلحة، ومن حيث إمكانية الدفع به ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ولا هو بالبطلان النسبي، بالرغم من جواز تصحيحه، ومن حيث عدم قدرة المحكمة على القضاء به من تلقاء نفسها، وإنما هو بطلان يكتسب طبيعة خاصة، تبدو سواء من حيث من له حق المطالبة به، أو من حيث ما يترتب من آثار.

من له حق التمسك بالبطلان لتخلف الشهر: البطلان لتخلف الشهر لا يقع بقوة القانون، ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وإنما يتعين أن يتمسك به صاحب المصلحة المشروعة منه^٦، وأصحاب المصلحة في طلب البطلان هم دائنو الشركة والشركاء والدائنون الشخصيون للشركاء:

- ففيمما يتعلق بدائني الشركة، فإن لهؤلاء الخيار بين طلب البطلان أو الإعراض عنه، فقد تكون لدائني الشركة مصلحة في طلب البطلان، كما لو رتب مدير الشركة رهناً على أحد عقاراتها، فإن البطلان يترتب عليه اعتبار الرهن كأنه من غير مال، فيستردون حقهم في التنفيذ على المال بعد انحلاله ببطلان الشركة، وعلى ذلك لدائن الشركة الحق في التنفيذ على أموالها دون أن يتمكن الشركاء من الاحتجاج في مواجهته ببطلانها لعدم شهرها، كما أن للغير مطالبة الشريك بتقديم حصته في رأس مال الشركة ولا يكون للشريك دفع المطالبة بأن الشركة باطلة لعدم شهرها.

يبد أن الغالب أن تكون مصلحة دائن الشركة في عدم طلب البطلان والابقاء على الشركة، حتى لا يتعرض لخطر مزاحمة الدائنين الشخصيين للشركاء على أموال الشركة، فيما لو قضي بالبطلان واعتبار أموال الشركة ملكاً للشركاء.

فإذا تمسك بعض الدائنين بالابقاء على الشركة وطلب بعضهم إبطالها، فيجب في هذه الحالة القضاء بالبطلان، لأنه هو الأصل في حالة تخلف إجراءات الشهر.

- وللشركاء مصلحة في التمسك ببطلان الشركة كل في مواجهة الآخر، حتى يتمكن من استرداد الحصة التي قدمها في رأس المال، إذ لا يجبر الشريك على البقاء في شركة مهددة بالبطلان لعدم شهرها^(١)، على أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم (م ٥٣)، وذلك لأن الشركاء ملزمون قانوناً بالشهر، والقاعدة أنه يمتنع على الشخص أن يفيد من إهماله وتقصيره في القيام بما يفرضه عليه القانون، كما لا يجوز للشركاء التمسك بهذا البطلان على دائني الشركة عند قيام هؤلاء بمقاضاتهم والتنفيذ على أموالهم.^(٢)

- كما أن للدائنين الشخصيين للشركاء الحق في طلب بطلان الشركة، بغرض إعادة حصة مدينهم في رأس مال الشركة إلى ذمته المالية ودخولها في الضمان العام المقرر لهم على أموال هذا المدين من الشركاء.

أما مدينو الشركة فليس لهم في الأصل حق التمسك ببطلانها لعدم الشهر، للتخلص من تنفيذ التزاماتهم قبلها، ويلتزمون بالوفاء بديونهم قبل الشركة سواء شهرت أم لم تشهر، إذ يتعارض مع حسن النية القول بأن للمدين مصلحة في التمسك ببطلان الشركة في هذه الصورة ليتحلل من تنفيذ التزامه قبلها، ومع ذلك يمكن القول بأن مدين الشركة أو مدين الشريك تنشأ له مصلحة مشروعة في طلب بطلانها لعدم شهرها، إذا كان له دين في ذمة أحد الشركاء وأراد أن يتمسك بالمقاصة بين الدينين، ولكن ليس باعتباره مديناً للشركة، وإنما بوصفه دائماً شخصياً لأحد الشركاء، إذ الراجح فقهاً، كما أسلفنا، أن للدائن الشخصي للشركة أو للشركاء أن يتمسك بالبطلان في هذه الحالة حتى يتمكن من التنفيذ على حصة مدينه.

تصحيح البطلان:

إذا استوفي الشركاء إجراءات الشهر قبل الحكم ببطلان الشركة، فحينئذ يزول البطلان ويمتنع الحكم به (م ٥٢)، وقد راعى المشرع بهذا الحكم أن بطلان الشركة لعدم شهرها هو بطلان لسبب شكلي، وقد تكون الشركة قد ظلت، في الفترة السابقة على استيفاء إجراءات الشهر، تتعامل مع الغير وتتشابك معاملاتهما بما ترتبه من حقوق والتزامات متبادلة، فأراد أن يحد من الآثار السلبية التي يربتها البطلان على كافة الأطراف من الناحيتين القانونية والاقتصادية، وأن يغلب المصلحة الجماعية الأجدر بالرعاية على المصلحة الفردية لطالب البطلان.

إلى هذا، فقد أجاز القانون للشركاء القيام بإجراءات الشهر، ولو بعد انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً المقررة لإجرائه، فيمتنع على إثره طلب البطلان من الغير الذي نشأت حقوقه بعد القيام بإجراءات الشهر، لأن حقوقه نشأت في مواجهة شركة استوفت من قبل إجراءات الشهر، كما يمتنع كذلك - وفقاً للرأي الراجح فقهاً - التمسك بالبطلان من قبل الغير ممن تولدت حقوقهم قبل الشركة قبل عمل إجراءات الشهر، بالنظر إلى إطلاق نص المادة ٥٢ تجاري قديم، التي تقضي بزوال البطلان بصفة عامة دون تفريق، كما يمتنع على الشركاء التمسك بالبطلان في مواجهة بعضهم البعض.^(١)

آثار البطلان:

إذا انتهى الأمر بصدور الحكم ببطلان الشركة، فإن أثر البطلان يختلف باختلاف الشخص الذي يتمسك به، وذلك على التفصيل الآتي:

فإذا قضى بالبطلان بناء على طلب أحد الشركاء، فإن أثره يقتصر على المستقبل ولا يمتد إلى الماضي، وعلى ذلك تصفى الشركة ويقتسم الشركاء أموالها، وتعتبر الشركة فيما بين الشركاء، في الفترة ما بين انعقادها والحكم ببطلانها، بمثابة شركة فعلية، فتبقى آثارها وتسري شروط عقد الشركة على تسوية حقوق الشركاء فيما يتعلق بالأعمال السابقة على انقضائها (م ٥٤ من التقنين التجاري القديم)، وذلك على التفصيل الذي أسلفناه بشأن أحكام الشركة الفعلية.

أما لو حكم ببطلان الشركة بناء على طلب الغير، فتطبق أحكام القواعد العامة في البطلان، فتعتبر الشركة بالنسبة له كأن لم تكن، سواء في الماضي أو المستقبل، ومن ثم فلا تسري في حقه أعمال الشركة وما يترتب عليها من آثار في الفترة ما بين انعقاد الشركة والحكم ببطلانها.

المطلب الثاني

حياة شركة التضامن

إذا استوفى عقد شركة التضامن أركانه كاملة، نشأ على إثره شخص معنوي، يتميز بخصائص معينة، ويكون قادراً على ممارسة نشاطه وحياته المستقلة عن الأشخاص المكونين له، وذلك عن طريق أشخاص يمثلونه ويعبرون عن إرادته ويبرمون التصرفات القانونية باسمه ولحسابه.

وعلى هذا نتناول فيما يتعلق بحياة شركة التضامن، خصائص الشركة، وإدارتها، وأحكام توزيع الأرباح والخسائر.

الفرع الأول: خصائص شركة التضامن

تتميز شركة التضامن بأربعة خصائص هي: المسؤولية المطلقة والتضامنية للشركاء عن ديون الشركة في جميع أموالهم، وعدم قابلية حصة الشريك فيها للتداول، وأن للشركة عنواناً يتكون من أسماء الشركاء، فضلاً عن اكتساب جميع الشركاء فيها صفة التاجر.

أولاً: المسؤولية المطلقة والتضامنية للشركاء عن ديون الشركة:

يسأل الشركاء في شركة التضامن عن ديون الشركة مسؤولية شخصية، وعلى وجه التضامن، شريطة أن يحصل التوقيع على التصرف الذي أدى إلى مديونية الشركة باسم الشركة، وفي ذلك تنص المادة ٢٢ تجاري على أن "الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الإمضاء عليها إلا من أحدهم، إنما يشترط أن يكون هذا الإمضاء بعنوان الشركة". والمسؤولية الشخصية للشريك عن ديون الشركة تعني، مسؤوليته عن هذه الديون في ذمته المالية مسؤولية غير محدودة، بحيث لا تقف هذه المسؤولية عند حدود حصته في رأس مال الشركة، وإنما تتعدى هذه الحصة لتشمل ذمته المالية بشكل مطلق، كما لو كانت هذه الديون ديوناً خاصة به، وهذا الحكم من النظام العام، ومن ثم يقع باطلاً كل شرط يعفي الشريك من مسؤوليته المطلقة عن هذه الديون أو يحصرها في حدود حصته في رأس مال الشركة، سواء ورد الشرط في عقد الشركة أو في اتفاق لاحق، دون أن ينال هذا البطلان من عقد الشركة، غير أن هذا الاتفاق صحيح فيما بين الشركاء، وعندئذ تكون مسؤولية الشريك في مواجهة باقي الشركاء محدودة بمقدار حصته في رأس المال.^(١)

ويفسر الفقه هذه المسؤولية الشخصية للشريك المتضامن، بأن تعهدات الشركة يتم التوقيع عليها بعنوان الشركة الذي يحتوي على اسم الشريك المتضامن صراحة أو ضمناً، ومن ثم يعتبر كل شريك كأنه وقع بنفسه على هذه التعهدات، فيسأل شخصياً عن الديون الناشئة عنها، وبحيث يكون لدائن الشركة، في هذه الحالة، عدة مدينين: الشركة ذاتها بوصفها شخصاً اعتبارياً، وكل شريك على حدة، ويتقرر له ضمان عام على أموال الشركة يكون مخصصاً له، وضمنان عام آخر بشكل إضافي على أموال الشركاء يتزاحمون عليه مع الدائنين الشخصيين للشركاء، فإذا لم تكف أموال الشركة للوفاء بديونها، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة.^(٢)

كما يسأل الشريك في شركة التضامن عن ديون الشركة مسؤولية تضامنية، وهو ما يعني أن لدائن الشركة أن يرجع بدينه ليس فقط على الشركة، كشخص معنوي، وإنما على كل من

الشركاء حتى يستوفي منهم جميعاً أو من أحدهم دينه كاملاً، فالشركاء جميعاً مسئولون بالتضامن في مواجهة دائني الشركة، وعلى ذلك فإن لدائني الشركة الحق في مزاحمة الدائنين الشخصيين للشركاء في الرجوع والتنفيذ على أموالهم الخاصة، وهذا واضح من نص المادة ٢٢ تجاري التي تقضي بأن: "الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها..".

وعلى هذا يقوم التضامن، في الالتزام بالوفاء بديون الشركة، بين الشركاء وبعضهم البعض من ناحية، وبين الشركاء والشركة ذاتها، باعتبارهم كفلاء متضامنون، ويقتضي تطبيق أحكام الكفالة التضامنية في القواعد العامة، أن يكون لدائن الشركة حق الاختيار في المطالبة بدينه بين الشركة أو أي من الشركاء.

إلا أن تطبيق هذه القواعد لما كان من شأنه أن يضع الشريك المتضامن تحت رحمة دائن الشركة، ويعرضه لعنت الدائن وعسفه في توجيهه المطالبة إلى الشريك، بالرغم من أن الشركة قد تكون في حالة يسر مالي يسمح بسداد الدين، فإن القضاء قد خرج عن تطبيق هذه القواعد العامة في شأن الكفالة التضامنية، وقيد حق الدائن في مطالبة الشريك أو التنفيذ على أمواله بقيدين جرى عليهما العرف التجاري وهما:

- ١- ثبوت الدين في ذمة الشركة سواء بإقرار من مدير الشركة أو بمقتضى حكم قضائي.
 - ٢- أن يقوم الدائن بإعذار الشركة بالوفاء، سواء تم ذلك بإنذار أو بتحرير بروتستو عدم الدفع أو بأي إجراء مماثل، بما يثبت امتناع الشركة عن الوفاء في ميعاد معقول يحدده الدائن.
- ذلك أن هذا التضامن لا يجعل من الشركاء مدينين أصليين مع الشركة في هذه الديون، لأن التعاقد يتم باسم الشركة ولحسابها، دون أن يكون الشركاء طرفاً فيه، بل مجرد كفلاء متضامين، فإذا استوفى الدائن هذين الشرطين، جاز له أن ينفذ على الأموال الخاصة بأي من الشركاء المتضامين في الشركة.^(١)

فإذا أوفى أحد الشركاء بدين على الشركة جاز له أن يرجع بما وفاه على الشركة، وجاز له أيضاً أن يرجع على كل من الشركاء الباقين كل بقدر حصته في الدين (م ٢٩٧ مدني)، وإذا كان أحد الشركاء معسراً، تحمل تبعة هذا الإعسار الشريك الذي وفي الدين وسائر الشركاء الموسرين كل بقدر حصته (م ٢٩٨ مدني).

نطاق مسؤولية الشريك الشخصية والتضامنية:

الأصل أن الشريك يظل مسؤولاً عن ديون الشركة طالما ظل عضواً في الشركة، وتستمر مسؤوليته حتى بعد انقضاء الشركة وتصفيتهما وإلى أن تنتهي مدة التقادم الخمسي، غير أن تطبيق هذه القاعدة يثير بعض الخلافات الفقهية، خاصة فيما يتعلق بتحديد مسؤولية الشريك المنضم إلى الشركة، أو في حالة انسحاب أحدهم منها أو تنازله عن حصته للغير، وذلك على النحو التالي:

مسؤولية الشريك المنضم:

تقوم المسؤولية التضامنية والشخصية للشريك المتضامن عن ديون الشركة التي نشأت عن الأعمال التي أبرمتها الشركة حال كونه شريكاً فيها، وقد استقر الرأي على أن الشريك المتضامن يعتبر مسؤولاً أيضاً عن ديون الشركة السابقة على انضمامه للشركة، لأنها عقدت باسم الشركة كشخص معنوي، على أنه يجوز الاتفاق على عدم مسؤولية الشريك الجديد عن ديون الشركة وقصر مسؤوليته على الديون اللاحقة لانضمامه، ولا يحتج بهذا الاتفاق على الدائنين إلا إذا تم شهره.^(١)

مسؤولية الشريك المنسحب:

إذا خرج الشريك من الشركة، في الأحوال التي يجوز له فيها ذلك مع استمرار الشركة فيما بين الشركاء، فلا مراء في استمرار مسؤوليته عن الديون التي نشأت في ذمة الشركة إلى تاريخ هذا الخروج، أما الديون والتعهدات التي تلت هذا الخروج، فلا يسأل عنها بشرط شهر خروجه من الشركة وحذف اسمه من عنوان الشركة إذا كان اسمه مدرجاً في العنوان، فإذا اختل أي من هذين الشرطين، ظل الشريك المنسحب مسؤولاً عن الديون التي نشأت بعد الانسحاب.^(٢)

أما إذا تنازل شريك عن حصته لآخر، فإنه لا يسأل عن الديون اللاحقة على تنازله ويسأل عنها المتنازل إليه، شريطه شهر هذا التنازل، ويثور في هذا الشأن أيضاً ما يتعلق بحكم الديون السابقة على شهر التنازل، وبمعنى آخر هل يتضمن التنازل عن الحصة حوالة الديون إلى المتنازل إليه؟

يرى بعض الفقهاء أن التنازل عن الحصة في الشركة لا ينطوي على حوالة للديون، وإنما حلول للمتنازل إليه محل المتنازل في حقوقه والتزاماته، فتبرأ به ذمة المتنازل عن ديون الشركة السابقة دون ما حاجة لرضاء الدائنين.^(٣)

والراجح فقهاً وقضاءً هو تقرير مسؤولية المتنازل الشخصية والتضامنية عن هذه الديون، حتى ولو كان قد اشترط على المتنازل إليه صراحة أن يحل محله في هذه الديون، ومرجع ذلك إلى أن التنازل ينطوي على حوالة دين، ولا تسري هذه الحوالة على الدائن إلا إذا أقرها، فإن حصل هذا الإقرار برئت ذمة المتنازل عن الديون السابقة على شهر تنازله وانتقلت إلى ذمة المتنازل إليه، وإلا ظلت ذمة المتنازل مشغولة بهذه الديون.^١

ثانياً: عدم جواز انتقال الحصص إلى الغير:

تقوم شركة التضامن، كما قدمنا، على الاعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء، ومن ثم فلا يجوز للشريك، بحسب الأصل، التنازل عن حصته بعوض أو بغير عوض إلى الغير دون موافقة باقي الشركاء، ذلك أن الشركاء قد وثقوا بشخص معين، فلا يجوز إجبارهم على قبول شخص آخر قد لا يعرفونه أو يولونه ذات الثقة التي أولوها لبعضهم البعض عند تكوين الشركة، ولنفس الحكمة فإنه يترتب على وفاة الشريك في شركات الأشخاص انقضاء الشركة.

على أن قاعدة عدم قابلية انتقال حصص الشريك في شركة التضامن، وفي شركات الأشخاص عموماً، لا تتعلق بالنظام العام، لذا يجوز الاتفاق في العقد التأسيسي للشركة على أنها لا تنقضي بخروج أحد الشركاء منها أو بوفاته أو بانتقال الحصة إلى شخص آخر، على أن يتم ذلك بشروط وقيود معينة، كاشتراط موافقة جميع الشركاء أو غالبيتهم على المتنازل إليه، أو على إمكان تداولها، على أن يكون لبقية الشركاء حق الاعتراض على المتنازل إليه خلال مدة معينة أو حق استرداد الحصة نظير دفع الثمن، أو غير ذلك من القيود.

فإذا لم يتضمن عقد الشركة قيوداً على انتقال الحصص، أو لم ينظم هذه المسألة، فإن تحويل الحصة إلى الغير، لما كان يعد بمثابة تعديل لعقد الشركة، فإن الأمر يتطلب إجماع الشركاء على هذا التعديل، إذ بهذه الموافقة الإجماعية يقوم الاعتبار الشخصي فيمن يتنازل له الشريك عن حصته، ولكن لا يسوغ النص في عقد الشركة على إمكانية التنازل عن الحصة دون قيد أو شرط، نظراً لما في ذلك من إهدار للاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركة التضامن^٢، كما أن حظر التنازل للغير لا يشمل نقل ملكية الحصة لأحد الشركاء، لانتفاء الحكمة من الحظر وهي إقحام شخص لا يتوفر فيه الاعتبار الشخصي بين الشركاء.^٣

كما يجوز للشريك دائماً أن يرهن حقه المترتب على تقديم حصته في الشركة، وللدائن المرتهن ولغيره من الدائنين أن يحجزوا على هذا الحق طبقاً لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير، وتؤدي

في هذه الحالة الأرباح المستحقة للشريك إلى الدائن الحاجز، كما يؤدي إليه نصيب الشريك في فائض التصفية عند انتهاء الشركة، كما يجوز لهؤلاء الدائنين أن يحجزوا على حصة الشريك في الشركة وبيعها بيعاً جبرياً.^(١)

وإذا كان التنازل عن الحصة للغير محظوراً، كقاعدة، فإنه يجوز مع ذلك للشريك دون حاجة موافقة باقي الشركاء، أن يرم مع شخص آخر ما يعرف في العمل باتفاق "الرديف Croupier" والذي بموجبه يحل هذا الأخير محله في كل الحقوق والالتزامات الناشئة عن حصته في الشركة أو في جزء منها فقط.^(٢)

والرديف شريك من الباطن للشريك صاحب الحصة، ويقتصر أثر الاتفاق بينه وبين الشريك على العلاقة بين الشريك والرديف، فلا تنشأ عنه علاقة مباشرة بين هذا الرديف وبين الشركة، فيظل أجنبياً عنها، ولا يجوز له التدخل في الإدارة أو مطالبة الشركة بالأرباح أو طلب الإطلاع على دفاترها ومستنداتها، فكافة هذه الحقوق منوط مباشرتها بالشريك، ويقتصر حق الرديف في مطالبة الشريك بنصيبه في أرباح الحصة، كما أنه ليس للشركة مطالبة الرديف بما يخص نصيبه في الحصة من خسارة أو بباقي الحصة التي تعهد الشريك المتنازل بتقديمها.^(٣)

ثالثاً: عنوان شركة التضامن:

لشركة التضامن عنوان يميزها عن غيرها من الشركات، تعرف به في الوسط التجاري وتوقع بها التعهدات والعقود التي تتم لحساب الشركة، ولا تلتزم الشركة بالتعهدات التي يوقعها أحد الشركاء إذا لم يكن التوقيع بعنوان الشركة.^(٤)

ووفقاً للمادة ٢٠ تجاري تؤلف شركة التضامن بين شخصين فأكثر للقيام بأعمال تجارية، وعلى هذا يتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء الذين تتألف منهم الشركة، والذين يعتمد عليهم الغير في تعامله مع الشركة، تعبيراً عن المسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء عن ديون الشركة، فإذا كان عدد الشركاء كبيراً، فإنه يجوز الاختصار على ذكر واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة "وشركاه، أو شركاؤهما، أو شركاؤهم"، والغالب أن يتضمن عنوان الشركة اسم أو أسماء من يتمتع من الشركاء بأكبر قدر من الشهرة أو الثقة التجارية، وإذا تكونت الشركة بين أفراد من أسرة واحدة، فقد جرى العمل على الاكتفاء بذكر اسم العائلة، مع إضافة ما يبين درجة القرابة بينهم مثل عبارة "إخوان ونحوها".

ولا يجوز أن يضم عنوان الشركة إلا أسماء الشركاء، فإذا ذكر في العنوان اسم شخص أجنبي عنها مع علمه بذلك كان مسؤولاً عن ديونها على وجه التضامن، وذلك حماية للوضع الظاهر، وحماية للغير الذي يتعامل مع الشركة اعتماداً على اسم هذا الأجنبي عنها، ومن ثم يجب أن يعامل هذا الشريك الظاهر في علاقته بالغير حسن النية كما لو كان شريكاً حقيقياً، طبقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية، أما إذا كان الغير سيئ النية، بأن كان يعلم بأن من وضع اسمه في عنوان الشركة هو شخص أجنبي عنها، فلا يسأل هذا الأخير في مواجهته.^(١)

ولذات الحكمة السابقة، فإنه إذا تغير أشخاص الشركاء أو خرج أحدهم منها أو توفي واستمرت الشركة رغم ذلك، وجب تعديل العنوان بحيث يحذف منه اسم الشريك الذي خرج من الشركة، حتى لا يظهر في العنوان إلا الشركاء المسؤولون عن ديونها مسؤولية شخصية وتضامنية، وعلى ذلك إذا تحول شريك متضامن في الشركة إلى شريك موص تعين استبعاد اسمه من عنوان الشركة.^(٢)

رابعاً: اكتساب الشريك صفة التاجر:

يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر، ولو لم تكن له هذه الصفة قبل الدخول في الشركة، وذلك لأن الشريك المتضامن يسأل مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، الأمر الذي يجعله في مركز يماثل مركز من يمارس التجارة باسمه ولحسابه منفرداً، فضلاً عن أن ورود اسم الشريك في عنوان الشركة، وهو الذي يوقع به على عقودها ومعاملاتها، يجعله كأنه قد أجرى التصرف باسمه ولحسابه.

ويستوجب اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر أن تتوافر له الأهلية اللازمة لاحتراف التجارة، وذلك ببلوغه سن الرشد معافي من الآفات العقلية، كما يمتنع على الأشخاص المحظور عليهم ممارسة التجارة الدخول كشركاء في شركة التضامن، كما يترتب على اكتساب الشريك صفة التاجر تحمله بالالتزامات الواجبة على التجار، فعليه أن يمسك دفاتر تجارية بطريقة تكفل بيان مركزه المالي المترتب على اعتباره عضواً في الشركة، كقيد مصاريفه ومسحوباته الشخصية، والأرباح المستحقة له عن أعمال الشركة وما قد يكون عليه من التزامات قبلها، بيد أن الشريك لا يلتزم بالقيد في السجل التجاري، اكتفاء بإدراج اسمه في عقد الشركة الواجب قيده في السجل التجاري ضمن البيان الخاص بأسماء التجار.^(٣)

وإذا حكم بإشهار إفلاس شركة التضامن استتبع ذلك إفلاس جميع الشركاء فيها، وذلك لأن الشركاء يكتسبون صفة التاجر ويسألون بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة، فيعتبر عجز الشركة وتوقفها عن دفع ديونها، توقفاً وعجزاً للشركاء، فتتحقق بشأنهم شروط شهر الإفلاس، وهكذا تتعدد التفليسات وتستقل، فتكون للشركة تفليسة تقتصر على دائئيتها، وتكون لكل شريك تفليسته المستقلة يتزاحم فيها دائئو الشركة ودائئوه الشخصيين. غير أن إفلاس أحد الشركاء في شركة التضامن لا يترتب عليه إفلاس الشركة، لأن الشركة غير مسؤولة عن ديون الشركاء، ولأن الشريك قد يعجز عن الوفاء بديونه، بينما تظل الشركة أو الشركاء الآخرون قادرون على الوفاء مع عدم الالتزام بديون الشريك المفلس، وإنما إفلاس أحد الشركاء يترتب عليه، كقاعدة عامة، انقضاء الشركة، لانحياز الاعتبار الشخصي للشريك.

الفرع الثاني: إدارة شركة التضامن

تستلزم شركة التضامن، كأى شخص معنوي، أن يكون لها شخص طبيعي يديرها ويعبر عن إرادتها ويقوم بأعمالها التجارية في حدود الأغراض المحددة لها، وبالنظر إلى عدم ورود أحكام خاصة لإدارة شركة التضامن في القانون التجاري، فلا بد، في حالة عدم نص الشركاء في العقد التأسيسي على كيفية إدارة الشركة كشخص معنوي، من الرجوع للأحكام الواردة في القانون المدني بشأن إدارة الشركة (المواد من: ٥١٦ إلى ٥٢٠).

وعلى هذا نعرض لقواعد إدارة شركة التضامن، من حيث: طريقة تعيين المدير وعزله، سلطاته، المسؤولية عن أعماله، وذلك وفق التفصيل الآتي:

الفصل الأول: تعيين المدير وعزله:

أولاً: تعيين المدير: الأصل، إذا لم يتحدد في عقد الشركة كيفية إدارتها، أن يعد كل شريك مفوضاً من باقي الشركاء بإدارة الشركة والقيام بأعمالها أمام الغير وتمثيلها أمام القضاء دون الرجوع إلى غيره من الشركاء، على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهنم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض (م ٥٢٠ مدني).^(١)

ويترتب على تعيين مدير أو أكثر للشركة أثر قانوني هام، هو استثنائه وحده بسلطة إدارة الشركة وتسيير أمورها دون تدخل من بقية الشركاء في هذه الإدارة^(٢)، وبما يعني سقوط حق بقية الشركاء في الإدارة أو الاعتراض على عمل المدير، وإلا ما كان لتعيين مدير للشركة ثم فائدة خاصة، فضلاً عما يترتب على المعارضة من تعطيل لعمل الشركة.

ويقتصر حق الشركاء فقط على رقابة هذه الإدارة، فيكون لكل شريك أن يطلع بنفسه على مركز الشركة وعلى سير أعمالها، وأن يفحص دفاترها ومستنداتها بما لا يضر بمصالحها أو بسرية أعمالها، وأن يوجه النصح لمديرها بما يحقق مصلحة الشركة، ويعتبر هذا الحق من الحقوق الشخصية للشريك وفقاً للاعتبار الشخصي الذي يسود شركات الأشخاص، ومن ثم فليس له أن ينبب عنه غيره في ممارسة حق الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويعتبر هذا الحق من النظام العام، ومن ثم يقع باطلاً كل اتفاق يقضي بحرمان الشريك منه (م ٥١٩ مديني).

وقد جرت العادة على أن يعهد بإدارة الشركة لواحد أكثر من الشركاء المتضامنين، بحيث تكون له مصلحة في إدارة الشركة فيحسن إدارتها على الوجه الأكمل، اعتباراً لمسئوليته الشخصية عن ديونها وإفادته من أرباحها، كما أن اختيار أحد الشركاء لإدارة الشركة يرجع أيضاً إلى الدور الخطير لمدير الشركة في تمكنه، بصفته تلك، من التوقيع بعنوان الشركة على نحو يلزم سائر الشركاء، لذلك فقليلاً ما يحدث أن يعهد بإدارة شركة التضامن لشخص من غير الشركاء، بل والغالب أن يعهد بذلك لأهم الشركاء وأكبرهم نصيباً في حصص الشركة وأكثرهم ملاءة وثقة مالية وقدرة على الإدارة.^(١)

المدير الإتفاقي والمدير غير الإتفاقي:

ومدير الشركة، شريكاً كان أو غير شريك، إما أن يعين بنص خاص في عقد الشركة، فيسمى في هذه الحالة بـ "المدير النظامي أو الإتفاقي"، كما تضافى هذه التسمية أيضاً، حتى ولو لم ينص عقد الشركة على تعيين مدير معين، على المدير إذا تم تعيينه في وقت لاحق لتكوين الشركة بمقتضى تعديل للعقد باتفاق الشركاء على تعيين مدير للشركة.

أما إذا لم يتضمن عقد الشركة تعيين مدير لها، وقام الشركاء بتعيين المدير، سواء كان من الشركاء أو من غير الشركاء، وقام الشركاء بتعيينه في اتفاق مستقل عن العقد، سمى هذا المدير بـ "المدير غير النظامي أو غير الإتفاقي".^(٢)

وقد استقر الرأي على أن مدير الشركة إذا كان اتفاقياً فإنه لا يعتبر مجرد وكيل عن الشركة، وإنما عضواً في الشركة، كشخص معنوي، وجزءاً منها وعنصراً من عناصرها، أما المدير غير الإتفاقي فلا يعدو أن يكون وكيلاً عن الشركة وتسري عليه أحكام الوكالة بأجر.

ويجب أن يتوفر فيمن يعهد إليه بإدارة الشركة الأهلية القانونية، ويفترض توافر هذه الأهلية في حالة كان المدير من الشركاء، حيث يشترط القانون، كما أسلفنا، أن يكون الشريك المتضامن

كامل الأهلية، بالنظر إلى مسؤوليته المطلقة والتضامنية واكتسابه صفة التاجر، وإن كان غير شريك فتشترط فيه الأهلية لأنه يسأل في مواجهة الشركة والشركاء والغير عما يقع منه أخطاء تعاقدية أو تقصيرية، وإن كانت الإدارة لشخص معنوي يشترط أن يكون ممثله القانوني كامل الأهلية.^(١)

ثانياً: عزل المدير: تختلف القواعد الخاصة بعزل مدير شركة التضامن باختلاف صفته وطريقة تعيينه:

أ- عزل المدير الشريك الاتفاقي:

فإذا اجتمع في مدير الشركة كونه نظامياً، جرى تعيينه في عقد التأسيس، وشريكاً في الشركة، فإنه لا يجوز عزله إلا بإجماع الشركاء بمن فيهم المدير ذاته، لأنه، وقد تم تعيينه في عقد الشركة، أصبح جزءاً من العقد، والعقد لا يجوز تعديله إلا بموافقة جميع الشركاء. بيد أنه يجوز للشركاء، في حالة لم يتوفر هذا الإجماع أو أبى المدير الاتفاقي الشريك النزول على إرادة الشركاء بعزله، طلب عزل المدير من المحكمة إذا وجد مسوغ لهذا الطلب، كما إذا أساء الإدارة أو ارتكب عملاً من أعمال الخيانة أو لم يعد قادراً على العمل، وللمحكمة في هذه الحالة سلطة تقدير قيمة هذا المسوغ وما إذا كان يبرر عزل المدير من عدمه (م ١/٥١٦ مدني)، فإذا قضت المحكمة بعزل المدير لتوفر المسوغ المشروع ترتب على ذلك انقضاء الشركة، لأن تعيين هذا المدير بعينه كان أحد مقوماتها، بدلالة وروده في عقدها التأسيسي، وذلك إلا إذا تضمن العقد التأسيسي أو اتفق جميع الشركاء، وبموافقة المدير نفسه، على استمرار الشركة بالرغم من عزله.

كما أنه لا يجوز للمدير الاتفاقي الشريك أن يعتزل الإدارة إلا بموافقة الشركاء، أو لسبب مقبول، وإلا كان مسئولاً عن تعويض الأضرار التي يمكن أن تصيب الشركة من جراء ذلك، وإذا اختلف الشركاء في تقدير مدى معقولية الأسباب في هذه الحالة، فإن محكمة الموضوع هي الجهة المختصة بتقدير جدية وكفاية أسباب الاعتزال أو الاستقالة، ويتربط أيضاً على اعتزال هذا المدير انقضاء الشركة، ما لم ينص العقد أو يتفق الشركاء على خلاف ذلك.

ب- عزل المدير غير الاتفاقي:

إذا كان المدير غير اتفاقي، شريكاً كان أو غير شريك،، أو كان مديراً اتفاقياً غير شريك، فإنه يكون قابلاً للعزل بموافقة الشركاء، ودون حاجة إلى الحصول على رضائه أو صدور حكم

من القضاء، كما أنه يجوز له اعتزال الإدارة، دون أن يترتب على ذلك انقضاء الشركة، ويرجع ذلك إلى أن المدير غير الاتفاقي يعتبر وكيلاً عن الشركة، والوكالة يجوز إنهاؤها من الموكل أو الوكيل على السواء، إذا روعي في ذلك الوقت المناسب والإخطار المسبق، وفي ذلك تنص المادة (٥١٦/٢ و٣ مدني) : " وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي، أما المديرون من غير الشركاء فهم دائماً قابلون للعزل".

ويكون عزل الشريك غير الاتفاقي بذات قوة الأداة التي قامت بتعيينه، فإذا تم تعيينه بإجماع الشركاء، تعين توافر الاجماع في قرار عزله، بينما تكفي للعزل موافقة أغلبية الشركاء إذا كان تعيينه بالأغلبية، كما يظل من الجائز دائماً، كما في الحالة السابقة، لأي من الشركاء أن يطلب من المحكمة عزل الشريك غير الاتفاقي إذا توفر المسوغ المقبول.

الغصن الثاني: سلطات المدير:

أولاً: المدير الواحد:

يتضمن عقد الشركة، عادة، تحديد سلطات المدير بشأن التصرفات والأعمال التي يجوز له مباشرتها منفرداً أو بالرجوع فيها لغيره من الشركاء، وحينئذ يجب على المدير أن يلتزم حدود السلطات المحددة له في عقد الشركة، فإذا لم تحدد سلطة المدير في العقد أو في الاتفاق اللاحق الذي تم به تعيينه، كان له أن يقوم بكافة الأعمال والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، فإذا سكت العقد أو الاتفاق عن تحديد سلطات المدير، فالأصل أنه يفترض أن الشركاء قد منحوا المدير كافة السلطات اللازمة، والتي يتمكن بها من تحقيق غايات الشركة، وعلى ذلك يكون له القيام بكافة الأعمال التي تدخل في غرض الشركة، سواء كانت هذه الأعمال من أعمال الإدارة أم من أعمال التصرف (م ٥١٦ مدني).

وعلى هذا فيكون للمدير أن يبيع ويشترى ويقرض، وله أن يستأجر المساكن اللازمة لممارسة نشاط الشركة، وله أن يوقع على الأوراق التجارية، وأن يبرم عقود استخدام الموظفين وتسيير شئوونهم الوظيفية، ويمثل الشركة فيما ترفعه أو يرفع عليها من الدعاوى القضائية، وله الوفاء بديون الشركة واقتضاء حقوقها، كما له أن يتصلح على حقوق الشركة وأن يبرم عقود التحكيم إذا كان في ذلك مصلحة الشركة، وله بالإجمال أن يقوم بكافة الأعمال التي تدخل في غرض الشركة.

غير أنه لا يجوز للمدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز الإدارة العادية للشركة أو التي لا تتفق مع غرضها المحدد أو تجاوزه إلا بنص صريح في العقد أو بموافقة الشركاء، ويسري هذا الحظر على أعمال التبرع الغير معتادة، وبيع أو رهن عقارات الشركة إذا كان بيع العقارات لا يدخل في أغراضها، ويمتنع عليه كذلك بيع متجر الشركة أو رهنه، كما لا يجوز للمدير أن ينافس الشركة، بأن يمارس لمصلحته الخاصة نشاطاً من نوع النشاط الذي تمارسه الشركة، كما لا يجوز أن يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة إلا بإذن خاص من الشركاء يصدر في كل حالة على حدة، نظراً

لتعارض مصلحته الخاصة مع مصلحة الشركة ورجحان مظنة تفضيله الأولى على الثانية.^(١)

والأصل أنه ليس للمدير، بوصفه نائباً عن الشركة، أن ينيب عنه غيره في القيام بأعمال الشركة إذا لم يكن مرخصاً له في ذلك، على أنه إذا أناب عنه غيره في ممارسة عمل معين فإنه يعتبر مسئولاً بالتضامن مع النائب كما لو كان العمل صادراً من المدير، فإذا كان مرخصاً له بذلك بمقتضى نص في العقد دون تعيين شخص النائب، فلا يكون المدير مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار النائب وعن خطئه فيما أصدره له من تعليمات (م ٧٠٨ مدني).

ثانياً: سلطات المديرين في حالة تعددهم:

قد يعين الشركاء أكثر من مدير لإدارة الشركة، وقد يتحدد اختصاص كل منهم ، وقد يترك الأمر دون تحديد، وقد يتفق على أن يعملوا مجتمعين:

أ- فإذا ما عين الاتفاق اختصاص كل مدير، كأن ينص على اختصاص أحدهم بالمشتريات والثاني بالمبيعات والثالث بالأوراق التجارية، والثالث بشئون العاملين ..، تعين على كل منهم أن يعمل في الحدود المخصصة له دون أن يتعدها، وإلا كان تصرفه غير نافذ في حق الشركة.

ب- أما إذا لم يعين لكل مدير اختصاص معين ودون أن ينص على عدم جواز أن ينفرد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة المختلفة، إنما يكون لأي من المديرين الآخرين أن يعترض على العمل قبل تمامه، وعندئذ يعرض الأمر على المديرين جميعاً للبت فيه بالأغلبية، فإذا تساوى الجانبان عرض الأمر على الشركاء، وحينئذ تكون العبرة بالقرار الذي يصدر بالأغلبية العديدة للشركاء (م ١/٥١٧ مدني).^(٢)

ج- أما إذا اتفق على أن تكون قرارات المديرين في حالة تعددهم بالإجماع أو بالأغلبية، تعين احترام هذا الشرط ووجب عدم انفراد أي منهم بالإدارة، ويجوز الخروج على هذا الأمر بحيث يكون لأي منهم أن يعمل منفرداً، إذا كان هناك أمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة

لا تستطيع الشركة تعويضها (م ٢/٥١٧ مدني)، ويحدث ذلك في الأعمال ظاهرة النفع للشركة، وذلك كأن يقوم أحد المديرين ببيع بضاعة معرضة للتلف أو يقوم بتجديد قيد رهن قبل فوات ميعاد التجديد، وحينئذ يكون تصرفه نافذاً في مواجهة الشركة والشركاء.

الغصن الثالث: المسؤولية عن أعمال المدير:

يفرق في هذا الشأن بين مسؤولية الشركة عن أعمال المدير وتصرفاته قبل الغير من جهة، ومسؤولية المدير نفسه عن أعماله وتصرفاته قبل الشركة:

أولاً: مسؤولية الشركة قبل الغير عن أعمال المدير:

المدير هو ممثل الشركة قانوناً، ومن ثم تسأل الشركة مسؤولية عقدية عن الأعمال والتصرفات القانونية لمديرها إذا توافر شرطان:

١- أن تتم العقود باسم الشركة ولحسابها، ويعتبر الأمر قد تم على هذا النحو متى تم التوقيع على التصرف بعنوان الشركة، ومن ثم تسأل الشركة عن الالتزامات التي تترتب على هذه التصرفات، كما يسأل كافة الشركاء عن هذه الالتزامات مسؤولية شخصية وتضامنية.^(١)

فإذا تعاقد المدير باسمه الشخصي وليس بعنوان الشركة، قامت قرينة على أن المدير يتعاقد لحسابه الخاص، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، أي أن يثبت المدير أنه بالرغم من استخدامه اسمه الشخصي، إلا أن التعاقد قد تم لحساب الشركة، ويجوز له هذا الإثبات بكافة الطرق، وللقاضي سلطة تقدير الدليل، ومن جهة أخرى فإن هذه القرينة لا يترتب عليها مباشرة إعفاء الشركة من الالتزام بالتعهدات التي وقعها المدير دون بيان لعنوان الشركة، وإنما يجوز للغير الذي تعاقد مع المدير، ويريد الاحتفاظ بحقه في الرجوع بالمسؤولية على الشركة، أن ينقض هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن.^(٢)

وقد يحدث أن يسبى المدير استعمال عنوان الشركة، فيبرم مع الغير عقداً لحسابه الخاص ويوقع عليه بعنوان الشركة في حدود سلطته الظاهرة، كأن يستأجر محلاً أو يقترض مبلغاً لمصلحته الشخصية ويوقع على العقد بعنوان الشركة، والأصل أن تلتزم الشركة بهذا التصرف الذي تم التوقيع عليه بعنوان الشركة، وفقاً للمادة ٢٢ تجاري-سالفه الذكر-حماية للأوضاع الظاهرة وتحقيقاً لاستقرار التعامل وحماية لائتمان الشركة قبل الغير، إنما يشترط لذلك أن يكون هذا الغير حسن النية، ويكون للشركة أن ترجع على المدير بالمسؤولية المدنية، وقد يعد هذا الأخير مسؤولاً جنائياً بخيانة الأمانة، وسوء النية لا يفترض، وإنما يقع على الشركة عبء الإثبات، فإن

استطاعت الشركة إثبات سوء نية الغير، بإقامة الدليل على أن الغير كان يعلم أن المدير يسيئ استخدام عنوان الشركة لمصلحته الشخصية، فلا تكون مسئولة في مواجهة الغير عن التصرف الذي أبرمه المدير، ولا يكون له سوى الرجوع على المدير شخصياً.^(١)

٢- أن يتعاقد المدير في حدود سلطته المحددة في عقد الشركة وطبقاً لأحكام القانون، فإذا لم يتعد المدير هذه الحدود التزمت الشركة بالتزامات التي تترتب على أعماله، فإن جاوزها كانت الشركة غير مسئولة، وليس أمام المتعاقد معه سوى الرجوع على المدير شخصياً.

فإذا تجاوز المدير حدود سلطته بأن أبرم تصرفاً لا يدخل في غرض الشركة، كبيع عقار للشركة أو تبرع بأموالها للغير تبرعاً غير معتاد أو اقترض من أحد البنوك، فلا تلتزم الشركة بهذا التصرف، ويلتزم به المدير شخصياً ولو كان الغير الذي تعامل مع المدير حسن النية، وليس للغير أن يتضرر من ذلك، ما دام أن حدود سلطة المدير قد نص عليها في عقد الشركة الذي أشهر وفقاً للقانون، إذ المفترض أن الغير قد علم بالقيود التي ترد على سلطة المدير قبل أن يبرم التصرف معه.

إلا أن تطبيق القاعدة السابقة، لما كان من شأنه أن يؤدي إلى العسف بالغير حسن النية، بتكليفه، في كل مرة يتعامل فيها مع الشركة، أن يرجع إلى قلم كتاب المحكمة أو مكتب السجل التجاري اللذين شهر فيهما عقد الشركة، للتأكد من مدى سلطة المدير قبل التعامل، فإن البعض يرى أن مسؤولية الشركة تنعقد قبل الغير حسن النية، ما دام أن تصرفات المدير قد جرت في نطاق غرض الشركة حتى لو جاوز المدير سلطته، وقد قنن المشرع الفرنسي هذا الاتجاه بعدم الاحتجاج بالقيود الواردة على سلطة المدير في مواجهة الغير حسن النية ولو تم شهرها وذلك في قانون الشركات لسنة ١٩٦٦، إلا أن الفقه الراجح ما زال يرى عدم مسؤولية الشركة عن أعمال المدير الذي يتجاوز سلطاته أمام الغير ولو كان حسن النية.^(٢)

هذا ولا تقتصر مسؤولية الشركة على العقود والتصرفات التي يبرمها المدير فحسب، وإنما تمتد إلى الأعمال غير المشروعة التي يرتكبها المدير أثناء إدارته أو بسببها، ويترتب عليها الإضرار بالغير، كما إذا ارتكب مثلاً عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة أو غشاً مالياً، حيث تكون الشركة مسئولة مسؤولية تقصيرية عن تعويض الضرر، وذلك على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، بينما يرى البعض أن المدير لا يعتبر تابعاً للشركة، وإنما جزءاً من كيانها، فيعتبر الخطأ الذي ارتكبه كأنه صادر عن الشركة ذاتها، وبالتالي تقوم مسؤولية الشركة في هذه الحالة

على أساس المسؤولية الشخصية عن أعمالها غير المشروعة التي صدرت منها، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (١٦٤ مدني).

ثانياً: مسؤولية المدير في مواجهة الشركة:

يلتزم المدير، شريكاً كان أو غير شريك، أن يبذل في إدارة الشركة ورعاية مصالحها عناية الرجل المعتاد (م ٢/٥٢١)، لأن المدير يعتبر بمنزلة الوكيل المأجور، حيث يتقاضى أجراً عن عمله، سواء تمثل في مرتب ثابت أو نسبة في الأرباح، وعلى هذا يعتبر المدير مسئولاً في مواجهة الشركة عن الأخطاء التي تقع منه أثناء قيامه بأعمال الإدارة، كما إذا أساء استخدام عنوان الشركة أو تجاوز حدود سلطاته أو قام بعمل منافس أو صدر منه إهمال أو تقصير، وفي حالة تعدد المديرين فإنهم يسألون قبل الشركة متضامين عن أخطائهم الشخصية، بالقياس على الحكم في حالة تعدد الوكلاء (م ١/٧٠٧ مدني).

وبالرغم من أن المدير لا يعتبر وكيلاً عن الشركة - كما أسلفنا - بل عضو الشركة وممثلها القانوني، إلا أن مسؤوليته عن أخطائه في إدارة الشركة تتحدد وفقاً لقواعد المسؤولية التعاقدية، ومن ثم فهو يلتزم، متى كان يعمل بأجر، أن يبذل عناية الرجل المعتاد، ولذلك فهو يسأل عن أخطائه ولو كانت يسيرة.

ويلتزم المدير أن يقدم للشركاء حساباً مؤيداً بالمستندات عن إدارته، ليتمكن الشركاء من ممارسة حق الرقابة على أعماله، فإذا سحب مبلغاً من حساب الشركة أو احتجزه، التزم بدفع فوائده من يوم أخذه أو احتجازه بدون حاجة إلى إعدار أو إستصدار حكم قضائي قبله، ودون الإخلال بما قد يستحق عليه من تعويض تكميلي عند الاقتضاء (م ١/٥٢٢ مدني) وبالمقابل فإنه إذا ما أمد الشركة بمال أو أنفق لصالحها مصروفات نافعة عن حسن نية وتبصر، وجب له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها (م ١/٥٢٢ مدني).^١

كما يسأل المدير جنائياً عما يرتكبه من جرائم، فإذا ما اختلس أو بدد شيئاً من أموال الشركة، اعتبر مرتكباً جريمة خيانة الأمانة.

الفرع الثالث: توزيع الأرباح والخسائر

يعد توزيع الأرباح والخسائر أحد الشروط الموضوعية الخاصة لعقد الشركة، والأصل أنه يتبع في هذا الشأن الشروط الواردة في عقد الشركة، مع مراعاة بطلان الشروط التي تقضي بجرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة، أي بطلان "شروط الأسد" أما إذا لم يتضمن عقد الشركة قواعد لتوزيع الأرباح والخسائر، وجب تطبيق أحكام التوزيع المنصوص عليها في القانون.

أولاً: توزيع الأرباح:

جرى العمل على توزيع الأرباح في نهاية كل سنة مالية، حيث تقوم الشركة في نهاية كل سنة مالية بعمل الجرد والميزانية وحساب الأرباح والخسائر، فإذا اتضح من الجرد والميزانية زيادة أصول الشركة عن خصومها، كانت الزيادة أرباحاً، تسمى بالأرباح الإجمالية.

وهذه الأرباح الإجمالية لا يتم توزيعها، وإنما الذي يوزع هو الأرباح الصافية، وهو الفائض بعد طرح الاحتياطيات التي يجب تجنبها لتحقيق العديد من الأغراض: كمواجهة الخسائر المحتملة أو توسيع نشاطات الشركة واستثماراتها، أو لتوزيع أرباح على الشركاء في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً، أو لقضاء أي من حاجات الشركة، كذلك يخصم من الأرباح الصافية النفقات والمصروفات التي تحملتها الشركة خلال السنة المالية، كأثمان المواد الأولية والاستهلاكات الرأسمالية ورواتب الموظفين وما ينفق على الأبنية والصيانة والخدمات والضرائب.^(١)

فإذا ما حققت الشركة أرباحاً صافية وجب توزيعها بالطريقة التي حددها عقد الشركة، وإلا تعين اتباع طريقة التوزيع القانونية التي حددتها المادة ٥١٤ من التقنين المدني، على ما أسلفنا توضيحه تفصيلاً، ويعتبر كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب، كما أنه لا يلتزم برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات المقبلة.

أما إذا لم تحقق الشركة أرباحاً في سنة من السنوات، أو هبطت أصول الشركة إلى أقل من رأس المال، فحينئذ يجب أن تتوقف الشركة عن توزيع مبالغ بصفتها أرباحاً، إلى أن يعود رأس المال إلى أصله، أو يقرر الشركاء تخفيض رأس المال بمقدار النقص.

بطلان توزيع الأرباح الصورية:

إذا حدث وقامت الشركة، بالرغم من ذلك وبدافع من محاولة التستر على أزمة مالية أملت بها أو لإيهام الغير بمتانة مركزها المالي وخلق ائتمان مزيف لها، بتوزيع مبالغ على الشركاء، فإن تلك المبالغ تعتبر أرباحاً صورية، لأنها في الحقيقة اقتطاع لجزء من رأس المال ورد غير مشروع لجزء

من حصص الشركاء أثناء حياة الشركة، وفي ذلك إهدار لمبدأ ثبات رأس المال ووجوب عدم المساس به طالما كانت الشركة قائمة.

وحيث أن يكون لدائني الشركة الحق في مطالبة الشركاء، بمقتضى الدعوى غير المباشرة، برد ما حصلوا عليه من أرباح صورية، ولو كان الشركاء حسني النية، فضلاً عن أن الشريك لا يكون له أن يتضرر من رد هذه المبالغ، لأنه بما له من حق في الرقابة على أعمال الشركة والاطلاع على دفاترها، كان يفترض به أن يعلم صورية هذا التوزيع.

ثانياً: توزيع الخسائر:

الأصل أن الشركاء لا يلتزمون، إذا لحقت بالشركة خسائر بأن نقصت أصولها عن خصومها، بتكملة ما نقص من قيمة رأس المال، وإنما تعوض الشركة خسائرها من أرباح السنوات التالية حتى يعود رأس المال إلى أصله، وإذا استمرت خسائر الشركة في السنوات التالية حتى نفذ رأس المال أو معظمه بحيث أصبح يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدداً، وجب حل الشركة وتصفيتها (م ٥٢٧ مدني)، وتظهر عند حل الشركة وتصفيتها مسألة كيفية توزيع الخسائر، ويتبع عندئذ في توزيع الخسائر القواعد الواردة في عقد الشركة، فإذا سكت العقد وجب إعمال طريقة التوزيع القانونية الواردة في المادة ٥١٤ من التقنين المدني، على نحو ما قدمنا.

المبحث الثاني

شركة التوصية البسيطة

شركة التوصية البسيطة هي شركة تؤلف تحت عنوان معين، وتتكون من نوعين من الشركاء، شركاء متضامنون يديرون الشركة ويسألون عن ديونها مسئولية شخصية في أموالهم الخاصة، وشركاء موصون يقتصر دورهم على تقديم الأموال والمشاركة في الأرباح والخسائر، ولا يشتركون في إدارة الشركة، وتنحصر مسئوليتهم عن التزاماتها في حدود حصصهم في رأس المال.

وتعرف المادة ٢٣ من قانون الشركات القديم شركة التوصية البسيطة بأنها: "الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامين، وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين".

وهي شركة من شركات الأشخاص رغم مسئولية الشركاء الموصين المحدودة، لأنها شركة تقوم على الاعتبار الشخصي بالنسبة إلى الشركاء المتضامين والشركاء الموصين كلاهما، ومن ثم فإن الغلط في شخص الشريك أياً كانت صفته يجعل العقد قابلاً للإبطال، كما أن وفاة أحد

الشركاء-ولو كان موصياً-أو إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه يترتب عليه انقضاء الشركة، ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك، وفضلاً عن ذلك فإن الاعتبار الشخصي للشركاء يؤثر في عدم إمكانية التنازل عن حصة الشريك للغير إلا بموافقة الشركاء، أو على الأقل بمراعاة القواعد التي ينص عليها عقد الشركة لتنظيم مثل هذا التنازل.

وقد انتشرت شركة التوصية البسيطة في الماضي على نطاق واسع، وذلك نظراً لملاءمتها بوجه خاص لتلك الفئة من أرباب الأموال التي ترغب في استثمار أموالها في التجارة دون تحمل مخاطرها بصفة مطلقة، غير أن انتشار شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة قد قلل كثيراً من اللجوء إلى هذا الشكل من الشركات، ومع ذلك ما يزال لهذه الشركة أهميتها في كل حالة يرغب فيها الشركاء في تأسيس شركة أشخاص، يقبل فيها بعضهم أو أحدهم المسؤولية التضامنية عن التزامات الشركة والبعض الآخر يحجم عن ذلك، مفضلاً الدخول كموصٍ بالأموال دون الالتزام المطلق في ذمته المالية بديون الشركة.^(١)

تقسيم: تتفق شركة التوصية البسيطة مع شركة التضامن في الأحكام التي تنظمها، ويكاد يكون محل الاختلاف بين شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة في أنه، بينما يكون جميع الشركاء في شركة التضامن شركاء متضامنون، تسري عليهم جميعاً ذات الأحكام القانونية المنظمة لهذه الشركة، تضم شركة التوصية البسيطة، إلى جانب الشركاء المتضامين، شركاء موصين، يخضعون لأحكام مغايرة عن الشركاء المتضامين فيما يتعلق بطبيعة المسؤولية، بما يترتب على ذلك من أحكام.

ولذا فإننا سنعرض لأبرز الأحكام الخاصة بشركة التوصية البسيطة من حيث خصائصها، ونشاطها وإدارتها، وذلك في مطلبين اثنين على النحو التالي:

المطلب الأول

خصائص شركة التوصية البسيطة

تتميز شركة التوصية البسيطة بالمسئولية المحدودة للشريك الموصي عن ديون الشركة بمقدار حصته في رأس المال، ومن ثم عدم اكتسابه صفة التاجر، وبأن لها عنواناً يتكون من اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين دون الشركاء الموصين.

أولاً: المسئولية المحدودة للشريك الموصي:

قلنا إن شركة التوصية البسيطة تضم من نوعين من الشركاء:

(١) شريك متضامن أو أكثر، لهم نفس المركز القانوني للشركاء المتضامنين في شركة التضامن، فهم يكتسبون صفة التاجر، وتندرج أسماءهم في عنوان الشركة، ولهم وحدهم الحق في إدارة الشركة، ويسألون عن ديونها مسئولية مطلقة وتضامنية.

(٢) وشريك موصٍ أو أكثر، لا يكتسبون صفة التاجر، وليس لهم الحق في الإدارة، ولا تدخل أسماءهم في عنوان الشركة، ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود الحصة التي قدمها كل منهم (م ٢٧ تجاري قديم).

وعلى هذا فإن الالتزام الرئيسي بالنسبة للشركاء الموصين هو المشاركة في تكوين رأس المال اللازم لنشاط الشركة بتقديم الحصة التي تعهدوا بها، وهي إما أن تكون حصة نقدية أو عينية، ولكنها لا يمكن أن تكون حصة عمل، لأن من شأن هذه الحصة أن تمكنه من التدخل في إدارة الشركة، وهو ممنوع من ذلك قانوناً، فضلاً عن أن الشريك الموصي مسئول عن ديون الشركة بمقدار حصته، وهو ما يقتضي أن تكون هذه الحصة قابلة للحجز عليها، وهو ما لا يتصور في حالة الحصة بالعمل^(١).

وإذا أخل الشريك الموصي بتقديم حصته أو جزء منها فلمدير الشركة، بوصفه ممثلها القانوني، أن يطالبه بتنفيذ التزامه، كما أن لدائن الشركة استعمال حقها في مطالبة الشريك عن طريق الدعوى غير المباشرة، وإن كان القضاء قد اعترف لدائن الشركة بدعوى مباشرة ضد الشريك لمطالبته بالوفاء بالحصة التي تعهد بتقديمها، وذلك لدرء خطر الاحتجاج في مواجهته من قبل الشريك الموصي بكافة الدفع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الشركة، كالدفع بانقضاء الدين بالمقاصة أو بالبطالان لتدليس الشركاء^(٢).

هذا والرأي الراجح فقهاً وقضائاً أن التزام الشريك الموصي بتقديم حصته في رأس مال الشركة، هو التزام تجاري تطبيقاً لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية، ولأن الشريك الموصي لا

يستهدف بتقديم الحصة في رأس مال الشركة مجرد توظيف أمواله واستثمارها، وإنما يستهدف، بما لديه من نية المشاركة، أن يتمتع بكافة حقوق الشريك في الشركة، من المشاركة في الأرباح والخسائر والرقابة والإشراف على أعمال الشركة والحق في التصويت على قراراتها واختيار مديريها... فضلاً عن أن المسؤولية المطلقة ليست شرطاً لاكتساب صفة التاجر.

وقد تبني قانون التجارة الجديد لسنة ١٩٩٩ في المادة (٤/ج) هذا الرأي صراحة بإقراره أن تأسيس الشركات يعتبر من الأعمال التجارية، ولا شك أن تقديم الحصة عمل مرتبط بتأسيس الشركة فيأخذ حكمه من حيث التجارية.^(١)

ومتى اعتبر الالتزام بتقديم حصة الشريك الموصي في الشركة تجارياً، فإن القواعد التجارية هي التي تحكم هذا الالتزام، فيكون الاختصاص بشأنه للمحاكم التجارية، وتطبق عليه قواعد الإثبات في المسائل التجارية.

ثانياً: عدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر:

يعتبر الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة في نفس مركز الشريك المتضامن في شركة التضامن، ومن ثم فهو يكتسب صفة التاجر ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل، أما الموصي فإنه، على خلاف ذلك، لا يكتسب صفة التاجر لمجرد انضمامه إلى الشركة، ما لم تكن له تلك الصفة من قبل، لذا لا يلتزم هذا الضمير بالتزامات التجار، ولا يترتب على شهر إفلاس الشركة شهر إفلاسه حتى ولو كان تاجراً، وذلك نتيجة لتحديد مسؤوليته عن ديون الشركة بمقدار حصته في رأس المال.

ولما كان الشريك الموصي لا يكتسب صفة التاجر بمجرد انضمامه إلى الشركة، فإنه يجوز لنقص الأهلية وكذلك الأشخاص الممنوعين من التجارة، كالموظفين العموميين والقضاة ورجال الجيش والأطباء والمحامين، الدخول كشركاء موصين في شركة التوصية البسيطة.

ثالثاً: عنوان الشركة:

تنص المادة ٢٤ تجاري قديم على أن " تكون إدارة هذه الشركة بعنوان ويلزم أن يكون هذا العنوان مكوناً من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المسؤولين بالتضامن"، ومن ثم فإنه إذا تضمن عنوان الشركة اسم شريك متضامن واحد، تعين أن يضاف عبارة " وشريكه أو شركاه" حتى ولو كان هؤلاء الشركاء جميعاً شركاء موصون، وبصفة عامة تسري في شأن هذا العنوان الأحكام الخاصة بعنوان شركة التضامن.

وعلى هذا لا يجوز أن يتضمن عنوان شركة التوصية البسيطة اسم واحد من الشركاء الموصين، وذلك حماية للغير، حتى لا يعتقد خطأً أن هذا الشريك الذي أدرج اسمه في عنوان الشركة مسئول عن ديون الشركة مسئولية غير محدودة، فيعتمد على هذا لدي تعامله مع الشركة، وقد حرص المشرع على تأكيد هذا المعنى، فنص في المادة (٢٦) من القنين التجاري القديم على أنه: "لا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم واحد من الشركاء الموصين أي أرباب المال الخارجين عن الإدارة".^(١)

فإذا ما تمت مخالفة الحظر السابق، بأن أدرج في عنوان الشركة اسم واحد من الشركاء الموصين، مع علمه بذلك وعدم اعتراضه عليه، فإن جزاء هذه المخالفة هو أن يصبح هذا الشريك مسئولاً عن ديون الشركة مسئولية تضامنية (م ٢٩ تجاري)، أي أنه يعتبر في مواجهة الغير في مركز الشريك المتضامن، بل ويكتسب بالنسبة لهم صفة التاجر، ولكنه يظل في مواجهة باقي الشركاء شريكاً موصياً، ومن ثم يكون له، إذا ألزم بدفع مبالغ تزيد على قيمة حصته، حق الرجوع عليهم بمقدار الزيادة.

أما إذا أدرج اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة دون علمه، فإنم يظل محتفظاً بصفته كشريك موص محدود المسئولية، بشرط أن يثبت حسن نيته، أي عدم علمه بدخول اسمه في عنوان الشركة، أو في حالة علمه بادر باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع اسمه من العنوان بمجرد علمه بذلك، ولهذا الشريك الحق في مطالبة باقي الشركاء بتعويض الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به نتيجة إدراج اسمه في عنوان الشركة بغير رضائه بغرض خلق ائتمان وهمي للشركة، بل إن هذا الفعل من جانب الشركاء قد تقوم به جريمة نصب المعاقب عليها قانوناً.^(٢)

المطلب الثاني

إدارة شركة التوصية البسيطة

منع الشريك الموصي من التدخل في أعمال الإدارة الخارجية للشركة:

الأصل، فيما يتعلق بإدارة شركة التوصية البسيطة، أنها تخضع للأحكام التي سبق إيضاحها في إدارة شركة التضامن، من حيث تعيين المدير وعزله وتعدد المديرين وسلطاتهم ومسئوليتهم.

وقد اختص المشرع إدارة شركة التوصية البسيطة بحكم معين، حيث تقضي المادة ٢٨ تجاري قديم، على أنه: لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة الشركة ولو بموجب توكيل، كما أن المشرع حرص في المواد ٢٣ و ٢٥ و ٢٦ على وصف الشركاء الموصين بأنهم الشركاء

الخارجون عن الإدارة، ويعتبر استبعاد الشريك الموصي من إدارة الشركة من المبادئ التقليدية في هذا النوع من الشركات، وعلى هذا يمتنع على الشريك الموصي أن يقوم بأي عمل يعتبر تدخلاً في إدارة الشركة، التي تعتبر حكراً على الشركاء المتضامنين، في حين يجوز الاتفاق على تعيين شخص من غير الشركاء لتولي هذه الأعمال.^(١)

الحكمة من الحظر: والحكمة من تقرير هذا المبدأ هو الرغبة في حماية الغير الذي قد يختلط عليه الأمر في حقيقة مركز الشريك الموصي، الذي يتدخل في إدارة الشركة، فيعتقد على غير الحقيقة أنه شريك متضامن، ويولي الشركة ثقته ويمنحها ائتماناً كبيراً، ثم يفاجأ بعد ذلك أنه شريك موص لا يسأل لا بقدر حصته، ولا يعترض على ذلك بأنه في مقدور الغير الاطلاع على ملخص عقد الشركة المشهر ليعلم أن الشريك الذي يتعامل معه إنما هو شريك موص غير مسئول إلا في حدود حصته، ومن ثم يمتنع عليه الاحتجاج بإهماله وتقصيره، لأن هذا الاعتراض مردود عليه بأن هذا الحظر مقصود منه تخريب الغير عناء البحث عن حقيقة صفة من يتولى إدارة الشركة، لأن الحياة التجارية تقوم على السرعة مما لا يتيسر معه للغير عملاً الرجوع إلى عقد الشركة المشهر للتحري عن صفة الشريك الذي يتعامل معه.

نطاق حظر تدخل الشريك الموصي في إدارة الشركة:

لما كانت الحكمة من تقرير هذا الحظر هو حماية الغير الذي يتعامل مع الشركة، فإن نطاقه يتحدد بتلك الأعمال التي من شأن قيام الشريك الموصي بها حمل الغير على الوقوع في اللبس في حقيقة صفة الشريك، وهي أعمال "الإدارة الخارجية" وهي تلك الأعمال التي تنطوي على تمثيل الشركة أمام الغير، كأن يشتري أو يبيع لغير لحساب الشركة أو أن يقرض باسمها أو أن يمثلها أمام القضاء كمدع أو مدعى عليه، ولا يجوز للشريك الموصي أن يقوم بمثل هذه الأعمال ولو بناء على توكيل من المدير أو الشركاء.

أما فيما يتعلق بأعمال الإدارة داخل الشركة، والتي لا تنطوي على تمثيل للشركة أمام الغير، فيجوز للشريك الموصي مباشرتها، لأنها أعمال لا يكون من شأنها أن توقع الغير في لبس بشأن حقيقة صفة الشريك في الشركة، كأن يشترك في تعديل عقد الشركة أو في تعيين مدير جديد وعزله وتقييد سلطته، وللشريك الموصي حق الاطلاع على دفاتر الشركة والتفتيش عليها وفحص ميزانيتها وإبداء النصح وتوجيه ملاحظات للمدير (م ٣١ تجاري قديم)، ويجوز النص في عقد

الشركة على وجوب موافقة الشركاء الموصين على بعض أعمال الإدارة كالإقتراض أو الرهن أو بيع العقارات.^(١)

ويجوز للشريك الموصي أن يشغل بعض الوظائف في الشركة، كأن يكون مديراً فنياً أو مهندساً أو محاسباً، ما دام أن هذه الوظائف لا تخوله صفة تمثيل الشركة أمام الغير .
ويلاحظ أخيراً أن البعض في الفقه ينتقد قاعدة منع الشريك الموصي من التدخل في الإدارة الخارجية للشركة، ويعتقد أن حماية الغير في هذا الخصوص قد تجاوزت الحدود المعقولة، في الوقت الذي يجوز فيه إعطاء هذه السلطة لأحد من غير الشركاء، فالإدارة لا تدل بطبيعتها على أن المدير شريك متضامن، كما أن مدير الشركة إذا كان من الغير فهو غير مسئول عن ديونها على الإطلاق، ومن ثم يجب أن يكون من الأولى منح الموصي حق الإدارة، ويمكن الرد على هذا القول بأن الغير قد ينخدع بسهولة في حقيقة الموصي ويعتبره شريكاً متضامناً، في حين أن المدير إذا كان أجنبياً فيسهل على الغير الوقوف على أمره وأنه ليس بشريك، عن طريق الاطلاع على عنوان الشركة الذي يوقع به العقد.^(٢)

جزاء مخالفة الحظر :

إذا خالف الشريك الموصي مبدأ الحظر وقام بالتدخل في أعمال الإدارة الخارجية للشركة، فإنه يعرض نفسه للجزاء الذي تقضي به المادة ٣٠ بأنه: إذا عمل أي واحد من الشركاء الموصين عملاً متعلقاً بإدارة الشركة فإنه يكون ملزوماً على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها التي تنتج من العمل الذي أجراه.. ، وعلى هذا يسأل الشريك الموصي عن العمل الذي قام به في أمواله الخاصة، وليس في حدود حصته فحسب ، كما لو كان شريكاً متضامناً، ويترتب هذا الجزاء بقوة القانون وليس للقاضي سلطة تقديرية في هذا الشأن، وتظل مسؤوليته فيما عدا هذا العمل مسئولية محدودة بقدر حصته.

فإذا ما تكرر تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية المحظورة عليه، جاز اعتباره مسئولاً مسئولية مطلقة وتضامنية، ليس فقط عن الديون المترتبة على الأعمال التي قام بها، بل عن جميع ديون الشركة ولو لم تكن ناتجة عن الأعمال التي أجراها، وهذا الجزاء جوازي يعود أمر تطبيقه وتقديره إلى القضاء، مستهدياً بعدد وجسامه أعمال الإدارة التي قام بها الشريك الموصي وما يترتب على ذلك من أثر بالنسبة للغير.^(٣)

ومتى تدخل الشريك الموصي في إدارة الشركة وتغلغل في نشاطها فإنه يجوز للمحكمة أن تعامله كشريك متضامن، وتعتبره مسئولاً عن كافة ديون الشركة وتعهدها مسؤولية شخصية وتضامنية قبل الذين تعاملوا معه أو قبل الغير، وحينئذ يمكن للمحكمة أن تعتبره تاجراً، وأن تشهر إفلاسه تبعاً لشهر إفلاس الشركة، ولا يحول دون ذلك كون هذا الشريك شاغلاً لوظيفة تحظر القوانين واللوائح على شاغلها العمل بالتجارة.^(١)

أما فيما يتعلق بعلاقة الشريك الموصي الذي يقوم بأعمال الإدارة بغيره من الشركاء في الشركة، فيختلف الحكم باختلاف ما إذا كان قد قام بهذا العمل بتوكيل منهم أو دون توكيل، حيث تظل مسؤوليته محدودة في علاقته معهم في حالة قيامه بالعمل بناء على توكيل من الشركاء، فإذا قام بالوفاء للغير بهذه الديون أمكنه أن يرجع عليهم بما يكون زائداً منها عن حصته، أما في حالة قيامه بالعمل دون توكيل من الشركاء، فإنه يعتبر مسئولاً في مواجهة من تعاقد معه مسؤولية غير محدودة، وليس له الرجوع على الشركاء فيما قد يتحمله قبل الغير من التزامات ناتجة عن تلك الأعمال.

المبحث الثالث شركة المحاصة

تعريف الشركة وأهميتها العملية:

شركة المحاصة هي شركة مستترة تنعقد بين شخصين أو أكثر يقدم كل منهم حصة من مال أو عمل لاقتسام الأرباح والخسائر الناشئة عن الاستغلال التجاري المشترك، ويقوم بأعمالها أحد الشركاء، وتتميز شركة المحاصة بأنها ليس لها وجود ظاهر أو ذاتية قانونية أمام الغير، ومن ثم فهي لا تكتسب الشخصية الاعتبارية، وليس لها ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية للشركاء، وعلى هذا نصت المادة ٥٩ من قانون التجارة القديم، بأنها شركة ليس لها رأس مال ولا عنوان وأنها شركة مستترة خفية لا وجود لها إلا فيما بين الشركاء فيها.

ونظراً لما تمتاز به شركة المحاصة من سهولة في الانعقاد واقتصاد في نفقات التأسيس والإدارة، فضلاً عن ملاءمتها لمختلف المشروعات والكثير من الظروف والملايسات، وخاصة تحقيقها لرغبة كثير من الشركاء في عدم الظهور أمام الغير، فقد انتشرت في العمل انتشاراً كبيراً كما يدل عليه كثرة الأحكام القضائية الصادرة بشأنها.

ولشركة المحاصة تطبيقات عملية كثيرة ، نذكر كافة صور الاتفاق الذي يقع من بعض التجار بقصد شراء السلع التجارية أو بعض المحصولات الزراعية، خاصة الموسمية، وإعادة بيعها والمضاربة على ارتفاع أسعارها بغرض تحقيق واقتسام الأرباح والخسائر، وتربية الماشية وبيعها، وكالاتفاق على شراء أنقاض منزل أو حطام سفينة وإعادة بيعها. وللإحاطة بأحكام شركة المحاصة نعرض لها من خلال تناول: خصائصها، تكوينها، نشاطها، انقضاءها وتصفيتها.

المطلب الأول

خصائص شركة المحاصة

يتجه معظم الفقه والقضاء المقارن إلى القول بأن أهم ما يميز شركة المحاصة أنها شركة خفية أو مستترة، ليس لها وجود ظاهر بالنسبة إلى الغير، ويقتصر وجودها على الشركاء فيها فحسب، ويتمثل مظهرها الخارجي في اقتسام الأرباح والخسائر فيما بينهم.

غير أن خفاء شركة المحاصة على الغير ليس سوى عنصر سلبي لا يكفي لتمييزها عن غيرها من الشركات، فالاستتار المقصود هنا لا يقصد به الاستتار المادي الواقعي، وإنما الخفاء القانوني المتمثل في عدم علم الغير بها بالطرق القانونية، كالشهر والنشر والتوقيع على المعاملات بعنوان يضم اسم الشركاء فيها، إلا أن غياب هذا العنصر عن شركة المحاصة لا يكفي معياراً لتمييزها عن غيرها من الشركات، حيث تشاركها في ذلك الشركات التجارية الأخرى التي لم تتخذ بشأنها إجراءات الشهر، وكذلك الشركات المدنية التي لا تخضع لإجراءات الشهر بالأساس.

وعلى هذا فإن الرأي الأرجح، في نظرنا، فيما يتعلق بأهم خصائص شركة المحاصة، هو الذي يضيف إلى عنصر الخفاء أو الاستتار الذي يحيط بهذه الشركة، أنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية أو الكيان القانوني الذي يمنحها وجوداً مستقلاً عن الشركاء فيها، فهذا العنصر الأخير تحديداً هو ما يميز شركة المحاصة عن الشركات الأخرى التي تتمتع، رغم استتارها القانوني لتخلف عنصر الشهر، بالشخصية القانونية المستقلة، كل ما في الأمر أن هذه الشركات الأخيرة، لا يجوز لها الاحتجاج بهذه الشخصية على الغير إلا باتخاذ إجراءات الشهر التي يتطلبها القانون.^(١)

ويترتب على أن المقصود باستتار الشركة هو الاستتار القانوني وليس الاستتار الفعلي أو الواقعي، أن هذا الاستتار لا يعني بالضرورة بقاء الشركة في طي الكتمان، إذ قد تفقد شركة

المحاصة صفتها المستترة من الناحية الواقعية متى علم الغير بوجودها، ومع ذلك تظل محتفظة بوجودها كشركة محاصة ما دامت محتفظة بصفتها المستترة من الناحية القانونية، أي ما دام لم يعبر الشركاء عن إرادتهم صراحة أو ضمناً بما ينبئ عن وجود الشركة كشخص معنوي في مواجهة الغير، كما لو قاموا بشهرها، أو اتخذوا لها عنواناً وجرى التوقيع به على تعاملات الشركة وتعهداتها قبل الغير، حيث تتحول في هذه الحالة إلى شركة تضامن فعلية.

وينبغي على انعدام الشخصية القانونية لشركة المحاصة ألا يكون لها اسم ولا عنوان، وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، ولا يكون للشركة موطن أو جنسية، كما أنها لا تخضع لإجراءات القيد في السجل التجاري، ويترتب على ذلك أيضاً أنه لا يجوز شهر إفلاس هذه الشركة، وإنما يشهر إفلاس الشريك الذي تعاقد مع الغير، إذا توافرت فيه شروط شهر الإفلاس. أخيراً فإن شركة المحاصة تعتبر من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة التي تجمع بين الشركاء، ويرتب على ذلك أنه لا يجوز للشريك فيها أن يتنازل عن حصته أو أن ينقل ملكيتها للغير دون موافقة باقي الشركاء أو بمراجعة القيود المتفق عليها، وتنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره أو انسحابه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.^(١)

المطلب الثاني

تكوين شركة المحاصة

يلزم أن يتوافر في عقد شركة المحاصة جميع الأركان الموضوعية العامة، والأركان الموضوعية الخاصة، وفقاً لما عرضت له تفصيلاً في النظرية العامة للشركات، أما الشروط الشكلية، المتمثلة في الكتابة والشهر، فهي غير واردة في هذا النوع من الشركات، وفي ذلك تنص المادة ٦٤ شركات: "لا يلزم في شركات المحاصة التجارية اتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى". وعلى هذا يذهب الرأي السائد في الفقه إلى أنه إذا كان موضوع شركة المحاصة مدنياً، وجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وفقاً للمادة ٥٠٧ مدني، التي تستوجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً، أما شركة المحاصة التجارية فلا يلزم لانعقادها أن يكون عقدها مكتوباً، وذلك لأن الكتابة إنما شرعت لمصلحة الغير الذي يهيمه أن يعلم بشروط عقد الشركة، ومدى سلطة الشخص المعنوي الذي يتعامل معه، في حين أن شركة المحاصة، كما قدمنا، شركة مستترة ليست لها شخصية معنوية.^(٢)

بينما ذهب اتجاه راجح في الفقه، إلى عدم اشتراط الكتابة لصحة عقد شركة المحاصة، سواء كانت الشركة مدنية أو تجارية، استناداً إلى أن النص القانوني الذي يستوجب كتابة العقد (المادة ٥٠٧ من التقنين المدني) خاص بعقد الشركة الذي ينشئ شخصاً معنوياً، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا إذا كان سند إنشائه مكتوباً ومشهوراً، أما بالنسبة إلى شركة المحاصة فلا يتوفر لها شيء من ذلك حتى يسري عليها حكم المادة ٥٠٧ الذي يشترط الكتابة في العقد، لأنها شركة لا تكتسب شخصية معنوية مستقلة ولا وجود لها أمام الغير.^(١)

أما فيما يتعلق بالشهر، فقد أسلفنا أن القانون أعفى شركة المحاصة من إجراءات الشهر المقررة لباقي الشركات، إذ لا ينشأ عنها شخص معنوي يحتاج الغير إلى أن يعلم به، كما أن الكتابة ليست لازمة لانعقادها، والشهر يقتضي إفراغ العقد في قالب مكتوب، فضلاً عن أن نص المادة ٦٤ تجاري، يعفي شركات المحاصة التجارية من اتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى.

إثبات شركة المحاصة:

تنص المادة ٦٣ من تقنين التجارة القديم على أنه "يجوز إثبات وجود شركة المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات"، وبالرغم مما قد يوحي به ظاهر النص من عدم جواز إثبات الشركة بغير الطريقتين المذكورين دون أوجه الإثبات الأخرى، إلا أن الثابت أن ما أورده النص من طرق لإثبات شركة المحاصة عن طريق الدفاتر التجارية والخطابات، إنما جاء على سبيل البيان والتمثيل لا على سبيل الحصر والتعيين، وأن شركة المحاصة يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن، وهذا واضح من عدم اشتراط الكتابة لانعقاد الشركة، بما يفيد جواز إثباتها بأي طرق غير الكتابة.^(١)

المطلب الثالث

نشاط شركة المحاصة

يعتبر انعدام الشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة لشركة المحاصة هو العنصر والعامل المميز لنشاط وإدارة هذه الشركة، ويظهر ذلك في طريقة وكيفية إدارة الشركة، فضلاً عن صفة المدير في حيازته لرأس مال الشركة والذمة التي ستؤول إليها الحصص المقدمة من الشركاء، إذ يترتب على عدم وجود الشخصية المعنوية لشركة المحاصة، أنها شركة ليس لها ممثل قانوني، أي مدير يعمل باسمها ولحسابها، وإنما ينظم الشركاء عادة طريقة لإدارة الشركة في عقدها التأسيسي،

ولتحديد حقوقهم والتزاماتهم، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر التي تنشأ عن أعمال الشركة، سواء وقعت منهم منفردين أو مجتمعين، وهذه الشروط عادة لا تخرج عن الصور الآتية:

١- فقد يتفق الشركاء على اختيار أحدهم لمباشرة أعمال الشركة، على أن يقدم لهم حساباً بنتيجة هذه الأعمال، تمهيداً لاقتسام ما ينشأ عنها من ربح أو خسارة، حيث يقوم هذا الشريك، الذي يطلق عليه "مدير المحاسبة" بكافة الأعمال والتصرفات التي يقتضيها تحقيق غرض الشركة، ويتولى مدير المحاسبة العمل مع الغير باسمه وبصفته الشخصية، ويكون وحده المسئول أمام الغير، ولا تنشأ أية علاقة مباشرة بين هذا الغير وباقي الشركاء، ومن ثم لا يكون له دعوى مباشرة قبل الشركاء لأنهم ليسوا طرفاً في العقد، ويكتسب هذا المدير صفة التاجر، ويلتزم بالقيود في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية، ويخضع لقواعد الإفلاس إن توافرت فيه شروطه.^(١)

ولا تقوم مسؤولية الشركاء المحاصين أمام الغير عن الأعمال التي قام بها مدير الشركة، إلا إذا كانوا قد زودوا المدير بوكالة صريحة باسمهم، إذا يتعامل المدير حينئذ مع الغير بوصفه أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء، وطبقاً للقواعد العامة فإن أعمال الوكيل تلزم الموكل متى وقعت في حدود سلطته.^(٢)

هذا وفي حالة الاتفاق على تسليم الحصص للمدير، فإما أن يتم الاتفاق على أن يكون ذلك لمجرد مباشرة أعمال الشركة دون نقل للملكية، أو على سبيل نقل الملكية، أو على أن تكون ملكية الحصص بينهم على سبيل الشيوخ.

أ- ففي حالة الاتفاق على تسليم الحصص لمباشرة أعمال الشركة، تنتقل حيازة الحصص إلى المدير، على أن يظل كل منهم مالكاً للحصص التي تعهد بتقديمها للشركة، وعلى هذا فإذا هلك الحصص تملك على مالكةا، إلا إذا كان الهلاك راجعاً إلى مخاطر الاستغلال المشترك الذي تقوم به الشركة، فتقع تبعته على الشركاء جميعاً، كما لو تمثلت الحصص في معدات ثم فُتت أثناء تشغيلها بفعل حريق.

وما دامت الحصص باقية على ملك الشركاء، فلا يكون للغير ممن يتعاملون مع مدير المحاسبة الحق في مطالبتهم، بطريق مباشر أو غير مباشر، بالوفاء بالحصص التي تعهدوا بتقديمها عند إبرام عقد الشركة، لأن هذه الحصص لا تشكل ضماناً عاماً لهم.^(٣)

وإذا أفلس الشريك المدير والحصص بين يديه كان لمقدمها أن يستردها من تفليسته إذا كانت معينة بالذات، أو الاشتراك في التفليسة كدائن عادي بقيمة الحصص إذا كانت من المثليات، أما

لو أفلس الشريك مقدم الحصة، فإنها تدخل في تفليسته ولدائنيه التنفيذ عليها، لأنها ما زالت على ملكه ولا يحتج على دائنيه بوجود الشركة.

ب- أما إذا اتفق الشركاء على نقل ملكية الحصص إلى مدير المحاصة، على أن يقتسم الشركاء الربح والخسارة، ففي هذه الحالة يتعين اتخاذ إجراءات نقل الملكية التي قررها القانون، كالتسجيل إذا كانت الحصة عقاراً أو التسليم إذا كانت منقولاً، وبذلك تنتقل الحصة للذمة المالية للمدير الذي يتعين عليه استثمارها في أغراض الشركة وليس لحسابه الخاص، وعلى هذا تدخل الحصة في الضمان العام لدائنيه وتدخل ضمن تفليسته.

ج- وقد يتفق الشركاء على أن تكون الحصص المقدمة منهم ملكاً شائعاً بينهم، ويجب أن يكون هذا الاتفاق صريحاً في عقد الشركة، لأن المحاصة لا تفترض الشيوع بطبيعتها، ومتى اتفق على الشيوع صراحة انطبقت أحكامه، وعلى ذلك إذا أفلس مدير المحاصة الذي يحوز الحصص، فلبقية الشركاء الدخول في التفليسة لاسترداد أنصبتهم من المال الشائع.

٢- وقد يتفق الشركاء على توزيع أعمال الشركة بينهم، بحيث يقوم كل منهم بجزء معين من هذه الأعمال، على أن يتقدم كل منهم كل فترة زمنية معينة يحددها عقد الشركة بحساب عن نشاطه، ويجرى تقسيم الأرباح والخسائر بين الشركاء على أساس أن تلك الأعمال تمت لحسابهم جميعاً، وفي هذه الحالة يعمل كل شريك باسمه ولحسابه الخاص، ويكون مسؤولاً وحده تجاه الغير الذي يتعامل معه، أما غيره من الشركاء فلا مسؤولية عليهم في مواجهة هذا الغير، وعلى ذلك نصت المادة ٦١ من التقنين التجاري القديم بقولها: "من عقد من المحاصين عقداً مع الغير يكون مسؤولاً عنه دون غيره".^(١)

٣- وقد يجري الاتفاق بين الشركاء على وجوب اشتراكهم في جميع الأعمال التي تتم لحساب الشركة، فتبرم العقود عندئذ باسم جميع الشركاء، ويلتزمون جميعاً قبل الغير على وجه التضامن متى كان موضوع الشركة عملاً تجارياً، تبعاً لقاعدة افتراض التضامن في المواد التجارية.^(٢)

المطلب الرابع

انقضاء شركة المحاصة

تنقضي شركة المحاصة، كبقية الشركات، بتوفر سبب من أسباب الانقضاء العامة لانقضاء الشركات، كما تنقضي بنفس الطرق التي تنقضي بها شركات الأشخاص، وهي تتمثل في أي من الحالات التي تؤدي إلى زوال الاعتبار الشخصي.

غير أن شركة المحاصة تتميز عن غيرها من الشركات، بأن انقضاءها لا يستتبع خضوعها لنظام التصفية المنصوص عليه في القانون، استناداً إلى أنها لا تتمتع بشخصية معنوية وليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، ومن ثم فإن الأمر يقتصر عند انقضاء الشركة على مجرد تسوية الحساب بين الشركاء لتحديد نصيب كل منهم في الربح والخسارة، ويباشر تسوية الحساب جميع الشركاء أو خبير أو أكثر يختاره الشركاء أو يعينه القضاء عند الاقتضاء.

وهو ما عبرت عنه محكمة النقض المصرية بقولها: "لا يجوز للشريك في شركة المحاصة إذا ما انقضت الشركة أن يطلب تصفية أموالها، لأنها ليست ملكاً للشركة، وكل حقه في مقابل مدير الشركة قاصر على مطالبته بحساب لمعرفة مقدار الربح والخسارة، واعتباره دائناً له في حصته ونصيبه في الربح إن كان هناك ربح، وعلى أن يخصم من حصته مقدار نصيبه في الخسارة إن خسر الشركة".^(١)

ولا يسري التقادم الخمسي الذي نصت عليه المادة ٦٥ من قانون التجارة القديم على الدعاوى التي يرفعها الغير على من تعامل معه من الشركاء، لأن هذا التقادم خاص بالشركات التي تكتسب الشخصية المعنوية، ويبدأ من تاريخ شهر انقضاء التصفية، ولأن الدائن لا يعلم بوجود الشركة، كما أنه ليست هناك تصفية بالمعنى الصحيح حتى يتم شهرها كما تقدم القول، لذلك يظل حق الدائن قائماً إلى أن ينقضي بمضي التقادم الطويل وفقاً للقواعد العامة، والمقدر بخمسة عشر عاماً.^(٢)

أثر زوال استتار شركة المحاصة على بقائها:

إذا زال استتار الشركة بموافقة جميع الشركاء، وتعاملت مع الغير بوصفها شركة، فيجوز للغير أن يتمسك بعقد الشركة، ويحول الاستتار بصور أي فعل أو تصرف من الشركاء ينبئ عن وجود الشركة في مواجهة الغير كشخص قانوني مستقل، كإشهار الشركة بالطرق القانونية أو أن يتخذ لها عنواناً يتم التوقيع به على عقودها، وحينئذ تتحول إلى شركة تضامن فعلية، ومن ثم يسأل الشركاء مسؤولية مطلقة وتضامنية عن ديون الشركة، وتكتسب الشركة شخصية قانونية وذمة مالية مستقلة تنتقل إليها ملكية الحصص التي تعهد الشركاء بتقديمها، وتصير هذه الذمة هي الضمان العام لدائني الشركة دون الدائنين الشخصيين للشركاء.^(٣)

الفصل الثالث

شركات المساهمة

مقدمة في: التعريف بالشركة المساهمة:

تعد شركة المساهمة Société anonyme النموذج الأمثل لشركات الأموال، والإدارة القانونية الكبرى لجمع الأموال الطائلة التي يقتضيها إنشاء وإدارة الأعمال الإقتصادية والتجارية العملاقة، والتي يسعى الاقتصاد الوطني من خلالها إلى قيام المشروعات التجارية والصناعية والمالية على نطاق واسع، للاستفادة من مزايا الإنتاج الكبيرة المرتبطة بهذا النوع من الشركات، ولإمكانية مقاومة المنافسة الدولية في هذا الشأن.

وتستند شركات المساهمة في تجميع رأس مالها على المبادأة الفردية والإدخار، إذ يتعاون الإدخار ورجال الأعمال على إنشاء شركات المساهمة عن طريق ما يكتبون به من أسهم يتكون منها رأس مال الشركة، وهم يحدهم الأمل في تكوين أرباح طائلة^(١).

أولاً: تعريف شركة المساهمة:

عرفت المادة الثانية من قانون الشركات المصري رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، شركة المساهمة بأنها: "شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم، ويكون للشركة اسم تجاري يُشتق من الغرض من إنشائها، ويجوز أن يتضمن الاسم التجاري للشركة اسماً أو لقباً لواحد أو أكثر من مؤسسيها"^(٢).

ثانياً: خصائص شركة المساهمة:

انتشرت شركة المساهمة بالنظر إلى ما تشتمل عليه من خصائص - تضمنها التعريف السابق - تجعلها قائمة على الاعتبار المالي، حيث يتوارى فيها الاعتبار الشخصي إلى حد بعيد، وينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، قابلة للتداول، وتكون مسؤولية الشركاء فيها مسؤولية محدودة بقدر ما اشتركوا به في رأس المال.^(٣)

١- رأس مال الشركة:

يتميز رأس مال شركة المساهمة بخصامته، وذلك نظراً لاضطراره بالمشروعات الكبرى التي تعجز عنها قُدرات الأفراد العاديين، ولقيام هذا الشكل من الشركات على الاعتبار المالي دون اعتداد بشخصية الشريك، ولذا يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها، وينقسم

رأس مالها إلى أسهم صغيرة متساوية القيمة قابلة للتداول بالطرق التجارية، وعادةً ما يُحاط جمعه بإجراءات حماية صارمة من قبل التشريعات التجارية والسلطات العامة في الدولة، بقصد توفير الحماية لجمهور المدّخرين وللإقتصاد الوطني بصفة عامة.^(١)

ولعل تقسيم رأس مال شركة المساهمة إلى أسهم صغيرة قابلة للتداول، مع تحديد مسؤولية الشريك بقدر قيمة أسهمه في رأس المال، هو ما أدى إلى ذبوع وانتشار هذا النوع من الشركات كأداة مثلى لجمع المدخرات اللازمة لأي حجم من المشروعات الرأسمالية.^(٢)

٢- اسم الشركة:

فإن شركة المساهمة ليس لها اسم ولا عنوان، فعلي خلاف شركات الأشخاص التي تقوم، كقاعدة عامة، على الاعتبار الشخصي، فإن شركة المساهمة لا تستطيع أن تتخذ من اسم أحد الشركاء فيها اسماً لها، ذلك أن استناد هذه الشركة على الاعتبار المالي يحتم أن تُشَقَّ تسمية الشركة من الغرض الذي قامت وتكونت من أجله، كأن تُسمى "شركة الملاحة الوطنية، شركة التأمين الأهلية، شركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع المركزي للأوراق المالية....." وهكذا.

ويجوز للشركة أن تتخذ تسمية مُبتكرة، ويقصد بالتسمية المبتكرة السمة التجارية التي يتخذها التاجر أو الشركة للتمييز بينها وبين الشركات المماثلة، مثل عبارة "الصالون الأخضر" أو "الأزياء الحديثة" أو "الضوء الذهبي" ويجب أن تشتمل إعلانات الشركة وكافة مُكاتباتها ومُراسلاتها على ما يدل على أنها شركة مُساهمة.^(٣)

وقد استحدث المشرع بمقتضى القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، حكماً جديداً يقضي بجواز أن يتضمن الاسم التجاري لشركة المساهمة اسماً أو لقباً لواحد أو أكثر من مؤسسيها.

٣- مركز الشريك في شركة المساهمة: نظراً للطبيعة المالية - باستثناء فترة التأسيس كما سيلي - لشركة المساهمة، وقيامها على الاعتبار المالي الذي يتوارى معه اعتبار شخصية الشركاء، فإن الشركة لن تتأثر بما يطرأ على شخصية الشركاء فيها من عوارض، كالإفلاس أو الإعسار أو الحجر أو الوفاة، ويدعم ذلك قابلية أسهمها للتداول، والرغبة في استمرار الشركة تؤدي دورها الاقتصادي بمنأى عن أي عارض قد يلحق بأي من الشركاء، ويرتبط بذلك تضاؤل عنصر نية المشاركة لدى جمهور المساهمين - كأحد الأركان التقليدية للشركة - حيث لا يجدو هؤلاء نية

المشاركة في رأس المال، بالمعنى المتعارف عليه، بقدر رغبتهم في الحصول على الأرباح، والمضاربة على أسعار الأسهم.^(١)

هذا، ومسئولية الشريك المساهم في شركة المساهمة عن ديون الشركة محدودة بقدر ما يملكه من أسهم (م ١/٢)، فمتى أوفى بالقيمة الاسمية بالكامل للأسهم التي اكتتب بها في رأس المال، انقطعت صلته بدائني الشركة الذين لا يستطيعون الرجوع عليه بعد ذلك، بطريق مباشر أو غير مباشر، وبالنظر إلى تلك المسؤولية المحدودة للشريك المساهم، فهو لا يكتسب صفة التاجر، لارتباط اكتساب تلك الصفة بالمسؤولية المطلقة عن مخاطر الاستغلال التجاري، ومن ثم فإن إفلاس الشركة لا يستتبع إفلاسه.

ثالثاً: الطبيعة القانونية لشركة المساهمة:

إن اضطلاع الشركات المساهمة بالمشروعات الاقتصادية والتجارية والمالية الكبرى، ذات التأثير الكبير على الاقتصاد الوطني، أدى إلى أن الصفة التعاقدية، التي طالما ارتبطت بفكرة الشركة، قد توارت إلى حد بعيد، وضعف دور مبدأ سلطان الإرادة وحرية التعاقد فيها، لتغلب على هذه الشركات فكرة "النظام القانوني Institution Juridique" الذي تسود فيه إرادة المشرع لا إرادة المتعاقدين، والتي تدخل بمقتضاها بأحكام آمرة لحماية الاقتصاد الوطني وجمهور المدخرين، سواء فيما يتعلق بالانضمام إلى الشركة عن طريق الاكتتاب في أسهمها، أو في أثناء حياتها التي تسير فيها الأمور وفقاً للقواعد القانونية التي يحددها نظام الشركة والأحكام التشريعية الآمرة، وفق ما يُعرف بـ "الشخصية القانونية" للشركة، والمستقلة تماماً عن إرادة المساهمين.^(١)

التنظيم التشريعي لشركات المساهمة في مصر:

ينظم شركات المساهمة في مصر القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والذي أصبح ساري المفعول في الأول من أكتوبر ١٩٨٢، ولائحته التنفيذية الصادرة بمقتضى قرار وزير شؤون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢، وقد ألغت المادة الثانية منه كافة القوانين التي تتعارض مع أحكامه.^(١)

وقد خضع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لتعديلات متلاحقة، لإضافة أو تعديل بعض أحكامه، أو لاستبعاد تطبيقه على بعض المجالات، وذلك في إطار مواكبة التطورات والتحويلات الاقتصادية والاستثمارية التي شهدتها مصر في الفترات التالية لإصداره، وكان ذلك بمقتضى

القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال^(١)، والقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨^(٢)، والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٨^(٣)، وقانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠^(٤)، وقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧^(٥)، وأخيراً القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١^(٦).
نطاق تطبيق القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١:

حدد قانون شركات الأموال رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ نطاق تطبيقه في المادة الأولى (المعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨) من مواد إصداره، التي تنص على أنه: " تخضع لأحكام هذا القانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، التي تتخذ مركزها الرئيس في جمهورية مصر العربية، أو تزاوّل فيها نشاطها الرئيس".

وعلى هذا يسري القانون على الشركات التي تتأسس في مصر وتتخذ فيها مركزاً رئيسياً، لأن المشرع حتم على هذه الشركات أن تتخذ في مصر مركزاً رئيسياً لها، بما يعني أن هذه الشركات تتمتع بالجنسية المصرية، تطبيقاً لمعيار مركز الإدارة، وكذلك على الشركات التي تتأسس في الخارج إذا اتخذت مركزها الرئيسي في مصر.

أما الشركات التي يوجد مركزها الرئيسي في خارج مصر، فلا تخضع، كقاعدة عامة، لأحكام هذا القانون، لكونها شركات أجنبية الجنسية، ومع ذلك تخضع لأحكام هذا القانون الشركات التي يوجد مركزها الرئيسي في الخارج، إذا زاولت في مصر نشاطها الرئيسي، وذلك إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور، كما أن هذا الحكم يعتبر تطبيقاً لنص المادة (٢/١١) من التقنين المدني، التي تقضي بأن: " النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، يسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي...، ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر، فإن القانون المصري هو الذي يسري".

كذلك ينطبق القانون على الشركات التي تؤسس في الخارج ويكون مركزها ونشاطها الرئيس في الخارج، إذا كان لها في جمهورية مصر العربية مركزاً فرعياً أو وكالة أو مكتباً للإدارة أو فرعاً أو مكتب تمثيل أو غير ذلك، إذ ينطبق عليها الباب السادس من قانون الشركات^(٧).

ويلاحظ أن قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣، قد تضمن أحكاماً كثيرة تعدل من نطاق تطبيق قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وتقضي المادة الرابعة من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ووفقاً للمادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، تسري أحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في قانون سوق رأس المال.

كما يعتبر القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، من جهة أخرى أيضاً، بمثابة الشريعة العامة التي ينبغي الرجوع إليها فيما لم يرد به نص في القانون الخاص بشركات قطاع الأعمال العام (الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١)، وهي دائماً تتخذ شكل شركات مساهمة، والشركات التي ينظمها قانون استثمار المال العربي والأجنبي رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، ثم رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والمعدل بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٠٠، والذي حل محله أخيراً قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧^(١).

تقسيم: سنعرض لشركة المساهمة بالدراسة من خلال تقسيمها إلى خمسة مباحث على النحو التالي:

المبحث الأول: تأسيس شركة المساهمة.

المبحث الثاني: الأوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة.

المبحث الثالث: إدارة شركة المساهمة.

المبحث الرابع: مالية شركة المساهمة.

المبحث الخامس: انقضاء شركة المساهمة.

المبحث الأول

تأسيس شركة المساهمة

مقدمة في:

مفهوم تأسيس شركة المساهمة:^(١)

لتحديد مفهوم الشركة المساهمة تحت التأسيس أهمية كبيرة، وذلك من حيث أن الشركة في ذلك الوقت تكون غير موجودة وغير مكتملة البناء القانوني، ومن ثمَّ غير صالحة لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، ومعلوم أن الشركة المساهمة تحت التأسيس تحتاج إلى أعمال وتصرفات متعددة في هذه الفترة حتى يكتمل تأسيسها، حيث تبدأ كفكرة في ذهن أحد

المؤسسين، فإذا ما اقتنع بها آخرون من رجال المال والأعمال تبدأ دراسة المشروع المقترح وجدواه من الناحية الاقتصادية، واتخاذ شكل شركة المساهمة كطريقة لتنفيذه، والبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.^(١)

ويُقصد بتأسيس الشركة القيام بالأفعال المادية والأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لإخراجها إلى حيز الوجود، كشخص قانوني مُستقل عن أشخاص الشركاء، وذلك باتباع الاجراءات التي حددها القانون.^(٢)

وتشمل الأفعال المادية التي يقوم بها المؤسس، إجراء الدراسات الاقتصادية والفنية وربما الاجتماعية والسياسية لمعرفة مدى جدوى المشروع، وتحديد المال اللازم، بينما تتمثل الأعمال القانونية في إعداد عقد التأسيس (العقد الابتدائي) والنظام الأساسي للشركة .

وعلى هذا فإن المؤسسين يقومون بإبرام العديد من التصرفات أثناء فترة التأسيس، ويدخلون مع الأغيار في علاقات تعاقدية لحساب الشركة تحت التأسيس، كتعاقدهم مع الخبراء لبناء مصنع لشركة تحت التأسيس، أو لشراء الأدوات والمهمات اللازمة، ودفع أجور الفنيين والعمال، والتعاقد مع مؤسسات الدعاية والإعلان، والتعاقد مع المكاتب العلمية لإجراء الدراسات والأبحاث التمهيدية لمشروع الشركة.^(٣)

ثم تبدأ مرحلة الاكتتاب في رأس المال، والتي يتخللها نوع من الرقابة من قِبَل السلطة العامة على عملية الاكتتاب، ضماناً لجديته ولدفع حد أدنى من قيمة رأس المال، ثم يلي ذلك، وبعد إغلاق الاكتتاب خلال مدة معينة، دعوة الجمعية العمومية التأسيسية للمساهمين للمُصادقة على تقدير قيمة الحصص العينية المقدمة في رأس المال، والمصادقة على إجراءات التأسيس، وذلك وصولاً إلى القيام بإجراءات شَهْر الشركة وقيدتها في السجل التجاري، واكتسابها، من ثم، الشخصية القانونية اللازمة لمزاولة نشاطها التجاري المحدد.^(٤)

هذا ويتخذ تأسيس شركة المساهمة إحدى وسيلتين تبعاً للطريقة التي يختارها المؤسسون لشكل الشركة: فإما أن يكون ذلك عن طريق التأسيس الفوري Foundation Simultarné، وهو النظام الذي يقتصر فيه المؤسسون في الاكتتاب في أسهم الشركة على أنفسهم، دون الإلتجاء إلى الجمهور في صورة اكتتاب عام، وقد يلجأ المؤسسون إلى طريق الاكتتاب العام "appel au Public"، ويطلق عليها أيضاً التأسيس المتتابع "Foundation Successive"، نظراً لأنها تعتمد في إتمامها على عدة مراحل متتابعة، على خلاف التأسيس الفوري، ويخضع تأسيس الشركة وفقاً لهذه الطريقة، لشروط وإجراءات متميزة ترتبط بخطورة هذا النوع من التأسيس على الادخار

العام، وكيفية استخدامه لخدمة الاقتصاد الوطني، وحماية جمهور المدخرين من وسائل التضليل والاحتيال التي قد يلجأ إليها مؤسسو هذا النوع من الشركات.^(١)

بداية ونهاية فترة التأسيس:

حتى تلتزم الشركة بالتصرفات والأعمال التي قام بها المؤسسون لحسابها في فترة التأسيس، وذلك بعد تأسيسها، لا بد وأن تكون هذه التصرفات قد أبرمت خلال فترة التأسيس، أي خلال الفترة التي يطلق فيها على الشركة المساهمة، الشركة تحت التأسيس.

ذلك أن المشروع خلال هذه الفترة لا يكون قد اكتسب شخصيته المعنوية المستقلة عن أشخاص المؤسسين، لعدم اكتمال إجراءات تأسيسه كشركة ذات كيان قانوني، كما أن هذه الفترة هي التي يتحدد بها الوقت الذي يُعتبر فيه الشخص، القائم بأعمال التأسيس، مؤسساً، وبالتالي تخضع تصرفاته وأفعاله للأحكام الخاصة بالمؤسسين، أيضاً لتحديد الوقت الذي تزول فيه صفة المؤسس، ومن ثم امتناع قيامه بأعمال لحساب الشركة بصفته مؤسساً.^(٢)

ولم يحدد المشرع التجاري في القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بداية ونهاية فترة التأسيس، إلا أنه فيما يتعلق ببداية فترة التأسيس، فلا شك أن التأسيس لا يبدأ بصورة مباشرة بتحرير العقد الابتدائي للشركة والتوقيع على نظامها الأساسي أو إخطار الجهة الإدارية المختصة بتأسيسها وقيدها في السجل التجاري، إذ لا يتصور أن يكون أي من هذه التصرفات هو أول ما قام به المؤسسون من أعمال في سبيل تأسيس الشركة، وإنما لا بد وأن يكون قد سبق ذلك العديد من التصرفات والأعمال التي تلت تبلور فكرة الشركة في ذهن صاحبها، حتى وصل الأمر إلى القيام بهذه الأعمال، وقيام الشركة، من ثم، كشخصية قانونية صالحة لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات.

وبدايةً نستبعد، في هذا الشأن، الرأي القائل بأن فترة التأسيس تبدأ من لحظة بروز فكرة تأسيس الشركة في ذهن أحد الأشخاص، فيسعى إلى إقناع غيره بمجدواها؛ نظراً لأن هذا الرأي يبتعد عن جوهر فكرة التأسيس التي يُرتب عليها المشرع أحكاماً قانونية هامة، كالمسؤولية المدنية والجنائية المقررة على عاتق المؤسسين عند مخالفتهم أحكام فترة التأسيس، كما أننا لا نُسلّم بالرأي السائد في الفقه^(٣) من أن بداية فترة التأسيس تكون من تاريخ كتابة العقد الابتدائي (التأسيسي) الذي يُبرمه المؤسسون فيما بينهم، ويتعهدون فيه على العمل على إنجاز إجراءات التأسيس كاملة، بناءً على اعتباره أول عمل ظاهر الدلالة على الشروع في التأسيس، ومن ثم يعتبر من وقع عليه مؤسساً ويخضع لأحكام تصرفات المؤسسين، دون الأعمال التي وقعت قبله.

ذلك أن هذا الرأي يغفل حقيقة أن تحرير العقد التأسيسي لم يأت من فراغ، وإنما يسبقه، بالضرورة، العديد من الأعمال والتصرفات المتعلقة بإجراء الدراسات الاقتصادية والفنية للمشروع، والتعاقد مع الخبراء القانونيين والمحاسبين والبنوك وبيوت الخبرة للتحقق من جدواه...، وعلى هذا فإننا نرى أن الأرجح هو أن فترة التأسيس تبدأ بالوقت الذي يبدأ فيه العمل الذي يُقصد به البدء في تأسيس الشركة، وبصفة من يقوم بذلك مؤسساً، ويشمل ذلك المؤسس الفعلي والخفي الذي قد لا يظهر اسمه في العقد التأسيسي للشركة، وإنما يقوم بأعمال قاطعة الدلالة في اتجاه قصده إلى الاشتراك في إنجاز الأعمال والإجراءات الفعلية للتأسيس.

أما ما يتعلق بتحديد نهاية فترة تأسيس الشركة المساهمة، والتي يُقصد بها تحديد الوقت الذي تُصبح فيه الشركة مُؤَسَّسة بصورة نهائية، فإن قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قد اعتبر أن الشركة قد أُسِّست بصورتها النهائية، وأن فترة التأسيس قد انتهت، وذلك من تاريخ القيد في السجل التجاري، حيث إن هذا التاريخ تثبت بمقتضاه الشخصية المعنوية للشركة، ويعتبر تاريخاً لتأسيس الشركة المساهمة بصفة نهائية، وفي هذا تنص المادة ٢٠/٢ من هذا القانون على أنه: "لا يجوز للشركة سحب المبالغ إلا بعد شهر نظامها أو عقد تأسيسها في السجل التجاري". وبصدور القانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، نصت المادة ١٧ الفقرة "د" (المعدلة) على أن: "الشركة تُشهر وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مُضي خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها في السجل التجاري".

وعلى ذلك فإن الفقرة (د) من المادة ١٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد تعديلها بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ أكدت على أن نهاية فترة التأسيس لشركة المساهمة تكون بتاريخ قيدها في السجل التجاري، وأضافت أن الشركة لا تشهر ولا تكتسب الشخصية الاعتبارية إلا بعد مُضي خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها في السجل المذكور.^(١)

وبذلك يتحدد مفهوم الشركة تحت التأسيس بأنها الشركة التي تتوافر فيها كافة العناصر المكونة للشركة عدا اكتسابها الشخصية المعنوية، الذي يتحدد تاريخه بمرور خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وبما يعني أن المؤسسين يكونون مسئولين عن أي تصرف يتم في هذه الفترة مسئولية شخصية وتضامنية.

تقسيم: وتفصيلاً لما تقدم سوف نقسم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين:

المطلب الأول: إجراءات تأسيس شركة المساهمة.

المطلب الثاني: الجزاءات المترتبة على مخالفة قواعد التأسيس ومسئولية المؤسسين.

المطلب الأول

إجراءات تأسيس شركة المساهمة

يمر تأسيس شركة المساهمة بعدة مراحل، تبدأ بتحرير العقد الابتدائي وصياغة النظام الأساسي، ويأتي ذلك جمع المال الكافي لتحقيق غرض الشركة، عن طريق طرح الأسهم التي يتكون منها رأس المال، على الاكتتاب العام، والوفاء بقيمة الأسهم، ثم دعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد، وإخطار الجهات المختصة بتأسيس الشركة، وأخيراً اتخاذ الإجراءات القانونية لشهر الشركة واكتسابها الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية المؤسسين والشركاء، وهو ما سنعرض له بالتفصيل في الصفحات التالية، غير أنه يلزم بداية التعرض لمفهوم من يعد مؤسساً للشركة والمركز القانوني لشركة المساهمة تحت التأسيس، ولمصير التصرفات التي أجراها المؤسسون خلال تلك الفترة.^(١)

الفرع الأول

تعريف المؤسس وبيان المركز القانوني للمؤسسين وللشركة تحت التأسيس

الفصل الأول:

تحديد مفهوم المؤسسين والشروط الواجب توافرها في المؤسس.

أولاً: مفهوم المؤسسين:

يرجع للمؤسسين الفضل في إيجاد شركات المساهمة وظهورها ككيان اقتصادي، فلولا وجود المؤسس ما وجدت الشركة، فهو من أوجد فكرة المشروع وعمل على تحويله إلى شركة قائمة، وذلك من حيث تحديد الغرض وتحديد مقدار رأس المال، وإبرام الصفقات القانونية التي تتعلق بها، كالاتفاق مع البنوك لتلقي الاكتتاب، ومع الخبراء والفنيين واستخدام العمال، ونظراً لخطورة وأهمية هذا الدور الذي يضطلع به مؤسسو شركات المساهمة، فإنه يجب تحديد مفهوم المؤسس وتمييزه عن غيره ممن يرتبطون بالشركة في مرحلة التأسيس، أيضاً ضرورة معرفة الشروط الواجب توافرها فيه.

وبالإضافة إلى ما سبق لنا ذكره من أهمية الدور الذي يقوم به مؤسسو شركات المساهمة في إيجاد هذا النوع من الشركات، باعتبارهم أنهم من يرسمون معالم وخطوات إنشاء الشركة في الواقع

العملي، فإن تعريف المؤسس، بصفة عامة، له أهمية من الناحية العملية والناحية القانونية على السواء.

وتظهر أهمية الدور الذي يلعبه المؤسسون وتأثيره المباشر على مصالح العديد من الأغيار في فترة التأسيس، من جهة أن إجراءات تأسيس الشركة يمكن أن تطول، ويتعدد الأشخاص المشاركون في عملية التأسيس، وخاصة ما يتعلق بجمع رأس مال الشركة المساهمة عن طريق الاكتتاب العام، وما يمكن أن يشوب إجراءاته من وسائل قد تنطوي على غش أو تحايل مما قد يُسبب الضرر للغير، وتقدير الحصص العينية المقدمة في رأس المال بأكثر من قيمتها، والمسئولية المدنية والجنائية التي تترتب على عاتق المؤسسين من جرائمها، وردعاً لأمثال هؤلاء الذين قد يسعون إلى إنشاء شركات وهمية للاستيلاء على مدخرات الأفراد والإضرار بالاقتصاد القومي.^(١)

كذلك فإن تحديد المشرع لحد أدنى من حيث عدد المؤسسين لصحة إجراءات تأسيس شركات المساهمة "ذات الاكتتاب العام على وجه الخصوص"، والاعتبار الشخصي الذي يمكن أن نلاحظه في هؤلاء، كعامل يمكن أن يكون هاماً لنجاح مشروع التأسيس، كل ذلك وغيره من الآثار القانونية التي ترتبط بتحديد من يعد مؤسساً، يعكس أهمية تحديد مفهوم "المؤسس" في شركة المساهمة، وذلك للوصول إلى تحديد مركزه القانوني.^(٢)

الخلاف الفقهي حول تحديد مفهوم المؤسس: وقد أثار تعريف من يعتبر مؤسساً خلافاً فقهيّاً، ما بين اتجاه يأخذ بالمفهوم الضيق، وآخر يتبنى المفهوم الواسع في بيان تعريف مؤسس الشركة المساهمة، وهو اختلاف يعود، كما قلنا، لطول إجراءات التأسيس، وتعدد الأدوار التي يقوم بها القائمون عليها واختلاف صورهم وطبيعة مسئوليتهم القانونية.

حيث يذهب اتجاه في الفقه إلى تعريف المؤسس تعريفاً ضيقاً، وينطلق هذا الاتجاه من أن التوسع في مفهوم المؤسس يصعب الأخذ به عندما نكون بصدد الجزاءات الجنائية، حيث يصطدم بمبدأ التفسير الضيق السائد في مجال المواد الجنائية.^(٣)

لذلك فإنه، وفقاً لهذا الاتجاه، يقتصر وصف المؤسس على كل من قام بإجراء قانوني لازم لتأسيس الشركة بوصفه مؤسساً، كتوقيع العقد الابتدائي للشركة أو نظامها الأساسي أو تقديم حصة عينية أو ظهور اسمه في نشرات الاصدار، حيث يفترض في مثل هذه الحالات توافر صفة المؤسس لدى هذا الشخص، وقيام مسئوليته عن إجراءات التأسيس بحكم القانون.^(٤) بحيث لا يستطيع أن ينفي مسئوليته عن أعمال التأسيس.^(٥)

وقد انتقد الفقه في مجمله الاتجاه الضيق في تعريف المؤسس، على اعتبار أنه يؤدي إلى إمكانية الغش والتدليس، وذلك بابتعاد المؤسس الحقيقي عن الظهور في إجراءات التأسيس حتى يعفى من المسؤولية، وإلقائها على غيره ممن يعتبرهم القانون مؤسسين، وقد ذهب هذا الاتجاه إلى أن صفة المؤسس يمكن أن تلحق كذلك بأي شخص من واقع نشاطه السابق على تأسيس الشركة.^(١)

ويتوسع هذا الاتجاه في تحديد مفهوم المؤسس، فيعتبر أن المؤسس هو كل من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة المساهمة بنية تحمل المسؤولية الناشئة عن الإخلال بإجراءات التأسيس، دون أن ينحصر نشاطه في التوقيع على العقد الابتدائي أو النظام الأساسي أو تقديم طلب الترخيص بإنشاء الشركة أو تقديم حصة عينية في رأس مالها.^(٢)

ونحن من جانبنا نرجح هذا الاتجاه، ذلك أنه إذا كانت الأحكام القانونية المتعلقة بتأسيس الشركة المساهمة تهدف، بصفة عامة، إلى حماية الادخار العام، فإنه يتعين التوسع في تعريف المؤسس، بحيث ينسحب هذا الوصف على كل من قام بمبادرة أو عمل إيجابي في سبيل تأسيس الشركة، ولو لم يوقع على العقد الابتدائي، أو حتى لم يكن من المساهمين.

كما أن في الأخذ بهذا الاتجاه ما يمكن أن يزيد الفرصة أمام الأغيار، ممن تلحقهم أضرار من جراء أفعال المؤسسين الفعليين، في اقتضاء حقهم في التعويض، بزيادة عدد من ينطبق عليهم وصف المؤسس، كما أن هذا النظر سوف يدفع هذا الأخير إلى أن يعمل على احترام أحكام القانون الخاصة بإجراءات التأسيس، كلما أدرك أن المسؤولية المدنية والجنائية سوف تطله عند الإخلال بهذه الأحكام.^(٣)

ويرى البعض في الفقه أنه يجب إعمال هذا التعريف "الموسع لمفهوم المؤسس" ليشمل، فضلاً عن الحالات التي تتقرر فيها المسؤولية المدنية للمؤسسين عن الأضرار الناجمة عن الإخلال بقواعد وإجراءات التأسيس، الحالات التي يكون فيها فعل المؤسسين مكوناً لجريمة يُعاقب عليها قانون العقوبات، ذلك لأن المؤسس الفعلي وإن لم تقترب يداه الفعل المؤثم، إلا أنه سيكون بمثابة المحرض أو الشريك للمؤسسين.^(٤)

مفهوم المؤسس في قانون الشركات:

وقد حرص المشرع التجاري المصري على تحديد مفهوم المؤسس وفقاً لهذا التفسير الموسع، فنص في المادة ١/٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن المؤسس هو: "كل من يشترك

اشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة بنية تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك، ويسري عليه حكم المادة ٨٩ من هذا القانون".

وعلى هذا فإن صفة المؤسس تنطبق على من ساهم في التأسيس إذا توفر فيه عنصران:
١- عنصر مادي: يتمثل في المشاركة الفعلية في تأسيس الشركة بأعمال قانونية أو مادية.
٢- عنصر معنوي: يتمثل في وصول المشاركة الفعلية إلى الحد الذي يُفيد الرغبة الصادقة من قبل المؤسس في تحمل المسؤولية الناجمة عن عملية التأسيس.

وبذلك يكون النص قد استبعد، من مجال انطباق وصف المؤسس، الأشخاص المروجين للمشروع بأعمال دعائية، أو من يقتصر دورهم على دعوة الغير للاكتتاب في أسهم الشركة أو مجرد تحصيل قيمة الأسهم، إذ أن هؤلاء، رغم اشتراكهم الفعلي في تأسيس الشركة، لم تتوفر فيهم نية تحمل المسؤولية الناشئة عن عمليات التأسيس، وهو ما أكدته المشرع بنصه في الفقرة الثالثة من المادة السابعة على أنه لا يعتبر مؤسساً: "كل من يشترك في التأسيس لحساب المؤسسين من أصحاب المهن الحرة وغيرهم".

كما أنه وحمايةً لجمهور المدخرين من أي تحايل يلجأ إليه المؤسسون، الذين يقومون بكافة الأعمال اللازمة لتأسيس الشركة، ويمتنعون عن التوقيع على عقدها الابتدائي بغرض التنصل من المسؤولية التي قد تترتب عليها، تحايلاً على أحكام القانون الخاصة بإجراءات تأسيس الشركات المساهمة، قرر المشرع صراحةً مد صفة المؤسس على المؤسس الظاهر والذي يوقع على العقد الابتدائي "والمؤسس الفعلي، فنص في الفقرة الثانية من المادة السابعة على أنه: "يعتبر مؤسساً على وجه الخصوص كل من وقع على العقد الابتدائي، أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة، أو قدم حصة عينية عند تأسيسها" وهي قرينة قطعية لا تقبل إثبات العكس.

وعلى هذا يمكن تعريف المؤسس بأنه: "كل من قام بفعل مادي أو إجراء قانوني من شأنه أن يساهم بفاعلية في تأسيس شركة المساهمة، وبنية تحمل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك".^(١)

المؤسس قد يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً متمتعاً بالأهلية القانونية:

وقد يكون المؤسس شخصاً طبيعياً، وهو الأصل، باعتباره الأكثر صلاحية لاكتساب الحقوق والقادر على التحرك فعلياً لمباشرة إجراءات التأسيس، والذي يُمثل المحل الأصلي للمسؤولية المدنية والجنائية والتحمل بتبعاتها^(٢)، وقد يكون المؤسس شخصاً اعتبارياً، سواء كان شخصاً اعتبارياً عاماً أو خاصاً، إذا كان من بين أهدافه التي أنشأ من أجلها تأسيس الشركات

المساهمة^(١). وذلك يكون عن طريق وجود ارتباط بين نشاط وأغراض الشخص المعنوي الراغب في التأسيس، ونشاط وأغراض الشركة المطلوب تأسيسها، حتى تظهر بوضوح أسباب وأهداف دخول الشخص المعنوي في تأسيس شركات أخرى، منعاً لتكدس الأموال دون أية رابطة بين الشركات المؤسسة، وإلا فإنه لا يستطيع القيام بإنشاء الشخص المعنوي الجديد إلا بإجراءات تغيير غرضه هو أولاً، ثم بعد ذلك يكون حراً في تأسيس الشخص المعنوي.^(٢)

ثانياً: الشروط الواجب توافرها في المؤسس:

اشتراط القانون بعض الشروط في المؤسسين، وذلك بقصد توفير قدر من الحيطة والنزاهة والجدية لدى من يتصدى لتأسيس هذا النوع من الشركات: ونعرض لهذه الشروط على النحو التالي:

١- عدم جواز الجمع بين وظيفة عامة والاشتراك في تأسيس شركة مساهمة:

يشترط المشرع في المؤسس ألا يكون من العاملين في الحكومة أو القطاع العام، أو أية هيئة عامة، إلا إذا كان ممثلاً لهذه الجهات، وعلى هذا نصت المادة ١٧٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بأنه: "لا يجوز لأي شخص الجمع بين أي عمل في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل ويجوز الاستثناء من حكم الفقرة السابقة... بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء..... وبشرط ألا يتعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها".

وقد كان من الواجب أن يمتد نطاق هذا الحظر ليسري أيضاً على أعضاء المجالس النيابية أثناء مدة عضويتهم، خاصة وأن الحظر ليس مقصوداً لذاته، وإنما لدرء شبهة استغلال النفوذ السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي^(٣). ويترب على مخالفة هذا الحظر بطلان التأسيس وذلك تلافياً لاستغلال نفوذ الوظيفة العامة لتحقيق مصالح خاصة.^(٤)

٢- ألا يكون المؤسس قد حكم عليه بعقوبة في جريمة محلة بالشرف والأمانة أو في إحدى

الجرائم المنصوص عليها قانوناً، ما لم يُرد إليه اعتباره:

يخضع المؤسس في شركة المساهمة لذات القيود التي يخضع لها أعضاء مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق باستبعاد كل من حُكِم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة، من سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفاليس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد ١٦٢، ١٦٣،

١٦٤ من قانون الشركات، وهي المواد خاصة بتقرير الجزاءات الجنائية التي تطبق بمناسبة مخالفة إجراءات تأسيس وإدارة الشركة وفقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١^٥.

درجة العناية الواجبة على المؤسس:

على المؤسس أن يبذل عناية الرجل الحريص في كافة معاملاته مع الشركة المساهمة تحت التأسيس أو لحساب هذه الشركة، حيث تنص المادة ١/١١ من قانون الشركات على أنه: "يجب على المؤسس أن يبذل في تعاملاته مع الشركة المساهمة تحت التأسيس أو لحسابها، عناية الرجل الحريص، ويلتزم، في هذا الشأن، بأية أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة هذا الالتزام، والمقصود بعناية الرجل الحريص هنا، على ما استقر عليه الفقه، هو بذل عناية الرجل المعتاد، باعتبار هذه الدرجة من العناية هي الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه عند إبرام المؤسس لأية عقود أو تصرفات لحساب الشركة تحت التأسيس.

والالتزام ببذل عناية الرجل الحريص هو في واقع الأمر التزام بالحرص العام، الذي يعني بالضرورة قيام المؤسس ببذل العناية الإيجابية التي تتطلبها عمليات تأسيس الشركة، وتقاس هذه العناية على ضوء معيار موضوعي يناط بالمألوف من عناية سواد الناس، وبدرجة العناية المطلوبة في مثل هذه الأعمال التي تتم لحساب الشركة تحت التأسيس، وعلى ضوء إمكانيات ومتطلبات تأسيس هذه الشركة ومدى لزوم هذه الأعمال عند تأسيسها.^٥

الحد الأدنى لعدد المؤسسين:

يقضي قانون الشركات الحالي رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في المادة الثامنة (المعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨) على أنه: " فيما عدا شركات الشخص الواحد، لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة".

ولعل الهدف من وراء اشتراط عدد معين في المؤسسين عند إنشاء وتأسيس شركات المساهمة، هو محاولة القضاء على الشركات الوهمية أو التي تمثل شريكاً واحداً في جوهرها، ولما كانت هذه الحكمة لا تتوافر في الحقيقة، حيث واقع الحال أنه يمكن تسجيل شركات يكون للشريك الواحد فيها ما يزيد على ٩٥٪ من رأس المال، فإن الثابت أنه من الأفضل الرجوع إلى القواعد العامة في العقود، وهي الاكتفاء بشريكين على الأقل في جميع الشركات أياً كانت طبيعتها.

وعلى خلاف ما يوحي به ظاهر نص المادة (١/٨) شركات - من أنه يجب أن يكون المؤسس شريكاً في الشركة وألا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة - فإن بعض الفقهاء يرى، وبحق،

أن حمل النص على معناه الحقيقي يُفيد أن المشرع لم يقصد وضع حد أدنى لعدد المؤسسين، إذ من الجائز أن يقوم باتخاذ إجراءات التأسيس شخص واحد أو أكثر، وأن ما قصد إليه في الواقع هو وجوب ألا يقل العدد عن ثلاثة أشخاص في حالة اقتصار الاكتتاب في رأس مال الشركة على المؤسسين وحدهم، إذ يُصبحون عندئذٍ شركاء في الشركة.^(١)

هذا واشتراط وجود ثلاثة شركاء مؤسسين على الأقل عند تأسيس الشركة المساهمة، هو شرط لاستمرارها أيضاً، وفي ذلك تنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أنه: "وإذا قلَّ عدد الشركاء عن النصاب المذكور في الفقرة السابقة اعتبرت الشركة مُنحلة بحكم القانون، إن لم تُبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب، ويكون من يبقى من الشركاء مسؤولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة".

ومن الناحية المقابلة فإن المشرع - وعلى خلاف اتجاهه بتحديد حد أدنى لعدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة - لم يضع حداً أقصى لعدد الشركاء، وذلك نظراً للاعتبار المالي في هذا النوع من الشركات، وبما يستتبعه من ضعف نية المشاركة لدى المساهم الذي يهيمه - في المقام الأول - المضاربة على قيمة ما يحمله من أسهم، بقصد الحصول على أقصى ربح ممكن، دون اعتبار لنية العمل والتعاون مع بقية الشركاء من أجل إنجاح مشروع الشركة أو تحمل مخاطره. الغصن الثاني: المركز القانوني للمؤسسين وللشركة تحت التأسيس.

يقوم المؤسسون في الشركات المساهمة بالعديد من الإجراءات التي يتطلبها تأسيس الشركة، ويبرمون في هذا الصدد العديد من التصرفات القانونية ويقومون بالأعمال المادية التي يتطلبها المشروع الاقتصادي، ويتم ذلك قبل أن يكون للشركة وجود قانوني على أرض الواقع، ويحيط بعملية التأسيس وبالمؤسسين أنفسهم الكثير من الظروف القانونية والواقعية، وذلك كفشل مشروع التأسيس أو إفلاس أحد المؤسسين أو وفاته، وما قد يلحق بهم، نتيجة لذلك، من خسائر باهظة فضلاً عن المسؤولية المدنية والجنائية.^(٢)

ويحتاج الأمر في هذه الحالة إلى معرفة كيف تنصرف آثار التصرفات إلى الشركة دون أن تدخل في ذمة المؤسسين، ومن يتحمل خلال هذه الفترة عبء التعهدات والديون، هل هم المؤسسون - بصفاتهم الشخصية - أم الشركة التي تكون في طور التأسيس ولم تتمتع بعد بالشخصية القانونية، وإذا اعتبرت الشركة هي المتعاقدة، فما هو الأساس القانوني لتفسير اكتسابها الحقوق المترتبة على هذه التصرفات وتحملها الالتزامات الناشئة عنها.^(٣)

ولا تشور المشكلة في حالة فشل مشروع تأسيس الشركة، إذ يتحمل المؤسسون فشل المشروع، ويكونون مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن جميع التصرفات التي قاموا بها، وكذلك عن المصروفات التي قاموا بإنفاقها في تأسيس الشركة^(١).

ويستفاد هذا الحكم صراحةً من نص المادة ١٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ التي يقضي بأنه: "إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بإنشائها جاز لكل مكتب أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين من يقوم برد الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين، وللمكتب أن يرجع على المؤسسين على سبيل التضامن بالتعويض عند الاقتضاء، كما يجوز لكل من اكتتب أن يطلب استرداد قيمة ما اكتتب به في رأس مال الشركة تحت التأسيس إذا مضت سنة من تاريخ الاكتتاب دون البدء في اتخاذ إجراءات التأسيس".

أيضاً يُستفاد ذات الحكم من القاعدة العامة التي أرستها المادة (١٠) من القانون المشار إليه، التي تنص على أن "يكون المؤسسون مسئولين بالتضامن بما التزموا به، ويعتبر المؤسس الذي التزم عن غيره، ملزماً شخصياً إذا لم يُبين اسم موكله في عقد إنشاء الشركة أو إذا اتضح بطلان التوكيل الذي قدمه".

ولكن الصعوبة تثور إذا قدر لمشروع الشركة النجاح ومن ثم اكتسابها الشخصية المعنوية، إذ المقرر في هذه الحالة انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن تصرفات المؤسسين في فترة التأسيس إلى الشركة المساهمة، حيث يثور التساؤل حول الأساس القانوني لقيام المؤسسين بهذه الأعمال والتصرفات لحساب الشركة تحت التأسيس.

وقد ساق الفقه من جانبه العديد من الآراء والنظريات التي حاولت الإجابة عن هذا التساؤل، ومن ثم عن بيان المركز القانوني للمؤسس وهو يتصرف لحساب الشركة تحت التأسيس:

١- اتجاه يرى أن المؤسس يتصرف باسمه ولحسابه:

فهناك اتجاه في الفقه ينكر على الشركة المساهمة تحت التأسيس، تمتعها بأي وجود قانوني قبل اكتمال إجراءات تأسيسها واكتسابها الشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة عن أشخاص المؤسسين، ووفقاً لهذا الاتجاه فإن المؤسس لا يقوم بالتصرفات خلال فترة التأسيس كممثل للشركة، وإنما يتعاقد باسمه الخاص ولحسابه، وهو وحده الدائن والمدين، وعند تأسيس الشركة ينقل هذه الحقوق والالتزامات إلى الشركة.

وعلى هذا فإنه لا محل للبحث عن أساس قانوني لتحديد العلاقة بين المؤسسين والشركة المساهمة تحت التأسيس، ذلك أن البحث عن هذا الأساس يفترض الاعتراف للشركة في هذه الفترة بوجود قانوني يسمح للمؤسسين أن يتصرفوا لحساب الشركة، دون أن يضطروا لتكرار نقل الحقوق والالتزامات المترتبة على تصرفاتهم لمصلحة الشركة بعد تأسيسها. ويرفض الفقه في مجمله هذا الرأي.

٢- نظرية الاشتراط لمصلحة الغير:

بينما يذهب البعض من الفقهاء إلى أنه يمكن تفسير انتقال الحقوق والديون المترتبة على التصرفات التي أبرمها المؤسسون إلى ذمة الشركة وفقاً لنظرية الاشتراط لمصلحة الغير، والمشتراط في هذه الحالة هو المؤسس، والمتعاقد معه هو المتعهد لمصلحة الشركة المساهمة تحت التأسيس، فالمؤسس يتعاقد باسمه الخاص لمصلحة الشركة المستقبلية، وهي إن كانت غير موجودة وقت التعاقد أو وقت الاشتراط لمصلحتها، إلا أن ذلك لا يتعارض مع طبيعة الاشتراط لمصلحة الغير في القواعد العامة، التي تقضي بأنه يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقلة، كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم يُعينا وقت العقد متى كان تعيينهما مستطاعاً وقت أن يُنتج العقد أثره طبقاً للمشاركة.^(١)

وبناءً عليه، فإن الشركة، بعد اكتمال تأسيسها، ستحل محل من تصرف لحسابها من المؤسسين، والمشتراط (المؤسس) يشترط لمصلحة الشركة تحت التأسيس، وهو ما يعني أن آثار هذه التصرفات ستصرف مباشرة لمصلحة الشركة بعد تمام تأسيسها، وبمجرد قبولها من الجمعية التأسيسية دون أن تدخل في ذمة المؤسسين.^(٢)

وقد عيب على نظرية الاشتراط لمصلحة الغير أن هذا الاشتراط قابل للفسخ من جانب المشتراط ما دام أن المنتفع لم يعلن قبوله لهذه المشاركة^(٣). وهو ما يمكن أن يُهدد تأسيس الشركة أو يُخل بالمرآة القانونية الناشئة عنه لو أعلن المؤسس رغبته في نقض التصرف أو الرجوع فيه قبل إعلان الشركة موافقتها عليه.

كما أن هذه النظرية، وإن كان من شأنها انتقال الحقوق المترتبة على تصرفات المؤسسين لمصلحة الشركة، إلا أنها تعجز عن إيجاد أساس قانوني لتحملها بالالتزامات المترتبة عليها وذلك بعد تمام تأسيسها.^(٤)

٣- نظرية الوكالة:

يرى جانب في الفقه أن المؤسس يعمل خلال فترة التأسيس بصفته وكيلاً عن الشركة المساهمة تحت التأسيس، ويقوم بهذه الصفة بالأعمال المادية والتصرفات القانونية اللازمة للتأسيس، ويستند هذا الاتجاه إلى أن الجمعية التأسيسية للشركة تستطيع إعطاء توكيل لشخص أو أكثر للقيام بمثل هذه التصرفات، فلم لا يمكن اعتبارهم موكلين عن الشركة وهي في طور التكوين، كما أن الشخصية المعنوية المحدودة المعترف بها للشركة تحت التأسيس تعطىها الأهلية القانونية بالقدر الكافي لتوكيل المؤسسين في مباشرة بعض التصرفات نيابة عنها، ويترتب على ذلك أن تصرفات المؤسسين كوكلاء عن الشركة تحت التأسيس تلزم الشركة بعد اكتمال تأسيسها إذا كانت من مقتضى الوكالة. ^(١)

ولا يخفى أن هذا الرأي لا يمكن قبوله بحال، حيث أن المؤسس لم يتعاقد مع الشركة تحت التأسيس حتى يقال بوجود عقد وكالة، كما أنه يشترط لصحة الوكالة أن يكون بمقدور الأصيل القيام بالتصرف، والشركة خلال فترة التأسيس لا تملك أهلية التصرف، كما أن من أركان الوكالة، كأي عقد من العقود، الرضا الصادر من ذي أهلية، ومعلوم أن الشركة تحت التأسيس غير متمتعة بالأهلية القانونية التي تؤهلها لتوكيل أشخاص للقيام بتصرفات قانونية لحسابها. ^(٢)

٤- فكرة الفضالة:

يرى أنصار هذا الاتجاه أنه يمكن رد العلاقة بين المؤسس والشركة المساهمة تحت التأسيس إلى أحكام الفضالة، فالمؤسس يُعتبر فضولياً يعمل لحساب الشركة المستقبلية، ويجب عليه وفقاً لأحكام الفضالة أن يَحْضِيَ في العمل الذي بدأه، وهو إجراءات تأسيس الشركة، إلى أن يتمكن رب العمل - الشركة المستقبلية - من مباشرته بنفسه، ويكون المؤسسون متضامنين معه في المسؤولية. ^(٣)

ويؤخذ على هذا الرأي أن الفضالة وفقاً لتعريفها في القواعد العامة بـ: "أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملتزماً بذلك" (المادة ١٨٨ مديني مصري) تفترض أنه لا بد للمؤسس أن يقوم بعمل ضروري أو عاجل لحساب الشركة تحت التأسيس حتى تلتزم به. ^(٤)

والمقرر أن تأسيس الشركة ليس من الأمور العاجلة التي تستدعي أن يتولى المؤسس عن قصد القيام بها، ثم إنه وفقاً لتعريف الفضالة، المشار إليه، يفترض أن يكون رب العمل الذي يعمل

الفضولي لحسابه موجوداً سلفاً (لحساب شخص آخر) والواقع، فيما يتعلق بالشركة المساهمة تحت التأسيس، أنها غير موجودة كشخص معنوي قائم بالفعل، وينحصر عمل المؤسس في إنشائها ابتداءً.^(١)

ومن ناحية أخرى فإن تطبيق سائر أحكام الفضالة على قيام المؤسسين بالإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة المساهمة، سيؤدي إلى نتائج تتعارض مع حقيقة الأمر بشأن الوضع القانوني للشركة المساهمة تحت التأسيس، ويظهر ذلك مما تقضي به هذه الأحكام من أن الفضولي يعتبر نائباً عن رب العمل متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وعندئذ يكون رب العمل ملزماً بتنفيذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وأن يعرضه عن التعهدات التي التزم بها^(٢)، كذلك تقضي أحكام الفضالة أنه يجب على الفضولي أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.^(٣)

ولا يخفى أن أيّاً من هذه الأحكام لا يمكن أن تنسجم مع طبيعة الشركة المساهمة تحت التأسيس، والفرض أنه لم توجد بعد كشخص قانوني قادر على الالتزام بالديون أو اكتساب الحقوق على نحوٍ كامل، إذ أنها لن تستطيع، والحال كذلك، أن تلتزم بالتعهدات التي عقدها المؤسس لحسابها في حال فشل المشروع، كما أن المؤسس، كفضولي حسب هذا الرأي، لن يستطيع أن يخطر (وفقاً لنص المادة ١٩١ مدني) بتدخله، الشركة (كرب عمل) والفرض أنها لم يتم إنشاؤها بعد.^(٤)

٥- المؤسس يعمل بوصفه ممثلاً للشركة تحت التأسيس. كشخص معنوي.

وعلى ما تقدم فإن الذي يبدو أن المركز القانوني الصحيح لمؤسسي شركات المساهمة لا يمكن تكييفه، من الناحية القانونية، وفق نظريات القانون المدني، ذلك أن مركز المؤسس يكتسب وضعاً قانونياً مستقلاً عن سائر المراكز القانونية في القواعد العامة، كالوكيل أو الفضولي أو المشترط لمصلحة الغير، فالمؤسس يقوم بأعمال مادية وتصرفات قانونية لا يمكن تفسيرها وفق الأنظمة السابقة، حيث إن هذه التصرفات ستنقل إلى ذمة الشركة بعد اكتمال إجراءات تأسيسها، وفق نظام معين يتفق مع طبيعة المركز القانوني للمؤسس تجاه الشركة في هذه الفترة، هذا المركز القانوني الخاص الذي أعرب المؤسسون عن إرادتهم في الأخذ به، من خلال بداهم في اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس الشركة، وهي إجراءات إلزامية تنتج آثاراً قانونية، فتمت هذه الإجراءات تم تأسيس الشركة.^(٥)

والرأي الذي استقر عليه الفقه الآن، والمؤيد بالنصوص التشريعية، هو أن المؤسسين، لدى قيامهم بإبرام الأعمال والتصرفات لحساب الشركة تحت التأسيس، إنما يعملون بوصفهم ممثلين لشخص معنوي هو الشركة المساهمة تحت التأسيس، على النحو الذي عرضناه، وأن الشركة تلزم بهذه التصرفات بناءً على أنها تتمتع بشخصية معنوية محدودة بالقدر اللازم لإتمام إجراءات التأسيس.^(١)

الفصل الثالث: مصير التصرفات التي أجراها المؤسسون خلال فترة التأسيس.

تقدم أن المؤسسين يباشرون، خلال فترة التأسيس، العديد من الأعمال والتصرفات سواء فيما بينهم أو مع الشركة المساهمة تحت التأسيس أو مع المكتتبين أو مع الغير، والمقرر هنا أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العلاقات القانونية التي تقوم بين المؤسسين أنفسهم أثناء فترة التأسيس لا تسري في حق الشركة بعد أن يتم تأسيسها، وإن كانت ذات أهمية كبيرة في إبراز الشركة إلى حيز الوجود ككيان قانوني واقتصادي، فالاتفاقيات المبدئية التي تبرم فيما بين المؤسسين، كالعقد الابتدائي الذي يعد بمثابة نقطة البداية من الناحية القانونية في حياة الشركة، لا يكون من شأنه أن يلزم الشركة بشيء بعد تأسيسها، فهو ملزم لأطرافه - المؤسسين - فقط كاتفاق تعاقدي، وسواء في هذا الشأن نجح مشروع تأسيس الشركة أو فشل.

ولكن ما يجب التعرض له في هذا الصدد هو مصير التصرفات الناشئة عن العلاقة بين المؤسسين والشركة المساهمة تحت التأسيس من ناحية، كذلك التصرفات التي تتم بين المؤسسين - لحساب الشركة تحت التأسيس - والغير من ناحية أخرى

أولاً: التصرفات التي تنشأ عن العلاقة بين المؤسسين والشركة المساهمة تحت التأسيس:

يحدث أن يرم المؤسسون عقوداً مع الشركة المساهمة تحت التأسيس، وترتب هذه العقود حقوقاً والتزامات متبادلة بين الطرفين، ولا يخفى ما قد تنطوي عليه هذه العقود من تحميل الشركة بالتزامات لمصلحة المؤسسين تشوبها مظنة محاباة هؤلاء المؤسسين، مما يلحق الضرر بالشركة وبالمساهمين، ولذا، ونظراً لأن شخصية الشركة وهي في طور التأسيس تكون محدودة بالقدر اللازم لإتمام تأسيسها، فإن المقرر قانوناً هو أن هذه التصرفات لن تسري في حق الشركة، أي أن هذه التصرفات ليست ملزمة للشركة إلا وفق ضوابط معينة، فلها مطلق الخيار، بعد تأسيسها، في رفضها أو قبولها.^(٢)

وهذا ما قرره المادة ١٢ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بنصها على أنه "لا يسري في حق الشركة بعد تأسيسها أي تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس وبين مؤسسيها ما لم يعتمد هذا التصرف من مجلس إدارة الشركة إذا كان أعضاؤه جميعاً لا صلة لهم بمن أجرى التصرف من المؤسسين، أو لم تكن لهم مصلحة في التصرف، أو من جماعة الشركاء، أو بقرار من الجمعية العامة للشركة في اجتماع لا يكون فيه للمؤسسين ذوي المصلحة أصوات معدودة..". وبذلك يكون المشرع التجاري المصري قد وضع قاعدة عامة لهذه التصرفات، وهي أن الأصل في مثل هذه التصرفات التي يجريها المؤسسون مع الشركة تحت التأسيس، هو عدم التزام الشركة بها، ومع ذلك يسري التصرف في حق الشركة في حالات معينة ذكرها النص، الأمر الذي سنعرض له على النحو التالي:

١ - حالة إقرار التصرف من قبل الجهة المنوط بها ذلك:

والجهة المنوط بها إقرار التصرف، في هذه الحالة، هي:

أ- مجلس الإدارة:

ويشترط لصحة إقراره لهذه التصرفات أن يكون جميع أعضائه غير مرتبطين بأية صلة بالمؤسس الذي أبرم التصرف مع الشركة، كأن يكون من ذوي القربي أو ممن تربطهم بالمؤسس صداقة متينة يخشى معها المحاباة، أو كان لكل أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم مصلحة في التصرف، كأن يكون بعضهم أو أحدهم شريكاً مع المؤسس في الصفقة، ولو كان ذلك بطريقة غير مباشرة.

ب- الجمعية العامة التأسيسية للشركاء:

يجوز اعتماد هذه التصرفات التي تبرم بين المؤسسين والشركة المساهمة تحت التأسيس من قبل الجمعية العامة العادية (التأسيسية)، ويأتي اختصاصها لإقرار مثل هذه التصرفات، في اعتقادنا، بالنظر لاحتمال أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة لهم صلة بهذا التصرف، ومن ثم لا تنطبق عليهم شروط صحة القرار، ذلك أنه غالباً ما يكون المديرون الأوائل وأعضاء مجلس الإدارة من المؤسسين، ولذا يشترط أيضاً لصحة اعتماد التصرف أن يستبعد من المشاركة في التصويت من تعاقد مع الشركة أو كان له مصلحة فيه. وتكون الموافقة على التصرف هنا بالأغلبية المثلثة لرأس المال أو للحاضرين أو حسب ما يقرره النظام الأساسي للشركة، ويمكن أن تشترط أغلبية خاصة، كما في حالة التصويت على تقدير الحصص العينية.^(١)

فإذا وافقت الجهة المشار إليها على اعتماد هذه التصرفات - وعادة ما توافق مجاملةً للمؤسسين الذين ساهموا بمجهودهم في إخراج الشركة إلى حيز الوجود - كانت الشركة ملزمة بها وتنتقل إليها آثار هذه التصرفات في مواجهة المؤسسين.

٢- حالة رفض إقرار التصرف من قبل الجهة المختصة في الشركة.

قد يحدث أن ترفض الجهات المختصة في الشركة إقرار التصرفات التي أبرمت بين المؤسسين وبين الشركة تحت التأسيس، لأي من أسباب عدم توافر شروط الإقرار، وهنا نرجع إلى الأصل العام الذي أشرنا إليه، وهو عدم سريان هذه التصرفات في مواجهة الشركة بعد تأسيسها، حيث سيتحملها المؤسسون بصفتهم الشخصية، دون أن يخل ذلك بحقهم في الرجوع على الشركة وفق شروط الإثراء بلا سبب إذا أفادت الشركة منها.

ثانياً: التصرفات التي تنشأ عن العلاقة القانونية بين المؤسس والغير.

فيما يتعلق بالتصرفات القانونية التي يبرمها المؤسسون مع الغير لحساب الشركة المساهمة تحت التأسيس، فإن المادة (١٠) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قد أوردت قاعدة عامة بهذا الشأن، تقضي بالمسئولية التضامنية للمؤسسين في جميع الأحوال عن هذه التصرفات، سواء أبرمت باسم الشركة تحت التأسيس أو باسم المؤسسين شخصياً، بنصها على أن "يكون المؤسسون مسئولين بالتضامن بما التزموا به، ويعتبر المؤسس الذي التزم عن غيره ملزماً شخصياً إذا لم يُبين اسم موكله في عقد إنشاء الشركة أو إذا اتضح بطلان التوكيل الذي قدمه"

وقد أتت المادة (١٣) من القانون المذكور بحكم صريح، فيما يتعلق بحكم أو مصير التصرفات التي يُجريها المؤسسون لحساب الشركة تحت التأسيس مع الغير، بنصها على سريان العقود والتصرفات التي أجراها المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية لتأسيس الشركة، أما في غير ذلك من الحالات فلا تسري تلك العقود والتصرفات في حق الشركة بعد التأسيس إلا إذا اعتمدتها الجهات المنصوص عليها في المادة (١٢) من القانون.

وعلى هذا فإن النص يُفرق في الحكم بين التصرفات الضرورية لتأسيس الشركة والتصرفات غير الضرورية على النحو الآتي:

١- التصرفات الضرورية لتأسيس الشركة:

تشمل هذه التصرفات كافة العقود والإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس الشركة، كذلك

الأعمال المادية التي يستوجبها تأسيسها من الناحية الاقتصادية والفنية، فهذه التصرفات والأعمال تلزم بها الشركة بحكم القانون دون حاجة إلى موافقة أية جهة أخرى، كمجلس الإدارة أو الجمعية العامة التأسيسية.^(١)

٢- التصرفات غير الضرورية لتأسيس الشركة (التصرفات النافعة للشركة).

أما فيما يتعلق بالعقود و الأعمال غير الضرورية لتأسيس الشركة، أو التي يقتصر أثرها على تحقيق منفعة للشركة، وإن كانت غير لازمة لإتمام إجراءات التأسيس، كقيام المؤسسين باستغلال فرصة قد لا تتكرر بعد تأسيس الشركة يكون من شأنها أن تحقق للشركة نفعاً، فإن مثل هذه التصرفات لا تلزم الشركة، وإن كانت تخضع لشروط وضوابط اعتمادها من قبل مجلس الإدارة أو الجمعية العامة التأسيسية، وذلك وفقاً لما ورد بالمادة (١٢) من القانون المشار إليه، وبحيث إذا تم اعتمادها فإن الشركة تحل محل المؤسسين في سريان آثار التصرفات عليها في مواجهة الغير، وذلك تطبيقاً لأحكام الحلول الاتفاقي المنصوص عليه في القانون المدني (المادتين: ٢٢٦، ٢٢٧) أما إذا رفض التصرف من قبل هذه الجهات، عاد التصرف إلى حكم الأصل العام المقرر في المادة (١٠) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وهو استمرار المسؤولية التضامنية والشخصية للمؤسسين عن الحقوق والالتزامات التي ترتبها هذه التصرفات.^(٢)

وفي جميع الأحوال يجب أن يضع المؤسس ذو المصلحة تحت نظر الجهة التي تعتمد التصرف كافة الحقائق المتعلقة بالتصرف المذكور.^(٣)

ويلاحظ أن تقدير ما إذا كانت العقود والتصرفات ضرورية ولازمة لتأسيس الشركة أم غير ضرورية للتأسيس، تعتبر مسألة موضوعية تخضع لتقدير قاضي الموضوع.^(٤)

الفرع الثاني

تحرير العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة

بعد إجراء الدراسات الأولية والاستعانة بالمختصين من الناحية الفنية والقانونية، تبدأ إجراءات التأسيس بتحرير عقد تأسيس الشركة أو ما يُسمى بالعقد الابتدائي، الذي يتم بمقتضاه توحيد جهود المؤسسين واعتمادهم المضيي في القيام بإجراءات التأسيس، ويجب أن يتضمن هذا العقد بيانات معينة، كاسم الشركة ومركزها الرئيسي والغرض من تأسيسها وأسماء المؤسسين وبيان وافٍ عن خصائص الأسهم والحصص العينية، ويُضيف قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ضرورة أن يتضمن هذا العقد تحديد مدة الشركة.^(١)

ويحدد عقد تأسيس الشركة عنوان مركزها الرئيسي الذي تتم فيه أعمال إدارتها، وتلتزم الشركة بشهر كل تعديل يطرأ على عنوان مركزها الرئيسي، وإلا جاز اتخاذ الإجراءات بما فيها توجيه الإعلانات على عنوان مركزها الرئيسي المنشهر بالسجل التجاري.^(٢)

هذا وتقضي المادة (١ مكرراً) من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨، بتعديل بعض أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بأنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢، وقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ المشار إليها، تتولى الهيئة العامة لسوق المال تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون".

وتلتزم الهيئة بمبكنة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها وفقاً لأحكام المادة (٥٠) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، وتسري إجراءات التأسيس الإلكتروني دون غيرها من الإجراءات الواردة في أي قانون آخر فور تفعيلها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط العمل بنظام التأسيس والخدمات الإلكترونية للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.

والواقع أنه لا يوجد دور كبير للمؤسسين في تحرير بيانات العقد، إذ تنص المادة (٩) من القانون المذكور على أن "يكون العقد الابتدائي الذي يُبرمه المؤسسون طبقاً للنموذج الذي يُصدره الوزير المختص بقرار منه" ويجوز التصديق على هذا العقد في حالة الضرورة والاستعجال وبإجراءات خاصة.^(٣)

وإلى جانب عقد التأسيس يوجب المشرع أن يضع المؤسسون النظام الأساسي لشركة المساهمة، والذي يشتمل على الأحكام التفصيلية التي يتفق عليها المؤسسون لإدارة الشركة، والتي تعد بمثابة دستور لها الذي يحدد كيفية إدارتها فيما بعد، وينظم كل ما يتعلق بنشاط الشركة منذ تأسيسها لحين انقضاءها، كما يتضمن البيانات التفصيلية التي اشتمل عليها عقد التأسيس، إذ يوجب المشرع على لجنة المؤسسين أن ترفق بطلب تسجيل الشركة، بالإضافة إلى عقد التأسيس نظامها الأساسي.

وتوجب المادة ١٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أن يكون العقد الابتدائي والنظام الأساسي رسمياً أو مُصدّقاً على التوقيعات فيه، وكما هو الشأن فيما يتعلق بعقد تأسيس الشركة المساهمة، فإن دور المؤسسين في تحديد بيانات النظام الأساسي يعد دوراً محدوداً، حيث يصدر بهذا الشأن قرار يُحدد كافة البيانات والشروط اللازمة في نموذج يُعد لهذا الأمر.^(١)

والغرض من وجود هذه النماذج هو توحيد الأنظمة التي تسير عليها الشركات، وحتى يكون المتعاملون على بينة مما يطلب منهم، ويجوز للمؤسسين عدم الالتزام بحرفية النماذج المعدة، حيث أجاز لهم القانون إضافة أو حذف بعض الشروط من هذه النماذج بما لا يتنافى مع أحكام القانون واللوائح.^(٢)

الفرع الثالث

تكوين رأسمال الشركة

رأس مال شركة المساهمة هو مبلغ من النقود يمثل القيمة الإسمية للحصص النقدية والعينية التي قدمت للشركة عند تأسيسها، ويقسم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة، ويسمى كل منها سهماً، ويحدد القانون القيمة الإسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهاً ولا تزيد على الألف جنيه^(٣)، ويتم طرح الأسهم على الجمهور للاكتتاب فيها، ويتولى المؤسسون تقدير قيمة رأس المال اللازم للمشروع الذي تنشأ الشركة من أجل تحقيقه.

وقد أخذ المشرع في قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بما يسمى بمبدأ ثنائية رأس المال، والذي مفاده أن يكون للشركة "رأس مال مرخص به Authorised Capital"، وهو رأس المال الكلي اللازم للمشروع، "ورأس مال مصدر Issued Capital"، وهو رأس المال اللازم للبدء في المشروع، وهو ما تضمنته المادة ٣٢ من القانون بنصها على أنه: "يكون للشركة رأس مال مصدر ويجوز أن يحدد النظام رأس مال مرخص به يجاوز رأس المال المصدر بما لا يزيد على عشرة أمثاله".

وتتميز هذه الطريقة في تحديد رأس مال شركة المساهمة بأنها أكثر مرونة واستجابة لنمو المشروع من الناحية الاقتصادية، فهو يتيح للشركة ميزة تمويلية هامة ويسر لها القيام ببعض العمليات، كمنح بعض الأسهم للعاملين، والاستجابة لعمليات تحويل السندات وأدوات الدين إلى أسهم، وزيادة أصول الشركة بالإدماج وغيره.

غير أن أهم مزايا هذه الطريقة الثنائية، في تحديد رأس مال مصدر للشركة ورأس مال مرخص به، هو أنها تتيح للشركة، إذا ما رغبت في زيادة رأس المال المصدر عن طريق إصدار أسهم جديدة، أن تقرر زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به، وذلك بقرار من مجلس الإدارة، ودون حاجة إلى إصدار قرار من الجمعية العامة العادية، حيث تقضي المادة (١/٣٣) من قانون الشركات، المعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ بأنه: "يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع زيادة رأس المال المصدر، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به في حالة وجوده، وتستثنى الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية من ذلك".

ويُحدد المؤسسون رأس المال المصدر الذي تحتاجه الشركة لتنفيذ أو للبدء في تنفيذ مشروعاتها، أما رأس المال المرخص به فهو يزيد على رأس المال المصدر ويحدده نظام الشركة، ونظراً لأن الدائنين في شركة المساهمة ليس لهم من ضمان إلا رأس مال الشركة في هذا النوع من الشركات، قيد المشرع إرادة المؤسسين في تقدير رأس المال وفي كيفية جمعه، بقيود تتعلق بالحد الأدنى لرأس المال الذي لا يجوز النزول عنه عند تأسيس الشركة، أو بطريقة جمعه، وذلك عن طريق ما يسمى بـ "الاكتتاب"^(١).

وهو ما تناوله وفق التفصيل الآتي:

الفصل الأول الحد الأدنى لرأس المال

لم يضع المشرع حداً أدنى لرأس مال الشركة المساهمة في القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، ولذا تكفلت اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بوضع هذا الحد فيما يتعلق برأس المال المصدر بما لا يقل عن مليون جنية لشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، وألا يقل ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة من رأس المال المصدر عن نصف رأس المال (م ٤١ من اللائحة).

ولم تتضمن هذه اللائحة الحد الأدنى لرأس المال المصدر لشركة المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ومن ثم يتعين الرجوع في هذا التحديد إلى اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بالتطبيق لحكم المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال - السابق الإشارة إليه - التي تحيل على اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد بشأنه نصٌ فيها. وطبقاً لأحكام هذه اللائحة الأخيرة لا يمكن أن يقل رأس مال هذا النوع من الشركات عن ربع مليون جنية.

أما فيما يتعلق بالحد الأقصى لرأس المال فلم يقره المشرع إلا بالنسبة إلى رأس المال المرخص به، إذ لا يجب أن يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر (م ٣٢ شركات المعدلة بالقانون رقم "٣" لسنة ١٩٩٨).

ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتباً فيه بالكامل، وأن يقوم كل مكتتب بأداء (١٠٪) على الأقل من القيمة الإسمية للأسهم النقدية تزداد إلى (٢٥٪) خلال مدة لا تتجاوز

ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة، على أن يسدد باقي هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تداول الأسهم قبل أداء قيمتها بالكامل.^(١)

وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداؤه بالكامل إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبشرط أن يؤدي المكتتبون في الزيادة ما لا يقل عن النسبة التي تقرر أدائها من رأس المال المصدر قبل زيادته، وأن يؤديوا باقي القيمة في ذات المواعيد التي تتقرر للوفاء بباقي قيمة رأس المال المصدر.^(٢)

الفصل الثاني الاكتتاب في رأس المال

أولاً: تعريف الاكتتاب وبيان طبيعته القانونية:

الاكتتاب هو تصرف قانوني يعلن المكتتب بمقتضاه عن إرادته في الاشتراك في مشروع الشركة، مع التعهد بتقديم حصة في رأس المال تتمثل في عدد معين من الأسهم. وقد اختلف الفقه في طبيعة الاكتتاب، فذهب رأي إلى أنه تصرف بالإرادة المنفردة للمكتتب^(٣)، والراجح أنه عقد بين المكتتب والشركة المساهمة باعتبارها شخصاً معنوياً في طور التكوين يمثلته المؤسسون، حيث يعترف القانون بالوجود القانوني للشركة تحت التأسيس في حدود الغرض وبالقدر اللازم لإكمال إجراءات التأسيس، بدلالة اعترافه بصحة وسريان العقود والتعهدات التي أجراها المؤسسون باسم الشركة، وإلزام الشركة بعد تأسيسها بتلك التصرفات متى كانت ضرورية لتأسيس الشركة.^(٤)

وبمقتضى هذا العقد يلتزم المكتتب بدفع القيمة الإسمية للأسهم التي اكتتب بها، مقابل التزام الشركة بتخصيص عدد من الأسهم للمكتتب بقدر ما اكتتب فيه، ويكون الاكتتاب باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة المكتتب إذا تم تحت تأثير غلط أو تدليس أو إكراه، على أن بطلان الاكتتاب لا يستتبع بطلان عقد الشركة.^(٥)

وهو عقد من قبيل عقود الإذعان، يقتصر فيه دور المكتتب على مجرد التسليم بالشروط التي ينص عليها نظام الشركة والشروط الواردة في نشرة الاكتتاب، ولا يكون للمكتتب إلا أن يقبلها في مجملها أو يرفضها برمتها، دون أن يكون له مناقشة شروطها، ويعتبر ذلك مظهراً من مظاهر سيادة فكرة النظام القانوني على شركة المساهمة، ويعتبر الاكتتاب في شركة المساهمة من الأعمال

التجارية، لأنه يتصل بمشروع تجاري (وفقاً للمادة ٤/ج من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩)، على أن ذلك لا يكسب المكتتب صفة التاجر.

ثانياً: طريقنا الاكتتاب:

يتم جمع رأس المال عن طريق الاكتتاب بإحدى طريقتين: (١) الاكتتاب المغلق Fondation instantanée، وفيه يتقاسم المؤسسون الأسهم فيما بينهم دون الالتجاء إلى طرح الأسهم على الجمهور، وتسمى هذه الطريقة بالتأسيس الفوري، ويطلق على الشركة في هذه الحالة، الشركة التي لا تطرح أسهمها للتداول، (٢) الاكتتاب المفتوح Apped public ou souscription، وفيه يتم جمع رأس المال عن طريق طرح الأسهم مباشرة على الجمهور ليتم شراؤها أو الاكتتاب بها، وتسمى هذه الطريقة بطريقة التأسيس المتعاقب Fondation Successive، نسبة إلى أنه يتم عبر عدة إجراءات متتابعة، كما يطلق على الشركة التي تلجأ إليها بالشركة التي تطرح أسهمها للتداول.^(١)

وقد وضعت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ في المادة (١/٤٠) معياراً للفرقة بين الاكتتاب المفتوح والاكتتاب المغلق، فنكون طبقاً لهذا المعيار، بصدد اكتتاب عام في حالة دعوة أشخاص غير محددين سلفاً إلى الاكتتاب في الأسهم دون اشتراط حد معين أدنى لعدد أو قيمة الأسهم التي يتم طرحها في هذا الاكتتاب، وبمفهوم المخالفة يكون الاكتتاب في غير هذه الحالة غير عام، أي مغلق.

ويجدر التنويه إلى أن ما يطرح على الاكتتاب، عاماً كان أو غير عام، هو رأس المال المصدر والأسهم النقدية التي تمثله، أما الأسهم التي تمثل الحصص العينية والمسماة بالأسهم العينية فلا تطرح على الاكتتاب، لأن الحصص العينية ينبغي تقييمها مباشرة عند تأسيس الشركة، وإذا ما تم ذلك فإنها تقوم بالنقد ويمنح أصحابها أسهماً بقدر قيمتها.

والاكتتاب بمعناه السابق لا يتم إلا في شركات المساهمة ذات الاكتتاب العام، وكذلك شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء المساهمين، أو ما ينص عليه أي قانون خاص باكتتاب معين، ولا تتبع هذه الوسيلة في تكوين أي نوع آخر من أنواع الشركات، سواء شركات أموال أو شركات أشخاص.^(١)

ثالثاً: شروط صحة الاكتتاب:

بالإضافة إلى الضوابط السابقة للاكتتاب، فقد اشترط المشرع لصحة الاكتتاب أن تتوافر الشروط الآتية:

١- أن يكون الاكتتاب كاملاً: ويقصد بذلك وفقاً للمادة ٣٢ من قانون الشركات، أن يكون رأس المال المصدر مكتتباً فيه بالكامل، فالأكتتاب بجزء فقط من رأس المال يبطل الاكتتاب ويضر بائتمان الشركة، ويرتب مسؤولية المؤسسين الشخصية قبل الغير، ذلك أن عدم الاكتتاب الكامل يجعل رأس المال المصدر-والذي تم تقديره بحيث يكون كافياً لتحقيق أهداف المشروع- غير كاف لتحقيق الغرض الذي أنشأت الشركة من أجله، كما أنه لا يتفق مع ارتضاه جميع المكتتبين وقبلوا الاكتتاب على أساسه.^(١)

وتفريعاً على ذلك فلا يجوز للمؤسسين عرض جزء فقط من رأس المال للاكتتاب، ولا يجوز لهم أيضاً الاكتفاء بالمبلغ الذي تم الاكتتاب فيه والاستغناء عن الباقي، ولا يجوز لهم إصدار السهم بأقل من قيمته الإسمية (م ٣/٣١ من القانون)، لأن ذلك يترتب عليه بقاء جزء من رأس المال بدون تغطية، وهذا مخالف لقاعدة وجوب الاكتتاب في رأس المال بالكامل، كما لا يجوز إصدار رأس المال بقيمة أعلى من القيمة الإسمية، إلا في الأحوال وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، لأن ذلك سيؤدي إلى تحديد رأس المال بأقل مما يكفي لتحقيق الغرض من الشركة.^(٢)

ويجب أن يظل الاكتتاب مفتوحاً للمدة المحددة بالنشرة بحيث لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين، وإذا لم يكتب في جميع الأسهم المطروحة خلال تلك المدة جاز باذن من رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على شهرين آخرين^(٣)، وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب في المدة المحددة له يجوز أن تقوم البنوك أو الشركات التي تلقت الاكتتاب تغطية كل أو بعض ما لم يتم تغطيته من الأسهم المطروحة للاكتتاب، إذا كان مرخصاً لها بذلك، ولها أن تعيد طرح ما اكتتبت به للجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول الأسهم المنصوص عليها في القانون.^(٤)

٢- أن يكون الاكتتاب باتاً: أي منجزاً، وهو شرط لازم للتأكد من ضمان الاكتتاب في رأس المال بالكامل، فلا يجوز تعليق الاكتتاب على شرط أو إضافته إلى أجل، لأن الاكتتاب المعلق على شرط أو المضاف إلى أجل سيمكن المكتتب من عدم الالتزام بالاكتتاب، فإذا علق الاكتتاب على شرط بطل الشرط وصح الاكتتاب وألزم المكتتب به، وإذا أضيف إلى أجل بطل الأجل واعتبر الاكتتاب فورياً، ومن أمثلة تعليق الاكتتاب على شرط أن يشترط المكتتب تعيينه في مجلس الإدارة أو في وظيفة في الشركة،

٣- أن يكون الاكتتاب جدياً: ويقصد بذلك أن يكون الاكتتاب حقيقياً وليس وهمياً أو صورياً، بمعنى أن يقصد المكتتب، من اكتتابه، الالتزام بتحمل أعباء دفع قيمة الأسهم وأن يكون شريكاً مساهماً في الشركة، والهدف من ذلك حماية الدائنين وقطع الطريق على الاكتتابات الصورية التي تتم من أشخاص يسخرهم المؤسسون بقصد الإيهام بتغطية الاكتتاب في كل الأسهم المطروحة.^(١)

وتعتبر مسألة إثبات جدية الاكتتاب من عدمه من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض، ويمكن إثبات صورية الاكتتاب بكافة طرق الإثبات.

٤- الحد الأدنى لعدد المكتتبين: وفقاً للمادة الثامنة من قانون الشركات^(٢)، فيما عدا شركات الشخص الواحد، لا يجوز أن يتم الاكتتاب من أقل من ثلاثة مكتتبين، وهو الحد الأدنى من المؤسسين الذي تطلبته هذه المادة، ويستوي أن يكون المكتتب شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً، كما لا يجوز أن يقل ما يكتب فيه مؤسسو الشركة عن نصف رأس المال المصدر^(٣)، وذلك سعياً لضمان جدية مشروع الشركة بالربط بين مصيره وبين المؤسسين، بحيث إذا فشل مشروع التأسيس تحمل هؤلاء العبء الأكبر من الضرر الناشئ عن هذا الفشل.^(٤)

رابعاً: الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب العام:

حرصاً من المشرع على حماية الإدخار الوطني، وعلى تفادي ضروب الغش المتنوعة، وعلى التثبت من موثوقية جهات تلقي الاكتتاب، فقد نصت المادة (١/٣٧) من قانون الشركات^(٥): "إذا طرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام، فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الاقتصاد بتلقي الاكتتابات أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض، أو الشركات التي يرخص بالتعامل في الأوراق المالية وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال.

ولكن دور البنوك لا يقتصر على تلقي الاكتتاب، ففي حالة عدم تغطية الاكتتاب في المدة المحددة له، يجوز للبنوك أو الشركات التي تلقت الاكتتاب تغطية كل أو بعض ما لم يتم تغطيته من الأسهم المطروحة للاكتتاب إذا كان مرخصاً لها بذلك، ولها أن تعيد طرح ما اكتتبت فيه للجمهور دون التقييد بإجراءات وقود تداول الأسهم المنصوص عليها في القانون.^(٦)

خامساً: أحكام الاكتتاب:

أ- نشرة الاكتتاب: نصت المادة ٤ من قانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أنه: لا

يجوز طرح أوراق مالية لأية شركة.. في اكتتاب عام للجمهور، إلا بناء على نشرة اكتتاب من هيئة سوق رأس المال، يتم نشرها في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقاً للنماذج التي تعدها الهيئة، ويجب أن يبين في النشرة أن اعتماد الهيئة للنشرة ليس اعتماداً للجدوى التجارية للنشاط موضوع النشرة أو لقدرة المشروع على تحقيق نتائج معينة.^(١)

هذا ومراعاة لمبادئ الإفصاح والشفافية، كأحد معايير الحوكمة التي توجب إحاطة راغبي الاكتتاب في مشروع الشركة التي تطرح أسهمها في اكتتاب عام بكافة المعلومات عن مشروع التأسيس، أوجبت المادة ٥ من قانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة عند تأسيسها الإفصاح عن البيانات الآتية:

(أ) غرض الشركة ومدتها. (ب) رأس مال الشركة المصدر والمدفوع. (ب) مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها. (د) أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية أن وجدت. (هـ) خطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب في الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال. (و) أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة. (ز) أية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية.^(٢)

وبناء على ذلك فقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال في المادة ٤٢ على أنه: "يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة عند التأسيس، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في القانون، البيانات الآتية:

١- اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها. ٢- تاريخ العقد الابتدائي. ٣- القيمة الاسمية للسهم وعدد الاسهم وانواعها وخصائص كل منها والحقوق المتعلقة بها سواء بالنسبة الى توزيع الارباح او عند التصفية. ٤- المدة التي يتعين على المؤسسين التقدم فيها بطلب الترخيص بتأسيس الشركة. ٥- بيان ما إذا كانت هناك حصة تأسيس، وما قدم للشركة في مقابلها، ونصيبها المقرر في الأرباح. ٦- إذا كان الاكتتاب العام عن جزء من راس المال يبين كيفية الاكتتاب في باقي راس المال. ٧- تاريخ بدء الاكتتاب والجهة التي سيتم الاكتتاب بواسطتها، والتاريخ المحدد لقفل الاكتتاب. ٨- تاريخ ورقم اعتماد الهيئة للنشرة. ٩- المبلغ المطلوب دفعه عند الاكتتاب بحيث لا يقل عن ربع القيمة الاسمية بالإضافة الى مصاريف الاصدار. ١٠- أسماء مراقبي حسابات الشركة وعناوينهم. ١١- بيان تقريبي مفصل بعناصر مصروفات التأسيس التي

ينتظر أن تتحملها الشركة من بدء التفكير في تأسيسها الى تاريخ صدور القرار بالتأسيس. ١٢- بيان العقود ومضمونها التي يكون المؤسسون قد أبرموها خلال الخمس سنوات السابقة على الاكتتاب ويزمعون تحويلها الى الشركة بعد تأسيسها، وإذا كان موضوع العقد شراء منشأة قائمة نقدا فيتعين تضمين النشرة موجزا لتقرير مراقب الحسابات عن هذه المنشأة. ١٣- تاريخ بداية السنة المالية وانتهائها. ١٤- بيان عن طريقة توزيع الربح الصافي للشركة. ١٥- طريقة تخصيص الاسهم اذا بلغت طلبات الاكتتاب اكثر من المطروح للاكتتاب. ١٦- المدة والحالات التي يجب فيها على الجهة التي تلقت الاكتتاب رد المبالغ الى المكتتبين".

وفي حالة إصدار أسهم مقابل حصة عينية، سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال، يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب ما يأتي:

أ- ملخص عن بيان الموجودات المالية والعينية المقدمة في مقابل الحصة العينية وأسماء مقدميها وشروط تقديمها، مع بيان ما إذا كانوا من المؤسسين أو أعضاء مجلس الادارة أو الشريك أو الشركاء المديرين، ومدى إفادة الشركة من هذه الموجودات والقيمة المطلوبة لكل نوع منها أصلاً. - بيان عن عقود المعاوضة التي وردت على العقارات المقدمة للشركة خلال السنوات الخمس السابقة على تقديمها وملخص بأهم الشروط التي تمت على أساسها هذه العقود، وما كانت تغله تلك العقارات من ريع في هذه المدة. - جميع حقوق الرهن والامتياز المترتبة على الحصص العينية. - ملخص واف عن قرار اللجنة المختصة بتقدير الحصة العينية وتاريخ صدوره. - عدد الأسهم المصدرة في مقابل الحصة العينية.^(١)

ب- تقديم نشرة الاكتتاب إلى هيئة سوق رأس المال لاعتمادها:

يقدم المؤسسون - قبل البدء في عملية الاكتتاب - إلى الهيئة نشرة الاكتتاب موقعاً عليها من جميع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً، ويرفق بالنشرة تقرير من مراقب حسابات بصحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها لمتطلبات القانون واللائحة، وكذلك عقد الشركة الابتدائي ونظامها الأساسي موقعاً عليه من المؤسسين، ويكون إيداع أصل نشرة الاكتتاب ومرفقاتها بالهيئة نظير إيصال مبين فيه تاريخ الإيداع.^(١)

وللهيئة أن تعترض - خلال أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إليها - على عدم كفاية أو دقة البيانات الواردة بها، وللهيئة أن تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار إليها أو بتصحيحها أو تقديم أية بيانات أو توضيحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافية. ويتم توجيه الاعتراض أو طلب استكمال البيانات وغير ذلك من الأوراق الى المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً، كما تخطر الجهة التي يجري عن طريقها الاكتتاب إذا تطلب الأمر ذلك.^(١) ولا يجوز قبل اعتماد نشرة الاكتتاب من الهيئة إجراء نشر من أي نوع من بيانات النشرة يتضمن على أي وجه الترويج لأوراق مالية. ومع ذلك يجوز بعد تقديم النشرة الى الهيئة توزيع إعلانات أو نشرات أو خطابات أو غير ذلك من البيانات الأساسية الخاصة بنشاط المشروع المقدمة عنه النشرة، على أن يشار في جميع الأحوال وبطريقة ظاهرة الى أن نشرة الاكتتاب لم تعتمد بعد من الهيئة.^(٢)

وإذا طرأ بعد اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب ما يؤثر على سلامة عملية الاكتتاب أو صحة بيانات النشرة أو تغيرت الظروف أو العناصر المادية أو القانونية التي اعتمدت بناء عليها النشرة، كان لرئيس الهيئة إيقاف إجراءات الاكتتاب إلى أن يتم اتخاذ الاجراء المناسب على الوجه الصحيح خلال المدة التي يحددها، وإلا وجب على الجهة التي تلقت الاكتتاب رد المبالغ المكتتب فيها الى المكتبتين.^(٣)

والمؤسسون مسئولون عن أي خطأ أو نقص في بيانات نشرة الاكتتاب، ويلتزمون بتعويض من يلحقه ضرر بسبب ذلك، هذا فضلاً عن معاقبتهم بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه -يتحملها المخالف شخصياً- أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة إثباتهم عمداً في نشرات الاكتتاب بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون (م ٣٦ من قانون سوق رأس المال)، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

ج- الإعلان عن الإكتتاب: ينشر موجز لنشرة الاكتتاب وتعديلاتها بعد اعتمادها من الهيئة، متضمناً البيانات الرئيسية لها في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداها على الأقل باللغة العربية قبل بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوماً على الأقل أو خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال.

على أن تتضمن تلك البيانات أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة ويجوز الحصول على نسخة معتمدة من النشرة من الهيئة بعد أداء الرسم المقرر.^(١)

د- مدة الاكتتاب: ويظل الاكتتاب مفتوحاً للمدة المحددة بالنشرة بحيث لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز شهرين.، وإذا لم يكتب في جميع الأسهم المطروحة خلال تلك المدة جاز باذن من رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على شهرين آخرين. (المادة ٤٨ من اللائحة).

ويجوز قفل باب الاكتتاب بعد تغطية قيمة الأسهم المطروحة وفقاً للشروط المحددة في نشرة الاكتتاب ومضى الحد الأدنى للمدة التي يظل الاكتتاب مفتوحاً فيها.^(٢)

هـ- تجاوز الاكتتاب عدد الأسهم: إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة ولم يحدد نظام الشركة كيفية التوزيع بين المكتتبين، وجب توزيعها بتخصيص عدد من الأسهم الإسمية أو لحاملها بحسب الأحوال لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة إلى عدد الأسهم المكتتب فيها، بحيث لا يترتب على ذلك إقصاء المكتتب في الشركة أياً كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها، ويراعى جبر الكسور لصالح الصغار المكتتبين، ويرد الى المكتتب ما دفعه عند الاكتتاب بالزيادة عما خصص له بالفعل.^(٣)

هذا وإذا انتهت المدة المقررة للاكتتاب والمدة التي قد يمتد إليها، ولم يغط الاكتتاب الأسهم المطروحة، ولم تقم البنوك أو الشركات المشار إليها في المادة ٣٦ من القانون بتغطية الاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه، فلا يجوز المضي في تأسيس الشركة، وعلى الجهة التي تلقت الاكتتاب إبلاغ هيئة سوق المال المكتتبين بذلك خلال أسبوعين من انقضاء المدة المذكورة، وأن ترد إليهم فور طلبهم ما دفعوه بما في مصاريف الإصدار^(٤)، إذ يعبر ذلك عن فشل مشروع الشركة، لعدم حصوله على الاقبال الذي كان يتوقعه المؤسسون .

و- شهادات الاكتتاب: وفقاً للمادة ٥٣ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، يتم الاكتتاب بموجب شهادات مبيناً بها تاريخ الاكتتاب وموقعاً عليها من المكتتب في الأسهم الإسمية، على أن يكتب بالأحرف عدد الأسهم التي اكتتب فيها. ويعطى المكتتب صورة من الشهادة متضمنة البيانات الآتية:

هـ- اسم وغرض الشركة التي يكتب في أسهمها- رأس مال الشركة والجزء المطروح للاكتتاب العام منه- القيمة الاسمية للسهم وما دفع منها عند الاكتتاب- تاريخ اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب- الحصص العينية في حالة وجودها- نوع الأسهم التي تم الاكتتاب فيها وعددها

وأرقامها-اسم الجهة التي تم فيها أداء المبالغ المطلوبة للاكتتاب-اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وذلك بالنسبة الى الاسهم الاسمية.

ز-قفل باب الاكتتاب وإخطار الهيئة العامة لسوق المال به: يجب على كل من المؤسسين والجهة التي تلقت مبالغ من المكتتبين إخطار الهيئة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لقفل باب الاكتتاب بالبيانات المتعلقة بالأسهم لحاملها، وبأسماء المكتتبين في الأسهم الاسمية وجنسياتهم ومحال إقامتهم وقيمة ما دفعه كل منهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها ومقدار الأسهم التي خصصت له، ويجوز لكل ذي شأن الحصول على نسخة من هذا البيان من الهيئة بعد أداء الرسم المقرر. (المادة ٥٦ من لائحة قانون سوق رأس المال).

وتظل المبالغ التي دفعت من المكتتبين تحت يد الجهة التي تلقت الاكتتاب، ولا يجوز السحب منها الا بعد أن يقدم من ينوب عن الشركة قانوناً ما يفيد إشهار نظام الشركة في السجل التجاري.

واستثناء من ذلك، وبمراعاة ما قد يرد بنشرة الاكتتاب، يتعين على الجهة التي تلقت المبالغ أن ترد الى المكتتبين جميع ما دفعوه من مبالغ وذلك في الحالات الآتية:

(أ) إذا صدر حكم من قاضي الأمور المستعجلة بتعيين من يسحب هذه المبالغ وتوزيعها على المكتتبين، وذلك اذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التأسيس.

(ب) اذا مضت مدة سنة على تاريخ قفل الاكتتاب، دون أن يتقدم المؤسسون أو من ينوب عنهم بطلب تأسيس الشركة.

(ج) اذا اتفق جميع المؤسسين على العدول عن تأسيس الشركة وقدموا الى الجهة التي تلقت الاكتتاب إقراراً منهم بذلك مصدقاً على التوقيعات الواردة فيه.

ويجوز لأصحاب الشأن فضلاً عن استرداد قيمة الاكتتابات الرجوع على المؤسسين بالتعويض بطلب يقدم لهيئة التحكيم المنصوص عليها بالقانون.^(١)

ح-الالتزام بتقديم بيانات بالتعديلات وتقديم تقارير دورية: على كل شركة طرحت أوراقاً مالية لها في اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها إلى الهيئة بياناً بالتعديلات التي تطرأ على نظامها الأساسي ونسب المساهمات في رأس مالها فور حدوثها وتقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها خلال الشهر التالي لانتهااء تلك المدة، على أن تتضمن هذه التقارير قائمتي المركز المالي

ونتيجة النشاط مصدقاً على ما ورد بهما من مراقب الحسابات وذلك طبقاً للنماذج المرفقة بهذه اللائحة.

ويتم إعداد التقارير عن نشاط شركات المساهمة والتوصية بالأسهم ونتائج أعمالها والقوائم المالية لها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ونماذج القوائم المالية.^(١) وتوجب المادة ٧ من قانون سوق رأس المال على الشركة ومراقبي حساباتها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الاكتتاب والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة.

الفرع الرابع الجمعية التأسيسية للشركة

الانعقاد والتصويت:

يلي الإجراء السابق - جمع رأس المال عن طريق الاكتتاب في رأس مال الشركة بالكامل - دعوة الجمعية التأسيسية للشركة للانعقاد، للنظر في مجموعة من الاختصاصات التي أناطها القانون بها، حيث تنعقد الجمعية التأسيسية للشركة بناء على دعوة جماعة المؤسسين أو وكيلهم، في خلال شهر من قفل باب الاكتتاب، أو انتهاء الموعد المحدد للمشاركة أو تقديم تقرير بتقويم الحصص العينية أيهما أقرب.

ويكون من حق جميع الشركاء حضور هذه الجمعية أياً كان عدد أسهمهم أو مقدار حصصهم.^(١)

ولا تجوز الوكالة في الحضور إلا إذا كانت صادرة لأحد المكتتبين وثابتة بموجب توكيل خاص مكتوب. ويجب أن يشتمل إعلان الدعوة إلى الانعقاد على اسم الشركة ونوعها ومقدار رأس المال ويوم وساعة الاجتماع ومكانه والنصاب المحدد لصحته، كما تحدد الدعوة المسائل التي سيتم طرحها للمناقشة في الاجتماع.^(١)

كما يشتمل الاعلان الموعد التي تدعى إليه الجمعية التأسيسية للمرة الثانية إذا لم يتوافر في الاجتماع الأول النصاب المحدد لصحته، بشرط ألا تزيد المدة بين الاجتماعين عن خمسة عشر يوماً (المادة ٣/٣١ من اللائحة).

ويتم نشر الاجتماع في صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية وذلك قبل الموعد المحدد له بثمانية أيام على الأقل.

ويشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من المكتتبين وأصحاب الحصص يمثل نصف رأس المال المصدر على الأقل.

وإذا لم يتوافر في الاجتماع النصاب المشار إليه، وجب توجيه الدعوة إلى اجتماع ثان في موعد لا يزيد على خمسة عشر يوماً من الاجتماع الأول، وذلك بالنشر عنه في صحيفة يومية تصدر باللغة العربية قبل الموعد المقرر للاجتماع بخمسة أيام على الأقل.

ويجوز توجيه هذه الدعوة بكتاب موصى عليه يوجه إلى من لم يحضر الاجتماع الأول من المكتتبين، وتتضمن الدعوة إلى الاجتماع البيانات الموضحة بالمادة (٣١) من اللائحة والسابق الإشارة إليها، وذلك مع الإخطار بعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول (المادة ٢/٣٢ من اللائحة).

ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من الشركاء يمثل ربع رأس المال المصدر على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين، ما لم يتطلب القانون أغلبية خاصة في بعض الأمور (المادة ٣/٢٧ من القانون والمادة ٣/٣٢ من اللائحة).

ويتولى رئاسة الجمعية التأسيسية أكبر المؤسسين أسهماً، وعند التساوي تسند الرئاسة إلى أحدهم بالقرعة، وتنتخب الجمعية أمين سر وجامعي أصوات (المادة ٣/٢٦ من القانون والمادة ١/٣٤ من اللائحة).^(١)

اختصاصات الجمعية التأسيسية:

تختص الجمعية التأسيسية بالنظر في المسائل الآتية: تقويم الحصص العينية المقدمة، والتحقق من صحة إجراءات التأسيس، والتصديق على نظام الشركة، والمصادقة على اختيار مجلس الإدارة الأول، وتعيين مراقب الحسابات^(٢)، ثم إخطار الجهات الإدارية المعنية بإنشاء الشركة واتخاذ إجراءات شهرها، حتى تتمكن من اكتساب شخصيتها الاعتبارية وممارسة نشاطها وفق الغرض المحدد.

أولاً: التحقق من تقدير الحصص العينية:

إذا دخل في تكوين رأس مال شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أو عند زيادة رأسمال أي منهما، حصص عينية مادية أو معنوية، في صورة عقارات أو محل تجاري أو منقولات أو حقوق..، فإنه يجب تقديرها تقديراً صحيحاً، والحكمة من ذلك هو درء المبالغة في تقدير هذه

الحصص لما يتضمنه ذلك من إضرار بحقوق الشركة وأصحاب الأسهم النقدية ودائني الشركة، فالمبالغة في تقدير هذه الحصص سيضر بالشركة لأنه سيؤدي بها إلى أن تبدأ نشاطها برأس مال يقل في حقيقته عن القدر اللازم لتحقيق أغراضها، ويضر بأصحاب الأسهم النقدية لأنه سيترتب عليه حصول أصحاب الأسهم العينية على قدر من الأرباح هو في الحقيقة من حق أصحاب الأسهم النقدية، كما سيلحق ضرراً بالدائنين لأن الضمان العام الذي اعتمدوا عليه، وهو رأس المال الإسمي، يزداد على مقداره الحقيقي^(١).

ولذا فقد تضمن القانون قواعد خاصة لضمان تقدير هذه الحصص تقديراً صحيحاً، وتمثل هذه القواعد فيما يلي:

١- يجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، أن يطلبوا من الهيئة العامة لسوق المال التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قدرت تقديراً صحيحاً.

٢- تختص بإجراء هذا التقدير لجنة تشكل بالهيئة برئاسة مستشار بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، وعضوية أربعة على الأكثر من الخبراء في التخصصات الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية تختارهم الهيئة، وتلتزم هذه اللجنة باتباع القواعد والاجراءات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تلتزم اللجنة بالمعايير المصرية للتقييم العقاري ومعايير التقييم المالي للمنشآت، بحسب الأحوال، وتودع اللجنة تقريرها في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها^(٢).

٣- إذا كانت الحصة العينية مملوكة للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو شركة من شركات القطاع العام، تعين أن يشارك في التقدير ممثل عن المال العام يختاره الوزير المختص وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتسري أحكام هذه المادة على ما يتم الاكتتاب فيه من أسهم عينية في كل زيادة في رأس المال قبل انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة^(٣).

٤- بعد انتهاء اللجنة المعنية من إجراء التقدير، تقوم الهيئة بإخطار وكيل المؤسسين ومقدم الحصة العينية بقرار لجنة التقييم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول^(٤).

٥- لكل ذي شأن خلال ٣٠ يوماً من الإخطار سالف الذكر أن يتظلم من تقدير اللجنة أمام لجنة للتظلمات تشكل من وزير الاستثمار، وتتكون هذه اللجنة من أحد نواب رئيس مجلس

الدولة رئيساً وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة-يختارهم المجلس-وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة-يختاره رئيسها-وأحد ذوي الخبرة يختارهم الوزير، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً وناظراً، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.^(١) وإذا لم يتم التظلم من قرار اللجنة المنوط بها تقويم الحصص العينية، يصبح تقدير اللجنة نهائياً تلتزم به الجمعية التأسيسية، وذلك دون الإخلال بحق مقدم الحصة العينية من الانسحاب من الشركة أو أداء الفرق نقداً إذا اتضح أن تقدير اللجنة لقيمة الحصة يقل عن القيمة التي قدمت من أجلها.^(٢)

ولا يجوز إصدار أسهم مقابل الحصة العينية إلا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه.^(٣) ثانياً: النظر في تقرير المؤسسين عن أعمال التأسيس والنفقات التي استلزمها: وذلك للتحقق من مراعاة الإجراءات والشروط التي استلزمها القانون لصحة عملية التأسيس.^(٤) ثالثاً: تختص الجمعية التأسيسية أيضاً بالموافقة والتصديق على نظام الشركة: ولا يجوز للجمعية إدخال تعديلات على نظام الشركة إلا بموافقة المؤسسين والأغلبية العددية للشركاء الممثلين لثلثي رأس المال على الأقل^(٥)، وذلك مراعاة مصلحة كبار المساهمين وصغارهم على حد سواء. رابعاً: المصادقة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة الأول ومراقب الحسابات: ^(٦) وقد جرى العمل على أن ينص نظام الشركة على تعيين مجلس الإدارة الأول من بين المؤسسين، وتعد موافقة الجمعية على النظام تصديقاً منها على هذا التعيين، مع مراعاة الأحكام الخاصة، بنظام الشركة والمتعلقة بتمثيل العاملين في إدارة الشركة.^(٧)

الفرع الخامس

الإخطار بإنشاء الشركة

تأسيس شركة المساهمة بين الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة:

نظراً لأهمية شركات المساهمة للاقتصاد القومي وخطورتها على الادخار العام، فإن الدول لا تترك أمر تأسيسها إلى الأفراد من المؤسسين يُضمنون عقودها ما يشاءون من أحكام، وإنما تفرض من الشروط والإجراءات ما يُمكن أن يخرج تأسيس شركة المساهمة من حظيرة الحرية التعاقدية ويُخضعها لقواعد مانعة ذات طابع تنظيمي.

وتسلك الدول في تشريعاتها، لتحقيق هذه الرقابة، إحدى طريقتين: إما الرقابة السابقة على التأسيس أو الرقابة اللاحقة عليه.

فمن التشريعات ما يفرض نوعاً من الرقابة اللاحقة على إنشاء شركات المساهمة، بحيث لا

تكتسب الشركة شخصيتها المعنوية قبل الحصول على هذا الترخيص اللاحق، كما هو الشأن بالنسبة لتقنين الشركات رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٦ في فرنسا، الذي أخضع شركات المساهمة ذات الاكتتاب العام لقواعد ونظم حتى يتم شهرها والاعتراف لها بالشخصية المعنوية، وذلك من خلال لجنة البورصة وتسعير الأوراق المالية ورقابة الموثق على الإيداع، وإيداع الأوراق لدى المحكمة، والنشر في جريدة الإعلانات القانونية، ثم يلي ذلك التسجيل بالسجل التجاري، الذي - بناءً على استيثاقه من كافة الإجراءات والأحكام القانونية السابقة - يمنح الشخصية الاعتبارية للشركة.

ويعيب هذه الطريقة إمكانية مفاجأة المؤسسين برفض الترخيص بإنشاء الشركة بعد ما بذلوا من جهدٍ ومال في فترة التأسيس، فضلاً عن عجزها عن مراقبة الإجراءات المتخذة لتأسيس الشركة، وأهمها الاكتتاب في رأس المال والتأكد من صحة هذه الإجراءات وجديتها، ولذا يُفضل بعض الفقهاء الرقابة المبكرة أو الواقية، بحيث يكون الترخيص الحكومي هو آخر إجراءات التأسيس.

ومن التشريعات ما يفرض ضرورة الحصول على ترخيص حكومي سابق، بحيث لا تنشأ الشركة المساهمة إلا إذا صدر بذلك ترخيص من الحكومة، وقد أخذت بهذا المبدأ تشريعات بعض الدول كالعراق وسوريا ولبنان، ويأتي اشتراط الترخيص الحكومي السابق في هذه الحالة، بغرض حماية جمهور المساهمين من التغير بهم من قبل مؤسسين لا خلاق لهم، ولحماية المصالح الوطنية وتهيئة وسيلة فعالة للحكومة لتوجيه نشاط هذا النوع من الشركات إلى أغراض مفيدة للاقتصاد الوطني، واستبعاد الشركات التي لا تتفق أغراضها والمصلحة الوطنية^(٥).

الوضع في التشريع التجاري المصري بين الترخيص الحكومي والإخطار بإنشاء الشركة المساهمة. كان التنظيم القانوني لتأسيس شركات المساهمة يستوجب تقديم طلب إنشاء الشركة إلى الإدارة العامة للشركات، مرفقاً به مجموعة من المحررات، وتقوم لجنة مشكلة من الوزير المختص، ورد النص عليها في المادة ١٨ من هذا قانون شركات الأموال رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بفحص طلبات إنشاء الشركات، وتصدر تلك اللجنة قرارها بالبت في طلبات التأسيس خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، ولا تعتبر الموافقة على تأسيس الشركات التي تطرح أسهمها وسنداتهما للاكتتاب العام نهائية إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص، بعد أخذ رأي الهيئة العامة لسوق المال، وإذا لم يصدر قراره خلال مدة ستين يوماً من تاريخ عرض موافقة اللجنة المذكورة على التأسيس، اعتبر ذلك موافقة على تأسيس الشركة، وبعد صدور قرار الوزير

المختص بالموافقة على تأسيس الشركة، وهو ما يُعرف بالترخيص الحكومي، يجب إشهار عقد الشركة ونظامها، بحسب الأحوال، في السجل التجاري، ولا تثبت الشخصية المعنوية للشركة إلا من تاريخ القيد في هذا السجل.^(١)

بينما تخضع الرقابة على تأسيس شركات المساهمة في مصر حالياً للتنظيم الوارد بالقانون رقم (٣) لسنة ١٩٩٨، بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وقد تضمن القانون المذكور إلغاء الترخيص الوزاري بتأسيس الشركة، واكتفى - إلا في أحوال استثنائية - بمجرد إخطار الهيئة العامة لسوق المال، بعد استيفاء المستندات المطلوبة لإنشاء الشركة.

وقد أوجب المشرع، بمقتضى المادة ١٧ من القانون رقم (٣) لسنة ١٩٩٨، والمعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨^(٢)، على المؤسسين أو من ينوب عنهم، إخطار الهيئة العامة لسوق المال بإنشاء الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات الآتية :

(أ) العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، أو عقد التأسيس بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
(ب) موافقة الجهات المختصة إذا كانت ممارسة أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقات خاصة بمقتضى أحكام قانون آخر.

(ج) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة أو حصصها، وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أدائها، ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتساب شخصيتها الاعتبارية، وتستثنى الشركات ذات المسؤولية المحدودة من تقديم هذه الشهادة.

(د) إيصال سداد رسم بواقع واحد في الألف من رأس مال الشركة المصدر بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، ومن رأس المال المدفوع بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وذلك بما لا يقل عن مائة جنيه، ولا يزيد على ألف جنيه.

(هـ) شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.

وقد نصت المادة الثامنة من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ على أن: "تلتزم شركات المساهمة

وشركات التوصية بالأسهم القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقاً لحكم البند (هـ) من الفقرة الأولى من المادة (١٧) المستبدلة بهذا القانون، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون".

وقد خرج المشرع على قاعدة الاكتفاء، في تأسيس الشركات، بالإخطار السابق، بالنسبة إلى بعض الشركات، حيث أوجب، بالإضافة إلى ما سبق، ضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة، إذا كان غرضها أو من بين أغراضها العمل في مجال نشاط الأقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بُعد، أو أي نشاط يتناول غرضاً أو عملاً من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .

ويشكل ذلك حالة استلزم فيها المشرع ضرورة الحصول، بالإضافة إلى إخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الشركة، على موافقة سابقة من مجلس الوزراء، حيث أنه قدر خطورة هذه الأنشطة على الأمن القومي، من خلال تأثيرها على الموروثات الثقافية والاجتماعية للشعب المصري^(١).

وعلى الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم الإخطار شهادة مؤرخة بذلك، متى كان مرفقاً به جميع المحررات المنصوص عليها، تفيد تسلمها للإخطار والمستندات المرفقة به، وتقوم هذه المصلحة بإدراج الإخطار بإنشاء الشركة في سجل تمسكه لهذا الغرض بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها.^(٢)

اعتراض الجهة الإدارية المختصة على إنشاء الشركة وآثاره:

يجوز للجهة الإدارية المختصة - وفقاً للمادة ١٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المعدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ - خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة أن تعترض على قيامها، وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل على عنوان الشركة المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار، مع إرسال صورة من الكتاب إلى السجل التجاري للتأشير به على بيانات قيد الشركة، ويجب أن يكون الاعتراض مُسبباً وأن يتضمن ما يلزم اتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الاعتراض.

ولا يجوز للجهة الادارية الاعتراض على قيام الشركة إلا لأحد الأسباب الآتية:

أ - مخالفة العقد الابتدائي أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو احتوائه على أمور مخالفة للقانون.

ب- إذا كان غرض الشركة مخالفاً للقانون أو للنظام العام.

ج- إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة .

وعلى الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالاعتراض أن تُزيل أسبابه أو أن تتظلم منه إلى وزير الاقتصاد، وإلا وجب على الجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجاري^٥.

ويعتبر فوات خمسة عشر يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه أسباب الاعتراض. وفي حالة تظلم الشركة تخطر بذلك بالبريد المسجل لإزالة أسباب الاعتراض، فإذا لم تُزلها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها برفض التظلم أصدرت الجهة الإدارية المختصة قراراً بشطب قيد الشركة من السجل التجاري، وفي جميع الأحوال تزول الشخصية الاعتبارية للشركة من تاريخ صدور قرار الشطب، ولأصحاب الشأن الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانهم أو علمهم به، وعلى المحكمة أن تقضي بالطعن على وجه الاستعجال^٥.

هذا وتنص الفقرة الأخيرة من المادة ١٩ بعد تعديلها على أنه: "ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن في أموالهم الخاصة عن الآثار أو الأضرار التي تترتب أو تلحق بالغير نتيجة لشطب قيد الشركة من السجل التجاري، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأخرى".

أما إذا قُبل التظلم تزول كافة آثار الاعتراض، وعلى مكتب وزير الاقتصاد إبلاغ كل من الشركة ومصلحة الشركات والسجل التجاري بقبول التظلم، هذا ويعتبر مُضي خمسة عشر يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه آثار الاعتراض، ويتعين الإبلاغ به إلى كل من الشركة ومصلحة الشركات والسجل التجاري^٥.

تقييم نظام الرقابة على تأسيس شركات المساهمة في ظل نظام الإخطار:

تتم الرقابة على تأسيس الشركات في ظل النظام الذي وضعه القانون رقم (٣) لسنة ١٩٩٨ في مرحلة لاحقة على القيد في السجل التجاري للشركة واكتسابها الشخصية الاعتبارية، وتأخذ شكل الاعتراض على إنشاء الشركة، والذي قد يؤدي إلى صدور قرار بشطب قيدها من السجل التجاري، وقد كان هدف المشرع من التعديل الذي طرأ على إجراءات تأسيس الشركات المساهمة، هو تحقيق السرعة المنشودة في مجال المعاملات التجارية، وتيسير العقبات أمام الراغبين في تأسيس هذا النوع من الشركات، خدمةً للاقتصاد الوطني ومواكبةً للتغيرات الهيكلية التي

طرأت عليه وتحوله إلى اقتصاد حر، وتمشياً مع سياسة الخصخصة وحرية التجارة والمنافسة، وتشجيعاً لاستثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية اللازمة لعملية التأسيس.^(١)

إلا أن هذا التعديل - وبالرغم من وجهة المقاصد والغايات التي استهدفها - بإلغائه نظام الترخيص الحكومي، ينطوي على المخاطر ذاتها التي من أجل تلafiها تم فرض نوع من الرقابة على تأسيس الشركات المساهمة بصفة عامة، وخاصة ما يتصل من هذه المخاطر بتهديد مصالح صغار المدخرين، وخطورة ذلك كله على الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى تأثير هذه الشركات المباشر على هذا الاقتصاد الذي تضطلع فيه هذه الشركات - في ظل النظام الرأسمالي والحرية الاقتصادية - بالدور الهام.^(٢)

والواقع أن خطورة هذا النظام - نظام الاخطار - تبدو من أنه يفتح الباب على مصراعيه أمام المنحرفين والمغامرين لتأسيس شركات وهمية وصورية، تقوم بالسطو على الادخار القومي وتوجيهه على نحو يضر بالاقتصاد الوطني ضرراً يتعذر تداركه أو إصلاحه، وكان حريّاً بالمشروع المصري أن يستفيد من تجربة الدول التي اعتنقت نظام حرية تأسيس الشركات، ويعمل على تعديل نظام السجل التجاري المصري بما يجعله وسيلة فعالة للتأكد من جدية الشركات المزمع قيدها في السجل وسلامة إجراءات تأسيسها.^(٣)

الفرع السادس

شهر شركة المساهمة واكتسابها الشخصية المعنوية المستقلة

بعد تمام إجراءات التأسيس، يتم قيد الشركة في السجل التجاري لشركات الأموال، وتكتسب الشخصية المعنوية بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا القيد، دون أن يصدر من الجهة الإدارية قرار بشطب قيد الشركة من السجل.

ويتم قيد الشركة في هذا السجل بموجب شهادة تعطى لمقدم الإخطار - المؤسسين أو من ينوب عنهم - من الجهة الإدارية المختصة، متى كان مرفقاً بهذا الإخطار جميع المحررات المنصوص عليها، ويتم قيد الشركة بموجب تلك الشهادة ودون حاجة لأي شرط أو إجراء آخر، وأياً كانت نسبة مشاركة غير المصريين فيها.^(٤)

وتتحقق الرقابة على تأسيس الشركة في هذه الحالة من خلال تعليق اكتساب الشركة شخصيتها المعنوية على القيد و مرور خمسة عشر يوماً عليه دون أن تعترض الجهة الإدارية المختصة عليه، بعد أن تفحص الإخطار بإنشاء الشركة والمستندات المرفقة به.^(٥)

ويوجد إلى جانب هذا القيد في السجل التجاري إجراء آخر، حتى تتم إجراءات شهر الشركة، وهو ضرورة نشر عقد الشركة، في حالة عدم الاعتراض على قيامها، في صحيفة الشركات مقروناً برقم القيد في السجل التجاري وتاريخه وذلك على نفقة الشركة.^(١)

المطلب الثاني

الجزاءات المترتبة على مخالفة قواعد التأسيس ومسئولية المؤسسين

نظم قانون الشركات الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامه، وكذلك المسؤولية المدنية والجنائية المترتبة على مخالفة هذه الأحكام، غير أن حكماً جديداً قد تم تبنيه في المادتين ١٧ و ١٨ من القانون، بعد تعديلهما بمقتضى القانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨، بشأن تطهير الشركة بعد قيدها في السجل التجاري من البطلان الناشئ عن الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس.

أولاً: جزاء مخالفة إجراءات التأسيس.

الأصل أنه إذا تمت مخالفة الشروط والإجراءات التي وضعها القانون، فإن الجزاء هو بطلان الشركة أو بطلان الشرط أو الإجراء الذي تم بالمخالفة لأحكام القانون، كما يحق لمن أصابه ضرر نتيجة هذا البطلان المطالبة بالتعويض، ويسأل بالتضامن من تسبب في هذا البطلان عن التعويض عند تعددهم.^(٢)

لكن الحكم الذي جاء به القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمعدل بالقانون رقم (٣) لسنة ١٩٩٨ في هذا الشأن، هو أنه يمتنع على ذوي الشأن الطعن ببطلان الشركة بمجرد قيدها في السجل التجاري، ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا القيد، حتى في حالة وجود عيب يشوب إجراءات التأسيس، وهذا هو مفهوم نص المادتين ١٨، ١٩ من القانون المشار إليه بعد تعديله، حيث تم تحصين الشركة المساهمة ذات الاكتتاب العام بمجرد انتهاء المهلة القانونية، ولم تعترض مصلحة الشركات على قيام الشركة، أو اعترضت وتم التظلم من قرارها وزالت آثار هذا الاعتراض لمضي خمسة عشر يوماً من تقديم التظلم دون البت فيه.^(٣)

وربما كان استبعاد البطلان كجزاء في حالة مخالفة قواعد تأسيس الشركات المساهمة - رغم أن اللجوء لطلب البطلان في هذه الحالة قد يكون أمراً طبيعياً بناءً على الطبيعة الآمرة لنصوص التشريعات التي تُنظم تأسيس الشركات بصفة عامة - هو رغبة التشريعات في تبني وسائل للحد، من أسباب بطلان الشركات المساهمة، من خلال التضييق من مدى حق طلب البطلان، ومن

وضع حد زمني للمطالبة به، وذلك لما يؤدي إليه بطلان الشركات من تقويض للبيان من أساسه، بما يترتب عليه من ضياع الجهد والمال.^(١)

ولا شك، أن هذا الحكم الذي ذهب إليه المشرع في قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد تعديله بالقانون رقم (٣) لسنة ١٩٩٨ - من حيث تطهير الشركة من عيوب التأسيس بمجرد مُضي المدة المحددة على قيد الشركة في السجل التجاري دون اعتراض وجعلها بمنأى عن البطلان - هو أمر تكتنفه العديد من المخاطر الجدية، وبما يحمل على التهاون في احترام القواعد الواجب اتباعها في تأسيس هذه النوع الهام من الشركات، لا سيما في فترة الاكتتاب وانعقاد الجمعية التأسيسية وتقويم الحصص العينية.

ويتأكد هذا النظر إذا وضعنا في الاعتبار أنه، في ظل التعديل الذي أتى به القانون رقم (٣) لسنة ١٩٩٨، واستبدال الرقابة الإدارية على التأسيس، مُثْلَةً في إخطار الجهة الإدارية المختصة-الهيئة العامة لسوق رأس المال-ومكتب السجل التجاري، بتأسيس الشركة، بالرقابة الحكومية السابقة على إجراءات التأسيس، التي تجعل من الصعب الموافقة على تأسيس الشركة التي يعتورها أي من أسباب البطلان، هذه الرقابة الإدارية، التي لم يزودها القانون بالوسائل الفعالة والأدوات التي تُمكنها من حمل ذوي الشأن على تقديم كل ما من شأنه التأكد من سلامة إجراءات التأسيس، تجعل عدم احترام أحكام القانون المتعلقة بإجراءات تأسيس شركات المساهمة أمراً كبير الاحتمال، خاصةً وأن الجهة الإدارية المختصة -مصلحة الشركات - لن يكون لها الاعتراض على تأسيس الشركات إلا في حالات محددة على سبيل الحصر، كما أن هذا الاعتراض سيعتبر كأن لم يكن بمجرد مرور خمسة عشر يوماً على التظلم دون البت فيه.^(٢)

ومع استبعاد المشرع البطلان كجزاء على مخالفة قواعد التأسيس، فإن هناك ثمة مفارقة مع ما ينص عليه القانون في المادة ١٦١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، المعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨، من أنه: "مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد الآمرة في هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارات شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكّلة على خلاف أحكامه، وذلك بما لا يخل بحق الغير حسن النية، وللمحكمة المختصة أن تحدد مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتصحيح البطلان إذا كان ذلك ممكناً".

وبمراجعة ما سبق فقد اتجه البعض في الفقه إلى تفسير ذلك بأن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة أصبح قاصراً على الحالات التي يتم فيها رفع دعوى البطلان قبل قيد الشركة في السجل التجاري، وإلا فإنه بعد هذا القيد لن يكون لنص المادة ١٦١ المذكورة مجال في التطبيق، سوى في حالات بطلان القرارات أو التصرفات التي تصدر على خلاف القانون، وتكون صادرة من مجلس الإدارة أو من الجمعية العامة، أو أن يكون سبب البطلان عيباً أو خللاً في العقد، أو يكون غرضها مخالفاً للقانون أو يتعارض مع المصالح القومية، أو كان مخالفاً للشروط الموضوعية العامة أو الخاصة لإنشاء الشركات بصفة عامة، دون تلك التي تكون قد صدرت في فترة التأسيس وتظهرت بالقيد في السجل التجاري.^(١)

ثانياً: المسؤولية المدنية والجنائية للمؤسسين.

على قدر ما تمثله عمليات تأسيس شركات المساهمة من أهمية للاقتصاديات الوطنية، من حيث أنها تضيف عناصر اقتصادية منتجة إليها، على قدر ما قد تنطوي عليه من مخاطر على هذه الاقتصاديات وعلى المدخرات العامة، وذلك في حالة ما إذا استغل المؤسسون عملية التأسيس هذه للغش والخداع والإيقاع بصغار المدخرين لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وقد تضافرت أحكام القانون على إقرار المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية، إذا شكلت المخالفة فعلاً يُعاقب عليه القانون الجنائي كجريمة، وذلك بقصد توفير الحماية للادخار العام والاقتصاد الوطني بصفة عامة.

المسؤولية المدنية:

لا يعني استبعاد تطبيق البطلان على مخالفة إجراءات التأسيس إعفاء المؤسسين من المسؤولية عن الأضرار التي تصيب الغير نتيجة هذه المخالفات، فإذا أخل مؤسسو شركات المساهمة بأي من الالتزامات العقدية أو القانونية خلال مرحلة التأسيس، وترتب على هذا الإخلال ضرر للغير، قامت في شأنهم أركان المسؤولية المدنية وفقاً للقواعد العامة^(٢).

حيث يسأل هؤلاء قبل الشركة وقبل المساهمين وقبل دائي الشركة عن الأضرار التي تترتب على مخالفة أحكام القانون المتعلقة بإجراءات التأسيس، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الشركات على أنه: "لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة أية شروط تعفي المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة"، ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عما التزموا به.^(٣)

والمقرر في هذا الشأن أنه لا يسري في حق الشركة بعد تأسيسها أي تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس وبين مؤسسيها، وذلك ما لم يعتمد هذا التصرف مجلس إدارة الشركة إذا كان أعضاؤه جميعاً لا صلة لهم بمن أجرى التصرف من المؤسسين أو لم تكن لهم مصلحة في التصرف، أو من جماعة الشركاء، أو بقرار من الجمعية العامة للشركاء في اجتماع لا يكون فيه للمؤسسين ذوي المصلحة أصوات معددة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يضع المؤسس ذو المصلحة تحت نظر الجهة التي تعتمد التصرف كافة الحقائق المتعلقة بالتصرف المذكور^(١).

ولكل من أصابه ضرر من جراء مخالفة المؤسسين لإجراءات التأسيس وأحكامه أن يرفع دعوى المسؤولية المدنية، سواء كان هو المؤسس نفسه أم الشركة المساهمة تحت التأسيس أم الغير، ويجوز رفع دعوى المسؤولية حتى ولو لم ترفع دعوى ببطالان الشركة لمخالفة أحكام التأسيس^(٢)، بل ذهبت بعض أحكام القضاء إلى أنه يجب قبول دعوى المسؤولية المدنية حتى ولو لجأ المؤسسون إلى حل الشركة تفادياً لدعوى المسؤولية الناجمة عن البطلان.^(٣)

فإذا كان من أقام دعوى المسؤولية هو أحد المؤسسين أنفسهم، فيشترط عندئذ ألا يكون قد اشترك في الخطأ الذي يعزى إليه الضرر، وإذا كانت الشركة، كشخص معنوي، هي التي باشرت هذه الدعوى، فلا بد في هذه الحالة من تعيين وكيل قضائي للشركة لمباشرة هذه الدعوى.^(٤) هذا وتشمل دعوى المسؤولية، في هذه الحالة، العديد من الأطراف، فهي تشمل المؤسسين، بصفة أساسية، بوصف أنهم هم من يجب عليهم أن يبذلوا في تعاملهم مع الشركة المساهمة تحت التأسيس أو لحسابها عناية الرجل الحريص، ويلتزمون - على سبيل التضامن - بأية أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة هذا الالتزام.^(٥)

كما تشمل دعوى المسؤولية أيضاً أعضاء مجلس الإدارة الأول ومراقب الحسابات الأول، وذلك قبل الشركة والمساهمين وكل دائن للشركة عن الضرر الناشئ عن الحكم ببطلان الشركة، أو عن أي خطأ في التأسيس لا يترتب عليه البطلان ويؤدي إلى إحداث ضرر بأي من الأطراف، ويرى البعض أنه في حالة رفع الدعوى يجب أن يتم تحديد أي من هؤلاء (المؤسسين، أعضاء مجلس الإدارة الأول، مراقب الحسابات الأول) قد تسبب في إحداث الضرر ليطم رفع الدعوى عليه، لئلا يتم رفع الدعوى مثلاً على أعضاء مجلس الإدارة عن خطأ لا علم لهم به ولا إرادة في إحداثه.^(٦)

ويحكم القاضي على المؤسسين بالتعويض إذا كان له مقتض، بأن كان ثمة خطأ وقع من المؤسس أدى لحدوث ضرر للغير، لكن إذا فشل مشروع تأسيس الشركة المساهمة، الذي أصاب الغير بضرر لا يرجع إلى فعل المؤسس ولا دخل له به، فإن المسؤولية تمتنع في هذه الحالة، لانتفاء الخطأ في جانب المؤسس، كأن يصدر قرار من الدولة مثلاً بحظر نشاط الشركة محل التأسيس، فحينئذ لا يحكم بتعويض على المؤسسين، ويكفيهم ضياع ما بذلوه من مال وجهد ووقت في عملية التأسيس.^(١)

ووفقاً لحكم المادة ١/٩ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١: "لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة أية شروط تعفي المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة".

ومن أمثلة الخطأ الموجب لمسؤولية المؤسسين، نشر بيانات كاذبة لإغراء الجمهور على الاكتتاب في أسهم الشركة، أو عدم استيفاء قيمة الأسهم عند الاكتتاب، أو قبول الاكتتاب من أشخاص معسرين، أو عدم متابعة إجراءات تأسيس الشركة دون سبب معقول، أو عدم إيداع المبالغ المحصلة من قيمة الأسهم في أحد البنوك، أو المبالغة في تقدير الحصص العينية.^(٢)

وتنص المادة ٢/١١ من القانون المذكور على أنه: "إذا تلقى المؤسس أية أموال أو معلومات تخص الشركة تحت التأسيس كان عليه أن يرد للشركة تلك الأموال، وأية أرباح يكون قد حصل عليها نتيجة استعماله لتلك الأموال أو المعلومات". ولكل طرف ذي شأن أن يطالب برد هذه الأموال أو المعلومات أو أية أرباح متحصلة عنها من قبل المؤسس.

وتذهب بعض الأحكام القضائية، في هذه الحالة إلى ضرورة التوسع في مفهوم من يُعد مؤسساً، حمايةً للادخار العام وجمهور المدخرين، بحيث تشمل الدعوى المدنية كل من قام بمبادرة أو عمل إيجابي لتأسيس الشركة ولو لم يكن من بين المؤسسين القانونيين، ما دام يمكن اعتباره المحرك الحقيقي لتأسيس الشركة.^(٣)

وتقضي المادة (٥٧) من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بأن: "المبالغ التي دفعت من المكتتبين تظل تحت يد الجهة التي تلقت الاكتتاب، ولا يجوز السحب منها إلا بعد أن يُتقدم من ينوب عن الشركة قانوناً ما يُفيد إشهار نظامها في السجل التجاري، وأنه يتعين أن يرد إلى المكتتبين جميع ما دفعوه إذا صدر حكم من قاضي الأمور المستعجلة بتعيين من يسحب هذه المبالغ وتوزيعها على المكتتبين إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها خلال ستة

أشهر من تاريخ تقديم طلب التأسيس، وكذلك إذا مضت مدة سنة على تاريخ قفل باب الاكتتاب دون أن يتقدم المؤسسون أو من ينوب عنهم بطلب تأسيس الشركة".^(١)

أيضاً تتعقد المسؤولية المدنية التضامنية على عاتق المؤسسين في حالة معينة نصت عليها المادة ٥/١٩ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، والمعدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨، ذلك أنه لدى إخطار الجهة الإدارية المختصة بتأسيس الشركة وفقاً للمادة ١٧ من قانون الشركات المذكور- المعدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨- واعتراض مصلحة الشركات على قيام الشركة للأسباب التي حددتها هذه المادة الأخيرة، فإنه إذا ما انتهى الأمر بشطب الشركة بقرار من الجهة المختصة، وما يترتب عليه من زوال شخصيتها المعنوية، فإنه وفقاً للمادة (٥/١٩ المعدلة) يكون المؤسسون مسئولين بالتضامن في أموالهم الخاصة عن الآثار أو الأضرار التي تترتب أو تلحق بالغير نتيجة الشطب، وذلك دون إخلال بالعقوبات الجنائية المقررة".

الطبيعة التضامنية للمسؤولية المدنية للمؤسسين:

تنشأ المسؤولية المدنية بحق مؤسسي شركات المساهمة إذا ما ارتكبوا أية مخالفة قانونية خلال مباشرتهم أعمال التأسيس المتطلبة قانوناً، وسبب ذلك ضرراً للغير، سواء قضي ببطلان الشركة أم لا^(٢)، وهي مسؤولية تضامنية تقع على عاتق كافة المؤسسين إذا تعددوا، وعلى هذا يلتزم المؤسسون على سبيل التضامن بأية أضرار قد تصيب الغير أو الشركة تحت التأسيس نتيجة مخالفة التزامهم ببذل العناية الواجبة قانوناً. (المادة ١١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١).

وقد ورد مبدأ تضامن المؤسسين في المادة العاشرة من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ التي تنص على أن: "يكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عما التزموا به، ويعتبر المؤسس الذي التزم عن غيره ملتزماً شخصياً إذا لم يُبين اسم موكله في عقد إنشاء الشركة أو اتضح بطلان التوكيل الذي قدمه..." أيضاً في المادة ١٤ من القانون المشار إليه، التي تقرر المسؤولية التضامنية أمام المكتتبين إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها خلال ستة أشهر من تاريخ طلب الترخيص بإنشائها..... إذا ثبت أن ثمة أخطاء يمكن نسبتها للمؤسسين حالت دون تأسيس الشركة في هذه المدة.^(٣)

المسؤولية الجنائية:

لا تكفي العقوبات المدنية المقررة في القانون من (بطلان - أداء حقوق للغير - التعويض عند الاقتضاء)، حتى وإن وصلت المسؤولية المدنية إلى حد المسؤولية التضامنية المطلقة وغير المحدودة

في أموال المؤسس المخالف، وإنما يجب إقرار عقوبات جنائية لفرض احترام الأحكام المتعلقة بإجراءات تأسيس الشركات المساهمة، وقد تضمن قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ النص على جزاءات جنائية في حالة مخالفة قواعده وأحكامه، وذلك في المادة ١٦٢ منه، والتي حلت محلها الجزاءات التي ورد النص عليها في قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢^(١).

فوفقاً للمادة ٦٣ من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ فإنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطاً من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له في ذلك وكل من طرح للاكتتاب أوراقاً مالية أو تلقى عنها أموالاً بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من أثبت عمداً في نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير هذه البيانات بعد اعتمادها من هيئة سوق رأس المال أو عرضها عليه، وكل من أصدر عمداً بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التي تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقي الاكتتاب" وهذا الحكم يلغي حكم المادة ١/١٦٢ شركات..

كما نصت المادة ٦٧ من القانون - المشار إليه - على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون"^(٢).

والجدير بالذكر هنا أن الجزاءات الجنائية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، لا تخل بضرورة توقيع العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، كتوقيع عقوبة النصب على المؤسسين إذا تبين أنهم لم يقصدوا تكوين شركة جدية، بل الترويج لشركة وهمية، وتوقيع عقوبة خيانة الأمانة في حالة اختلاسهم الأموال التي تم تحصيلها لحساب الشركة...^(٣)

المبحث الثاني

الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة

تمهيد وتقسيم:

الأوراق المالية Securities التي تصدرها شركات المساهمة هي صكوك أو مستندات تمثل قيمة مالية^(٤). وهي في صورتها التقليدية تشمل ثلاثة أنواع: الأسهم والسندات وحصص التأسيس أو

حصص الأرباح.^(١)

فالأسهم هي أوراق مالية تثبت حق صاحبها في ملكية جزء شائع من صافي أصول الشركة أو موجوداتها وما ينتج عن استثمارها من أرباح، كما تعطي لمالكها نصيباً في موجوداتها عند التصفية، أما السندات فهي أوراق تمثل حقاً في دين على الشركة مصدرة الورقة، وتضفي على صاحبها صفة الدائن، وتعطيه حق الحصول على فائدة ثابتة واسترداد قيمة السند في الميعاد المحدد، أما حصص التأسيس فهي صكوك تمنحها الشركة لبعض الأشخاص نظير خدمات يؤدونها إلى الشركة، تخول الحق في الحصول على نصيب من أرباح الشركة دون أن يقابلها حصة في رأس المال.

وتشكل الأوراق المالية التقليدية الغالبية العظمى من الأوراق المالية المتداولة في سوق الأوراق المالية، هذه الأوراق التي تصدرها شركات المساهمة من أسهم وسندات وحصص تأسيس، هو ما سنتناوله على النحو التالي:

المطلب الأول

الأسهم

تمهيد: السهم هو الصك الذي تصدره شركة المساهمة وتمنحه للمساهم نتيجة اكتتابه في رأس مالها^(١). وقد جرى تعريف السهم، بما يراعي الحقوق اللصيقة به والمخولة لصاحبه سواء أثناء حياة الشركة أو بعد انقضائها، على أنه حق الشريك في الشركة وفي ذات الوقت الصك المثبت لهذا الحق^(٢).

ويمثل السهم مستند ملكية له قيمة اسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية، وتتمثل القيمة الاسمية للسهم في القيمة المدونة على قسيمة، وعادة ما يكون منصوفاً عليها في عقد تأسيس الشركة المصدرة، أما القيمة الدفترية فتتمثل في قيمة حقوق الملكية - التي لا تتضمن الأسهم الممتازة ولكنها تتضمن الاحتياطات والأرباح المحتجزة - مقسومة على عدد الأسهم العادية المصدرة، وأخيراً تتمثل القيمة السوقية في القيمة التي يباع بها السهم في السوق، وقد تكون هذه القيمة أقل أو أكثر من القيمة الاسمية أو القيمة الدفترية للسهم، ويدرك المتعاملون في هذه السوق أن القيمة الحقيقية للسهم تتوقف على العائد الذي يتوقع تولده نتيجة لامتلاكه، أي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات التي يتوقع أن يجنيها المستثمر^(٣).

ويخول السهم لصاحبه العديد من المزايا والحقوق، كالحق في التنازل عن السهم، والحق في البقاء في الشركة، والحق في نصيب من الأرباح، والحق في حضور الجمعية العامة والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، والحق في الرقابة على أعمال الشركة والإطلاع على دفاترها ومستنداتها بما لا يلحق ضرراً بالشركة، والحق في الاشتراك في ناتج التصفية عند انتهاء الشركة.

وهذه الحقوق مقررّة للمساهم بوصفه شريكاً في الشركة، فهي تستند إلى نية المشاركة وما تستتبعه من وجود المساواة بين الشركاء، لذلك تعتبر من الحقوق الأساسية للمساهم، بحيث يقع باطلاً كل قرار من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بها. (م ٦٨/أ شركات).

وستتناول في دراستنا للأسهم، خصائص الأسهم، وأنواعها، ثم تداولها والقيود التي ترد على التداول، والوفاء بقيمتها، والحقوق الملازمة لها.

الفرع الأول: خصائص الأسهم

تتميز الأسهم الصادرة عن شركات المساهمة بأنها تصدر بقيمة إسمية متساوية، وعدم قابليتها للتجزئة، فضلاً عن قابليتها للتداول على الوجه المبين بالقانون.

١- المساواة في القيمة:

وفقاً للمادة (٣١) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١: "يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، ويحدد النظام القيمة الإسمية للسهم بحيث لا تقل عن عشرة قروش ولا تزيد على ألف جنيه ، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون. ويلغى كل نص يخالف ذلك في أى قانون آخر".^(١)

وعلى هذا يقسم رأس مال شركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة، تخول أصحابها ذات الحقوق وتحملهم ذات الواجبات، حيث يسهل ذلك تقدير الأغلبية في الجمعيات العامة للشركة وعملية توزيع الأرباح على المساهمين، فضلاً عن تنظيم سعر الأسهم في البورصة، غير أن القيمة الإسمية للسهم يمكن أن تتفاوت من إصدار إلى آخر، إلا أنه يجب تساوي الأسهم في كل إصدار على حدة حتى لا تتفاوت المراكز القانونية للمكتتبين في الإصدار الواحد^(٢)، وقد قضت المادة ١١ من قانون رأس المال بأن: "جميع حقوق والتزامات أصحاب الأسهم تكون متساوية ولا يلزم المساهمون إلا بقيمة أسهمهم..".

غير أن هذا الأصل لا يتعلق بالنظام العام، إذ يجوز مخالفته بإصدار أسهم تمنح أصحابها مزايا خاصة تسمى بالأسهم الممتازة، حيث قد يعطى حامل السهم الممتاز أولوية على حملة الأسهم العادية في أموال التصفية وفي التوزيعات السنوية، أو أن يمنح عددًا من الأصوات في الجمعيات العامة للشركة تزيد على تلك المقدرة للأسهم العادية، ومع ذلك يجب أن تتوافر المساواة بين الأسهم من ذات النوع في الحقوق وفي القيود.^(٣)

٢- عدم القابلية للتجزئة:

كما يتميز السهم بأنه غير قابل للتجزئة بالنسبة إلى الشركة، وهو حكم مقرر أيضاً لتسهيل مباشرة الحقوق للصيقة به، والممنوحة لصاحبه، فإذا تعدد الملاك، كما إذا آلت ملكية السهم بسبب الوفاة إلى عدد من الورثة، وجب أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المترتبة على ملكية السهم في مواجهة الشركة، كحق الحضور في الجمعية العمومية وحق التصويت.^(٤)

٣-قابلية السهم للتداول:

السهم قابل للتداول دائماً^(١)، إذ يجوز التنازل عنه بطرق القيد في سجلات الشركة إذا كان اسمياً، وبالتسليم إذا كان لحامله، وبالتظهير إذا كان لأمر، وقابلية السهم للتداول هي السمة الجوهرية له، والتي تفرقه عن حصة الشريك في شركة الأشخاص والتي لا يجوز التنازل عنها، كقاعدة، إلا بقيود وشروط معينة.

الفرع الثاني: أنواع الأسهم

تنقسم الأسهم إلى أنواع مختلفة بحسب الوجهة المتخذة أساساً للتقسيم.

أولاً: من حيث شكلها: الأسهم الإسمية والأسهم لحاملها:

تنقسم الأسهم من حيث الشكل: إلى أسهم اسمية وأسهم لحاملها، فالأسهم الإسمية هي التي يثبت عليها اسم مالكيها وتكون له دون غيره كافة الحقوق المرتبطة بالسهم، ويجرى تداول هذا السهم عن طريق القيد في سجلات الشركة. أما الأسهم لحاملها فهي التي لا تحمل اسم صاحب الحق فيها، وإنما يذكر في السهم عبارة لحامله، ويعتبر حامل السهم هو المالك في مواجهة الشركة، حيث تصبح الحيازة دليلاً على الملكية، ويتم تداول هذا السهم عن طريق التسليم المادي.^(٢) وقد ألغى المشرع المصري بمقتضى قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الأسهم لحاملها، ولم يقر سوى الأسهم الإسمية بمقتضى المادة ٣١/١، قبل أن يجيز لاحقاً الأسهم لحاملها بمقتضى المادة الأولى من قانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، وأعطاهما كافة حقوق الأسهم الإسمية عدا حق التصويت، وأوجب ضرورة الوفاء بقيمتها بالكامل عند الاكتتاب، مع عدم جواز تحويلها إلى أسهم إسمية أو العكس.^(٣)

ثانياً: من حيث طبيعة الحصة المقدمة في رأس المال: الأسهم النقدية والأسهم العينية:

فالأسهم النقدية هي التي تعطى نظير الحصة النقدية، ويجب دفع ١٠ ٪ من قيمتها الاسمية عند الاكتتاب، تزداد إلى ٢٥ ٪ خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة (م ٣٢ من قانون الشركات المعدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨)، على أن يسدد الباقي من قيمتها خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة، بشرط ألا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة، وهذه الأسهم هي التي يقع عليها الاكتتاب وحدها عند تأسيس الشركة، ويجوز تداولها حتى قبل سداد قيمتها.

أما الأسهم العينية فهي التي تعطى نظير الحصص العينية، عقاراً كانت أو منقولاً، وهي تختلف عن الحصص العينية في وجوب الوفاء بقيمتها كاملة لدى تقديمها في رأس المال، ووجوب تقدير قيمتها والتأكد من صحة التقدير، حتى يحصل المساهم على أسهم توازي التقييم الصحيح للحصة العينية^(١)، ولا يجوز تداول هذه الأسهم قبل نشر القوائم المالية عن سنتين مالتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة^(٢)، ويسري هذا الحكم على أسهم زيادة رأس المال التي تعطى مقابل حصص عينية، على أن تبدأ مدة السنتين من تاريخ تعديل بيانات الشركة بالسجل التجاري بما يفيد الزيادة.^(٣)

ثالثاً: من حيث استهلاكها: أسهم رأس المال وأسهم التمتع:

تنقسم الأسهم من حيث قابليتها للاستهلاك أثناء حياة الشركة إلى أسهم رأس المال وأسهم التمتع: ويقصد بسهم رأس المال Action de Capital السهم الذي يمثل جزءاً من رأس مال الشركة، نظراً لأن صاحبه لم يسترد قيمته أثناء حياة الشركة، أما سهم التمتع Action de Jouissance فهو الذي استهلك قيمته بحصول صاحبه على قيمته الإسمية أثناء حياة الشركة دون الانتظار، كما هو الوضع الطبيعي، إلى موعد حل الشركة وتصفيتها، ومن ثم فهو لا يمثل جزءاً في رأس مال الشركة.

ويعتبر استهلاك الأسهم، بالمفهوم المتقدم، عملية استثنائية، إذ الأصل هو عدم إخراج الشريك من الشركة باستهلاك أسهمه أثناء حياة الشركة، وإلا لكان معنى ذلك حرمان الشريك من حقه دون سند من القانون في البقاء في الشركة حتى يتم حلها وتصفيتها، إلا أن الشركة قد ترى أنه من المفيد للشركاء استهلاك الأسهم ورد قيمتها الإسمية للمساهمين أثناء حياتها، ويحدث ذلك في الحالة التي يخشى معها هلاك موجوداتها ومواردها قبل حلها وتصفيتها، ومن أمثلة الصورة السابقة، التي تقوم معها الحاجة إلى استهلاك الأسهم حال حياة الشركة، حالة ما إذا كانت الشركة تقوم على استغلال منجم أو محجر ينتهي بعد مدة معينة، أو كانت تستغل مرفقاً عاماً لمدة معينة بطريق الامتياز من الدولة، ثم تقول ممتلكات الشركة بعد انقضاءها إلى الدولة بدون مقابل كشركات المياه والكهرباء واستغلال الثروة المعدنية.

إذ لا شك أنه في الحالات السابقة ونحوها يكون من شأن الانتظار إلى الوقت الذي تنقضي فيه الشركة، حتى تشرع في رد قيمة الأسهم للشركاء، عجز الشركة عن توفير المال الكافي لدفع قيمة الأسهم في هذا التوقيت، مما يترتب عليه حرمان المساهمين من الحصول على قيمة

أسهمهم مطلقاً، وحينئذ تلجأ الشركة إلى تعجيل رد قيمة الأسهم للمساهمين "استهلاك الأسهم" بطريقة تدريجية، حتى إذا ما انقضت مدتها تكون قد استهلكت جميع الأسهم.

إجراءات وشروط استهلاك الأسهم:

وعلى ما تقدم، وبناء على ما حدده قانون الشركات ولائحته التنفيذية، فإنه لا يجوز إصدار أسهم تمتع إلا بالنسبة إلى الشركات التي ينص نظامها على استهلاك أسهمها قبل انقضاء أجل الشركة، بسبب تعلق نشاط الشركة بالتزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ممنوح لها لمدة محددة، أو بوجه من أوجه الاستغلال مما يستهلك بالاستعمال أو يزول بعد مدة معينة.^(١)

ويتم استهلاك الأسهم عادة بإحدى وسيلتين: (١) رد القيمة الإسمية لأسهم يتم اختيارها سنوياً بطريق القرعة. (٢) استهلاك الأسهم كلها بصفة تدريجية عن طرق رد جزء من القيمة الإسمية لكافة الأسهم كل عام، بحيث تستهلك كلياً في نهاية أجل الشركة^(٢)، ولا شك أن الطريقة الثانية أكثر عدالة من الطريقة الأولى التي يحتمل معها، بعد أن يسترد بعض المساهمين كامل قيمة أسهمهم، أن تمنى الشركة بخسائر يستحيل معها رد قيمة أسهم بقية المساهمين الذين لم تستهلك أسهمهم، مما يفتح الباب لهؤلاء الآخرين للإدعاء ببطلان استهلاك الأسهم في هذه الحالة.^(٣)

ويشترط لاستهلاك الأسهم، وفقاً للمادة ٣٥ / ١ من قانون الشركات، أن يكون منصوفاً عليه في نظام الشركة، وأن تدفع قيمة الأسهم المستهلكة من الأرباح أو الاحتياطيات القابلة للتوزيع، ولا يترتب على استهلاك الأسهم تخفيض رأس المال^(٤)، فلا يجوز أن تدفع قيمة الأسهم من رأس المال إعمالاً لمبدأ ثبات رأس المال، وإنما يتم ذلك من الاحتياطي الاختياري، وإلا كان لدائي الشركة دعاوى مباشرة قبل المساهمين للمطالبة باسترداد ما تم توزيعه عليهم مقابل استهلاك الأسهم، وعليه يجب أن تقف عملية استهلاك الأسهم إذا لم تحقق الشركة في سنة احتياطيات قابلة للتوزيع.^(٥)

حقوق أصحاب الأسهم المستهلكة:

متى تم استهلاك الأسهم حصل أصحابها على أسهم تمتع في الحدود التي ينص عليها نظام الشركة وفقاً للمادة ٣٥ / ١ من نظام الشركات، ويمنح سهم التمتع لصاحبه نسبة في الأرباح بالقدر المحدد في نظام الشركة، فضلاً عن استحقاقه حصة من ناتج التصفية بعد رد قيمة أسهم

رأس المال إلى أصحابها، ويكون لأسهم التمتع فيما عدا ما تقدم كافة الحقوق المقررة لحملة أسهم رأس المال في حدود ما ينص عليه نظام الشركة.^(١)

التفرقة بين استهلاك الأسهم وشراء الشركة لأسهمها:

استهلاك الشركة لأسهمها بالمعنى المتقدم، الذي يتضمن قيام الشركة برد القيمة الإسمية للسهم في مقابل منح المساهم أسهم تمتع تعطي نصيباً في الأرباح وحصّة في فائض التصفية، وفي الحدود الواردة في نظام الشركة، بحيث لا يترتب عليه انقطاع صلة المساهم بالشركة طوال مدة بقائها، هذا الاستهلاك لا ينبغي الخلط بينه وبين ما يعرف بشراء الشركة لأسهمها، والذي قد يتم بقيام الشركة بشراء الأسهم وفقاً لقيمتها في سوق الأوراق المالية أو بأي طريقة أخرى، وبحيث لا يكون للبائع بعد انتقال ملكية الأسهم للشركة صلة بينه وبين الشركة.

وقد كان المشروع يجيز للشركة شراء أسهمها في حالات استثنائية وردت في المادة ٤٨ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

إلا أنه لما كان شراء الشركة لأسهمها قد ينطوي على تخفيض مستتر لرأس المال دون اتباع الإجراءات القانونية، ولخشية لجوء الشركة إلى هذه الطريقة للمضاربة أو لدعم أسعار أسهمها حال اغيارها، لكل ذلك فقد تم تعديل المادة ٤٨ من قانون الشركات بمقتضى القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ والذي تضمن تطوراً ملفتاً، إذ تقضي هذه المادة بعد تعديلها بأنه: "لا يجوز أن تحصل الشركة بأي طريقة على جانب من أسهمها يجاوز ١٠ ٪ من إجمالي الأسهم المصدرة، ويجب على الشركة في حالة حصولها على جانب من الأسهم فيما يجاوز نسبة الـ ١٠ ٪ - المشار إليها- إخطار الهيئة العامة لسوق المال بذلك في موعد لا يجاوز ثلاثة أيام عمل، ويتعين عليها أن تتصرف في هذه الأسهم للغير في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ حصولها عليها، وإلا وجب عليها إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الإسمية لتلك الأسهم واتباع الإجراءات المقررة لذلك".

وإذا تقاعست الشركة عن القيام بإنقاص رأسمالها وفقاً للأحكام السابقة، تولت الهيئة اتخاذ إجراءات إنقاص رأس مال الشركة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إنذارها بذلك، ولا يعد تصرفاً للغير قيام الشركة بالتصرف في الأسهم المشار إليها للشركات التابعة أو المرتبطة بها.

وفي جميع الأحوال، لا يكون للأسهم المشار إليها حق التصويت أو الحصول على الأرباح عند توزيعها، وتستنز من إجمالي أسهم الشركة عند حساب الحضور والنصاب اللازم للتصويت

في الجمعية العامة، وذلك إلى حين التصرف فيها، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التصرف في الأسهم، وعلاقة الشركة بالشركات التابعة أو المرتبطة بها.

ويجوز للشركة شراء بعض أسهمها لتوزيعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم في الأرباح.^(١)

رابعاً: من حيث الحقوق التي تمنحها الأسهم لصاحبها: الأسهم العادية والأسهم الممتازة:

الأصل، طبقاً للقاعدة القانونية التي تقرر المساواة بين المساهمين في الحقوق والواجبات المترتبة على ملكية الأسهم، أن الأسهم تمنح المساهمين حقوقاً متساوية، ويشمل ذلك الحق في الأرباح والتصويت وفي نصيب من موجودات الشركة بعد تصفيتها، وكذلك المساواة في الالتزامات التي ترتبها الشركة، غير أن قاعدة المساواة لا تتعلق بالنظام العام، بمعنى أنه يجوز الاتفاق على خلافها في نظام الشركة، كأن ينص على منح امتيازات معينة لنوع من الأسهم، لأن المساواة المشار إليها تعني فقط المساواة في الحقوق والواجبات التي تمنحها الأسهم التي تنتمي إلى نوع واحد.

وعلى هذا فالأسهم العادية هي تلك الأسهم التي تمنح أصحابها الحقوق العادية للصيقة بالسهم والتي لا تنفصل عنه، والتي لا يعد بدونها سهماً، كالحصول على نصيب في الأرباح والاشتراك في التصويت وعلى نصيب من فائض التصفية، أما الأسهم الممتازة فهي تلك تخول أربابها، بجانب الحقوق التي تخولها الأسهم العادية، أولوية الحصول على امتيازات معينة، مثل الحصول على نسبة محددة من الأرباح أو من فائض التصفية "أسهم الأولوية" أو ميزة الحصول على عدد من الأصوات في الجمعية العامة يزيد على تلك المقررة لأصحاب الأسهم العادية "الأسهم ذات الصوت المتعدد"، ويتم منح هذه الأسهم عادة لتحقيق أغراض معينة، كتشجيع الجمهور على الاكتتاب في الأسهم الجديدة المصدرة أو إغراء حملة السندات على قبول تحويلها إلى أسهم، خاصة عند عجز الشركة عند سداد قيمة هذه السندات.

وقد أقر قانون الشركات وقانون سوق رأس المال هذا النوع من الأسهم، فوفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٣٥ من قانون الشركات، المعدلة بالقانون رقم ٤ سنة ٢٠١٨، يجوز أن ينص نظام الشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات أو القيود، ولا يجوز الجمع بين امتيازي التصويت وناتج التصفية، كما لا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق التعديل به.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصدار أسهم ممتازة أو زيادة رأس المال بأسهم ممتازة إلا بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق والأحكام الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة.^(١)

الفرع الثالث: تداول الأسهم

مبدأ حرية تداول الأسهم:

قدمنا أن أهم خصائص الأسهم أنها قابلة للتداول بالطرق التجارية ودون حاجة لاتباع إجراءات حوالة الحق، ولا يجوز النص على عكس ذلك في نظام الشركة (م ١٣٩ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات) ويشمل ذلك تداول شهادات الاكتتاب التي يتسلمها المكتتب بصفة مؤقتة قبل قيد الشركة في السجل التجاري إلى حين استبدالها بالأسهم (م ٤٦ من قانون الشركات).

وتختلف طريقة تداول السهم تبعاً لشكله، فإذا كان السهم إسمياً فيتم نقل ملكيته عن طريق القيد في سجل الملكية الذي تمسكه الشركة في مقرها الرئيسي، وذلك بناء على إقرار يقدم إلى الشركة يتضمن اتفاق المتنازل والمتنازل إليه على التنازل عن الصك وموقعاً على الإقرار من كل منهما أو من ينوب عنهما، ويتم التأشير على الصك بما يفيد نقل الملكية إلى من انتقلت إليه، ومن ثم تقوم الشركة بإكمال إجراءات نقل الملكية عن طريق القيد في سجلاتها (المادتين ١٢٠ و ١٢١ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات).

أما إذا كان السهم لحامله فيتم التصرف فيه بطريق التسليم أو المناولة، لأن الحق الثابت في السهم يندمج في الصك ذاته، فتصبح حيازة الصك دليلاً على الملكية.

تداول الأسهم في ضوء نظام الإيداع المركزي للأوراق المالية.

غير أن هذا الطريق لتداول الأسهم، عن طريق إثبات نقل الملكية بسجلات الشركة خلال مدة معينة من تاريخ إخطارها به من قبل إدارة البورصة، بحيث تنتقل ملكية الورقة المالية الاسمية إلى المالك الجديد بتسليمه الدعامة المحسوسة والتأشير على الورقة المالية (السهم) بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه^(٢)، هذا الطريق لم يعد معمولاً به الآن بعد تطبيق أحكام الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية في كافة البورصات المالية الحديثة، حيث ترتب على نظام الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية زوال الكيان المادي والملموس للأوراق المالية، وتحويلها إلى مجرد قيود

دفترية في الحساب المفتوح باسم مالكيها، ويتم تداولها وتسوية العلاقات الناشئة عن هذا التداول ونقل الملكية عن طريق التحويل بين الحسابات بالطرق الإلكترونية عن طريق وسطاء ماليين يتولون إتمام عمليات التداول بمجرد التحويل بين الحسابات لمصلحة المتعاملين، وبذلك فقد تم إحلال سجلات الأوراق المالية لدى مؤسسات المقاصة والإيداع المركزي محل سجلات الأوراق المالية لدى جهات الإصدار، تسهياً لتنفيذ عملية التداول على الأوراق المالية وتيسيراً لإتمام المقاصة والتسوية ونقل الملكية.^(١)

وفيما يتعلق بسوق الأوراق المالية في مصر، فإنه في ضوء قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٣، تم إنشاء شركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع المركزي للأوراق المالية^(٢)، وبدأت الشركة ممارسة نشاطها منذ سنة ١٩٩٦ للوصول للحيازة المركزية للأوراق المالية، وليكون التعامل عليها من خلال القيود الحسابية بدلاً من تبادل صكوك الأوراق المالية المطبوعة، وتزاول الشركة نشاط الإيداع المركزي ونشاط القيد المركزي.^(٣)

ووفقاً لقانون الإيداع والقيد المركزي رقم (٩٣) لسنة ٢٠٠٠م، يجب أن يودع لدى شركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع المركزي الأسهم المقيدة في إحدى بورصات الأوراق المالية، وجميع الأسهم التي تصدرها أي شركة إذا طرحت أسهماً لها في اكتتاب عام، ويجوز إيداع غير ذلك من الأسهم^(٤). وبذلك يكون المشرع قد جمع بين الإيداع الإجباري والإيداع الاختياري، ويتم الإيداع الاختياري وفقاً للشروط التي يضعها مجلس إدارة شركة الإيداع المركزي وتوافق عليها هيئة سوق المال.^(٥)

ويبدو من عمومية النص أن الالتزام بالإيداع المركزي والتحول إلى القيد الحسابي بدلاً من الدعامات المادية المحسوسة يسري على الأسهم لحاملها، والتي لم يعد لها وجود في ظل تطبيق أحكام القانون التي جردت الأسهم من شكلها المادي وحولتها إلى مجرد قيود حسابية، واستبدل بها ما يمكن وصفه بالأسهم مجهولة الاسم، والتي تقيد في حساب يمسكه وسيط مالي يلتزم بعدم الإفصاح عن هوية مالكيها.^(٦)

القيود الواردة على مبدأ حرية تداول الأسهم.

وفقاً للمادة ١٣٩ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ".. يكون السهم قابلاً للتداول ولا يجوز النص على غير ذلك في نظام الشركة"، وبالرغم من ذلك فإنه يمكن أن ترد قيود على تداول الأسهم يكون مصدرها إما نص في القانون، فتسمى بـ "القيود القانونية"، ويتم ذلك بغرض حماية حقوق المساهمين والاقتصاد الوطني من الغش أو من المضاربات غير المشروعة، كما أن نظام

الشركة الأساسي قد ينص على بعض القيود على تداول أسهم شركة المساهمة، فتسمى تلك القيود في هذه الحالة بـ"القيود الاتفاقية"، وقد اعترف بصحة هذه القيود شريطة ألا تصل إلى حد حرمان المساهم من حقه في التنازل عن أسهمه، وهو حق متعلق بالنظام العام.

أولاً: القيود القانونية:

تضمن قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ النص على بعض القيود القانونية على تداول الأسهم في حالات معينة، نشير إليها على النحو التالي:

١- لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية، قبل نشر القوائم المالية للشركة عن سنتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط اللازمة، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (٥٣) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.^(١)

وفيما عدا حصص التأسيس والأسهم المشار إليهما، يكون تداول أسهم شركات المساهمة وفقاً للقواعد والجراءات التي ينظمها قانون الشركات وقانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وهذا ما قضت به الفقرتان الأولى والثانية من المادة ٤٥ من قانون الشركات المعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨.

ويسري هذا الحظر على ما يكتب فيه مؤسسو الشركة في كل زيادة في رأس المال قبل انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة المذكورة.^(٢)

والحكمة من هذا الحظر هي الرغبة في قطع سبيل الغش على المؤسسين الذين قد يقدمون على مشروع فاشل أو يرتكبون أثناء التأسيس أياً من الأفعال الضارة، ثم يسارعون إلى التخلص منها وقبض قيمتها بمجرد تأسيس الشركة، لذلك رأي المشرع أنه من الواجب أن يربط أقدار المؤسسين بأقدار الشركة طيلة هذه المدة، محققاً بذلك نوعاً من ضمان جدية المؤسسين وصدق نواياهم.

ومع ذلك يجوز -استثناء من الأحكام المتقدمة- أن يتم بطريق الحوالة نقل ملكية الأسهم التي يكتب فيها مؤسسو الشركة من بعضهم لبعض أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة، إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة^(٣)، لأن الحكمة من الحظر، وهي تلافي صور الغش والأفعال الضارة، لا تتوفر في هذه الحالات.^(٤)

٢- لا يجوز تداول شهادات الاكتتاب ولا الأسهم بأزيد من القيمة التي صدرت بها مضافاً

إليها-عند الاقتضاء-مقابل نفقات الإصدار، وذلك في الفترة السابقة على قيد الشركة في السجل التجاري بالنسبة إلى شهادات الاكتتاب، أو في الفترة التالية لتاريخ القيد حتى نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة إلى الأسهم، إلا وفقاً للشروط والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد.^(١)

وتبدو الحكمة من هذا الحظر في تلافي الضرر الذي قد يصيب جمهور المكتتبين من الاندفاع إلى شراء الصكوك المشار إليها بأزيد من قيمتها الحقيقية، جراء ارتكاب المؤسسين بالشركة أعمال غش أو إعلانات كاذبة تؤدي إلى المبالغة في تقدير قيمة هذه الصكوك، ثم يفاجئون، بعد أن تبدأ الشركة في ممارسة نشاطها، بالقيمة الحقيقية المتدنية لها.

٣- كما يحظر تداول أسهم الضمان الواجب على عضو مجلس إدارة الشركة تقديمها لضمان أعمال إدارته، وذلك طيلة مدة شغله لهذا المنصب، ويجب إيداع القدر من الأسهم التي يملكها عضو مجلس الإدارة أو التي تقدم من الأصيل الذي ينوب عنه لضمان إدارته في خلال شهر من تاريخ التعيين أحد البنوك المعتمدة لهذا الغرض، ويستمر إيداع هذه الأسهم مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة وكالة العضو، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها بأعماله. وإذا لم يقدم العضو أسهم الضمان المشار إليها ويحتفظ بها على الوجه المنصوص عليه بطلت عضويته.^(٢)

٤- وقد تضمنت المادة ٨ من قانون سوق رأس المال والمادة ٥٩ من لائحته التنفيذية حظراً على تداول الأسهم التي يترتب على تملكها السيطرة على الشركة، وذلك بهدف منع تركيز ملكية الأسهم بيد بعض المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين. وتتلخص أحكام هذه الحالة في أنه:

أ- على كل من يرغب في عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه ١٠ % من الأسهم الاسمية في رأس مال إحدى الشركات التي طرحت أسهما لها في اكتتاب عام، أن يخطر الشركة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، متضمناً نسبة مساهمته في رأس مال الشركة، ومرفقاً به بيان كاف بالعملية، وعلى الأخص نوع الأسهم محل العملية وعددها ومواصفاتها ومكان عقد العملية بالنسبة إلى الأسهم غير المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، وذلك قبل عقد العملية بأسبوعين على الأقل واسم وعنوان شركة السمسرة التي تتم العملية بواسطتها.

ب- على الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك ١ %

على الأقل من رأس مال الشركة. وعلى الشركة خلال أسبوع من تاريخ اخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك ١٪ على الأقل من عدد أسهم الشركة على عنوانه الثابت لديها أو بالنشر عن ذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وأن تبلغ به كذلك البورصة المقيدة بها. وتسري الأحكام السابقة في حالة عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم اسمية ٥ ٪ من رأس مال الشركة. ومتى تم إبداء الرغبة في الشراء على النحو المتقدم فلا يجوز لراغب الشراء التصرف في أسهمه في الشركة خلال الفترة من تاريخ الاخطار المشار إليه إلى تمام عقد العملية أو انتهاء المدة المقررة لعقدها حسب الأحوال، ويتعين اتخاذ الاجراءات المشار إليها قبل عقد كل عملية فيما يجاوز النسبتين سالفتي الذكر.^(١)

ووفقاً للفقرة ٣ من المادة ٨ من قانون سوق رأس المال، يترتب على مخالفة الأحكام السابقة إلغاء العملية دون إخلال بمسئلة المتسبب عن هذه المخالفة، وذلك فضلاً عن معاقبة المخالف بالعقوبة المقررة في المادة ٦٦ من قانون سوق رأس المال.^(٢)

ثانياً: القيود الاتفاقية:

يجوز أن يتضمن عقد الشركة قيوداً على تداول الأسهم شريطة ألا يصل إلى منع التداول، لأن حق المساهم في التنازل عن أسهمه للغير يعد من الحقوق الأساسية التي لا يجوز حرمانه منها، أو تعليق هذا التنازل على الإرادة المطلقة للشركة، وقد أجازت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات أن يتضمن نظام الشركة بعض القواعد المتعلقة بتنظيم تداول الأسهم بشرط ألا تصل إلى حرمان المساهم من حق التنازل عن أسهمه، ولا يجوز إدراج هذه الشروط في نظام الشركة بعد تأسيسها، ما لم يتضمن النظام الذي وافق عليه المؤسسون النص على حق الجمعية العمومية غير العادية في إدخال القيود التي تراها على تداول الأسهم (م ٣٩ / ٢ من اللائحة).

ومن أمثلة القيود الاتفاقية: النص في نظام الشركة على تحريم التنازل لأشخاص معينين، كهؤلاء الذين يمارسون أعمالاً منافسة للشركة أو من يحملون أفكاراً ومبادئ بحيث يمثل وجودهم في الشركة خطراً عليها، أو عدم جواز بيع أسهم الشركة للأجانب، أو على ضرورة عرض الأسهم المراد بيعها على بقية المساهمين قبل بيعها للغير، أو على حق الشركة في استرداد الأسهم التي تم بيعها قبل عرضها على الشركاء، وللقضاء مراقبة مدى صحة هذه الشروط ومدى إمكان الاحتجاج بها.

وتقضي المادة ١٤٠ من اللائحة بأنه يجوز أن ينص في نظام الشركة على وجوب موافقة إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال على تنازل المساهم عن أسهمه إلى الغير حتى لو كان من بين المساهمين بشروط معينة^(١)، ولا يسري هذا القيد على ما يتم من تنازل بين الأزواج والفروع والأصول.

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن المادة ٦٣ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال قد ألغت هذه الشروط في حالات معينة، بنصها على أنه: "لا يجوز للشركة أو نظامها الأساسي وضع قيود على تداول أسهمها متى كانت من شركات الاكتتاب العام أو على الأسهم التي يتم قيدها ببورصات الأوراق المالية وذلك مع عدم الإخلال بالأوضاع المقررة عند تاريخ العمل بهذه اللائحة". ويظهر من هذا النص أن القيود الاتفاقية لا تصح إلا فيما يتعلق بالشركات القائمة عند تاريخ العمل بهذه اللائحة وبالنسبة للشركات التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام.

المطلب الثاني

السندات وصكوك التمويل

تمهيد:

كثيراً ما تحتاج الشركة أثناء حياتها إلى أموال بخلاف رأس المال، وذلك لسد حاجتها من السيولة اللازمة لنشاطها، وعلى الشركة أن تبدأ بالمبادرة إل مطالبة المساهمين بسداد الجزء غير المدفوع من رأس المال، كما تستطيع الشركة أن تحصل على هذه الأموال إما عن طريق زيادة رأس مالها، أو عن طريق الاقتراض من الغير، وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة.

وإذا قررت الشركة اللجوء إلى الاقتراض من الغير، فهي إما أن تعقد قرضاً فردية، كالاقتراض من البنوك، وذلك إذا كان مبلغ القرض غير كبير وأجل وفائه قصيراً، أو تعقد قرضاً جماعية بمبالغ كبيرة في شكل سندات تطرح للاكتتاب العام لمدة كبيرة، تتراوح غالباً بين خمس سنوات وعشرين سنة، وغالباً ما تفضل الشركة هذا الأسلوب الأخير للحصول على الأموال، نظراً لما تقتضيه زيادة رأس المال من إجراءات وما تؤدي إليه من إدخال مساهمين جدد يشاركون المساهمين الأول في أرباح الشركة،

وعلى هذا يعد إصدار السند بمثابة اتفاق أو عقد بين المنشأة المصدرة (المقرض) والمستثمر أو المكتتب (المقرض)، موضوعه قرض جماعي طويل الأجل، حيث يقرض الطرف الثاني مبلغاً مالياً للطرف الأول، والذي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة،

ويتم ذلك في صورة صكوك متساوية القيمة قابلة للتداول بالطرق التجارية، تمثل قرضاً جماعياً طويل الأجل يعقد عن طريق الاكتتاب العام، وتصدر في شكل شهادات اسمية أو لحاملها.^(١) وقد أجاز المشرع في المادة ٤٩ من قانون الشركات والمادة ١٢ من قانون رأس المال، للشركة إصدار سندات، وحدد شروط إصدارها وكيفية الاكتتاب بها، وحقوق حملة السندات. وعلى هذا فسوف نتناول بالدراسة خصائص السندات وأنواعها وشروط إصدارها وحقوق أصحاب السندات.

الفرع الأول: خصائص السندات وأنواعها

أولاً: خصائص السندات:

تتميز السندات بأنها تصدر في صورة قرض جماعي طويل الأجل، ومن ثم فيجب أن تتساوى إذا كانت من ذات الإصدار الواحد، سواء فيما يتعلق بقيمتها المالية أو بشروطها أو بتمائل الحقوق التي تخولها لأصحابها أو في قابليتها للتداول، شأنها في ذلك شأن الأسهم.^(٢) وتصدر السندات أو صكوك التمويل في شكل شهادات اسمية أو لحاملها قابلة للتداول، وتخول الصكوك أو السندات من ذات الإصدار حقوقاً متساوية لحاملها في مواجهة الشركة، ويوقع على السندات والصكوك عضوان من أعضاء مجلس إدارة الشركة يعينهما المجلس أو من الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، ويكون لها كوبونات ذات أرقام متسلسلة مشتملة على رقم السند أو الصك، وتختتم بخاتم بارز للشركة.^(٣) وتنتقل ملكية السندات بطريق القيد في سجلات الشركة إذا كانت اسمية، وبالتسليم إذا كانت لحاملها، ويجب الحصول على ترخيص من الهيئة في حالة طرح السندات وصكوك التمويل في اكتتاب عام.^(٤)

وكما هو الشأن بالنسبة لتداول الأسهم، فإنه مع التطور التشريعي لإدراج وإيداع الأوراق المالية مركزياً بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠، وما تبعه من تأسيس شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، وتبني النظم الآلية في عمليات المقاصة والتسوية ونقل الملكية في سوق الأوراق المالية، لم يعد تداول السندات يتوقف على ما إذا كانت اسمية أو لحاملها، حيث زال الكيان المادي لهذه السندات وتحولت إلى مجرد قيود حسابية لدى مؤسسات المقاصة والتسوية والإيداع والحفظ المركزي، حيث يتم نقل ملكيتها بمجرد التحويل بين حسابات العملاء لدى هذه المؤسسات.^(٥)

ولا يخضع تداول السندات للقيود الواردة على تداول الأسهم، وينبغي لإمكانية التداول، أن تقيد السندات التي تصدرها الشركة وتطرحها للاكتتاب العام، في جدول أسعار بورصات الأوراق المالية في مصر وذلك خلال سنة من تاريخ قفل باب الاكتتاب، ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب مسئولاً عن ذلك وعن التعويض الذي يستحق بسبب عدم القيد عند الاقتضاء.^(١)

ثانياً: أنواع السندات:

تتعدد الأنواع والصور التي يمكن أن تصدر عليها السندات، ومن ذلك:

١- السندات العادية: au de la valeur dominal :

وهي السندات التي تصدر بذات القيمة الاسمية المبينة بها، ويلتزم المكتتب بسدادها كاملة عند الاكتتاب ويستردها بذات القيمة عند نهاية مدة السند، ويحول هذا السند لصاحبه فائدة ثابتة عادة ما تكون مرتفعة، حيث لا يعطي السند ميزات أخرى غير الفائدة. وهناك السند العادي ذو العائد المتغير، وهو الذي يعطي صاحبه فائدة تختلف بحسب ما تحققه الشركة من أرباح، وهو نوع من أنواع القرض مع المشاركة في الأرباح pret avec participation bénéfiques.

٢- السندات بعلاوة وفاء:

وهي سندات تصدر بأقل من قيمتها الإسمية، بمعنى أن صاحبها يلتزم بدفع مبلغ أقل من قيمة السند الإسمية على أن ترد له الشركة القيمة الإسمية، ويسمى الفرق بين القيمة الإسمية وما يتم تحصيله "علاوة وفاء: prime de remboursement"، ويحصل حامل هذا السند على هذه العلاوة مضافاً إليها فائدة ثابتة تحسب على أساس القيمة الإسمية للسند، وتعتبر هذه العلاوة نوعاً من الفائدة.

٣- السندات ذات النصيب:

وهي سندات تصدر بقيمتها الإسمية وتستحق فائدة ثابتة كما هو الشأن في السندات العادية، ولكن بالإضافة إلى الحق في الاقتراع على جائزة كبيرة تمنح لعدد من الأسهم التي تحدد بطريق القرعة، وتقصد الشركة من إصدار هذه السندات تشجيع الجمهور إلى الاكتتاب فيها، وعادة لا تعطي هذه السندات فائدة كبيرة، حيث تستقطع الشركة جزءاً من الفائدة لاستخدام الفرق في منح الجائزة المالية.

٤- السندات ذات الضمان الشخصي أو العيني:

وهي سندات تصدر بقيمتها الاسمية كالسندات العادية أيضاً، وتخول صاحبها الحق في الحصول على فائدة ثابتة، إلا أنها مضمونة بضمان عيني أو بضمان شخصي، كما هو الحال إذا ضمنت الحكومة أو إحدى البنوك هذه السندات أو كانت مضمونة برهن رسمي على عقارات الشركة وموجوداتها، ويشترط عادة لتقرير هذا الضمان موافقة الجمعية العامة العادية، ويجب أن يتم الرهن أو الكفالة لصالح جماعة حملة السندات قبل إصدار السندات، ويتولى إتمام إجراءات الرهن أو الكفالة الممثل القانوني للجهة التي تضمن السندات وذلك بعد موافقة السلطة المختصة في هذه الجهة، وإذا كان الضمان رهناً وجب قيده قبل فتح باب الاكتتاب في السندات.^(١)

٥- السندات القابلة للتحويل إلى أسهم: وهي سندات تعطي حاملها الحق في طلب تحويلها إلى أسهم، وتحوله من ثم من دائن للشركة إلى مالك أو شريك فيها، وقد أجازت المادة ٥١ من قانون الشركات هذا النوع من السندات بنصها على أنه: يجوز أن تتضمن شروط إصدار السندات قابليتها للتحويل إلى أسهم بعد مضي المدة التي تحددها الشركة في نشرة الاكتتاب، ويتم التحويل بموافقة صاحب السند، ويشترط في هذه الحالة مراعاة القيود المقررة لزيادة رأس المال، ويتم ذلك بموافقة صاحب السند، ومقتضى ذلك أن تحدث مقاصة بين حق الشريك في قيمة السهم والتزام الشركة برد القيمة الاسمية للسند.^(٢)

الفرع الثاني: إصدار السندات

وفقاً للمادة ١٢ من قانون سوق رأس المال يكون إصدار السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى سواء كانت اسمية أو لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية...، كما أوجبت هذه المادة لإصدار السندات أن يتم بموجب اكتتاب عام بعد الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة العامة لسوق المال، وذلك بناء على نشرة معتمدة من الهيئة.

وعلى هذا فعندما أجازت القوانين المنظمة لشركات المساهمة إصدار سندات بطريق الاكتتاب العام، حددت شروط إصدار هذا القرار وإجراءاته وذلك على النحو التالي:

أ- لا يجوز لشركة المساهمة إصدار سندات إلا بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة مرفقاً به تقرير من مراقب الحسابات يتضمن الشروط التي تصدر بها السندات^(٣)، فلا

يملك مجلس الإدارة إصدار هذا القرار، لأنه لا يتعلق بأعمال الإدارة المعتادة للشركة، ولذلك أسند القانون إصداره إلى الجمعية العامة لتعلقه بالمركز المالي والسياسة المالية للشركة، والجمعية المختصة بإصدار القرار في هذه الحالة هي الجمعية العامة العادية وفقاً للمادة ١/٢١ من قانون سوق رأس المال، التي تملك تقدير ملائمة القرض لمشروع الشركة سواء من حيث مقداره أو من حيث مدته، وليست الجمعية العامة غير العادية.^(١)

ويجب وفقاً للمادة (١/١٢) -السابق الإشارة إليها- أن تتضمن موافقة الجمعية العامة العائد الذي يغله السند أو الصك أو الورقة وأساس حسابه دون التقييد بالحدود المنصوص عليها في أى قانون آخر، ويجوز للجمعية العامة أن تضمن قرارها بإصدار السندات أو الصكوك قيمتها الاجمالية وما لها من ضمانات وتأمينات مع تفويض مجلس إدارة الشركة في اختيار وقت الإصدار وتحديد الشروط الأخرى المتعلقة بها، ويجب إصدار تلك الأوراق خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية التالية لقرار الجمعية العامة.^(٢)

ب- أن يتم دفع قيمة رأس المال المصدر بالكامل، إذ من غير المقبول لشركة المساهمة أن تلجأ إلى الإقتراض وهي لم تحصل بعد على جزء من رأس مالها، وعلى سبيل الاستثناء يجوز للشركة أن تصدر سندات قبل سداد رأس المال بالكامل في الحالات الآتية:

- ١- إذا كانت السندات مضمونة بكامل قيمتها برهن له الأولوية على ممتلكات الشركة.
- ٢- السندات المضمونة من الدولة.
- ٣- السندات المكتتب فيها بالكامل من البنوك، أو الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية وإن أعادت بيعها.
- ٤- الشركات العقارية، وشركات الائتمان العقاري، والشركات التي يرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص.^(٣)

ج- ألا تتجاوز قيمة السندات التي تصدرها الشركة صافي أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقاً لآخر قوائم مالية وافقت عليها الجمعية العامة، أو لطرحها للاكتتاب العام^(٤)، وذلك حتى لا تكون قيمة القرض الذي تعقده الشركة أكبر من مجموع أصول الشركة وموجوداتها، التي تمثل الضمان العام لدائني الشركة، ومن ثم فلا يجوز إصدار السندات قبل نشر ميزانية الشركة عن سنة مالية على الأقل.

ومع ذلك يجوز بقرار من الهيئة العامة لسوق المال أن ترخص لهذه الشركات في إصدار سندات بقيمة تجاوز صافي أصولها، ويشترط لطرح السندات أو صكوك التمويل بقيمة تجاوز صافي أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقاً لآخر قوائم مالية وافقت عليها الجمعية العامة، أو لطرحها للاكتتاب العام، الشروط الآتية:

١- أن تقدم الشركة للهيئة شهادة التصنيف الائتماني^١ على ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات التي ترتبها السندات أو الصكوك، وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

٢- أن تفصح الشركة عن هذا التصنيف وعن التعريف المقترن به ودلالته وفقاً للجهة التي أصدرت شهادته، وذلك في نشرة الاكتتاب أو في الدعوة إليه بحسب الأحوال.

ومع ذلك يجوز أيضاً بقرار من مجلس إدارة الهيئة الترخيص للشركة بإصدار سندات وصكوك تمويل بقيمة تجاوز صافي أصولها أو طرحها للاكتتاب العام في حالة عدم الصلاحية للتصنيف الائتماني أو إذا كان التصنيف دون المستوى المشار إليه، وذلك كله في الحدود التي يصدر بها القرار.^١

د- الحصول على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال في حالة طرح السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى في اكتتاب عام.^١

هـ- لا يجوز الدعوة للاكتتاب العام إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار، إحداها على الأقل باللغة العربية^١، ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقاً للنماذج التي تعدها الهيئة.

وطبقاً للمادة (٢/٥) من قانون سوق رأس المال يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب الأخرى، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بإصدار الأسهم، الإفصاح عن البيانات الآتية :

سابقة أعمال الشركة، أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسؤولين بها وخبراتهم، أسماء حاملي الأسهم الاسمية الذين يملك كل منهم أكثر من ٥ % من أسهم الشركة ونسبة ما يملكه كل منهم، موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاثة السابقة أو عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة أيهما أقل والمعدة طبقاً لقواعد الإفصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية والنماذج التي تضعها الهيئة، نتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي الصحيح لها.^١

على أنه إذا لم يتم تغطية جميع السندات وصكوك التمويل المطروحة للاكتتاب خلال المدة المقررة، يجوز لمجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، أن يقرر الاكتفاء بما تم تغطيته، مع إخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من قرار المجلس.^(١) هذا وبصفة عامة تسرى على السندات وصكوك التمويل القواعد والأحكام المقررة للأسهم وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص.^(٢)

الفرع الثالث: حقوق أصحاب السندات

حامل السند دائن للشركة له الحق في الحصول على الفوائد المحددة في شروط الإصدار، واسترداد قيمة السند في الميعاد.

فيجب على الشركة دفع الفوائد أيّاً كان المركز المالي للشركة حتى وإن لم تحقق أرباحاً، وقد ينطوي إصدار السندات على شروط أخرى لصالح المقرض، مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضماناً للسداد أو وضع قيود على إصدار سندات أخرى، وقد تلجأ الشركة، في سبيل إغراء الجمهور بالاكتتاب في السندات، إلى تخصيص نسبة معينة من الأرباح لحملة السندات، علاوة على الفائدة الثابتة التي يتقاضونها، إلا أن ذلك لا يغير من طبيعة السند ولا يحول حامله إلى شريك، بل يظل دائناً للشركة لأنه لا يشترك في الخسائر ولا دخل له في إدارة الشركة.^(٣)

كما أن لحامل السند، بوصفه دائناً للشركة، الحق في استرداد قيمة السند في الموعد المحدد وفقاً لشروط الإصدار، ولا يجوز تقديم ميعاد الوفاء أو تأخيرها، لأن الأجل حق للطرفين فلا يجوز تعديله إلا بموافقتهم، إلا أن هذه القاعدة قد ترد عليها استثناءات في حالات معينة:

استهلاك السندات:

فضلاً عن أن العقد قد يتضمن شروطاً لصالح المقرض تتيح له استدعاء السندات (استهلاكها) قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه لما كان الوفاء بجميع قيمة السندات دفعة واحدة عند حلول أجل الوفاء، قد يكون متعذراً على الشركة، فإنها قد تحتفظ لنفسها بشرط صريح في نشرة الإكتتاب بالحق في استهلاك عدد من السندات سنوياً، وتحدد القرعة السندات التي يتم استهلاكها.

وللشركة دائماً أن تقوم باستهلاك سنداتهما عن طريق شرائها من سوق الأوراق المالية، لأن السندات قابلة للتداول، ويتم استهلاك السندات من الأرباح القابلة للتوزيع أو من الاحتياطي

أو من رأس المال، وليس لدائن الشركة أن يتضرر من استهلاك السندات من رأس المال، إذا أن نقصان رأس المال في هذه الحالة يقابله نقص مماثل في مقدار ديون الشركة، وذلك على عكس استهلاك الأسهم الذي لا يجوز أن يتم إلا من الأرباح، فإذا لم تحقق الشركة أرباحاً فلا يمكن استهلاك الأسهم.^(١)

ومتى استهلك السند انقطعت صلة حامله بالشركة نهائياً، وذلك على خلاف الحال بالنسبة لاستهلاك الأسهم، حيث يمنح صاحب السهم المستهلك سهم تمتع يخوله حق التصويت في الجمعيات العامة والحق في نصيب من الأرباح.^(٢)

جماعة حملة السندات:

لغرض حماية المصالح المشتركة لأصحاب السندات، نظم قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في المادة ١/٥٢ لأول مرة في التشريع المصري جماعة حملة السندات، تضم جميع حملة السندات ذات الإصدار الواحد، كما أورد قانون سوق رأس المال رقم ٩٢ لسنة ١٩٩٣ ولائحته التنفيذية تنظيماً مفصلاً لهذه الجماعة، وتتكون من حملة السندات وصكوك التمويل ذات الإصدار الواحد جماعة غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها.^(٣)

تعيين الممثل القانوني للجماعة وعزله:

يكون لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره في اجتماع للجماعة بالأغلبية المطلقة لحملة أكثر من نصف قيمة الإصدار، وتحدد الجماعة فترة تمثيله لها ومن ينوب عنه عند غيابه، والمكافأة المالية التي ترى الجماعة تقريرها له، فإذا لم يتم اختياره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع دعى إليه لاختياره، يجوز لكل من أعضاء الجماعة أن يطلب من الهيئة تعيين ممثل للجماعة، وعلى رئيس الهيئة أن يصدر قراره بتعيين ممثل للجماعة خلال شهر من تاريخ وصول الطلب للهيئة.

ويتم عزل الممثل القانوني للجماعة بالأغلبية المطلقة لحملة أكثر من نصف قيمة الإصدار، لفقده أحد الشروط المبينة في لائحة قانون سوق رأس المال، أو لغيرها من الأسباب بناء على طلب من حملة ٥٪ من قيمة الإصدار أو من الهيئة، ويجب أن يكون قرار العزل مسبباً.^(٤)

ويجب أن يكون ممثل الجماعة شخصاً طبيعياً وألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة مصدرة الأوراق المالية أو مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي تلك الأوراق، أو يكون عضواً بمجلس إدارة أو من الشركاء المديرين أو أعضاء مجلس المراقبة أو من العاملين لدى شركة

تملك أكثر من ١٠٪ من رأس مال الشركة مصدرة الأوراق المالية أو ضامنة لكل أو بعض ديون هذه الشركة.^(١)

ويجب على رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب للإدارة، والممثل القانوني للجماعة أن يخطر الهيئة بتشكيل الجماعة واسم ممثلها القانوني، وعلى الممثل القانوني للجماعة أن يخطر كلا من الهيئة، ورئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب للإدارة بصورة موقعة منه من القرارات التي تصدرها الجماعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.^(٢)

اختصاصات الممثل القانوني للجماعة:

يتولى الممثل القانوني للجماعة مباشرة الإختصاصات الآتية: ١- رئاسة اجتماعات الجماعة، وفي حالة غيابه ومن ينوب عنه تختار الجماعة من يحل محله في رئاسة الاجتماع. ٢- القيام بأعمال الإدارة اللازمة لتسيير أمور الجماعة وحماية مصالحها وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه له الجماعة. ٣- تمثيل الجماعة في مواجهة الشركة أو الغير أمام القضاء. ٤- رفع الدعاوى التي توافق الجماعة على إقامتها باسمها وذلك بغرض المحافظة على المصالح المشتركة لأعضائها، وبصفة خاصة الدعاوى المتعلقة بإبطال القرارات والأعمال الضارة بالجماعة من الشركة إن كان لذلك مقتضى.

ويجب على الشركة إخطار ممثل الجماعة بموعد جلسات الجمعية العامة وموافاته بجميع الأوراق المرفقة بالإخطار على الوجه الذي يتم به إخطار المساهمين.

ويكون للممثل القانوني للجماعة حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة، وإبداء ملاحظاته دون أن يكون له صوت محدود في المداولات، ويكون له عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس إدارة الشركة أو الجمعية العامة للشركة، ويجب إثبات محتواها في محضر الجلسة، ولا يجوز للممثل القانوني للجماعة التدخل في إدارة الشركة.^(٣)

اجتماعات جماعة حملة السندات: تدعى للاجتماع - في أي وقت - جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى في الأحوال الآتية:

(أ) إذا طلب الممثل القانوني للجماعة. (ب) إذا طلب مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال. (ج) إذا طلب حملة مالا يقل عن ٥٪ من قيمة السندات وصكوك التمويل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من الشركة أو الممثل القانوني للجماعة، فإذا لم يتم الاجتماع خلال ثلاثين يوماً جاز للطالبين أو بعضهم أن يطلبوا من القضاء

الأمر بتعيين ممثل مؤقت للجماعة يتولى الدعوة لعقد الاجتماع ورئاسته. (د) اذا طلبت ذلك هيئة سوق المال. (هـ) اذا طلب مصفي الشركة خلال فترة التصفية.

على أن يتضمن الطلب في جميع الأحوال الموضوعات المطلوب عرضها على الجماعة.^(١) ويجب على كل من وجه الدعوى لاجتماع الجماعة أن يخطر الهيئة والشركة مصدرة الأوراق بالبيانات والاختارات الموجهة للدعوة لعقد اجتماع الجماعة وذلك في ذات تاريخ الاخطار أو الاعلان^(٢) ، ويكون اجتماع الجماعة صحيحاً بحضور الأغلبية الممثلة لقيمة السندات وصكوك التمويل، فاذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول كان الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.^(٣)

وتتضمن الدعوة الى اجتماع جماعة حملة السندات وصكوك التمويل البيانات المتطلبة لدعوة الجمعية العادية للشركة - والواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - وعلى أن يضاف إلى البيانات المبينة في الدعوة للاجتماع بيان الاصدار أو الاصدارات التي يدعى حملة أوراقها الى الاجتماع، واسم وعنوان الشخص الذي يدعو الى الاجتماع وصفته، أو قرار المحكمة بتعيين ممثل مؤقت للدعوة الى الاجتماع في حالة وجوده.^(٤)

ويحدد الشخص أو الجهة التي طلبت الدعوة الى الاجتماع جدول الأعمال، ويجوز لحملة ما لا يقل عن ٥٪ من القيمة الإسمية للسندات وصكوك التمويل أن يطلبوا من الشخص أو الجهة التي لها حق الدعوة إدراج مسائل معينة في جدول الاجتماع لنظرها وإصدار قرارات في شأنها، ولا يجوز مناقشة أو إصدار قرارات في شأن مسائل لم تدرج في جدول الاجتماع.^(٥)

ويكون لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل أن تتخذ في اجتماعاتها الإجراءات الآتية:
(أ) أي إجراء يكون من شأنه حماية المصالح المشتركة لحملة السندات وصكوك التمويل وتنفيذ الشروط التي تم على أساسها الاكتتاب. (ب) تقرير النفقات التي قد تترتب على أي من الاجراءات التي تتخذها. (ج) إبداء أية توصيات في شأن من شئون الشركة لتعرض على الجمعية العامة للمساهمين أو مجلس الإدارة.

ولا يجوز لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل أن تتخذ أية إجراءات يترتب عليها زيادة أعباء أعضائها أو عدم المساواة في المعاملة بينهم.^(٦)

المطلب الثالث

حصص التأسيس أو حصص الأرباح

حصص التأسيس أو أنصبة المؤسسين هي صكوك تخول أرباحها الحق في الحصول على نصيب من أرباح الشركة دون أن يقابلها تقديم حصة في رأس المال، فهي صكوك لا تمثل نصيباً في رأس مال الشركة على خلاف أسهم المساهمين، وليس للصك الذي يجسد هذه الحصص قيمة اسمية، وإنما تتمتع هذه الحصص بقيمة فعلية تتحدد على أساس ما يقرر لها من أرباح، وهي عادة ما تمنح للمؤسسين نظير ما قاموا به من مجهودات في سبيل تأسيس الشركة، ويجوز للشركة أن تلغي هذه الحصص، على خلاف الأسهم حيث لا يجوز إخراج أحد المساهمين من الشركة بدون رضاه^(١).

ويتم إنشاء هذه الحصص سواء عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها، وقد ظهرت حصص التأسيس لأول مرة سنة ١٨٥٨ في نظام شركة قناة السويس البحرية، وذلك كمكافأة للمؤسسين والحكومتين الفرنسية والمصرية على الجهود التي بذلت لتأسيس ونجاح المشروع، ولما كانت هذه الحصص تقتطع من أرباح الشركة دون أن يشارك أصحابها في تكوين رأس المال اللازم لمباشرة نشاطها، فإن المشرع كثيراً ما يحظرها أو يتدخل لوضع قيود على إصدارها وتداولها وكيفية تحديد الأرباح التي تخصص لها.

وعادة ما ينظر إلى حصص التأسيس نظرة شك وارتياب، نظراً لأن إنشائها يؤدي إلى نتائج متعارضة مع مبادئ العدالة، حيث يجعل أصحابها في مركز أفضل من مركز المساهمين، بالنظر إلى أنهم يتمتعون بنصيب ثابت من الربح مع عدم مساهمتهم في تكوين رأس المال، في حين أن المساهمين يتحملون في الخسارة بقدر مساهمتهم في رأس المال، فضلاً عن تقلب نصيبهم في الأرباح.

وقد حدا الوضع السابق بالعديد من التشريعات التجارية إلى حظرها تماماً (قانون الشركات الفرنسي لسنة ١٩٦٦، وقانون الشركات اللبناني الصادر في ١٩٤٢م)، أما المشرع المصري فقد قيد إصدارها بشرطين، فوفقاً للمادة ١/٢٤ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١: لا يجوز إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح إلا مقابل التنازل للشركة عن التزام منحه الحكومة أو حق من الحقوق المعنوية، مثال ذلك أن يتم التنازل للشركة عن التزام منحه الحكومة كاستغلال مشروع نقل نقل أو توريد ماء أو غاز، أو التنازل عن حق معنوي كبراءة اختراع أو علامة تجارية.

الحقوق التي تمنح لأصحاب حصص التأسيس:

تخول حصص التأسيس أصحابها نصيباً محدداً من الأرباح، ويجب أن يتضمن نظام الشركة بياناً بمقابل تلك الحصص والحقوق المتعلقة بها، غير أنه لا يجوز أن يخصص لهذه الحصص ما يزيد على ١٠٪ من الأرباح الصافية بعد حجز الاحتياطي القانوني ووفاء ٥ ٪ على الأقل بصفة ربح لرأس المال^(١).

ومعنى هذا أن أصحاب حصص التأسيس لا يشاركون في الأرباح بالنسبة المقررة إلا بعد تجنيب الاحتياطي القانوني ودفع ٥ ٪ من الأرباح لأصحاب أسهم رأس المال، وقد يقول الأمر إلى عدم حصول أصحاب حصص التأسيس على أي نصيب من الأرباح إذا ما تبين أن الأرباح الصافية لا تكفي، بعد خصم الاحتياطي القانوني ودفع النسبة المشار إليها لحملة الأسهم، للوفاء بنسبة أصحاب حصص التأسيس من هذه الأرباح.

هذا وليس لأصحاب حصص التأسيس أي نصيب في فائض التصفية عند حل الشركة وتصفيتها، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بقانون الشركات^(٢).

وفي سبيل الدفاع عن مصالحهم يكون لأصحاب حصص التأسيس الحق في الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها وذلك بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للخطر^(٣)، كما يجوز لهم حضور جلسات الجمعية العامة للشركة دون أن يكون لهم بأي وجه من الوجوه الاشتراك في مداولاتها أو التصويت على قراراتها، وتنفذ قرارات الجمعية العامة في مواجهتهم رغم عدم اشتراكهم في التصويت عليها، ومع ذلك فلا يجوز للجمعية العامة أن تعدل حقوقهم في الأرباح إلا بعد موافقتهم.

تداول حصص التأسيس:

تصدر حصص التأسيس في صورة صكوك إسمية، ومن ثم فهي صكوك قابلة للتداول، حيث يتم نقل ملكيتها عن طريق القيد في سجلات الشركة، ولا يجوز تداول هذه الحصص قبل نشر القوائم المالية وسائر الوثائق الملحقه بها عن سنتين مائتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة^(٤).

وكما هو الشأن بالنسبة للأسهم والسندات، فإنه بصدر قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠، وإدخال النظم الإلكترونية في إتمام عمليات التداول وتسوية المراكز القانونية والمالية الناشئة عنها عبر آليات القيد والحفظ المركزي، فقد تجردت

الصكوك القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية من دعامتها المادية، ومن ثم فقد أصبح تداولها يتم عن طريق القيود الحسابية في المؤسسات والشركات المناط بها القيام بنشاط الإيداع والقيود المركزي.

إلغاء حصص التأسيس:

طبقاً لنص المادة ٢/٣٤ من قانون الشركات: للجمعية العامة للشركة الحق في إلغاء حصص التأسيس بشروط معينة: ١-مضي ثلث مدة الشركة أو عشر سنوات مالية على الأكثر من تاريخ إنشاء تلك الحصص، ما لم ينص نظام الشركة على مدة أقصر ٢٠-أن يتم الإلغاء بالنسبة لجميع الحصص ذات الإصدار الواحد في حالة وجود أكثر من إصدار ٣-أن يكون الإلغاء بناء على تعويض عادل.^(١)

وفي الأحوال التي يكون فيها للجمعية العامة إلغاء حصص التأسيس لها بدلاً من إلغائها بناء على اقتراح مجلس الإدارة تحويل حصص التأسيس إلى أسهم ويزداد رأس المال بقيمتها في حدود رأس المال المرخص به^(٢)، وتتم زيادة رأس المال خصماً من المال الاحتياطي القابل للتوزيع، وتقسم هذه الزيادة على عدد من الأسهم توزع على أصحاب حصص التأسيس وبذلك يتحول أصحاب حصص التأسيس إلى مساهمين.

المبحث الثالث إدارة شركة المساهمة

تمهيد وتقسيم:

على خلاف قواعد الإدارة في شركات الأشخاص التي تتسم بالبساطة كقاعدة عامة، فإن التنظيم القانوني لإدارة شركة المساهمة، وبالنظر إلى التأثير المباشر لهذا النوع من الشركات على الإدخار والاقتصاد الوطني بصفة عامة، يقوم على تعدد جهات الإدارة والرقابة على الشركة، وقد أخضع القانون هذه الهيئات لما يمكن تسميته بوحدة المصالح والأهداف المشتركة، كما وضع أيضاً العديد من القواعد المنظمة للهيكل المالي للشركة، بهدف إحكام الرقابة على مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين فيما يتعلق بالتصرف في أرباح الشركة وماليتها.

وقد صيغت هيئات الإدارة والرقابة على شركة على شركة المساهمة على صورة نظام الحكم في الدول الديمقراطية، فالسلطة العليا للشركة تتمثل في الجمعية العامة للمساهمين، غير أنه لما كان

من المتعذر عليها بسبب كثرة المساهمين، في الغالب، أن تقوم بتصرف الأمور العادية للشركة، فإنها تقوم بانتخاب عدد قليل من المساهمين في صورة مجلس إدارة، ليضلع بممارسة أعمال الإدارة العادية للشركة وتحقيق الهدف الذي أنشأت من أجله، كما تقوم الجمعية العامة بتعيين مراقب أو مراجع للحسابات ليتولى الرقابة على أعمال مجلس الإدارة نيابة عنها ويرفع إليها تقريره بنتائج هذه الأعمال.

وسوف نتكلم، فيما يتعلق بإدارة شركة المساهمة، عن مجلس الإدارة، والجمعية العامة للشركة، والرقابة على نشاط الشركة، وذلك في المطالب الثلاثة الآتية:

المطلب الأول مجلس الإدارة

مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للشركة التي تتولى تسيير أعمالها وتحمين على نشاطها، ذلك أن السلطة العليا في الشركة وإن كانت، بحسب الأصل، هي للجمعية العامة للمساهمين، إلا أن عزوف هؤلاء عن استعمال صلاحياتهم في حضور الجمعيات العامة أو مباشرة دورهم في الرقابة والإشراف على أعمال وشئون الشركة، قد أضعف السلطة الممنوحة قانوناً للجمعية العامة، وفتح المجال أمام مجلس الإدارة لممارسة السلطة الفعلية في تسيير أمور الشركة. وقد أورد المشرع تنظيماً مفصلاً لكيفية تشكيل مجلس الإدارة وشروط العضوية في المجلس وانعقاده، كما عرض لسلطات المجلس واختصاصاته، وأخيراً لالتزامات مجلس الإدارة ومسئوليته. وهو ما نعرض له بشئ من التفصيل.

الفرع الأول: تشكيل مجلس الإدارة

تقضي المادة ١/٧٧ من قانون الشركات بأن: "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للطريقة المبينة بنظام الشركة، واستثناء من ذلك يكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات".

وقد نصت المادة (٧٧ مكرراً) من قانون الشركات-المضافة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨- على أنه: "يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس

المال في عضوية مجلس الإدارة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط هذا التمثيل وحدوده وإجراءاته".

ويلاحظ أن عدد أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يكون فردياً، وذلك لتأمين الأغلبية اللازمة لإصدار القرارات، وألا يقل الحد الأدنى عن ثلاثة، كشرط ابتداء واستمرار، وإلا كانت قراراته باطلة لصدورها وفق تشكيل باطل للمجلس تطبيقاً للمادة ١٦١ شركات (المعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨)، وليس هناك حد أقصى لعدد الأعضاء، ومن ثم يترك تحديده للنظام الأساسي للشركة.

وتحسب مدة العضوية من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، أو تاريخ صدور قرار الجمعية العامة باختيار أعضاء المجلس بحسب الأحوال، إلى تاريخ انتهاء أعمال أول جمعية عامة تعقد للنظر في القوائم المالية عن السنة المالية التي تقع فيها نهاية مدة العضوية، ويجوز تجديد عضوية مجلس الإدارة الذي انتهت مدته لمدة أو لمدد أخرى، ما لم ينص النظام على غير ذلك.^(١) وإذا خلا منصب عضو مجلس الإدارة بعد تشكيله على نحو صحيح، وجب شغل المنصب بعضو جديد، وتختلف طريقة تعيين العضو في هذه الحالة باختلاف الأحوال:

أ- فإذا ترتب على خلو المنصب نقصان عدد الأعضاء الباقين عن الحد الأدنى الذي تطلبه القانون لصحة تشكيل المجلس، يجب دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في تعيين خلفاً لمن انتهت عضويته لأي سبب من الأسباب، وتوجه الدعوة في هذه الحالة من قبل الجهة الإدارية المختصة بناء على طلب أعضاء مجلس الإدارة الباقين.^(٢)

ب- أما إذا لم يترتب على خلو المنصب نقصان عدد الأعضاء عن الحد الأدنى المتطلب قانوناً، فيحل محل العضو الذي خلا منصبه العضو التالي له في عدد الأصوات في آخر انتخاب للمجلس، وتكون مدة العضو الجديد مكتملة لمدة سلفه، وفي غير هذه الأحوال يعين المجلس من يحل محله حتى أول انعقاد للجمعية العامة، ويتم تعيين من يحل محل عضو مجلس الإدارة الممثل بشخص معنوي بناء على ترشيح من يمثله، على أن يتم ذلك الترشيح خلال شهر من تاريخ خلو المنصب.^(٣)

ج- وفي حالة خلو منصب أكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة، وجب على من تبقى من أعضاء المجلس دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد فوراً لانتخاب من يحل محلهم، على أن يكون

تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط ذلك وإجراءاته.^(١)

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا انتهت مدة عضو مجلس الإدارة جاز تحديد عضويته لمدة أو لمدد أخرى، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك، ويعتبر تحديد العضوية بمثابة تعيين جديد تسري عليه كافة الأحكام والشروط التي تسري على التعيين لأول مرة، بما في ذلك إعادة حساب قيمة أسهم ضمان العضوية.^(٢)

وعلى كل شركة أن تعد سنوياً قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس وأعضاء المجلس وصفاتهم وجنسياتهم، وتحتفظ الشركة بصورة من القائمة، وترسل الأصل إلى الجهة الإدارية المختصة في أول يناير من كل سنة، كما يجب أن تخطر الشركة الجهة الإدارية بأي تغيير يطرأ على هذه القائمة.^(٣)

إشراك العاملين في الشركة في مجلس الإدارة:

وفقاً للمادة ٨٤ شركات، يكون للعاملين في شركة المساهمة التي تنشأ طبقاً للقانون نصيب في إدارة هذه الشركات. وقد قررت اللائحة التنفيذية للقانون عدة طرق لإشراك العاملين في إدارة الشركة، وذلك على النحو التالي:

إما النص في النظام الأساسي للشركة على أن يقوم العاملون في الشركة باختيار ممثلهم في مجلس الإدارة، وبشرط ألا يتجاوز عددهم ثلث أعضاء المجلس، أو بأن يكون اشتراك العاملين في مجلس الإدارة عن طريق تملكهم لأسهم العمل التي تكون مملوكة لجموع العاملين دون مقابل، ولا تدخل في تكوين رأس المال، ولا تكون لها قيمة اسمية وغير قابلة للتداول، ويتحقق ذلك بتكوين جمعية خاصة بالعاملين في الشركة تتمتع بالشخصية المعنوية، ويشارك فيها العاملون الذين مضى على خدمتهم بالشركة أكثر من سنة، وتختار هذه الجمعية ممثلين لها بالجمعية العامة وبمجلس الإدارة، وذلك في الحدود المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، وأخيراً قد يتحقق اشتراك العاملين في مجلس إدارة الشركة عن طريق لجنة إدارية معاونة، ويحضر رئيس اللجنة اجتماعات مجلس الإدارة ويكون له صوت محدود في المداولات.^(٤)

عضوية الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة:

يجوز تشريع الشركات أن يكون الشخص الاعتباري عضواً في مجلس إدارة شركة المساهمة، وعلى الشخص المعنوي-فور تعيينه عضواً بمجلس الإدارة- تحديد من يمثله في المجلس من الأشخاص الطبيعيين، وفي هذه الحالة يجب أن يتوفر في هؤلاء جميع الشروط الواجب توافرها في

أعضاء مجلس الإدارة.^(١)

ويتم تعيين ممثل الشخص الاعتباري لمدة عضوية من مثله، فإذا جددت عضوية الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة، وجب أن يعين مثله عن كل مدة تتجدد عضويته عنها، ولا يجوز للشخص الاعتباري أن يغير مثله من جلسة إلى أخرى إلا إذا رأى أن يستبدل به ممثلاً آخر، وحينئذ يتعين تحديد شخص الممثل الجديد وإخطار الشركة به^(٢)، على أنه يجوز للشخص الاعتباري في حالة وجود مانع لدى مثله أو غيابه أن ينوب عنه غيره في حضور الجلسة.^(٣) ويعين الشخص الاعتباري ممثله في الجمعية العامة للشركة، ولا يجوز أن ينوب ممثل الشخص الاعتباري بمجلس الإدارة عن هذا الشخص في حضور الجمعية العامة.^(٤)

الأعضاء الاحتياطيون بمجلس الإدارة:

وفقاً للمادة ٧٨ من قانون الشركات يجوز أن يتضمن نظام الشركة أوضاع تعيين أعضاء احتياطيين بمجلس الإدارة يحلون محل الأعضاء الأصليين في حالة الغياب أو قيام مانع من الموانع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وقد حددت اللائحة التنفيذية في المادة ٢٤٠ هذه الحالات بأنها تشمل حالات من يتغيب من الأعضاء الأصليين دون عذر يقبله المجلس، وذلك بغرض تفادي تعطيل أعمال المجلس في هذه الحالات.

توزيع الأعمال بين أعضاء المجلس:

يعين أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيساً للمجلس، ولا يكتمل تكوين مجلس الإدارة إلا إذا عين من بين أعضائه رئيساً، تكون مهمته الدعوة لانعقاده وترأس جلساته، ويجوز للمجلس أن يعهد إلى الرئيس بأعمال العضو المنتدب، كما يجوز للمجلس أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، ويكون التعيين لمدة لا تتجاوز مدة عضويتيها بالمجلس، ويجوز تجديد التعيين في هذين المنصبين.^(٥)

ويمثل الشركة أمام القضاء رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي بحسب النظام الأساسي للشركة، ويحدد نظام الشركة ولوائحها الداخلية الاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس المجلس والرئيس التنفيذي والأعضاء والموظفين.^(٦)

والأصل أن يقوم مجلس الإدارة بكامل هيئته بتصريف أمور الشركة، غير أن العمل جرى على انتداب عضو من المجلس لمباشرة شئون الشركة والإشراف على هيئاتها الإدارية، والقيام بالأعمال الجارية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة يسمى بـ "العضو المنتدب"، فوفقاً للمادة ٧٩ من قانون الشركات: "يجوز لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال

الشركة، كما يكون للمجلس ما يلي: (ب) أن يندب عضواً أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية، ويحدد المجلس اختصاص العضو المنتدب..، ويشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغاً للإدارة. كما يكون لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة من غير الأعضاء يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي بها، ويجوز أن يدعى لحضور جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت محدود، ويباشر المدير العام أعماله تحت إشراف العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة إذا كان يقوم بأعمال الإدارة الفعلية ويكون مسئولاً أمامه، وينظم العلاقة بين المدير العام وبين الشركة عقد العمل الذي عين بموجبه.^(١)

ومع مراعاة أحكام قانون العمل يجوز تنحية المدير العام في أي وقت بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة إن كان يتولى الإدارة الفعلية، وفي حالة وفاة أو تنحية أو استقالة العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة يستمر المدير العام في مباشرة عمله إلى أن يتم تعيين من يحل محل العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة.^(٢)

الفرع الثاني: شروط عضوية مجلس الإدارة

استلزم القانون توافر عدة شروط فيمن يعين عضواً في مجلس إدارة شركة المساهمة، وذلك ضمناً لنزاهته وكفاءته، وتتمثل تلك افلشروط فيما يلي:

١- **شروط النزاهة وحسن السمعة:** يشترط المشرع في عضو مجلس الإدارة ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس، أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.^(٣)

والحكمة من هذا الشرط تعود إلى توخي أن يتوافر في عضو مجلس الإدارة درجة من النزاهة وحسن السيرة في شخصه وتصرفاته، وغني عن البيان أنه يشترط أن يكون العضو كامل الأهلية حر الإرادة.^(٤)

٢- **شروط قبول العضوية في المجلس:** كما يشترط المشرع شرطاً شكلياً من الشروط البدئية، هو أن يقر كل عضو مجلس إدارة كتابة بقبوله التعيين، وأن يتضمن الإقرار سنه وجنسيته وأسماء الشركات التي زاول فيها أي عمل من قبل خلال السنوات الثلاث السابقة على التعيين، مع بيان نوع هذا العمل.^(٥) ويهدف هذا الشرط إلى التحقق من هذه البيانات من خلال مراجعة الإقرار

المقدم من العضو من جهة، وإلى بسط رقابة الدولة على الشركات التي تقوم بإدارة مرفق عام أو باستغلاله من جهة أخرى.^(١)

وبغرض الحصول على الموافقة على هذا التعيين، يجب إبلاغ قرارات الجمعية العامة أو مجلس الإدارة، الخاصة بهذا التعيين، إلى الوزير المختص بكتاب موصى عليه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور القرار إلى الوزير، ويعتبر فوات ثلاثين يوماً من تاريخ وصول التبليغ دون إبداء الاعتراض على التعيين بمثابة موافقة ضمنية عليه.^(٢)

٣- الشروط الخاصة بعدم استغلال عضو مجلس الإدارة لوظيفة عامة أو استغلال النفوذ:

أ- لا يجوز لأى شخص الجمع بين أى عمل فى الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدارة فى إحدى الشركات المساهمة سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر، إلا إذا كان ممثلاً لهذه الجهات. ومع ذلك يجوز الترخيص بالقيام بهذا العمل، بمقتضى إذن خاص من رئيس مجلس الوزراء، وبشرط ألا يترتب على ذلك توليه رئاسة مجلس الإدارة أو القيام بأعمال العضو المنتدب، وفى جميع الأحوال لا يصدر الإذن إلا بعد بحث الأمر و التأكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة أو التأثير فيها، وبشرط ألا يتعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.^(٣)

ب- لا يجوز- بغير إذن خاص من رئيس مجلس الوزراء - للوزير أو لأى من العاملين شاغلى وظائف الإدارة العليا، قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه الوزارة أو الوظيفة أن يعمل مديراً أو عضو مجلس إدارة أو أن يشتغل بصفة دائمة بأى عمل فى أو إدارى أو استشارى فى شركة من شركات المساهمة التى تكفل لها الحكومة مزايا خاصة عن طريق الإعانات أو الضمان، أو التى ترتبط مع الحكومة أو وحدات الحكم المحلى بعقد من عقود الاحتكار، أو عقد من عقود الأشغال العامة أو بعقد التزام مرفق عام أو بعقد استغلال مصدر من مصادر الثروة المعدنية أو الطبيعية. ويعتبر باطلا كل عمل يخالف حكم هذه المادة ، ويلزم المخالف بأن يؤدى المكافآت والمرتببات التى قبضها من الشركة لخزانة الدولة.^(٤)

ج- لا يجوز لعضو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أن يعين فى مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها، أو كان مالكاً لعشرة فى المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها قبل انتخابه. ويكون باطلاً كل عمل يخالف هذا الحكم، ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة.^(٥)

د- لا يجوز للعضو بأحد المجالس الشعبية المحلية بصفته الشخصية أو بوصفه نائباً عن الغير أن يعمل مديراً أو عضواً لمجلس إدارة أو أن يشتغل ولو بصفة عرضية بأى عمل أو استشارة فى شركة من شركات المساهمة التى تستغل أحد المرافق العامة الكائنة فى دائرة اختصاص المجلس الذى يكون عضواً فيه، أو التى ترتبط مع المجلس الشعبى أو المحلى بعقد من عقود الاحتكار، أو عقد من عقود الأشغال العامة. ويكون باطلاً كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة.^(١)

٤- الشروط الخاصة بتفرغ عضو مجلس الإدارة:

أ- مع عدم الإخلال بالاستثناءات المقررة لممثلى بنوك القطاع العام - لا يجوز لعضو مجلس إدارة بنك من البنوك التى تزاوّل نشاطها فى مصر أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر- أو شركة من شركات الائتمان التى يكون لها نشاط فى مصر - وكذلك القيام بأى عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة فى أيهما.^(١)، ويهدف هذا الحظر إلى الحيلولة دون تحقيق مصالح شخصية لبعض الأشخاص، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لنشاط البنوك، عن طريق سيطرتهم على مجالس إدارة أكثر من بنك وإضراراً بالمصلحة العامة أو مصلحة المساهمين.

ب- لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأى عمل فى أو إدارى بأية صورة كانت فى شركة مساهمة أخرى إلا بترخيص من الجمعية العامة للشركة التى يتولى عضوية مجلس إدارتها.^(١)

ج- لا يجوز أن يسند إلى عضو مجلس الإدارة خلال فترة عضويته أى وظيفة من وظائف الشركة أو أى عمل دائم أو مؤقت بها.^(١)

الفرع الثالث: اجتماعات مجلس الإدارة وسلطاته وواجباته

أولاً: اجتماعات مجلس الإدارة:

وفقاً للمادة ٨٠ من قانون الشركات-المعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه فى حالة خلو منصب الرئيس. ويجوز لثلث أعضاء المجلس أن يتقدموا بطلب كتابى لرئيس المجلس لعقد اجتماع له، فإذا تخلف رئيس المجلس عن دعوته فى خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، كان لهم دعوة المجلس إلى

اجتماع تخطر به الهيئة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه.

ويجوز عقد الاجتماع خارج المركز الرئيسي للشركة أو بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ومنها التوقيع الإلكتروني، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وذلك ما لم توجب اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي للشركة عقد اجتماع المجلس في المركز الرئيسي للشركة.

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة على عدد أكبر، ويجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم في حضور الجلسات، بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقة عليها من رئيس مجلس الإدارة^(١)، فإذا كان المجلس مكوناً من ثلاثة أشخاص فقط، فلا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثتهم جميعاً.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين ما لم يشترط نظام الشركة أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس^(٢)، ويجب أن تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في دفتر خاص يوقع عليه من الرئيس وأمين السر، ويسرى على هذا الدفتر الشروط والأوضاع الخاصة بدفاتر الجمعية العامة^(٣)، وذلك من حيث ضرورة تدوين أسماء من حضر ومن لم يحضر من أعضاء المجلس، وأعدار من لم يحضر...، وخلاصة وافية لجميع المناقشات، وكل ما يطلب الأعضاء إثباته في المحضر^(٤).

وغني عن البيان أن مخالفة الأحكام والشروط الواردة بنظام الشركة أو بالقانون بشأن صحة اجتماع مجلس الإدارة، يترتب عليها بطلان ما يصدر عن المجلس من قرارات، كما لو لم تراعى الاشتراطات الخاصة بالنصاب القانوني لصحة الاجتماع، أو صدور قرار دون توافر الأغلبية اللازمة، وفي هذه الحالة يكون لذوي الشأن أن يرفع دعوى بطلان قرار المجلس في حدود سنة من علمهم بالقرار المخالف، وفقاً للمادة ١٦١ من قانون الشركات.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافآت عن عملهم، فوفقاً للمادة ٨٨ من قانون الشركات: يبين نظام الشركة كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة في الأرباح بأكثر من ١٠٪ من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطي القانوني والنظامي، وتوزيع ربح لا يقل عن ٥ ٪ من رأس المال على المساهمين

والعاملين، ما لم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى. وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة و بدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس، واستثناء من ذلك يكون تحديد مكافآت ومرتببات وبدلات العضو المنتدب بقرار من مجلس الإدارة.

ثانياً: سلطات مجلس الإدارة:

لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها (م ١/٥٤ شركات)، ومن ثم فللمجلس أن يقوم بجميع الأعمال التي يقتضيها غرض الشركة سواء أكانت من أعمال الإدارة أو التصرف، باستثناء ما قرره القانون أو نظام الشركة من أعمال وتصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة، والأصل أن يقوم مجلس الإدارة بعمله تحت إشراف ورقابة الجمعية العامة صاحبة الاختصاص الأصيل، غير أنه إزاء الضعف الذي أصاب الجمعية العامة، فقد استأثر مجلس الإدارة بالسلطة الفعلية في إدارة الشركة.^(١)

وعلى هذا فلا يجوز لمجلس الإدارة أن يقوم بأي من التصرفات أو الأعمال التي تخرج عن نطاق غرض الشركة، أو يفتتت على الجمعية العامة في اختصاصاتها، فلا يملك المجلس تعديل النظام الأساسي للشركة، أو اتخاذ قرار بإنهائها، ويقع عليه واجب تنفيذ قرارات الجمعية العامة للمساهمين.

ووفقاً للمادة ٦٤ شركات (المعدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨) على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية- في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين- خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها، القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.

كما يجب على مجلس الإدارة أن ينشر القوائم المالية وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة، ويجوز إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك الاكتفاء بإرسال نسخة من هذه الأوراق إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه، أو بأي طريقة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية ومواعيد إرسالها.^(٢)

كما لا يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يتبرع بأموال الشركة في سنة مالية أى تبرع من أى نوع إلى حزب سياسى وإلا كان التبرع باطلاً. ولا يجوز أن يتبرع من أموال الشركة في سنة مالية بما يجاوز ٧٪ من متوسط صافي أرباحها خلال السنوات الخمس السابقة على هذه السنة، إلا أن يكون التبرع للأغراض الاجتماعية الخاصة بالعاملين أو لجهة حكومية أو إحدى الهيئات العامة.

ويشترط لصحة التبرع على أى حال صدور قرار من مجلس الإدارة بناء على ترخيص عام من الجمعية العامة متى جاوزت قيمته ألف جنيه.^(١)

التزام الشركة بأعمال وتصرفات مجلس الإدارة:

قدمنا أن لمجلس إدارة شركة المساهمة سلطة إجراء التصرفات القانونية نيابة عن الشركة، وذلك في حدود أحكام القانون ونظام الشركة ولوائحها الداخلية. وعلى هذا تلتزم الشركة بجميع تصرفات وأعمال مجلس الإدارة، طالما تمت ممارستها لحساب الشركة، وكانت في إطار اختصاصات المجلس المحددة قانوناً، ولا يلتزم أعضاء المجلس بهذه التصرفات بصفة شخصية، لأنهم وكلاء عن الشركة فأعمالهم تلزم الموكل.

فإذا ما قام مجلس إدارة الشركة بأعمال أو تصرفات تخرج عن حدود أغراض الشركة أو تتجاوز اختصاصات المجلس المحددة في القانون أو في نظام الشركة، فلا ريب أن أعضاء المجلس يتحملون مسؤولية هذه التصرفات في مواجهة الشركة، ولكن هل تلتزم الشركة بهذه التصرفات أمام الغير؟

المقرر في هذا الشأن أن الشركة تلتزم أيضاً أمام الغير بجميع تصرفات وأعمال مجلس الإدارة في هذه الحالات، وذلك حماية للغير حسن النية الذي ينخدع بالوضع الظاهر، أو لم يتبين له خروج هذه الأعمال أو التصرفات عن حدود غرض الشركة أو صلاحيات مجلس الإدارة أو مخالفتها لقاعدة قانونية آمرة، وهذا ما قرره المادة ٥٥ من قانون الشركات بقولها: "يعتبر ملزماً للشركة أى عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضائه في الإدارة، أثناء ممارسته لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد، ويكون للغير حسن النية أن يحتج بذلك في مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادراً بالتجاوز لسلطة مصدره أو لم تتبع بشأنه الإجراءات المقررة قانوناً. وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركة أن تدفع مسؤوليتها عن أية أعمال أو أوجه نشاط تمارسها بالفعل بأن نظام الشركة لم يصرح لها بالقيام بمثل تلك الأعمال أو أوجه النشاط.

أما إذا قام بالتصرف أحد موظفي الشركة أو الوكلاء عنها، فلا يعتبر هذا التصرف ملزماً للشركة، ما لم يكن مرخصاً به صراحة أو ضمناً من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو من يفوضه من أعضائه في الإدارة بحسب الأحوال. ومع ذلك يكون للغير حسن النية أن يتمسك في مواجهة الشركة بأى تصرف يجريه أحد موظفي الشركة أو وكلائها، إذا قدمته إحدى الجهات

المشار إليها على أنه يملك سلطة التصرف نيابة عنها، واعتمد الغير على ذلك في تعامله مع الشركة.^(١)

ولا يجوز للشركة أن تتمسك في مواجهة الغير حسن النية من المتعاملين معها بأن نصوص عقد الشركة أو لوائحها لم تتبع بشأن التصرف. كما لا يجوز لها أن تحتج بأن مجلس إدارتها أو بعض أعضائه أو مديري الشركة أو غيرهم من الموظفين أو الوكلاء لم يتم تعيينهم على الوجه الذى يتطلبه القانون أو نظام الشركة، طالما كانت تصرفاتهم في حدود المعتاد بالنسبة لمن كان في مثل وضعهم في الشركات التي تمارس نوع النشاط الذى تقوم به الشركة.^(٢)

وكما أسلفنا، فلكي يتمتع الغير بالحماية التي قررها القانون، يتعين أن يكون حسن النية، ولا يعتبر حسن النية في حكم القانون- من يعلم بالفعل أو كان في مقدوره أن يعلم، بحسب موقعه بالشركة أو علاقته بها، بوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة. ولا يعتبر الشخص عالماً بمحتويات أية وثيقة أو عقد، لمجرد نشرها أو شهرها بإحدى الوسائل المنصوص عليها في هذا القانون.^(٣)

هذا وإذا كانت الأحكام التي تضمنها قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، من شأنها الحفاظ على استقرار التعامل وحماية الأوضاع الظاهرة، فإنه-وكما يرى بعض الفقهاء بحق- فإنها قد تفتح الباب على مصراعيه أمام قيام الغير بالتحليل، في الوقت الذي يصعب فيه إثبات سوء نيته، فضلاً عما تنطوي عليه من إهدار للقيمة القانونية للإشهار، وهو أمر لا يمكن تبريره بمجرد القول بحماية الغير حسن النية، خاصة مع الوضع في الاعتبار أن الحماية جاءت في صورة واسعة وفضفاضة بحيث يستطيع أن يلتفت عليها حسن النية وسيئها على حد سواء.^(٤)

ثالثاً: واجبات أعضاء مجلس الإدارة:

بغرض حماية مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين، ومن أجل النأي بأعضاء مجلس الإدارة عن بعض الأعمال والتصرفات التي تنطوي على الشبهات، فقد فرض المشرع بعض الواجبات على أعضاء مجلس الإدارة، نوجزها فيما يلي:

١- لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أى نوع كان، لأى من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أى قرض يعقده أحدهم مع الغير.^(٥)

ويستثنى من ذلك شركات الائتمان، فيجوز لها أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو تفتح له اعتماداً أو تضمن له القروض التي يعقدها مع الغير. على أن يكون ذلك في نطاق مزاوله

الأعمال الداخلة ضمن غرضها وبنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة بالنسبة لجمهور العملاء.^(١)

ولا يعتبر هذا الحكم، في نظرنا، استثناءً من حظر إقراض شركة المساهمة لعضو مجلس إدارتها أو ضمانه، ذلك أن شركات الائتمان عندما تقوم بهذه الأعمال، إنما تطبق الشروط والأوضاع التي تلتزم باتباعها عند إقراض أو ضمان قروض أي من عملائها بصفة عامة.^(٢) ويلزم المشرع الشركة أن تضع تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة أيام على الأقل بياناً من مراقبي الحسابات، يقررون فيه أن القروض أو الاعتمادات أو الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد تمت دون إخلال بأحكامها. ويعتبر باطلاً كل عقد يتم على خلاف هذه الأحكام، دون إخلال بحق الشركة في مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء.^(٣)

٢- يلتزم كل عضو في مجلس إدارة الشركة، وكل مدير من مديريها، تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة، في عملية تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها، أن يبلغ المجلس بذلك، وأن يثبت إبلاغه في محضر الجلسة. ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية. وعلى مجلس الإدارة إبلاغ أول جمعية عامة بهذه العمليات قبل التصويت على القرارات.^(٤)

٣- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة لشركة المساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاوها الشركة، بغير ترخيص مسبق وخاص من الجمعية العامة. وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هي.^(٥)

ويسهل تبرير هذا الحظر، ذلك أن عضو مجلس الإدارة وهو من تقع عليه مسؤولية المحافظة على مصالح الشركة وتحقيق أهدافها، يتمتع عليه، والحال هكذا، أن ينافس الشركة في أعمالها، فيقع تحت تهمة تقديم مصلحته الشخصية على مصلحة الشركة.

٤- وفقاً للفقرة الثانية من المادة ٩٨ من قانون الشركات، المضافة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨: "لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة استغلال أو إفشاء ما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب اشتراكهم في إدارتها بما يضر بمركز الشركة المالي وأنشطتها التجارية".

وتقضي الفقرة الثالثة من المادة السابقة بأنه: "مع عدم الإخلال بمسئولية من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية من أعضاء مجلس الإدارة عن التعويض، يجوز لمجلس الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة العامة لسوق المال وموافقة جميع الأعضاء، فيما عدا العضو المخالف، إيقاف عضويته ابتداء من تاريخ ثبوت المخالفة في حقه وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التالية، للتصويت على استمرار عضويته".

٥- يتمتع على أى عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة فى أى وقت، أن يكون طرفاً فى أى عقد من عقود المعاوضة التى تعرض على هذا المجلس لإقرارها، إلا إذا رخصت الجمعية العامة مقدماً بإجراء هذا التصرف، ويعتبر باطلاً كل عقد يبرم على خلاف هذا الحكم.^(١)

٥- وفقاً للمادة (٢٠١/١٠٠) من قانون الشركات: يحظر على عضو مجلس الإدارة أو أحد المديرين، أن يبرم عقداً من عقود المعاوضة مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو أحد هؤلاء المديرين فى مجلس إدارتها أو فى إدارتها، أو يكون لمساهمي الشركة أغلبية رأس المال فيها، إذا كان هذا العقد مما يلحقه البطلان، فإذا أبرم هذا العقد كان باطلاً، ويقع البطلان فى هذه الحالة إذا كانت نسبة الغبن فيه تتجاوز خمس القيمة وقت التعاقد، دون إخلال بحق الشركة وحق كل ذى شأن فى مطالبة المخالف بالتعويض.^(٢)

وتقضي الفقرة الثالثة من المادة (١٠٠) شركات، المذكورة، بأنه: "ومع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٧٦) من هذا القانون، يجوز إبطال عقود المعاوضة التي يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها، ويجوز لمساهمي الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أي أضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود، وطلب رد المكاسب التي حققها المستفيدون". والحكمة من هذا الحظر وما يترتب من بطلان العقود التي تتم بالمخالفة له، في مثل هذه الحالات التي يكون فيها عضو مجلس إدارة إحدى الشركات مرتبطاً بعمل في شركة أخرى، تعود إلى دفع مظنة تفضيل مصلحة إحدى الشركتين على الأخرى.

الفرع الرابع

مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم

الفصل الأول: مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة:

قدمنا أن مجلس إدارة الشركة يملك أوسع السلطات في تسيير أمور الشركة وتحقيق أهدافها، وأنهم يحصلون على أجر مقابل هذا العمل، ومن ثم فعليهم أن يبذلوا العناية الواجبة لتنفيذ مهامهم، وإذا كانت القاعدة أن أعضاء مجلس الإدارة لا يسألون عن الأضرار التي تصيب الشركة أو المساهمين أو الغير، طالما أن هذه الأضرار لا يمكن نسبتها إلى خطأ ارتكبه أعضاء مجلس الإدارة، فإن الرأي مستقر على انعقاد مسئوليتهم عن هذه الأضرار إذا ثبت في جانبهم ثم خطأ. وهذه المسؤولية قد تكون مسئولية جنائية، متى كانت الأفعال التي وقعت منهم تشكل جرائم معاقب عليها جنائياً، وقد تكون المسؤولية مدنية، تنشأ عن الخطأ الذي يرتكبه أعضاء مجلس الإدارة، متى كان يخرج عن عداد الأفعال المجرمة وفق أحكام القانون، وسبب ضرراً لأحد من الأغيار، وسوف نعرض أولاً لأحكام المسؤولية المدنية، ثم نتبعها بتناول قواعد المسؤولية الجنائية.

أولاً: المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة:

يسأل أعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع الأخطاء التي يرتكبونها أثناء وبمناسبة إدارة الشركة، فضلاً عن أعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة، سواء كان ذلك نتيجة مخالفتهم أحكام القانون أو ما يقضي به النظام الأساسي للشركة، أو إساءة تدبير أمور الشركة نتيجة الإهمال أو سوء التصرف وعدم الاحتراز، كما لو غامروا بأموال الشركة في مضاربات غير مأمونة العواقب دون اتباع القواعد والحسابات التجارية والاقتصادية، أو منافسة الشركة منافسة غير مشروعة أو الاقتراض باسم الشركة دون ضمانات كافية فتزب علي أي من ذلك الإضرار بمصلحة الشركة.

والمسئولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة مسئولية تضامنية متى نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم، استناداً إلى مبدأ "وحدة السلطة" الذي يحكم عمل مجلس الإدارة^(١)، وكل شرط يقضي بخلاف ذلك يعتبر باطلاً، وهذا ما قرره ١٦١ من قانون الشركات (المعدلة بالقانون ٤ لسنة ٢٠١٨) التي تقضي بأنه: "مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يقع باطلاً

كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد الآمرة في هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارات شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكّلة على خلاف أحكامه، وذلك بما لا يخل بحق الغير حسن النية..، وفي حالة تعدد من يرجع إليهم سبب البطلان يكونون مسئولين عن التعويض بالتضامن فيما بينهم.

أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل عنها المعارضون إذا أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع، ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية، إلا إذا ثبت عدم علم عضو مجلس الإدارة الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به، وذلك حتى لا يعد الإعفاء من المسؤولية في هذه الحالة دافعاً إلى تشجيع الروح السلبية بين أعضاء المجلس، واتخاذهم من الغياب سبيلاً لتفادي المسؤولية التي قد تنعقد في حالة المشاركة.

دعوى المسؤولية:

دعوى المسؤولية هي الأداة القانونية لحماية الشركة أو المساهمين أو الغير ممن أصابهم ضرر من أفعال أو تصرفات مجلس إدارة الشركة، ولا ترفع الدعوى إلا ممن أصابه الضرر. وعلى هذا فهناك ثلاثة أنواع من الدعاوى: الدعوى التي ترفع باسم الشركة، ودعوى المساهم الفردية، والدعوى التي ترفع من الغير.

أ- دعوى الشركة:

يطلق اصطلاح دعوى الشركة على الدعوى التي ترفعها الشركة كشخص معنوي لضرر أصابها من أخطاء ارتكبتها مجلس الإدارة، وقيل في تكييف هذه الدعوى أنها دعوى تقوم على أساس مسئولية تعاقدية، حيث يعد مجلس الإدارة نائباً أو وكيلاً عن الشركة، وقيل أنها مسئولية قانونية، لأن القانون هو الذي نص عليها، والواقع أنه ليس هناك أهمية كبيرة لهذا الخلاف، فالأهم في هذا الصدد هو إثبات الخطأ المرتكب من مجلس الإدارة والأضرار التي أصابت الشركة وعلاقة السببية بينهما، وذلك وصولاً لإقرار حق الشركة في التعويض عما أصابها من أضرار.^(١)

والممثل القانوني للشركة هو رئيس مجلس الإدارة وقت رفع الدعوى، بناء على قرار من الجمعية العامة العادية بتحديد من تنتدبه لمباشرة هذه الدعوى باسمها، فإذا كان رئيس المجلس ممن تشملهم دعوى المسؤولية، فيمكن تعيين عضو آخر في مجلس الإدارة لمباشرتها، فإذا شملت

الدعوى كافة أعضاء المجلس، فيتم تحريك الدعوى من قبل رئيس مجلس الإدارة الجديد أو من يليه، وإلا فعلى الجمعية العامة تعيين من يباشر الدعوى نيابة عنها.^(١)

ورغبة في حماية المساهمين والغير نصت المادة ١٠٢ من قانون الشركات على أنه: "لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم". ذلك أن الجمعية العامة قد تقرر في اجتماعها السنوي، لدي سماعها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات، إبراء ذمة مجلس الإدارة، ثم يتضح بعد ذلك وقوع غش أو إساءة استعمال السلطة، ومن ثم فلا تعتبر مصادقة الجمعية العامة على التقارير أو الميزانية السنوية بمثابة إعفاء عن الأخطاء التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة.

غير أنه، ومن جهة أخرى، فإن المشرع قد وضع حداً للمدة التي يمكن أن تقام فيها دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، فقضى بأنه: "إذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات، فإن هذه الدعوى تسقط بمضى سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جنائية أو جنحة فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى العمومية".^(٢)

ب- دعوى الشركة التي ترفع من مساهم أو مجموعة من المساهمين:

دعوى الشركة تمارس، ليس فقط من ممثليها القانوني، وإنما أيضاً بواسطة مساهم أو بعض المساهمين باسم الشركة، ولجهة الإدارة المختصة مباشرة هذه الدعوى، وتسمى بدعوى الشركة التي تمارس بصفة شخصية، ويحدث ذلك في حالة إحجام الجمعية العامة للشركة أو تقاعسها عن تحريك الدعوى إهمالاً أو مجاملة لمجلس الإدارة، فكل مساهم وحده يستطيع رفع دعوى الشركة أياً كانت نسبة مساهمته في رأس مال الشركة، ويقع باطلاً كل شرط في نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة، أو على اتخاذ أى إجراء آخر.^(٣)

وعلى هذا فكل ما يشترط لرفع هذه الدعوى، هو أن يحمل المدعي صفة المساهم وقت رفع الدعوى وطوال فترة التقاضي، كما أنها، بوصفها دعوى جماعية تمارس باسم الشركة، يجب أن يكون حق الجمعية العامة في رفعها ما زال قائماً، فإذا انقضى هذا الحق مثلاً بمصادقة الجمعية

العامة على تقارير مجلس الإدارة وانقضت مدة سنة من تاريخ هذا التصديق وفقدت الجمعية العامة من ثم حق رفع الدعوى، سقط بالتبعية حق المساهم في رفعها. وما يحكم به من تعويضات في هذه الدعوى يلحق بذمة الشركة مباشرة كشخص معنوي، فيما لا يحصل من رفع الدعوى سوى على نصيبه من تلك التعويضات، علاوة على نفقات ورسوم رفع الدعوى.^(١)

ج-دعوى المساهم الفردية:

إذا اقتصر الضرر الذي سببه خطأ أعضاء مجلس الإدارة، على أحد المساهمين أو بعضهم، دون أن يمتد أثره إلى الشركة كشخص معنوي، فيقوم الحق لهذا المساهم في رفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس وفقاً للقواعد العامة^(٢)، كما لو حرم أحد المساهمين من نصيبه في الأرباح أو من الاشتراك في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، أو لم ترد لهم حصصهم بعد انقضاء الشركة بقرار من مجلس الإدارة، ففي هذه الحالة يحق للشريك أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر.

وأساس هذه الدعوى المسؤولية التقصيرية التي تركز على الفعل الضار، والتي يشترط لقيامها إثبات خطأ مجلس الإدارة أو أحد أعضائه والضرر وعلاقة السببية بينهما، فهي لا تستند إلى رابطة عقدية تربط بين المساهم ومجلس الإدارة، وللمساهم أن يتصالح عنها مع المتسبب في الضرر، باعتبار طلب التعويض عن الأضرار الشخصية التي أصابته حقاً خالصاً له.^(٣)

ولا ارتباط بين هذه الدعوى الفردية للمساهم ودعوى الشركة كشخص معنوي، ولا تتوقف إحداها على الأخرى، فإذا انقضت دعوى الشركة، بمصادقة الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة أو بإجازة تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو إبراء المجلس منها ومروور سنة على ذلك، فيبقى حق المساهم قائماً في المطالبة بجبر الضرر الذي أصابه، ولا يتوقف حق المساهم في تحريك هذه الدعوى على إذن من الجمعية العامة، ويختص المساهم وحده دون الشركة بما يحكم به من تعويض في هذه الدعوى، ويمكن في حال تسببت الأخطاء في أضرار لعدة مساهمين، أن يقوموا بتوكيل أحدهم في رفع دعوى المسؤولية الشخصية.^(٤)

د-دعوى الغير:

قد يترتب على خطأ أعضاء مجلس الإدارة إلحاق الضرر بالغير، وذلك كما لو قام أعضاء المجلس بالتوقيع على صكوك أسهم مزورة دون التحقق من صحتها، أو إخفاء جزء من أموال الشركة أو توزيع أرباح صورية على المساهمين، فيكون للغير المطالبة بتعويض الأضرار التي أصابته، وللغير في هذه الحالة، فضلاً عن دعوى المسؤولية التقصيرية ضد أعضاء مجلس الإدارة، أن يرفع دعوى في مواجهة الشركة بسبب مسئوليتها الشخصية عما يقع من مجلس الإدارة من أخطاء، باعتبار مجلس الإدارة جزءاً من نسيج الشركة وعضواً من أعضائها أو كوكيل عنها، وفي هذه الحالة يكون للشركة أن تعود على عضو مجلس الإدارة المتسبب بالخطأ.^(١)

ولا تتأثر دعوى الغير في هذه الحالات بما يرد في نظام الشركة أو بقرارات الجمعية العامة، وتتقدم وفقاً للقواعد العامة، فضلاً عن استئثار رافعها بنتيجة الحكم فيها.

ثانياً: المسؤولية الجنائية لأعضاء مجلس الإدارة:

يتعرض أعضاء مجلس الإدارة للمسؤولية الجنائية إذا ما وقعت منهم أفعال تندرج تحت طائلة نصوص جنائية، سواء ورد النص عليها في قانون العقوبات، كارتكابهم أفعالاً تشكل جريمة نصب أو خيانة أمانة أو تزوير، أو نص عليها في قانون الشركات ذاته، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة ١٦١ شركات، من معاقبة كل عضو مجلس إدارة وزع أرباحاً أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه-يتحملها المخالف شخصياً-أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومن ذلك أيضاً المادة ٣/١٦٣ شركات التي تعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً: كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التي تخصص لضمان إدارته على الوجه المقرر في هذا القانون في مدى سنتين يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين، وكذلك كل من تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها، أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمداً بياناً من البيانات التي يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها، وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت في تقارير الشركة بيانات غير صحيحة، أو أغفل عمداً بياناتها.

وفي حالة العود أو الامتناع عن إزالة المخالفة التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حديها الأدنى والأقصى.^(١)

الفصل الثاني: عزل أعضاء مجلس الإدارة:

لما كان أعضاء مجلس الإدارة وكلاء عن الجمعية العامة للمساهمين في تسيير أمور الشركة، فيجوز كقاعدة عامة أن تقرر الجمعية العامة في أي وقت عزلهم^(٢)، إذا كان في ذلك مصلحة الشركة، وهو حق يتعلق بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز النص في نظام الشركة على عدم جواز عزل مجلس الإدارة، وللجمعية العامة عزل جميع أعضاء المجلس دفعة واحدة، كما أن لها أن تعزل واحداً أو أكثر من هؤلاء الأعضاء ولو كانوا معينين في نظام الشركة، كما هو الشأن بالنسبة لأعضاء أول مجلس إدارة، ولو لم يكن موضوع العزل وارداً في جدول الأعمال، ولعضو مجلس الإدارة المعزول الحق في المطالبة بالتعويض إذا كان قرار العزل بغير مسوغ يبرره.^(٣)

كذلك يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يعتزلوا العمل في عضوية المجلس، بشرط اختيار الوقت المناسب والإخطار المسبق، وإلا التزموا بتعويض الشركة عما أصابها من ضرر نتيجة لذلك، وذلك تطبيقاً للقواعد العامة^(٤)، وفي كافة الأحوال فإن عزل مجلس الإدارة أو اعتزاله العمل لا يحتاج به تجاه الغير إلا إذا جرى إشهاره وفقاً لأحكام القانون.^(٥)

المطلب الثاني

الجمعية العامة للمساهمين

تعتبر الجمعية العامة للمساهمين بمثابة برلمان الشركة حيث يجتمع فيها المساهمون للتداول في أمور الشركة واتخاذ القرارات الهامة والرقابة على أعمال مجلس الإدارة، وبالرغم من الوهن الذي أصاب الجمعية، بسبب كثرة المساهمين وقلة خبرتهم وانصرافهم عن حضور اجتماعاتها أو القيام بدورهم الرقابي على أعمال مجلس الإدارة واكتفاءهم بالمضاربة على أسهم الشركة دون تعاون إيجابي منهم لتحقيق أغراض الشركة، إلا أن الجمعية العامة تظل، ولو نظرياً على الأقل، هي الجهة صاحبة السيادة في الشركة ومصدر السلطات فيها.

وقد جرى العمل على تقسيم الجمعية العامة تبعاً لاختصاص كل نوع منها إلى ثلاثة أنواع: الجمعية التأسيسية: وهي التي يناط بها مراقبة عملية التأسيس والموافقة على تقويم الحصص العينية

وعلى النظام الأساسي للشركة واختيار أول مجلس للإدارة وأول مراقب للحسابات، والجمعية العامة العادية: وهي المختصة بالأساس بالرقابة على أعمال الإدارة، ثم الجمعية العامة غير العادية: وهي التي يعهد إليها تعديل النظام الأساسي للشركة واتخاذ القرارات المصيرية المؤثرة على كيان الشركة.

وحيث قد سبق لنا دراسة الجمعية التأسيسية، فإننا نعرض هنا للجمعية العامة العادية وغير العادية، فنوضح الأحكام المشتركة لكلا النوعين، ثم للأحكام الخاصة بكل منهما.

الفرع الأول

الأحكام المشتركة بين الجمعية العادية وغير العادية

أولاً: انعقاد الجمعية العامة:

تتعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان الذين يعينهما نظام الشركة، ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقل في السنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.^(١)

وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات، أو عدد من المساهمين يمثل ٥ ٪ من رأس مال الشركة على الأقل بالنسبة للجمعية العامة العادية و ١٠ ٪ بالنسبة للجمعية العامة غير العادية، بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية.^(٢)

ولا محل لتطلب الإيداع المشار إليه بعد صدور قانون الإيداع والقيود المركزي رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ - على ما سلف التوضيح - .

وقد قصد المشرع من إعطاء هذا الحق لهذه النسبة من المساهمين، الاهتمام بحقوق الأقلية وتحقيق التوازن بين هؤلاء وبين من يملكون غالبية رأس المال ويتحكمون من ثم في مصير الشركة. ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة^(٣) أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد في الأحوال التي يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة، على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع. كما يكون للجهة

الإدارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده. أو امتنع الأعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.^(١)

وتتم الدعوة لاجتماع الجمعية بإخطار يجب نشره مرتين في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية، على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول، وقبل موعد الاجتماع الأول بخمسة عشر يوماً..، ويجوز الدعوة إلى اجتماع ثان في نفس الدعوة إلى الاجتماع الأول بشرط أن يكون الاجتماع عادياً وأن يتضمن نظام الشركة ما يسمح بذلك.^(٢)

وقد كانت الفقرة الأولى من المادة ٢٠٣ من لائحة قانون الشركات تنص على وجوب إرسال الإخطار بالدعوة إلى عناوين المساهمين الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد العادي، وقد تم حذف هذا النص بمقتضى قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٢٥٦ لسنة ٢٠١٨، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ونص القرار على أن يستبدل بنص المادة ٢٠٣ / فقرة أولى النص التالى: "يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول".

وقد جاء هذا القرار للتسهيل على الشركات وضمان انعقاد جمعياتها العامة، لأن بعض الشركات يصل عدد المساهمين فيها إلى الآلاف، الأمر الذي يشكل عائقاً في تأخير انعقاد الجمعية العامة بسبب التأخير في وصول الإخطار بالدعوة للمساهمين بها، الأمر الذي يمثل نقلة إجرائية نوعية تساهم في التيسير على الشركات.

وتتضمن الدعوة إلى الاجتماع ملخصاً واضحاً لجدول الأعمال، حتى يتمكن المساهم من دراسة الموضوعات التي ستكون محلاً للمناقشة، كما يتضمن إخطار الدعوة تاريخ وساعة ومكان انعقاد الاجتماع الثاني في حالة عدم توافر النصاب^(٣)، وتخطر الهيئة العامة لسوق المال والإدارة العامة للشركات ومراقب الحسابات والممثل القانوني لجماعة حملة السندات بصورة من البيانات التي ترسلها الشركة للمساهمين لحضور الجمعية العامة، كما يجب على الشركة إرسال صورة من

القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة للجهات السابق ذكرها^(١)، وتكون مصروفات النشر والإخطار على نفقة الشركة.

ويترتب على نشر الإخطار حظر قيد أي تصرف في سجلات الشركة حتى ينفذ اجتماع الجمعية^(٢)، وفي حالة عدم مراعاة الإجراءات السابقة يبطل اجتماع الجمعية العامة وما يصدر عنه من قرارات.

نظام حضور الجلسات:

يعتبر حضور جلسات الجمعية العامة والاشتراك في جلساتها والتصويت على قراراتها من الحقوق الأساسية لكل مساهم، سواء كان من أصحاب الأسهم الإسمية أو لحاملها، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في حضور اجتماع الجمعية العامة، بشرط أن يكون الوكيل أحد المساهمين في الشركة، وألا يكون الوكيل عضواً في مجلس إدارة الشركة إذا كان الموكل من غير أعضاء المجلس، وذلك لئلا يتخذ أعضاء مجلس الإدارة هذه الإنابة وسيلة لشراء أصوات المساهمين والحيلولة دون ممارسة حقهم في مراقبة أعمال مجلس الإدارة، كما يشترط أن تكون الوكالة ثابتة في صك كتابي، ويجوز أن يتم التوكيل بغرض حضور اجتماع أو أكثر من اجتماعات الجمعية العامة.

هذا ولم يتطلب قانون الشركات حيابة المساهم لعدد معين من الأسهم لكي يتسنى له حضور الجمعية العامة، ومن ثم يكون لكل مساهم حضور الاجتماع أياً عدد الأسهم التي يحوزها، غير أنه إذا تضمن نظام الشركة شرطاً يتطلب توفر نصاب معين من الأسهم لإمكانية اشتراك المساهم في الجمعية العامة، فهناك رأي في الفقه يذهب إلى صحة مثل هذا الشرط، لأنه شرط يتعلق بتنظيم حق حضور جلسات الجمعية العامة ولا يترتب عليه حرمان المساهم من ممارسة هذا الحق، إذ يستطيع أن يأتلف مع غيره من صغار المساهمين لتوفير النصاب المطلوب، ثم اختيار واحد منهم لتمثيلهم في اجتماعات الجمعية العامة^(٣)، غير أننا لا شك لدينا في عدم صحة هذا الشرط، لأن حضور اجتماعات الجمعية العامة يعتبر من النظام العام، إذ أنه يعد الوسيلة الأساسية للمساهمين في ممارسة حقهم في إدارة الشركة ورقابتها، والذي يترجم في الحقيقة في مجرد الحق في التصويت.

كما يجوز أن ينص نظام الشركة على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم في الجمعية العامة، سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن الغير.

ويثبت حضور المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة في سجل تدرج فيه البيانات الخاصة باسم المساهم ومحل إقامته وعدد الأسهم التي يحوها وعدد الأصوات التي تحولها له...، ويلزم كل من مراقبي الحسابات وجامعي الأصوات بالتوقيع على السجل قبل بداية الاجتماع.^(١)

ولمصلحة الشركات وللهيئة العامة لسوق المال وللهيئة العامة للاستثمار إيفاد مندوب لحضور الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة المساهمة، ولا يجوز لهما الإدلاء برأيهما في الجلسة، وإنما لإبداء ملاحظتهما وإخطار الشركة بما إذا كان هناك مخالفات قانونية خلال عشرة أيام على الأكثر من انعقاد الجمعية العامة، وللشركة أن ترد على هذه الملاحظات^(٢)، كما يكون للممثل القانوني لجماعة حملة السندات حضور الاجتماع وإبداء ملاحظاته، دون أن يكون له صوت معدود.^(٣)

كما يلزم تشريع الشركات مجلس الإدارة بأن يكون ممثلاً في اجتماعات الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته، (وهو ثلاثة أعضاء وفقاً للمادة ٣/٧٧ شركات)، وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك، ولا يجوز التخلف عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.^(٤)

وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتخبين للإدارة، وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية. فإذا كان نصاب اجتماع المساهمين قانونياً، ولم يتوافر نصاب مجلس الإدارة في الاجتماع، جاز للجمعية في هذه الحالة النظر في توقيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يحضروا بغير عذر مقبول، فإذا تكرر غيابهم جاز للجمعية أن تنظر في عزلهم وانتخاب غيرهم ثم تدعى الجمعية لاجتماع آخر. وتنظم الإجراءات المتعلقة بحضور المساهمين الجمعية العامة في اللائحة التنفيذية.^(٥)

ويرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس الجهة التي دعت للاجتماع أو رئيس الهيئة العامة لسوق المال، ويحدد نظام الشركة من تكون له الرئاسة عند غياب رئيس الجمعية، وإلا تنتخب الجمعية رئيساً للاجتماع من بين الحاضرين^(٦)، ويقوم رئيس الجمعية بتعيين أمين سر الجمعية وجامعي الأصوات ويعتمد ذلك من الجمعية العامة، ويطلب الرئيس من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات تعيين نسبة حضور المساهمين.^(٧)

جدول أعمال الاجتماع:

إذا اكتمل النصاب القانوني لصحة الاجتماع، فالأصل أنه لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، وإذا حددت المسائل المدرجة في جدول الأعمال فلا يجوز تغييرها بالحذف أو الإضافة حتى ولو تم تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر بسبب عدم اكتمال النصاب. وذلك حتى لا يفاجأ المساهمون بمسائل لم يعلنوا سلفاً بها، ومن ثم لا يتوفر لهم الاستعداد الكافي لممارسة حقهم في مراقبة أعمال الإدارة بشأنها.^(١)

ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع. وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة، ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.^(٢)

وتحدد الجهة التي تدعو لاجتماع الجمعية العامة مواد جدول أعمالها، ومع ذلك يجوز للمساهمين الذين يمتلكون ٥ % على الأقل من أسهم الشركة أن يطلبوا إدراج بعض المسائل في جدول أعمال الجمعية العامة العادية، وذلك بكتاب مسجل يوجه إلى مجلس إدارة الشركة أو تسليمه في مقر مجلس الإدارة مقابل إيصال، على أن يوضح في الطلب القرار المطلوب إصداره من الجمعية وأسبابه، ويرفقوا به ما يفيد إيداع أسهمهم بمركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، ويجب أن يقدم الطلب قبل الموعد المقرر للإنعقاد الأول للجمعية بعشرة أيام على الأقل، ويجب أن تضاف مشروعات القرارات المطلوب إصدارها إلى جدول الأعمال وتطرح للتصويت عليها بالجمعية.^(٣)

حق التصويت على القرارات:

يعتبر التصويت على قرارات الجمعية من الحقوق الأساسية للمساهمين، ووفقاً للمادة ٧٣/١ من قانون الشركات، يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها نظام الشركة، ويجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السري إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.

ووفقاً للفقرة الثانية من المادة ٧٣ من قانون الشركات، المضافة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨: "يجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها، ويجوز للمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك دون

التقيد بحكم الفقرة الخامسة من المادة (٦٧) من هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ويجوز للشركات المقيدة أسهمها بنظام الإيداع والقيود المركزي استخدام ما تراه من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية، والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية، وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.^(١)

والقاعدة أن لكل سهم صوتاً واحداً، بحيث يكون للمساهم عدد من الأصوات بقدر الأسهم التي يحوزها، تطبيقاً لمبدأ المساواة بين المساهمين^(٢)، ومع ذلك فقد نصت المادة ٩٢ من قانون سوق رأس المال رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٢ على أنه: "يجوز أن ينص نظام الشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت، على أن تتساوى الأسهم من نفس النوع في الحقوق والمميزات أو القيود، كما يجوز أن ينص نظام الشركة على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن الغير^(٣)، مع مراعاة أنه لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠٪) من مجموع الأسهم الإسمية من رأس مال الشركة، وبما لا يجاوز (٢٠٪) من الأسهم المثلة في الاجتماع.^(٤)

هذا وبحق لأعضاء مجلس الإدارة التصويت بما يملكونه من أسهم ولو كانت مقدمة كضمان لعضويتهم، ولكن لا يجوز لهم الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة، ولا تحسب الأسهم التي يحوزونها في نصاب التصويت.^(٥)

ويباشر المساهم حقه في التصويت ولو كان الموضوع المعروض على التصويت يتصل بمصلحة شخصية له، ولو كانت هذه المصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة، ويستثنى من هذا الحكم التصويت على تقدير الحصص العينية، فلا يجوز لصاحبها الاشتراك في التصويت الخاص به^(٦)، كما يستثنى من هذا الحكم أيضاً حالة عدم الوفاء بما تبقى من قيمة الحصص الإسمية للسهم، فلا يكون للأسهم التي أعذر أصحابها للوفاء بباقي قيمتها ولم يقوموا بالوفاء أي حقوق في التصويت بعد مضي شهر من تاريخ الإعذار حتى تمام السداد، وتستنزله هذه الأسهم من نصاب التصويت.^(٧)

ولما كان التصويت من الحقوق الأساسية للمساهم التي لا يجوز حرمانه منها، فإنه لا يجوز للمساهم أن يتنازل للغير عن الأصوات المقررة للأسهم التي يمتلكها، لأنه من الحقوق الشخصية التي لا يجوز التنازل عنها، كما أنه من المزايا اللصيقة بالسهم فلا يجوز التخلي عنه بمعزل عن السهم، فإذا وقع هذا التنازل كان باطلاً، كذلك يعتبر باطلاً تعهد المساهم بالتصويت على نحو معين، إذ أن من واجب المساهم أن يستخدم حقه في التصويت بحرية تامة، ولا يضع نصب عينيه إلا صالح الشركة، ويمكن إسناد البطلان في هذه الحالة إلى الغش الذي يفسد سائر التصرفات.^(١)

محضر اجتماع الجمعية:

وفقاً للمادة ٧٥ من قانون الشركات، يحرر محضر بملخص وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة، وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع وإثبات نصاب الحضور والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون إثباته في المحضر. كما تسجل أسماء الحضور من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات.

وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في دفاتر خاصة، ويتبع في مسك هذه الدفاتر والسجلات الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية من حيث: وجوب أن تكون هذه الدفاتر خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير. ويجب أن تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة بالتسلسل، ويتعين قبل استعمالها أن تختم كل ورقة منها بخاتم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ويوقع عليها من الموثق المختص، ويكون إثبات الترقيم ووضع خاتم مصلحة الشهر والتوثيق على النحو السالف الذكر ثابت التاريخ في صدر كل صفحة دفتر قبل استعماله، ولا يجوز تسجيل دفتر جديد إلا بعد تقديم الدفتر السابق للموثق المختص ليؤشر بإقفاله وإثبات ذلك في السجلات المعدة لذلك بالمصلحة.

وتسرى هذه الأحكام الخاصة بالتوثيق على سجل المساهمين وسجل حضور الجمعية العامة، كما تسرى أيضاً على الدفاتر المحاسبية الأصلية والمساعدة، وتلتزم الشركة بضرورة الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالدفاتر والسجلات، ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسؤولين عن صحة بيانات دفاتر الجمعية المشار إليها، ويسأل من يكون منهم من أعضاء مجلس

الإدارة عن مطابقتها لما ينص عليه القانون ونظام الشركة، ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للجهة الإدارية المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.

بطلان قرارات الجمعية العامة:

بالإضافة إلى ما قرره قانون الشركات من أنه يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد التي يقررها، أو يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه، وذلك دون إخلال بحق الغير حسنى النية^(١)، فقد نصت المادة ٢١/٧٦ من هذا القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة.

ويظهر من هذا النص أن هناك نوعان لبطلان قرارات الجمعية العامة لشركة المساهمة: بطلان وجوبي وبطلان جوازي:

فالبطلان الوجوبي: هو الذي يجب على القاضي الحكم به، ولا يملك إزاءه أي سلطة تقديرية إذا توفرت موجباته، ومناطق هذا البطلان مخالفة أحكام القانون، كما لو تمت مخالفة الأحكام الخاصة بالإخطار بالدعوة إلى حضور الاجتماع والبيانات التي يجب أن يتضمنها، أو مخالفة قواعد النشر، أو إغفال دعوة الهيئة العامة لسوق المال ومراقب الحسابات لحضور الاجتماع، أو مخالفة التزام أعضاء مجلس الإدارة بقواعد نشر القوائم المالية قبل موعد الاجتماع، أو انعقاد الاجتماع بالرغم من عدم توفر النصاب القانوني لصحته...^(٢)

أما البطلان الجوازي: فيخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع في ضوء مراعاة مصلحة الشركة، ومدى مساهمة القرار في تحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله الشركة، ومن أمثلة هذا البطلان القرارات التي تصدر عن غش أو تدليس أو إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو تجاوزها، أو كان من شأن القرار إلحاق الضرر بالشركة، أو الإضرار بمصلحة أقلية المساهمين، كحرمانهم من نصيبهم في الأرباح، أو تمخض القرار عن تحقيق مصلحة مجلس الإدارة دونما نظر إلى اعتبار مصلحة الشركة، كتقرير مزايا أو مكافآت لهم رغم سوء حالة الشركة المالية، أو رغم عدم تحقيقها أرباح تبرر توزيع هذه المكافأة أو تقرير تلك المزايا.

ووفقاً للفقرة الثالثة من المادة ٧٦ من قانون الشركات: لا يجوز أن يطلب البطلان في هذه

الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية. وبالرغم مما قد يوحي به ظاهر هذا النص من تعليق الحكم بالبطلان، في صورته الوجوبية والجوازية، على طلب المساهمين، إلا أننا نؤيد ما ذهب إليه البعض في الفقه من ضرورة قصر النص على حالات البطلان الجوازي دون البطلان الوجوبي، ذلك أن تطبيق أحكام البطلان الوجوبي يجب ألا يتوقف على إرادة المساهمين، وإنما يستمد قوته من إرادة المشرع، باعتبارها قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام.^(١)

وعلى هذا فلا يجوز الطعن في القرار، في الحالات الجوازية لطلب البطلان (القرارات التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة) ممن حضر الاجتماع ووافق على القرار، كذلك لا يقبل الطعن على القرار ممن تغيب عن الاجتماع بدون سبب مقبول، إذا لا يقبل أن يعتبر الإهمال سبباً لنشوء الحق، أما إذا تعلق الأمر بالقرارات التي تصدر مخالفة لأحكام القانون أو لنظام الشركة (البطلان الوجوبي)، فيثبت الحق في طلب بطلانها لكل ذي مصلحة، سواء حضر الاجتماع أو لم يحضر، وسواء وافق على القرار أو اعترض عليه، كما يثبت الحق في طلب هذا البطلان للمساهمين وللغير على حد سواء.^(٢)

ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين، وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في إحدى الصحف اليومية وفي صحيفة الشركات.^(٣) وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك.^(٤)

وقف قرار الجمعية العامة:

استحدث قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٣ حكماً خاصاً يتعلق بإمكانية وقف قرارات الجمعية العامة، إذ تقضي المادة العاشرة من هذا القانون بأنه: "لمجلس إدارة هيئة سوق المال، بناء على أسباب جدية يبيدها عدد من المساهمين الذين يملكون ٥ % على الأقل من أسهم الشركة وبعد التثبت، وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلسي الإدارة أو غيرهم.

وجاءت المادة (٧٦ مكرراً) المضافة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ بتعديل قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لتقضي بأنه: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بالنسبة للشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية أو التي طرحت أوراقاً مالية لها في اكتتاب عام، أو الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، يكون للهيئة بناء على طلب المساهمين الذين يملكون نسبة لا تقل عن (٥ %) من أسهم الشركة، متى ثبت لها جدية الطلب، إصدار قرار بوقف ما صدر من الجمعية العامة للشركة من قرارات إضراراً بهم، أو صدرت لصالح فئة معينة من المساهمين، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم وذلك كله بالشروط المحددة في المادة (٧٦) من هذا القانون.

ولا يقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العامة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدور تلك القرارات، ولذوي الشأن إقامة الدعوى بطلب إبطال قرارات الجمعية العامة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار إيقاف التنفيذ وإخطار الهيئة بنسخة من صحيفة الدعوى، وإلا اعتبر قرار إيقاف التنفيذ كأن لم يكن".^(١)

الفرع الثاني

الأحكام الخاصة بالجمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية للمساهمين هي الجهة التي تمثل السلطة العليا في الشركة، وهي الجهة الرقابية على أعمال مجلس الإدارة، وتتناول أحكام الجمعية العامة العادية من حيث انعقادها، ونصاب صحة اجتماعها والتصويت على قراراتها، واختصاصاتها وسلطاتها.

أولاً: أحكام انعقاد الجمعية العامة العادية:

الدعوة للإنعقاد:

تتعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين، في دور انعقادها العادي، بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان الذين يعينهما نظام الشركة، ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقل في السنة خلال الستة الشهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة.^(١)

ومجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة، في دور انعقاد غير عادي، كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا طلب إليه ذلك

مراقب الحسابات، أو عدد من المساهمين يمثل ٥ ٪ من رأس مال الشركة على الأقل، بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية.^(١)

فإن لم يتم مجلس الإدارة بواجبه في دعوة الجمعية العامة للإنعقاد في دور انعقادها العادي، أو لم يستجب إلى طلب الدعوة للإنعقاد الموجه إليه من المساهمين أو من مراقب الحسابات-على ما تقدم-فقد نصت المادة ٦٢ من قانون الشركات على أنه: "لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للإنعقاد في الأحوال التي يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة، على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع، كما يكون للجهة الإدارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده، أو امتنع الأعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور و في جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.

الوثائق والمستندات الواجب إطلاع المساهمين عليها قبل بدء الاجتماع:

يجب على مجلس الإدارة أن ينشر القوائم المالية وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات في صحيفتين يوميتين وذلك قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بعشرين يوماً على الأقل، وذلك حتى يدرس المساهمون ما ورد بهذه الوثائق ويتمكنون من مناقشتها في الاجتماع.^(١) كما يجب على مجلس الإدارة أن يضع تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة أيام على الأقل، بياناً من مراقبي الحسابات يقررون فيه أن الشركة لم تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو لم تضمن أي قرض عقده أحدهم مع الغير، وإذا كانت الشركة من شركات الإئتمان فعليها أن تبين ما إذا كان تعاملها مع أعضاء مجلس الإدارة اتبع فيه ذات الشروط والأوضاع التي تتبعها الشركة مع جمهور العملاء.^(٢)

وعلى مجلس الإدارة أيضاً أن يضع تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص كشفاً تفصيلياً بجميع المبالغ التي تصل رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، والمزايا العينية التي يتمتعون بها، والمبالغ المخصصة لكل منهم، والمكافآت وأنصبة الأرباح التي يقترح توزيعها عليهم، والمبالغ التي أنفقت في سبيل الدعايا، والتصرفات التي يكون فيها لأحد أعضاء المجلس مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة، وتفصيلات التبرعات.^(٣)

كما ألزم المشرع مجلس الإدارة أن يضع تحت تصرف المساهمين بمركز الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل، كشفاً متضمناً أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة ومحال إقامتهم وبيان الشركات الأخرى التي يتولون عضوية مجالس إدارتها أو يقومون بأعمال الإدارة الفعلية فيها، وبياناً بالمسائل المطروحة على الجمعية ونص مشروعات القرارات المطلوب اتخاذها، وتقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية وملاحظات مجلس المراقبة في حالة وجودها.^(١)

ويكون للمساهمين الاطلاع على المستندات السابق الإشارة إليها في المواعيد المحددة بمقر الشركة، سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء عنهم، ويجوز للمساهمين الحصول على صورة منها بعد أداء الرسم المقرر.^(٢)

نصاب صحة الاجتماع ونصاب صحة التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية: قدمنا أن حق حضور المساهم الجمعية العامة والتصويت على قراراتها يعتبر من النظام العام، ولا يجوز استبعاد المساهم من حضور اجتماع الجمعية العامة مهما قل عدد الأسهم التي يمتلكها. ووفقاً للفقرة الأولى من المادة ٦٧ من قانون الشركات، المعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨: "لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز نصف رأس المال". ويأتي اشتراط هذه النسبة المتواضعة لصحة اجتماع الجمعية العادية ضماناً لانعقاد الجمعية العامة واطلاعها بالاختصاصات المنوطة بها قانوناً، وذلك في ظل إجحام المساهمين عن حضور اجتماعات الجمعية العامة واكتفاءهم بالحصول على أرباح الأسهم والمضاربة على أسعارها. فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويجوز أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع الأول تحديد موعد الاجتماع الثاني حال عدم اكتمال النصاب القانوني، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك.

وتبدأ الجمعية اجتماعها السنوي بقراءة التقرير المقدم من مجلس الإدارة، وتعرض الجهة التي أعدت التقرير القوائم المالية، ويتلو مراقب الحسابات تقريره متضمناً البيانات والمعلومات المتصلة بموجب القانون واللائحة.^(٣)

ولكل مساهم أثناء اجتماع الجمعية العامة حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية

وتقرير مراقب الحسابات، وما يتكشف أثناء الاجتماع من وقائع خطيرة، ويكون مجلس الإدارة ملزماً بالإجابة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر^(١)، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون رأيها ملزماً^(٢).

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات انعقاد الجمعية ورئاستها وكيفية اختيار أمانة السر وجامع الأصوات، وطريقة أخذ الأصوات^(٣)، ويعني هذا أن قياس الأغلبية يعتد فيها بعدد الأصوات التي تمنحها الأسهم الممثلة في الاجتماع، وليس بعدد الأسهم ذاتها، إذ قد تتوفر هذه الأغلبية بعدد من الأسهم يقل عن ٥٠ % من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع نظراً لوجود أسهم متعددة الأصوات^(٤).

وفي كل الأحوال يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام، ويجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السري إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل^(٥).

ثانياً: اختصاصات الجمعية العامة وسلطاتها:

تقضي المادة ٦٣ من قانون الشركات بأنه: "مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي: (أ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم. (ب) مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسؤولية. (ج) المصادقة على القوائم المالية. (د) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة. (هـ) الموافقة على توزيع الأرباح. (و) كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمين الذين يملكون ٥ % من رأس المال عرضه على الجمعية العامة، كما تختص بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة.

وقد فصلت اللائحة التنفيذية اختصاصات الجمعية العامة العادية، سواء ما يتعلق منها بمجلس الإدارة، أو بشأن مراقب الحسابات، أو ما يتعلق بالمسائل المالية، وذلك على النحو التالي:

١- اختصاصات الجمعية العامة العادية الخاصة بمجلس إدارة الشركة:

يمكن إيجاز اختصاصات الجمعية العامة العادية الخاصة بمجلس إدارة الشركة على الوجه الآتي:

-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآت وبدلات ورواتب أعضاء-مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسؤولية وبراءة ذمته-عزل أعضاء المجلس أو أحدهم ولو لم يكن ذلك وارداً في جدول الأعمال، كما أن لها أن ترفع دعوى المسؤولية عليهم-توقيع غرامة مالية على أعضاء المجلس الذين لم يحضروا الاجتماع بغير عذر مقبول-الترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب لشغل وظيفة العضو المنتدب في شركة أخرى-الترخيص لعضو مجلس الإدارة يقوم بعمل فني أو إداري في شركة مساهمة أخرى بصفة دائمة-الترخيص لعضو مجلس الإدارة بالتجار لحسابه أو لحساب غيره في فروع نشاط الشركة-التصدي لأي عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال النصاب-إصدار التوصيات بشأن الأعمال التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة.^(١)

٢-الاختصاصات المتعلقة بمراقب الحسابات:

للجمعية العامة العادية النظر في تقرير مراقب الحسابات، وكذلك تعيينه وتعيين السنة المالية التي ينتدب لها وتحديد أتعابه، كما تختص هذه الجمعية بالنظر في تغيير مراقب الحسابات أثناء السنة المالية التي ينتدب لها بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون، والنظر في عزل مراقبي الحسابات وإقامة دعوى المسؤولية عليهم، كذلك النظر في تقرير مراقب الحسابات في حالة عدم تمكنه من أداء مهمته.^(٢)

٣-الاختصاصات المتعلقة بالمسائل المالية للشركة:

للجمعية العامة العادية فيما يتعلق بالمسائل المالية للشركة الاختصاصات التالية:
-المصادقة على القوائم المالية- الموافقة على توزيع الأرباح^(٣)-إصدار قرار وقف الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال المصدر-تكوين احتياطات أخرى غير الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي-استخدام الاحتياطي النظامي فيما يعود بالنفع على الشركة والمساهمين، ما لم يكن مخصصاً لأغراض معينة-التصرف في الاحتياطات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها-الموافقة على توزيع نسبة من الأرباح الصافية التي تحققها الشركة نتيجة بيع أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه، بشرط ألا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من إعادة أصولها إلى ما كانت عليه-الموافقة على إصدار سندات وعلى الضمانات التي تقرر لحملتها-النظر في قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات-الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة-الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع متى تجاوزت قيمته ألف جنيه.^(٤)

هذا، ووفقاً للمادة ١٢ من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٣: "يكون إصدار السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى سواء كانت اسمية أو لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة، ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، ويجب أن تتضمن موافقة الجمعية العامة العائد الذي يغله السند أو الصك أو الورقة وأساس حسابه دون التقييد بالحدود المنصوص عليها في أى قانون آخر.

ويجب الحصول على ترخيص من الهيئة في حالة طرح السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى في اكتتاب عام.

رابعاً: الاختصاصات المتعلقة بتصفية الشركة:

تختص الجمعية العامة بتعيين المصفين وتحديد أتعابهم وعزلهم- تحديد المدة المقررة للتصفية ومدها بعد الاطلاع على تقرير المصفي- النظر في الحساب المؤقت الذي يقدمه المصفي كل ستة أشهر- التصديق على الحساب الختامي لأعمال التصفية- تعيين المكان الذي تحفظ فيه دفاتر الشركة ووثائقها بعد شطبها من السجل التجاري.^٥

الفرع الثالث

الأحكام الخاصة بالجمعية العامة غير العادية

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام الأساسي للشركة والنظر في حل الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها نصف رأس المال، ومن ثم فهي لا تنعقد إلا عندما يستلزم الأمر هذا الانعقاد، وإذا كان الأصل وفقاً للقواعد العامة أن النظام الأساسي للشركة، بوصفه قانون المتعاقدين، لا يجوز تعديله إلا بموافقة الشركاء جميعاً، فإنه نزولاً على الضرورات العملية تم العدول عن حكم القواعد العامة في هذا الشأن، وإقرار حق تعديل نظام الشركة بأغلبية خاصة، لا سيما وأن شركة المساهمة مركز قانوني منظم أقرب إلى القانون منه إلى العقد.^٦

هذا ووفقاً للمادة ٧٠/أ من قانون الشركات، تسرى على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية، مع مراعاة أن القانون قد اختص الجمعية العامة غير العادية بأحكام خاصة من حيث: دعوتها للاجتماع، والمستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين قبل اجتماعها، ونصاب صحة اجتماعها وإصدار قراراتها، ثم تحديد اختصاصها.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون ١٠٪ من رأس المال على الأقل لأسباب جدية، ويشترط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة^(١)، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية، وإذا لم يقيم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا إلى الجهة الإدارية المختصة (الهيئة العامة لسوق المال - الإدارة العامة للشركات) التي تتولى توجيه الدعوة^(٢).

ويضع مجلس الإدارة تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص بمركز الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بخمسة عشر يوماً على الأقل ما يأتي:

١- بيان بالمسائل المعروضة على الجمعية ومشروعات القرارات المطلوب اتخاذها، وإذا طلب المساهمون الحائزون على ما نسبته ١٠٪ من أسهم الشركة إدراج بعض المسائل في جدول الأعمال، تعين وضع بيان بتلك المسائل ومشروعات القرارات المتعلقة بها تحت تصرف المساهمين قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ اجتماع الجمعية.

٢- تقرير مراقب الحسابات عن المسائل المعروضة على الجمعية.

ويكون لأصحاب الأسهم والسندات وحصص التأسيس الاطلاع على المستندات والأوراق المشار إليها في المواعيد المحددة بمقر الشركة، سواء بأنفسهم أو عن طريق من ينوب عنهم قانوناً، مع حقهم في الحصول على نسخة منها بعد دفع الرسم المقرر.

نصاب صحة الاجتماع ونصاب إصدار القرارات:

نظراً لخطورة القرارات المنوطة بالجمعية العامة غير العادية اشترط المشرع نصاباً مرتفعاً لصحة اجتماع هذه الجمعية، ولذا فلا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة ومواعيدها وطرق النشر والإعلان ومن له حق الحضور من غير المساهمين^(٣).

ووفقاً للفقرة (ج) من المادة ٧٠ من قانون الشركات، بعد تعديلها بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨، تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع،

فإذا تعلق القرار بزيادة رأس المال المرخص به، أو تخفيض رأس المال، أو حل الشركة قبل الميعاد، أو تغيير غرضها، أو إدماجها، أو تقسيمها، فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة، ويعد هذا الحق للجمعية العامة غير العادية من النظام العام، بحيث لا يجوز أن يتضمن نظام الشركة ما يفيد حرمانها أو تقييد حقها في تعديل نظام الشركة، ويقع باطلاً كل نص في نظام الشركة يقضي بخلاف ذلك، لأن مصدر هذا الحق هو القانون ذاته وليس أحكام النظام الأساسي للشركة، ولذا فقد نصت المادة ٦٨/ج من قانون الشركات على أنه: "يكون للجمعية العامة غير العادية النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره، أو حلها قبل موعدها، أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجبارياً، أو إدماج الشركة، وذلك أيا كانت أحكام النظام".

كما تختص الجمعية العامة بإضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي.^(١)

والجدير بالذكر أن الفقه مستقر على أن هذا التعداد قد ورد على سبيل المثال لا الحصر، ومن ثم يحق للجمعية غير العادية أن تتصدى لتعديل النظام الأساسي للشركة في كل حالة تتطلب تحقيق الانسجام بين ما يتضمنه النظام والظروف الاقتصادية المتغيرة.

كما أن الرأي الراجح فقهاً أن هذا التعداد لا يشمل إمكانية تغيير جنسية الشركة بنقل مركزها الرئيسي خارج مصر، وإلى دولة أخرى تتجه الرغبة إلى إكساب الشركة جنسيتها، لأن تغيير جنسية الشركة مسألة شديدة الخطورة من الناحية القانونية، لأن التغيير يترتب عليه خروج الشركة من نطاق القانون المصري إلى نطاق قانون أجنبي غير معروف، مما يهدد الحقوق المكتسبة للمساهمين، وقد يؤدي إلى زيادة التزاماتهم^(٢)، كما أن هذا القرار يخالف حكم القانون الذي يقضي بأن تتخذ شركات المساهمة التي تأسس في مصر مركزها الرئيسي في جمهورية مصر العربية^(٣)، ومن ثم اكتسابها الجنسية المصرية بناء على معيار مركز الإدارة الرئيسي المعول عليه بالأساس في تحديد اكتساب الجنسية المصرية.^(٤)

القيود الواردة على اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:

ومن جهة أخرى فإن المشرع، وفضلاً عما قرره في المادة ٢/٧٦ من قانون الشركات من إبطال كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة، قيد حق الجمعية العامة غير العادية بقيود معينة لدى استخدام سلطتها في إجراء تعديل نظام الشركة، وذلك على النحو التالي:

١- عدم زيادة أعباء المساهمين أو المساس بحقوق المساهم الأساسية: فلا يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات يترتب عليها زيادة التزامات المساهمين، ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدّها بصفته شريكاً^(١)، ويتعين الحصول على موافقة جميع المساهمين على أي تعديل يترتب عليه زيادة التزامات المساهمين.

ولم يفرق المشرع بين القرارات التي تصدر من الجمعية العامة غير العادية ويترتب عليها زيادة أعباء المساهمين، والتي تطلب بشأنها الحصول على إجماع المساهمين، والقرارات التي يكون من شأنها المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدّها بصفته شريكاً، والتي قضى بإبطالها بشكل مطلق.

ومن أمثلة زيادة التزامات المساهمين: زيادة القيمة الإسمية للأسهم ومطالبة المساهمين بالزيادة، أو إلزام المساهمين بالاشتراك في الأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة بمناسبة زيادة رأس المال، أو تحويل الشركة إلى شركة تضامن بحيث تتحول مسؤولية الشركاء إلى مسؤولية مطلقة وتضامنية عن ديون الشركة بعد أن كانت مسؤولية محدودة، فكل هذه صور من القرارات لا يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدرها، فإن خالفت ذلك واتخذت قراراً بشأنها، فلا يلزم القرار إلا من وافق عليه، ولا ينفذ في حق من اعترض عليه من الشركاء.

بينما يعتبر من قبيل الحقوق الأساسية للمساهم التي يستمدّها من صفته كشريك، حق حضور الجمعية العامة والتصويت على قراراتها، وحق المشاركة في الأرباح، وحق الحصول على نصيب من ناتج التصفية، وحق تداول الأسهم، وحق الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية عليهم، والطعن بالبطلان على قرارات الجمعية العامة الباطلة، فإذا ما صدر من الجمعية العامة قراراً من شأنه المساس بهذه الحقوق اعتبر قراراً باطلاً.

وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم، أو لطلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيّبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جديدة، ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين.^(١)

٢- لا يجوز تغيير الغرض الأصلي إلا لأسباب توافق عليها الجهة الإدارية المختصة^(٢): والحكمة من هذا الحظر واضحة، ذلك أن من شأن تغيير الغرض الأصلي للشركة إلغاء مشروع الشركة كلية وخلق شركة جديدة، مما يستلزم اتباع إجراءات تأسيس جديدة، فضلاً عما قد ينطوي على هذا التغيير من تجاوز لإرادة المساهمين الذين اكتتبوا بأسهم الشركة لدى تأسيسها وهي تهدف لتحقيق غرض معين، فإذا هم يفاجئون بتغييره، وبالتالي أوجب المشرع حتى يمكن تغيير الغرض الأساسي للشركة أن يكون ذلك بناء على أسباب قوية تبرر هذا التغيير، وأن توافق عليه الجهة الإدارية المختصة، فإذا تحققت موافقة هذه الجهة أمكن تغيير الغرض الرئيسي للشركة، وفي هذه الحالة تظل الشركة محتفظة بشخصيتها الاعتبارية التي كانت للشركة وفق غرضها الأول.^(٣)

٣- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية المساس بحقوق الغير: فهي لا تمتلك تغيير العقود التي أبرمتها الشركة مع الغير، ولا تعديل حقوق حملة السندات أو إجبارهم على تحويلها إلى أسهم، إلا إذا وافقوا على ذلك، لأنهم يعتبرون، كدائنين للشركة، من الغير في مواجهة الشركة، فلا تملك الجمعية العامة العادية أو غير العادية المساس بحقوقهم التعاقدية أو القانونية إلا بموافقتهم.^(٤)

٤- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات تمس حقوق أصحاب الأسهم الممتازة: إذ لا يمكن أن يتم ذلك إلا بموافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم التي يتعلق بها التعديل بأغلبية الأصوات الممثلة لثلثي رأس المال الذي تمثله هذه الأسهم^(٥)، فوفقاً للمادة ٣٥/ ٢ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١: "يجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، على أن تتساوى الأسهم من نفس النوع في الحقوق والمميزات أو القيود، ولا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق التعديل به".

المطلب الثالث

الرقابة على إدارة شركة المساهمة

الأصل أن للجمعية العامة، بوصفها صاحبة السلطة العليا والكلمة الأخيرة في كل أمور الشركة، حق الرقابة على أعمال الجهة التي تدير الشركة من الناحية الفعلية وهي مجلس الإدارة، وذلك بما لها من حق أصيل في الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها^(١)، والتصويت على مشروعات القرارات التي تعرض على الجمعية، إلا أن هذه الجمعية لا تقوم من الناحية العملية بدورها في تلك الرقابة، فالمساهمون لا يهتمون غالباً إلا بالربح الذي يحصلون عليه أو المضاربة على أسعار الأوراق المالية التي يملكونها من خلال عمليات البيع والشراء في سوق الأوراق المالية، ولا يولون إدارة الشركة أهمية تذكر، كما أن مراجعة حسابات الشركة تقتضي معرفة وخبرة فنية لا تتوافر عادة لدى المساهمين، كما تستلزم ممن يقوم بها أن يحافظ على سرية معلومات الشركة.

لذلك كله فقد جرى العمل في التشريعات والأنظمة المختلفة، تطبيقاً لقواعد ومبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، على أن يتولى مهمة الرقابة على أعمال الشركة من الداخل شخص أو أكثر، نيابة عن الجمعية العامة، يسمى مراقب أو مراجع الحسابات، يضاف إلى ذلك نوع من الرقابة والمحاسبة "الخارجية" على أعمال مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات أنفسهم، متى ما وقع منهم بمناسبة أداء أعمالهم ما يدعو إلى الشك والريبة في سلامة هذه المعاملات، وذلك هو نظام التفتيش على الشركة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام المساهمين لكشف أي مخالفات تقع من مجلس الإدارة أو من مراقبي الحسابات لواجباتهم المقررة في قانون الشركات أو في نظام الشركة ومحاسبتهم عليها، وذلك فضلاً عما تضمنه قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ من بعض صور الرقابة على شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.

وعلى هذا سنعرض، فيما يتعلق بالرقابة على إدارة شركة المساهمة، لمراقبي الحسابات في فرع أول، ثم لنظام التفتيش على إدارة الشركة في فرع ثان.

الفرع الأول

مراقب الحسابات

Le Commissaire au compte

سنتناول فيما يتعلق بمراقبي الحسابات: كيفية تعيينهم وعزلهم، والشروط التي يجب توافرها فيمن يعين مراقباً للحسابات، ثم لاختصاصات مراقبي الحسابات وسلطاتهم، وأخيراً لمسئولية مراقبي الحسابات.

أولاً: تعيين مراقبي الحسابات وعزلهم:

١- تعيين مراقبي الحسابات:

يقصد بمراقب الحسابات، ذلك الشخص الذي يعهد إليه بواسطة جماعة الشركاء بالقيام بأعمال الرقابة الداخلية على الشركة، كمراجعة وفحص حسابات الشركة وميزانيتها، وحساب الأرباح والخسائر فيها، وأعمال مجلس الإدارة، والتحقق من مدى احترام أحكام القانون ونظام الشركة في كل ذلك، وبشكل يحقق صالح الشركة والشركاء والمصلحة العامة، ويقوم المراقب بمهامه القانونية والعقدية لمدة زمنية معينة ينص عليها عقد تعيينه مقابل أجر (أتعاب) تقدرها الجمعية العامة للمساهمين.

ويجب أن يكون لشركة المساهمة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة^(١) تعيينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه، وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن^(٢)، واستثناء من ذلك يعين مؤسسو الشركة المراقب الأول، ويتولى مراقب الشركة الأول مهمته لحين انعقاد أول جمعية عامة^(٣).

ويباشر المراقب الذي تعيينه الجمعية العامة مهمته من تاريخ تعيينه إلى تاريخ انعقاد الجمعية التالية، وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي ندب لها، ولا يجوز تفويض مجلس الإدارة في تعيين المراقب أو تحديد أتعابه دون تحديد حد أقصى، فإذا لم يكن للشركة في أى وقت لأى سبب مراقب للحسابات، تعين على مجلس الإدارة اتخاذ إجراءات تعيين المراقب فوراً، ويعرض ذلك على الجمعية العامة في أول اجتماع لها^(٤).

٢- عزل مراقب الحسابات واستقالته:

ومن حق الجمعية العامة عزل المراقب أثناء السنة المالية التي انتدب لها. ويبطل بطلاناً مطلقاً كل شرط مخالف. (م ١٠٣/٥ شركات). كما أنه يجوز في حالة عزل المراقب، أن تقيم دعوى المسؤولية عليه بسبب عدم صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين (المادة ١٠٦ فقرة أخيرة من القانون، والمادة ٢١٧ من اللائحة)، أو إذا أفشى أسرار الشركة أمام المساهمين أو غيرهم. (المادة ١٠٨ من القانون).

فالجمعية العامة تمتلك تعيين المراقب، لذلك فهي تملك عزله، بل إن لكل مساهم أن يتقدم بطلب مكتوب إلى مجلس الإدارة يقترح فيه طلب عزل المراقب، بشرط أن يبين المساهم الأسباب التي يستند إليها للعزل، وأن يقدم الطلب قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل. (المادة ١٠٣/٤ من القانون).

كما يجوز للجمعية العامة - في جميع الأحوال - بناء على اقتراح أحد أعضائها تغيير مراقب الحسابات، وفي هذه الحالة يتعين على صاحب الاقتراح أن يخطر الشركة برغبته تلك وما يستند إليه من أسباب، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، وعلى الشركة إخطار المراقب فوراً بنص الاقتراح وأسبابه، وللمراقب أن يناقش الاقتراح في مذكرة كتابية تصل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل، ويتولى رئيس مجلس الإدارة تلاوة مذكرة المراقب على الجمعية العامة، فإذا نجح في إقناع الجمعية العمومية بسلامة موقفه فلا مبرر لعزله أو تغييره، ويقع باطلاً كل قرار تتخذه الجمعية العامة في شأن تعيين المراقب أو استبدال غيره به على خلاف الأحكام السابقة.^(١)

ويجوز للمراقب أن يستقيل من عمله قبل انتهاء السنة المالية المنتدب لها، بشرط ألا يستعمل هذا الحق بشكل يلحق الضرر بالشركة، ويلتزم المراقب بتعويض الشركة عن الضرر الذي يلحقها من جراء استقالته فجأة أو في وقت غير مناسب، أما إذا انتهت مدة عمله، فمن حق المراقب أن يطلب عدم تجديد مدة وکالته، دون التزام بالتعويض، ولو كان سبب استقالته بسيطاً أو لم يكن هناك سبب للاستقالة.

ثانياً: الشروط الواجب توافرها في مراقب الحسابات:

تنقسم هذه الشروط إلى طائفتين:

(أ) الشروط التي تتعلق بالكفاءة المهنية والسمعة.

(ب) الشروط التي تهدف إلى تحقيق استقلال مراقب الحسابات وحياديته ونزاهته.

(أ) الشروط المتعلقة بالكفاءة والسمعة أو السيرة:

يجب أن تتوافر في مراقب (أو مراقبي) حسابات شركة المساهمة الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ (م ١/١٠٣ من القانون). وتحظر المادة الأولى من قانون ١٣٣ لسنة ١٩٥١، المذكور، مزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة إلا على من كان اسمه مقيداً في السجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة التجارة والصناعة. وبذلك يضمن المشروع جدية المراقبة وإسنادها إلى فئة من المتخصصين. ويشترط للقيد في السجل العام توافر عدة شروط في طالب القيد (وفقاً للمادة ٢ من قانون ١٣٣ لسنة ١٩٥١) وهي:

١- أن يكون طالب القيد مصرياً مقيماً في مصر "المملكة المصرية سابقاً"
٢- أن يكون كامل الأهلية المدنية، أي بلغ سن الرشد (٢١ سنة ميلادية) دون أي عارض من عوارض الأهلية.

٣- أن يكون حسن السمعة، لم تصدر عليه أحكام قضائية أو قرارات تأديبية ماسة بالشرف. وتختلف المؤهلات العلمية المطلوبة، حسب الجدول الذي يرغب الطالب القيد فيه، وهل هو جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين، أو جدول المحاسبين والمراجعين، أم جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين^(١).

(ب) الشروط التي تتعلق باستقلال المراقب وحياده ونزاهته:

١- لا يجوز لمراقب الحسابات أن يجمع بين صفته (عمله) وصفة المؤسس (الاشتراك في تأسيس الشركة) أو عضوية مجلس الإدارة، أو الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في الشركة. (م ١/١٠٤ من قانون الشركات).

والحكمة من هذا الحظر هي ضمان حياد المراقب ونزاهته واستقلاله وإبعاده عن الشبهات، وألا تكون له مصلحة تؤثر في قيامه بعمله على نحو يحقق مصالحه الخاصة.

٢- لا يجوز - كذلك - أن يكون المراقب شريكاً لأي شخص يباشر نشاطاً مما ذكر في الفقرة السابقة، أو أن يكون موظفاً لديه أو من ذوي قريبه حتى الدرجة الرابعة. (م ٢/١٠٤ من القانون)، وذلك بهدف تأكيد استقلال المراقب وعدم تبعيته لأي شخص كان، كالمؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو المدير.

٣- يحظر على مراقب الحسابات قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه العمل بشركة المساهمة، أن يعمل مديراً أو عضواً بمجلس الإدارة أو أن يشتغل بصفة دائمة أو مؤقتة بأي عمل في أو إداري أو استشاري في الشركة التي كان يعمل بها. (المادة ١٠٧/١ من القانون)، وذلك لضمان نزاهة المراقب وعدم تواطئه مع مديري الشركة والمهيمنين عليها، وتحرره من نفوذ مجلس الإدارة. ويعتبر باطلاً كل عمل يخالف هذا الحكم، ويلزم المخالف بأن يؤدي إلى خزانة الدولة المكافآت والمرتبات التي صرفت له من الشركة. (م ١٠٧/٢).

الطبيعة القانونية لعلاقة مراقب الحسابات بالشركة والمساهمين:

اختلف الرأي حول طبيعة هذه العلاقة إلى اتجاهين - اتجاه تقليدي يستند إلى النظرية التعاقدية، واتجاه حديث وهو السائد ويسمى بالنظرية العضوية، أو الفكر النظامي.

(١) النظرية التعاقدية:

ومجمل النظرية التعاقدية هو أن مراقب الحسابات يعتبر وكيلاً عن الشركة التي تخضع لرقابته، وهو وكيل بأجر يربطه بالشركة عقد وكالة، وقد تبني المشرع الفرنسي إلى وقت قريب هذه النظرية قبل أن يتجه إلى الأخذ بالنظرية الحديثة، أما القانون المصري فيتبنى نظرية الوكالة، أي اعتبار المراقب وكيلاً من مجموع المساهمين، ومسئولاً مسئولية مدنية أمامهم في حالة عدم صحة البيانات الواردة في تقريره، وأنه يحق لكل مساهم أثناء اجتماع الجمعية العامة، أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضح كل ما ورد فيه. (م ١٠٦/٤ من قانون الشركات).

وقد تلاشت تقريباً نظرية الوكالة، لأنها لا تكفي لتكييف العلاقة بين مراقب الحسابات وبين الشركة. حيث يؤخذ على هذه النظرية، أن الوكيل يكلف بأعمال قانونية لحساب الموكل، أما المراقب فيقوم بأعمال مادية (المراجعة - الفحص - المراقبة) وإبلاغ المساهمين بنتائج تحرياته أو أعماله، دون التزامهم بالمعلومات المقدمة إليهم من ذلك المراقب، كذلك، فإنه وإن كانت الجمعية العامة هي التي تعين المراقب وتعزله وتحدد أتعابه، إلا أنها لا تملك سلطة مطلقة في كل ذلك، وإنما يقع عليها مراعاة شروط التعيين السابق بيانها، كما أنها لا تملك عزله إلا لمبرر معقول، وإلا كانت مسئولة عن الضرر الذي يلحق المراقب من جراء تعسفها في استعمال حق العزل، وكل ذلك يتعارض مع القول بنظرية الوكالة وأن المراقب يمارس عمله كوكيل عن الشركة.^(١)

(٢) نظرية العضوية (الاتجاه النظامي):

ويرى أنصار هذه النظرية، أن المراقب عضو بالشركة، مهمته هي الرقابة على إدارتها، وأن

المراقب عبارة عن جزء أو قطعة في آلة قانونية (الشركة) ينظمها القانون، ودور المراقب قانوناً هو الرقابة على حسابات الشركة، لأنه موظف بها، وعلى الرغم من أن المساهمين هم الذين يعينونه، وأنه مرتبط بهم تعاقدياً، وأن العقد المبرم بينه وبين المساهمين يعتبر بمثابة عمل شرطي لتطبيق نظام قانوني وضعه المشرع يخضع له مراقب الحسابات، إلا أن المراقب لا يبقى وكيلاً أو تابعاً للمساهمين (ناخبه)، كالنائب في البرلمان مستقل عن ناخبه، ونحن بدورنا نؤيد هذا الاتجاه الذي يتسق مع الأحكام التي وضعها القانون لمراقبي الحسابات واختصاصاتهم وعلاقتهم بالشركة والمساهمين والغير، كما سيلي.^٥

ثالثاً: اختصاصات (مهام) مراقب الحسابات:

١- رقابة الحسابات:

وهذه هي المهمة التقليدية لمراقب الحسابات، وتنحصر هذه المهمة - بوجه عام - في مراجعة حسابات الشركة وفحص الميزانيات وحساب الأرباح والخسائر، وملاحظة تطبيق أحكام القانون ونظام الشركة، وتقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى الجمعية العامة.

وحتى يمكن للمراقب القيام بهذه المهمة القانونية، منحه المشرع "في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها، ويتعين على مجلس الإدارة أن يمكن المراقب من كل ما تقدم" (م ١/١٠٥ من القانون).

وعلى مجلس الإدارة أن يمكن المراقب من استعمال الحقوق المذكورة أعلاه، وفي حالة عدم تمكنه من ذلك، يجب على المراقب أن يثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة، ويعرض على الجمعية العامة إن لم يتم المجلس بتيسير مهمته.^٥

على أن مباشرة المراقب لمهامه السابقة لا يعنى السماح له بالتدخل في الإدارة الداخلية أو الخارجية للشركة، أو الاعتراض على أعمال المديرين أو توجيه مجلس الإدارة. ومع ذلك يحق للمراقب توجيه النصح والإرشاد إلى مجلس الإدارة وتنبيهه إلى مواطن الزلل.

كما يجب على مجلس الإدارة أن يوافي المراقب بصورة من الإخطارات والبيانات التي يرسلها إلى المساهمين المدعوين لحضور الجمعية العامة (م ١/١٠٦ من القانون). ويدخل في اختصاص المراقب أيضاً، أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد (م ٣/٦١). وللمراقب أن يدعو بنفسه الجمعية العامة للانعقاد إذا تراخى المجلس عن الدعوة لانعقادها، على الرغم من

وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع. (م ١/٦١).

٢- واجب المراقب في تقديم المعلومات عن طريق التقارير العامة أو الخاصة:

أ- التقارير العامة:

يجب على المراقب أن يقدم تقريره السنوي (العام) عن نتائج عمله يبين فيه حالة الشركة وميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر فيها، والحسابات المقدمة من مجلس الإدارة، وما إذا كانت ثمة مخالفات للقانون أو نظام الشركة، ويتلو المراقب التقرير على الجمعية العادية في اجتماعها العادي، ويجب أن يشتمل التقرير على البيانات التي نص عليها القانون واللائحة التنفيذية. (المادة ١٠٦/٣ من القانون).

ويجري العمل على أن ينص التقرير المقدم من مراقب الحسابات على أنه قد تحقق من صحة الميزانية ومن سلامة البيانات المقدمة، وذلك في حدود ما اطلعوا عليه من بيانات ومستندات. والواضح أن المراقبين يريدون بهذه العبارة الأخيرة التهرب من المسؤولية، لذلك، نميل إلى القول بأن ذكر هذه العبارة لا ينفي مسؤولية المراقبين، إذا كان واجبهم يفرض عليهم - طبقاً لعناية الرجل المعتاد - أن يطلبوا الاطلاع على مستندات أخرى.

وعلى المراقب، أو من ينوبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة أن يحضر اجتماع الجمعية العامة، ويتأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت في الدعوة للاجتماع، وعليه أن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله كمراقب للشركة، وبوجه خاص في الموافقة على الميزانية بتحفظ أو بغير تحفظ، أو في إعادةّها إلى مجلس الإدارة. (م ١٠٦/٢).

ب - التقارير الخاصة:

يجب على المراجع أن يقدم تقارير خاصة إلى الجمعية العامة بشأن الموضوعات الهامة التي يحرص على لفت نظر الجمعية العامة إليها بصفة خاصة. ومثال ذلك:

- تقرير مراقب الحسابات عن مشروع عقد اندماج الشركة. (م ٢٩١م لائحة).
- التقرير الخاص بالاتفاقات المبرمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بين الشركة وبين أحد أعضاء مجلس الإدارة، أو المدير العام، أو المؤسس، أو عضو مجلس المراقبة، كعقود البيع، أو القرض أو الإيجار أو التوريد...، إذ تتضمن هذه العقود - عادة - تعارض في مصالح أطرافها.
- التقرير الخاص بحالات زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بقرار من الجمعية العامة غير

العادية، أو بتحويل المستندات إلى أسهم.

- التقرير الخاص بمسألة تغيير الشكل القانوني للشركة أو تقسيمها.

- التقرير الخاص بشروط إصدار أسهم تخصيص العاملين.

ج - التزام المراقب بإخطار أو إبلاغ النيابة العامة بالجرائم التي يكتشفها أو يعلم بها أثناء أو بمناسبة قيامه بمهمة المراجعة. ويترتب على امتناع المراقب عن أداء هذا الواجب تعرضه لجزاء جنائية أخرى مدنية، فالمطلوب من المراقب ألا يكون "كلباً للحراسة" كما في قانون الشركات الإنجليزي، وإنما يجب أن يكون مثل "كلب البوليس أو الصيد". فمن واجب المراقب - في القانون الفرنسي - أن يقوم بالتحري وليس فقط التحقق، ولا يتضمن قانون الشركات المصري حكماً مشابهاً.

٣- واجب المراقب في التحذير من الأخطار (المهمة الجديدة لمراقب الحسابات):

على المراقب التزام بتحذير وتنبيه مجلس الإدارة بالخطر الذي يهدد استمرار نشاط الشركة بسبب واقعة معينة، أو يهدد مصالح المساهمين، أو كان هناك خطر جدي على مصالح الدائنين، كما إذا لاحظ المراقب تزايداً مستمراً في الوضع الحرج للشركة، وكان من شأن تنبيه مجلس الإدارة بذلك أن يقوم هذا المجلس باتخاذ إجراءات من شأنها إصلاح هذا الوضع. وإذا امتنع المراقب عن القيام بهذا الواجب الذي يشبه "صوت سارينة أو صافرة إنذار بالخطر" فإنه يسأل عن ذلك الامتناع.

كما يسأل المراقب قانوناً، إذا كان غرضه من عملية التحذير (الداخلي) هو الإضرار بالشركة وليس لحمايتها (سوء نية المراقب)، أو كان علماً بأن استمرارية نشاط الشركة غير معرضة للخطر. وبالعكس، فلا يسأل المراقب إذا قام بواجبه بحسن نية، أو أخطأ خطأً يسيراً في التقدير.

رابعاً: مسؤولية مراقب الحسابات:

يواجه مراقب الحسابات مسؤولية ثقيلة لها عدة صور هي: المسؤولية المدنية، المسؤولية الجنائية، والمسؤولية التأديبية.

(١) المسؤولية الجنائية للمراقب:

تتعقد مسؤولية مراقب الحسابات جنائياً، إذا توافر في خطئه أو فعله أركان جريمة من جرائم القانون العام كجريمة التزوير، أو النصب أو خيانة الأمانة. أو إذا ارتكب جريمة من الجرائم الخاصة، التي نص عليها قانون الشركات. وفي هذا الشأن تنص المادة ٦٢/١٥٠ من قانون

الشركات على أنه: "مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه - يتحملها المخالف شخصياً - أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مراقب صادق على توزيع أرباح أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون وكل مراقب وكل من يعمل في مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمداً وقائع جوهرية أو أغفل عمداً هذه الوقائع في التقرير الذي يقدمه للجمعية العامة وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتقضي المادة ١٦٤ بأنه: "وفي حالة العود أو الامتناع عن إزالة المخالفة التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة تضاعفت الغرامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حديها الأدنى والأقصى".

كما يسأل المراقب مدنياً وجنائياً إذا خالف التزامه بالمحافظة على أسرار مهنته. حيث تقضي المادة ١٠٨ شركات، بأنه: "مع عدم الإخلال بالتزامات المراقب الأساسية لا يجوز لمراقب الحسابات أن يذيع على المساهمين في مقر الجمعية العامة أو في غيره أو إلى غيرهم ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله، وإلا وجب عزله ومطالبته بالتعويض".

(٢) المسؤولية المدنية لمراقب الحسابات:

المبدأ: مراقب الحسابات مسئول مدنياً عن أخطائه أو إهماله، أمام الشركة والشركاء والغير الذين لحق بهم ضرر أثناء وبسبب قيام المراقب بتنفيذ عمله، وإذا كان للشركة أكثر من مراقب واشتركوا في الخطأ كانوا مسئولين قبل الشركة بالتضامن.^(١)

طبيعة المسؤولية: يسأل المراقب مسؤولية عقدية أمام الشركة بسبب أخطائه أو إهماله في القيام بواجباته، بينما تكون مسؤولية المراقب أمام المساهمين أو الغير حسن النية - في حالة ثبوتها - مسؤولية تقصيرية، إذ لا توجد صلة تعاقدية، فيما بين المراقب والمساهمين أو الغير.

شروط قيام المسؤولية المدنية قبل الشركة والمساهمين والغير: يشترط لقيام هذه المسؤولية توافر شروط ثلاثة: خطأ المراقب، والضرر، وعلاقة السببية بين خطأ المراقب والضرر الحاصل، ويقع على المدعي إثبات هذه العناصر الثلاثة. فأساس المسؤولية المدنية للمراقب هو الخطأ الواجب الإثبات وليس الخطأ المفترض، هذا ويعفى المراقب من المسؤولية إذا فشل المدعي في إثبات خطأ المراقب والضرر وعلاقة السببية بينها، أو إذا أثبت المراقب أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة، أو خطأ المضرور نفسه، أو خطأ الغير (كمجلس

الإدارة)، أو إذا أثبت المراقب انتفاء الخطأ من جانبه، أي أثبت أنه بذل العناية الواجبة عليه في تنفيذ وظائفه.

طبيعة التزام المراقب: الرأي السائد في الفقه والقضاء هو أن التزام المراقب هو التزام بوسيلة وليس بتحقيق نتيجة، أي أنه التزام بسيط ببذل العناية.

درجة العناية المطلوبة: ودرجة العناية المطلوبة من المراقب هي العناية الواجبة أو العناية المعقولة *diligence Reasonable*، ويقصد بذلك، عناية المراقب المجتهد أو النشيط (رب الأسرة الحريص) ويتجه البعض إلى القول بأن العناية المطلوبة من المراقب هي عناية الرجل المعتاد في أداء عمله.

(٣) المسؤولية التأديبية لمراقب الحسابات:

تعتقد مسؤولية المراقب تأديبياً بسبب مخالفته للقانون أو اللائحة، أو أصول الصدق والأمانة والنزاهة وحسن السلوك والاستقامة والشرف، حتى ولو لم يكن هذا الفعل (الخطأ) مرتبطاً مباشرة المهنة، كما يتعرض المراقب للجزاء التأديبي في حالة ارتكابه خطأً مدنياً أو جنائياً، وتوقع الجزاء عليه لجنة مختصة بذلك قانوناً.

ويتمثل الجزء التأديبي في الإنذار، أو التوبيخ أو الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز سنتين، أو شطب الاسم من جدول النقابة.^(١)

الفرع الثاني

التفتيش على إدارة الشركة

قصد من هذا النظام الذي استحدثه قانون ١٩٥٤م وأبقى عليه قانون الشركات ١٩٨١، حماية مصلحة المساهمين، بعد أن ظهر مراراً تحكم أعضاء مجلس الإدارة أو عدد من كبار المساهمين في مصائر شركة المساهمة، ونظراً لضعف الإدارة الداخلية في حالات عديدة، فإنه يكون لهذا النظام أهميته في الكشف عن المخالفات الجسيمة التي تقع من أعضاء مجالس الإدارة أو المراقبين في أداء واجباتهم المقررة قانوناً أو في نظام الشركة.

وخشية أن يساء استعمال هذا النظام، فقد أحاط المشرع هذا الحق بجملة قيود تهدف إلى حماية أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين من كيد المساهمين وسعيهم إلى التشهير بهم.^(٢)

فوفقاً للمادة ١٥٨/١ من قانون الشركات، يكون للجهة الإدارية المختصة وللشركاء الحائزين على ٣٠٪ من رأس المال على الأقل بالنسبة إلى البنوك، و ١٠٪ من رأس المال على الأقل بالنسبة إلى غيرها من شركات المساهمة، أن يطلبوا التفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة، أو مراقبي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم التي يقرها القانون أو

النظام، متى وجد من الأسباب ما يرجح وجود هذه المخالفات وفق ما تقرره اللجنة المناط بها الفصل في طلب التفتيش.^(١)

ويقدم الطلب إلى وزير الاقتصاد الذي يشكل بقرار منه لجنة للنظر في الطلب يشترك في عضويتها مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات^(٢)، ويجب أن يكون مشتملاً على الأدلة التي يستفاد أو يرجح معها جدية الأسباب المقدمة من الطالبين والتي تبرر اتخاذ هذا الإجراء، لذلك يجب أن يرفق بالطلب الأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادة ٣٠٥ من اللائحة، وأن يودع معه - إن كان مقدماً من المساهمين - الأسهم التي يملكونها، ويستعاض عن هذا الإيداع الآن تقديم الوثيقة التي تسلمها شركة الإيداع والقيود المركزي بالتطبيق لأحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ (م ٢/٢٥).

وإذا اقتنعت اللجنة بوجهة نظر الطالبين - بعد سماع أقوالهم في جلسات سرية - فإنها تأمر بالتفتيش وتندب خبيراً أو أكثر لهذا الغرض، ويلتزم الطالبون بإيداع مبلغ تحدده اللجنة لحساب المصروفات، ويجب أن يشمل الإذن بالتفتيش الاطلاع على أية أوراق أو سجلات لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش.^(٣)

وتقوم اللجنة بدراسة تقرير الخبراء المنتدبين للتفتيش، وهنا لا يخرج الأمر عن أحد فرضين: (١) أن يتبين للجنة عدم صحة ما نسبته طالبوا التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات، وحينئذ فللجنة أن تأمر بنشر تقرير الخبير كله أو بعضه، أو الاقتصار على نشر نتيجته في إحدى الصحف اليومية، كما تلزم طالي التفتيش بنفقات ومصاريف الطلب مع تحملهم المسؤولية عن التعويض إن كان له مقتض.

(٢) أن تقتنع اللجنة بصحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين، وفي هذه الحالة يكون لها أن تأمر باتخاذ التدابير العاجلة وبدعوة الجمعية العامة على الفور للاجتماع، ويرأس اجتماعها في هذه الحالة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو أحد موظفيها الذي تختاره اللجنة، وللجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة أو رفع دعوى المسؤولية عليهم، بشرط أن يصدر قرارها بموافقة الشركاء الحائزين لنصف رأس المال، بعد استبعاد نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء المجلس، وللجمعية أن تقرر تغيير مراقبي الحسابات ورفع دعوى المسؤولية عليهم.^(٤)

ولا يجوز إعادة انتخاب المعزولين من أعضاء مجلس الإدارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم (م ١٦٠ / ٦ شركات).

المبحث الرابع مالية شركة المساهمة

وفقاً للمادة ٣٩ من قانون الشركات: يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام وتعد عنها قوائم مالية طبقاً لمعايير المحاسبة التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد، ولا يجوز، كأصل عام، أن تزيد السنة المالية للشركة عن اثني عشر شهراً فيما عدا السنة المالية الأولى. والحساب الختامي لكل سنة مالية من حياة الشركة هو الذي يدل على ما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً يمكن توزيعها على المساهمين من عدمه، ومن البدهي أنه لا يجوز أن يتم توزيع الأرباح إلا بعد تجنب الاستقطاعات التي ينص عليها القانون أو يحددها نظام الشركة، فيما يسمى بالاحتياطات.

وسوف نتناول، فيما يتعلق بمالية الشركة: كيفية تكوين المال الاحتياطي للشركة، ثم كيفية توزيع الأرباح والخسائر.

المطلب الأول

تكوين المال الاحتياطي للشركة

تلتزم شركات المساهمة -قانوناً- دون غيرها من الأشكال الأخرى للشركات - باقتطاع نسبة معينة من الأرباح لتكوين الاحتياطي، الذي يخطط لتغطية الخسائر التي قد تلحق الشركة في سنة ما أو لقضاء حاجاتها التي تظهر مستقبلاً، ومواجهة أزماتها ولتقوية ائتمائها، ويتنوع احتياطي الشركة ما بين احتياطي يفرضه القانون يسمى بالاحتياطي القانوني، واحتياطي ينص عليه في نظام الشركة يطلق عليه الاحتياطي النظامي، واحتياطي تقرره الجمعية العامة للشركة يعرف بالاحتياطي الاختياري أو الاحتياطي الحر.

أولاً: الاحتياطي القانوني:

يلتزم مجلس الإدارة بأن يجنب من صافي الأرباح جزءاً من عشرين (٥٪) على الأقل لتكوين احتياطي قانوني، ويقتطع الاحتياطي القانوني بنسبة ٥٪ من الأرباح الصافية كل عام حتى يصل إلى ما يساوي نصف رأس المال، فيجوز حينئذ للجمعية العمومية أن توقف هذا الاحتياطي^(١).

والاحتياطي القانوني ضمان تكميلي للضمان العام للدائنين، ويأخذ حكم رأس المال، فليس للشركة أن تتصرف فيه أو توزعه على المساهمين وفقاً لقاعدة ثبات رأس المال، ولكن لا

مانع من إدماجه كله أو بعضه في رأس المال (زيادة رأس المال) بإجراء تعديل نظام الشركة عن طريق صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة.^(١)

ثانياً: الاحتياطي النظامي:

يجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي^(١)، ويكون ذلك لتحقيق أغراض معينة يحددها النظام، كتجديد الآلات أو إقامة المباني أو استهلاك رأس المال وسندات الدين أو شراء حصص التأسيس.

ومتى نص النظام على هذا التخصيص فلا يجوز للجمعية العامة العادية تقرير استعمال هذا الاحتياطي في غير الأغراض المخصص لها، وإلا كان قرارها مشوباً بالبطلان لمخالفته النظام الأساسي للشركة، إذ لا تملك هذه الجمعية تعديل النظام الأساسي للشركة. أما إذا لم يكن الاحتياطي النظامي مخصصاً لغرض معين، فيجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة مشفوع بتقرير من مراقب الحسابات، أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين، بشرط ألا يكون قد سبق تخصيص الاحتياطي النظامي لأغراض معينة.^(١)

ثالثاً: الاحتياطي الاختياري أو الحر:

وفقاً للمادة (٦/٤٠ شركات)، يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تكوين احتياطات أخرى اختيارية.

ويختلف الاحتياطي الاختياري عن كل من الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي، في أنه احتياطي تقرره الجمعية العمومية العادية في سنة مالية معينة دون أن يلزمها به نظام الشركة، كما أن لها حرية التصرف فيه، وفي توزيعه في شكل أرباح على المساهمين عندما لا توجد حاجة إليه، أو إذا لم تحقق الشركة أرباحاً من نشاطها في سنة معينة، وليس للدائنين حق الاعتراض، إذ لا يدخل هذا الاحتياطي الحر في رأس المال، إلا أنه لا يجوز أن يقتطع جزء من الأرباح لتكوين احتياطي اختياري دون مبرر أو ضرورة - كمواجهة نفقات غير منظورة أو لتجديد آلات - حتى لا يضار المساهمون بحرماتهم من أرباح الشركة.

ومن المستقر عليه أن للجمعية العامة الحرية في ترحيل الاحتياطي، حتى ولو لم يكن النظام الأساسي يتضمن نصاً يبيح ذلك، وتعتبر الأرباح المرحلة في هذه الحالة بمثابة احتياطي حر ذي صفة مؤقتة.^(١)

الاحتياطي المستر أو غير المشروع:

ويعني الاحتياطي الذي قد يعتمد مجلس الإدارة إلى تكوينه، عن طريق تصوير ميزانية الشركة على خلاف الواقع، ويكون ذلك إما بتقدير الأصول بأقل من قيمتها الحقيقية، أو بالمبالغة في تقدير الخصوم، وذلك لدرء مخاطر الخسائر الكبيرة التي يمكن أن تلحق الشركة في سنوات مقبلة، أو لإخفاء أرباح كبيرة حققتها الشركة أو للتهرب من الضرائب المستحقة. وتكوين هذا الاحتياطي بهذه الطرق، أمر غير مشروع، ففيه حرمان للمساهمين من حصة من أرباحهم، كما أنه ضار بالمساهمين الذي يتنازل عن أسهمه بالبيع، حيث لا يحصل على قيمتها الحقيقية، وبناءً عليه يجوز للمساهمين أن يطلبوا توزيعه عليهم.

المطلب الثاني

توزيع الأرباح والخسائر

أولاً: توزيع الأرباح:

لا يخفى أن الغرض من قيام الشركة هو تحقيق الأرباح وتوزيعها على المساهمين أصحاب رأس المال، والأرباح الممكن توزيعها هي الأرباح الصافية، وهي التي تنتج عن مباشرة الشركة لعمليات معينة خلال السنة المالية بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، كفوائد ديون الشركة والضرائب وتجنّب الاحتياطي القانوني أو النظامي أو الاختياري، ويقتضي تحقيق الأرباح إعداد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.

وقد أدخل قانون ١١١ لسنة ١٩٦١م مبدأ اشتراك العاملين في الشركة في الأرباح تمشياً مع اعتبارات العدالة وربطاً بين العمل وبين تحقيق الربح، ويعطي هذا المبدأ حافزاً مادياً يعود بالخير على الشركة وعلى المساهمين أنفسهم، وفيه - أيضاً - تكريم لعنصر العمل وحفظ لأهميته واعتباره في مواجهة رأس المال، كما أن اشتراك العمال في الربح يعد متمماً لمبدأ اشتراكهم في الإدارة.

وقد أقر قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م هذا المبدأ في المادة (٤١)، ومع ذلك فقد عدل من قدر وكيفية توزيع الأرباح، خلافاً للقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٦١م والقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٦٢م.

وتقوم الجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بتحديد كيفية توزيع الأرباح الصافية، بعد احتساب كافة الاستهلاكات والمبالغ المخصصة للاحتياطي القانوني أو النظامي،

وخصم التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح على مختلف أصحاب الحقوق وهم المساهمون، وأصحاب حصص التأسيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويكون ذلك بعد إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر^(١)، وذلك طبقاً للأحكام التالية:

١- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى في الأرباح، قدرها ٥ % على الأقل من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى^(٢).

٢- يخصص بعد ما تقدم نسبة معينة من الأرباح لا يجوز أن تزيد على ١٠٪ لحصص التأسيس^(٣)

٣- يخصص بعد ما تقدم نسبة من الأرباح لا يجوز أن تزيد على ١٠٪ لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة^(٤)

٤- ويوزع الباقي بعد ذلك من الأرباح على المساهمين وعلى العاملين كحصة إضافية. ومع ذلك فإنه يعمل بنظام توزيع الأرباح في الشركات القائمة في أول إبريل ١٩٨٢م متى كان أفضل مما ورد بالمادة ٨٨ (م ١٩٦ من اللائحة).

اشترك العاملين في الأرباح:

تنص المادة ٤١ من قانون الشركات على أنه: "يكون للعاملين في الشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن ١٠٪ من هذه الأرباح، ولا تزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة الـ ١٠٪ المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع"

وبناء على ذلك فقد نصت المادة ٢/١٩٦ من اللائحة على أنه: "إذا كان النظام يحدد للعاملين نصيباً في الأرباح يزيد على ١٠٪ ولا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين في الشركة، جنب نصيب العاملين في الزيادة على ١٠٪ في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين، ويجوز توزيع مبالغ منه على العاملين في السنوات التي لا تتحقق فيها أرباح بسبب خارج عن إرادة الشركة، أو استخدامه في إنشاء مشروعات إسكان أو خدمات تعود عليهم بالنفع، وذلك كله وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال."

والملاحظ أن قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م يضمن حداً أدنى للعاملين هو ١٠٪ من الأرباح وبحد أقصى هو مجموع أجورهم السنوية. وبذلك يكون قد وضع العاملين في مركز أسوأ من

قانون رقم ١١١ لسنة ١٩٦١م، الذي كان يخصص لهم ٢٥٪ من أرباح شركة المساهمة، وطبقاً لقانون ١٩٨١م فإن ما يزيد عن الـ ١٠٪ من الأرباح يصبح خاضعاً لمشئعة الجمعية العمومية. كما يلاحظ أن قانون ١٩٨١م يفضل في هذا الشأن قانون الاستثمار رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤م، الذي ترك تحديد نصيب العاملين في الأرباح لقرار يصدر من الجمعية العامة، دون تحديد حد أدنى لها (م ١/١٢).^٥

ويجوز للشركة شراء بعض أسهمها لتوزيعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم في الأرباح.^٥ هذا والمقرر أن حق كل من المساهم والعامل في اقتضاء الأرباح ينشأ من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها، وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار (أي من تاريخ نشأة الحق في الربح). ولا يلزم المساهم أو العامل برد الأرباح التي قبضها - على وجه يتفق مع أحكام هذا القانون - ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.^٥

بطلان توزيع الأرباح الصورية:

يعتبر رأس المال المصدر (وكذلك الاحتياطي القانوني أو النظامي) بمثابة الضمان العام لدائني الشركة، ومن ثم يحرم على الشركة توزيعه في شكل أرباح صورية، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ ثبات رأس المال، ويعتبر من الجرائم المعاقب عليها قيام مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على خلاف القانون وكذلك مصادقة مراقب الحسابات على مثل هذا التوزيع (م ٥/١٦٢).

لذلك فإنه لا يجوز توزيع الأرباح إذا ترتب على ذلك منع الشركة من الوفاء بالتزاماتها النقدية في مواعيدها، ويكون لدائني الشركة أن يطالبوا من القضاء بإبطال أي قرار مخالف للأحكام السابقة، ويكون أعضاء مجلس الإدارة الذين وافقوا على التوزيع مسئولين على وجه التضامن قبل الدائنين في حدود مقدار الأرباح التي أبطل توزيعها، كذلك يجوز للدائنين الرجوع على المساهمين الذين علموا بأن التوزيع قد تم بالمخالفة لحكم المادة ٤٣ من القانون، وذلك في حدود الأرباح التي قبضوها.

وهكذا، فإنه يجب أن يكون توزيع الأرباح نتيجة لزيادة فعلية في أصول الشركة عن خصومها، وليس من رأس المال في شكل أرباح صورية.

ثانياً: توزيع الخسائر:

إذا منيت الشركة بخسائر، فلها تغطيتها من الاحتياطي، فإذا ما استمرت الخسائر ونقص الاحتياطي وبدأ رأس المال في التناقص، فإنه لا يجب أن يتجاوز هذا النقص نسبة معينة يحددها نظام الشركة، فإذا نقص رأس المال إلى هذه النسبة، كان من الواجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية لتقرر إما الاستمرار وإما حل الشركة وتصفيتها، وتوزيع الخسائر عند التصفية على جميع المساهمين، وفقاً لما جاء في نظام الشركة من قواعد، بشرط ألا يتجاوز الخسارة قيمة الأسهم التي يحوزها المساهم.

ووفقاً لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م، إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.^(١)

المبحث الخامس:

انقضاء شركة المساهمة

أسباب الانقضاء:

أولاً: أسباب الانقضاء العامة:

تنقضي شركة المساهمة متى قام بشأنها أحد الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء كافة الشركات، وغني عن البيان أن شركة المساهمة لا تنقضي بداهة لأسباب ترجع إلى شخص أحد الشركاء المساهمين كوفاته أو الحجر عليه أو إعساره، فهذه الشركة لا تقوم - كما سبق - على الاعتبار الشخصي، بل على الاعتبار المالي، لذلك فإنها لا تنقضي بالإرادة المنفردة لأحد المساهمين، فإذا رغب مساهم معين في الخروج من الشركة، كان أمامه أن يبيع ما يمتلك من أسهم فتتقطع صلته بالشركة دون تأثير على استمرار قيامها.

بينما تنقضي شركة المساهمة بقوة القانون بالأسباب العامة لانقضاء الشركات كانهاء مدة الشركة، أو انتهاء الغرض الذي قامت من أجله (م ٥٢٦ مدني) أو هلاك رأس المال أو معظمه قبل انتهاء مدتها بحيث لا تستطيع الشركة الاستمرار في عملها بسبب الخسارة (م ١/٥٢٧ مدني، م ٦٩ من قانون ١٩٨١).

كذلك تنقضي شركة المساهمة بسبب التأميم، أي انتقال ملكية الأسهم إلى شخص واحد هو الدولة، وتحول الشركة الخاصة إلى "شركة قطاع عام".

وتنقضي الشركة - أيضاً - بصدر حكم قضائي بحلها بناء على طلب أحد الشركاء إذا وجد مسوغ يبرر ذلك^(١)، كالعداء الحاد المستحكم بين أعضاء مجلس الإدارة أو سوء التفاهم المستحكم بين المساهمين بصورة تجعل من غير الممكن إيجاد نوع من التعاون فيما بينهم، على أن هذا غير متصور عملاً إلا بالنسبة لشركات المساهمة الصغيرة.

ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر حل الشركة قبل حلول الأجل المعين لها في نظامها الأساسي (تقصير مدة الشركة)، ويكون ذلك صدور القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع^(٢).

ثانياً: الاندماج:

وتنقضي شركة المساهمة - مع استمرار المشروع الذي تضطلع به - باندماجها مع شركة أخرى، والاندماج هو فناء شركة داخل أخرى أو فناء شركتين أو أكثر لتتألف منهما شركة جديدة تندمج فيها الشركات القائمة. ويتم الاندماج باتفاق الشركتين المندجتين، ويلزم لذلك صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الاندماج، لأن العملية إما أن تتضمن انقضاء قبل الميعاد بالنسبة للشركتين معاً، وإما أن تتضمن انقضاء إحداها قبل الميعاد وزيادة رأس مال الأخرى^(٣).

ووفقاً للمادة (١٣٠) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، المعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨، يشترط أن يتم الاندماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية لكل من الشركتين، وأن يصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة ١٨ من القانون (وهي لجنة طلبات إنشاء الشركات)، وتعتبر الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفاً للشركات المندجة، وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها، وذلك في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج، مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين^(٤).

وعلى هذا يتم الاندماج بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين المندجة والمندمج فيها أو من جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال بحسب الأحوال، ويجوز للمساهمين الذين اعترضوا على قرار الاندماج في الجمعية أو لم يحضروا الاجتماع بعذر مقبول، طلب التخارج من الشركة واسترداد قيمة أسهمهم وذلك بطلب كتابي يصل إلى الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شهر قرار الاندماج، ويتم تقدير قيمة الأسهم أو الحصص بالاتفاق، أو بطريق القضاء، على أن يراعى في ذلك القيمة الجارية لكافة أصول الشركة، ويجب أن تؤدي

القيمة غير المتنازع عليها للأسهم أو الحصص المتخارج عنها إلى أصحابها قبل تمام إجراءات الاندماج، ويحكم القضاء بالتعويضات لأصحاب الشأن إن كان لها مقتضى، ويكون للمبالغ المحكوم بها امتياز على سائر موجودات الشركة المندمجة.^(١)

ثالثاً: انتفاء ركن تعدد الشركاء:

وتعتبر شركة المساهمة منحلة بحكم القانون إذا نزل عدد الشركاء فيها إلى أقل من ثلاثة، وذلك ما لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب، ففيما عدا شركة الشخص الواحد، لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة، فإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون ما لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب، أو يطلب من بقي من الشركاء خلال هذا الأجل تحويلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد، ويكون من بقي من الشركاء مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة".^(٢)

رابعاً: الخسارة المؤثرة على رأس المال:

القاعدة العامة أن تنقضي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها، وتنطبق هذه القاعدة على الشركات كافة، أياً كان شكلها القانوني، لكن المشرع رأي، مع ذلك، أن يفرد شركة المساهمة -بحكم خاص- نظراً لأهميتها وحفاظاً منه على حقوق دائئيتها- مؤداه النظر في حل الشركة متى بلغت خسائرها نسبة معينة من رأس المال. فنص على أنه، إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.^(٣)

وعلى ذلك لا يصح الانتظار حتى هلاك جميع أموال الشركة لتقرير حلها، بل ينبغي متى بلغت نسبة الخسائر نصف رأس المال، المبادرة إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للتداول في مصير الشركة. وهي مقيدة، في هذا المقام، بأحد أمرين: إما حل الشركة، وإما الإبقاء عليها. فإن قدرت استمرار الشركة عليها إعادة رأس المال إلى أصله إما بالاقتطاع من الاحتياطات المتوفرة لديها، احتراماً لمبدأ ثبات رأس المال وعدم جواز المساس به، وإما بتخفيض رأس المال بنسبة الخسارة إذا لم تتمكن من جبره لعدم كفاية ما لديها من احتياطات متراكمة.

وإذا كان المشرع قد أعطى للجمعية العامة غير العادية رخصة تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجبارياً، فلا يعني ذلك أنه ترك لها مطلق الحرية في إحداث التغيير على

النحو الذي تراه، بل قصد، في اعتقادنا، منحها سلطة تقديرية تستعملها على ضوء ظروف الواقع بشرط ألا تتجاوز حدود النسبة التي قررها القانون، ذلك أن المشرع - بعد أن رخص للجمعية، بمقتضى نص الفقرة "ج" من المادة ٦٨ من القانون، تغيير النسبة الموجبة لحل الشركة - عاد فحدد في المادة التي تليها، وهي المادة ٦٩، هذه النسبة بمقدار نصف رأس المال المصدر.^(١)

ومما لا شك فيه أن ورود مسألة التغيير بهذا الترتيب يدل على انصراف نية المشرع إلى وضع قاعدة عامة مفادها اختصاص الجمعية العامة غير العادية بسلطة تحديد نسبة الخسارة المفوضة إلى حل الشركة، وإلى ضبط هذه القاعدة بتقييد سلطة الجمعية بنسبة معينة، تعتبر بمثابة حد أعلى لا يصح تجاوزه بحال من الأحوال.

وفي عبارة موجزة تعتبر النسبة التي حددها القانون قاعدة متعلقة بالنظام العام، بحيث يقع باطلاً وكأن لم يكن، أي نص في النظام الأساسي أو قرار من الجمعية العامة غير العادية يقضي بتحديد نسبة أعلى منها. فالمسموح به، إذن، هو تغيير النسبة المؤدية إلى حل الشركة بالخفض لا بالزيادة.

والتفسير المتقدم هو الذي يحقق، في نظرنا، الحماية لدائني الشركة لأن زيادة النسبة على الحد الذي قرره القانون فيه تحديد للدائنين، خاصة وأن رأس المال هو الحد الأدنى من الضمان الذي يعولون عليه في استيفاء حقوقهم.

هذا ويجب على مجلس الإدارة من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب مقدم من عدد من المساهمين يمثلون ١٠٪ من رأس المال، أن يقوم بدعوة الجمعية للانعقاد للنظر في أمر حل الشركة أو استمرارها، فإن تقاعس عن ذلك كان للجهة الإدارية المختصة توجيه هذه الدعوة.

فإذا لم تنعقد الجمعية بسبب عدم اكتمال النصاب أو لم تستطع التداول واتخاذ القرار المناسب، ويكون لكل ذي مصلحة الحق في اللجوء إلى القضاء الذي يقرر، على ضوء ظروف الواقع، إما حل الشركة أو استمرارها، هذا فضلاً عن مساءلة أعضاء مجلس الإدارة.^(٢)

الفصل الرابع

الشركات ذات الطبيعة المختلطة

الشركات ذات الطبيعة المختلطة، هي تلك الشركات التي تقوم على أساس كل من الاعتبار الشخصي والاعتبار المالي في نفس الوقت، فهي تحتل مركزاً وسطاً بين شركات الأشخاص وشركات الأموال، وتندرج كل من شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة تحت هذا النوع من الشركات.

وسوف نتناول في دراستنا لهذه الشركات وفي بحثين متتاليين كلاً من: الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة التوصية بالأسهم.

المبحث الأول

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تمهيد:

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي تلك الشركة التي تضم مجموعة محدودة من الشركاء الذين لا يكتسبون صفة التاجر، ويكون كل منهم مسئولاً عن ديون الشركة في حدود حصته في رأس المال ولا يتجاوزها إلى أمواله الخاصة.

ونظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعتبر نظاماً مبتكراً Original يجمع بين مزايا شركات الأشخاص ومزايا شركات الأموال، دعت إليه الرغبة في مواجهة الضرورات العملية، وتمكين أرباب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين تقوم فيما بينهم علاقات شخصية أو روابط عائلية، من تحديد مسؤوليتهم عن ديون الشركة، واحتفاظهم في نفس الوقت بحق المساهمة الجدية في إدارة المشروع والرقابة عليه، وقد ظهرت لأول مرة في ألمانيا عام ١٨٩٢، تفادياً لصرامة قواعد تأسيس شركات المساهمة، حيث تم تفضيلها كشكل للشركات التي تتأسس فيما بين أفراد العائلة الواحدة أو فيما بين الأصدقاء.

وقد لاقى هذا الشكل من الشركات قدراً كبيراً من النجاح نظراً للمزايا التي يوفرها للشركاء، فهو يسمح لهم بتأسيس المشروعات الصغيرة أو المتوسطة دون تحملهم بالمسؤولية التضامنية والشخصية عن ديونها، ودون اضطرارهم إلى تأسيس الشركات المساهمة، بما تتطلبه من إجراءات طويلة باهظة التكلفة، ودون أن يمتنع عليهم، كما هو الشأن في نطاق شركات التوصية بنوعيتها وذلك بالنسبة للشركاء الموصين، التدخل الإيجابي في إدارة المشروع، كذلك فإن اتباع هذا الشكل

يطمئن الشركاء إلى استمرار الشركة مغلقة Fermé عليهم. وعدم إدخال أشخاص غرباء عنهم. (سنرى فيما بعد أن حصص الشركاء غير قابلة للتداول بالطرق التجارية). كما أنه يمكن، من خلال اتباع نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الإبقاء على المشروعات الصغيرة أو المتوسطة التي قد تكون مزدهرة ثم يطرأ على مؤسسيها ما يحول دون الاستمرار في قيامهم على شئونها، بسبب التقاعد أو المرض أو الوفاة مثلاً، وذلك مع عدم الإضرار إلى تصفيتها أو انتقالها إلى الغير.

وعلى الرغم من هذه المزايا التي تتمتع بها الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فإنه لا يمكن أن يخفي ما يقابلها من عيوب على جانب كبير من الخطورة، فالشركة تتميز بأن كافة شركائها محدودو المسؤولية عن ديونها، كما هو الشأن بالنسبة للشركات المساهمة، إلا أن هذا التحديد وإن كان مفيداً بالنسبة للشركاء، فإنه غير مستحب في كافة الأحوال، ذلك أنه يشجع الشركاء على التسرع والاندفاع والقيام بصفقات خطيرة، اعتماداً على تحديد مسؤوليتهم وعدم تعرضهم لشهر الإفلاس.

إلا أن العيب الرئيسي لهذه الشركات يبقى هو ضعف الائتمان الذي تتمتع به، فالشركة لا يتوافر لديها عادة رأس مال ضخم، يكون ضماناً كافياً لحقوق الدائنين، ويعوضهم عن الضمان القوي المستمد من مسؤولية الشركاء الشخصية والتضامنية في نطاق شركات التضامن، والذي تفتقده هذه الشركة، وعادة ما لا تتجاوز قيمة الحصص الحد الأدنى القانوني بحيث يكون رأس مال الشركة بسيطاً للغاية، لا يتماشى مع النشاط الذي تقوم به، ومن هنا فقد كشف العمل عن ارتفاع نسبة الشركات من هذا النوع التي أشهر إفلاسها ولم تكف أصولها لسداد حقوق دائنيها.

ومن الناحية العملية، كثيراً ما تشترط البنوك لتقديم ائتمان للشركة، أن يتعهد مديرها شخصياً بضمان ديون الشركة بأكملها في أمواله الخاصة، وبذلك تحولت الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة توصية، يحتل فيها المدير مركز الشريك المتضامن، وفقد بالتالي ميزة تحديد المسؤولية، وإلى جانب ما سبق فقد كشف العمل أيضاً أن كثيراً من هذه الشركات مجرد شركات وهمية، حيث قد استغلها البعض لتحديد مسؤوليتهم، رغم أنها في حقيقة الأمر مجرد مشروعات فردية، وهو ما كان يحرمه التشريع الفرنسي وغيره من التشريعات التي أخذت بهذا النظام.

وقد نظم المشرع المصري هذا النوع من الشركات لأول مرة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤م، وذلك بالمواد من ٦٣-٨٦ منه. كما احتفظ به قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م، ونظمه في المواد من ١١٦ إلى ١٢٩ منه.

وسوف نتناول بالدراسة أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقاً لنفس الخطة السابق اتباعها، فنعرض لتعريف الشركة وخصائصها، ثم تأسيسها وتمويلها، فضلاً عن إدارتها، وأخيراً نعرض لانقضاء الشركة، ونخصص لكل من هذه الموضوعات مطلباً مستقلاً.

المطلب الأول

التعريف بالشركة ذات المسؤولية المحدودة وخصائصها

تعرف المادة الرابعة من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها: "شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسؤولاً إلا بقدر حصته، ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقاً للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة، فضلاً عن الشروط المقررة في هذا القانون. وللشركة أن تتخذ اسماً خاصاً، ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من غرضها، كما يجوز أن يتضمن اسمها اسم شريك أو أكثر".

ومن هذا التعريف، تتضح لنا الخصائص الأساسية التي تتمتع بها الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الأمر الذي نتناوله فيما يلي:

خصائص الشركة:

ثار الخلاف حول طبيعة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فذهب رأي إلى اعتبار هذه الشركة من شركات الأموال، استناداً إلى أن الحصص التي يقدمها الشركاء، يكون لها الاعتبار الأول، أما الرأي الآخر، فيعتد أساساً بالطابع الشخصي للشريك، ولذلك فهو يعتبرها من شركات الأشخاص، بحيث تعتبر أحكام شركات الأشخاص هي الشريعة العامة بالنسبة لهذا النوع من الشركات.

وفي واقع الأمر، فإن هذه الشركة تعتبر من طبيعة مختلطة، فهي في مركز وسط بين شركات الأموال والأشخاص. وترتيباً على ذلك، يجب عند خلو القانون من تنظيم إحدى المسائل

المتعلقة بهذا النوع من الشركات، الرجوع بشأنها، إما إلى أحكام شركات الأموال أو الأشخاص، تبعاً لما إذا كانت المسألة يغلب عليها الطابع المالي أو الشخصي.

ويلاحظ أن المشرع، بتنظيمه الشركة ذات المسؤولية المحدودة في إطار قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، يكون قد انحاز إلى تصنيفها في عداد شركات الأموال، حيث أخضع إجراءات تأسيسها لذات الإجراءات الصارمة الخاصة بتأسيس شركات المساهمة، مع بعض الاختلافات البسيطة، وبإلزامه المؤسسين بإيداع كامل قيمة جميع الحصص في حساب يفتح باسم الشركة تحت التأسيس بأحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير المختص، مع عدم جواز السحب منه إلا بعد تقديم من ينوب عن الشركة ما يفيد إشهار نظامها في السجل التجاري^(١)، كما أجاز المشرع عزل المديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في جميع الأحوال، دون أن يؤثر هذا العزل في حياة الشركة^(٢)، كما تطبق ذات القواعد الخاصة بالجمعية العامة في شركات المساهمة على الجمعية العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة (المادة ١٢٦ من القانون)، وكذلك الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات (المادة ١٢٨ من القانون)^(٣).

ومع الوضع في الاعتبار كافة ما تقدم، فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتميز عن غيرها من الشركات التي ينظمها القانون بالخصائص الآتية:

١- قلة عدد الشركاء:

يضع التشريع المصري، أسوة بغيره من التشريعات الأجنبية، حداً أقصى لعدد الشركاء لا يجوز تجاوزه، وقد أوجب ألا يزيد عددهم على خمسين شريكاً، ويقصد بهذا الشرط الإبقاء على الاعتبار الشخصي فيما بين الشركاء، إلى جانب استخدام هذا الشكل كإطار قانوني للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة.

وعلى عكس ما كان عليه الوضع في ظل القانون الملغي رقم (٢٦ لسنة ١٩٥٤) لا يشترط أن يكون الشركاء جميعاً من الأشخاص الطبيعيين، إذ لا خلاف في أن تشريع الشركات الحالي يميز أن يكون الشخص المعنوي شريكاً في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وطبقاً لما هو مقرر في القواعد العامة للشركات، فضلاً عما يقضي به نص المادة ٨ من قانون الشركات، المعدلة بمقتضى قانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨، وفيما عدا حالة تكوين شركة الشخص الواحد، لا يجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن اثنين،

كما أنه يكفي توافر هذا الشرط حتى ولو كان الشريكان زوجين (زوج وزوجة)، ولا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً.

٢- تحديد مسؤولية الشركاء:

تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأن مسؤولية جميع الشركاء فيها محدودة بمقدار حصتهم في رأس المال، فالشركاء، رغم توافر الاعتبار الشخصي فيما بينهم، غير مسؤولين عن ديون الشركة بصفة شخصية وعلى وجه التضامن، بل هناك حد أقصى لمسؤوليتهم، هو مقدار الحصة التي قدمها كل منهم في رأس المال. وترتيباً على ذلك، فإن ذمة الشركة وحدها تكون ضامنة لحقوق دائيها، دون ذم الشركاء، ويكون هؤلاء في مأمن من أي رجوع عليهم طالما قاموا بأداء قيمة هذه الحصص، ومن الثابت أن تحديد مسؤولية الشريك تعتبر الميزة الجوهرية لهذا النوع من الشركات، وهي التي اشتق منها اسمها.

واستناداً إلى هذه المسؤولية المحدودة للشركاء، فإن مصير الشركة لا يرتبط بمصير الشركاء، فعلى الرغم من أن الاعتبار الشخصي للشريك يعتبر من خصائص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، مثلها في ذلك مثل شركات الأشخاص، إلا أنها، رغم ذلك، لا تنقضي عند وفاة أحد الشركاء، أو إفلاسه، أو إعساره، أو الحجر عليه، حيث تنتقل حصة من يتوفى من الشركاء إلى ورثته أو الموصى لهم (١٨م/٥ من القانون)، على أن يؤخذ في الاعتبار النصاب القانوني لعدد الشركاء (خمسون شريكاً) تطبيقاً لنص المادة الرابعة من القانون.

ويترتب على مسؤولية الشريك المحدودة، أنه لا يكتسب كقاعدة صفة التاجر، ولذلك لا يشترط أن يتوافر في شأنه الأهلية التجارية، كما أنه يجوز للولي أو الوصي أن يستثمر أموال القاصر في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وذلك كله على الرغم من أن دخول الشريك في الشركة التجارية يعتبر عملاً تجارياً من جانبه، كذلك فإن شهر إفلاس الشركة، لا يترتب عليه شهر إفلاس الشريك، فضلاً عن أن شهر إفلاس أحد الشركاء لا يؤثر على حياة الشركة، ولا يترتب عليه انقضاؤها، كما سيلبي.^(١)

ويستثنى من قاعدة المسؤولية المحدودة للشركاء في شركة المسؤولية المحدودة حالات معينة تصبح فيها مسؤولية الشركاء شخصية، وهذه الحالات هي:

أ- إذا ثبت أن القيمة المقدرة للحصة العينية في عقد الشركة أكبر من قيمتها الحقيقية، فإذا ثبت وجود زيادة في هذا التقدير وجب أن يؤدي الفرق نقداً إلى الشركة، ويسأل باقى الشركاء بالتضامن عن أداء هذا الفرق، إلا إذا أثبتوا عدم علمهم بذلك.^(١)

ب- إذا قل عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن النصاب المقرر قانوناً-وهو شريكاً على الأقل- يكون من بقي من الشركاء مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة، وتظل هذه المسؤولية قائمة ما لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب، أو يطلب من بقي من الشركاء خلال هذا الأجل تحويلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد.^(٢)

ج- إقرار المسؤولية المطلقة في المال الخاص بحق كل من تصرف باسم الشركة بالمخالفة للأحكام التي قررتها المادة السادسة من قانون الشركات، والتي توجب أن تحمل جميع العقود والفواتير والأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التي تصدر عن الشركة، عنوان الشركة ويبين فيها نوعها قبل العنوان أو بعده، وذلك بحروف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسى وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته في آخر ميزانية.^(٣)

٣- حظر الالتجاء إلى الاكتتاب العام أو إصدار صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية:

القاعدة أنه لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة رأس مالها أو الحصول على القروض اللازمة لها عن طريق الاكتتاب العام (م ٢/٤ شركات). كذلك لا يجوز للشركة إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، ومن هذه الناحية، تقترب الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شركات الأشخاص، حيث يحظر قانوناً عليها القيام بمثل تلك التصرفات. والهدف من تقرير هذا الحظر، هو الرغبة في استبعاد المضاربة على صكوكها، بسبب ما تقدمه من ضمان محدود، فضلاً عن تعذر معرفة حقيقة مركزها المالي.

٤- تقييد التنازل عن الحصص وخضوعه لحق الاسترداد:

على الرغم من تحديد مسؤولية الشركاء، وهو ما يقرب الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شركات الأموال، فإنها تتميز عن هذه الأخيرة، بأن حصص الشركاء فيها لا يجوز أن تتخذ شكل أوراق مالية، أسهم أو سندات إسمية أو للحامل، قابلة للتداول بالطرق التجارية، ومع ذلك، يجوز التنازل عنها بشروط معينة، وقد تضمنت هذا الحكم صراحة الفقرة الأولى من المادة ١١٨ من قانون الشركات، التي تجيز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمي أو عري مصدق على التوقيعات

الواردة به، إلا أن ينص في نفس عقد تأسيس الشركة على ما يخالف ذلك، بمعنى أنه يجوز النص في العقد التأسيسي على إخضاع التنازل لموافقة الشركاء الإجماعية، أو على مجرد موافقة الأغلبية. هذا، وحفاظاً على الطابع الشخصي للشركة، فقد خول القانون للشركاء حق استرداد الحصة المباعة بنفس الشروط التي بيعت بها، كما ألزم من يعتزم بيع حصته، أن يبلغ سائر الشركاء-عن طريق المديرين- بالعرض الذي وجه إليه، فإذا انقضى شهر من تاريخ إبلاغ العرض دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد، يكون الشريك الراغب في البيع حراً في التصرف في حصته، فإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك، قسمت الحصة المباعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، على أنه يجوز للشركاء فيما بينهم أن يتداولوا حصصهم في الشركة، كلها أو بعضها، وفي هذه الحالة، لا يكون للباقيين الحق في الاسترداد، إلا إذا نص العقد صراحة على جواز ذلك.^(١)

٥- اسم وعنوان الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم خاص بها، وقد كان المنطق يقتضي ألا يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة عنوان يتركب من أسماء الشركاء فيها، على غرار العنوان في شركتي التضامن والتوصية البسيطة، نظراً لمسئولية الشريك المحدودة عن التزامات الشركة، إلا أن المشرع لم يلتزم هذا المنطق وأجاز للشركة أن تختار اسماً لها مستمداً من غرضها، أو أن تتخذ عنواناً يضم اسماً واحداً أو أكثر من شركائها (م ٣/٤ من القانون).

ولا شك أن هذا الوضع يكون من شأنه أن يوقع الغير في لبس حول حقيقة التزام الشركاء الواردة أسمائهم في عنوان الشركة، فيتعاقد مع الشركة ويوليها ثقته وبنحها ائتمانه معتقداً في مسئوليتهم المطلقة والشخصية عن التزاماتها، ثم يفاجأ بمسئوليتهم المحدودة عن أعمال الشركة وعقودها، ومعالجة لهذا الوضع فقد قرر المشرع ضرورة أن تحمل جميع العقود والفواتير والأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التي تصدر عن الشركة، عنوان الشركة ويبين فيها نوعها قبل العنوان أو بعده، وذلك بحروف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسي وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته في آخر ميزانية.^(٢)

المطلب الثاني

تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تمهيد:

يشترط لصحة تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، توافر كافة الأركان اللازمة لتأسيس أي شركة أخرى، سواء من حيث الأركان الموضوعية العامة، أو من حيث الأركان الموضوعية الخاصة، هذا إلى جانب وجوب توافر الشروط الشكلية، وهي الكتابة والشهر، طبقاً لما يتطلبه القانون في هذا الخصوص، وفضلاً عما سبق، فقد اختص المشرع تأسيس هذا النوع من الشركات بأحكام خاصة، سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية، وسوف سنقتصر في هذا المقام على دراسة تلك الأحكام، أما فيما عدا ذلك، فيحال في شأنه إلى أحكام القواعد العامة للشركات السابق لنا دراستها.

الفرع الأول: الشروط الموضوعية الخاصة^(١)

١-تعدد الشركاء:

(أ) الحد الأدنى لعدد الشركاء:

قدمنا أنه، فيما عدا شركة الشخص الواحد، لا يجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن اثنين (م ١/٨ من قانون الشركات)، ويجب - كقاعدة - توافر الحد الأدنى لعدد الشركاء طوال فترة حياة الشركة، ذلك أن هذا الشرط، لا يعتبر مجرد شرط لصحة تأسيس الشركة، بل يعتبر شرطاً لبقائها واستمرارها كذلك. وقد نصت المادة ٢/٨ من القانون على أنه: "إذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور في الفقرة السابقة (شريكاً)، اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون دون توقف ذلك على طلب ذوي الشأن.

ومع ذلك، فقد خفف المشرع من شدة حكم هذا النص، بأن أجاز للشركة استكمال النصاب خلال ستة أشهر على الأكثر من وقوع النقص، وذلك مع تشديد مسؤولية الشريك الباقي في الشركة خلال فترة النقص، بحيث يكون مسئولاً في جميع أمواله عن كافة التزامات الشركة، بمعنى أن تحديد المسؤولية يتوقف خلال فترة النقص، وتحل محلها المسؤولية المطلقة للشريك الذي تجتمع في يده كافة الحصص، وذلك إلى حين استكمال النقص أو تحولها لشركة من شخص واحد، ويتأكد بقاء الشركة، ومن هذا التاريخ تعود للشريك مسؤوليته المحدودة (المادة ٨ من القانون - المعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ - و المادة ٦٠ من اللائحة).

وعلى هذا فإن اجتماع الحصص في يد شريك واحد لا يترتب عليه حل الشركة بقوة القانون، وفقاً للمادة (٨) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ (المعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨) إلا إذا لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب على النحو السابق، أو يطلب من بقي من الشركاء خلال هذا الأجل تحويلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد، ويكون من بقي من الشركاء مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة".^(١)

(ب) الحد الأقصى لعدد الشركاء:

يحدد القانون الحد الأقصى لعدد الشركاء بخمسين شريكاً، (المادة ٤ من القانون، والمادة ٢/٦٠ من اللائحة). وهو ما ينسجم مع الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه الشركة، كما يؤكد ذلك رغبة المشرع في قصر هذا النظام على المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، إلا أنه من الجائز أن يزيد العدد، لسبب أو لآخر عن خمسين شريكاً، وفي هذا الفرض، يخير القانون الشركاء بين اتباع أحد حلين: إما أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكام القانون في هذا الشأن خلال مدة سنة من تاريخ تحقق الزيادة، أو أن يتخذوا إجراءات تغيير شكل الشركة إلى شركة مساهمة، وفي حالة عدم القيام بأي من هذين الحلين، يكون لكل ذي مصلحة حق المطالبة بحل الشركة قضاء.^(٢)

٢- غرض الشركة:

للشركة، كقاعدة، حرية القيام بأي نوع من أنواع النشاط التجاري أو المدني بشرط أن يكون مشروعاً، ومع ذلك، فقد حظر المشرع على هذا النوع من الشركات القيام ببعض أنواع النشاط الذي يحتاج إما إلى رؤوس أموال ضخمة أو إلى ائتمان قوي، وهو ما لا تحققه الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بسبب تحديد مسؤولية جميع الشركاء، فضلاً عن ضالة رأس مالها إذا ما قورنت بالشركة المساهمة، وعلى هذا المعنى نصت صراحة المادة (٥) من القانون، بقولها: "لا يجوز أن تتولى الشركة أعمال التأمين أو البنوك أو الادخار، أو تلقي الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير بوجه عام".

٣- رأس مال الشركة:

يتكون رأس مال الشركة من مجموع الحصص التي يكتب فيها الشركاء، ويعتبر هو الضمان الوحيد لحقوق الدائنين، ويرجع السبب في ذلك، فضلاً عن تحديد مسؤولية جميع الشركاء، إلى ضالة رأس مالها إلى حد كبير.

وقد سبق أن أشرنا إلى أن العيب الرئيس لهذه الشركات هو ضعف الضمان الذي تقدمه للغير، ولذلك فقد اضطر المشرع، خشية تأسيس شركات من هذا النوع برؤوس أموال منخفضة لا تكفي لضمان حقوق دائئيتها، إلى تطلب حد أدنى لرأس المال لا يجوز في أي وقت النزول عنه، ضماناً لجدية المشروع وتوفير حد أدنى من الضمان يمكن الدائنين من التعويل عليه. وقد أحال القانون إلى اللائحة التنفيذية في تحديد الحد الأدنى لرأس المال. وقد نصت المادة ٢٧١ من اللائحة على أنه: "لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه"، ومقتضى ذلك أنه يجوز تعديل الحد الأدنى لرأس المال دون حاجة لتعديل عقد الشركة نفسه كلما دعت الظروف الاقتصادية إلى ذلك، ويعتبر هذا الحكم من مظاهر تبسيط إجراءات تأسيس هذا النوع من الشركات، وهو ما حرص عليه المشرع في ظل قانون الشركات الحالي رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

هذا، ومن حق الشركاء دائماً، زيادة أو تخفيض رأس المال خلال حياة الشركة، وذلك باتباع الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الأحوال، إلا أنه لا يجوز أن يقل رأس المال في أي وقت عن خمسين ألف جنيه، درءاً للتحايل على أحكام القانون، أما إذا انخفض رأس المال عن هذا الحد، بسبب لا يرجع لإرادة الشركاء، وجب عليهم إما اتخاذ إجراءات زيادته وإعادةه إلى هذا النصاب خلال مدة سنة من تاريخ هبوطه، أو تغيير شكل الشركة إلى نوع آخر من الشركات التي لا تشترط حداً أدنى لرأس مالها، فإذا لم يقم الشركاء بذلك، يكون لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة بحكم من القضاء.^(١)

تقديم الحصص في رأس المال:

ينقسم رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى حصص متساوية القيمة لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه، فالقانون، والحال كذلك، يضع حداً أدنى لقيمة الحصة، إلا أنه لم يضع حداً أقصى لقيمتها، بخلاف ما اتبعه بالنسبة للأسهم كما سبق أن أشرنا، كما أنه لم يفرض قاعدة عامة يجب اتباعها عند توزيع الحصص بين الشركاء، ومن ثم يجوز أن يستأثر أحد الشركاء بمعظم الحصص، وتكون له السيطرة الكاملة على المشروع، رغم أنه في نفس الوقت لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة في كامل ذمته المالية، وإنما بجزء فقط من ذمته، وهو ما يحقق له وضعاً لا يعترف به التشريع المصري - كقاعدة عامة - الذي يجعل ذمة الشخص بأكملها ضامنة لما عليه من ديون.

ولا يجوز توزيع الحصص -كقاعدة- إلا على الشركاء الموقعين على عقد الشركة التأسيسي، لأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة -كما هو الشأن بالنسبة لشركات الأشخاص- يتمتع عليها تكوين رأس مالها عن طريق الالتجاء إلى الاكتتاب العام، وذلك بخلاف شركات المساهمة (أو التوصية بالأسهم)، فالتأسيس إنما يقع في دائرة مغلقة Fermé، ويقتصر الاكتتاب على الشركاء فقط، وذلك كله احتراماً للطابع الشخصي للشركة ذات المسؤولية المحدودة. الوفاء بقيمة الحصص:

يشترط أن يتم الوفاء بكل قيمة الحصص التي يتكون منها رأس المال عند تأسيس الشركة، لا فرق في ذلك بين الحصص النقدية أو الحصص العينية. أ-الحصص النقدية:

غالباً ما تتخذ الحصص المقدمة من الشركاء شكل الحصص النقدية، ويجب أن يتم أداء كامل قيمة هذه الحصص عند تأسيس الشركة، بمعنى أنه لا يكفي لصحة تأسيس الشركة، كما هو الشأن بالنسبة للأسهم النقدية، الوفاء بجزء فقط من قيمتها، ويرجع هذا التشدد إلى حرص المشرع على حماية الدائنين وتأكيد تحقق الحد الأدنى من الضمان الذي يعتمدون عليه ووضعه فعلاً تحت تصرفهم. هذا، وقد نصت المادة ٢٠ من القانون على أنه: "يجب أن تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص، ولا يجوز للشركة سحب هذه المبالغ إلا بعد شهر عقد تأسيسها في السجل التجاري". ب-الحصص العينية:

لا تختلف الحصص العينية عن الحصص النقدية، من حيث وجوب الوفاء بها كاملة عند التأسيس، إلا أن المشرع، خلافاً لما هو متبع بالنسبة لشركات المساهمة، لم يفرض اتخاذ إجراءات خاصة لتقويمها، بل ترك أمر تقديرها للشركاء أنفسهم، قاصداً بذلك تيسير تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وعدم إرهاب الشركاء بنفقات باهظة لا تتناسب مع قدرتهم المالية، خاصة إذا أخذنا في عين الاعتبار أن هذه الشركات غالباً ما تقوم بالمشروعات الصغيرة أو المتوسطة، كما أسلفنا.

ويجب أن تقدر الحصة بمعرفة أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون، ويتضمن تقرير أهل الخبرة وصفاً دقيقاً للحصة العينية وأسس حساب قيمتها، ويوقع الشركاء بالإطلاع على التقرير وموافقته عليه (م ٢/٦٩ من اللائحة). كما يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة نوع

الحصة العينية وقيمتها والتمن الذي ارتضاه باقي الشركاء لها واسم الشريك ومقدار حصته في رأس المال مقابل ما قدمه.

وإذا كان المشرع لم يفرض إجراءات خاصة لتقويم الحصة العينية، فإنه قد استعاض عن ذلك بتقرير مسئولية الشريك مقدم الحصة تجاه الغير عن الفرق بين قيمتها الحقيقية وقيمتها المذكورة في العقد، فضلاً عن مسئولية باقي الشركاء عن هذا الفرق بالتضامن فيما بينهم، إلا إذا أثبتوا عدم علمهم بالمبالغة في قيمة الحصة العينية.^(١)

خصائص الحصة:

تفرد حصة الشريك، في نطاق الشركات ذات المسئولية المحدودة، بخصائص معينة، تميزها عن السهم في شركات المساهمة من ناحية، والحصة في نطاق شركات الأشخاص من ناحية أخرى، وهذه الخصائص تنحصر فيما يأتي:

أ- عدم القابلية للإنقسام: فحصة الشريك غير قابلة للقسمة، بمعنى أنه إذا تعدد الملاك لحصة واحدة، فإنها لا تكون قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، وطبقاً لنص المادة (١١٦/٣) من قانون الشركات: إذا تعدد الملاك لحصة واحدة، يجب عليهم أن يختاروا من بينهم من يعتبر مالِكاً منفرداً للحصة في مواجهة الشركة، وحتى يتم هذا الاختيار، يجوز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتعلقة بالحصة، بمعنى أن وقف الحقوق، لا يقع بقوة القانون، وإنما هو مجرد رخصة للشركة، بحيث يكون لها مطلق التقدير في شأنها، إما أن تستعملها وإما أن تغفلها وتتغاضى عن مباشرتها، ويجب تطبيق هذا الحكم في كافة حالات تعدد الملاك أياً كان السبب الذي يستند إليه.

ب- المساواة في القيمة: طبقاً لنص المادة ١١٦ من القانون، ينقسم رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى حصص متساوية، وعلى ذلك، فالأصل أن تكون الحصص بقيمة اسمية واحدة، وقد وضع القانون حداً أدنى لقيمتها لا يجوز أن تنخفض عنه، وهو مائة جنيه، وعلى العكس لم يضع حداً أقصى لقيمتها، وذلك خلافاً لمسلكه بالنسبة لشركات المساهمة، حيث وضع حداً أعلى، وحداً أدنى لقيمة السهم.

ويترتب على قاعدة المساواة بين الحصص، المساواة في الحقوق التي تمنحها لأصحابها. ومع ذلك، فمن الثابت أنه يجوز مخالفة قاعدة المساواة بشرط خاص في العقد التأسيسي، يجوز بمقتضاه أن تكون بعض الحصص ممتازة أو ذات أفضلية على غيرها، وقد يتعلق الامتياز إما

بالأرباح أو بناتج التصفية - كما سبق أن أشرنا- وقد أجاز تشريع الشركات ذلك، حيث نص صراحة على أنه: " تتقاسم الحصص الأرباح وفائض التصفية سوية فيما بينهما، ما لم ينص في عقد الشركة على غير ذلك" (م/١١٦/٢).

هذا، وقد سبق التأكيد على أنه لا يجوز أن يكون موضوع الامتياز خاصاً بالتصويت في الجمعية العمومية، لأن هذا الحق الأخير يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه.

ج - عدم قابلية الحصة للتداول بالطرق التجارية: كذلك تتميز الحصة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعدم قابليتها للتداول بالطرق التجارية. ومن هذه الناحية تختلف الحصة عن السهم الذي تعتبر صفته الجوهرية هي قابليته للتداول بهذه الطرق، وقد نصت المادة ٢٧٢ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على هذا الحكم بقولها: "لا يجوز أن تتخذ الحصص شكل صكوك قابلة للتداول". كما أنه يتمتع على الشركة ذات المسؤولية المحدودة إصدار أسهم قابلة للتداول سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها^(١)، هذا فضلاً عن معاقبة المؤسس أو المدير الذي يوجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أوراق مالية أيّاً كان نوعها لحساب الشركة، وكذلك كل من عرض هذه الأوراق للاكتتاب لحساب الشركة.

وينبغي على ما سبق، أنه ينبغي الرجوع إلى العقد التأسيسي لإثبات ملكية الحصة، فهو يعتبر السند الوحيد الذي يثبت ملكية الشريك للحصص التي اكتتب بها، ولا يغني عنه تمثيل الحصص بشهادات تصدرها الشركة بأسماء الشركاء، ذلك أن مثل هذه المحررات تعتبر مجرد إقرار من الشركة بملكية الحصة.

ولتيسير هذا الإثبات، حرص المشرع على إلزام الشركة بإعداد سجل خاص يتضمن مجموعة من البيانات الهامة، تساعد أصحاب المصلحة، سواء أكانوا من الشركاء أم من الغير، في الإثبات، حيث يعد بمركز الشركة سجل للشركاء يتضمن بيانات تتعلق بأسماء الشركاء وجنسياتهم، وعدد الحصص التي يملكها كل منهم، فضلاً عن بيان التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها، وتاريخ توقيع أطراف التصرف متى كان بين الأحياء (المتنازل والمتنازل إليه) أو توقيع المدير ومن آلت إليه ملكية الحصة في حالة انتقال الحصة بسبب الوفاة^(٢).

وسجل الشركاء سجل علني، يجوز للشركاء أو صاحب المصلحة من غيرهم الإطلاع عليه، كما ترسل سنوياً إلى الجهة الإدارية المختصة قائمة تشمل على البيانات الواردة بالسجل، فضلاً عن التغييرات التي تكون قد طرأت عليها، ويتم نشر هذه البيانات في النشرة التي تعد لهذا

الغرض، ومديرو الشركة مسئولون شخصياً وتضامنياً عن كافة الأضرار التي تنشأ بسبب إمساك السجل بطريقة غير صحيحة، أو إعداد القوائم بطريقة معيبة، أو بسبب عدم صحة البيانات التي تثبت في السجل أو القوائم.

احتياطي الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة، من خلال الأرباح التي تكونت لديها، أن تكون احتياطياً، ووفقاً لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م، فليس هناك ما يلزم هذه الشركات بتكوين احتياطي قانوني، وقد أثار ذلك خلافاً حول ما إذا كان يجوز للشركاء أن يدرجوا في عقد الشركة أحكاماً خاصة بتكوين مال احتياطي للشركة، وفي هذا الخصوص، فإن المادة ٣٨ من النموذج المعتمد لعقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة قد أقرت إمكانية تكوين احتياطي بنسبة ٥ % من الأرباح الصافية السنوية، بعد خصم جميع المصروفات العامة على الأقل، والتكاليف الأخرى، إلا أنه قد ترك أمر تحديد مقدار هذا الإحتياطي النظامي لمطلق حرية الشركاء.

كذلك، يجوز، بعد خصم نسبة ٥ % من الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي، وتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ٥ % من رأس المال على الأقل على الشركاء، وبعد تخصيص ١٠ % من الأرباح المتبقية على الأكثر للمديرين، ونسبة الأرباح المقررة على العاملين، أن تقرر الجمعية العمومية للشركاء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تكوين احتياطي غير عادي أو اختياري.

وبناء على كل ما سبق، فالشركة، وإن كانت معفاة من تكوين احتياطي قانوني، إلا أنها تلزم بتكوين احتياطي نظامي، كما يجوز لها أيضاً تكوين احتياطي اختياري أو حر، وتستطيع أن تعتمد على هذه الاحتياطات في تمويلها، دون أن تضطر إلى الإلتجاء إلى طرق التمويل الخارجي، وهي محدودة في خصوص هذه الشركات، نظراً للطابع الشخصي للشركة ومنعها قانوناً من الإلتجاء إلى الإكتتاب العام بصفة عامة.

الفرع الثاني: الشروط الشكلية

أولاً: الكتابة:

لم يستلزم قانون الشركات الحالي رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أن يكون عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة رسمياً، وإنما أجاز أن يكون إما رسمياً أو مصداً على التوقيعات فيه، وذلك تبسيطاً لإجراءات التأسيس، وهو ما يتفق ومسلك المشرع بصفة عامة.^(١)

ويجب أن يتضمن عقد التأسيس البيانات الواردة بنص المادة ٦٥ من اللائحة التنفيذية، وتشمل هذه البيانات ما يلي:

أسماء الشركاء وبيان ما إذا كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين وجنسياتهم ومحل إقامتهم أو مركز إدارتهم بحسب الأحوال-تحديد رأس مال الشركة وعدد الحصص التي ينقسم إليها وقيمة كل حصة-توزيع الحصص على الشركاء-إذا كان ما قدمه الشريك حصة عينية، فيحدد نوع الحصة وقيمتها والتمن الذي ارتضاه باقي الشركاء لها واسم الشريك ومقدار حصته في رأس المال مقابل ما قدمه-أسماء المديرين المعيّنين لإدارة الشركة وما إذا كانوا من الشركاء أو من غيرهم مع جواز بيان الأجل الذي ينتهي فيه تعيينهم-أسماء أعضاء مجلس الرقابة إذا زاد عدد الشركاء على عشرة والمدة التي يتولى مهامه خلالها-اسم أو أسماء مراقبي الحسابات الأول.

ويجب تحرير العقد وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من الوزير المختص، ولا يجوز الخروج على بيانات النموذج إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة^(١)، إلا أنه يجوز للشركاء استبعاد بعض أحكام النموذج، بمعنى أنهم غير ملزمين بالأخذ بكافة ما ورد به من أحكام، كما أنهم قد يضيفون إليها بعض الشروط الأخرى بشرط ألا تتنافى مع أحكام القانون أو اللوائح^(٢).

ثانياً: استيفاء متطلبات الرقابة على تأسيس الشركة:

١- وجوب الحصول على موافقة لجنة فحص طلبات الترخيص بإنشاء الشركة:

طبقاً لنص المادة ١٧ من قانون الشركات المعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨، على المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الهيئة بإنشاء الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات الآتية:

- (أ) عقد التأسيس بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
- (ب) موافقة الجهات المختصة إذا كانت ممارسة أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقات خاصة بمقتضى أحكام قانون آخر.
- (ج) إيصال سداد رسم بواقع واحد في الألف من رأس المال المدفوع بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يزيد على ألف جنيه.

وعلى هذا، تبدأ إجراءات تأسيس الشركة، بتقديم طلب إنشاء الشركة إلى الإدارة العامة للشركات (إخطار الجهة الإدارية المختصة)، مرفقاً به عقد التأسيس وكافة الأوراق الأخرى التي

يتطلبها القانون أو اللائحة، فإذا كان الطلب مستوفياً، قامت بإحالة إلى اللجنة الفنية المختصة بفحص طلبات إنشاء الشركات المنصوص عليها في المادة ١٨ من القانون، ويجب عليها أن تبت في الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الأوراق المستوفاة.

فإذا لم تعترض اللجنة المختصة على تأسيس الشركة خلال هذه المدة، بكتاب يوجه إلى أصحاب الشأن ويتم تبليغه إلى مكتب السجل التجاري المختص، اعتبر الطلب مقبولاً (م١٩/١). ولا يجوز للجنة أن تعترض على التأسيس إلا بقرار مسبب في إحدى الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر، والتي تتلخص في: عدم مطابقة عقد التأسيس للشروط والبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج، أو تضمنه شروطاً مخالفة للقانون، أو متى كان غرض الشركة أو النشاط الذي سوف تقوم به مخالفاً للنظام العام أو الآداب، أو إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر له الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة، أو إذا كان أحد المديرين لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون.

هذا، ويلاحظ أنه لا يشترط لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة صدور قرار بذلك من الوزير المختص، وبعبارة أخرى يكفي لتأسيس الشركة مجرد الموافقة على طلب التأسيس من جانب اللجنة الفنية المختصة والمشكلة وفقاً لأحكام القانون.^(١)

٢- تطبيق مبدأ حرية تأسيس الشركة: (الإخطار بتأسيس الشركة):

طبق المشرع مبدأ حرية تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك بموجب القانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨، حيث اكتفى في خصوص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بإلزام المؤسسين بمجرد إخطار الجهة الإدارية المختصة بقيام الشركة، على أن يرفق بالإخطار مجموعة من المحررات والمستندات التي تؤكد قيام المؤسسين بتحرير عقد التأسيس وفقاً للنموذج الخاص بهذا الشكل، ومتضمناً كافة البيانات الإلزامية الواجب إدراجها فيه، فضلاً عن قيامهم بالاكتمال في جميع الحصص وسداد كامل قيمتها، وإيداع هذه المبالغ تحت تصرف الشركة في أحد البنوك المرخص لها بذلك حتى تكتسب الشركة شخصيتها المعنوية.

ومتى كان الإخطار مستوفياً كافة المستندات المطلوبة، التزمت الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الإخطار شهادة بذلك، يكون له بموجبها قيد الشركة في السجل التجاري، دون اشتراط أي إجراء أو شرط آخر، وذلك كله أيأ كانت نسبة مشاركة غير المصريين في الشركة.

ومن وجهة نظرنا، يجب مراجعة إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم

١٥٩ لسنة ٨١ ، ووجوب فرض الرقابة السابقة على تأسيس هذه الأنواع من الشركات نظراً لأهميتها الفائقة، والدور الكبير الذي تقوم به في الحياة الاقتصادية.

ثالثاً: الشهر والعلانية:

تخضع الشركات ذات المسؤولية المحدودة لإجراءات الشهر والعلانية التي ينظمها القانون، ويتم الشهر عن طريق القيد في السجل التجاري، فضلاً عن النشر عنها بالوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التي تصدر لهذا الغرض.

١- الشهر في السجل التجاري:

يجب إشهار عقد الشركة في السجل التجاري الذي يتبعه مركزها الرئيسي، وذلك بتقديم نسخة من عقد التأسيس موثقة أو مصدقاً على التوقعات الواردة فيها طبقاً لما تقضي به نصوص القانون واللائحة، حيث تحفظ النسخة بمكتب السجل التجاري، كما يتم قيد الشركة بالسجل التجاري طبقاً للأوضاع المقررة بقانون السجل التجاري^(١).

ويقوم مكتب السجل التجاري المختص، بموافاة الهيئة العامة لسوق المال، والإدارة العامة للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة، وشهادة بقيد الشركة في السجل مبيناً بها تاريخ القيد ورقمه ومكانه^(٢).

وقيد الشركة في السجل التجاري على النحو السابق، يمثل أهمية بالغة، حيث يرتب القانون على إجراءاته، وبعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد، اكتساب الشركة الشخصية المعنوية. فضلاً عن أنه، بتمام قيد الشركة في السجل التجاري وفوات هذه المدة دون اعتراض مسبب من الجهة الإدارية المختصة، لا يجوز الطعن ببطالانها بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس^(٣).

٢- النشر:

وبجانب الشهر في السجل التجاري يتعين أيضاً، إذا لم تعترض الإدارة العامة للشركات على قيام الشركة، نشر عقد الشركة في صحيفة الشركات مقروناً برقم القيد في السجل وتاريخه، وذلك على نفقة الشركة^(٤). حيث تنص الفقرة الأولى من المادة ١/٢١ من القانون على أن: "تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها سواء بالوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التي تصدر لهذا الغرض أو بغير ذلك من الطرق". وتطبيقاً لذلك، تتولى الإدارة العامة للشركات

نشر عقد تأسيس الشركة، فضلاً عن تاريخ القيد بالسجل التجاري ورقمه ومكانه، بصحيفة الشركات (م ٧٩ من اللائحة التنفيذية).

رابعاً: جزاء الإخلال بقواعد وإجراءات التأسيس:

يسري على الشركات ذات المسؤولية المحدودة كافة الأحكام التي أوردها قانون الشركات بشأن تحديد المؤسسين، وما يشترط أن يتوافر في شأهم من شروط وتحديد التزاماتهم ومسئولياتهم. وذلك كله على النحو السابق بيانه.

١ - المسؤولية المدنية والجنائية للمؤسسين:

(أ) المسؤولية المدنية:

يكون المؤسسون مسئولين بالتضامن قبل كل ذي شأن ولو نص على خلاف ذلك، عن أي جزء من رأس المال تم الاكتتاب فيه على وجه غير صحيح، ويعتبرون بحكم القانون مكتتبين به، ويتعين عليهم أدائه بمجرد اكتشاف سبب البطلان، كذلك فهم مسئولون عن المبالغة في قيمة الحصة العينية في عقد تأسيس الشركة، ويعتبرون بحكم القانون مكتتبين بهذه الزيادة ويتعين عليهم أدائها متى ثبت ذلك.

(ب) المسؤولية الجنائية:

إلى جانب ذلك، يكون كل مؤسس مسئولاً جنائياً طبقاً لنص المادة (٢٤١/٢) من القانون التي تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا تضمن عقد الشركة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك، وإذا ما وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أوراق مالية لحساب شركة ذات مسؤولية محدودة، وكل من عرض هذه الأوراق للاكتتاب لحساب الشركة.

٢ - تطهير الشركة من البطلان:

وكما هو الشأن بالنسبة لشركات المساهمة، لا يجوز الطعن ببطلان الشركة بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس، بعد شهر عقد الشركة في السجل التجاري (م ٢٣ من القانون).

المطلب الثالث

إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة والرقابة على أعمالها

ينظم المشرع إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة على غرار الشركة المساهمة، حيث تتعدد أجهزة الإدارة والرقابة على النحو التالي:

الفرع الأول: إدارة الشركة

أولاً: الجمعية العمومية للشركاء:

يجتمع الشركاء في جمعية عمومية لمناقشة شئون الشركة، وتضم الجمعية العمومية جميع الشركاء في الشركة، ويكون لكل حصة صوت ولو نص في عقد التأسيس على خلاف ذلك، ويبين عقد التأسيس زمان ومكان انعقادها، وتتبع في دعوة الجمعية العامة للانعقاد وفي المداولات، القواعد المقررة بالنسبة للشركات المساهمة.^(١)

وبناءً على ذلك، فلا يجوز تقييد حق الشريك في حضور الجمعية والتصويت فيها بتملك حد أدنى من الحصص، كما أنه لا يجوز إصدار حصص ذات صوت متعدد، كذلك فإن القانون لم يضع حداً أقصى لعدد الأصوات التي قد تكون للشريك، ومن ثم يجوز في ظل الوضع الحالي أن يهيمن أحد الشركاء على الشركة طالما كانت له أغلبية الحصص، ويجوز للشركاء الغائبين أن يصوتوا بالكتابة أو أن ينيبوا عنهم غيرهم في حضور الجمعية العمومية، والأصل أن يكون التوكيل خاصاً، إلا أنه يجوز أن ينص في العقد التأسيسي على خلاف ذلك.^(٢)

ولا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره شركاء يمثلون ربع رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى، بشرط ألا تجاوز نصف رأس المال، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويجوز أن يتضمن نظام الشركة الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الحصص الممثلة فيه.^(٣)

وتنعقد الجمعية العامة للشركاء بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان الذين يعينهما نظام الشركة، ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقل في السنة خلال الستة الشهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة.^(٤)

وتختص الجمعية العمومية العادية، بالتصديق على الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، وتحديد حصص الأرباح التي توزع على الشركاء، كما تختص بتعيين المديرين وأعضاء مجلس الرقابة وتحديد مكافآتهم، وبصفة عامة تختص الجمعية بكافة المسائل التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية غير العادية، ولا تكون قرارات الجمعية، في خصوص هذه المسائل، صحيحة إلا إذا صدرت بالأغلبية المطلقة للأصوات على الأقل، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

الجمعية العمومية غير العادية:

تختص الجمعية العمومية غير العادية بتعديل عقد الشركة، وزيادة رأس المال وتخفيضه، كما تختص بعزل المديرين، ويشترط لصحة صدور قرارات الجمعية العمومية غير العادية، توافر أغلبية خاصة، تتمثل في الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك^(١)، ويجوز للشركاء، تطبيقاً لهذا الحكم، أن ينصوا في العقد على وجوب صدور القرار بالإجماع مثلاً، أو على صدوره بأغلبية أكبر من نصاب التصويت المحدد قانوناً، ولا يجوز لهم على العكس، تحديد أغلبية أقل، ذلك أن التحديد القانوني يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز مخالفته، حماية للأقلية.^(٢)

ثانياً - مدير الشركة:

١- تعيين المدير:

يقوم بإدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو عدة مديرين يتولى الشركاء اختيارهم من بينهم، وهذا هو الوضع الغالب، أو أن يكونوا أجاناب عنهم، وذلك بخلاف الوضع في الشركات المساهمة، حيث يشترط كقاعدة أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من بين المساهمين، وقد يعين المدير إما في عقد تأسيس الشركة، فيكون بذلك مديراً اتفاقياً أو نظامياً، أو أن يعين بعقد مستقل لاحق على عقد الشركة، فيعتبر مديراً غير نظامي، كذلك فقد يفضل الشركاء أن يقوموا جميعاً بإدارة الشركة، وليس هناك ما يمنع من ذلك، وهو وضع متصور من الناحية العملية متى كان عدد الشركاء قليلاً، اثنين أو ثلاثة مثلاً.

كذلك، فقد يعين الشركاء المدير (أو المديرين) لأجل معين، أو دون تعيين أجل، وطبقاً لأحكام القانون، يعتبر المديرون (أو المدير) المعينون في العقد التأسيسي، دون تحديد مدة وکالتهم، معينين لمدة بقاء الشركة، سواء أكانوا من بين الشركاء أم من غيرهم، وذلك كله إلا إذا

نص العقد على ما يخالف ذلك.^١ هذا، ويلاحظ أنه متى اتفق الشركاء على تعيين مدير الشركة أو مديرين على حسب الأحوال، امتنع عليهم التدخل في أعمال الإدارة.^٢

٢- الشروط الواجب توافرها في المدير:

طبقاً لأحكام قانون الشركات يجب توافر شروط معينة في مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وقد أحال القانون في بيانها على لائحته التنفيذية^٣، وقد أشارت هذه اللائحة إلى تلك الشروط في المادة ٢٨١ بقولها: "يجب أن يتوافر في مديري الشركة الشروط المبينة بالمادة ٨٩ من القانون، وأن يكون أحدهم على الأقل مصري الجنسية".

وعلى هذا يشترط أن يتمتع مدير الشركة بالنزاهة، وذلك بألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في قانون الشركات في المواد: ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤ منه^٤، ويشير هذا الشرط إلى أن مدير الشركة يجب أن يكون شخصاً طبيعياً، إذ لا يعقل أن ترتكب الشركة بنفسها-باعتبارها شخصاً معنوياً-تلك الجرائم، كما لا يتصور خضوعها للعقوبات السالبة للحرية المرصودة لها في المواد السابقة.

وقد كان الحكم المقرر في قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، يقضي بأنه يجب أن يكون المدير متمتعاً بالجنسية المصرية، أما إذا تعدد المديرون، فيجب أن يكون أحدهم على الأقل مصري الجنسية، غير أن هذا الشرط لم يعد له محل بعد أن ألغى المشرع بمقتضى القانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨-المعدل للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١-ما كان ينص عليه القانون الأخير من اشتراط أن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة الخاضعة لأحكامه من المصريين، وعلى هذا فلا يوجد من ثم داع لضرورة توافره في أحد مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

والمدير كفاعلة لا يكتسب صفة التاجر، إلا أنه يجب أن يكون بالغاً سن الرشد، كامل الأهلية، غير مصاب بأي عارض من عوارض الأهلية، كالفقه مثلاً أو العته.

٣- عزل المدير:

وفقاً للمادة (٤/١٢٠) من قانون الشركات، والمعدلة بمقتضى القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨، يجوز عزل المدير أياً كان مركزه في الشركة، بشرط موافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال، وسواء كان تعيينه لأجل محدد أو دون تعيين أجل، غير أن هذا النص لا

ينصرف، من وجهة نظرنا سوى للمدير النظامي، ويجوز للشركاء مخالفة هذه القاعدة، بأن يشترطوا صدور قرار إجماعي من الشركاء، إلا أنه لا يجوز لهم النص في العقد التأسيسي على صدور قرار العزل بأغلبية أقل من تلك التي يحددها القانون (أغلبية مزدوجة، أغلبية عددية للشركاء، والحائز لثلاثة أرباع رأس المال) على أساس أن هذا التحديد القانوني، يتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفته، ويعتبر هو الحد الأدنى الواجب توافره لصحة قرار عزل المدير (أو المديرين)، أما إذا كان المدير غير اتفاقي، أي معيناً بقرار من الجمعية العامة للشركاء، فيجوز عزله بقرار يصدر بالأغلبية "المطلقة" للأصوات، ما لم ينص القانون أو العقد على غير ذلك.^(١)

ويجوز للمدير أن يعتزل الإدارة بتقديم استقالته بشرط توافر حسن النية، بالألا تتم في وقت غير مناسب بالنسبة للشركة أو أن تكون صادرة عن غش، وإلا حق للشركة طلب التعويض بقدر ما لحقها من أضرار بسببها.

وفي كل الأحوال يجب شهر قرار العزل أو الاعتزال بالتأشير به في السجل التجاري، ولا ينفذ هذا القرار إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إثباته في السجل التجاري.^(٢)

٤-سلطات المدير:

طبقاً لأحكام القانون، يكون لمديري الشركة سلطة كاملة في النيابة عنها ما لم ينص عقد تأسيسها على غير ذلك.^(٣) وتطبيقاً لهذا المعنى، يقوم المدير بتمثيل الشركة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. وبالتالي، يكون له سلطة التعامل باسمها وإجراء كافة المعاملات والعقود الداخلة ضمن غرضها.

ويجوز للشركاء دائماً تقييد سلطة المدير، إما في العقد التأسيسي للشركة أو في القرار الصادر بتعيينه؛ فقد يحظر عليه العقد القيام ببعض التصرفات أصلاً، أو أن يفرض عليه الحصول على إذن مسبق من الجمعية العمومية لإجرائها، أو أن يصدر بالموافقة عليها قرار جماعي من الشركاء.

ويجب شهر القيود الواردة على سلطات المدير، في السجل التجاري، ولا يجوز للشركة الاحتجاج بها على الغير إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إثباتها في السجل (٢/١٢١م).

هذا، ويجب على المدير تنفيذ وکالته بحسن نية، وهو، باعتباره وکيلاً مأجوراً، يلتزم ببذل عناية الرجل المعتاد تطبيقاً لأحكام القواعد العامة^(٤)، وبالتالي يجب عليه، إذا انفرد بالإدارة، إبلاغ جمعية الشركاء عن أي تعارض بين مصلحته ومصلحة الشركة في أي عملية من العمليات التي

يزمّع إجراءها، للترخيص بالعملية أو لاتخاذ ما تراه الجمعية من إجراء^(١)، ولا مجال لتطبيق هذا الحكم إذا ما تعدد المديرون، لأن التعدد في حد ذاته، يكفل منع إساءة أحدهم لسلطته، ويكفي هنا مجرد قيام المدير بإبلاغ باقي زملائه بالعملية محل الاعتبار.

٥- مسؤولية الشركة عن أعمال المدير:

تلتزم الشركة بكافة الأعمال والتصرفات التي يجريها المدير باسمها أو بعنوانها، في حدود السلطة المخولة له، وذلك بشرط أن يكون توقيع المدير (أو غيره من العاملين) مشفوعاً بالصفة التي يتعامل بها، فإذا تجاوز المدير حدود سلطته، يكون من حق الشركة أن تتمسك في مواجهة الغير، ولو كان حسن النية، بعدم مسؤوليتها عن مثل هذه التصرفات، وذلك طالما كانت القيود الواردة على سلطة المدير مشهورة طبقاً لأحكام القانون (م ١٢١/٢).

إلا أن المادة ١٢١/٣ من القانون نصت على أنه: "وتسري الأحكام المتعلقة بحماية المتعاملين مع الشركة والواردة في المواد من ٥٣ حتى ٥٨ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م على الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها".

وتطبيقاً لهذه الأحكام، لا يجوز للشركة أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود الواردة على سلطة المدير، المنصوص عليها في العقد التأسيسي، ولو كانت مشهورة بالطرق التي ينظمها القانون، كما يكون للغير حسن النية أن يتمسك في مواجهة الشركة بأى تصرف يجريه أحد موظفى الشركة أو وكلائها، إذا قدمه المدير على أنه يملك سلطة التصرف نيابة عنها، واعتمد الغير على ذلك في تعامله مع الشركة، كذلك لا يجوز للشركة أن تتمسك في مواجهة الغير حسن النية من المتعاملين معها أن نصوص عقد الشركة أو لوائحها لم تتبع بشأن التصرف، كما لا يجوز لها أن تحتج بأن مديرى الشركة أو غيرهم من الموظفين أو الوكلاء لم يتم تعيينهم على الوجه الذى يتطلبه القانون أو نظام الشركة، طالما كانت تصرفاتهم في حدود المعتاد بالنسبة لمن كان في مثل وضعهم في الشركات التي تمارس نوع النشاط الذى تقوم به الشركة .

وهكذا فقد رأى البعض قيام التعارض بين أحكام المادة ١٢١، بفقرتيها الثانية والثالثة، ورجح تغليب نص الفقرة الثانية، على نص الفقرة الثالثة، واضعاً في الاعتبار أن عدم السماح للشركة بالتمسك في مواجهة الغير، ولو كان حسن النية، بما تضعه من قيود على سلطة الإدارة، رغم قيامها بالإجراءات القانونية التي ألزمها إياها القانون، يؤدي في الواقع إلى إهدار مصلحة

الشركة، وتفضيل مبالغ فيه لمصلحة الغير، ولا يمكن أن ننفي وجود أي إهمال من جانبه، لأنه كان يستطيع إبتداء التحقق من سلطة المدير، ويجب أن يتحمل نتيجة تقصيره وإهماله.^(١)

بينما نرجح ما ذهب إليه البعض في الفقه، من إمكانية التوفيق بين الفقرتين بحيث يتم إعمال أحكامهما معاً، فالفقرة الثانية - عندما تتكلم عن نفاذ القيود الواردة على سلطة المدير في مواجهة الغير بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إثباتها في السجل التجاري - لا تقصد وضع قرينة قانونية على علم الغير بهذه القيود، بل تهدف إلى تعطيل مبدأ الأثر النسبي، وذلك بالخروج بهذه القيود من دائرة العلاقات الداخلية الضيقة التي تضم - بالتطبيق لمبدأ الأثر النسبي للاتفاقات - كلاً من المدير والشركة والشركاء، إلى دائرة العلاقات الخارجية التي تضم، بجانب هؤلاء، الغير الذي سيتعامل مع الشركة، بحيث يمتنع على هذا الأخير - حال علمه بهذه القيود - التمسك بعدم سريانها عليه إعمالاً لمبدأ الأثر النسبي للعقود.^(٢)

أما الفقرة الثالثة من المادة ١٢١ من القانون، فقد تكفلت ببيان أحكام علم الغير، وتتلخص هذه الأحكام - كما يتبين من نص المادة ٥٨ من القانون التي أشارت إليها الفقرة الثانية سالف الذكر - في أن الغير يفترض فيه حسن النية، أي لا يعلم بالقيود على سلطة المدير ولو تم شهرها، لأن الشخص - حسب الفقرة الثانية من المادة ٥٨ - لا يعتبر "علماً بمحتويات أي وثيقة أو عقد لمجرد شهرها أو نشرها بإحدى الوسائل المنصوص عليها في هذا القانون" ومن بينها، بطبيعة الحال، التأشير بالسجل التجاري، وأن على الشركة - إذا ما أرادت التنصل من الالتزامات التي رتبها المدير في ذمتها بالمخالفة للقيود الواردة على سلطته - إقامة الدليل على سوء نية الغير، أي إثبات أنه، على حد تعبير الفقرة الأولى من المادة ٥٨، يعلم بالفعل أو كان في مقدوره أن يعلم بحسب موقعه بالشركة أو علاقته بها بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة".

القاعدة، إذاً، هي عدم جواز الاحتجاج على الغير بالقيود الاتفاقية التي ترد على سلطة المدير، حتى ولو كانت هذه القيود مشهورة بالطرق القانونية، لعدم افتراض علم الغير بها طبقاً لمبدأ حسن النية.

ويتعطل عمل هذه القاعدة في الحالتين التاليتين:

أ- إذا أقامت الشركة الدليل على عدم حسن نية الغير، بأن أثبتت أنه يعلم بالفعل أو كان في مقدوره أن يعلم، بحسب علاقته بالشركة، بالقيود المشار إليها.

ب- إذا كانت القيود التي تحد من سلطة المدير قانونية، أي تستمد وجودها من القانون ذاته وليس من عقد تأسيس الشركة، فللشركة أن تحتج بهذه القيود عليه إعمالاً لمبدأ عدم جواز العذر بجهل القانون، ومثال هذه القيود ما استثنى من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة للشركاء.

٦- مسؤولية المدير:

أ- المسؤولية المدنية: المديرون مسؤلون عن أي إخلال بواجباتهم، كما في حالة الخروج عن غرض الشركة، أو توزيع أرباح صورية، أو إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول. وقد ألت المادة ١٢٢/١ من القانون في شأن هذه المسؤولية إلى أحكام الشركات المساهمة، حيث تقضي بأن: "يكون حكم المديرين من حيث المسؤولية حكم أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة". والأصل أن تكون المسؤولية فردية، فإذا تعدد المديرون، فلا قيام للتضامن فيها بينهم، إلا إذا صدر الفعل أو التصرف بموافقتهم الإجماعية أو متى فرض القانون مسؤوليتهم على وجه التضامن، كما في حالة إمساك سجل للشركاء أو إعداد القوائم بطريقة غير صحيحة أو بسبب عدم صحة البيانات التي تثبت في السجل أو القوائم.^(١)

ب- المسؤولية الجنائية: كذلك، يتعرض المدير للمسؤولية الجنائية إذا ما ارتكب أيّاً من الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات في المواد ١٦٢/٢، م ٤/١٦٢، والعقوبة المقررة لهذه المخالفات، هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

الفرع الثاني: الرقابة على نشاط الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أولاً: مجلس الرقابة:

طبقاً لأحكام القواعد العامة، يكون لكل شريك حق مباشرة الرقابة والإشراف على إدارة الشركة، ويعتبر هذا الحق من الحقوق الأساسية للشريك، ولا يجوز حرمانه منه باعتباره متعلقاً بالنظام العام (المادة ٥١٩ مديني)، ولا شك في أن ممارسة الرقابة الفردية تعتبر أمراً سهلاً متى كان عدد الشركاء قليلاً (عشرة شركاء فأقل)، ولذلك فقد نصت المادة (١٢٥) من قانون الشركات على أنه: "يكون للشركاء غير المديرين، في الشركات التي لا يوجد بها مجلس رقابة، ما للشركاء المتضامنين من رقابة في شركات التضامن"، أما إذا زاد عدد الشركاء على هذا الحد، فقد قدر

المشرع أن مباشرة الرقابة الفردية تعتبر أمراً يكاد يكون مستحيلاً، كما أن من شأنه عرقلة أعمال الشركة، ولذلك فقد أوجب أن يعهد بالرقابة إلى مجلس يتكون من عدد محدود من الشركاء، وفي ذلك تنص المادة ١٢٢ من القانون على أنه: "إذا كان عدد الشركاء أكثر من عشرة، وجب أن يعهد بالرقابة إلى مجلس يتكون من ثلاثة على الأقل من الشركاء".

ومقتضى ذلك، أن وجود مجلس للرقابة بالشركة يكون إجبارياً، متى كان عدد الشركاء يتجاوز عشرة شركاء، أما إذا كان العدد أقل من ذلك، فلا تلتزم الشركة بتكوين المجلس، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من تكوينه إذا ما فضلت الشركة ذلك، ولم تر أن يباشر الشركاء جميعاً الإشراف والرقابة على أعمال الإدارة، ولم يعين القانون الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الرقابة، ولكنه اكتفى بتحديد حده الأدنى، بحيث إنه لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن ثلاثة وأن يكونوا جميعاً من الشركاء^(١)، فلا يجوز أن يكون أحدهم أجنبياً عن الشركة في حالة تعدد المديرين، على ما سبق أن أشرنا، إلا أنه يجوز أن ينص في العقد التأسيسي للشركة على أن يكون عضو مجلس الرقابة مالكاً لعدد معين من الحصص، لضمان الأخطاء التي قد يرتكبها خلال مدة عضويته.

ويعين مجلس الرقابة الأول في العقد التأسيسي للشركة، كما تختص الجمعية العمومية العادية للشركاء باختيار أعضاء المجالس التالية، ويحدد العقد التأسيسي مدة عضوية المجلس، ويجوز في جميع الأحوال إعادة انتخاب الأعضاء^(٢).

كما تختص الجمعية العمومية العادية أيضاً بعزل أعضاء مجلس الرقابة، ويصدر قرارها في هذا الخصوص بموافقة الأغلبية العادية للأعضاء، كذلك يجوز لعضو المجلس الاستقالة ويكون لمجلس الرقابة في هذه الحالة تعيين عضو آخر يحل محله، كما يجب أن يتم إجراء التعيين على وجه السرعة خلال الشهر التالي، وذلك إذا نقص الأعضاء عن ثلاثة، ويقوم العضو الجديد بمباشرة عمله في الحال إلى حين انعقاد أول اجتماع للجمعية العمومية التي تقوم إما بإقرار تعيينه أو تعيين آخر بدلا منه.

ويسري في شأن انعقاد مجلس الرقابة وتدوين محاضر جلساته ما يسري على مجلس الإدارة في شركات المساهمة، ويكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل، كما تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي، يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس.

وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون في سجل خاص، يشبه الدفاتر التجارية المنتظمة من حيث وجوب ترقيم صفحاته والتوقيع عليها من جانب الرئيس وأمين السر، كما يجوز استخراج صور من هذه المحاضر يصدق عليها رئيس المجلس.

وتقتصر مهمة المجلس على الإشراف والرقابة، فهو يقوم بتمثيل الشركاء في علاقاتهم مع الإدارة، دون أن يتدخل في أعمال الإدارة، فهذه الأعمال يتولاها المدير أو المديرون. ولتمكينه من أداء مهمته على الوجه الأكمل، خوله القانون حق فحص دفاتر الشركة ووثائقها، وأن يقوم بجرد الصندوق والأوراق المالية والوثائق ومحفظة الأوراق المالية، كما أن من حقه أن يطالب المديرين بتقديم تقارير في أي وقت، كما أنه يراقب الميزانية والتقرير السنوي ومشروع توزيع الأرباح، ويضع المجلس تقريراً بنتيجة أعماله، يبين فيه المخالفات والأخطاء التي قد يكتشفها في قوائم الجرد، ويبين الأسباب التي قد تحول دون إجراء توزيع حصص الأرباح التي تقترحها الإدارة. ويقدم التقرير سنوياً إلى جماعة الشركاء (الجمعية العامة) قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل^(١).

ويعتبر أعضاء مجلس الرقابة وكلاء عن الشركاء، في الإشراف والرقابة على أعمال الشركة، وبصفة خاصة على أعمال المديرين. وعلى هذا الأساس، يكون المجلس مسئولاً أمام الجمعية العمومية عما يقع منه من أخطاء في أداء مهمته. ولا يسأل - كقاعدة - أعضاء المجلس عن أعمال المديرين أو عن نتائجها، ومع ذلك، يجوز مساءلتهم عن هذه الأعمال إذا علموا بما وقع فيها من أخطاء وأغفلوا ذكرها في تقريرهم المقدم للجمعية العمومية، كما سبق أن أشرنا^(٢).

هذا، ويعتبر مجلس الرقابة مجرد هيئة داخلية مفوضة من جانب الشركاء في مباشرة الإشراف والرقابة على أعمال الإدارة، وهي تقوم بهذه المهمة لمصلحة كافة الشركاء، وليس لها أي وجود بالنسبة للغير، وبالتالي لا يكون للغير أي حق في مساءلتها عما قد يقع من أخطاء في تنفيذ المهمة الملقاة على عاتقها.

ثانياً - مراقب الحسابات:

كذلك، يجب تعيين مراقب الحسابات في الشركة، وتطبق على المراقب نفس القواعد المقررة في هذا الشأن في خصوص شركة المساهمة؛ بمعنى أن وجود مجلس للرقابة على النحو السابق لا يغني عن تعيين مراقب للحسابات (م ١٣٨ من قانون الشركات).

المطلب الخامس

انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالأسباب العامة لانقضاء الشركات بصفة عامة. وتنقضي الشركة إذا نقص رأسمالها بحيث لا يكفي ما تبقى منه لتحقيق غرض الشركة أو للقيام باستثمار مجد، هذا، وطبقاً لنص المادة ١٢٩ من قانون الشركات، يتعين على المديرين، إذا ما بلغت الخسارة نصف رأس مال الشركة، أن يعرضوا على الجمعية العمومية أمر حل الشركة، ويصدر القرار بالحل بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة، وهي الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال، إلا إذا نص عقد الشركة على خلاف ذلك. أما إذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال، فإنه يجوز للشركاء الحائزين لربع رأس المال أن يطلبوا الحل، كما يكون لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة إذا ترتب على الخسارة انخفاض رأس المال إلى أقل من الحد الأدنى المحدد قانوناً.^(١)

ومما تجدر ملاحظته، أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة، رغم قيامها على الاعتبار الشخصي، لا تتأثر بأي من أسباب الانقضاء المبنية على هذا الاعتبار، ومقتضى ذلك أن الشركة لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو إعساره أو انسحابه أو الحجر عليه، ومن هذه الناحية، تتميز الشركة عن شركات الأشخاص وتقترب من شركات الأموال، على ما سبق أن أشرنا.

وفي جميع الأحوال التي تنقضي فيها الشركة، يجب شهر هذا الانقضاء بالقيود في السجل التجاري وبالنشر بالوسائل الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية، على الوجه الذي سبق لنا إيضاحه.

المبحث الثاني شركة التوصية بالأسهم

تقسيم:

نتناول في دراستنا لشركة التوصية بالأسهم تعريفها وخصائصها، ثم تأسيسها وإدارتها، والرقابة عليها، مالية الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر، وانقضاءها.

المطلب الأول

تعريف شركة التوصية بالأسهم وخصائصها

تعريف الشركة:

تعرف المادة ١/٣ من قانون الشركات، شركة التوصية بالأسهم بأنها: "شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر، وأسهم متساوية القيمة يكتب فيها مساهم أو أكثر، ويمكن تداولها على الوجه المبين في القانون".

ويؤخذ على هذا التعريف-من وجهة نظرنا- أنه غير دقيق لاستعماله لفظ "يملكها"، إذ المعروف أن للشريك حق دائنية قبل الشركة يعطيه حق الحصول على نصيب في الأرباح وفي ناتج التصفية، بينما تكون الشركة كشخص معنوي هي المالكة للحصة.

خصائصها العامة:

شركة التوصية بالأسهم، كما يتبين من التعريف المذكور، شركة ذات طبيعة مختلطة، Hybride، تأخذ من خصائص كل من شركة التوصية البسيطة وشركة المساهمة.

١-الشركاء في الشركة: تضم شركة التوصية بالأسهم فريقين من الشركاء مختلفين في المركز القانوني بالنسبة للشركة: الشركاء المتضامنون، والشركاء المساهمون، وتعتبر الشركة من شركات الأشخاص بالنسبة للشركاء المتضامين، ومن شركات الأموال بالنسبة للشركاء المساهمين، وعلى هذا فللشريك المتضامن في شركة التوصية بالأسهم نفس مركز الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة، حيث يسأل الشركاء المتضامنون عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية فيما بينهم، ويوضع اسمهم أو اسم أحدهم في عنوان الشركة، ويستأثرون بإدارتها، ولا تنتقل حصصهم بالوفاة إلى ورثتهم، ولا يجوز لهم كأصل عام، التنازل عن حصصهم للغير، وتنقضي الشركة بوفاتهم.

بينما يتمتع الشريك المساهم بذات المركز القانوني للشريك المساهم في شركة المساهمة. فلا يسأل عن ديون الشركة إلا مسؤولية محدودة بقدر ما قدمه في رأس المال، وتكون أسهمه قابلة للتداول، وليس لشخصه أي اعتبار في وجود الشركة أو في استمرارها.^(١)

ويتشابه مركز الشريك المساهم في شركة التوصية بالأسهم مع الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة، لأنه يحظر على كليهما القيام بأعمال الإدارة الخارجية للشركة، بيد أنه يوجد خلاف بينهما وهو أن أسهم الشريك المساهم تكون قابلة للتداول، على خلاف حصص الشريك الموصي فهي غير قابلة - كأصل عام - للتداول.

ويجوز للشريك المتضامن في شركة التوصية بالأسهم أن يقدم حصة مالية، وأن يكتب في أسهم الشركة، فيكتسب أيضاً صفة المساهم بجانب صفته كشريك متضامن، ويتقرر له نفس حقوق المساهمين، أما لو قدم الشريك المتضامن حصة عمل فقط، فإنها تكون مقبولة، ولكن لا تدخل في رأس المال.

٢- عنوان الشركة: يتكون عنوان شركة التوصية بالأسهم من اسم واحد أو أكثر من أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم^(٢)، ورغم عدم تعرض المشرع في هذا الشأن على الجزاء المترتب في حالة ورود اسم الشريك المساهم في عنوان الشركة، فإن الأمر قد استقر على اعتبار الشريك المساهم في هذه الحالة مسؤولاً مسؤولاً غير محدودة عن ديون والتزامات الشركة.^(٣)

ويجب أن يذكر في جميع عقود الشركة وفواتيرها والأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى عنوان الشركة، ويبين فيها نوعها "شركة توصية بالأسهم" قبل العنوان أو بعده، وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسي، وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته في آخر ميزانية^(٤)، والغرض من ذلك أن يعرف الغير نوع الشركة وما تقدمه من ضمان.

عيوب شركة التوصية بالأسهم:

جدير بالذكر أن شركة التوصية بالأسهم ليست منتشرة على نطاق واسع في عالم الأعمال في الوقت الحالي، ويغلب على المشروعات التي يضطلع بها هذا النوع من الشركات الطابع العائلي، وبالتالي فهي المجال الأرحب لما يعرف بـ "الشركات العائلية"، كما يلاحظ على شركة التوصية بالأسهم، إذا ما قارناها بشركة المساهمة، أن نظام الشركة الأولى يترك حرية واسعة في تحديد مركز المديرين، الذين يتمتعون بثقل كبير (باعتبار أنهم من الشركاء المتضامنين المسؤولين

مسئولية غير محدودة) في الإدارة، ما يسهل لهم فرص الحصول على الائتمان، كما أن لشركة التوصية بالأسهم، باعتبارها من شركات الأموال، أن تقوم بتغطية رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام، كل هذا مع تركيز الإدارة في أيدي قلة من الأفراد، هم في الغالب أعضاء أسرة واحدة، مما يمنحهم سيطرة وثباتاً أكثر من مديري شركات المساهمة.

المطلب الثاني

تأسيس شركة التوصية بالأسهم

تنص المادة (١١٠) من قانون الشركات على أنه: "فيما عدا أحكام المواد ٣٧، ٧٧، ٩١، ٩٢، ٩٣، تسري على شركة التوصية بالأسهم سائر أحكام شركات المساهمة في هذا القانون، مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل". والهدف من الحكم الذي تضمنته المادة ١١٠ المذكورة، هو حماية كل من المساهمين والإدخار القومي معاً.

وعلى هذا ينطبق على تأسيس شركة التوصية بالأسهم الأحكام الآتية:

١- ينطبق على المؤسس في شركة التوصية بالأسهم نفس التعريف الوارد بالمادة ٧ من القانون السالف ذكرها، أما عدد الشركاء المؤسسين فيجب ألا يقل عن اثنين، وفقاً للمادة (١/٨) من ذات قانون.

٢- يكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عما التزموا به (م ١٠ من القانون)، ووفقاً للمادة (١١ من القانون): يجب على المؤسس أن يبذل في تعاملاته مع الشركة تحت التأسيس أو لحسابها عناية الرجل الحريص، ويلتزم المؤسسون - على سبيل التضامن - بأية أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة هذا الالتزام، وإذا تلقى المؤسس أية أموال أو معلومات تخص الشركة تحت التأسيس، كان عليه أن يرد إلى الشركة تلك الأموال وأية أرباح يكون قد حصل عليها نتيجة استعماله لتلك الأموال أو المعلومات.

٣- يعتمد مجلس الإدارة أو جماعة الشركاء أو الجمعية العامة التصرفات التي تتم بين الشركة تحت التأسيس وبين المؤسسين، وتسري العقود والتصرفات في مواجهة الشركة بعد التأسيس، متى كانت ضرورية. (١)

٤- يكون العقد الابتدائي طبقاً للنموذج الذي يصدره الوزير المختص (م ١ من القانون). ويجب أن يكون عقد الشركة الابتدائي ونظامها رسمياً أو مصداقاً على التوقعات فيه

(م ١٥). ويجب أن يحرر كل منهما طبقاً للنموذج الذي يصدر بقرار من الوزير المختص، (م ١٦ من القانون).

٥- يقدم طلب إنشاء الشركة إلى الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن توافق عليه لجنة فحص طلبات الإنشاء، وأن يعتمد الوزير قرار اللجنة المذكورة، وأن تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص ... إلخ. (المواد من ٢٠:١٧، والمادة ٣٦ من القانون).

٦- ينقسم رأسمال شركة التوصية بالأسهم، بالنسبة للشركاء المساهمين، إلى أسهم متساوية القيمة، ولا تقل القيمة الإسمية للسهم عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه، وتكون الأسهم قابلة للتداول على غرار شركات المساهمة، (م ٣١ من القانون)، ولا يجوز أن يقل رأس المال المصدر لشركة التوصية بالأسهم عن مائتين وخمسين ألف جنيه، أو أن يقل المبلغ المدفوع نقداً من رأس المال المدفوع عند التأسيس عن الربع. (م ٣٢ من القانون، م ٦ من اللائحة).^٥

ويجب شهر عقد الشركة ونظامها بحسب الأحوال في السجل التجاري،^٥، ولا يجوز طلب بطلان الشركة بعد شهرها في السجل التجاري (م ٣٢ من القانون).

وتبطل التصرفات أو التعاملات أو القرارات التي تصدر من المؤسسين أو مجلس الإدارة أو الجمعية العامة على خلاف القانون، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية (م ١٦١ من القانون)، وتخضع المخالفات والجرائم التي يرتكبها المؤسسون أو غيرهم لذات العقوبات السالفة البيان. (م ١٦٢ من القانون).

٧- لا يجوز أن تتولى شركة التوصية بالأسهم أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الإيداع أو تلقي الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير. (م ٥ من القانون)، ولا يصح في تبرير هذا الحكم القول بأن الأعمال التي يشملها هذا الحظر تتضمن كثيراً من المخاطر لتعلقها باستثمار أموال الغير، الأمر الذي يخشى معه ضياع أموال المستثمرين وحقوقهم بسبب ضالة رأسمال هذا الشكل من أشكال الشركات، ومن ثم ضعف اهتمامها في مواجهة مخاطر هذه الأنواع من الاستثمارات، فهذا التبرير وإن كان يقبل بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة - التي يسري عليها ذات الحظر - فإنه يصعب قبوله في صدد شركة التوصية بالأسهم، ذلك أن شركة التوصية بالأسهم تخضع لذات إجراءات تأسيس شركة المساهمة، ويسري عليها نفس الحد الأدنى من رأس المال الذي يسري على شركة المساهمة، في الوقت الذي أجاز فيه المشرع القيام بهذه الأعمال لشركات

المساهمة دون شركات التوصية بالأسهم، هذا بالرغم من وجود الشريك أو الشركاء المتضامنون في تشكيل هذه الأخيرة، والذين يسألون في كافة أموالهم عن التزامات الشركة، وبما يمثله ذلك من ضمان إضافي يضاف إلى رأس مال الشركة وسائر موجوداتها وما يتكون لها من احتياطات.

وعلى هذا فإن تبرير هذا الاستثناء يجد أساسه الصحيح في اشتغال هذه الشركة على عنصر الاعتبار الشخصي المستمد من وجود شريك متضامن أو أكثر، الأمر الذي يمكن أن تتأثر معه الشركة في وجودها ومصيرها بما يطرأ على أي من هؤلاء من عوارض، وعلى هذا فيكون من المقبول إذن أن يحظر عليها القيام بأعمال التأمين والادخار والبنوك وتلقي الودائع واستثمارها لحساب الغير، وهي أنشطة تعتمد بطبيعتها على الاعتبار المالي^(١)

المطلب الثالث

نشاط شركة التوصية بالأسهم

الفرع الأول: الإدارة:

المدير الفرد: تعدد المديرين:

يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم، حسبما تقضي المادة ١١١ من قانون الشركات، إلى شريك متضامن أو أكثر، ويعين عقد تأسيس الشركة أسماء من يعهد إليهم بالإدارة وسلطاتهم فيها.

ويتضح بذلك، أن إدارة شركة التوصية بالأسهم حكر على الشركاء المتضامين، دون الشركاء المساهمين أو الغير، وأن المدير قد يكون فرداً، وقد يتعدد الشركاء المتضامنون المعهود إليهم بالإدارة بنص في عقد التأسيس، فالمدير في هذه الشركة يكون دائماً شريك "اتفاقي" يتم تعيينه في عقد الشركة وليس في عقد مستقل، ولذلك يعتبر تعيينه عنصراً من عناصر عقد الشركة، ولا يجوز عزله إلا بتعديل ذلك العقد وموافقة المديرين على العزل، ما لم يوجد شرط مخالف بعقد الشركة.

وهكذا، يتمتع المدير بمركز ثابت، وهذه من مزايا شركة التوصية بالأسهم، ومع ذلك يجوز عزله قضائياً إذا توافر سبب مشروع، وتنقضي الشركة بعزل المدير (م ٥١٦ مدني) ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.

ويأخذ المدير الشريك المتضامن حكم المؤسس في شركة المساهمة، وعلى هذا يكون حكم من يعهد إليهم بالإدارة، من حيث المسؤولية، حكم المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة في تطبيق هذا القانون (م ١٠/٢ من القانون)، ويقع على عاتق المدير كافة الالتزامات التي تقع على عاتق أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة^(١)، ويشترط في مدير شركة التوصية بالأسهم ذات الشروط الواجبة في المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة المساهمة، كشرط اكتمال الأهلية، وشرط النزاهة، والإقرار المكتوب بقبول التعيين، على النحو السابق بيانه. (م ٨٩، ٩٠ من القانون).

ويحدد عقد الشركة السلطات والاختصاصات المنوطة بالشريك أو الشركاء المديرين، ومع مراعاة نصوص العقد، يكون للمدير أوسع السلطات في التصرف والإدارة، فيما عدا المسائل التي ينص العقد على أنها من اختصاص الجمعية العامة للشركة، كما يبين عقد الشركة أو نظامها كيفية أو طريقة تحديد مكافأة المدير أو المديرين، ولا يجوز تقدير المكافأة بنسبة معينة في الأرباح بأكثر من ١٠٪ من الأرباح الصافية، كما سبق بيانه في شأن شركات المساهمة.^(٢)

وإذا تعدد الشركاء المديرون، فيكون لكل منهم على انفراد التصرف باسم الشركة، ولا يحتاج على الغير باعتراض أحد المديرين على تصرف صادر من مدير آخر، ما لم يثبت علم الغير بهذا الاعتراض قبل إبرام التصرف.^(٣)

كما يجوز للمدير أو المديرين الاستعانة بمن يرون من الفنيين والإداريين، وتفويضهم في بعض اختصاصاتهم، على أن يكون المدير مسئولاً شخصياً عن أعمال هؤلاء معاونيهم، ولا تثبت لهم صفة المدير.^(٤)

وفضلاً عن ذلك، يسأل المديرون مسئولية مدنية عن أخطائهم وأوجه إهمالهم في الإدارة، كما يسألون مسئولية جنائية عن الجرائم التي ورد النص عليها في قانون العقوبات أو تلك التي يرتكبونها بالمخالفة لقانون الشركات على نحو ما بيناه.^(٥)

الفرع الثاني: الجمعية العامة:

تتكون الجمعية العامة من جميع المساهمين، وتقوم بدور رقابي هام، وتسري عليها الأحكام السابق ذكرها بالنسبة للجمعية العامة في شركات المساهمة، إلا أن وجود شريك أو أكثر متضامن في الإدارة في شركات التوصية البسيطة يحد من سلطان وسيادة الجمعية العامة في مواجهة المديرين.

وتتعدد الجمعية العامة مرة على الأقل سنوياً لمناقشة تقارير المديرين ومراقب الحسابات ومجلس المراقبة، والمصادقة على الميزانية والموافقة على حساب الأرباح والخسائر، باعتبار أن هذه جميعاً من أعمال الإدارة الداخلية الغير محظورة على المساهمين.

وتتمتع الجمعية العامة - بوجه عام - بذات الاختصاصات الممنوحة لنظيرتها في شركة المساهمة، بيد أنه لا يجوز لها عزل المدير الشريك، فهو غير قابل للعزل كما عرفنا إلا لأسباب قوية وبحكم قضائي، كما لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين أن تباشر أو أن تقر الأعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير (أعمال الإدارة الخارجية)، كما أنه ليس للجمعية العامة العادية تعديل عقد الشركة أو نظامها إلا بموافقة المديرين، ما لم يقض عقد الشركة أو نظامها بغير ذلك، وتنبو الجمعية العامة عن المساهمين في مواجهة المديرين.^(١)

الفصل الخامس

شركة الشخص الواحد

تمهيد وتقسيم:

استقرت غالبية القوانين منذ زمن بعيد - كقاعدة عامة - على عدم الاعتراف بشركة الشخص الواحد المحدودة، وذلك لتعارضها مع الفكرة العقدية، وما تستلزمه من تعدد الشركاء، ومبدأ وحدة الذمة المالية، وعدم قابليتها للانقسام، والمنصوص عليها صراحة في القوانين المدنية والقوانين التجارية على حد سواء.

ولكن ومع تطور الحياة الاقتصادية في مصر، ومع الرغبة في تشجيع زيادة حجم الاستثمار الوطني في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسايرة في هذا الشأن للعديد من التشريعات والنظم التي أقرت الأخذ بشركة الشركة الواحد، كان على المشرع أن يعيد النظر في نصوص قانون الشركات، والسماح بالاعتراف بشركة الشخص الواحد^(٢)، وهذا ما تحقق بالفعل بإصدار القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٨ (الجريدة الرسمية العدد ٢٢ مكرر (ط) بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠١٨).

وقد أقر المشرع بمقتضى هذا القانون الأخذ بشركة الشخص الواحد، بمفهومها المعروف في القانونين الألماني والإنجليزي، واستبدل بمقتضى مادته الأولى مسمى "قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد"

بمسمى " قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة " أينما ورد في القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر". كما نصت المادة الثانية من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ على أنه: " يستبدل بنص المادتين (١-فقرة أولى).. ، من مواد القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، النصان الآتيان: " مادة: (١-فقرة أولى): " تسري أحكام هذا القانون المرافق على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد". وبتناول، فيما يتعلق بشركة الشخص الواحد، التعريف بهذه الشركة وبيان أساسها القانوني في مبحث أول، ثم الأحكام المتعلقة بنشاط الشركة وانقضائها في مبحث ثان.

المبحث الأول

التعريف بشركة الشخص الواحد وأساسها القانوني

في معرض التعريف بشركة الشخص الواحد نتناول في مطلب أول ماهيتها وخصائصها ومبررات تنظيمها من الناحية القانونية والاقتصادية، ثم نعرض في مطلب ثان للأساس القانوني لإقرار هذه الشركة.

المطلب الأول

ماهية شركة الشخص الواحد وخصائصها ومبررات تنظيمها

الفرع الأول: ماهية شركة الشخص الواحد

تقوم فكرة الشخص الواحد على السماح لشخص واحد، سواء كان طبيعياً أو معنوياً، بأن يكون شركة بمفرده، وذلك عبر اقتطاع مبلغ معين من ذمته المالية وتخصيصه للاستثمار في مشروع معين، على شكل شركة تكتسب الشخصية المعنوية، بحيث تكون مسؤولية الشخص الواحد - مؤسس هذه الشركة - محدودة بقدر القيمة أو المبلغ المخصص لأعمالها، من دون أن يكون مسؤولاً في باقي عناصر ذمته المالية الأخرى عن الديون الناشئة عن استثمار مشروع الشركة.^(١)

وتعرف شركة الشخص الواحد بأنها كل مشروع يمتلك رأس ماله بالكامل شريك واحد، طبيعياً كان أو معنوياً، وتكون لهذه الشركة ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشريك، وتؤسس هذه الشركة ابتداءً من شريك واحد أو قد تؤول جميع الحصص فيها إلى شريك، ولذلك فإن شركة الشخص الواحد تعد استثناءً على الأصل الذي يقضي بوجوب توافر شريكين على الأقل لقيام أي شركة.^(١)

وقد عرفها المشرع المصري في المادة (٤ مكرراً) من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨، بنصه على أن: "شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها".

وتتخذ الشركة اسماً خاصاً لها يستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها، ويجب أن يتبع اسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد، ويوضع على مركزها الرئيسي وفروعها - إن وجدت - وفي جميع مكاتبها.

ومن هنا تختلف شركة الشخص الواحد، بهذا المفهوم، عن المؤسسة الفردية، فبينما نجد أن شركة الشخص الواحد تكون مسؤولية الشريك الوحيد فيها محدودة بمقدار ما خصصه من أموال كرأس مال للشركة، فإن مالك المؤسسة الفردية يكون مسؤولاً مسؤولية غير محدودة في كافة أمواله الشخصية عن ديون والتزامات المشروع، كما أن المؤسسة الفردية، وعلى خلاف شركة الشخص الواحد التي تكتسب شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمة الشريك، لا تكتسب شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة عن شخص صاحبها، وإنما يظل هو المسئول عن جميع حقوق والتزامات المؤسسة والضامن لجميع حقوق دائنيها.

الفرع الثاني: خصائص شركة الشخص الواحد

من خلال تعريف المشرع لشركة الشخص الواحد في المادة (٤ مكرراً) من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ المشار إليها سلفاً، يمكن تحديد أهم خصائص هذه الشركة فيما يلي:

١- اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية:

بالرغم من أن شركة الشخص الواحد يتم تأسيسها من شخص طبيعي أو اعتباري واحد من بداية حياة الشركة، أو أن تؤول جميع حصص الشركة إلى شخص واحد، فإنها تكتسب بمجرد قيدها في السجل التجاري الشخصية الاعتبارية^(٢)، بحيث تكون لها بعد ذلك ممارسة أعمالها التي

أنشأت من أجلها، ويعتبر تمتع الشركة بذمة مالية مستقلة من أهم الآثار المترتبة على تمتع الشركة بالشخصية المعنوية.

٢- المسؤولية المحدودة للشريك الفرد:

تتمتع شركة الشخص الواحد بذمة مالية منفصلة عن ذمة الشريك المؤسس لها أو الذي آلت إليه ملكية جميع رأسمالها، وبالتالي تستقل الشركة بأموالها عن أموال الشريك الواحد فيها، وهذا ما يؤدي بدوره إلى تحديد مسؤولية الشريك عن الالتزامات الناشئة على الشركة في حدود ما خصصه هذا الشريك من رأس مال لها، دون امتداد تلك الالتزامات إلى أمواله الشخصية، وتعد أموال الشركة هي الضمان الوحيد لدائنها، مع ملاحظة أن مسؤولية الشركة ذاتها عن ديونها ليست محدودة، بل هي مطلقة في جميع أموالها، وبذلك تتسم شركة الشخص الواحد بضعف ائتمائها مقارنة بغيرها من الشركات.

٣- عنوان شركة الشخص الواحد:

وفقاً للفقرة الثانية من المادة (٤ مكرراً) من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨، يجب أن يكون اسم شركة الشخص الواحد إما مستمداً من الغرض من تأسيسها أو من اسم المؤسس، ويجب أن يتبع اسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة، ويوضع على مركزها الرئيسي وفروعها - إن وجدت - وفي جميع مكاتبها.

٤- عدم اكتساب الشريك صفة التاجر:

يترتب على المسؤولية المحدودة للشريك في شركة الشخص الواحد أن الشريك الوحيد لا يكتسب صفة التاجر بمجرد تأسيسه الشركة، ما لم يكن قد اكتسبها من قبل^(١)، وتترتب على ذلك نتيجة مفادها: جواز شهر إفلاس شركة الشخص الواحد إذا توقفت عن دفع ديونها، ولا يجوز شهر إفلاس الشريك الوحيد تبعاً لإفلاس الشركة- كأصل عام-، وذلك لاستقلال ذمته المالية عن ذمة الشركة، وعدم اندماج شخصية الشريك الوحيد في شخصية الشركة القانونية، وعدم اكتسابه لصفة التاجر.^(١)

الفرع الثالث: مبررات تنظيم شركة الشخص الواحد

أخذت العديد من الأنظمة القانونية بشركة الشخص الواحد، سواء كانت بصورة شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مغلقة، وذلك للعديد من المبررات القانونية والإقتصادية:

أولاً: المبررات القانونية:

١- المسؤولية المحدودة للشريك:

لعل من أهم الأسباب التي تدفع بالأشخاص إلى اللجوء لصورة شركة الشخص الواحد، هو ما يتيح هذا النوع من النشاط التجاري من تحديد مسؤولية الشريك عن ديون أو التزامات الشركة، وذلك بمقدار حصته أو مساهمته في رأس المال، وبحيث لا تمتد تلك الالتزامات التي تقع على عاتق الشركة إلى أموال الشريك الشخصية، ومن خلال هذه الميزة، يتحقق لمؤسس الشركة المؤلفة من شخص واحد، النجاة من مخاطر التعثر المالي أو الإفلاس في حالة فشل مشروعه التجاري، حيث إن الشركة، عندما تعجز عن سداد الديون، فإنها هي من تتعرض لمخاطر الإفلاس وليس صاحبها.^(١)

٢- الحد من تأسيس الشركات الوهمية:

يقصد بالشركة الصورية أو الوهمية: تلك الشركة التي يضم نظامها الأساسي العدد المحدد قانوناً من الشركاء، وبحيث تبدو مكتملة الشكل القانوني المطلوب الذي تفرضه القواعد القانونية التي توجب ضرورة تعدد الشركاء كشرط لتأسيس الشركة واستمرارها، في حين تكون جميع الحصص أو الأسهم فيها مملوكة لواحد فقط من الشركاء، والذي تعود إليه بمفرده نتيجة الاستثمار المالي لمشروع الشركة، ولا يملك باقي الشركاء، على تعددهم، شيئاً من رأس المال، فيرغب منشئ الشركة الصورية أو الوهمية الاستفادة من تلك الميزة عبر التحايل على القانون.^(٢)

هذه الصورة لا تقتصر فقط على مخالفة القانون، وإنما يصل ضررها إلى من يتعامل مع هذه الشركة الصورية، وذلك بمنح المشروع التجاري، الذي يتخذ شكل شركة من الشركات، ائتماناً على خلاف الحقيقة في مواجهة الغير، لهذا كان وجود تنظيم قانوني خاص بشركة الشخص الواحد، لا يعد مجرد مطلب فقهي فقط، وإنما يمثل -من هذه الوجهة - ضرورة عملية ملحة، وذلك للقضاء على الشركات الوهمية وما يترتب عليها من آثار سلبية.

ثانياً: المبررات الاقتصادية لشركة الشخص الواحد:

١- تحقيق متطلبات الإدارة المثلى للمشروعات التجارية:

من أهم المزايا التي ترتبط بشركة الشخص الواحد، هي القدرة على الاستفادة من مزايا الإدارة الفردية للمشروعات التجارية، فيستطيع الشريك الوحيد أن يدير مشروعه بنفسه، أو أن يتخذ قراراً بتعيين مدير من الغير، وبحيث تعكس هذه الإدارة رغبات وتطلعات هذا الشريك الوحيد لمشروعه التجاري، والاستفادة، من ثم، مما تتسم به تلك الصورة من الإدارة من مرونة وسرعة، دون التقييد بالإجراءات الشكلية المعتادة لصورة الإدارة الجماعية، وما تتطلبه من انعقاد الجمعيات العامة للشركاء، فضلاً عما تنطوي عليه من خضوع رأي الأقلية للأغلبية.

وعلى هذا فوجود شريك وحيد في شركة الشخص الواحد، يمثل فرصة لإدارة الشركة بشكل فعال، لا يتقيد فيها بإجراءات دعوة باقي الشركاء للاجتماع، أو الحاجة إلى الحصول على الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات، وربما تعطيل اتخاذ القرارات الهامة والعاجلة في حالة عدم تأمين تلك الأغلبية، ما يؤثر سلباً على اقتصاد الشركة، كما أن الإنفراد بالإدارة، في بعض الحالات، قد يحول دون تحقق إشكالات بين الأعضاء تحد من عملية اتخاذ القرارات.

غير أن صورة الإدارة الفردية، التي تعتبر وبحق من مزايا تأسيس مثل هذا النوع من الشركات، إذا كانت تعتبر ميزة فعلية في حالة إدارة الشركات البسيطة، فإنها قد لا تصلح في حالة وجود شركات كبرى تقوم بأعمال معقدة وتحتاج إلى إدارات متخصصة، مما يفرض على الشريك الوحيد أن يلجأ إلى أساليب الإدارات المتخصصة لتسيير أمور الشركة، إضافة إلى أن تصرفات الشريك الوحيد، إذا ما قام بإدارة الشركة بنفسه فقط، في الوقت الذي تعد فيه تلك التصرفات ملزمة للشركة في مواجهة الغير حسن النية، قد تلحق ضرراً بدائي الشركة، وتعطي الشريك مجالاً واسعاً للتحايل وإبرام عقود صورية.

٢- الحفاظ على بقاء واستمرار الشركة ككيان اقتصادي مزدهر:

بما أن شركة الشخص الواحد تقوم على مبدأ الفصل بين الذمة المالية الشخصية للشريك، والذمة المالية المخصصة للغرض من تأسيس الشركة، فإن المسؤولية المحدودة للشريك بمقدار المبلغ المالي الذي خصصه لممارسة عمله التجاري، يترتب عليها السماح للأشخاص بإنشاء مشروع يتمتع بذمة مالية مستقلة، في صورة شركة شخص واحد، ومن ثم تحقيق الاستقلال بين مختلف المشروعات التي يملكها نفس الشخص، وبحيث لا تتأثر المشروعات المزدهرة مالياً بتعثر غيرها من

المشروعات المملوكة لذات الشخص أو إفلاسها، ومن ثم الحفاظ على استمرار الشركة كوحدة تجارية واقتصادية.

وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن تأسيس شركة من شخص واحد تكتسب الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية هذا الشريك، يترتب عليه أن تكون حياة واستمرار هذه الشركة منفصلة تماماً عن حياة مالكيها، فوفاة المالك لن تكون نتيجتها الحتمية هي انقضاء هذه الشركة، كما هو الشأن بالنسبة للمشروع الفردي، حيث يمكن انتقالها للورثة، وذلك باتباع إجراءات تحويل هذه الشركة إلى شركة متعددة الشركاء، ومن ثم تجنب بيعها بحجة تقسيم الموجودات بين الورثة.^(١) وكذلك الأمر بالنسبة لحالة تنازل الشريك عن الشركة لصالح الغير، فإن هذا التنازل يمكن أن يتم بكل يسر وسهولة، بخلاف التنازل عن الشركات الأخرى، والذي يتطلب موافقة باقي الشركاء، أو خضوعها لإجراءات قانونية وقضائية متعددة.^(٢)

٣- تأمين استمرار أعمال المهنين:

تقدم شركة الشخص الواحد حلاً عملياً لأصحاب المهن الحرة، كالمحاسبين والمحامين والصيدلة، وغيرهم ممن يحظر عليهم بحكم القانون احتراف التجارة، وذلك لتمكينهم من ممارسة مهنتهم من خلال شكل الشركة، والتمتع بكافة المزايا المرتبطة بهذا الشكل، فقد يقضي أصحاب هذه المهن فترة طويلة من أعمارهم لبناء خبراتهم ومراكز أعمالهم، وبالتالي يكون من غير المنصف أن تنتهي هذه المشروعات بوفاة أصحابها، أو ألا يتمكن ورثتهم بعد وفاتهم من الاستفادة من ثمار هذه الأعمال، لانقضائها بانقضاء حياة أصحابها، بعد أن تكون قد اكتسبت الشهرة.

المطلب الثاني

الأساس القانوني لشركة الشخص الواحد

تمهيد:

يتقاطع تنظيم شركة الشخص الواحد بعدد من الأنظمة القانونية المستقرة في القواعد العامة، والتي تقف حائلاً دون تنظيم هذا النوع من الشركات، فالأركان، الموضوعية والشكلية، الواجب توافرها لتأسيس الشركات -بشكل عام- لا تتوفر مجتمعة لشركة الشخص الواحد، حيث تتعارض الطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحد مع المبادئ القانونية المستقرة للشركات في القانون، وعلى رأس هذه المبادئ مبدأ الفكرة التعاقدية، وما تستلزمه من ضرورة تعدد الشركاء، فضلاً عما يفرضه مبدأ وحدة الذمة المالية وعدم قابليتها للإنقسام.

وفي مقابل ذلك، فقد اجتهد مؤيدو تنظيم شركة الشخص الواحد في محاولة إسناد هذا النوع من الشركات إلى أساس قانوني تقوم عليه، وذلك ما بين إرجاعها إلى ما يعرف بـ "نظرية تخصيص الذمة المالية"، أو مبدأ الإرادة المنفردة، أو نظرية الشخصية المعنوية، وذلك للتأسيس لمبدأ الفصل بين شخصية الشريك الوحيد وشركة الشخص الواحد، وكأساس لتحديد مسؤولية الشريك الوحيد.

وبناءً على ذلك، سوف نعرض أولاً لمدى تعارض الطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحد مع المبادئ القانونية المستقرة للشركات في الأنظمة القانونية، ثم نتناول ثانياً الأساس القانوني لشركة الشخص الواحد.

الفرع الأول

تعارض الطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحد مع المبادئ القانونية المستقرة في النظرية العامة للشركات

أولاً: تعارض شركة الشخص الواحد مع الفكرة العقدية:

عرف المشرع عقد الشركة في المادة ٥٠٥ من التقنين المدني بأنها: "عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة".^(١)

ويتطلب هذا المفهوم اللغوي والقانوني للشركة (باعتبارها عقداً) أن تشتمل على أكثر من شخص واحد، سواء أكان هذا الشخص طبيعياً أو معنوياً. لذا، يلزم فكرة العقد، كأساس لقيام الشركة وكشرط لقيامها، مبدأ تعدد الشركاء.

ويترتب على هذا المعنى، الذي يطبع الشركة بالطابع العقدي، بطلان شركة الشخص الواحد وانعدامها في مرحلة التأسيس، لانتفاء ركن تعدد الشركاء الذي تمليه الفكرة العقدية للشركة، واعتبارها منحلة بحكم القانون، في حالة اجتماع رأسمالها في يد شريك واحد.

إلا أنه وبالرغم من هذا التعارض ما بين الفكرة العقدية، التي تستلزم وجود شريكين أو أكثر في الشركة، وبين فكرة الشركة التي لا تحتوي إلا على شريك وحيد فقط، فإن المشرع المصري خرج على هذا الأصل، بأن أورد استثناء يسمح بوجود شركة تتألف من شخص واحد، بطبيعة خاصة مختلفة عن باقي أنواع الشركات الأخرى، وذلك بنصه في المادة الثامنة من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ - بتعديل بعض أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - على أنه: "فيما

عدا شركة الشخص الواحد، لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة، كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقي الشركات الخاضعة لهذا النظام...". ومن هنا يتبين لنا أن القانون المصري أورد - ضمناً - أنه يمكن أن تقوم شركة الشخص الواحد دون حاجة لطرف آخر يتعاقد معه، وذلك بناء على إرادته المنفردة.

وبموجب هذا النص، فإنه لا تعارض بين تكوين شركة تتكون من شخص واحد في القانون المصري، وبين تعريف الشركة، لأن السماح بتكوين شركة بذلك الشكل، يعبر عن حالة استثنائية خارجة عن الأصل العام، وهي الصفة العقدية للشركة.

وهذا هو مسلك القانون المدني الفرنسي الصادر عام ١٩٨٥م، الذي نص على أن: "تنشأ الشركة من شخصين أو أكثر يتفقون بمقتضى عقد يبرم فيما بينهم على تخصيص أموال أو عمل لمشروع مشترك، بغرض تقسيم الأرباح الناتجة عنه، ويجوز أن تنشأ الشركة بعمل إرادي من شخص واحد، وذلك في الحالات التي يحددها القانون". فقد أجاز المشرع الفرنسي، على هذا، أن تقوم شركة بإرادة منفردة، ولكن وفق الحالات المحددة بالقانون، وبالتالي أصبحت الإرادة المنفردة، بجانب العقد، مصدراً منشئاً للشركة.

ثانياً: تعارض شركة الشخص الواحد مع مبدأ "وحدة الذمة المالية":

يقصد بالذمة المالية في الفقه القانوني "التقليدي": مجموع ما للإنسان من حقوق أو أموال وما عليه من ديون تقدر بالنقد، منظوراً إليها باعتبارها مجموعة أو وحدة قانونية^(١). وكقاعدة، فإنه لا يدخل في الذمة المالية كافة الحقوق والدعاوى التي ليست لها قيمة مالية، إذ يطلق على هذه الحقوق، الحقوق الخارجة عن الذمة المالية، ومن هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة وحقه في العمل والزواج والتنقل، وسائر الحريات العامة، ولكن الاعتداء على هذه الحقوق قد يولد حقاً مالياً لصاحبه في طلب التعويض عن الضرر الذي أصابه من هذا الاعتداء، فيدخل هذا التعويض عندئذ في نطاق الذمة المالية^(٢).

فالذمة المالية في القانون تشمل الحقوق المالية التي يملكها الإنسان بالفعل، والتي قد يملكها في المستقبل، سواء أكانت حقوقاً شخصية أو عينية، وبالإضافة إلى ذلك، يدخل في نطاق الذمة المالية جميع الحقوق التي يكون موضوعها أشياء غير مادية، والتي تسمى بحقوق الملكية الأدبية والفنية وحقوق الملكية الصناعية والتجارية، ولكن هذه الحقوق تدخل في الذمة المالية باعتبار جانبها المالي فقط، كحقوق المؤلف المالية، وأما الجانب المعنوي من هذه الحقوق، فلا

يدخل في الذمة المالية، لأنها حقوق غير ذات قيمة مالية.^١

ويتضح من تعريف الذمة المالية على النحو السابق، أن الذمة المالية تتكون من شقين اثنين: أحدهما إيجابي يتمثل في مجموع ما للشخص من حقوق مالية، والآخر سلبي يتمثل في مجموع ما على الشخص من التزامات مالية، فإذا غلب الشق الإيجابي أصبحت الذمة دائنة، وإن زاد الشق السلبي أصبحت الذمة مدينة، وهذان الشقان مندمجان كوحدة متكاملة، بحيث يشكلان معاً الذمة المالية للشخص القانوني.

النتائج المترتبة على مبدأ وحدة الذمة المالية: ترتبط هذه الوحدة أو المجموعة، المكونة للذمة المالية، من فكرة الشخصية، حيث إن إرادة الإنسان تجعل من جميع الحقوق التي يتمتع بها، مجموعة واحدة مستقلة تخضع لنظام قانوني معين، وعلى هذا، استخلصت النظرية التقليدية نتيجتان، اعتبرتا الأساس الذي قامت عليه هذه النظرية، وهما: الأولى: أن الذمة المالية هي مجموعة قانونية، والثانية: ارتباط الذمة المالية بالشخصية.

١- الذمة المالية مجموعة قانونية:

فالذمة المالية في نظر الفقه التقليدي مجموعة قانونية مستقلة عن العناصر المكونة لها، وهي ليست ذات الحقوق والالتزامات المالية المتكونة منها، بل هي مجموع من المال تفتى فيه كل العناصر الداخلة فيه، فجميع حقوق الإنسان والتزاماته تؤلف كلاً لا يتجزأ، أي تؤلف وحدة قانونية هي الذمة المالية.

وثمة نتائج ثلاثة أساسية تترتب على اعتبار الذمة المالية مجموعة قانونية مندمجة في مجموع من المال:

أ- ارتباط العناصر الموجبة للذمة المالية بالعناصر السالبة:

فيضمن الموجب منها السالب، ويتميز هذا المجموع من المال - أي الذمة المالية - عن كل العناصر المكونة له، إذ تقوم الذمة المالية بذاتها كوحدة مجردة، لها كيانها الخاص المستقل عن عناصرها المكونة لها، ووفقاً لذلك، فإن كل التغيرات التي تحدث على هذه العناصر، والتي يكون من شأنها التأثير في قيمتها الإيجابية أو السلبية، لا يكون لها من أثر في كيان الذمة المالية ذاتها، إذ تبقى الذمة المالية وحدة متميزة عن العناصر الداخلة في تكوينها.^٢

وعلى هذا، يتحقق وجود الذمة المالية، ولو لم يكن لصاحبها أو عليه أي حق، اكتفاء باحتمال نشوء حقوق مالية له أو عليه في المستقبل.^٣

وعلى أساس ما تقدم، تتخصص عناصر الجانب الإيجابي للذمة المالية للوفاء بعناصر الجانب السلبي لها، سواءً تلك العناصر الحالية منها أو المستقبلية، ولولا نظرية الذمة المالية لاقتصر حق كل دائن عادي على الأموال الموجودة وقت نشوء الدين دون الأموال المستقبلية، فبفضل نظرية الذمة المالية أصبحت الذمة المالية (بما تشتمل عليه من أموال وحقوق) هي الضمان العام للدائنين.^(١)

فعندما نقول: إن ذمة المدين هي الضمان العام لدائنيه، فالمقصود بذلك هو ما اشتملت عليه الذمة المالية من عناصر إيجابية وقت التنفيذ، لا وقت نشوء الدين، فالذي ينفذ عليه الدائن ويبيعه لاستيفاء دينه هو أموال المدين، وليست الذمة المالية للمدين، لأن تلك الذمة غير قابلة للحجز أو البيع، وإنما ينفذ على العناصر الإيجابية الموجودة في الذمة المالية، كما أن للدائنين حق ضمان عام على هذا المجموع، لا على مال معين بالذات، فيستطيع الدائن أن ينفذ على أي مال للمدين، حتى ولو لم يكن هذا المال مملوكاً للمدين وقت نشوء الدين، إلا أنه قد أصبح أحد عناصر ذمته المالية وقت التنفيذ، هذا من جانب، ومن جانب آخر لا يستطيع الدائن التنفيذ على مال كان في ذمة المدين المالية وقت نشوء الدين، إلا أنه خرج منها قبل التنفيذ، لأن هذا الدين قد انفصل عن الذمة المالية ولم يعد محسوباً من ضمن عناصرها، فهذا المال قد خرج من الضمان العام للدائنين.^(٢)

ب- ينتقل هذا المجموع من المال -بعناصره الإيجابية والسلبية- بالوفاة من المورث إلى الوارث، أي تنتقل ذمة المورث المالية إلى وارثه، ذلك أنه لما كانت الذمة المالية تمثل وحدة قانونية يرتبط جانبها الإيجابي بالجانب السلبي، فعليه، لا ينهار هذا الارتباط عند وفاة صاحبها، بل يظل قائماً بحيث تنتقل ذمة المورث المالية - بما تشتمل عليه من حقوق وديون - إلى وارثه.^(٣)

ج- يحل المال المستبدل بأي عنصر في هذا المجموع محل المال المبدل، باعتبار أن المال المبدل عنصراً في مجموع من المال، ويبقى هذا المجموع -أي الذمة المالية- على حاله، بالرغم من تغير عناصره، وذلك بفضل تماثل عناصر الذمة المالية.^(٤)

٢- ارتباط الذمة المالية بالشخصية:

أما بالنسبة للفكرة الثانية التي ترتبط بمبدأ وحدة الذمة المالية، فتتمثل في أن أهم خصائص الذمة المالية، هي أنها بمثابة تعبير عن المظهر المالي للشخصية القانونية للإنسان، فالذمة المالية في نظر فقهاء القانون ليست سوى المظهر المالي للشخصية، والتعبير عن القدرة المالية التي يملكها

الإنسان باعتباره إنساناً، وعلى هذا تعتبر الذمة المالية أثراً من آثار الشخصية القانونية، فمجرد الصلاحية لأن يكسب الشخص حقوقاً ولو لم يكسبها بالفعل، وصلاحيته لأن يلتزم بديون، ولو لم يلتزم بدين ما منها، بمجرد الصلاحية تلك تقوم الذمة المالية، وبهذا تقترب الذمة المالية بهذا المعنى من أهلية الوجوب في الفقه الإسلامي.^(١)

فالذمة المالية بهذا المعنى هي قابلية كسب الحقوق وترتيب الالتزامات، وهذه هي الشخصية القانونية، وعلى هذا ذهب أنصار النظرية التقليدية إلى القول بأن الذمة المالية هي الشخصية القانونية، ويترتب على ذلك أن الأشخاص وحدهم هم من يكتسبون الذمة المالية، وعدم قابلية الذمة المالية للانفصال عن صاحبها.^(٢)

وقد استنتج أنصار النظرية التقليدية من ارتباط الذمة المالية بالشخصية نتيجة أخرى، وهي عدم قابلية الذمة المالية للتعدد، إذ ليس للشخص الواحد إلا ذمة مالية واحدة، شأنها شأن الشخصية، فكما أن الشخصية لا تتعدد ولا تتجزأ، فإنه لا يجوز للشخص - حال حياته - أن يجزئ ذمته المالية، فيجعل بعض الدائنين يختصون بجزء منها والدائنين الآخرين يختصون بالجزء الآخر، إذ أن الشخصية لا تتعدد ولا تتجزأ وعلى هذا يكون لكل شخص ذمة مالية واحدة.^(٣) أما إذا وجدت ذمة مالية تضاف إلى جانب الذمة المالية الأصلية، فلا يعبر ذلك سوى عن حالات معينة على سبيل الاستثناء، وفي غير هذه الحالات لا يجوز لشخص حال حياته أن يجزئ ذمته المالية، فيجعل بعض الدائنين يختصون بجزء منها والدائنين الآخرين يختصون بالجزء الآخر.^(٤)

وواضح أن هذا الفهم يتنافى مع إمكانية قيام الشخص باقتطاع جزء من أمواله يترتب عليه قيام شخص معنوي مستقل بذمته المالية عن الذمة المالية العامة لصاحبه في صورة شركة من شخص واحد.

الفرع الثاني

الأساس القانوني لشركة الشخص الواحد

اجتهد الفقه القانوني الحديث في محاولة لتحديد الأساس القانوني لشركة الشخص الواحد، ما بين إرجاعها إلى ما يعرف بـ "نظرية تخصيص الذمة المالية"، أو تأسيسها على فكرة الشخصية المعنوية، وذلك كمصدر منشئ لشركة الشخص الواحد، وفي ذات الوقت للتأسيس لمبدأ الفصل بين شخصية الشريك الوحيد وشركة الشخص الواحد.

وبناء على هذا سوف نتناول: نظرية تخصيص الذمة المالية، ثم نظرية الشخصية المعنوية:

أولاً: "نظرية تخصيص الذمة المالية":

يذهب أنصار هذه النظرية، وفي مقدمتهم الفقيه الألماني برنر، إلى أن الذمة المالية لا تستند على أساس الشخصية، بل تستند على أساس التخصيص لغرض معين، فالذمة المالية ليست هي الشخصية، ولا هي متفرعة عنها، ولا مرتبطة بها، بل هي مجموعة من الحقوق والواجبات ترتبط فيما بينها، لا بسبب انتمائها إلى شخص معين، وإنما بسبب تخصيصها لغرض معين.^(١)

فحيث توجد مجموعة من الحقوق والالتزامات المالية يجمعها الاستناد إلى غرض معين، يمكن القول بوجود ذمة مالية، دون حاجة إلى استلزام وجود شخص معين تستند إليه هذه الحقوق والالتزامات المالية^(٢)، ودون حاجة أو ضرورة لإسناد الحقوق والالتزامات إلى شخص معين أو إلى عدد من الأشخاص.

فلا ضرورة إذن، لكي يقوم الحق، من وجود صاحب له، فهناك حالات ينهض فيها هذا الحق بذاته دون إسناده إلى شخص معين، مثال ذلك أنه عندما يخصص مجموع من المال لغرض معين، فإن هذا المجموع يعتبر (ذمة مالية) تنهض بمجرد تخصيص هذا المجموع من المال لغرض معين، فنكون في هذه الحالة أمام ذمة مالية صالحة لكي تنصب فيها بعض الحقوق ولتحققها بعض الالتزامات، دون حاجة لوجود صاحب تعزى إليه.

وقد أراد أنصار نظرية التخصيص تلك، الاستغناء عن فكرة الشخص المعنوي، إذ إنهم يقصرون الشخصية القانونية على الشخص الطبيعي وحده، ويعتبرون الشخصية المعنوية مجرد افتراض يخالف الواقع، فالشخص المعنوي -في نظرهم- مجرد حيلة مصطنعة لإمكانية الاعتراف لمجموعات من الأشخاص (كالجمعيات والشركات)، أو الأموال (كالأوقاف والمؤسسات) بذمة مالية خاصة مستقلة عن ذمة كل عضو من أعضائها، ولا يحتاج الأمر -في نظر أنصار نظرية التخصيص- لإدراك هذه النتيجة إلى افتراض هذه الشخصية المعنوية، لأن كلاً من هذه المجموعات تفترض وجود حقوق والتزامات مالية يجمعها التخصيص لغرض معين، أي تفترض وجود ذمة مالية قائمة بذاتها دون أن تستند إلى شخص معين.^(٣)

وعلى هذا، تم تفسير الأوضاع القانونية التي تنتج عن نشاط جماعي يؤثر في مصالح مجموع من الأشخاص دون أن ينسب إلى شخص معين منهم بالذات، فالحقوق والالتزامات التي تتعلق بنشاط الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، مستقلة عن حقوق والتزامات الأفراد المكونين لها، والرابط

الذي يجمع بين هذه الحقوق والالتزامات يستقل بها عن حقوق الأفراد المكونين لها، وهو الغرض المقصود من الجمعية أو الشركة أو المؤسسة، وعلى ذلك توجد ذمة مالية مشتملة على الحقوق والالتزامات التي تتعلق بنشاط الشركة أو المؤسسة، فهي ذمة مالية لا تستند إلى شخص ما في وجودها، وإنما يجمع عناصرها الغرض الذي خصصت له.

النتائج المترتبة على نظرية تخصيص الذمة المالية:

وتأسيساً على ما تقدم، فقد استنتج من نظرية تخصيص الذمة المالية نتائج ثلاثة تخالف النتائج المستخلصة من النظرية التقليدية للذمة المالية هي. (١): إمكانية وجود ذمة مالية دون الاستناد إلى شخص ما. (٢): إمكانية تعدد الذمة المالية للشخص الواحد. (٣): إمكانية انتقال الذمة المالية.

١- وجود ذمة مالية لا تستند إلى شخص ما:

إن الرابط الذي يجمع بين عناصر الذمة المالية -وفقاً لنظرية التخصيص- هو تخصيصها لتحقيق غرض معين، وعلى ذلك فمن الجائز أن توجد ذمة مالية دون أن ترتبط في وجودها بشخص ما، فلو قام شخص بتخصيص جزء من أمواله لغرض إيجاد شركة أو مؤسسة، فلا ضرورة لوجود شخصية معنوية لتلك الشركة أو المؤسسة تستند إليه.

وعلى هذا يكفي أنصار هذه النظرية -كما أسلفنا- بوجود ذمة مالية جديدة عن ذمة الشخص المالية العامة، وهذه الذمة المالية الجديدة لا تستند إلى شخص ما، وإنما تقوم على أساس تخصيص العناصر المكونة لها لتحقيق غرض معين، وإذا كان القانون يعطي للعناصر المخصصة لتحقيق غرض معين شخصية اعتبارية، فإن الشخصية هنا تعتبر أثراً للذمة المالية، أي أن الذمة المالية هي التي خلقت الشخصية وليس العكس.^(١)

٢- إمكانية تعدد الذمة المالية للشخص الواحد:

ما دامت الذمة المالية -وفقاً لنظرية التخصيص لغرض مالي معين- تستند على أساس تخصيص مجموعة من الحقوق والالتزامات لتحقيق غرض معين، ولا تستند على أساس الشخصية، فمن الممكن أن تتعدد الذمم المالية للشخص الواحد، بحيث يكون له أكثر من ذمة مالية واحدة بقدر تعدد أوجه تخصيص المال، أي تتعدد الذمم المالية للشخص الواحد بتعدد الأغراض التي تخصص لها مجموعات من حقوقه والتزاماته.

ومن الأمثلة الدالة على وجود هذا التعدد للذمم في القانون^(١)، نظام الوقف^(٢): فهو نظام ينشأ من خلال تخصيص أموال معينة لتحقيق غرض معين، وبذلك يتكون الوقف من عنصرين: ذمة مالية مستقلة، وغرض معين تخصص هذه الأموال لتحقيقه.

وتعد تجزئة الذمة من الأسباب الأساسية للاعتراف بشركة الشخص الواحد، إذ إنها تتيح للشخص أن تكون له ذمة مالية تجارية تخصص لغرض معين هو شركة الشخص الواحد، وعلى أن تظل حقوق والتزامات الشركة محدودة بقيمة المبلغ المخصص لها كذمة مالية تجارية مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها - كما سيلي -.

٣- إمكانية انتقال الذمة المالية:

يترتب على تصور استناد الذمة المالية على أساس التخصيص لتحقيق غرض معين، وليس على أساس الشخصية - وفقاً للنظرية الحديثة - أنها تكون مجموعة فعلية - لا مجموعة احتمالية - من الحقوق والتزامات المالية المخصصة لتحقيق غرض معين، فيمكن - تبعاً لذلك - التصرف بالذمة المالية، لأنها كمجموعة فعلية، يمكن النزول عنها، ويجوز انتقالها بالموت إلى الورثة، دون حاجة إلى ما تصطنعه النظرية التقليدية في سبيل تبرير هذا الانتقال^(٣)، كما أن إباحة التصرف في الذمة المالية، بما تشتمل عليه من حقوق وديون حال الحياة، من شأنه تيسير التعامل، وهو أمر لا يمكن الوصول إليه إلا بإقرار فكرة التخصيص لتحقيق غرض معين^(٤).

ثانياً: نظرية الشخصية المعنوية:

الشخصية القانونية هي مجموعة تنظيمية من القواعد القانونية يجري تطبيقها على الفرد، أو مجموعات الأفراد^(٥)، والشخص القانوني، بصفة عامة، هو مجموعة من الحقوق الشخصية والتزامات والمسؤوليات، وإذا كانت ثمة اختلافات تقوم بين القواعد التنظيمية للكائن القانوني - فرداً كان هذا الكائن أو مجموعة - فذلك مرجعه، ليس إلى اختلاف في الطبيعة بينهما، وإنما إلى اختلاف في مستوى أو درجة التنظيم^(٦).

ويتضح من التبع التاريخي للشخصية المعنوية للشركة أنها تقوم أساساً على وجود شريكين على الأقل لإمكان تأسيس الشركة، والدافع إلى تطلب توافر المصلحة الجماعية لمنح الشركة الشخصية المعنوية، هو ما يحدث أحياناً في العمل من تسيير مشروعات فردية بقصد الإفادة من مبدأ تحديد المسؤولية، وقيام شركات غير حقيقية "وهية" لا يعترف بها القانون، فقد يلجأ البعض إلى

التحاييل لتكوين شركات وهمية، لأن الطرف الآخر لا يكون سوى خيال ظل حتى يكتمل فقط الشكل القانوني للشركة.

إلا أن بعض القوانين الحديثة تفحصت الواقع، وأقرت حديثاً الشخصية المعنوية للمشروع الذي يمتلكه شخص واحد، منحية جانباً الاعتبارات القانونية الشكلية التي لا يصح أن تحجب عن استكشاف الحقائق الاقتصادية والاجتماعية القائمة في الواقع، وطرحت نوعاً جديداً من الشركات، وهو شركة الشخص الواحد، لتستوعب الحالات التي يتم فيها الالتجاء لشكل الشركة المتمتعة بالشخصية المعنوية دون مقتضى الشركات الوهمية، حتى يتسنى التقريب بين الواقع والقانون، إذ لا جدال في وجود هذه المشروعات في شكل شركات لا تحمل من عناصر الشركة إلا اسمها.^(١)

ولما كانت الحكمة التي استهدفها المشرع من منح الشخصية المعنوية للشركة، هي تمكينها من مواجهة الغير، كشخص واحد متميز ومستقل عن الأعضاء المكونين له ليسهل تحقيق الغرض الذي اجتمعت من أجله مجموعة الأشخاص أو الأموال، وكذلك إمكانه تحديد مسؤولية الشركاء فيه عند حدود مساهمتهم في رأسماله، فقد أخذت التشريعات الحديثة -على سبيل المثال التشريع الفرنسي والألماني الحاليان- طرح شكل جديد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، كأساس لتنظيم مشروع الشخص الواحد ذي المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، وهكذا أعفى القانون المشروع الفردي من ركن تعدد الشركاء، وسمح له باكتساب الشخصية المعنوية مباشرة، وبعبارة أوضح اعترف للشخص الواحد أن ينشئ بمفرده شركة تتمتع بالشخصية القانونية دون حاجة إلى وجود شركاء آخرين، حيث كانت هذه الشركات موجودة بالفعل في الحياة العملية، في شركات لا تحمل من عناصر الشركة إلا اسمها.

ويلاحظ أن القانون الفرنسي الجديد رقم ٩٩٧ - ٨٠ الصادر في ١١ من يوليو سنة ١٩٨٥ أسس تنظيم مشروع الشخص الواحد ذي المسؤولية المحدودة على فكرة الشخصية المعنوية، أي على أساس قانون الشركات وليس على فكرة ذمة التخصيص كنظام.^(٢)

وإذا كانت الحاجة إلى الفصل بين الأموال المخصصة للنشاط موضوع الشركة والأموال الشخصية للشركاء، اقتضت الإقرار للشركة بذمة مالية مستقلة، وما يتبع ذلك من نتائج، وذلك في ظل وجود مجموعة من الأشخاص داخل الشركة، فليس هناك ما يمنع أن يكون للشخص الواحد هذه النتيجة، طالما أن هناك حاجة ملحة تقتضي ذلك، أي أن فكرة شركة الشخص

الواحد تقتضيها الضرورات العملية، ولا شيء يمنع من ذلك في ظل القواعد والأحكام المتضمنة في قانون الشركات.

المبحث الثاني

أحكام شركة الشخص الواحد

تمهيد وتقسيم:

اتجهت القوانين المقارنة إلى تنظيم شركة الشخص الواحد بوصفها نوعاً من أنواع الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركات المساهمة المغلقة، وذلك من خلال إخضاعها للقوانين التي تنظم هذين النوعين من الشركات، مع النص على بعض القواعد الخاصة بها^(١)، أو من خلال إصدار تشريعات خاصة لتنظيم شركة الشخص الواحد، مع الإحالة فيما لم يرد به نص خاص إلى القواعد العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات المساهمة والشركات بوجه عام.^(٢) أما فيما يتعلق بالقانون المصري فقد نص المشرع في المادة (٦) من القانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، على أنه: "يضاف إلى الباب الثاني من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليه فصل رابع بعنوان "شركات الشخص الواحد" يضم مواد جديدة نصوصها الآتية...".

وفي ضوء هذه النصوص نعرض لأحكام شركة الشخص الواحد من حيث التأسيس واكتساب الشخصية الاعتبارية، ورأسمال الشركة، وإدارتها، وطبيعة مسؤولية الشريك، وانقضاء الشركة، وذلك على النحو التالي:

المطلب الأول:

تأسيس شركة الشخص الواحد

أولاً: تكوين الشركة:

تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة (الجهة الإدارية المختصة)، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل على اسمها، وأغراضها،

وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، وفروعها إن وجدت، ومقدار رأسمالها، وقواعد تصنيفاتها، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.^(١)

وتتميز شركة الشخص الواحد عن غيرها من الشركات بأن تكوينها يتم بإحدى طريقتين، طريقة التأسيس المباشر، والتأسيس غير المباشر:

١- التكوين المباشر:

هو التكوين الذي لا يرتبط فيه الشركاء المؤسسون "الشريك الوحيد" بشركة موجودة، فهو خلق شخص معنوي جديد، وذلك من خلال عمل إرادي منشئ للشركة لأول مرة من شخص واحد فقط، وقد أخذ بهذا الطريق قانون الشركات الألماني لعام ١٩٨٠م، وقانون الشركات الفرنسي لعام ١٩٨٥م، كما فعل ذلك المشرع المصري، حيث أجاز تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، وذلك في المادة (١٢٩ مكرراً) من القانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨، التي تنص على أنه:

استثناء من حكم المادة (٥٠٥) من القانون المدني، يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري، في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقاً لأحكام هذا الفصل، وتكون هذه الشركة محدودة المسؤولية.

ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين التي تميز لبعض الجهات تأسيس شركات بمفردها، يشترط لتأسيس الشركة إذا كان مؤسسها أحد أشخاص القانون العام الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، بحسب الأحوال.

وقد حظر القانون على شركات الشخص الواحد القيام بتأسيس شركة من شركات الشخص الواحد.^(٢)

وتخضع شركة الشخص الواحد - كقاعدة عامة - للأحكام العامة للإرادة المنفردة، ويسري على الإرادة المنفردة ما يسري على العقد من أحكام، باستثناء ما يتعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام^(٣)، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص، تطبق على شركات الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسؤولية المحدودة الواردة بهذا القانون.^(٤)

٢- التكوين غير المباشر:

يقصد بالتكوين غير المباشر لشركة الشخص الواحد، اجتماع كل أسهم الشركة أو حصصها في يد مساهم أو شريك واحد، سواء بشرائها، أو نتيجة وفاة الشريك الثاني، إذا كان ليس له وارث، في الشركة المكونة من شريكين فقط، أو لأي سبب آخر مشروع.^٥

وبالرغم من عدم اشتغال النص السابق على إمكانية استمرار الشركة في حالة أيلولة جميع حصصها إلى شريك واحد، فإنه بالمقابل لا يوجد في هذا القانون ما يحول، في حالة اجتماع حصص الشركة في يد شريك واحد، من استمرار الشركة بالطريق الاستثنائي لتكوين شركة الشخص الواحد، فالأساس المكون لهذه الشركة في هذه الحالة هو العقد المبرم بين شريكين أو أكثر، بمعنى أن الشركة في هذه الحالة تكون قد تكونت بالطريقة التقليدية وفقاً لمبدأ تعدد الشركاء، وبدلاً من انقضاء الشركة في حالة زوال هذا التعدد، تستمر الشركة بشريك واحد، ويعترف القانون بصحتها واستمرار شخصيتها المعنوية في حال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة الشخص الواحد.

ثانياً: رأسمال الشركة:

شركة الشخص الواحد في القانون المصري هي شركة من شركات المسؤولية المحدودة، وقد سبق أن أشرنا إلى أن العيب الرئيسي لهذه الشركات هو ضعف الضمان الذي تقدمه للغير، ولذلك فقد اضطر المشرع، خشية تأسيس شركات من هذا النوع برؤوس أموال منخفضة لا تكفي لضمان حقوق دائئيهما، إلى تطلب حد أدنى لرأس المال لا يجوز في أي وقت النزول عنه، ضماناً لجدية المشروع وتوفير حد أدنى من الضمان يمكن الدائنين من التعويل عليه، حيث تقضي القواعد المنظمة للشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنه لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأسها عن خمسين ألف جنيه، ويجب أن يدفع بالكامل عند تأسيس الشركة.^٦

ووفقاً للمادة ١٢٩ مكرراً (١) من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨: "تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى لرأسمال شركة الشخص الواحد".

وتنفيذاً لهذا النص فقد صدر القرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨، ونص في المادة (٢٨٧ مكرر ٢) على أنه: "لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن خمسين ألف جنيه ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة".

ولا يجوز لشركة الشخص الواحد أن تلجأ إلى الاكتتاب العام، سواء في مرحلة تكوين رأس المال لدى تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها، كما لا يجوز لها تقسيم رأسمال الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول، أو الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، كما أن القانون قد حظر على شركة الشخص الواحد ممارسة أعمال التأمين أو البنوك أو الادخار أو تلقي الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير.^(١)

ثالثاً: اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية:

وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (١٢٩ مكرراً) من القانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨: تشهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري. وتسري العقود والتصرفات التي أجراها المؤسس باسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت لازمة لتأسيس الشركة.^(٢)

المطلب الثاني: إدارة شركة الشخص الواحد

بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لشركة الشخص الواحد، لا سيما ما يتعلق بوجود شريك وحيد فيها، ومحاولة تطبيق أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة عليها، فإن الشريك الوحيد له حق مباشرة كافة السلطات المخولة لجميع الشركاء، وبالتالي يحل الشريك الوحيد محل الجمعية العامة في اختصاصاتها وصلاحياتها، فضلاً عن سائر اختصاصات مجلس الإدارة.^(٣) وبناء على ذلك يكون لشركة الشخص الواحد مدير مفوض يتمثل بالشريك الوحيد فيها، أو مدير واحد أو أكثر من الغير، يتم تعيينه بقرار فردي من هذا الشريك، وتحدد اختصاصاته وصلاحياته في العقد التأسيسي أو بقرار لاحق، ويخضع هذا القرار المنفصل عن العقد التأسيسي في هذه الحالة لكافة طرق الشهر التي يخضع لها العقد نفسه، وذلك حرصاً على حماية الغير حسن النية ممن يتعامل مع الشركة، من تمسكها في مواجهته بعدم صحة تعيين المدير، للتخلص من التزاماتها أو التزام المدير قبله، وبالمقابل لحماية الشركة من تمسك الغير ببطالان تعيين المدير، للتخلص من جانبهم من التزاماتهم تجاه الشركة.^(٤)

وأما بشأن إنهاء عمل المدير أو عزله من إدارة الشركة، فتسري على شركة الشخص الواحد أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لشركة الشخص الواحد، فينتهي عمل المدير بانتهاء المدة أو الوفاة أو العزل أو العجز أو فقدان الأهلية أو الاستقالة.

سلطات المدير في شركة الشخص الواحد:

يختلف مدى السلطات الممنوحة لمدير شركة الشخص الواحد بحسب ما إذا كان هو مؤسس الشركة أو الشريك الوحيد فيها، أو في حالة كان المدير شخصاً من الغير:

١- مدير الشركة هو مالکها أو مؤسسها:

تكون صفة مدير شركة الشخص الواحد في هذه الحالة مزدوجة، حيث يجمع في آن واحد بين اختصاصات الجمعية العامة من جهة، والمدير المفوض من جهة أخرى، وبذلك فلا يكون هناك تقسيم بين السلطات في الشركة في تلك الحالة التي يكون فيها الشريك الوحيد هو مدير الشركة، بل يجمع بين يديه كافة السلطات.

وفي هذا الشأن تقضي المادة (١٢٩) مكرراً (٣) من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ بأن: "يقوم مؤسس شركة الشخص الواحد على جميع شئونها، وله على الأخص الآتي:

- ١- تعديل عقد تأسيس الشركة.
 - ٢- حل الشركة وتصفيته وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
 - ٣- دمج الشركة في شركة أخرى، أو معها، أو تحويلها إلى شركة من طبيعة أخرى.
 - ٤- زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بما لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 - ٥- تعيين مدير أو أكثر للشركة، وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم، واعتماد توقيعاتهم، ويمثل المدير أو من يحدده مؤسس الشركة من بينهم في حالة تعددهم، الشركة أمام القضاء والغير، ويكون المدير أو المديرون مسئولين عن إدارتها أمام المالك.
 - ٦- عزل مدير الشركة أو تقييد اختصاصاته.
- وفي جميع الأحوال، لا تكون الإجراءات المشار إليها نافذة في حق الغير إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

ويلتزم مؤسس شركة الشخص الواحد، في حالة تصرفه في كامل رأس المال إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر، باتخاذ إجراءات تعديل بيانات الشركة والسجل التجاري، وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التصرف وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي حالة التصرف في جزء من رأسمال الشركة إلى شخص أو أكثر، تلتزم الشركة باتخاذ إجراءات توفيق أوضاعها وفقاً للشكل القانوني الذي يختاره الشركاء لها خلال مدة لا تتجاوز

تسعين يوماً من تاريخ التصرف، وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميع الأحوال، لا يكون التصرف نافذاً في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري^(١).

٢- مدير الشركة شخص من الغير:

في الحالة التي يكون فيها مدير الشركة شخصاً آخر غير الشريك الوحيد، فإن تقسيم السلطات في الشركة يتم بين الشريك الوحيد بصفته قائماً مقام الجمعية العامة للشركة، وبين المدير المفوض الذي يخول من قبل الشريك الوحيد بممارسة كافة سلطات المدير اللازمة لإدارة الشركة.

ويتم تحديد سلطات المدير في عقد الشركة، فإذا سكت العقد عن ذلك، كان لمدير الشركة السلطات الكاملة لتسيير أعمال الشركة في حدود الغرض المحدد لها^(٢)، وتمثل هذه السلطات في القيام بالأعمال المتعلقة بالشركة باعتبارها شخصاً معنوياً، فهو يقوم بكل التصرفات والأعمال التي تسهل استغلال الشركة بما يتلاءم مع طبيعتها التي تتغير حسب تغير الظروف الاقتصادية، باعتباره الأقرب للتعرف على متطلبات الشركة، ولا تقتصر صلاحيات المدير على الاهتمام بالأموال الداخلية فحسب، وإنما يعد المدير هو الممثل القانوني الوحيد للشركة، ويتشابه دوره في هذا الشأن مع دور رئيس مجلس الإدارة في شركة المساهمة، ومن ثم فهو يقوم بكافة ما يلزم لإدارة الشركة والتعبير عن إرادتها أمام الغير، وهذا يستوجب التزام المدير بحدود الوكالة أو السلطة المخولة إليه^(٣).

وتقضي المادة (١٢٩) مكرراً (٦) من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ بأن: "يلتزم مدير شركة الشخص الواحد ببذل عناية الرجل الحريص في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز للمدير أن يتولى إدارة شركة أخرى أيّاً كان نوعها إذا كانت تعمل في النشاط ذاته الذي تزاوله الشركة أو أحد فروعها، كما لا يجوز له أن يتعاقد مع الشركة التي يتولى إدارتها لحسابه أو لحساب غيره، أو يمارس لحساب الغير نشاطاً من نوع النشاط الذي تزاوله الشركة".

مسئولية مدير شركة الشخص الواحد:

يسأل المدير - سواء كان هو الشريك الوحيد أو شخص آخر من الغير - في شركة الشخص الواحد، في مواجهة الشركة و في مواجهة الغير عن الأفعال التي يرتكبها، والتي تشكل للنصوص

القانونية المنظمة لشركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة، كذلك يسأل المدير عما يرتكبه من أخطاء في إدارة الشركة تشكل مخالفة لنظام الشركة.^(١)

الرقابة على أعمال الإدارة في شركة الشخص الواحد:

قدمنا أن الرقابة على إدارة الشركة، تتمثل في كافة الإجراءات والاشتراطات التي يفرضها القانون لغرض ضمان قيام الشركة بنشاطها وفقاً للقواعد القانونية والشروط العقدية، والأصل في فكرة الرقابة أنها من حق الشريك غير المدير في الإشراف على إدارة الشركة، وهو حق متعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته، وتكمن الحكمة من وراء ذلك في حماية الائتمان والمحافظة على استقرار المعاملات التجارية من التصرفات الخاطئة التي قد يأتي بها بعض المدراء، نظراً للسلطات الواسعة والمتعددة الممنوحة لهم.^(٢)

ولخصوصية هذه الشركة، كونها مملوكة لشريك واحد، فإن طبيعة الرقابة على أعمال مديرها تختلف بحسب ما إذا كان هذا المدير هو الشريك الواحد فيها أو كان أحداً من الغير، فإذا كان المدير هو الشريك الوحيد، فإنه يستطيع أن يدير شركته دون حاجة إلى الغير، وبالتالي فإنه يملك السلطات الإدارية والرقابية بصفة تلقائية، وستخضع تصرفاته في هذه الحالة لرقابة القانون، ومن ثم يمكن إبطال قراراته إذا كانت مخالفة لأحكام القانون، لذا تعد الالتزامات التي يفرضها القانون على الشريك الوحيد، نوعاً من الرقابة الخارجية على شركة الشخص الواحد، أما إذا اختار الشريك الوحيد التنحي عن الإدارة، وتعيين شخصاً من الغير للقيام بهذه المهمة، فيستطيع الشريك الوحيد في هذه الحالة أن يمارس مهمة الرقابة على أعمال المدير، ويمكن أن يطلق على هذا النوع من الرقابة، بالرقابة الداخلية.^(٣)

المطلب الثالث: مسؤولية الشريك الواحد

خلافاً لقاعدة المسؤولية المحدودة للشريك في شركة الشخص الواحد عن معاملات الشركة والتزاماتها، تقضي الفقرة (٤) من المادة (١٢٩ مكرراً) من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ بأنه: "استثناء من أحكام المادة (٤ مكرراً) من هذا القانون، يسأل مؤسس شركة الشخص الواحد عن جميع أمواله في الحالات الآتية:

١- إذا قام بسوء نية بتصفية الشركة أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو تحقيق الغرض من إنشائها.

٢- إذا لم يتم بالفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة.

٣- إذا أبرم عقوداً أو أجرى تصرفات باسم الشركة تحت التأسيس ولم تكن هذه العقود أو التصرفات لازمة لتأسيس الشركة.

ويراعى في هذا الشأن ما تقضي به المادة (١٢٩) مكرراً (٨) من القانون المذكور من أنه: "مع عدم الإخلال بحكم البند (٢) من المادة (١٢٩) مكرراً (٤) من هذا القانون، يجوز لمؤسس شركة الشخص الواحد التعاقد بشخصه مع هذه الشركة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بشرط ألا يمثل ذلك خلطاً بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة، وأن يكون التعاقد بالسعر العادل".

المطلب الرابع: انقضاء شركة الشخص الواحد

تنقضي شركة الشخص الواحد بذات الأسباب العامة التي تنقضي بها الشركات بصفة عامة، إضافة لذلك، تنقضي شركة الشخص الواحد ببعض الأسباب الخاصة بها.

فوفقاً للمادة (١٢٩) مكرراً (٩) من القانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨: "تحل شركة الشخص الواحد وتنقضي شخصيتها الاعتبارية في الحالات الآتية:

- ١- خسارة نصف رأسمال الشركة ما لم يقرر مالكيها الاستمرار في مزاوله نشاطها.
 - ٢- انقضاء الشخص الاعتباري مالك رأسمال الشركة.
 - ٣- الحجر على مالك الشركة أو فقدته لأهليته.
 - ٤- وفاة مالك الشركة، إلا إذا آلت الشركة إلى وارث واحد أو اختار الورثة استمرارها في ذات الشكل القانوني وقاموا بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
- وقد أجازت القوانين المقارنة للشريك الوحيد أن يقوم مقام المصفي وممارسة دور التصفية في الحالات التي لا تكون فيها التصفية بأمر قضائي، وتتحدد سلطات المصفي في سند تعيينه، سواء كان ذلك السند هو عقد الشركة التأسيسي أو حكم المحكمة، ويكون عليه في هذه الحالة أن يقوم بجميع الأعمال الضرورية لعملية التصفية بالمحافظة على أموال الشركة ومحاسبة المديرين، وعليه -كذلك- أن يتخذ جميع الإجراءات الاحتياطية التي تقتضيها مصلحة الشركة، وأن يلتزم بإعداد جرد بجميع ما للشركة من أصول، وما عليها من خصوم، ويعد ميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وتقريراً عن أعمال التصفية وفقاً لنصوص عقد الشركة.^(١)

تم بحمد الله تعالى وتوفيقه

د/ذكري عبدالرازق محمد خليفة

أستاذ القانون التجاري ورئيس قسم القانون الخاص

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

جامعة الأهر